

eBook
2020

Coleção Carreiras Jurídicas

DIREITO ADMINISTRATIVO

Autor:
Flávia Limmer



Organizado por CP Iuris

ISBN 978-85-5805-008-1

DIREITO ADMINISTRATIVO

1ª edição

Brasília

CP Iuris

2020

SOBRE A AUTORA

FLÁVIA LIMMER. Pós-Doutora (2017) e Doutora em Direito (2013) pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ . Possui graduação (2001) e mestrado (2004) em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Foi bolsista Nota 10 pela FAPERJ (bolsa prêmio por mérito acadêmico). É professora adjunta na PUC-Rio, lecionando nos cursos de graduação e especialização, e foi coordenadora adjunta do Instituto de Direito da mesma Instituição. Leciona ainda nos cursos de especialização da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro (EMERJ), no CEPED - UERJ, no IBMEC e na FGV. Foi pesquisadora da ANP (Agência Nacional do Petróleo) nas áreas de meio ambiente e regulação do petróleo. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Ambiental, Direito do Petróleo (regulação), Direito Constitucional e Direito Administrativo, atuando principalmente nos seguintes temas: princípios, teoria do risco, relações entre economia e meio ambiente, biocombustíveis, sustentabilidade e exploração e produção do petróleo e do gás.

Capítulo 1 – Noções Preliminares.....	28
1. O Estado e suas funções.....	28
1.1. Funções Essenciais à justiça.....	28
1.2. Função Administrativa.....	29
1.3. Administração Pública.....	29
2. Fontes do Direito Administrativo	30
3. Sistemas Administrativos	30
4. Reforma Administrativa.....	31
4.1. Contrato de Gestão	32
4.2. Agências Executivas.....	32
4.3. Agências Reguladoras.....	32
4.4. Terceiro Setor	33
4.5. Gestão Pública e Serviços Públicos.....	33
5. Tendências no Direito Administrativo Brasileiro	33
5.1. Supremacia do Interesse Público sobre o Privado.....	33
5.2. Princípio da Subsidiariedade.....	34
5.3. Formas Consensuais como Instrumento de Resolução de Problemas da Administração.....	34
5.4. Administração Dialógica	35
Questões	35
Comentários	36
Capítulo 2 – Regime Jurídico Administrativo	38
1. Conteúdo do Regime Jurídico-Administrativo	38

1.1. Princípios da Administração Pública.....	38
1.1.1. Supremacia do interesse público sobre privado:	39
1.1.2. Indisponibilidade do interesse público sobre privado.....	41
1.2. Princípios Constitucionais Expressos	41
1.2.1. Princípio da Legalidade	41
1.2.2. Princípio da Juridicidade	43
1.2.3. Princípio da Impessoalidade.....	43
1.2.4. Princípio da Moralidade.....	44
1.2.5. Princípio da Publicidade.....	45
1.2.6. Princípio da Eficiência	46
1.2.7. Outros princípios	47
a) Princípio da economicidade	47
b) Princípio da razoabilidade e proporcionalidade	47
c) Princípio da autotutela.....	49
d) Princípio da presunção de legitimidade.....	49
e) Princípio da segurança jurídica.....	49
f) Princípio da confiança legítima	50
g) Princípio da motivação	51
h) Princípios do informalismo e da simplificação	51
i) Princípio da igualdade	51
j) Princípio da finalidade pública	52
k) Princípio da ampla defesa e contraditório	52
l) Princípio da continuidade	54
m) Princípio da intranscendência e atos praticados pelas gestões anteriores	55

n) Princípio da responsividade	56
2. Jurisprudência	56
2.1. Súmulas do STF	56
2.2. Súmulas do STJ.....	56
2.3. Informativos do STF	57
2.4. Informativos do STJ	58
Questões	59
Comentários	61
Capítulo 3 – Organização da Administração Pública.....	64
1. Introdução.....	64
1.2. Órgãos públicos.....	65
1.2.1. Classificação dos órgãos.....	66
a) Quanto à posição estatal	66
b) Quanto à estrutura.....	66
c) Quanto à atuação funcional	66
1.3. Autarquias	66
1.3.1 Universidades.....	68
1.3.2 Autarquias corporativas.....	68
1.3.3. OAB.....	69
1.3.4. Agências reguladoras	70
1.3.5. Teoria do Risco da Captura.....	71
1.3.6. Deslegalização e Teoria Função Regulatória.....	72
1.4. Fundações públicas	72
1.4.1. Fundações públicas de direito público	73

1.4.2. Fundações públicas com personalidade jurídica de direito privado.....	73
1.4.3. Agências executivas	74
1.5. Empresas estatais.....	74
1.5.1. Criação e extinção.....	75
1.5.2. Controle e regime de pessoal	75
1.5.3. Falência e recuperação judicial.....	76
1.5.4. Empresas Públicas	76
1.5.5. Sociedades de Economia Mista	76
1.5.6. Regime jurídico aplicável às Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista	77
1.5.7. Regime híbrido aplicável às estatais	78
1.5.8. Lei das Empresas Estatais (Lei 13.303/16)	78
1.5.9. Subsidiárias	79
1.6. Consórcio público.....	80
1.6.1. Requisitos para consórcio público	81
1.6.2. Prerrogativas de um consórcio público	81
1.6.3. Contrato de programa	81
1.6.4. Contrato de rateio	81
1.7. Teses do STJ	82
1.7.1. Organização administrativa.....	82
1.7.2. Conselhos.....	83
1.8. Jurisprudência.....	84
1.8.1. Súmulas do STF.....	84
1.8.2. Súmulas do STJ	84
1.8.3. Informativos do STF	84

1.8.4. Informativos do STJ	86
Questões	86
Comentários	88
Capítulo 4 — Terceiro setor e entes de cooperação	90
1. Entidades de apoio	91
2. Certificado de utilidade pública federal (UPF)	92
3. Entidades com certificado de entidades beneficentes de assistência social (CEBAS)	92
4. Instituições Comunitárias de Educação Superior (ICES)	93
5. Serviços Sociais Autônomo (Sistema “S”)	93
Organização Social (OS)	94
7. Organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)	94
8. A Lei 13.019/14 e as parcerias com organizações da sociedade civil	96
9. Chamamento público	96
10. Diferenças entre OSCIP’s e OS’s	97
11. Quarto setor	97
12. Jurisprudência	98
12.1. Informativos do STJ	98
Questões	98
Comentários	99
Capítulo 5 — Atos administrativos	102
1. Introdução	102
2. Atos da administração e atos administrativos	102
3. Fases de constituição de um ato administrativo	103
3.1. Perfeição	103

3.2. Validade	103
3.3. Eficácia.	103
4. Formação dos atos administrativos	103
4.1. Simples	103
4.2. Compostos	104
4.3. Complexos	104
5. Classificação dos atos praticados pela Administração	105
6. Outras Classificações	105
7. Atos administrativos x fatos administrativos	105
8. Silêncio administrativo	105
9. Requisitos de validade ou elementos do ato administrativo.....	106
9.1. Elementos do ato por Celso Antônio Bandeira de Melo	106
9.2. Elementos tradicionais do ato administrativo	107
9.1.1. Competência (ou sujeito competente).....	107
9.1.2. Finalidade.....	107
9.1.3. Forma.....	108
9.1.4. Motivo	108
9.1.5. Objeto ou conteúdo.....	110
10. Mérito administrativo.....	110
11. Atributos do ato administrativo	111
11.1. Presunção de legitimidade.....	111
11.2. Presunção de veracidade	112
11.3. Imperatividade.....	112
11.4. Exigibilidade.....	112

11.5. Autoexecutoriedade.....	113
11.6. Coercitibilidade ou Coercibilidade.....	113
11.7. Tipicidade	113
12. Extinção dos atos administrativos	114
13. Classificação dos atos administrativos	114
14. Espécies de atos administrativos	117
14.1 Atos normativos.....	117
14.2. Atos ordinatórios	118
14.3. Atos negociais	119
14.4. Atos enunciativos	120
14.5. Atos punitivos	120
15. Extinção dos atos administrativos	120
15.1. Revogação	121
15.2. Anulação.....	121
15.3. Cassação	122
15.4. Caducidade	122
16. Jurisprudência	122
16.1. Súmulas do STJ.....	122
Questões	122
Comentários	123
Capítulo 6 — Poderes administrativos	125
1. Introdução.....	125
2. Abuso de poder	125
3. Poder discricionário e poder vinculado	125

4. Classificação dos poderes administrativos	126
4.1. Poder regulamentar (poder normativo)	126
4.2. Poder hierárquico	127
4.3. Poder disciplinar	128
4.4. Poder de polícia	128
4.4.1. Atributos do poder de polícia	131
4.4.2. Condições de validade ou limites do poder de polícia	132
4.4.3. Taxas de polícia	132
4.4.4. Competência	132
5. Teses do STJ	133
6. Jurisprudência	134
6.1. Súmulas STF	134
6.2. Súmulas STJ	134
6.3. Informativos do STF	134
6.4. Informativos do STJ	134
Questões	135
Comentários	136
Capítulo 7 — Agentes públicos	138
1. Introdução.....	138
2. Classificação dos agentes públicos.....	138
2.1. Agente político.....	138
2.2. Servidores públicos	139
2.2.1. Servidores estatutários	139
2.2.2. Empregados públicos	139

2.2.3. Servidores temporários.....	140
2.3. Militares	140
2.4. Particulares em colaboração com o Poder Público.....	140
3. Cargos, empregos e funções públicas	141
3.1. Cargo público	141
3.2. Emprego público	142
3.3. Função pública	142
3.3.1. Diferença entre cargo em comissão e função de confiança.....	142
4. Regime jurídico do servidor.....	142
5. Condições de ingresso.....	143
6. Direito subjetivo à nomeação.....	143
7. Controle dos concursos públicos	144
8. Reserva de Vagas.....	145
9. Provimento e vacância.....	145
9.1. Provimento	145
9.2. Vacância	146
10. Criação de cargos.....	147
11. Remuneração dos servidores	148
12. Perda do cargo do servidor estável.....	149
13. Responsabilidade dos servidores.....	150
13.1. Responsabilidade civil.....	150
13.2. Responsabilidade administrativa	151
13.3. Responsabilidade penal.....	151
14. Acumulação de cargos, empregos e funções públicas.....	151

15. Estabilidade, vitaliciedade e estágio probatório	152
15.1. Estabilidade	152
15.2. Vitaliciedade	153
15.3. Estágio probatório.....	153
16. Direito de greve	154
17. Teses do STJ: concurso público, servidores	155
17.1. Concurso Público.....	155
17.2. Servidores.....	158
17.3. Remuneração	159
18. Jurisprudência	161
18.1. Súmulas STF	161
18.2. Súmulas do STJ.....	162
18.3. Informativos STF	162
18.4. Informativos STJ.....	164
Questões	165
Comentários	166
Capítulo 8 — Licitações públicas	168
1. Conceito.....	168
2. Fundamentos constitucionais.....	168
3. Objeto.....	169
4. Finalidades da licitação	169
5. Destinatários das regras licitatórias.....	169
6. Princípios gerais da licitação	170
6.1. Legalidade	170

6.2. Impessoalidade	171
6.3. Moralidade	171
6.4. Igualdade	171
6.5. Publicidade	171
6.6. Probidade	171
6.7. Vinculação ao instrumento convocatório	171
6.8. Julgamento objetivo.....	171
6.9. Sigilo das propostas.....	171
6.10. Vinculação ao instrumento convocatório	172
6.11. Julgamento objetivo	172
7. Contratação direta.....	172
7.1. Dispensa de licitação	172
7.1.1. Licitação dispensada	172
7.1.2. Licitação dispensável	173
7.2. Inexigibilidade de licitação	176
8. Procedimento da licitação.....	177
8.1. Fase interna	177
8.1.1. Comissão de licitação.....	177
8.2. Fase externa	178
8.2.1. Publicação do instrumento convocatório.....	178
8.2.2. Habilitação	179
8.2.3. Classificação das propostas	180
8.2.4. Julgamento das propostas.....	180
8.2.5. Homologação e adjudicação.....	181

9. Modalidades de licitação	181
9.1. Concorrência.....	182
9.2. Tomada de preços.....	183
9.3. Convite	183
9.4. Concurso.....	183
9.5. Leilão.....	183
9.6. Pregão	184
9.7. Sistema de registro de preços (SRP)	185
10. Tipos de licitação	186
10.1. Menor preço	186
10.2. Melhor técnica	186
10.3. Melhor técnica e menor preço	186
10.4. Tipo maior lance ou oferta.....	186
11. Recursos	186
12. Anulação e revogação da licitação	187
13. Licitação e contratação de serviço de publicidade	187
13. Sistema de cotação eletrônica	188
14. Licitações para microempresas e empresas de pequeno porte	188
15. Regime Diferenciado de Contratações (RDC).....	189
15.1. Regras aplicáveis às licitações do RDC	190
15.1.1. Caráter sigiloso do orçamento.....	190
15.1.2. Inovações para aquisição	190
15.1.3. Regime de contratação integrada	190
15.1.4. Remuneração variável	191

15.1.5. Contratações simultâneas	191
15.2. Fases do RDC.....	191
15.3. Publicidade no RDC	191
15.4. Modos de disputa.....	192
15.5. Critérios de julgamento	192
15.6. Critérios de desempate.....	193
15.7. Recursos	193
15.8. Regras aplicáveis aos contratos do RDC.....	193
15.9. Sanções administrativas	194
16. Licitações na Lei nº 13.303/16	194
17. Teses do STJ.....	196
18. Jurisprudência	196
18.1. Informativos do STF.....	196
18.2. Informativos do STJ	197
Questões	199
Comentários	201
Capítulo 9 — Contratos administrativos.....	202
1. Conceito	202
2. Espécies	202
3. Princípios e Características.....	203
3.1. Formalismo.....	203
3.2. Bilateralidade.....	204
3.3. Comutatividade	204
3.4. Publicidade.....	204

3.5. Personalíssimo (<i>intuitu personae</i>).....	204
3.6. Mutabilidade/Instabilidade	204
3.7. Desequilíbrio.....	205
4. Vigência dos contratos.....	205
5. Prorrogação contratual	206
6. Alterações contratuais	206
6.1. Alterações bilaterais.....	206
6.2. Alterações unilaterais.....	207
7. Aditivo e apostila.....	207
8. Equação econômico-financeira do contrato	208
8.1. Correção monetária	208
8.2. Reajuste.....	208
8.3. Recomposição / revisão de preços	209
9. Teoria da Imprevisão	209
9.1. Fato do Príncipe	209
9.2. Fato da Administração	210
9.3. Caso Fortuito e Força Maior.....	210
9.4. Interferências Imprevisíveis.....	210
10. Execução do contrato.....	210
10.1. Fiscalização do contrato	210
11. Mediação e autocomposição de conflitos, no âmbito da administração pública.....	211
12. Inexecução e da rescisão dos contratos	212
12.1. Rescisão unilateral	213
12.2. Exceptio non adimpleti contractus em face da administração	213

13. Sanções administrativas.....	214
14. Sanções previstas na Lei do Pregão.....	214
15. Garantias.....	215
16. Ocupação Temporária ou Retomada do objeto contratual	215
17. Convênios.....	215
17.1. Convênio em sentido estrito	215
17.2. Termo de execução descentralizada.....	216
17.3. Contrato de repasse	216
18. Consórcios públicos	216
19. Jurisprudência	216
19.1. Informativos do STF.....	216
19.2. Informativos do STJ	217
Questões	218
Comentários	220
Capítulo 10 — Serviços públicos	222
1. Conceitos e elementos.....	222
2. Princípios	222
2.1. Princípio da generalidade	222
2.2. Princípio da continuidade	222
2.3. Princípio da modicidade das tarifas.....	223
2.4. Princípio da atualidade.....	224
2.5. Princípio da mutabilidade do regime	224
3. Classificação do serviço público.....	224
4. Remuneração	224

5. Prestação e execução dos serviços públicos.....	225
5.1. Delegação de serviço público.....	225
5.2. Concessão de serviço público.....	226
5.3. Permissão de serviço público.....	227
5.4. Autorização de serviço público	227
6. Serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens	227
7. Contratos de concessão comuns.....	228
8. Contratos de concessões especiais (Parceria Público-Privada)	230
9. Sociedades de Propósito Específico (SPE's).	232
10. Concessões patrocinadas	233
11. Procedimento de Manifestação de Interesses (PMI).....	233
12. Teses do STJ.....	234
13. Jurisprudência	234
13.1. Informativos do STF.....	234
13.2. Informativos do STJ	235
Questões.....	236
Comentários.....	238
Capítulo 11 — Responsabilidade Civil do Estado.....	239
1. Teorias	239
1.1. 1ª Teoria – Teoria da Irresponsabilidade Civil do Estado	239
1.2. 2ª Teoria – Teoria da Responsabilidade com Culpa	239
1.3. 3ª Teoria: Teoria da Culpa Administrativa (Culpa do Serviço ou Culpa Anônima)	239
1.4. 4ª Teoria: Teoria do Risco Administrativo	240
1.5. 5ª Teoria: Teoria do Risco Integral	241

2. Responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro	242
3. Responsabilidade dos notários.....	243
4. Requisitos para a demonstração da responsabilidade estatal.....	243
5. Causas excludentes e atenuantes da responsabilidade	243
6. Responsabilidade do Estado por danos decorrentes de sua omissão	243
7. Responsabilidade do Estado por atos legislativos	244
8. Responsabilidade do Estado por danos decorrentes de sua omissão legislativa	244
9. Responsabilidade do Estado por atos judiciais	245
10. A responsabilidade civil por danos decorrentes de obras públicas	245
11. Prescrição.....	245
12. Sujeito passivo da lide.....	246
13. Responsabilidade do Estado por danos causados por atos terroristas.....	246
14. Responsabilidade do Estado pela perda de uma chance	246
15. Erros médicos e SUS.....	246
16. Teses do STJ sobre responsabilidade civil do Estado.....	247
17. Jurisprudência	248
17.1. Súmulas do STJ.....	248
17.2. Informativos do STF.....	248
17.3. Informativos do STJ	250
Questões	251
Comentários.....	252
Capítulo 12 — Bens públicos.....	254
1 Introdução.....	254
2. Bens das empresas públicas e das sociedades de economia mista	254

3. Classificação dos Bens Públicos	254
4. Possibilidade do uso de bem público pelo particular	255
4.1. Instrumento estatais de outorga de títulos para que o uso de bens públicos seja utilizado pelo particular.....	255
4.1.1. Autorização de uso	255
4.1.2. Permissão de uso.....	255
4.1.3. Concessão de uso	255
4.1.4. Concessão de direito real de uso	256
4.2. Instrumento privados de outorga de títulos para uso exclusivo de bens públicos por particulares	256
4.2.1. Locação	256
4.2.2. Enfitese dos terrenos de Marinha.....	256
5. Bens públicos em espécie.....	257
5.1. Terras devolutas.....	257
5.2. Terrenos de Marinha	257
5.3. Terrenos reservados.....	257
5.4. Terras tradicionalmente ocupadas pelos índios	257
5.5. Plataforma continental.....	258
5.6. Rios	258
5.7. Faixa de fronteira	258
5.8. Ilhas.....	258
6. Teses do STJ	259
7. Jurisprudência	259
7.1. Súmulas do STF	259

7.2. Súmulas do STJ.....	259
7.3. Informativos do STF	260
7.4. Informativos do STJ	260
Questões	261
Comentários	262
Capítulo 13 — Intervenção do Estado no domínio econômico	264
1. Introdução.....	264
2. Princípios da ordem econômica.....	264
3. Atuação regulatória	265
3.1. Repressão do abuso do poder econômico	265
4. Intervenção direta do Estado no exercício da atividade econômica	265
5. Jurisprudência	266
5.1. Súmulas do STF	266
5.2. Informativos do STF	267
5.3. Informativos do STJ	267
Questões	267
Comentários	269
Capítulo 14 — Processo administrativo.....	271
1. Princípios	271
1.1. Motivação.....	272
1.2. Oficialidade.....	272
1.3. Princípio da gratuidade	273
1.4. Pluralidade de instâncias	273
1.5. Segurança jurídica	273

1.6. Imparcialidade	274
1.7. Formalismo Moderado	274
2. Competência	275
2.1. Delegação e avocação	275
2.2. Impedimento e suspeição.....	275
3. Peculiaridades do processo administrativo	275
3.1. Atos processuais	275
3.2. Pareceres e laudos técnicos	276
3.3. Tramitação prioritária	276
3.4. Recurso administrativo, coisa julgada administrativa e revisão.....	276
3.4.1. Recurso administrativo	276
3.4.2. Coisa julgada administrativa	277
3.4.3. Revisão.....	277
3.5. Preclusão	277
3.6. Processo administrativo e súmula vinculante	277
3.7. Processo administrativo disciplinar	277
3.7.1. Espécies de processo disciplinar	278
3.7.2. Penalidades disciplinares	279
3.7.3. Fases do processo disciplinar	279
4. Prescrição da ação disciplinar.....	280
5. Teses do STJ	280
6. Jurisprudência	285
6.1. Súmulas do STF	285
6.2. Súmulas do STJ.....	285

6.3. Informativos do STF	286
6.4. Informativos do STJ	286
Questões	288
Comentários	289
Capítulo 15 — Improbidade Administrativa	291
1. Introdução.....	291
2. Elementos do ato de improbidade.....	295
2.1. Sujeito passivo	295
2.2. Sujeito ativo.....	296
2.3. Ato de improbidade	296
2.3.1. Atos que levam ao enriquecimento ilícito (art. 9).....	296
2.3.2. Atos que causam prejuízos ao erário (art. 10)	297
2.3.3. Atos decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário (art. 10-A)	298
2.3.4. Atos que violam os princípios da administração pública (art. 11).....	299
2.3.5. Elemento subjetivo	300
3. Sanções possíveis	300
4. Gradação das sanções	301
5. Dos processos administrativos e judicial	302
6. Responsabilização objetiva de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração (Lei 12.846/13)	302
6.1. Atos lesivos à administração pública	303
6.2. Responsabilização administrativa	303
6.3. Responsabilização judicial	304

6.4. Acordo de leniência.....	304
6.5. Prescrição	305
6.6. Competência para julgamento	305
7. Teses do STJ	305
8. Jurisprudência	307
8.1. Súmulas do STJ.....	307
8.2. Informativos STF	307
8.3. Informativos STJ.....	308
Questões	309
Comentários	310
Capítulo 16 — Controle da administração pública	312
1. Introdução.....	312
2. Classificação do controle da administração.....	312
2.1. Conforme o momento a ser exercido o controle.....	312
2.2. Conforme a amplitude.....	312
2.3. Conforme a origem	312
3. Controle exercido pela própria Administração (recursos administrativos)	313
3.1. Espécies de recursos administrativos	313
3.1.1. Representação	313
3.1.2. Reclamação	313
3.1.3. Pedido de reconsideração	314
3.1.4. Recurso hierárquico próprio.....	314
3.1.5. Recurso hierárquico impróprio.....	314
3.1.6. Revisão.....	314

4. Controle legislativo	314
4.1. Controle político	314
4.2. Controle financeiro e orçamentário	315
4.3. Controle judicial	316
5. Jurisprudência	316
5.1. Informativos STJ	316
Questões	316
Comentários	317
Capítulo 17 — Intervenção do Estado na propriedade	319
1. Introdução	319
2. Limitação administrativa	319
3. Servidão administrativa	320
4. Ocupação temporária	321
5. Requisição administrativa	321
6. Tombamento	323
6.1. Espécies de tombamento	323
6.2. Efeitos do tombamento	324
6.3. Competência para o tombamento	324
6.4. Tombamento de Bens Públicos	324
7. Desapropriação	324
7.1. Base legal	325
7.2. Competência	326
7.3. Modalidades de desapropriação	326
7.3.1. Desapropriação sanção para reforma urbana	327

7.3.2. Desapropriação sanção para fins de reforma agrária.....	327
7.3.3. Desapropriação confisco	328
7.4. Desapropriação indireta e desapropriação por zona	328
7.4.1. Desapropriação indireta.....	328
7.4.2. Desapropriação por zona	329
7.5. Procedimento da desapropriação	329
7.5.1. Fase declaratória	330
7.5.2. Fase executória.....	330
8. Teses do STJ	332
8.1. Intervenção do Estado na Propriedade	332
8.2. Desapropriação.....	332
9. Jurisprudência	334
9.1. Súmulas do STF	334
9.2. Súmulas do STJ.....	335
9.3. Informativos do STF	335
9.4. Informativos do STJ.....	336
Questões.....	338
Comentários.....	339
Referências Bibliográficas.....	341

CAPÍTULO 1 – NOÇÕES PRELIMINARES

1. O ESTADO E SUAS FUNÇÕES

Tradicionalmente, o Estado é uma instituição organizada social, jurídica e politicamente, detentora de personalidade jurídica de direito público e de poder soberano. O Estado, por meio das instituições e do governo, tem como função gerir os interesses de um povo dentro de um território. O art. 1º da CRFB traz os fundamentos do Estado Democrático de Direito, a saber: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político.

No Brasil adota-se a forma federativa de Estado, prevista no art. 1º *caput* e art. 60, § 4º, I, ambos da CRFB/88. Ou seja, é a maneira como se dá a distribuição de Poder no espaço territorial. Neste modelo há uma dispersão do poder político. Os entes federativos (União, Estados, Municípios e Distrito Federal) são dotados de autonomia; sendo que a União, como poder central, é a única que detém a soberania.

Não se deve confundir soberania com autonomia. Como dito apenas a União, que representa o conjunto dos membros integrantes da federação, é dotada de soberania. Já os integrantes da federação são dotados de autonomia, possuindo independência para agir dentro dos limites e parâmetros impostos pela constituição, as chamadas competências constitucionais. Assim inexistente relação de subordinação ou de hierarquia entre os entes federativos: cada um atua dentro dos limites de suas competências, delineadas nos arts. 21, 22, 23, 24 e 30 da CRFB/1988.

Visando o atendimento da coletividade, o Estado deve desenvolver três funções. Trata-se da Separação de Poderes, proposta por Montesquieu¹ como forma de evitar abusos de poder e adotada pelo art. 2º CRFB/88. São elas:

- **Função legislativa:** exercida principalmente pelo Poder Legislativo, cuja atuação principal é de legislar e de fiscalizar (art. 44 e seguintes da CRFB);
- **Função executiva:** exercida principalmente pelo Poder Executivo, cuja atuação principal é de administrar (art. 76 e seguintes da CRFB);
- **Função judicial ou jurisdicional:** exercida principalmente pelo Poder Judiciário, cuja atuação principal é de julgar e colaborar na autocomposição de conflitos (art. 92 e seguintes CRFB/88).

Os três Poderes exercem funções típicas e atípicas. As primeiras são aquelas que nomeiam o Poder, já que constituem sua atuação central. As funções atípicas são aquelas em que um Poder exerce a função que, preponderantemente, é atribuída a outro Poder. Por exemplo, em situações previstas pela Constituição o Poder Executivo poderá legislar, tal como acontece nas medidas provisórias previstas no art. 64 CRFB.

Disto conclui-se que todos os quatro entes federativos possuem Poderes Legislativos e Executivos próprios; já a União, os Estados-membros e o Distrito Federal também possuem Poder Judiciário.

1.1. FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA

a Constituição traz ainda as funções essenciais à justiça, sendo essas:

- o Ministério Público (art. 127 e seguintes da CRFB/88);
- a Advocacia Pública (art. 131 e 132 da CRFB/88);
- a Advocacia (art. 133 da CRFB/88);
- a Defensoria Pública (art. 134 e 135 da CRFB/88).

¹MONTESQUIEU. *O Espírito das Leis* 9ª ed. São Paulo: Martin Claret, 2010.



1.2. FUNÇÃO ADMINISTRATIVA

Como visto acima a função administrativa é tipicamente exercida pelo Poder Executivo. Entretanto, existem casos em que os Poderes Legislativo e Judiciário, atipicamente, também a exercem (quando realizam concurso público, quando licitam para a compra de bens e aquisições de serviços, quando organizam folha de pagamento e licenças de servidores, dentre outros). Assim, é possível identificar a função administrativa pelo seu caráter residual. Quando não se trata de atividade legislativa ou jurisdicional, será administrativa.

A doutrina identifica a função administrativa por meio de três critérios:

- **Critério subjetivo (orgânico):** observa-se o **sujeito** que exerce a ação, ou seja, o órgão.
- **Critério objetivo-material:** observa-se o **conteúdo** da matéria tratada. Ou seja, pela atividade exercida – poder de polícia, intervenção na ordem econômica ou na propriedade privada.
- **Critério objetivo-formal:** observa-se a **forma** do regime que disciplina o assunto ou atividade (se regime de direito público ou de direito privado).

A função administrativa do Estado compreende diversas atividades, tais como:

- **Serviço público:** atividade ou serviço prestado que visa proporcionar comodidade aos administrados.
- **Poder de polícia:** atividade que restringe o exercício das liberdades individuais em prol da coletividade.
- **Fomento:** atividade administrativa que estimula a iniciativa privada.
- **Intervenção:** atividade da administração no domínio econômico, seja direta (o Estado exerce atividade econômica) ou indiretamente (o Estado regulamenta o exercício ou fiscaliza a atividade econômica).

O Poder Executivo (seja ele federal, estadual, distrital ou municipal) atua através do Governo (fixação dos objetivos e políticas públicas) e pela Administração Pública (execução das atividades).

1.3. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

O conceito de “administração pública” gera divergências doutrinárias, uma vez que pode ser entendido como as tarefas e objetivos que compõe os objetivos estatais, ou como os agentes públicos e órgãos que executam tais atividades.

Em regra a administração pública pode ser entendida em dois sentidos:

- **Sentido objetivo:** refere-se a atividade de administrar, a execução das atividades pelo Poder Público. Quando usada nesse sentido escreve-se “administração pública” em letras minúsculas.
- **Sentido subjetivo:** quando refere-se à Administração Pública como sujeito. Ou seja, o conjunto de órgãos, pessoas e agentes que executam as atividades administrativas. Por isso, escreve-se “Administração Pública” com letras maiúsculas.

O direito administrativo vai envolver normas que disciplinam a administração pública nos seus dois sentidos, tanto do ponto de vista do sujeito que a exerce quanto da atividade.

São **critérios** para conceituação do direito administrativo:

- **Critério do Poder Executivo:** o objeto do direito administrativo estaria relacionado à atuação exclusiva do Poder Executivo. Esse critério é incompleto.
- **Critério do serviço público (León Duguit):** o objeto do direito administrativo é a disciplina do serviço público. Este critério é insuficiente.
- **Critério das relações jurídicas (Laferrière):** o direito administrativo seria o conjunto de regras que disciplina as relações entre a administração e os administrados. Esse critério despreza as relações internas da administração, sendo incompleto.



- **Critério teleológico (finalístico):** o direito administrativo é um conjunto de normas que vai disciplinar a forma de atuação do poder público para alcançar a sua finalidade e para consecução de seus fins.
- **Critério negativo ou residual (Tito Prates da Fonseca):** tudo que não é dos demais ramos do direito é direito administrativo. Seria definido por exclusão. Não é adotado.
- **Critério da administração pública (Hely Lopes Meirelles):** o direito administrativo é o ramo do direito que envolve normas jurídicas que disciplinam a administração pública no sentido de exercício da sua função administrativa. **É o adotado.**

Atente-se que existe ainda o conceito de Administração Pública extroversa e Administração Pública introversa:

- **Administração Pública extroversa:** relação que existe entre a Administração e os administrados.
- **Administração Pública introversa:** relação entre os próprios entes públicos.

Percebe-se que a Administração Pública introversa é instrumental, visto que serve como um meio para se alcançar efetividade para se alcançar a Administração Pública extroversa. Isso porque, em verdade, o Estado serve para alcançar a finalidade em prol do povo.

2. FONTES DO DIREITO ADMINISTRATIVO

São fontes do Direito Administrativo:

- Princípios e regras;
- Leis;
- Atos normativos infralegais;
- Doutrina;
- Jurisprudência;
- Costumes;
- Precedentes administrativos.

Os precedentes administrativos são fontes do Direito Administrativo. O precedente pressupõe uma reiteração de atos administrativo em situações similares, ficando a Administração vinculada a esses entendimentos quando analisar uma relação jurídica distinta, mas que seja com a mesma razão ou fundamento. Se a Administração vem constantemente atuando dessa forma, por uma questão de segurança jurídica, pressupõe-se que em uma situação similar ela atuará do mesmo jeito. Este é o disposto pelo art. 30 da Lei nº 13.655/2018:

Art. 30 As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas.
Parágrafo único. Os instrumentos previstos no **caput** deste artigo terão caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se destinam, até ulterior revisão.

Apenas em duas situações a administração pode se afastar de um precedente administrativo:

- Se o ato invocado como precedente for um ato ilegal;
- Quando a administração se convencer de que o interesse público justifica a alteração do seu entendimento prévio (*overruling*).

3. SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

O sistema administrativo tem como destaque:

- **Sistema do contencioso administrativo (sistema francês):** em regra, os atos da administração se sujeitarão à jurisdição do contencioso administrativo. É formado por um órgão específico da Administração Pública com competência para julgar os atos administrativos. Não é necessário bater às portas do Poder Judiciário para rever um ato da Administração.
- **Sistema judiciário (sistema inglês ou jurisdição una):** é possível um controle de todos os atos da Administração pelo Poder Judiciário. É o sistema adotado no Brasil, apesar de algumas mitigações da Justiça Desportiva, ou no caso de habeas data, exigindo o prévio requerimento administrativo, ou mesmo no caso de reclamação no âmbito administrativo.

4. REFORMA ADMINISTRATIVA

Principalmente após a era Vargas o Brasil adotou um modelo de estado intervencionista na economia e extremamente burocrático. Em 1990, com a onda neoliberal, o país iniciou sua reforma administrativa, se aproximando de um modelo gerencial, similar ao adotado pela iniciativa privada. Basicamente, há três formas de Administração Pública:

- **Administração Pública patrimonialista:** o Estado se confunde com o príncipe (soberano). O Estado é uma extensão do poder do príncipe, sendo patrimônio desse;
- **Administração Pública burocrática:** surgiu como uma ideia de bloquear a corrupção. Visa profissionalizar os agentes, organizando-os em carreiras, havendo hierarquia funcional, controle formal, impessoalidade, etc. O problema é que o formalismo se tornou um fim em si mesmo, ficando evidenciada a incapacidade de se obter serviços públicos eficientes. A administração burocrática atua para si mesma, e não para o povo. O interesse público se confunde com o interesse do próprio Estado (interesse público secundário);
- **Administração pública gerencial:** mantém os ideais da administração burocrática (tais como de impessoalidade e profissionalização dos agentes), mas as adapta para um modelo próximo ao adotado pela iniciativa privada. Há uma definição precisa dos objetivos que a Administração deve atingir, pautado pela eficiência. Há uma maior autonomia, mas haverá controle posterior dos resultados. Prevê maior descentralização das atividades e redução dos níveis hierárquicos, aproximando-se da administração privada. A ênfase é nos resultados. O interesse público irá se confundir com o interesse da coletividade.

A reforma administrativa busca aproximar, no que for possível, a forma de gestão da Administração Pública da forma adotada pela iniciativa privada. Essa reforma ainda está em andamento.

Visa-se a simplificação. Por exemplo a Lei 13.726/18, que racionaliza atos e procedimentos administrativos dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, foi apelidada de Lei de Desburocratização.

Em relação ao servidor público, a reforma administrativa trouxe alterações, fixando possibilidade de avaliação de desempenho destes, bem como a perda do cargo por excesso de despesa e violação das diretrizes de responsabilidade fiscal.

Há também uma preocupação com o aumento da participação do administrado na gestão pública. Para tal é necessário simplificar a transparência, os meios de participação etc.

Busca-se a “privatização do Direito Administrativo” ou “fuga para o direito privado”: uma maior contratualização da atividade administrativa, com paulatina diminuição do tamanho do Estado através da delegação de serviços públicos para particulares.

Na mesma linha a Administração deverá ser Consensual: deve-se construir um acordo de vontades entre o Estado e a sociedade com vistas a legitimação atividade administrativa em prol do interesse público e para realização direitos fundamentais.

São dois os principais desdobramentos do consensualismo: um influi na formação da vontade administrativa que, passa a se operacionalizar (principalmente, e não exclusivamente) pelas consultas e audiências públicas (daí vem a expressão “Administração dialógica”). O outro, na releitura do princípio da indisponibilidade do interesse público, no sentido de que não existe uma única forma de atender ao



interesse público. O que se propõe é uma ponderação entre as diversas necessidades de uma sociedade cada vez mais plural, negando um caráter único e absoluto.

4.1. CONTRATO DE GESTÃO

A reforma administrativa também trouxe o contrato de gestão. Segundo Di Pietro, **o contrato de gestão é uma forma de ajuste:**

- **entre a administração pública direta e entidades da administração pública indireta, ou;**
- **entre a administração pública direta e entidades privadas que atuem paralelamente (organizações sociais).**

O contrato de gestão fixa parcerias com o Poder Público, e nele são discriminadas as metas a serem atingidas pelo contratado, bem como os benefícios que lhe serão conferidos. Quando celebrado entre órgãos da Administração ou entre o Poder Público e entidades da Administração Indireta o contrato de gestão basicamente amplia a autonomia gerencial, orçamentária e financeira do órgão ou entidade, dando uma maior margem de atuação.

As metas fixadas pelo Contrato de Gestão possibilitam um controle maior por parte da Administração, ao que se dá o nome de **administração gerencial**.

4.2. AGÊNCIAS EXECUTIVAS

A reforma estabeleceu a **possibilidade de o Poder Público qualificar como agência executiva uma autarquia ou uma fundação**, desde que cumpridos os requisitos legais, para então se alcançar uma maior eficiência no desempenho.

A qualificação poderá ser conferida por iniciativa do Ministério supervisor, sendo efetuada por ato específico do chefe do Poder Executivo. Após será firmado um contrato de gestão com o respectivo Ministério supervisor; e será criado um plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional. A qualificação e o plano estratégico visam **a redução de custo e aumento da eficiência** da autarquia ou fundação. O contrato de gestão terá duração mínima de um ano, podendo ser revisto a qualquer momento em caráter excepcional pelo Ministério Supervisor. O contrato poderá ser prorrogado, igualmente após a análise do Ministério Supervisor.

São exemplos de agências executivas o Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (Inmetro), a Agência Nacional do Desenvolvimento do Amazonas (ADA) e Agência Nacional do Desenvolvimento do Nordeste (ADENE).

4.3. AGÊNCIAS REGULADORAS

Com a adoção do modelo gerencial de Estado inúmeros serviços antes diretamente prestados pelo Poder Público foram transferidos para a iniciativa privada, através da delegação de serviços públicos. O fim dos monopólios estatais gerou a necessidade de criação de Agências Reguladoras no Brasil.

As Agências Reguladoras são autarquias de regime especial, criadas para regulação de atividades econômicas que antes eram praticadas pelo Estado e foram transferidas para o setor privado. Sua função é ditar normas que conduzirão os agentes envolvidos na prestação do serviço público delegado: o Poder Público, o particular que efetivamente prestará o serviço público e os usuários. A regulamentação significa, portanto, a intervenção estatal junto aos setores privados, onde serão impostas normas de conduta e a eficiência do serviço prestado. Assim as Agências Reguladoras podem exercer poder de polícia em determinado setor, regular e controlar as atividades que constituem objeto de concessão, permissão ou autorização de serviços públicos, além de exercer poder normativo. Trata-se de um exemplo de intervenção por atuação indireta do Estado no domínio econômico.



São exemplos a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis), a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) e a ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações).

As Agências Reguladoras serão melhor exploradas no item 3.3.4.

4.4. TERCEIRO SETOR

Entidades do Terceiro Setor são organizações que não têm fim lucrativo e não pertencem ao Estado, mas procuram atender interesses coletivos. A reforma administrativa gerou dois novos títulos para o Terceiro Setor:

- Organizações Sociais (OS);
- Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP).

Além disso, foi proposta a publicização de serviços não exclusivos ou uma descentralização de prestações que não envolvam o poder de Estado, que exige imperatividade do Estado.

O Terceiro Setor será explorado no item 4.

4.5. GESTÃO PÚBLICA E SERVIÇOS PÚBLICOS

No âmbito da reforma do Estado, concebeu-se a ideia de que podem ser identificados quatro setores dentro da Administração Pública:

- **Setor de núcleo estratégico:** é o governo em sentido lato, responsável pela definição de leis, políticas públicas e estratégias de atuação do Estado. Isso corresponde ao Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário, Ministério Público, mas não em relação à entidade, e sim aos agentes públicos, como o Presidente da República, ministros de Estado etc.;
- **Setor de atividades exclusivas:** são atividades que somente o Estado pode prestar, como a cobrança e fiscalização de impostos, emissão de passaporte, segurança pública etc.;
- **Setor de serviços não exclusivos:** são atividades em que o Estado atua com outras organizações, tanto com as chamadas públicas não estatais quanto com as organizações privadas;
- **Setor de produção de bens e serviços para o mercado:** o Estado atua como empresa, consolidando as chamadas empresas estatais. Diante dessa concepção em relação aos serviços públicos, existe um intento dos chamados reformistas de limitar essa atuação do Estado.

Atente-se que **o serviço público não estatal (Terceiro Setor) é constituído por organizações sem fins lucrativos**, os quais estão objetivando atingir interesse público e interesse da coletividade. Os reformistas afirmam que esse setor se encontra entre o Estado e o particular. Por isso, a expressão **publicização**.

5. TENDÊNCIAS NO DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO

As mudanças de paradigmas descritas anteriormente influenciam uma revisitação do defendido pela doutrina clássica, havendo uma mudança de conceitos e institutos dentro do Direito Administrativo.

Com base nessa alteração, inicia-se um diálogo sobre conceitos e institutos discutidos com base na administração pública gerencial.

5.1. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO

A supremacia do interesse público sobre o privado deixou de ser encarada como algo absoluto. A doutrina moderna diferencia entre:

- **Interesse público primário:** é o interesse da sociedade propriamente dito;
- **Interesse público secundário:** é o interesse do Estado, da máquina administrativa.



No caso de colisão entre interesse particular e o interesse público secundário, não haverá necessariamente a supremacia do interesse público sobre o privado, pois será necessário analisar o caso concreto. Pode ocorrer que a situação em apreço justifique que sejam respeitados os interesses do particular e não os interesses secundários do Estado, já que estes, por exemplo, podem não ter amparo jurídico. O Ministro Luís Roberto Barroso afirma que, **por vezes, o interesse privado do indivíduo deve prevalecer sobre o interesse público secundário.**

5.2. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE

Em relação ao princípio da subsidiariedade, é necessário observar que o Estado só irá atuar quando o particular não puder atuar ou atuar de forma insuficiente. Ele se subdivide em:

- **Subsidiariedade em sentido negativo:** é a estipulação de limites para a atuação estatal, naquilo que pode ser feito ao particular;
- **Subsidiariedade em sentido positivo:** é a imposição de um dever de intervenção, se for suficiente à atuação da iniciativa privada.

Di Pietro² afirma que o Estado só prestará as atividades que o particular não puder desenvolver, ou o Estado irá complementar apenas naquilo em que a atuação do particular se mostrar insuficiente.

5.3. FORMAS CONSENSUAIS COMO INSTRUMENTO DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DA ADMINISTRAÇÃO

É um dos temas mais debatidos atualmente: a adoção de soluções consensuais de resolução de conflitos. É a possibilidade da Administração Pública chegar a um acordo com o particular.

A resolução de litígios pelo Poder Público, no ambiente extrajudicial, é ação que se mostra necessária nos dias de hoje, sob pena de inefetividade tanto do setor administrativo quanto do Poder Judiciário.

Isso será percebido, por exemplo, quando a Advocacia Geral da União realiza a função de resolução de conflitos por meio da Câmara de Conciliação e Arbitragem. O objetivo é que se evite litígios entre órgãos e entidades da própria Administração federal.

Percebeu-se que essa atuação da Câmara é satisfatória e traz benefícios à União. O objetivo, neste momento, é solucionar controvérsias de natureza jurídica entre a Administração Pública e a administração dos Estados e Distrito Federal. Não mais será a Câmara de Conciliação e Arbitragem responsável por dirimir litígios entre órgãos e entidades da administração federal, mas também pela relação da União com os Estados e Distrito Federal.

A Lei nº 13.140/2015 passou a admitir que União, Estados, DF e Municípios criem câmaras de prevenção e de resolução administrativa de conflitos no âmbito de suas advocacias públicas.

O **consensualismo** é o princípio pelo qual a Administração Pública deve procurar a autocomposição para solucionar os conflitos nos quais é parte. Antigamente, se entendia que a Administração Pública não poderia realizar qualquer autocomposição, pois o interesse público seria indisponível.

Todavia, hoje se entende possível ao Poder Público realizar a autocomposição, visto que seria um método mais eficiente e econômico de resolução de seus conflitos, não somente economizando atos administrativos e/ou processuais, mas também gerando maior potencial de obtenção daquilo que a Administração pretende, seja o adimplemento de um contrato, o pagamento de um tributo ou de uma multa etc.

²DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo** 33ª ed. São Paulo: Gen Forense, 2020. Livro eletrônico não paginado.



De acordo com o art. 26, parágrafo 1º da LINDB, esse compromisso buscará solução jurídica proporcional, equânime, eficiente e compatível com os interesses gerais; não poderá conferir desoneração permanente de dever ou condicionamento de direito reconhecidos por orientação geral; e deverá prever com clareza as obrigações das partes, o prazo para seu cumprimento e as sanções aplicáveis em caso de descumprimento.

5.4. ADMINISTRAÇÃO DIALÓGICA

Como o próprio nome indica, a administração dialógica traz a ideia de estabelecimento de debate. É a abertura de um diálogo entre o Poder Público e os particulares, permitindo que estes colaborem com a agilidade das atividades administrativas.

Dessa forma, a atividade administrativa será aperfeiçoada e terá mais legitimidade, visto que se chegou a uma decisão após ouvir a sociedade.

A administração dialógica pode ocorrer quando a Administração Pública se presta a fazer **audiências públicas** para ouvir as pessoas da localidade quando irá promover grande empreendimento no local ou quando ouve a sociedade em relação ao **orçamento participativo**.

QUESTÕES

1. (TRF2) TRF2, 2018. A reforma administrativa, no âmbito da gestão do Estado brasileiro, busca tornar administração pública mais eficiente e voltada para a cidadania. Nesse sentido, é correto afirmar que:

- a) foram restringidas as modalidades de parceria do Poder Público a fim de permitir maior controle de gastos e, por conseguinte, maior eficiência.
- b) foram criadas fontes de receitas para o Estado, sob autorização do STF, tais como a taxa de iluminação pública e a taxa de limpeza e conservação urbana.
- c) foi retomada a ideia de uma Administração Pública rígida e voltada para o controle interno, em detrimento da Administração Pública gerencial, que se mostrou inábil no combate à corrupção e ao nepotismo.
- d) a Lei 13.334, de 13.09.2016 criou o Programa de parceiros de investimento, destinado ao fortalecimento da interação entre o Estado e a iniciativa privada, para a execução de empreendimento público de infraestrutura.
- e) o Estado retoma atividades que são próprias da iniciativa privada, ampliando sua atuação, a título de intervenção no domínio econômico, nos termos do art. 173 da Constituição Federal.

2. (TJPR) PUC-PR, 2014 Sobre o conceito do direito administrativo e a sua formação histórica no Brasil, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

I A primeira cadeira de direito administrativo no Brasil foi criada em 1851 e com a implantação da República acentuou-se a influência do Direito Público Norte-Americano, adotando-se todos os postulados do *rule of law* e do *judicial control*.

II O Brasil adotou, desde a instauração da primeira República, o sistema da jurisdição única, com exceção do período de vigência da Emenda Constitucional nº. 07/77, com a instalação dos dois contenciosos administrativos por ela estabelecidos.

III O direito administrativo tem como fontes a lei, a doutrina, os costumes e a jurisprudência, vigorando entre nós, desde o início da República, dado a influência sofrida do direito norte-americano, o princípio do *stare decisis*.

IV A interpretação do direito administrativo, além da utilização analógica das regras do direito privado que lhe foram aplicáveis, há de considerar, necessariamente, três pressupostos: 1º) a desigualdade jurídica entre a Administração e os administrados; 2º) a presunção de legitimidade dos atos da Administração; 3º) a necessidade de poderes discricionários para a Administração atender ao interesse público.



- a) Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
- b) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
- c) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- d) Apenas as assertivas I e IV estão corretas.

3. (MP-CE) FCC, 2014. Em sua formação, o Direito Administrativo brasileiro recebeu a influência da experiência doutrinária, legislativa e jurisprudencial de vários países, destacando-se especialmente a França, considerada como berço da disciplina. No rol de contribuições do Direito Administrativo francês à prática atual do Direito Administrativo no Brasil, NÃO é correto incluir:

- a) a adoção de teorias publicísticas em matéria de responsabilidade extracontratual das entidades estatais.
- b) a adoção do interesse público como eixo da atividade administrativa.
- c) ideia de exorbitância em relação ao direito comum, aplicável aos particulares.
- d) a teoria do desvio de poder.
- e) o sistema de contencioso administrativo.

4. (DPE-AM) Instituto Cidades, 2011. De acordo com a doutrina nacional, os órgãos e agentes públicos estão compreendidos no sentido de Administração Pública:

- a) subjetivo
- b) objetivo
- c) de atividade administrativa
- d) de atividade política
- e) de atividade política e administrativa

COMENTÁRIOS

1 – Gabarito D

- a) A Lei nº 11.079 de 2004 ampliou
- b) Súmula vinculante 41-STF: O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa.
- c) Segundo Di Pietro a reforma administrativa instaurou a “Administração Pública Gerencial, que envolve (...) substituição do controle formal pelo controle de resultados” (p.81).
- d) Correta
- e) Segundo Di Pietro o atual direito administrativo prevê a “aplicação do princípio da subsidiariedade: com as seguintes consequências (...) reconhecimento de que a iniciativa privada, seja através dos indivíduos, seja através das associações, tem primazia sobre a iniciativa estatal (...) o Estado deve abster-se de exercer atividades que o particular tem condições de exercer por sua própria iniciativa e com seus próprios recursos” (p.80).

2 – Gabarito D

I – Correta

II – Errado. Segundo Alexandre Mazza: “Sob a égide da Carta de 1967, a Emenda Constitucional n. 7, de 13 de abril de 1977, autorizou a criação de contenciosos administrativos federais e estaduais para decisão de questões fiscais, previdenciárias e de acidentes de trabalho, mas que nunca chegaram a existir” (p. 61).

III – A primeira parte da afirmativa está correta. Contudo tradicionalmente o Brasil adota o sistema da *civil law*. O princípio do *stare decisis* é proveniente da *common law*. Embora o atual Código de Processo Civil aponte uma inegável adoção do sistema de precedentes típico da *common law* não é correto afirmar que este sistema é adotado no Brasil desde o início da República.

IV – Correta.



3 – Gabarito E

Na questão o candidato deverão assinalar a alternativa errada. Sendo assim o gabarito analisará apenas o erro da alternativa E. O Brasil adota o sistema da jurisdição una e da inafastabilidade do controle do Poder Judiciário(art. 5º, XXXV, CF). O sistema do contencioso administrativo, adotado por exemplo na França, prevê a existência de um órgão paralelo ao Poder Judiciário com competência para julgamento de conflitos em que uma das partes seja o ente público, com a possibilidade de decisões definitivas. O sistema brasileiro recebeu influencia do norte americano, portanto a alternativa errada é a 'E'.

4 – Gabarito A

O sentido Formal ou Orgânico ou Subjetivo significa o conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas que tenham a incumbência de executar as atividades administrativas. Já o sentido Material ou Funcional ou Objetivo refere-se à atividade administrativa desenvolvida pelo Estado, por seus órgãos e agentes.



CAPÍTULO 2 – REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO

1. CONTEÚDO DO REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO

É interessante começar o estudo da matéria chamando atenção para duas pedras de toque do Direito Administrativo, a **supremacia do interesse público** e a **indisponibilidade do interesse público**. **Esses conceitos, que serão aprofundados em seguida, compõem um arcabouço do regime jurídico administrativo**, ou seja, o conjunto de regras e princípios que regem a atuação da Administração Pública.

O regime jurídico-administrativo é caracterizado pela incidência de normas específicas, de caráter administrativo, referindo-se a princípios e regras. Em relação aos princípios, Dirley da Cunha Jr³ traz a **teoria da tridimensionalidade funcional dos princípios**. Os princípios vão servir como:

- **Fundamentadores:** princípios como valores fundamentadores do sistema jurídico.
- **Orientadores:** princípios como orientadores da sua exata compreensão, tendo função interpretativa.
- **Supletivos:** princípios como supletivos das demais fontes do direito.

Portanto, os princípios terão as funções de fundamentar, orientar e suplementar.

1.1. PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Gustavo Binimbojm⁴ argumenta que o Direito Administrativo poderia ser dividido em duas fases: o chamado *giro democrático-constitucional* coloca os direitos fundamentais como foco das políticas públicas, transformando Administração Pública em uma Administração Pública cidadã. Paralelamente ocorre o *giro pragmático*, voltado para a eficiência e solução de problemas reais, se distanciando de uma atuação meramente burocrática. Em ambos os princípios são essenciais para nortear a atuação estatal.

Já Celso Antônio Bandeira de Mello⁵ sugere que o regime jurídico-administrativo é formado por princípios maiores ou magno, sendo que a partir daí todos os demais princípios se organizariam:

- **Supremacia do interesse público sobre privado:** há uma relação vertical, ou seja, uma preponderância do interesse da Administração sobre o interesse particular. Isso se percebe com as cláusulas extravagantes em contratos administrativos.
- **Indisponibilidade do interesse público:** o patrimônio pertence à coletividade, não podendo o administrador dispor destes. Cabe ao agente administrativo gerir esses bens e interesses em prol da coletividade.

A união destes dois princípios forma o Regime Jurídico-Administrativo, ou seja, o raciocínio base, que deve pautar toda a atuação da Administração Pública. Eles serão detalhados abaixo, mas cabe uma explicação inicial.

É certo que a Administração Pública não pode agir da mesma maneira que age um particular, pois está submetida a algumas limitações que decorrem da indisponibilidade do interesse público. Mas, ao mesmo tempo, também é contemplada com uma série de benefícios que decorrem da supremacia do interesse público.

Tratando-se de interesse público (algo que atinge toda a coletividade) a Administração Pública detém certas prerrogativas que visam a permitir o melhor exercício de suas atribuições, visando atingir a

³ CUNHA Jr, Dirley. **Curso de Direito Constitucional 13ª ed.** Salvador: Juspodivum, 2018.

⁴ BINENBOJM, Gustavo. **Poder de Polícia, Ordenação, Regulação:** transformações político-jurídicas, econômicas e

⁴ BINENBOJM, Gustavo. **Poder de Polícia, Ordenação, Regulação:** transformações político-jurídicas, econômicas e institucionais do Direito Administrativo Ordenador 2ª ed. Rio de Janeiro: Fórum, 2017.

⁵ MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Curso de Direito Administrativo 33ª ed.** São Paulo: Malheiros, 2019.



finalidade pública. Por outro lado, tratando-se de uma atividade pública e não de uma atividade particular, o Estado está submetido a uma série de restrições; por exemplo: a regra do concurso público. A Administração Pública não pode contratar quem bem entender, deve selecionar os candidatos tanto para que possa contratar, de fato, os melhores, como para evitar favoritismos.

É nesse sentido que o regime jurídico administrativo cria uma série de regras e sistemas que serão estudados ao longo de todo este livro. O regime jurídico administrativo é aquilo que une toda a matéria a ser estudada e que decorre da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público.

Por um lado, a supremacia implica prerrogativas, formas de o Estado atuar que sejam compatíveis com os bens jurídicos por ele tutelados, por outro lado, há limites, de modo que o poder estatal possa ser controlado e que não haja um desvio daquilo que é de todos, a fim de impedir favoritismos, contratações com interesses escusos e assim por diante.

O regime jurídico-administrativo vai permitir que existam prerrogativas em favor da Administração Pública, mas também a colocará em uma posição de sujeição às regras do regime jurídico-administrativo.

1.1.1. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE PRIVADO:

É um princípio implícito na CRFB, e decorre da interpretação extensiva de institutos como a desapropriação ou a requisição.

Renato Alessi⁶, baseando-se em Carnelutti, distingue o interesse público primário do interesse público secundário. O primeiro é o conjunto de interesses individuais preponderantes em uma coletividade. Está relacionado à satisfação das necessidades coletivas. Luís Roberto Barroso esclarece que “o interesse público primário é a razão de ser do Estado e sintetiza-se nos fins que cabe a ele promover: justiça, segurança e bem-estar social”⁷.

Já o interesse público secundário está inserido no primário. Trata-se do aparelhamento do Estado, ou seja, o interesse da própria Administração Pública, se traduzindo na manutenção das receitas públicas e a defesa dos bens públicos. Segundo Barroso são os interesses “da pessoa jurídica de direito público que seja parte em uma determinada relação jurídica – quer se trate da União, do Estado-membro, do Município ou das suas autarquias. Em ampla medida, pode ser identificado como o interesse do Erário, que é o de maximizar a arrecadação e minimizar as despesas”⁸.

Os interesses públicos primários são definidos pelo Legislador, especialmente o Constituinte. No conflito entre o interesse público primário e o secundário, o primário sempre irá prevalecer.

O interesse público possui caráter instrumental. A Administração Pública é o instrumento que o Governo possui para atingir o bem comum, sendo assim esta possuirá *privilégios* sobre o interesse particular. A representação material do interesse público garante uma posição privilegiada de supremacia do órgão administrativo em relação ao individual/privado, por exemplo na possibilidade de desapropriação, na imposição de cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos, prazos maiores em demanda judicial, possibilidade de modificação unilateral de seus atos e na intervenção no domínio econômico.

Deve-se destacar que se trata de um poder-dever: atos administrativos que não tenham finalidade pública são considerados desvio de finalidade.

De acordo com autores tradicionais, como Celso Antônio Bandeira de Mello⁹, Hely Lopes Meirelles¹⁰ e Maria Sylvia Di Pietro¹¹, a supremacia do interesse público sobre o particular consubstancia um princípio

⁶ Renato Alessi apud MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Op. cit., p. 114.

⁷ BARROSO, Luís Roberto. Prefácio: o estado contemporâneo, os direitos fundamentais e a redefinição da supremacia do interesse público. In: SARMENTO, Daniel (org.). **Interesses públicos versus interesses privados: desconstruindo o princípio de supremacia do interesse público**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. XIII.

⁸ Idem, ibidem.

⁹ MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Curso de Direito Administrativo** 33ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019, p. 53.

¹⁰ MEIRELLES, Hely Lopes Meirelles. **Direito Administrativo Brasileiro** 43a. edição. São Paulo: Malheiros, 2018.

¹¹ DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo** 33ª ed. São Paulo: Gen Forense, 2020. Livro eletrônico não paginado.



do ordenamento jurídico brasileiro, ainda que não esteja expressamente contemplado em nenhum texto normativo. Para eles, no conflito entre o interesse do administrado e o do Poder Público, este último sempre irá prevalecer, por que em tese representa o interesse da coletividade.

Já uma segunda corrente contesta a versão clássica da supremacia do interesse público sobre o privado: Humberto Ávila¹², Daniel Sarmento¹³, Gustavo Binimbojm¹⁴ e Alexandre Aragão¹⁵. Este último esclarece que em uma sociedade plural e complexa, não se pode destacar apenas um interesse público. Pelo contrário, vários coexistem, tal como saúde pública, acesso à educação, liberdade de expressão, geração de empregos, preservação ambiental, combate ao déficit público, melhoria e ampliação dos serviços públicos, entre outros.

Idosos colocarão como prioridade o acesso à saúde, pais de crianças pequenas apontarão o acesso universal à educação de qualidade como meta governamental principal. São múltiplos os interesses que coexistem na sociedade, todos igualmente relevantes e justificáveis. A escolha do que será priorizado pelo Governo no momento não pode ser pensada apenas sob o prisma de “maioria”, seja no sentido numérico ou sociológico, já que há o dever de respeito e atendimento às minorias.

O verdadeiro interesse público predominante deve ser absorvido através do disposto pela Constituição. Soma-se que a CRFB consagra tanto interesses da coletividade quanto direitos fundamentais individuais. Não há hierarquia entre eles no texto constitucional, logo esses devem ser sempre ponderados. Sendo assim, o termo *interesse público* deve ser interpretado como a máxima realização de todos os interesses, individuais e coletivos, protegidos juridicamente.

O debate sobre a existência ou não da supremacia do interesse público se materializa especialmente entre Celso Antônio Bandeira de Mello e Humberto Ávila.

Ávila afirma que, de acordo com a teoria formulada por Robert Alexy¹⁶, os princípios devem ser sempre sopesáveis. Logo não é possível se falar em supremacia. Ainda que esta exista não pode ser

¹² ÁVILA, Humberto. Repensando o “Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Particular.” In: **Revista Trimestral de Direito Público**, nº 24. São Paulo: Malheiros, 1998; e ÁVILA, Humberto. Repensando o “Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Particular.” In: SARMENTO, Daniel (org.), **Interesses públicos versus interesses privados: desconstruindo o princípio de supremacia do interesse público**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

¹³ SARMENTO, Daniel. Interesses Públicos vs. Interesses Privados na Perspectiva da Teoria e da Filosofia Constitucional. In: SARMENTO, Daniel (org.) **Interesses Públicos versus Interesses Privados: Desconstruindo o Princípio da Supremacia do Interesse Público**. 3ª tiragem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

¹⁴ BINEMBOJM, Gustavo. Da Supremacia do Interesse Público ao Dever de Proporcionalidade. Um Novo Paradigma para o Direito Administrativo. In: SARMENTO, Daniel (org.) **Interesses Públicos versus Interesses Privados: Desconstruindo o Princípio da Supremacia do Interesse Público**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. BINEMBOJM, Gustavo. *Uma Teoria do Direito Administrativo: Direitos fundamentais, democracia e constitucionalismo*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

¹⁵ ARAGÃO, Alexandre Santos de. A “supremacia do interesse público” no advento do estado de direito e na hermenêutica do direito público contemporâneo. In: SARMENTO, Daniel (org.) **Interesses públicos versus interesses privados: desconstruindo o princípio de supremacia do interesse público**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.

¹⁶ A teoria da ponderação de princípios é uma das grandes contribuições de Robert Alexy para o estudo dos direitos fundamentais. Segundo o autor dois princípios jurídicos podem incidir sobre o mesmo caso concreto, sem que um anule completamente o outro: prevalecerá na circunstância específica, mas segundo ainda será aplicável no caso, ainda que com peso menor. Por exemplo: P₁ (princípio 1) prevalece na circunstância C sobre P₂ (princípio 1). Logo (P₁CP₂). A linguagem matemática pode assustar em um primeiro momento. Mas o que a teoria proposta por Alexy explica é que em uma determinada circunstância C, por exemplo um caso de injúria na imprensa, o P₁, princípio constitucional será sopesável: imagine que o P₁ é o direito fundamental à privacidade; ele será ponderado com o P₂, princípio da liberdade de expressão, e eventualmente poderá prevalecer sobre esse. Em outras palavras, princípios não se anulam, mas o intérprete deve encontrar concordância prática entre eles, para que no caso concreto um prevaleça sobre o outro. Porém, nada impede que na concordância C₂, em outro cenário fático, o princípio P₂ venha a prevalecer sobre P₁, por exemplo, na divulgação de informações sobre uma figura pública. Cf. ALEXY, Robert. **Teoria de los Derechos Fundamentales**. Madri: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001, p.134.



considerada um princípio jurídico: princípios tem como característica principal serem ponderáveis, prevalecendo em algumas circunstâncias, mas podendo ser aplicados de forma diminuta em outras. Ávila defende que, seguindo a teoria de Alexy, a supremacia do interesse público sobre o privado não pode existir. Do contrário o lado público (através do princípio que representa o interesse público) sempre teria prioridade sobre qualquer outro ou não seria classificado como supremo. Portanto para Ávila não há que se falar em supremacia.

Por seu turno Celso Antônio Bandeira de Mello sustenta que jamais se afirmou que a supremacia do interesse público seria absoluta; e sim que o interesse público é muito relevante por ser interesse coletivo, conferindo à Administração Pública certas prerrogativas.

Sobre o tema deve se considerar que a supremacia do interesse público não está acima de direitos e garantias fundamentais, principalmente aqueles que são oponíveis por parte do indivíduo em face do Estado da sociedade.

A supremacia do interesse público é aceita amplamente pela doutrina clássica e, em uma prova objetiva, convém marcar a alternativa que a entenda como algo existente, ainda que não expressa na Constituição brasileira. Lembre-se: é a supremacia que fundamenta às prerrogativas da Administração, enquanto a indisponibilidade do interesse público baseia as limitações a que se submete o Poder Público, não possuindo este a mesma liberdade que um particular.

1.1.2. INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE PRIVADO

A Administração Pública jamais deve atuar visando suas predileções, e sim tendo como foco a efetivação dos interesses públicos primários. O patrimônio pertence à coletividade, não podendo o administrador dispor destes. Cabe ao agente administrativo gerir esses bens e interesses em prol da coletividade.

A indisponibilidade também é um princípio implícito na Constituição. Além da **desvinculação aos interesses pessoais do administrador público, aponta que o agente público não tem disponibilidade sobre estes interesses. A Administração Pública gerencia o patrimônio público pautada no ordenamento jurídico**, não podendo deixar de perseguir o bem comum (interesse público primário) ou conservar o patrimônio público (secundário). Por exemplo, a obrigatoriedade licitar e de realização de concursos públicos, o dever de justificar os subsídios e as anistias fiscais etc.

1.2. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS EXPRESSOS

São aqueles previstos no art. 37^{caput} da CRFB, que dispõe: *“a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência” (...).*

1.2.1. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

Apontado como central pela doutrina clássica do Direito Administrativo, o princípio da legalidade surge em oposição aos regimes absolutistas, comuns entre os séculos XVI a XVIII. Neste modelo, a atuação do Estado se confundia com a vontade do governante, e era marcada pela arbitrariedade. Existia o pensamento que não deveriam existir limitações jurídicas na atuação estatal, como resume a expressão *“the king can do no wrong”* (o rei não erra), tão comum na época.

No século XIX há o advento do conceito de Estado de Direito, em que o Estado passa a ser submetido a limites jurídicos. Nesta fase inicialmente o princípio é desenhado como legalidade como vinculação negativa à lei: o administrador público poderia agir livremente, desde que não houvesse uma vedação legal. Dava-se ao administrador o mesmo limite que era imposto aos particulares.



Uma nova leitura da legalidade passa a ser defendida por notórios doutrinadores, dentre eles Hans Kelsen. É o pensamento de Kelsen que influencia a noção clássica de princípio da legalidade administrativa, defendida por diversos autores do Direito Administrativo até hoje: **legalidade como vinculação positiva à lei**. O positivismo normativista de Kelsen gera a exigência que a Administração Pública tenha sua atuação pautada na vontade coletiva, materializada na Constituição e nas leis. A lei passa a ser o centro do ordenamento jurídico. Vigorava o mito da completude, em que a lei seria capaz de prever todas as situações possíveis.

No Brasil o princípio da legalidade é extraído do art. 5º, II da CRFB, o qual diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei.

Para uma prova de primeira fase, a lição que deve ser levada é que o princípio da legalidade exige que toda conduta da Administração Pública tenha base em lei. Esse conceito é basilar no Direito Administrativo: costumes não permitem que a Administração faça X ou Y, todo ato administrativo deve ter base jurídica na legislação.

Podemos apontar alguns exemplos de aplicação do princípio da legalidade:

- Não se pode exigir exame psicotécnico como etapa em um concurso público sem previsão de lei (STF, AI 677718 AgR);
- Não é possível impor limite de idade em concursos públicos se não for por lei (STF, RE 425760 RE).

Há algumas críticas a essa posição, que já foram cobradas em provas para o Ministério Público. Parte da doutrina defende que o princípio da legalidade é importantíssimo, mas que hoje não há, simplesmente, um dever de observância à legalidade, mas sim um dever de observância da juridicidade, ou seja, além do respeito à lei, é preciso que se respeitem as escolhas valorativas e axiológicas feitas pela Constituição. Este posicionamento será detalhado como um princípio próprio, abaixo.

No tocante ao administrador, a legalidade traz duas vertentes:

- **Vertente negativa:** a legalidade representa uma limitação à atuação do administrador, pois não pode fazer o que a lei não permite;
- **Vertente positiva:** a atuação do administrador depende de autorização legal, e havendo mandamento legal, o administrador deve cumpri-lo. Em outras palavras, se a lei permite algo, o administrador deve respeitá-lo.

O avanço da democracia e o avanço do positivismo tornaram insuficiente o raciocínio que defende que basta que a atuação administrativa seja legal. Percebe-se que há uma mutação da noção clássica da legalidade, fazendo com que **não baste que o ato seja legal, devendo ele também ser legítimo**.

Isto é, além de obedecer à lei, o ato deve obedecer à moralidade e atingir finalidade pública. Essa concepção de legitimidade confere maior grau de controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário. Isso porque, agora, o Poder Judiciário pode invalidar um ato administrativo quando ele não atinge finalidade pública ou quando ele viola princípios da Administração Pública, como o princípio da moralidade.

Percebe-se que **o avanço da legalidade vai permitir o conceito de legitimidade**, ampliando a vinculação negativa, pois a **Administração não pode praticar um ato ilegal, um ato contrário à moralidade ou um ato contrário à finalidade pública**.

Alexandre Mazza¹⁷ afirma que essa possibilidade de controle pelo Judiciário da legitimidade do ato praticado pela Administração Pública é denominada de **princípio da sindicabilidade**.

Raquel Melo Urbano de Carvalho¹⁸ diz que o princípio é denominado **princípio da constitucionalidade**, pois se permite o controle da atividade administrativa em razão das normas constitucionais estabelecidas, ou seja, por meio do princípio da moralidade ou do princípio da eficiência.

¹⁷ MAZZA, Alexandre. **Manual de Direito Administrativo** 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 123.

¹⁸ CARVALHO, Raquel Melo Urbano de. **Curso de direito administrativo**. Salvador: Juspodivm, 2008, p. 52.



Quando se começa a permitir um maior controle da Administração com base na constituição, Raquel Carvalho afirma que há incidência do princípio da constitucionalidade, enquanto Alexandre Mazza se refere a esse fenômeno como princípio da sindicabilidade.

Além dessa evolução do conceito de legalidade, que vai abranger também a legitimidade, há também a abrangência da juridicidade, que passaremos a abordar agora.

1.2.2. PRINCÍPIO DA JURIDICIDADE

Paulo Otero¹⁹ influenciou a doutrina brasileira ao defender o que a Administração Pública deve respeitar as escolhas valorativas e axiológicas feitas pela Constituição, o que nomeia como **princípio da juridicidade**. Em outras palavras, **a Administração fica vinculada ao ordenamento jurídico como um todo, e não apenas à lei**.

A **juridicidade** será apresentada como um conceito maior, que vincula a Administração Pública ao ordenamento jurídico como um todo, o que permite uma maior margem ao administrador, que ganha maior autonomia, pois poderá atuar dentro do ordenamento constitucional, e não apenas dentro da regra legal específica.

Para Gustavo Binembojm²⁰ a juridicidade é uma evolução do princípio da legalidade. O autor destaca que:

Com a constitucionalização do direito administrativo, **a lei deixa de ser o fundamento único e último da atividade administrativa**. A Constituição – entendida como sistema de regras e princípios – passa a constituir o cerne da vinculação administrativa à juridicidade. A legalidade, embora ainda muito importante, passa a constituir apenas um princípio do sistema de princípios e regras constitucionais. Passa-se, assim, a falar em um princípio da juridicidade administrativa para designar a **conformidade da atuação da Administração Pública ao direito como um todo, e não mais apenas à lei**.

Então, em uma prova de primeira fase, a resposta é: a Administração, diferentemente do particular, só pode fazer o que a lei lhe permite fazer. O particular pode fazer, em regra, tudo que a lei não lhe veda expressamente, já a Administração, o Estado e o agente público só podem agir se seu comportamento tiver base legal.

Para uma prova discursiva, é importante citar a visão de Paulo Otero de que essa obediência à legalidade não deve se restringir apenas à lei, mas a todo o ordenamento jurídico, inclusive à Constituição e aos valores previstos na Constituição e por ela consagrados, com a observação que a legalidade evoluiu e hoje consubstancia o princípio da juridicidade.

Lembre-se: o particular pode fazer tudo que não lhe é proibido.

É possível, enfim, perceber pelo menos **três fases do conceito de legalidade**:

- **Legalidade estrita:** a Administração somente irá atuar nos limites da lei;
- **Legitimidade:** a atuação administrativa deve ser legal, mas também conforme a moralidade e buscando finalidade pública;
- **Juridicidade:** na verdade, a atuação da Administração deve ser legal, legítima, mas também jurídica, visto que ela deverá atuar conforme o ordenamento jurídico e os limites estabelecidos na ordem jurídica.

¹⁹OTERO, Paulo. **Legalidade e Administração Pública**: o sentido da vinculação administrativa à juridicidade. Coimbra: Almedina, 2011.

²⁰BINENBOJM, Gustavo. **Uma Teoria do Direito Administrativo**: direitos fundamentais, democracia e constitucionalização. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 311-312.



1.2.3. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE

A Administração Pública deve adotar uma postura objetiva, sem favoritismo perante os cidadãos e os próprios agentes públicos, ou seja, a Administração tem o dever de tratar todos de forma equânime, isonômica, sem que pessoalize a relação que estabelece com o administrado e mesmo entre os seus agentes. A ideia é que todas as pessoas deram poderes ao Estado e, portanto, esse poder não pode ser desviado, de forma a favorecer interesses particulares.

O princípio da impessoalidade deve ser concebido em dois aspectos:

- **Buscar o interesse público:** não pode o agente público utilizar o seu cargo para promover um amigo ou beneficiar o seu parente. As decisões devem ter finalidade pública. O princípio do concurso público (art. 37, II, CRFB) é reflexo desse conceito, ou ainda o princípio do procedimento licitatório (art. 37, XXI, CF/88) e a vedação do nepotismo (STF, Súmula Vinculante nº 13);
- **Imputação do ato administrativo:** quem faz o ato não é o agente público pessoalmente, e sim o órgão ou entidade da Administração à qual o agente pertence.

Sobre a publicidade governamental é importante lembrar que esta deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social; e jamais deve trazer nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Por exemplo, a propaganda pode indicar que se trata de uma obra do Governo do Município de Recanto Feliz, mas será proibido colocar a foto ou o nome do prefeito ou do secretário de obras.

O princípio da impessoalidade implicará que a atuação se dê para o interesse público e para o fato de que será o Estado que atua, e não ao agente público.

1.2.4. PRINCÍPIO DA MORALIDADE

O princípio da moralidade é a exigência de que a atuação da administração Pública seja ética. Esse princípio, juntamente com o da impessoalidade visto acima, justificam a Súmula Vinculante nº 13 do STF que veda o nepotismo:

Súmula Vinculante 13. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.

Em relação à vedação do nepotismo, o STF entende que **a nomeação de um parente para cargo político não viola a súmula vinculante 13, ressalvados os casos de inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral** (STF, Rcl 34.413 AgR, DJE 220 de 10-10-2019 e Rcl 28.024 AgR, DJE 125 de 25-6-2018). Como se trata de um ato de natureza eminentemente política, os cargos apontados pela SV 13 são de livre nomeação e exoneração.

A SV 13 se refere até o parente em 3º grau (tio e sobrinho), portanto o primo (4º grau) não está sob a incidência da súmula (STF, Rcl 9.013).

Ainda segundo a Corte, **essa vedação ao nepotismo não pode alcançar os servidores admitidos mediante prévia aprovação em concurso público, ocupantes de cargo de provimento efetivo**, haja vista que isso poderia inibir o próprio provimento desses cargos, violando, dessa forma, o art. 37, I e II da CF/1988, que garante o livre acesso aos cargos, funções e empregos públicos aos aprovados em concurso público (Inf. 786, STF).



O STJ também se manifestou no mesmo sentido, estabelecendo que não há nepotismo na nomeação de servidor para ocupar o cargo de assessor de controle externo do Tribunal de Contas mesmo que seu tio (parente em linha colateral de 3º grau) já exerça o cargo de assessor-chefe de gabinete de determinado Conselheiro, especialmente pelo fato do cargo do referido tio não exercer qualquer poder legal de nomeação do sobrinho. **A incompatibilidade da prática enunciada na SV 13 com o art. 37 da CF/1988 não decorre diretamente da existência de relação de parentesco entre pessoa designada e agente político ou servidor público, mas da presunção de que a escolha para ocupar cargo de direção, chefia ou assessoramento tenha sido direcionada à pessoa com relação de parentesco com quem tenha potencial de interferir no processo de seleção** (Inf. 815, STF).

1.2.5. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE

Atualmente, a publicidade não significa simplesmente a publicação de um ato, devendo ser compreendida de uma forma mais ampla. É preciso que essa publicação seja clara e haja transparência, permitindo ao cidadão fiscalizar a atuação. Sua base está no próprio art. 5º CRFB, incisos XIV e XXXIII:

Art. 5º, XIV CRFB: é assegurado a todos o acesso a informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional.

Art. 5º, XXXIII CRFB: todos tem direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

A Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) diz que **qualquer interessado poderá pedir acesso à informação a um órgão ou entidade**(art. 10). É vedado à Administração impor quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público. Apresentando o requerimento (que deve conter a identificação do requerente e a informação que deseja), o acesso à informação compreenderá:

- O direito de obter uma informação contida em registro ou em documento que seja do órgão ou entidade;
- O direito à informação íntegra e atualizada;
- O direito a uma informação sobre uma atividade exercida pelo órgão ou entidade;
- O direito à informação do patrimônio público;
- O direito à informação ao resultado de uma inspeção ou auditoria, ou ainda de uma prestação de contas.

O órgão deve autorizar ou conceder o acesso imediato à informação(art. 11). Caso não possa fazê-lo de imediato, a Administração terá o **prazo de no máximo 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado justificadamente por 10 (dez) dias**, comunicando ao administrado o modo e o local de como será feita a consulta.

O **prazo de até 20 dias** também será para indicar as razões de direito pelas quais houve a recusa da informação. Se o órgão ou a entidade requerido não possuir a informação, e tiver ciência de qual a detém, deverá indicar qual é o órgão responsável no momento da resposta. Poderá ainda remeter o requerimento ao órgão ou a entidade para que seja informado ao administrado. Havendo o indeferimento da informação, o interessado **poderá recorrer no prazo de 10 dias** (art. 15).

O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de documentos pelo órgão ou entidade pública consultada, situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais utilizados (art. 12).



A lei vai dar acesso à informação, mas admitirá **hipóteses de restrição à informação**, tal como (art.23):

- Hipótese em que se mostre imprescindível o sigilo à segurança da sociedade ou do Estado;
- Hipótese em que o acesso irrestrito põe em risco a defesa e a soberania nacional;
- Hipótese em que o acesso colocar em risco a condução de negociações ou relações internacionais do Brasil;
- Hipótese em que o acesso colocar em risco a segurança, vida ou saúde da sociedade ou da população.
- Hipótese em que o acesso colocar em risco a estabilidade financeira, econômica ou monetário do país.
- Hipótese em que o acesso colocar em risco planos e operações estratégicas das forças armadas.
- Hipótese em que o acesso colocar em risco projeto de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico.
- Hipótese em que o acesso colocar em risco de instituições.
- Hipótese em que o acesso colocar em risco de altas autoridades.
- Hipótese em que o acesso colocar em risco atividade de inteligência ou investigação, relacionadas à prevenção e repressão de crimes.

Perceba que há restrição ao acesso. Essas informações que guardam sigilo são passíveis de classificação (art. 24):

- **Informação ultrassecreta:** a informação poderá ficar restrita à sua informação **por até 25 anos**.
- **Informação secreta:** a informação poderá ficar restrita à sua informação **por até 15 anos**.
- **Informação reservada:** a informação poderá ficar restrita à sua informação **por até 05 anos**.

Em suma, o princípio da publicidade impõe a ampla divulgação dos atos da Administração e as informações existentes em seus cadastros, exceto as sob necessário sigilo (tais como as que visam a segurança da sociedade) e as pessoais (ligadas à honra e intimidade dos particulares).

Está fundamentado nos princípios fundamentais da Constituição (art. 1º), especialmente o democrático e republicano, pois permite o exercício da cidadania ativa.

É a publicidade que garante controle dos atos administrativos, já que para controlar, necessário conhecer. Sendo assim é requisito para eficácia dos atos administrativos.

Na mesma linha possibilita a divulgação dos vencimentos brutos mensais dos servidores públicos, desde que não sejam divulgados o endereço residencial e o CPF (STF, ADI 2472). Entende o STF que estes dados já são de publicação obrigatória nos veículos oficiais de imprensa dos diversos entes federados. Não cabe, no caso, falar de intimidade ou de vida privada, pois os dados objeto da divulgação em causa dizem respeito aos indivíduos enquanto agentes públicos e sua atuação e remuneração como tais. **A prevalência do princípio da publicidade administrativa é um dos principais modos de concretizar a República enquanto forma de governo.** A negativa de prevalência do princípio da publicidade administrativa implicaria, no caso, inadmissível situação de grave lesão à ordem pública.(STF, ADI 2198).

O princípio da publicidade não impõe apenas a divulgação da decisão administrativa. Na máxima efetividade do princípio da publicidade, é preciso garantir transparência de toda a tramitação processual, visto que permitirá maior fiscalização do particular. O art. 11 da Lei 8.429/90 diz que **constitui ato de improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da administração pública, negar publicidade aos atos oficiais.**

1.2.6. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA

É outro princípio expresso na CRFB, trazido pela EC 19/98. Se traduz pela atuação competente, que alcança **bons resultados com o mínimo de desperdício**, evitando a morosidade, desperdício, baixa produtividade. É mais do que fazer melhor gastando menos, também significa **executar a atividade com**

presteza, perfeição e bom rendimento funcional. Diogo de Figueiredo Moreira Neto²¹ aponta que este princípio marcou a passagem de um modelo burocrático para uma Administração Pública Gerencial. A Administração Pública deve se aproximar, na medida do possível, do modelo de gestão da iniciativa privada. Assim o Estado deve se preocupar não só em cumprir as tarefas estabelecidas pela legislação, mas também em desempenhar tais atribuições com qualidade, perfeição e celeridade, visando a efetivação dos direitos fundamentais.

Já Celso Antônio Bandeira de Mello²² diz que o princípio da eficiência decorre de uma faceta do princípio italiano da boa administração: o agente público deve sempre buscar a melhor e mais adequada solução, tendo como parâmetro o interesse público e a legalidade. Por exemplo a CRFB estabelece que para adquirir estabilidade o servidor deve passar por avaliação de desempenho (art. 41 §4) e que mesmo após a estabilidade haverá avaliação de desempenho (art. 41 § 1 III).

O princípio exige justamente que as ações públicas não desperdicem recursos e consigam implementar suas finalidades de forma econômica, ótima, valendo a pena o custo benefício, não podendo a Administração gastar mal. Haverá controle dos gastos e da aplicação de recursos, segundo o art. 70 CRFB. Não se trata de uma mera norma programática: há auditorias operacionais do TCU que visam justamente verificar o controle da eficiência de acordo com parâmetros objetivos. Embora o gestor tenha hoje uma discricionariedade grande para estabelecer prioridades e gastos mais importantes no momento, em alguns casos específicos é possível verificar um total descompasso no que se refere à eficiência.

Ressalte-se que eficiência não se resume apenas à rentabilidade, custo benefício, mas também celeridade e rapidez, está intrinsecamente ligada a uma razoável duração do processo administrativo e há controle sobre esta matéria.

1.2.7. OUTROS PRINCÍPIOS

A) PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE

Intimamente ligado ao princípio da eficiência, a economicidade pode ser traduzida como o **princípio do custo-benefício**. Maria Sylvia Di Pietro indica que a economicidade, assim como a legitimidade, envolve uma “questão de mérito, para verificar se o órgão procedeu, na aplicação da despesa pública, de modo mais econômico, atendendo, por exemplo, a uma adequada relação custo-benefício”²³

Trata-se da **adequação entre receita e despesa**, o que permitirá que o não seja obrigado a fazer um maior sacrifício, suportando um peso maior de carga tributária para obter bens e serviços que estão disponíveis no mercado a menor preço.

B) PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

O STF aplica com frequência estes princípios, que podem ser resumidos como uma conduta coerente equilibrada, sem excessos e pautada na racionalidade.

Virgílio Afonso da Silva²⁴ esclarece que os princípios não possuem origem brasileira. A razoabilidade teria sua origem nos Estados Unidos, pela *common law*, por uma leitura do devido processo legal: deve ter caráter substantivo, vedando excessos e atuações arbitrárias do Estado, permitindo o controle de mérito

²¹MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. R. de Dir. Administrativo & Constitucional, ano 11, n. 45, jul./set. 2011. Belo Horizonte: Forum, 2011, p. 13-37.

²²MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Curso de Direito Administrativo** 33ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019, p. 50.

²³DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo** 33ª ed. São Paulo: Gen Forense, 2020. Livro eletrônico não paginado.

²⁴SILVA, Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável in *Revista dos Tribunais* nº 798. São Paulo: RT, 2002, p. 23-50.

sobre a atuação do legislador no que tange a defesa dos direitos fundamentais, e como critério de aferição de constitucionalidade das leis.

A proporcionalidade nasce na Alemanha, também permitindo que o Estado de Direito afaste a arbitrariedade. A Proporcionalidade desenvolve-se no âmbito do direito administrativo, para controle dos atos da Administração Pública. A doutrina alemã divide a proporcionalidade em subprincípios: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.

O razoável seria a ideia de que uma medida deve respeitar o bom senso, sendo adequada, racional, sem que haja especificação clara quanto a isso. Seria aferível apenas no caso concreto, ligada a ideia de bom senso ou boa medida. Já a proporcionalidade é mais específica, traz a ideia de que deve haver adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito ou sopesamento.

Embora os princípios, em tese, não sejam sinônimos ou fungíveis, o STF comumente os aplica juntos, principalmente para controle de atos discricionários. A razoabilidade vai impor uma tríplice exigência ao desempenho da atividade administrativa, devendo o ato administrativo ser dotado de características que jurisprudência da Corte denomina de filtros, subprincípios ou testes:

- Adequação ou idoneidade: ato deve ser apto para alcançar o fim pretendido;
- Necessidade ou exigibilidade: o ato deve ser o estritamente necessário para atingir o fim desejado, sempre se optando pela medida menos gravosa para o particular;
- Proporcionalidade: ponderação entre ônus imposto e benefício que será alcançado com o ato.

O ato administrativo deve ser aprovado nos três testes acima. Para saber se um ato administrativo é adequado é preciso em primeiro lugar saber se a medida restritiva que se quer implementar de alguma forma contribui para o objetivo a ser alcançado. É sempre uma relação entre o fim que se quer atingir e o meio que se utiliza. Imagine que a polícia queira limitar uma manifestação que poderá reunir grupos em conflito, que potencialmente podem se agredir fisicamente. A ideia aqui é preservar vidas e a integridade física. Diferentes meios, de alguma forma, são adequados a esta finalidade. Para que seja adequado, basta que em alguma medida aquele meio contribua para o objetivo. É possível simplesmente cancelar a passeata, o que de alguma forma contribui para a finalidade. Dificilmente uma medida não será adequada, mesmo as medidas mais drásticas, porque de alguma forma atingem o objetivo.

Na segunda fase, a da necessidade, é preciso verificar se existe um outro meio, igualmente efetivo, que irá atingir o objetivo com a mesma eficácia, mas menos gravoso para o direito fundamental e o interesse ali discutido. Seria possível por exemplo policiar o local, colocar muros entre as torcidas ou blocos de manifestantes etc. É comum imaginar que proibir a passeata não passa no crivo da necessidade, mas mesmo medidas extremas e drásticas podem atender à esse quesito, pois se essa necessidade se impõe dificilmente se encontrará medida igualmente eficaz para atingir o objetivo.

No teste final da proporcionalidade em sentido estrito ou do sopesamento, o juiz constitucional deverá colocar na balança os dois interesses em jogo. Deve-se perguntar: ante a eficácia da medida drástica, que é uma forma adequada de colocar em equilíbrio o bem jurídico liberdade de expressão/manifestação/reunião, como fica o bem jurídico da segurança pública os direitos das pessoas que moram na região? Essa terceira etapa permite verificar se a medida violará ou não direitos fundamentais.

A jurisprudência do STF apresenta outros casos de aplicação dos princípios. Por exemplo a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítima quando justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido (STF, ARE 678.112 RG); a exigência de altura mínima para o cargo de carreiras policiais é possível para o cargo de agente, mas não constitucional para a



habilitação ao cargo de escrivão, cuja natureza é estritamente escriturária (STF, RE 150.455), é possível apresentar apenas um documento com foto para votar, sem ter o título de eleitor em mãos não sendo razoável impedir o voto caso o cidadão não apresente os dois (STF, ADI 4467).

O princípio da proporcionalidade é essencial ao estado democrático de direito, pois **proíbe o excesso**, mas também **proíbe a proteção deficiente**.

C) PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA

Trata-se de um poder-dever. O princípio da autotutela permite que a Administração revise os seus atos tanto os ilegais, quanto os inconvenientes ou inoportunos: seja por meio de uma revogação (no caso de atos discricionários) ou por invalidação (no caso de atos ilegais).

O STF, na **Súmula 473**, diz que **a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial**.

D) PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE

Os atos administrativos se revestem de uma presunção de legitimidade, ou seja, é uma presunção relativa de que os atos foram praticados conforme o direito. A legitimidade se divide em:

- Presunção de verdade: se presume que das alegações da Administração Pública são verdadeiras;
- Presunção de legalidade: presunção de adequação dos atos às normas legais;
- Presunção relativa (*juris tantum*): gera a inversão do ônus da prova em desfavor do administrado.

Como consequência do princípio as decisões administrativas possuem execução imediata, podem criar obrigações para os particulares, mesmo que estes não concordem, e o Poder Público pode executar suas próprias decisões sem a necessidade de prévio processo judicial.

E) PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA

O princípio da segurança jurídica fundamenta-se na necessidade da atuação da Administração Pública ser previsível e estável, evitando incertezas e receios nos particulares. Está previsto no art. 2º, caput, da Lei 9.784/99. A prescrição e a decadência são exemplos de institutos decorrentes da segurança jurídica. Por outro lado a estabilidade difunde a consolidação das ações administrativas, criando novos mecanismos de defesa por parte do administrado, tais como o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, de uso mais constante no direito privado.

Segundo JJ Gomes Canotilho²⁵ e José Santos Carvalho Filho²⁶ o princípio da segurança jurídica pode ser visualizado sob dois prismas:

- **prisma objetivo:** o princípio da segurança jurídica implica **irretroatividade das normas**, ou seja, a proteção de atos perfeitamente realizados conforme a norma que vigia à época. Trata-se da inafastabilidade da estabilização jurídica (art. 5º, XXXVI CRFB)
- **prisma subjetivo:** o princípio da segurança jurídica implica **preservação das expectativas legítimas da sociedade**. É o princípio da proteção da confiança legítima, que será explorado abaixo.

²⁵ CANOTILHO, JJ Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição 7ª ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 257.

²⁶ CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de direito administrativo** 32ª ed. São Paulo: Atlas, 2018, p.34.



Nesse sentido, o art. 24 da LINDB estabelece que a revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. Ainda sobre o tema, leia o art. 30 da LINDB e o seu regulamento (o Decreto nº 9.830/19, especialmente o seu art. 19).

F) PRINCÍPIO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA

Decorrente da dimensão subjetiva da segurança jurídica, o princípio da proteção da confiança legítima busca proteger o sentimento do indivíduo em relação a atos do Estado dotados de presunção de legitimidade e com a aparência de legalidade. Aponta a necessidade de ponderação de interesses e modulação de decisões trazidas por alterações superveniente, na legislação ou no entendimento do Poder Público, que possam trazer instabilidade para a sociedade.

Tem-se apontado limites para atuação da Administração Pública na revisão de seus atos, visando o respeito ao princípio da segurança jurídica. Há confiança legítima do cidadão no Estado, que deve ser protegida, e restringe a autotutela mesmo em algumas hipóteses de ilegalidade. A confiança legítima tem efeitos:

- Negativos ou de abstenção: Estado fica impedido de anular seus atos;
- Positivos: a expectativa criada no cidadão pelo Estado deve ser atendida.

Há limites: a má-fé do particular impede a alegação de quebra da confiança; e se o caso for de mera expectativa (promessa em aberto, sem indício razoável que será cumprida). A promessa deve ser firme ou haver ato formal para gerar a exigência.

Um exemplo de aplicação dessa dimensão o art. 54 da Lei nº 9.784/1994 estipula que a Administração pode anular atos administrativos, mas ao mesmo tempo consagra o princípio da segurança jurídica ao estabelecer que **deve ser respeitado o prazo de 5 (cinco) anos para anular atos administrativos geradores de efeitos favoráveis para os destinatários, salvo se comprovada má-fé, contados da data em que praticados os referidos atos, ainda que anteriores à edição da lei.**

O art. 27 da Lei 9.868/99 e o art. 11 da Lei 9.882/99 permitem a modulação de efeitos em decisão acerca de controle de constitucionalidade, de modo a resguardar a confiança depositada pelo indivíduo na lei editada pelo Estado.

O art. 23 da LINDB prevê que a decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais.

No campo da jurisprudência o STF já julgou que a União deveria indenizar os prejuízos causados a empresários do setor sucroalcooleiro em virtude de sua intervenção no domínio econômico, fixando preços inferiores aos propostos por autarquia vinculada ao próprio governo (RE 422.941/DF). Por seu turno STJ decidiu que a União não tem de indenizar indústrias nacionais prejudicadas com a redução das alíquotas do imposto de importação, visto que não há direito subjetivo da indústria quanto à manutenção da alíquota do imposto de importação, não havendo quebra do princípio da confiança (REsp 1.492.832/DF).

Todavia, o STF, por meio do Informativo 833, decidiu que **a Administração Pública não pode, depois de terem se passado mais de 05 anos, anular a anistia política concedida mesmo que, antes de completar este prazo, a AGU tenha emitido nota questionando os critérios adotados na concessão.** A nota emitida pela AGU teve efeito similar ao de um parecer e, por isso, não impediu o fluxo do prazo decadencial, não podendo ser classificada como "exercício do direito de anular", para os fins do § 2º do art.

54 da Lei nº 9.784/99. Vale ressaltar que, no caso concreto, não ficou demonstrada má-fé do interessado. Além disso, não houve flagrante inconstitucionalidade na concessão de anistia, mas sim nova interpretação da Administração Pública quanto ao efetivo enquadramento como anistiado político.

Por outro lado, o Supremo entendeu que **o servidor que recebeu auxílio-moradia apresentando declaração falsa de que havia se mudado para outra cidade terá que ressarcir o erário e devolver os valores recebidos mesmo que já se tenha passado mais de 05 anos**, desde a data em que o pagamento foi autorizado. (Inf. 839, STF).

G) PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO

Impõe a necessidade de externalizar os motivos, ou seja, os fundamentos da decisão estatal. Ao explicitar o fundamento normativo e o raciocínio que levou ao ato ou a decisão, permite-se o exercício do controle interno, externo e pelo cidadão.

H) PRINCÍPIOS DO INFORMALISMO E DA SIMPLIFICAÇÃO

O princípio da simplificação e o princípio do informalismo ou formalidade moderada caminham juntos. Os atos administrativos devem ser realizados, veiculados e ter o seu teor da maneira mais simples possível, visando alcançar a eficiência administrativa.

Os atos administrativos devem gerar o mínimo de encargo sobre os interessados: a Administração deve procurar os procedimentos, documentos e atos que tenham de praticar ou enviar para as entidades competentes, bem como a necessidade de deslocações físicas.

I) PRINCÍPIO DA IGUALDADE

O princípio da igualdade baseia-se na máxima aristotélica, posteriormente explicada por Rui Barbosa: igualdade é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades - igualdade do ponto de vista material.

Como reflexo do princípio da igualdade, há a chamada **teoria da autovinculação administrativa**, reflexo da “autolimitação administrativa”, explicada por Paulo Otero²⁷ como as medidas adotadas pelo Poder Público que geram, a ele próprio, determinadas contenções.

A autovinculação administrativa significa uma limitação à prática dos atos administrativos, mesmo os discricionários, em razão de precedentes administrativos anteriores. **Os precedentes administrativos impedem o atuar contraditório pela Administração Pública, ainda que o ato seja discricionário.**

A fixação um entendimento pela Administração Pública, por respeito à boa-fé ou igualdade, a vinculará quando for analisar outra relação jurídica similar. Rafael Carvalho Rezende de Oliveira²⁸ esclarece que

o precedente administrativo pode ser conceituado como a norma jurídica retirada da decisão administrativa anterior, válida e de acordo com o interesse público, que, após decidir determinado caso concreto, deve ser observada em casos futuros e semelhantes pela Administração.

²⁷ Cf. OTERO, Paulo. **Legalidade e administração pública**: o sentido da vinculação administrativa à juridicidade. Coimbra: Almedina, 2003.

²⁸ OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende de Oliveira. **Precedentes no Direito Administrativo**. Forense. Rio de Janeiro, 2018, p. 95.



A Administração poderá alterar o seu entendimento (*overruling*), mas essa alteração deverá ser prospectiva (*prospect overruling*), além de não ensejar efeitos retroativos, sob pena de violação à segurança jurídica.

Nesse sentido o art.30 da LINDB esclarece que:

Art. 30. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas.
Parágrafo único. Os instrumentos previstos no caput deste artigo terão caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se destinam, até ulterior revisão.

Veja ainda o art. 2º, parágrafo único, XIII e o art. 50, VII, da Lei 9.784/99.

J) PRINCÍPIO DA FINALIDADE PÚBLICA

Com base neste princípio, a Administração deverá atuar, nas suas ações e prerrogativas, de acordo com uma finalidade: atender aos interesses da coletividade, especificamente explícito ou implícito na ordem jurídica.

O desvio dessa finalidade torna o ato ilegal, e poderá ser:

- **Desvio de finalidade genérico:** quando a ação administrativa não atende a qualquer interesse público. Por exemplo quando o prefeito desapropria imóvel de um desafeto, apenas por vingança.
- **Desvio de finalidade específico:** quando o Estado, embora tenha uma intenção de atender aos anseios públicos em sua atuação, se desvia do que determina a lei. Assim, caso um servidor cometa um erro passível de punição, mas ao invés de instaurar um Processo Administrativo Disciplinar seu superior simplesmente o remove para outra comarca, haverá desvio de finalidade.

K) PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO

Por força da Constituição deve ser observado o direito de ampla defesa e contraditório a todo cidadão também no processo administrativo.

A regra geral é que o contraditório seja prévio. Eventualmente, em casos de urgência, é possível que o contraditório seja diferido.

O contraditório deve ser protegido em seus dois aspectos, formal e material. No sentido formal, o contraditório significa a possibilidade de a pessoa ser ouvida, já o material significa que a manifestação do particular deve ser capaz de modificar o convencimento de quem irá decidir – em outras palavras a oitiva do administrado não pode ser um ato meramente *pro forma* em um processo em que a decisão final já esteja previamente formada. É absolutamente necessário que o contraditório seja substancial. Além de ser ouvido, em regra previamente, o administrado deve ter a possibilidade de influir no juízo de quem decidirá.

Sobre a questão deve ser observada a Súmula Vinculante nº 05 do STF:

“Súmula Vinculante 05: A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.”

A análise detalhada da Súmula Vinculante nº 05 do STF é importantíssima, uma vez que esta se contrapõe à súmula 343, do STJ (“é obrigatória a presença de advogado em todas as fases de processo administrativo disciplinar”). O STJ jamais alterou expressamente o seu entendimento, mas atualmente prevalece que a súmula 343 está revogada.



Portanto, em um processo administrativo, não necessariamente disciplinar, o administrado pode ser acompanhado por advogado apenas se assim desejar. Caso o acusado não tenha assistência jurídica esta circunstância não gerará a nulidade do processo administrativo.

Outro importante entendimento, também muito cobrado, está na Súmula Vinculante 21:

“Súmula Vinculante 21: É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.”

Certas leis, sobretudo em matéria tributária, condicionam a interposição de recurso administrativo a depósito prévio, uma vez que a sua interposição seria causa de suspensão do crédito tributário. O fisco desejava condicionar o exercício do direito do recurso a um depósito integral do valor da dívida. Entendeu o STF que tal ato é inconstitucional: caso, por ventura, ainda existam leis formalmente permitindo esta exigência, estas não podem ser aplicadas pelos entes federativos, não prevalecem ante a vedação da súmula vinculante.

Uma observação importante diz respeito **ao prazo para a Administração anular seus próprios atos**. É sabido que no artigo 54, da Lei do Processo Administrativo postula prazo decadencial para que a Administração possa anular seus atos:

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

Em virtude da segurança jurídica, essa possibilidade não é infinita. A Administração tem em regra 05 anos, salvo má-fé do beneficiado, para anular seus próprios atos – comprovada a má-fé de quem se beneficiou não existe prazo, pode-se anular a qualquer tempo. Mas atenção: leis específicas podem estipular prazos diferentes da regra geral de 05 anos.

O que fazer quando o ente federativo (estado-membro, município ou o Distrito Federal) não possua lei específica que preveja prazo decadencial para anulação? A Administração teria a eternidade para anular atos? O STJ proferiu uma decisão emblemática sobre o tema, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendendo que **deve ser aplicado o prazo decadencial de 05 anos da Lei Federal por analogia integrativa**, não obstante a autonomia legislativa dos entes para regular a matéria em seus territórios. (STJ, MS 18.338/DF).

Deve-se lembrar, porém, que o Supremo Tribunal Federal entendeu que **prazo decadencial do art. 54 da Lei nº 9.784/99 não se aplica quando o ato a ser anulado afronta diretamente a Constituição Federal**.

A situação de flagrante inconstitucionalidade não pode ser amparada em razão do decurso do tempo ou da existência de leis locais que, supostamente, agasalham a pretensão de perpetuação do ilícito. (...) A inconstitucionalidade *prima facie* evidente impede que se consolide o ato administrativo acoimado desse gravoso vício em função da decadência (MS 26860).

Observe ainda a Súmula Vinculante nº 03:

Súmula Vinculante 03: Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.



Esta Súmula Vinculante tem sido muito cobrada em concursos públicos. O STF entende que os atos concessivos de aposentadorias, reformas e pensões têm natureza *complexa* (MS 3.881). A análise do TCU é necessária para completar o ato administrativo de concessão, por força do art. 71 III CRFB e do art. 54 da Lei 9.784/1999. Em outras palavras, o ato do TCU é essencial, não meramente homologatório. Porém, esta apreciação dispensa um processo formal, com atendimento a todos os princípios constitucionais processuais, sendo na verdade um ato de verificação do valor dos proventos. O STF entendeu e sumulou que a análise do TCU dispensa o contraditório: como o ato é complexo a aposentadoria nunca foi de fato concedida, pois o ato só se completa após a decisão do TCU. A súmula causa estranheza inicial, justamente porque seria uma exceção ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo. Porém, isso ocorre porque o ato é complexo, ou seja, quando o cidadão apresentou o requerimento já deveria saber que a obtenção de sua aposentadoria só ocorreria com o ato do TCU.

Porém, como a concessão de aposentadorias, reformas e pensões são essenciais à manutenção e à subsistência dos indivíduos, geralmente o órgão competente inicia o pagamento antes da análise do TCU. Na prática o TCU só realiza o controle de legalidade após um longo período em que o benefício já está sendo pago. E, como já visto, o Direito Administrativo atual também apresenta como princípios a segurança jurídica e o respeito à confiança legítima.

Caso o entendimento fosse que a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão efetivamente se aperfeiçoasse com o ato de concessão inicial a Administração Pública teria cinco anos para, constatada alguma ilegalidade, anular o benefício, salvo comprovada má-fé. Para evitar isso é que o STF entende que o ato que concede a aposentadoria é ato complexo – a ideia é um ato que exige duas manifestações independentes de vontade, ou seja, enquanto o TCU não se manifesta a aposentadoria não começa efetivamente, já que o ato administrativo não se aperfeiçoa. Em outras palavras, a concessão inicial pelo órgão previdenciário e a análise do TCU são na verdade um único ato, de formação longa no tempo, que somente se completaria com o registro efetuado pelo TCU.

Logo duas consequências ocorrerão:

- **A decadência do direito da Administração anular a concessão do benefício não ocorrerá enquanto o TCU não efetuar o registro.** O prazo de cinco anos previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 só começará a fluir após o registro efetuado pelo TCU.
- **Não cabe cogitar contraditório e ampla defesa previamente à atuação do TCU**, a análise da corte de contas pode ocorrer sem que o particular apresente sua manifestação. Em 19/02/2020 o STF entendeu em repercussão geral que o TCU tem cinco anos, contados do recebimento do processo de aposentadoria, reforma ou pensão, para negar o registro do benefício, por motivo de ilegalidade. Passado esse prazo, fica extinto esse direito, ou seja, o benefício não mais poderá ser cancelado/anulado. Foi fixada a tese que “em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas” (RE 636.553/RS).

Por fim o STF já havia declarado que “não há direito adquirido a regime jurídico referente à composição dos vencimentos de servidor público, podendo, destarte, a Corte de Contas da União concluir pela ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria se a conclusão obtida, embora respeitando decisão judicial transitada em julgado, se fundamenta na alteração do substrato fático-jurídico em que proferido o *decisum* (tais como alteração do regime jurídico do vínculo ou reestruturação da carreira)” (MS 35.303 AgR, rel. min. Dias Toffoli, julgado em 05/02/2018).



L) PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE

Trata-se de um princípio implícito, ligado à prestação de serviços públicos, que não pode ser interrompida, sob pena de grave prejuízo à coletividade. Não se trata de prestar o serviço em horário integral, e sim de garantir a prestação de acordo com a necessidade da população.

Duas questões comumente cobradas em concursos derivam deste princípio. A primeira se refere **ao direito de greve do servidor público**. Nem sempre a greve será permitida. Categorias militares, inclusive o corpo de bombeiros e as polícias militares, são consideradas essenciais e portanto este direito é mitigado (art. 142, da CRFB).

Para os demais servidores o direito de greve é possível. O art. 37, inc. VII CRFB não possui eficácia plena, exigindo a edição de ato normativo que integre sua eficácia. Como a mesma não foi editada o STF consolidou, nos Mandados de Injunção 670, 708 e 712, o entendimento que deve ser aplicada, por analogia a Lei de Greve (Lei 7.783/89) que rege a paralisação dos celetistas à esfera pública.

Porém, essa aplicação deverá ser feita com adaptações. O STF entende que a greve deve ser ponderada com o princípio da continuidade do serviço público. Logo alguns pontos devem ser observados:

- A paralisação dos serviços (quaisquer que sejam) pode ser apenas parcial. A regularidade na prestação deve ser mantida, especialmente visando suprir as necessidades urgentes da população, sob pena de configurar abuso de direito.
- *A Administração Pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo.*
- *Contudo o desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público (STA 867 MC).*
- O movimento grevista deve cientificar a Administração com antecedência mínima de 72 horas da paralisação, mediante comunicação formal.
- Necessidade da paralisação deverá ser parcial, assegurando o funcionamento dos serviços essenciais em cota mínima.

A segunda se refere a **suspensão do serviço público por inadimplemento**. Por exemplo, há possibilidade do corte de fornecimento de água e luz em razão do não pagamento da conta? Apesar da divergência entre o art. 6º, § 3º, II Lei nº 8.987/95 e o art. 22 CDC, pacificou-se o entendimento de que havendo inadimplemento é possível o corte do fornecimento.

Porém, não se admite o corte de fornecimento de serviços essenciais, tais como escolas, hospitais ou presídios. Nesse caso há uma essencialidade do serviço público, que sobretudo é prestado à coletividade (STJ, REsp 285.262-MG). Deve-se ressaltar que em razão da pandemia de COVID19 alguns Tribunais de Justiça concederam decisões cautelares suspendendo a possibilidade de interrupção de fornecimento de serviços essenciais, inclusive de telefonia e internet, enquanto perdurasse o período de isolamento. Cabe acompanhar se o entendimento irá vigorar na Corte Superior.

A última se refere **ao inadimplemento por parte da administração pública, quando esta contrata particulares para a prestação de serviços ou fornecimento de bens, em razão da não aplicação da teoria da exceção de contrato não cumprido aos contratos administrativos**(Art. 39 Lei nº 8.987/95). Esta questão será explorada em item específico, mas brevemente adianta-se que não é possível invocar a exceção do contrato não cumprido se o inadimplemento não superar 90 dias. É importante lembrar que a supremacia do interesse público confere prerrogativas à Administração Pública, e uma delas é: se o Estado não paga o concessionário, este não pode de imediato interromper o serviço, devendo aguardar minimamente 90 dias.



M) PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA E ATOS PRATICADOS PELAS GESTÕES ANTERIORES

Segundo o entendimento do STF, o Estado só pode sofrer restrições nos cadastros de devedores da União por atos praticados pelo Poder Executivo. Dessa forma, atos do Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e dos entes da Administração Pública indireta (como as autarquias e as empresas públicas) não podem gerar sanções da União contra o Estado, diante da ausência de ingerência direta do Executivo sobre eles.

Na mesma linha o princípio da intranscendência subjetiva das sanções proíbe a aplicação de punições às administrações atuais por atos de gestão praticados por gestores anteriores. Para isso a gestão atual deverá tomar medidas para ressarcir o erário e corrigir as falhas após sua posse, por exemplo apresentando os documentos cabíveis ao órgão fiscalizador, ajuizando ações de ressarcimento contra o antigo gestor etc. Caso o faça o ente federativo não poderá ser incluído nos cadastros de inadimplentes da União (STFAC 2614/PE, AC 781/PI e AC 2946/PI, Info 791).

N) PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE

Segundo Alexandre Mazza²⁹ a Administração deve reagir adequadamente às demandas da sociedade principalmente no que concerne a responsabilidade fiscal, tanto evitando gastos e endividamentos desnecessários, mas principalmente em relação ao dever do administrador público de prestar contas.

Trata-se da **teoria da *accountability* (ou da responsividade)**, de origem norte-americana. Segundo ela **a função do administrador público inclui o dever subjetivo de prestar contas pela legitimidade das suas escolhas fiscais**. O princípio da responsividade prevê que o administrador público deve ser responsabilizado quando não observa a vontade do administrado, supostamente constante na lei, inclusive orçamentária.

2. JURISPRUDÊNCIA

2.1. SÚMULAS DO STF

Súmula vinculante 13: A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na Administração Pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.

Súmula 473: “A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Súmula 346: A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula 06: “A revogação ou anulação, pelo Poder Executivo, de aposentadoria, ou qualquer outro ato aprovado pelo Tribunal de Contas, não produz efeitos antes de aprovada por aquele tribunal, ressalvada a competência revisora do judiciário.”

²⁹MAZZA, Alexandre. **Manual de Direito Administrativo** 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 123.



2.2. SÚMULAS DO STJ

Súmula 615: “Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos.”

2.3. INFORMATIVOS DO STF³⁰

STF, Info 956. Plenário. RE 817338/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 16/10/2019. Repercussão geral – Tema 839

No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.

STF, Info 951. Plenário. ACO 2892 AgR/DF, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/9/2019

A Corte tem afastado a aplicação da SV 13 a cargos públicos de natureza política, como são os cargos de Secretário Estadual e Municipal. Mesmo em caso de cargos políticos, será possível considerar a nomeação indevida nas hipóteses de: nepotismo cruzado; fraude à lei e inequívoca falta de razoabilidade da indicação, por manifesta ausência de qualificação técnica ou por inidoneidade moral do nomeado.

STF, Info 952. 1ª Turma. Rcl 29033 AgR/RJ, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 17/9/2019.

O cadastro restritivo não deve ser feito de forma unilateral e sem acesso à ampla defesa e ao contraditório. Isso porque, muitas vezes, a inscrição pode ter, além de motivação meramente financeira, razões políticas. Assim, ao poder central (União) é possível suspender imediatamente o repasse de verbas ou a execução de convênios, mas o cadastro deve ser feito nos termos da lei, ou seja, mediante a verificação da veracidade das irregularidades apontadas. Isso porque o cadastro tem consequências, como a impossibilidade da repartição constitucional de verbas das receitas voluntárias. A tomada de contas especial, procedimento por meio do qual se alcança o reconhecimento definitivo das irregularidades, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa, tem suas regras definidas em lei. Ao final, é possível tornar o dano ao erário dívida líquida e certa, e a decisão tem eficácia de título executivo extrajudicial.

STF, Info 825. 1ª Turma. ACO 732/AP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 10/5/2016.

É necessária a observância da garantia do devido processo legal, em especial, do contraditório e da ampla defesa, relativamente à inscrição de entes públicos em cadastros federais de inadimplência. Assim, a União, antes de incluir Estados-membros ou Municípios nos cadastros federais de inadimplência (exs: CAUC, SIAF) deverá assegurar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

STF Info 815. 2ª Turma. Rcl 18564/SP, rel. orig. Min. Gilmar Mendes, red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 23/2/2016.

³⁰CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:<<https://www.Buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia>>.



Não há nepotismo na nomeação de servidor para ocupar o cargo de assessor de controle externo do Tribunal de Contas mesmo que seu tio (parente em linha colateral de 3º grau) já exerça o cargo de assessor-chefe de gabinete de determinado Conselheiro, especialmente pelo fato de que o cargo do referido tio não tem qualquer poder legal de nomeação do sobrinho. A incompatibilidade da prática enunciada na SV 13 com o art. 37 da CF/88 não decorre diretamente da existência de relação de parentesco entre pessoa designada e agente político ou servidor público, mas de presunção de que a escolha para ocupar cargo de direção, chefia ou assessoramento tenha sido direcionado à pessoa com relação de parentesco com quem tenha potencial de interferir no processo de seleção.

STF, Info 782. Plenário. ARE 652777/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 23/4/2015 (repercussão geral).

É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes de seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias.

STF, Info 732. 2ª Turma. RMS 31661/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 10/12/2013.

A Administração Pública pode anular seus próprios atos quando estes forem ilegais. No entanto, se a invalidação do ato administrativo repercute no campo de interesses individuais, faz-se necessária a instauração de procedimento administrativo que assegure o devido processo legal e a ampla defesa. Assim, a prerrogativa de a Administração Pública controlar seus próprios atos não dispensa a observância do contraditório e ampla defesa prévios em âmbito administrativo.

2.4. INFORMATIVOS DO STJ³¹

STJ Info 634. REsp 1412433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018 (recurso repetitivo).

Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

STJ, Info 598. 1ª Turma. REsp 1270339-SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 15/12/2016.

Em regra, o serviço público deverá ser prestado de forma contínua, ou seja, sem interrupções (princípio da continuidade do serviço público). Excepcionalmente, será possível a interrupção do serviço público nas seguintes hipóteses previstas no art. 6º, § 3º da Lei n.º 8.987/95: a) Em caso de emergência (mesmo sem aviso prévio); b) Por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, desde que o usuário seja previamente avisado; c) Por causa de inadimplemento do usuário, desde que ele seja

³¹CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:<<https://www.Buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia>>.



previamente avisado. Se a concessionária de energia elétrica divulga, por meio de aviso nas emissoras de rádio do Município, que haverá, daqui a alguns dias, a interrupção do fornecimento de energia elétrica por algumas horas em virtude de razões de ordem técnica, este aviso atende a exigência da Lei nº 8.987/95? SIM. A divulgação da suspensão no fornecimento de serviço de energia elétrica por meio de emissoras de rádio, dias antes da interrupção, satisfaz a exigência de aviso prévio, prevista no art. 6º, § 3º, da Lei nº 8.987/95.

STJ, Info 540. 1ª Turma. REsp 1.193.248-MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 24/4/2013.

Não configura improbidade administrativa a contratação, por agente político, de parentes e afins para cargos em comissão ocorrida em data anterior à lei ou ao ato administrativo do respectivo ente federado que a proibisse e à vigência da Súmula Vinculante 13 do STF.

STJ, Info 529. 1ª Turma. AgRg no RMS 40427-DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 3/9/2013.

O ato de remoção de servidor público por interesse da Administração Pública deve ser motivado. Caso não o seja, haverá nulidade. No entanto, é possível que o vício da ausência de motivação seja corrigido em momento posterior à edição dos atos administrativos impugnados. Assim, se a autoridade removeu o servidor sem motivação, mas ela, ao prestar as informações no mandado de segurança, trouxe aos autos os motivos que justificaram a remoção, o vício que existia foi corrigido. STJ. 1ª Turma. AgRg no RMS 40427-DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 3/9/2013 (Info 529) ato de remoção de servidor público por interesse da Administração Pública deve ser motivado. Caso não o seja, haverá nulidade. No entanto, é possível que o vício da ausência de motivação seja corrigido em momento posterior à edição dos atos administrativos impugnados. Assim, se a autoridade removeu o servidor sem motivação, mas ela, ao prestar as informações no mandado de segurança, trouxe aos autos os motivos que justificaram a remoção, o vício que existia foi corrigido.

STJ, Info REsp 730.800-DF, Rel. Min. Franciulli Netto, julgado em 6/9/2005.

Não pode a Administração, após a efetivação do contrato e a prestação dos serviços, reter o pagamento ao fundamento de que não comprovada a regularidade fiscal pela empresa contratada, porquanto isso fere os princípios da moralidade administrativa e da legalidade. No caso, cuidou-se do fornecimento de “quentinhas” e sequer foi exigida a certidão de regularidade fiscal (art. 29, III, da Lei n.8.666/1993) quando da habilitação dos concorrentes.

QUESTÕES

1. (MPE-BA) CEFET BA, 2018. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a prática do nepotismo nas nomeações para cargo em comissão, de confiança ou de função gratificada, é correto afirmar que

- A) vedação à prática do nepotismo abrange toda a administração pública, exceto as empresas estatais, em função do regime híbrido de pessoal a que estão submetidas.
- B) com fundamento na máxima proteção à moralidade administrativa, a Lei Estadual pode ampliar a vedação ao nepotismo para os cargos de provimento efetivo por concurso público.



C) desde que haja previsão expressa em Lei Estadual, é possível excepcionar as vedações à prática dos atos de nepotismo, já que a matéria não se encontra regulada em Lei Federal.

D) excepcionalmente, é possível a análise da configuração da prática vedada de nepotismo em hipóteses que atinjam ocupantes de cargos políticos, desde que, em análise concreta, além do parentesco, seja verificada troca de favores ou fraude à lei.

E) para a configuração da prática ilícita de nepotismo, nos cargos administrativos e políticos, basta a configuração da relação de parentesco entre a autoridade nomeante ou servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, e, de outro lado, o nomeado: cônjuge, companheiro, parente em linha reta ou colateral ou por afinidade até o terceiro grau.

2. (TJCE) CESP, 2018. Considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca dos princípios constitucionais e infraconstitucionais que regem a atividade administrativa, julgue os itens a seguir.

I Em obediência ao princípio da legalidade, a vedação à prática do nepotismo no âmbito da administração pública é condicionada à edição de lei formal.

II A publicidade é condição de eficácia dos atos administrativos, razão pela qual pode caracterizar prática de ato de improbidade administrativa a desobediência ao dever de publicação de atos oficiais.

III Viola o princípio da isonomia a previsão de critérios discriminatórios de idade em certame de concursos públicos, ressalvados os casos em que a natureza das atribuições do cargo justificar.

IV O princípio da proteção da confiança legítima não autoriza a manutenção em cargo público de servidor público empossado por força de decisão judicial de caráter provisório posteriormente revista, ainda que decorridos mais de cinco anos da investidura no cargo.

Estão certos apenas os itens

A) I e II.

B) I e III.

C) III e IV.

D) I, II e IV.

E) II, III e IV.

3. (PGE-PE). CESPE, 2018

Considerando a doutrina e o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores acerca do regime jurídico-administrativo e do princípio constitucional da legalidade na administração pública, assinale a opção correta.

A) O princípio da legalidade veda à administração a prática de atos inominados, embora estes sejam permitidos aos particulares.

B) Em virtude do princípio da reserva legal, a administração pública deve fazer o que está prescrito em lei e abster-se de atuar quando a lei proibir.

C) A utilização de prova emprestada nos processos administrativos disciplinares ofende o princípio da legalidade.

D) Apesar de estar submetida à legalidade estrita, a administração pública poderá interpretar normas de maneira extensiva ou restritiva com relação aos direitos dos particulares quando não existir conteúdo legal expresso.

E) Aplica-se a teoria do fato consumado no caso de remoção de servidor público para acompanhar cônjuge em virtude de decisão judicial liminar, ainda que a remoção não se ajuste à legalidade estrita.

4. (PGE-TO) FCC, 2018. Acerca das modernas correntes doutrinárias que buscam repensar o Direito Administrativo no Brasil, Carlos Ari Sundfeld observa:

Embora o livro de referência de Bandeira de Mello continue saindo em edições atualizadas, por volta da metade da década de 1990 começou a perder aos poucos a capacidade de representar as visões do meio – e de influir [...] Ao lado disso, teóricos mais jovens lançaram, com ampla aceitação, uma forte

contestação a um dos princípios científicos que, há muitos anos, o autor defendia como fundamental ao direito administrativo [...]. (Adaptado de: Direito administrativo para céticos, 2a ed., p. 53)

O princípio mencionado pelo autor e que esteve sob forte debate acadêmico nos últimos anos é o princípio da

- A) presunção de legitimidade dos atos administrativos.
- B) processualidade do direito administrativo.
- C) supremacia do interesse público.
- D) moralidade administrativa.
- E) eficiência.

5. (TRF-5) CEBRASPE/CESPE, 2018. Acerca dos princípios constitucionais e legais que regem a administração pública, assinale a opção correta.

- A) Situação hipotética: Lei de determinado estado da Federação estipula programa de incentivo fiscal exclusivamente para atletas nascidos no estado e que tenham a melhor classificação no campeonato estadual. Assertiva: Nessa situação, para o STF, a fixação de condições formais para a concessão de benefício fiscal exime a lei estadual de resguardar o tratamento isonômico no que se refere aos concidadãos.
- B) Conforme o STJ, o princípio da continuidade dos serviços públicos não impede a interrupção do fornecimento de energia elétrica destinada à iluminação pública de hospital municipal inadimplente.
- C) Situação hipotética: Uma autarquia federal constatou, a partir de denúncia, que servidor efetivo com dois anos de exercício no cargo havia apresentado documentação falsa para a investidura no cargo. Assertiva: Nessa situação, conforme o STF, os atos praticados pelo servidor até o momento são válidos, em razão dos princípios da proteção à confiança e da segurança jurídica.
- D) Não configura ofensa ao princípio da moralidade a nomeação de esposa de magistrado, devidamente concursada, para função de confiança diretamente subordinada ao juiz cônjuge.
- E) Todo ato administrativo emitido por agente público submete-se ao princípio da legalidade; quando o ato atende exclusivamente à legalidade, exclui-se do controle judicial o juízo de conveniência e oportunidade

6. (PGE-SE) CESPE, 2017. Considerando os princípios constitucionais e legais, implícitos e explícitos, que regem a atividade da administração pública, assinale a opção correta.

- A) Os princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público guiam a atuação do administrador, de modo que apenas o juízo discricionário excepciona-se ao controle judicial.
- B) Em decorrência do princípio da reserva legal, a administração pública está autorizada a fazer apenas aquilo que não seja legalmente proibido.
- C) De acordo com o STJ, o princípio da continuidade dos serviços públicos não impede a interrupção do fornecimento de energia elétrica para município inadimplente, ainda que o valor cobrado esteja sob questionamento em sede administrativa.
- D) Em virtude dos princípios da proteção à confiança e da segurança jurídica, entende o STF que podem ser considerados válidos os atos praticados por agente público ilegalmente investido.
- E) Por ser um princípio estruturante implícito da atuação da administração pública, na prática, a supremacia do interesse público é um conceito jurídico indeterminável.

COMENTÁRIOS

1 – Gabarito D

- a) Incorreta, conforme o próprio texto da Súmula Vinculante nº 13.
- b) Incorreta. Norma que impede nepotismo no serviço público não alcança servidores de provimento efetivo. Info 786 STF
- c) Incorreta. "É inconstitucional lei estadual que excepciona a vedação da prática do nepotismo, permitindo que sejam nomeados para cargos em comissão ou funções gratificadas de até dois parentes das

autoridades estaduais, além do cônjuge do Governador." STF. Plenário. ADI 3745/GO, rel. Min. Dias Toffoli, 15/5/2013 (Info 706).

d) Correta. STF. 1ª Turma. Rcl 29033 AgR/RJ, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 17/9/2019 (Info 952).

e) Incorreta. "Não há nepotismo na nomeação de servidor para ocupar o cargo de assessor de controle externo do Tribunal de Contas mesmo que seu tio (parente em linha colateral de 3º grau) já exerça o cargo de assessor-chefe de gabinete de determinado Conselheiro, especialmente pelo fato de que o cargo do referido tio não tem qualquer poder legal de nomeação do sobrinho. A incompatibilidade da prática enunciada na SV 13 com o art. 37 da CF/88 não decorre diretamente da existência de relação de parentesco entre pessoa designada e agente político ou servidor público, mas de presunção de que a escolha para ocupar cargo de direção, chefia ou assessoramento tenha sido direcionado à pessoa com relação de parentesco com quem tenha potencial de interferir no processo de seleção." STF. 2ª Turma. Rcl 18564/SP, rel. orig. Min. Gilmar Mendes, red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 23/2/2016 (Info 815).

2 – Gabarito E

I – Errada. Segundo o STF a vedação do nepotismo decorre diretamente dos princípios constitucionais, especialmente os da moralidade e da impessoalidade, não demandando edição de lei formal.

II – Correta. Ver art. 11, IV, da Lei 8.429/92.

III – Correta. Os critérios para cargos públicos devem obedecer os princípios da isonomia e da razoabilidade, só podendo ser estabelecidos em razão da natureza e atribuição do cargo. Cf. Súmula 683 STF: "o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido."

IV – Correta. Cf. STF, RE 608.482. A teoria do fato consumado não é compatível com o sistema de acesso a cargos públicos, quando o candidato tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, posteriormente cassado.

3 – Gabarito A

A) Correta

B) Errada. Na parte final da questão está descrito o princípio da legalidade quando aplicável a particulares. Soma-se que não se confunde o princípio da legalidade (em que a Administração Pública deve se pautar na norma jurídica em sentido amplo) com o da reserva legal (que postula que determinadas matérias devem ser regulamentadas por lei formal).

C) Errada. Cf. Súmula 591, STJ: é permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar; desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa.

D) Errada. A Administração Pública não pode realizar interpretação extensiva ou restritiva salvo quando a lei assim determinar. STJ RMS 26944/CE.

E) Errada. A teoria do fato consumado não pode ser aplicada para validar a remoção de servidor público destinada a acompanhamento de cônjuge. Cf. STJ, EREsp 1.157.628-RJ.

4 – Gabarito C

De acordo com autores tradicionais, como Celso Antônio Bandeira de Mello, Hely Lopes Meirelles e Maria Sylvia Di Pietro, a supremacia do interesse público sobre o particular consubstancia um princípio do ordenamento jurídico brasileiro, ainda que não esteja expressamente contemplado em nenhum texto normativo. Para eles, no conflito entre o interesse do administrado e o do Poder Público, este último sempre irá prevalecer, por que em tese representa o interesse da coletividade.

Já uma segunda corrente contesta a versão clássica da supremacia do interesse público sobre o privado: Humberto Ávila, Daniel Sarmento, Gustavo Binbenbajt e Alexandre Aragão. Sustentam que em uma sociedade plural e complexa, não se pode destacar apenas um interesse público. Pelo contrário, vários coexistem, tal como saúde pública, acesso à educação, liberdade de expressão, geração de empregos, preservação ambiental, combate ao déficit público, melhoria e ampliação dos serviços públicos, entre outros.

5 – Gabarito C

- A) Incorreta. A simples fixação de condições formais para a concessão de benefício fiscal não exime o instrumento normativo de resguardar o tratamento isonômico no que se refere aos concidadãos. STF, ADI 4259/2016.
- B) Incorreta. É lícita a interrupção do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento, após aviso prévio da concessionária. Porém, o mesmo não se aplica a serviços básicos essenciais, como hospitais. STJ, REsp 721119 – RS.
- C) Correta.
- D) Incorreta. Cf. Súmula Vinculante nº 13.
- E) Incorreta. A discricionariedade não se confunde com arbitrariedade, o ato deve observar a legalidade e o Poder Judiciário poderá analisar o mérito administrativo quanto ao atendimento dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e moralidade.

6 – Gabarito D

- A) Incorreta. As decisões discricionárias também se submetem ao princípio da legalidade, já que a conduta da Administração Pública não pode ser arbitrária.
- B) Incorreta. A Administração Pública se submete ao princípio da legalidade estrita.
- C) Incorreta. É possível a interrupção de fornecimento de serviço público por inadimplência do município, desde que respeitada a regra da notificação prévia e que o corte não gere prejuízo aos serviços essenciais. STJ, REsp 726627/MT.
- d) Correta. O ato praticado por servidor ilegalmente investido poderá ser validado, visando não prejudicar o particular de boa fé.
- E) Incorreta. A supremacia do interesse público é conceito jurídico indeterminado (possui significados diversos, sendo estabelecido de acordo com o caso concreto), e não indeterminável (que jamais poderá ser definido).



CAPÍTULO 3 – ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

1. INTRODUÇÃO

A Administração Pública pode prestar suas funções de várias maneiras: por si mesma; ou transferindo para outros sujeitos. Nesta última hipótese, quando cria pessoas jurídicas para executar atividades que define e delega.

Na **centralização administrativa ou atuação centralizada** não há delegação de funções: é o próprio Poder Público que executa suas atividades de forma direta, por seus órgãos pelos integrantes da administração pública direta. Por exemplo, quando a própria Administração Pública constrói uma escola, realiza concursos públicos, ou organiza seus órgãos. Veja, ainda, o art. 37 XXII CRFB, que dispõe sobre a administração tributária como exemplo de atuação centralizada.

Na **desconcentração** a atividade desenvolvida pelo Ente federativo é distribuída internamente. Para isso são criados órgãos, centros de competência, para o exercício de cada função. Nessa situação há uma só pessoa jurídica de direito público (o ente federativo), que distribui suas competências entre os órgãos que ela mesma criou. Não há, assim, a criação de uma entidade com personalidade jurídica própria. Na desconcentração há hierarquia administrativa: os órgãos ficam subordinados ao Ente que os criou. Por exemplo, a secretaria de educação em um município.

Já na **descentralização administrativa ou atuação descentralizada**, a Administração Pública cria entidades administrativas que possuem personalidade jurídica própria, e transfere para estas algumas das funções administrativas. Logo há duas pessoas diferentes: o Ente da federação e a pessoa jurídica que ele criou. Não há relação de subordinação entre elas, apenas de vinculação.

A descentralização administrativa pode ocorrer por três formas:

- Por outorga: nesse modelo o Ente da federação cria uma pessoa jurídica, visando alienar para esta a execução de determinada atividade pública.
- Por delegação: aqui a o Ente irá repassar a execução da atividade pública para uma pessoa jurídica de direito privado, tal como acontece nos contratos de concessão e permissão de serviços públicos, que serão detalhados no item 2.11. Ressalte-se que só é possível a transferência da execução do serviço. A titularidade sempre permanecerá com o Ente Federativo, já que está baseada no poder de império que só este possui.
- Territorial: trata-se de uma hipótese específica, geralmente estudada em Direito Constitucional, quando a União cria os chamados Territórios Federais (art. 18 §2º CRFB) – uma pessoa jurídica de direito público, com espaço geográfico determinado, e dotada de competências administrativas, mas que não possui autonomia política e legislativa. Os territórios são chamados pela doutrina de autarquias territoriais. Mas, apesar do nome, não pertencem à administração indireta, logo não podem ser confundidos com as autarquias que veremos no item 03, abaixo.

Hely Lopes Meirelles esclarece que a administração é um instrumento que tem o Estado para pôr em prática as decisões do governo. Em razão da possibilidade da atuação ser centralizada ou descentralizada, como visto acima, a Administração pode ser dividida em administração direta e administração indireta:

- **Administração direta:** é composta por órgãos públicos pertencentes aos entes federativos, não tendo personalidade jurídica própria. É o fenômeno da desconcentração. A atividade administrativa é exercida pelo próprio ente federativo, de forma centralizada, através dos seus órgãos internos. Veja sobre o tema o art. 4º I do Decreto-Lei nº 200/67 e o item 2 abaixo. Ex.: União se desdobrando em órgãos desconcentrados, como o Ministérios.
- **Administração indireta:** é produto da descentralização, resultando na criação de outras pessoas com personalidade jurídica própria, sendo sujeito de direitos e obrigações, bem como



responsáveis pelos seus atos. Possuem ainda receita e patrimônio próprios, bem como capacidade de autoadministração. Para a criação ou extinção destas pessoas jurídicas o art. 37 XIX da CRFB impõe lei específica – a lei em questão será lei ordinária, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo (por exemplo como está previsto no art. 61 § 1º II, “e” da CRFB/88, que dispõe sobre a iniciativa legislativa na esfera federal). É composta pelas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Confira o art. 4º II do Decreto-Lei 200/67 e o item 3.3 e seguintes, mais adiante.

1.2. ÓRGÃOS PÚBLICOS

Os órgãos são divisões da estrutura estatal, que recebem funções determinadas, e executam atividades estatais por meio de agentes públicos. Integram a estrutura de uma mesma pessoa jurídica. São fruto da desconcentração administrativa, logo não são dotados de personalidade jurídica própria. Ou, nas palavras de Hely Lopes Meirelles³², “*são centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais, através de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertence*”. O art. 1 § 2º, I da Lei nº 9.784/99 traz o conceito legal de órgão administrativo.

A exteriorização das vontades da Administração Pública segue as seguintes teorias:

- **Teoria do mandato:** o Estado outorga ao seu agente um mandato, a fim de que este aja em seu nome. Esta teoria é criticada por não explicar a forma pela qual o Estado transfere seus poderes ao agente. Portanto, não é adotada.
- **Teoria da representação:** o Estado é representado pelo seu agente. Maria Sylvia Zanella Di Pietro³³ critica esta vertente, pois nivela o Estado como um incapaz, que necessita de representação. Também não é adotada.
- **Teoria do órgão ou teoria da imputação volitiva:** o Estado manifesta sua vontade por meio de órgãos que integram a sua estrutura. Por sua vez os agentes manifestam sua vontade em nome do órgão, sendo imputada ao Estado a vontade exteriorizada pelo seu agente. É a teoria adotada no Brasil.

Hely Lopes Meirelles³⁴ aponta que os **órgãos públicos são centros de competência** instituídos para o desempenho de funções estatais, cuja atuação é imputada a pessoa jurídica que compõem esses órgãos. São exemplos de órgãos a Câmara dos Deputados, STF, Senado, etc.

Por seu turno José dos Santos Carvalho Filho³⁵ diz que, apesar de órgãos ser entes despersonalizados, os órgãos representativos de poder, como os tribunais, Câmara dos Deputados, Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, **poderão defender em juízo as suas prerrogativas constitucionais**. Por exemplo o Tribunal de Justiça poderá impetrar de segurança contra ato do governador do Estado que não repassa o duodécimo orçamentários devidos. O Tribunal não tem personalidade jurídica, mas **tem personalidade judiciária**.

Por conta disso, o STJ editou a **Súmula 525**, afirmando que **a Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais**.

³² MEIRELLES, Hely Lopes Meirelles. **Direito Administrativo Brasileiro**. 43a. edição. São Paulo: Malheiros, 2018, p.40.

³³ DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 33ª ed. São Paulo: Gen Forense, 2020. Livro eletrônico não paginado.

³⁴ MEIRELLES, Hely Lopes Meirelles. **Direito Administrativo Brasileiro**. 43a. edição. São Paulo: Malheiros, 2018.

³⁵ CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de Direito Administrativo**. 32ª ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 561.



1.2.1. CLASSIFICAÇÃO DOS ÓRGÃOS

A) QUANTO À POSIÇÃO ESTATAL

- **Órgãos independentes:** os órgãos são independentes quando não se subordinam hierarquicamente a nenhum outro órgão.
- **Órgãos autônomos:** são os órgãos da cúpula da administração, que tem autonomia, mas se subordinam ao órgão independente. Por exemplo, o Ministério do Trabalho é autônomo, mas se submete ao Presidente da República.
- **Órgãos superiores:** são órgãos que exercem função de direção, controle, chefia, mas se subordinam aos órgãos autônomos. Por exemplo, diretorias de empresas públicas.
- **Órgãos subalternos:** são órgãos de execução, fazendo somente aquilo que é designado. Por exemplo almoxarifado.

B) QUANTO À ESTRUTURA

- **Órgãos simples (ou órgãos unitários):** são órgãos que não possuem outros órgãos subordinados. Não há mais órgãos dentro da sua estrutura.
- **Órgãos compostos:** São órgãos em que há uma desconcentração das atividades, pois outros órgãos exercem parcela de sua atividade. Por exemplo, a Procuradoria Geral da União é um órgão superior das Procuradorias Regionais.

C) QUANTO À ATUAÇÃO FUNCIONAL

- **Órgãos singulares (unipessoais):** são órgãos cuja decisão depende da vontade de uma pessoa. Por exemplo a Presidência da República.
- **Órgãos colegiados (pluripessoais):** são órgãos cujas decisões são tomadas por mais de uma pessoa. Não há hierarquia entre seus membros. Por exemplo, as decisões do Plenário do CNJ.

1.3. AUTARQUIAS

A Autarquia tem natureza jurídica de pessoa jurídica de direito público interno (art. 41, IV CC/2002) criada por lei específica, a fim de prestar atividades típicas de Estado, dentro das competências e limites que lhe foram definidas. Não são subordinadas aos órgãos da Administração Direta, existindo apenas uma relação de vinculação. Veja o art. 4º II “a” e art. 5º, ambos do Decreto-Lei nº 200/67; e o art. 2º do Decreto-Lei nº 6.016/1943.

São exemplos de Autarquias a CVM (Comissão de Valores Mobiliários), o BACEN (Banco Central), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Note-se que as Autarquias serão **criadas** diretamente por lei específica (art. 37 XIX CRFB): ou seja, passam a existir já com a promulgação e publicação da lei, e não dependem de qualquer outro ato adicional como registro em cartório de registro civil das pessoas jurídicas e nem de registro na junta comercial. A lei que criar a autarquia deve ser específica para esta finalidade, e será lei ordinária de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo do ente federativo ao qual ela estará vinculada. É comum que seja editado um ato infralegal, via de regra um decreto, que disciplina a organização da Autarquia.

Em razão do princípio do paralelismo das formas como as Autarquias são criadas por lei, serão extintas por meio de outra lei.

Trata-se de descentralização administrativa, tendo personalidade jurídica própria. Assim, titulariza direitos e obrigações e possui patrimônio próprio, inicialmente formado pela transferência de bens (móveis



e imóveis) do ente federativo que a criou. Após a incorporação o patrimônio da Autarquia será classificado como bem público, e na hipótese de extinção da Autarquia deverá ser devolvido ao ente federativo.

De acordo com o Decreto-Lei nº 200/1964 as Autarquias executam atividades típicas da Administração Pública. Se o ente político optar por descentralizar um serviço público tipicamente estatal, que não possa ser prestado por uma entidade privada, essa descentralização deverá se dar através de autarquia. Por exemplo o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – é a Autarquia que executa atividades para previdência social.

Assim os atos praticados pelas Autarquias serão classificados como atos administrativos. Como elas concretizam serviços públicos e atividades de escopo social, e não atuam nas operações de natureza estritamente econômica, podem fazer uso de cláusulas exorbitantes, já que seus contratos são classificados como contratos administrativos.

As Autarquias responderão pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo assegurado o direito de regresso contra o responsável se este tiver agido com dolo ou culpa, conforme o art. 37 § 6º CRFB/88. A responsabilidade civil é objetiva, na modalidade do risco administrativo, ou seja, independe de culpa, basta o ato, o dano e o nexo causal para que a autarquia deva indenizar eventual prejuízo. Entende o STJ que, caso a Autarquia não possua patrimônio suficiente para indenizar os danos causados, o ente federativo responderá subsidiariamente³⁶.

A Autarquia segue o regime de pessoal do ente que a criou, em razão do art. 39 CRFB. Os agentes públicos das Autarquias serão agentes públicos, da categoria de servidores públicos. Segue-se o chamado regime jurídico único³⁷. Nesta linha as Autarquias devem observar regras tais como exigência de realização de concurso público, proibição de acumulação de cargos, teto remuneratório, regime especial de aposentadoria etc.

As Autarquias gozam de todas as prerrogativas inerentes à Fazenda Pública, possuindo privilégios processuais tais como:

- Isenção das custas judiciais, salvo o reembolso das despesas judiciais feitas pela parte autora (art. 4º, I da Lei nº 9.289/96);
- Duplo grau de jurisdição obrigatório quando a sentença lhe for contrária (art. 496, I CPC c/c art. 2º § 1º Lei nº 6.830/80);
- Dispensa de depósito prévio para interposição de recurso (Art. 1-A da Lei nº 9.494/97);
- Prazo em dobro para se manifestar (art. 183 CPC c/c art. 10 Lei nº 9.469/97);
- Realização de execução para cobrança de seus créditos de acordo com o rito da lei de execução fiscal;
- O pagamento das condenações judiciais das Autarquias será por precatório (art. 100 CRFB). As autarquias têm fila própria de precatórios, então, por exemplo, uma dívida do INSS não faz com que o particular aguarde na fila da União, mas da própria Autarquia, uma vez que as dotações orçamentárias são específicas.
- Estão submetidas a **prescrição quinquenal**, ou seja, eventuais prestações de direitos contra a autarquia, prescrevem no prazo de 05 anos.

Como visto os bens das Autarquias são classificados como bens públicos. Esta classificação gera diversas consequências jurídicas. Há a **impenhorabilidade de seus bens, que também** não podem ser objeto de hipoteca ou anticrese. Além disso são imprescritíveis, ou seja, como no caso da usucapião que é uma prescrição aquisitiva, sendo o decurso do tempo que faz nascer direitos. Por fim são relativamente inalienáveis: podem ser alienados de forma condicionada, desde que haja lei.

As Autarquias gozam de **imunidade tributária recíproca**, também chamada de ontológica, prevista no artigo 150, da CRFB. Veda-se a instituição e cobrança de impostos sobre o patrimônio, a renda e os

³⁶ STJ, AgRg no AREsp 203.785/RS.

³⁷ Sobre o regime jurídico único veja o item Servidores Públicos.

serviços por elas prestados, com o requisito que estes estejam vinculados as suas finalidades principais. Caso a Autarquia explore outras atividades, mesmo que distantes das essenciais aos seus fins, mas comprove que são revertidas para a sua finalidade principal, a imunidade recíproca também será aplicada (STF, AgR RE 475.268).

Por fim as Autarquias possuem autonomia administrativa, mas se subordina a um controle finalístico pela entidade que a criou. Este controle finalístico é também chamado de **tutela** ou de **supervisão ministerial**. Estas, no entanto, não são presumidas. A **supervisão ministerial** visa essencialmente a realização dos objetivos que justificaram a criação da entidade (autarquia).

A diferença entre supervisão ministerial e subordinação hierárquica é de que, nesta última, ocorre dentro de uma estrutura vertical, dentro da mesma pessoa jurídica, havendo hierarquia. A hierarquia independe da previsão legal, decorrendo da própria estrutura da entidade.

Há a possibilidade recurso sobre uma decisão da autarquia para um Ministro. Em regra, os dirigentes de uma autarquia são exercentes de cargo em comissão, exonerável *ad nutum* pelo Presidente da República, havendo, ainda, a possibilidade de que uma decisão da autarquia seja impugnável perante um órgão da administração pública indireta. Se isso ocorrer, está-se diante do recurso hierárquico impróprio, que, em verdade não é um recurso hierárquico, justamente porque não há hierarquia entre a autarquia e o Ministério a qual se vincula, mas, desde que haja previsão em lei haverá tal recurso.

1.3.1. UNIVERSIDADES

As universidades públicas podem ser organizadas como autarquias de regime especial (melhor abordado adiante), e tem em comum com as agências reguladoras, uma maior autonomia. Como principal característica das universidades está o fato de o reitor não poder ser exonerado *ad nutum*, dependendo do preenchimento de requisitos. Há cultura de que o reitor seja nomeado a partir de lista tríplice, formulada pelos membros da própria instituição, mas não há obrigatoriedade.

As autarquias possuem as prerrogativas do ente da federação que as criou.

- **Imunidade tributária:** as autarquias terão imunidades relativas sobre seu patrimônio, rendas e serviços, desde que vinculados às suas finalidades essenciais. É a **imunidade condicionada**. O STF confere uma interpretação ampliativa dessa imunidade, pois como visto acima entende que basta que a renda seja destinada à consecução à finalidade essencial para ser imune. Por exemplo, os ganhos do estacionamento são revertidos em prol da entidade, logo não há incidência do imposto sobre o estacionamento.
- **Impenhorabilidade, inalienabilidade e imprescritibilidade dos bens;**
- **Débitos pagos por meio de precatórios;**
- **Execução fiscal dos seus créditos;**
- **Benefício da prescrição quinquenal de seus débitos.**

1.3.2. AUTARQUIAS CORPORATIVAS

As autarquias corporativas são as entidades de classe, como o CFEA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia), CFM (Conselho Federal de Medicina), CRO (Conselho Regional de Odontologia), O STJ e o STF classificam estes conselhos como autarquias especiais, gozando de imunidade tributária, submetendo-se à fiscalização e prestação de contas ao Tribunal de Contas da União, tendo que realizar concurso público para contratação de pessoal e licitações para contratação.

Os conselhos profissionais, também chamados de autarquia de controle ou autarquias corporativas, são espécie de autarquias muito peculiares. Tais entidades inicialmente eram públicas, e servem para fiscalizar uma determinada arte ou ofício, é o caso do Conselho Federal de Medicina.

Diferentes corporações tem um conselho profissional responsável pelo exercício do poder de polícia. Essa entidade tem a responsabilidade de fiscalizar o exercício dessas profissões.



Inicialmente entendidas como entidades privadas, foram objeto da ADI 1717, em que o STF entendeu que devem ser organizadas sob a forma de Autarquias, já que o poder de polícia não poderia ser transferido/delegado a um agente particular. Na mesma linha,

ficou consignado que: (i) estas entidades foram criadas por lei, tendo personalidade jurídica de direito público com autonomia administrativa e financeira; (ii) exercem a atividade de fiscalização de exercício profissional que, como decorre do disposto nos artigos 5º, XIII, e 21, XXIV [da Constituição Federal], é atividade tipicamente pública; (iii) têm o dever de prestar contas ao Tribunal de Contas da União.

O valor cobrado a título de anuidade dos inscritos nos conselhos profissionais, segundo o STF, tem natureza jurídica de contribuição especial (de interesse das categorias profissionais), portanto tributo, devendo estar previsto em lei, assim como sua base de cálculo e alíquota (RE 704.292). Durante muito tempo essas cobranças ocorriam com base em mera resolução, hoje não mais. Trata-se de obrigação *ex lege*.

Há vários precedentes do STF que conselhos profissionais podem e devem ser fiscalizados pelo TCU (MS 22.643, RE 539.224).

Como os conselhos profissionais são autarquias seus servidores estão submetidos ao regime estatutário. Contudo o STF não ainda não delineou como deverão ser solucionados os casos dos servidores destes conselhos que foram contratados sob o regime celetista, estando pendente de julgamento a ADC 36, a ADI 5.367 e a ADPF 367.

O STF entende que os conselhos profissionais não podem ajuizar ADI, ADC ou ADPF pois não são sindicatos nem entidades de classe, mas sim autarquias que exercem poder de polícia. Porém, podem ajuizar ação civil pública, já que as autarquias em geral têm legitimidade para ajuizar ACP e os conselhos profissionais são uma autarquia.

Embora as Autarquias em geral estejam submetidas ao regime jurídico público, podendo pagar suas dívidas por meio de precatórios, o mesmo não se aplica aos conselhos profissionais. Em virtude da decisão do STF no RE 938.837, embora sejam Autarquias, os conselhos profissionais não pagam suas dívidas por meio de precatórios, mas por execução comum, como se particular fosse, uma vez que o conselho profissional tem receita própria e não orçamento. Assim, não estando submetido à lei orçamentária, não haveria sentido pagar suas dívidas por meio de precatórios.

Os conselhos profissionais não estão isentos de custas processuais. Quando um determinado conselho profissional busca cobrar as anuidades, faz isso por meio de execução fiscal, pois é entidade que atua em nome do estado e a anuidade é um tributo. A ação que permite a execução desse tributo é uma execução fiscal, mas diferentemente dos outros entes os conselhos profissionais não gozam de isenção de custas.

1.3.3. OAB

De acordo com o STF a Ordem dos Advogados do Brasil não deve ser considerada uma entidade pública, mas autarquia *sui generis* em virtude do papel que tem para defesa do estado democrático, portanto o regime jurídico aplicável aos demais conselhos profissionais não é extensível à OAB (ADI 3.026). Por exemplo, a OAB cobra seus devedores como particular e não por execução fiscal. Além disso não goza das prerrogativas de que gozam os conselhos profissionais. Permanece como uma entidade privada, sob o argumento de que à OAB deve ser concedida maior autonomia, independência e distanciamento da entidade ao Poder Público. Também não se submete à fiscalização dos Tribunais de Contas.



1.3.4. AGÊNCIAS REGULADORAS

Maria Sylvia Zanella Di Pietro³⁸ esclarece que, de forma genérica, qualquer órgão da administração direta ou entidade da administração indireta, que possua função de regular as matérias de sua competência, poderá ser classificado como agência reguladora.

Porém, de forma específica, o termo agências reguladoras se refere ao regime jurídico estabelecido a determinadas Autarquias, denominadas Autarquias Especiais. Recebem esta classificação porque gozam de um regime jurídico diferenciado e, consequentemente, guardam uma série de peculiaridade. Ou, como definem Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino:

são entidades administrativas com alto grau de especialização técnica, integrantes da estrutura formal da administração pública, instituídas como autarquias sob regime especial, com a função de regular um setor específico de atividade econômica ou um determinado serviço público, ou de intervir em certas relações jurídicas decorrentes dessas atividades, que devem atuar com a maior autonomia possível relativamente ao Poder Executivo e com imparcialidade perante as partes interessadas (Estado, setores regulados e sociedade).³⁹

As agências reguladoras surgiram nos EUA após a Quebra da Bolsa de Nova York em 1929. O governo americano apresentou o *New Deal*, um amplo plano para recuperação da economia. Entre as suas propostas estava o maior controle do Poder Público sobre a atuação das empresas privadas. Ou seja, nos EUA, as agências reguladoras surgiram como uma forma de possibilitar que o Estado intervisse na economia, mas sem interferir de modo drástico na liberdade do empresariado.

Já no Brasil, as agências reguladoras foram criadas para regular setores que antes eram explorados unicamente pelo Poder Público, em regime de monopólio estatal. Na década de 1980, os governos militares brasileiros adotavam uma política econômica extremamente intervencionista e concentradora. Os serviços públicos eram prestados diretamente pelo Estado, em regime de monopólio de produção, e a Regulação e gerência dos setores de infra-estrutura atribuída a departamentos ministeriais diretamente subordinados aos ministros de Estado. A chegada do modelo neoliberal para o Brasil, na década seguinte, gerou a contestação do modelo econômico até então vigente, sob a alegação de excesso de burocracia, atraso técnico, má qualidade dos produtos e serviços e mobilização dos recursos públicos em serviços não essenciais. A Lei nº 8.031/1990 instituiu o Plano Nacional de Desestatização, visando a retirada da execução direta dos serviços públicos e das atividades econômicas das mãos do Estado, transferindo estas funções para a iniciativa privada. Neste contexto surgem as agências reguladoras no Brasil, visando garantir que o livre mercado ingressasse em áreas que antes eram monopólio do Poder Público, mas permitindo a supervisão estatal sobre a correta execução das atividades⁴⁰.

Por exemplo são agências reguladoras existentes no Brasil a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), a ANA (Agência Nacional de Águas), a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), a ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) dentre outras.

As agências reguladoras são disciplinadas pelas Leis nº 9.986/2000 e pela Lei nº 13.848/2019. São **características** da agência reguladora:

- a) **As decisões da agência reguladora não se submetem a uma revisão de um órgão integrante do Poder Executivo.** É o caráter técnico que deve prevalecer. As agências reguladoras são órgãos colegiados e com perfil técnico. Nesta linha sua atuação estaria menos suscetível às

³⁸ DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. *Direito Administrativo* 33ª ed. São Paulo: Gen Forense, 2020. Livro eletrônico não paginado.

³⁹ ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. *Direito Administrativo descomplicado*. 25ª ed., São Paulo: Método, 2017, p. 204.

⁴⁰ Sobre o histórico das Agências Reguladoras, c.f. ARAGÃO, Alexandre Santos de. **Agências Reguladoras e a Evolução do Direito Administrativo Econômico**. São Paulo: Gen Forense, 2013.



pressões políticas transitórias e momentâneas, permitindo a tomada de decisões neutra e acertada. Para isso a lei criou uma série de medidas de salvaguarda para fortalecer essas instituições e para blindá-las de eventual pressão política indevida.

Embora cada agência reguladora tenha um regime jurídico próprio, previsto pela lei que a instituiu, a regra é da adoção do regime colegiado. São presididas por vários diretores, que possuem mandatos não coincidentes (art. 4º, § 1º da Lei nº 9.986/2000), evitando que o Governo da ocasião nomeie de uma vez só todos os diretores daquela entidade.

- b) Os dirigentes das agências reguladoras são nomeados pelo Presidente da República, após aprovação do Senado Federal, exercendo mandatos fixos e com estabilidade.** Há vedações para a indicação, previstas no art. 8º-A da Lei nº 9.986/2000. Os requisitos para ser dirigente estão dispostos no art. 5º da mesma lei⁴¹. Os mandatos não devem coincidir com o mandato do Presidente da República. Uma vez nomeados, os dirigentes das agências reguladoras só poderão perder seus cargos no caso de renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou processo administrativo disciplinar. Assim, o Presidente da República pode nomeá-los, mas não pode destituí-los, salvo em hipóteses excepcionais previstas em lei, como por exemplo a prática de crime ou perda da capacidade. O dirigente não pode ser exonerado *ad nutum*. (art. 9º Lei nº 9.986/2000).
- c) Com relação aos dirigentes, há a quarentena.** Terminado o mandato, o ex-dirigente ficará impedido pelo período de no mínimo 06 meses de prestar qualquer serviço no setor público ou em empresa integrante de setor regulado pela agência reguladora. Ele receberá remuneração compensatória durante a quarentena, ficando vinculado à agência (art. 8º Lei nº 9.986/2000).
- d) As agências reguladoras gozam de autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira. Não há tutela ou subordinação hierárquica.** Sendo assim os atos das agências reguladoras só poderão ser revistos pro elas próprias ou pelo Poder Judiciário. O Ministério ao qual estão vinculadas não poderá rever seus atos, salvo na hipótese de edição de ato que exorbite os limites de sua competência regulatória. Já o controle externo das agências reguladoras será exercido pelo Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União.

1.3.5. TEORIA DO RISCO DA CAPTURA

O regime específico adotado pelas agências reguladoras visa evitar conflito de interesses, advocacia administrativa, e uso de informações obtidas ou conhecimento obtido para atuar de plano naquele setor.

É aqui que se trata da **Teoria do Risco da Captura**. Segundo José dos Santos Carvalho Filho⁴², tal teoria busca impedir uma vinculação promíscua entre a agência reguladora de um lado e o governo instituidor, ou os entre regulados, de outro, com flagrante comprometimento da independência da pessoa controladora. A captura acaba por reduzir a independência político-administrativa da agência em relação

⁴¹ Os candidatos a dirigentes das Agências Reguladoras deverão ser cidadãos brasileiros de reputação ilibada e de notório conhecimento no campo de sua especialidade, com formação acadêmica compatível com o cargo para o qual foi indicado, e devendo ter experiência profissional de, no mínimo:

- 10 (dez) anos, no setor público ou privado, no campo de atividade da agência reguladora, OU
- 04 (quatro) anos ocupando cargo de direção ou de chefia superior em empresa no campo de atividade da agência reguladora ou cargo em comissão ou função de confiança no setor público, OU
- cargo de docente ou de pesquisador no campo de atividade da agência reguladora ou em área conexa OU
- 10 (dez) anos de experiência como profissional liberal no campo de atividade da agência reguladora ou em área conexa.

⁴² CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de direito administrativo** 32ª ed. São Paulo: Atlas, 2018.



aos regulados, bem como aos agentes políticos, violando a impessoalidade exigida para a função institucional.

A doutrina divide a captura em captura econômica e captura política:

- **Captura econômica:** é a materializada em razão da vinculação entre os interesses dos setores regulados e a agência reguladora, gerando um desvirtuamento das finalidades regulatórias da agência reguladora.
- **Captura política:** é a prevalência das decisões de ordem política em detrimento das tecnicamente apropriadas, estando relacionada diretamente ao processo de escolha dos dirigentes das agências.

A Constituição de 1988 reforça a ideia de regulação imparcial e impessoal, exemplo disto é a previsão inserta em seu art. 52, III, f, que autoriza, por meio de lei ordinária, a aprovação prévia pelo legislativo, por voto secreto, dos dirigentes de entidades reguladoras indicados pelo chefe do Poder Executivo.

Assim, a teoria da captura se corporifica através da influência de interesses privados no desempenho das atividades regulatórias, visando seu benefício em detrimento dos fins legalmente previstos para tal atividade.

1.3.6. DESLEGALIZAÇÃO E TEORIA FUNÇÃO REGULATÓRIA

É muito comum associar o processo de surgimento das agências à chamada deslegalização, o processo pelo qual o Parlamento delega sua competência legislativa para que certas decisões passem a ser tomadas por um órgão técnico, e não mais por lei. Na França, por exemplo, a deslegalização é plena – o Poder Legislativo transfere totalmente a edição de determinadas normas aos órgãos técnicos. Nessas situações, a agência reguladora teria competência para editar um ato normativo geral e abstrato relativo ao setor que atua com caráter inovador na ordem jurídica.

No Brasil, a deslegalização total não é permitida. Os regulamentos emanados por agências reguladoras não podem ser atos normativos primários, que inovam a ordem jurídica. Cabem aos órgãos ou entidades com função regulatória editar atos normativos complementares, especialmente de conteúdo técnico, regulamentando o setor, mas sem inovar na ordem jurídica.

Ou seja, as agências reguladoras possuem discricionariedade técnica, um poder normativo fundado no seu conhecimento de causa e sua capacidade institucional. Mas como se trata de um juízo regrado e baseado em conceitos técnicos, não pode ser discricionário, aberto e indefinido, que daria margem a diferentes decisões.

1.4. FUNDAÇÕES PÚBLICAS

A fundação pública visa transportar os conceitos da fundação privada para o direito administrativo. Observe-se que existem diferentes tipos de fundação e que a fundação pública é semelhante à fundação privada, no sentido de que há um patrimônio afetado para um determinado fim social. Há assim três traços são marcantes: a ausência de fins lucrativos, a finalidade social e a afetação do patrimônio ao fim desejado pelo instituidor ou fundador. No caso das fundações públicas o instituidor sempre será um ente da federação.

As fundações públicas são entidades da Administração Indireta e estão previstas no art. 5º IV do Decreto-Lei nº 200/67. Elas visam a execução do interesse público e podem adotar duas feições: fundação pública de natureza privada; ou fundação pública de natureza pública. Neste último caso é também chamada de fundação autárquica, ou seja, tudo que foi dito a respeito da autarquia, vale para essa forma de fundação.

São exemplos de fundação pública a UnB (nome jurídico Fundação Universidade de Brasília), sendo portanto uma fundação pública de natureza pública, equiparando-se a uma Autarquia e com personalidade jurídica de direito público.



Já as fundações públicas de natureza privada são entidades com personalidade de direito privado, com atribuição de competências administrativas específicas, cujas áreas de atuação devem ser definidas em lei complementar, conforme o art. 37 XIX CRFB. Há inclusive na doutrina quem entenda que elas não deveriam existir, tal como postula Celso Antônio Bandeira de Mello, uma vez que a CRFB não teria feito essa distinção: para este autor, uma vez que as fundações possuem atribuições claramente públicas, elas nada mais são do que Autarquias.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro⁴³ defende que o Poder Público pode criar tanto fundações de direito público quanto de direito privado, de acordo com o fixado pela sua lei instituidora. Esta posição foi adotada pelo STF na ADI 191. Isso significa que o legislador poderá optar por criar uma fundação através de lei, ou autorizar a criação de uma fundação pública através de lei. Se o nascimento da fundação emana diretamente da lei, haverá uma fundação pública com personalidade jurídica de direito público. Se a lei apenas autoriza a criação da fundação, haverá uma fundação pública com personalidade jurídica de direito privado, já que será criado nos moldes da fundação de direito privado.

A instituidora sempre será uma entidade pública, que a criará por meio de uma lei específica, destacando parcela de seus bens e conferindo a esse patrimônio uma personalidade jurídica. O patrimônio irá desempenhar funções estatais com autonomia, mas a fundação ficará sujeita ao controle finalístico de suas atividades.

No tocante aos bens das fundações públicas, qualquer que seja a natureza de sua personalidade, são os bens das fundações serão impenhoráveis, pois são afetados, tendo finalidade pública.

A imunidade tributária recíproca em relação aos impostos é uma prerrogativa conferida às fundações públicas de qualquer natureza.

1.4.1. FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO

As fundações públicas com personalidade jurídica de direito público gozam das mesmas prerrogativas das autarquias. São denominadas de fundações de **fundações autárquicas** por Celso Antônio Bandeira de Melo. O STJ segue o entendimento de equiparação da fundação de direito público à autarquia, tal como se extrai do CC 169.704-TO.

É exemplo deste tipo de fundação a FUNAI - Fundação Nacional do Índio.

As fundações autárquicas são criadas por lei, não estando submetidas à exigência de inscrição do ato constitutivo no registro civil das pessoas jurídicas.

Seus bens são considerados bens públicos, e gozam de privilégios processuais e tributários dados à fazenda pública. Adotam o regime estatutário de pessoal.

1.4.2. FUNDAÇÕES PÚBLICAS COM PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Estas fundações, apesar criadas e mantidas pelo Poder Público, são regidas pelo direito privado. Também são chamadas de fundações governamentais e seguem um regime jurídico híbrido.

São criadas por lei específica, aplicando-se o disposto no art. 37 XIX CRFB: caberá a lei complementar definir suas finalidades.

Por serem mantidas com o patrimônio público não são fiscalizadas pelo Ministério Público. Seu Controle será feito pelo Tribunal de Contas da União ou estadual, a depender do ente federativo que a criou.

Não gozam de privilégios processuais.

⁴³ DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo** 33^a ed. São Paulo: Gen Forense, 2020. Livro eletrônico não paginado.



1.4.3. AGÊNCIAS EXECUTIVAS

A reforma administrativa estabeleceu a **possibilidade de o Poder Público qualificar como agência executiva uma autarquia ou uma fundação**, desde que cumpridos os requisitos legais, para então se alcançar uma maior eficiência no desempenho. As agências executivas são autarquias ou fundações que sejam qualificadas como agência executiva pelo Chefe do Executivo. Há a celebração de um contrato de gestão entre a autarquia ou fundação e o seu ministério supervisor.

Com elas busca-se o cumprimento do princípio da eficiência. Isso porque há uma maior liberdade de atuação para a autarquia ou fundação, mas haverá fixação de metas, por meio de contratos de gestão, como se verá abaixo.

A qualificação poderá ser conferida por iniciativa do Ministério supervisor, sendo efetuada por ato específico do chefe do Poder Executivo. Após será firmado um contrato de gestão com o respectivo Ministério supervisor; e será criado um plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional. A qualificação e o plano estratégico visam **a redução de custo e aumento da eficiência** da autarquia ou fundação. O contrato de gestão terá duração mínima de um ano, podendo ser revisto a qualquer momento em caráter excepcional pelo Ministério Supervisor. O contrato poderá ser prorrogado, igualmente após a análise do Ministério Supervisor.

São requisitos para qualificação de agência executiva:

- **Plano estratégico** de reestruturação e desenvolvimento institucional em andamento;
- **Contrato de gestão** celebrado com o respectivo ministério supervisor, constando os objetivos, metas e quais os instrumentos a ser empregados para que as metas sejam alcançadas.

Firmado o contrato de gestão entre a autarquia e o ministério supervisor, o ente supervisor vai renunciar determinados instrumentos de controle pelo tempo pactuado no contrato de gestão, aumentando a autonomia da agência executiva. O ente supervisor se compromete a repassar constantemente verbas, visando o cumprimento das metas estabelecidas no contrato de gestão.

A qualificação como agência executiva vai ocorrer por meio de **decreto do Presidente da República**, e ocorrerá após a celebração do contrato de gestão. Esta qualificação vai vigorar enquanto vigorar o contrato.

São exemplos de agências executivas o Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (Inmetro), a Agência Nacional do Desenvolvimento do Amazonas (ADA) e Agência Nacional do Desenvolvimento do Nordeste (ADENE).

O art. 24, §1º, da Lei de Licitações diz que **as agências executivas podem dispensar licitação na contratação de bens, serviços e obras pelo dobro do limite estipulado para as demais autarquias e fundações públicas** que não recebem a qualificação de agência executiva.

Normalmente, a dispensa é autorizada para os casos de 10% dos limites estipulados pela licitação na modalidade convite:

- **Até 30 mil reais para agência executiva**, pois obras e serviços de engenharia de até 15 mil é dispensado.
- **Até 16 mil reais para agência executiva**, pois compras de bens e serviços comuns de até 8 mil reais é dispensado.

1.5. EMPRESAS ESTATAIS

Consideram-se empresas estatais todas as sociedades, sejam civis ou empresariais, em que o Poder Público detém o controle acionário. As empresas governamentais podem ser empresas públicas ou sociedades de economia mista, de acordo com o previsto no art. 5º II e III do Decreto-Lei nº 200/67.



O STF ampliou a interpretação do art. 173 da CRFB/88, entendendo que tanto as empresas públicas quanto as sociedades de economia mista podem ser criadas para a prestação de serviços públicos ou para a exploração de atividades econômicas⁴⁴. Este entendimento foi cristalizado pelo art. 1º da Lei 13.303/2016.

1.5.1. CRIAÇÃO E EXTINÇÃO

Ambas são criadas após autorização legislativa específica, não cabendo lei genérica (art. 37 XIX CRFB), com a indicação clara de relevante interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional na lei que autoriza sua criação (art. 2º § 1º da Lei nº 13.303/2016).

Contudo a lei não as institui por si só, apenas as autoriza; a criação se dá após o registro dos atos constitutivos no órgão competente (cartório de registro civil ou na junta comercial). Somente após essa fase a empresa pública e a sociedade de economia mista irão adquirir personalidade jurídica própria.

Em razão do princípio do paralelismo das formas a extinção das empresas governamentais também dependerá de lei com autorização específica. Tanto a lei que cria as empresas estatais, como a lei que as extingue serão de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo (art. 61 §1º, II “e” CRFB).

É importante fazer uma nota adicional, em razão de uma recente decisão do STF em 2019 (ADIs 5.624, 5.846, 5.924, e 6.029): **a privatização das estatais, ou seja, a alienação do controle acionário de empresas públicas e sociedade de economia mista exige autorização legislativa e licitação.**

O STF considerou que para o Poder Público passar a atuar em determinada atividade econômica, o que pode ocorrer somente em situações excepcionais, a Constituição prevê a necessidade de edição de lei, ou seja, de autorização do Poder Legislativo. Da mesma forma, para que o Estado se retire de determinada atividade econômica, também há necessidade de concordância do Poder Legislativo. Como a perda do controle acionário é equivalente à extinção completa da sociedade de economia mista, essa operação demanda autorização legislativa.

1.5.2. CONTROLE E REGIME DE PESSOAL

As empresas governamentais integram a Administração Indireta do Poder Público, consequentemente também estão sujeitas ao controle interno e externo, seja pelo Tribunal de Contas, pela Supervisão Ministerial, interposição de ação popular ou ação de improbidade administrativa.

O regime de pessoal aplicável será o de emprego público, regido pela CLT. Apesar de incidência das regras trabalhistas os empregados das estatais:

- não podem acumular seus empregos com cargos ou funções públicas;
- são equiparados a funcionários públicos para fins penais;
- são agentes públicos para fins de improbidade administrativa.

Tradicionalmente, o STF entende que a demissão do empregado de empresa pública e sociedade de economia mista exige Processo Administrativo Disciplinar. Isto porque os princípios extensíveis à administração pública também se aplicam às empresas estatais, que tem as limitações típicas de uma entidade estatal. Porém, no julgamento do RE 589.998-ED, ocorrido em 2018, a Corte estabeleceu que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT tem o dever de motivar os atos de dispensa sem justa causa de seus empregados. A fim de conciliar a natureza privada dos vínculos trabalhistas com o regime essencialmente público reconhecido à ECT, não é possível impor-lhe nada além da exposição, por escrito, dos motivos ensejadores da dispensa sem justa causa. Entendeu o STF que não se pode exigir, em especial, instauração de processo administrativo ou a abertura de prévio contraditório. Foi fixada a seguinte tese de julgamento: A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados.

⁴⁴ STF, AgR no RE 605.908e AgR-ED no AI 651.512.



1.5.3. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Embora o art. 2º, I da Lei nº 11.101/2005 tenha fixado que as empresas públicas e sociedades de economia mista não se submetem ao regramento concernente à recuperação judicial, extrajudicial e à falência, há divergência doutrinária relevante sobre a possibilidade das empresas pública e sociedades de economia mista se submeterem ao regime de falência. Rafael Oliveira⁴⁵ aponta que existem basicamente três posições sobre o tema:

- a primeira defende a inconstitucionalidade do art. 2º, inciso I, da Lei nº 11.101/2005, por violar o art. 173, § 1º, inciso II, da CRFB. Nesse sentido: José Edwaldo Tavares Borba⁴⁶;
- a segunda advoga que o art. 2º, inciso I, da Lei nº 11.101/2005 deve ser interpretado conforme a CRFB, limitar a sua aplicação às empresas estatais prestadoras de serviços público. Nesse sentido: Celso Antônio Bandeira de Mello, José dos Santos Carvalho Filho, Diógenes Gasparini e Maria Sylvia Zanella Di Pietro;
- por fim há a que se posiciona a favor a constitucionalidade do art. 2º, inciso I, da Lei nº 11.101/2005 e a sua aplicabilidade a todas as empresas estatais, independentemente de serem prestadoras de serviços públicos ou exploradoras de atividade econômica em sentido estrito. Em caso de insolvência, o ente político é responsável pela reparação dos lesados, caso a empresa pública ou sociedade de economia mista não consiga arcar com as responsabilidades. Nesse sentido: Marcos Jurueña Villela Souto, Marçal Justen Filho e Marcos Bemquerer.

1.5.4. EMPRESAS PÚBLICAS

São definidas pelo art. 3º da Lei nº 13.303/16. As empresas públicas são pessoas jurídicas com criação autorizada por lei. Contudo só serão efetivamente criadas após o registro de seus atos constitutivos no órgão competente. Podem adotar qualquer forma acionária (por exemplo limitada ou sociedade anônima), mas terão seu capital social formado unicamente por recursos públicos, admitindo a participação acionária de outras pessoas jurídicas de direito público interno e/ou de entidades da administração indireta. Contudo a maioria do capital votante deve pertencer aos entes federativos (União, estados-membros, Distrito Federal ou municípios).

O regime jurídico a que estão submetidas poderá ser predominantemente de direito público(se atuarem em regime de monopólio ou prestando serviços públicos) ou de direito privado (caso explorem atividades econômicas em concorrência com a iniciativa privada). Mesmo na segunda hipótese estarão submetidas a certas regras especiais, uma vez que compõe a Administração Indireta e em razão da finalidade pública que perseguem.

As causas em que as empresas públicas federais forem autoras, rés, assistentes ou oponentes serão processadas pela Justiça Federal (art. 109, I CRFB).

São exemplos de empresas públicas o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), a CEF (Caixa Econômica Federal) e a EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária).

1.5.5. SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

Estão previstas no art. 4º da Lei nº 13.303/2016. São igualmente criadas por autorização legal, mas efetivamente criadas após o registro de seus atos constitutivos no órgão competente e visam a prestação de serviços públicos ou a exploração de atividades econômicas. Na mesma linha são dotadas de

⁴⁵ OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. **Curso de direito administrativo** 6ª ed. São Paulo: Gen Método, 2018, p. 137.

⁴⁶ BORBA, José Edwaldo Tavares. **Sociedade de economia mista e privatização**. Rio de Janeiro, Lúmen Júris, 1997, p. 23.

personalidade jurídica de direito privado, mas submetidas à regras especiais em razão de sua finalidade pública.

Porém, adotam necessariamente a forma de sociedade anônima. O Ente da federação deverá possuir o controle acionário. Para isso ele deverá possuir a maior parte das ações ordinárias (com direito a voto), sendo permitido vender o remanescente aos particulares interessados. Desta forma o Estado poderá tomar as decisões essenciais e estratégicas da empresa, e deter o controle sobre sua administração. Outra possibilidade que garante o controle estatal é o Estado deter uma *golden share*, ou seja, ações de classe especial que garantem ao detentor o direito absoluto na tomada de decisões estratégicas.

As causas das sociedades de economia mista serão julgadas pela justiça estadual, conforme a Súmula 556 do STF.

São exemplos de Sociedades de Economia Mista a PETROBRAS, o Banco do Brasil e a ELETROBRAS.

1.5.6. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL ÀS EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

Como visto acima a criação de empresas públicas e sociedades de economia mista não é livre. Isto porque a CRFB explicita que a exploração das atividades econômicas deve ser exercida preferencialmente por empresas privadas. A atuação direta do Poder Público na economia, também chamada de Estado Empresário, deve ser excepcional, sendo possível apenas nas situações previstas nos art. 173 e 175 da CRFB.

O art. 173 CRFB dispõe que “a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo”. Já o art. 175 CRFB esclarece que “incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos”.

Ou seja, a autorização para criação de uma empresa pública ou sociedade de economia mista para exploração de atividade econômica só será realizada se for **indispensável para a segurança nacional** ou **quando houver relevante interesse público**. A ideia central da CRFB é de que a intervenção do estado diretamente na economia deve ser excepcional, pois a livre iniciativa deve preponderar.

Embora a CRFB não faça expressamente, o STF diferencia as empresas estatais que exploram serviços públicos ou que estejam em regime de monopólio, das que exploram atividades econômicas. Extremamente importante é o § 2º do art. 173 CRFB, ao postular que “as empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado”.

Para o STF as empresas governamentais que exploram atividades econômicas são regidas pelo art. 173 CRFB, devendo ser regidas preponderantemente pelo direito privado – como atuam em concorrência com o setor privado não podem receber vantagens não extensíveis aos demais, já que a livre concorrência é garantida pelo art. 170 CRFB. Por exemplo a PETROBRAS quando compete nas licitações para arrematar blocos exploratórios de petróleo que serão objeto de contratos de concessão; ou do Banco do Brasil quando fornece cartão de crédito aos seus correntistas.

Já as empresas estatais que prestam serviços públicos, ou que atuam em monopólio, seguem o disposto no art. 175 CRFB, e suas atividades são regidas preponderantemente pelo direito público. O STF assinalou que a atividade destas empresas está voltada à atuação própria do Estado, de natureza não concorrencial, logo elas poderão gozar de prerrogativas vedadas ao setor privado. É o caso da INFRAERO (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária) e da ECT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos).

Na hipótese dessas entidades, tem-se uma empresa governamental que, por ser prestadora de serviço público, recebe a incidência de boa parte do regime administrativo. Por exemplo, os Correios são beneficiados pela imunidade recíproca do artigo 150, da CF, pela prescrição quinquenal prevista no decreto que rege a matéria. Além disso estão submetidos à responsabilidade objetiva, devem fazer concurso e licitar, ao menos no que se refere às atividades meio. Na mesma linha o STF também já esclareceu que as empresas públicas, prestadoras de serviços públicos podem pagar suas dívidas por meio de precatórios e não por meio de uma execução cível comum (STF, Rcl 32.882 e Rcl 32.888).



1.5.7. REGIME HÍBRIDO APLICÁVEL ÀS ESTATAIS

Resumidamente pode-se afirmar que as empresas governamentais seguem um duplo regime, de direito público e de direito privado, dependendo da área que atuam. Se exploram atividades econômicas em concorrência com o setor privado seguirão precipuamente o regime de direito privado, mas se submetem subsidiariamente às regras de Direito Público previstas na CRFB. Caso prestem serviços públicos estão sujeitas principalmente ao regime de direito público, em razão do princípio da continuidade dos serviços públicos.

José dos Santos Carvalho Filho⁴⁷ explica o regime híbrido normativo:

A análise do regime jurídico das empresas públicas e das sociedades de economia mista e de suas subsidiárias deve partir de dois pressupostos – um deles, considerando o fato de que são pessoas de direito privado, e o outro, a circunstância de que integram a Administração Pública. Sem dúvida, são aspectos que usualmente entram em rota de colisão, mas, por sua vez, inevitáveis ante a natureza das entidades. Diante disso, a consequência inevitável é a de que seu regime jurídico se caracteriza pelo hibridismo normativo, no qual se apresenta o influxo de normas de direito público e de direito privado. Semelhante particularidade, como não poderia deixar de ser, rende ensejo a numerosas perplexidades e divergências.

O mesmo raciocínio será utilizado quanto ao regime tributário aplicável. O STF, na ACO 1460SP já decidiu que a imunidade tributária recíproca do art. 150, VI, “a” CRFB pode ser estendida à empresa pública e à sociedade de economia mista, desde que três requisitos sejam observados:

- a) a imunidade tributária recíproca se aplica apenas à propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado;
- b) atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política; e
- c) a desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre concorrência e do livre exercício de atividade profissional ou econômica lícita.

O STF vem reconhecendo a impenhorabilidade de bens e imunidade em relação a impostos de empresas públicas e sociedade de economia mista que prestam serviços públicos, mas também de empresas públicas e sociedade de economia mista que prestam serviço público com exclusividade (Cf. RE 220.906).

Por fim cabe ressaltar que tanto as empresas públicas quanto as sociedades de economia mista possuem personalidade jurídica de direito privado, independente de atuarem em monopólio, executarem serviços públicos ou explorarem atividades econômicas.

1.5.8. LEI DAS EMPRESAS ESTATAIS (LEI 13.303/16)

A Lei 13.303/2016 alterou significativamente a ordem jurídica, trazendo um novo arcabouço jurídico aplicável às empresas estatais, especialmente às licitações, que serão trabalhadas em item específico.

O conceito da nova Lei das Estatais foi evitar o aparelhamento e corrupção, aumentando a transparência e permitindo que elas sejam administradas de forma impessoal, com base numa racionalidade própria do mercado, sem que elas sejam utilizadas para fins políticos. Nesse aspecto, a Lei

⁴⁷ CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de direito administrativo** 32^a ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 561.



das Estatais cria regras para nomeação de dirigentes, como, por exemplo, definindo os critérios que pessoas sem experiência na área ou que não possuam certos requisitos técnicos, não podem preencher certos cargos do conselho de administração das empresas estatais.

Em seus artigos iniciais a Lei nº 13.303/2016 estabelece ser uma lei nacional, aplicável em todos os entes federativos, bem como à todas as espécies de empresas estatais (sociedades de economia mista e empresas públicas), sejam elas exploradoras de atividades econômicas ou prestadoras de serviços públicos. A lei abrange os Correios, a INFRAERO, assim como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, por exemplo.

São estabelecidas regras especiais no que se refere às licitações, facilitando a realização destas. Como visto as empresas governamentais não podem receber privilégios não extensíveis às empresas privadas, em razão do princípio da livre concorrência. Porém, a adoção de procedimentos licitatórios, embora indispensável, engessava as estatais e faziam com que essas perdessem a competitividade. O estatuto jurídico das empresas estatais se inspirou e reproduziu em parte o Regime Diferenciado de Contratações, que permite, por exemplo, contratações mais ágeis e simplificadas, processos menos morosos etc.

Por exemplo, a dispensa de licitação, que na lei 8.666/90 corresponde a 10% ou 20% do valor da carta convite, quando se tratar de uma empresa estatal, o valor é de R\$ 100.000,00 quando se tratar de obras e serviços e R\$ 50.000,00 quando se tratar de compras e serviços.

Ou seja, nessas hipóteses, em se tratando de uma obra de até R\$ 100.000,00 ou de bens e serviços de até R\$ 50.000,00, será dispensável a licitação, não sendo necessário à sua realização, podendo haver contratação direta.

Ademais, a lei permite que os conselhos de administração dessas empresas estatais deliberem por aumentar esse patamar de acordo com a realidade de cada empresa estatal.

Tal mudança legislativa é de grande importância e relevância, tendo concedido, justamente por conta das mudanças que promove no ordenamento jurídico, o prazo de 24 meses para que fossem implementadas.

1.5.9. SUBSIDIÁRIAS

As empresas subsidiárias ou controladas são subdivisões de uma empresa, que se encarregam da execução de tarefas específicas. Trata-se de uma nova empresa, com personalidade jurídica independente da empresa controladora. São disciplinadas pelo Decreto 8.945/2016. Por exemplo, no Brasil a PETROBRAS possui como subsidiárias a TRANSPETRO e a Liquigás.

A empresa pública ou sociedade de economia mista responsável pela constituição de uma empresa subsidiária será conhecida como **sociedade ou empresa de primeiro grau (primária)** e a **subsidiária será conhecida como uma sociedade de economia mista ou empresa pública segundo grau (secundária)**. Essas subsidiárias serão **controladas diretamente pela sociedade ou empresa primária**, mas também sofrerão um **controle indireto pelo ente instituidor da entidade de primeiro grau**.

O art. 37 XX CRFB c/c art. 2º § 2º da Lei nº 13.303/2016 possibilita a criação de empresas subsidiárias, dependendo para tal de autorização legislativa. O STF entende que não será necessário promulgar uma nova lei cada vez que a empresa governamental deseje criar uma subsidiária. Basta que a lei que instituiu a empresa pública ou sociedade de economia mista preveja, de forma genérica, que estas poderão criar subsidiárias, que será possível a criação de quantas controladas a empresa-mãe desejar (ADI 1.649).

Seguindo o mesmo raciocínio o STF decidiu em 2019, na ADI 5.624, que a **venda de subsidiárias de estatais não exige autorização legislativa**. Neste caso, como não há necessidade de lei para cada subsidiária a ser criada, a extinção destas também prescinde de lei específica. Soma-se que a alienação do controle das subsidiárias e das controladas não precisa de prévia licitação. Porém, será indispensável essa alienação cumpra procedimentos que observem os princípios da administração pública inscritos no art. 37 da CF/88, respeitada, sempre, a exigência de necessária competitividade.



O STF entendeu que a alienação de subsidiárias é hipóteses de desinvestimento, ou seja, é alienação de ativos da empresa estatal com a mera intenção de adequação do seu portfólio para que ela possa aperfeiçoar seus objetivos econômicos. Para essa situação a alienação é dispensável por força do art. 29 XVIII da Lei 13.303/2016.

Caso fosse hipótese de desestatização, onde ocorre a alienação da própria estatal-mãe em razão de desistência do Estado na atuação no setor econômico, o procedimento licitatório deve ser realizado, em razão do disposto na Lei nº 9.491/1997.

1.6. CONSÓRCIO PÚBLICO

O art. 241 CRFB estabelece que os entes políticos devem promover uma gestão associada dos serviços públicos, a fim de que sejam poupados, serviços sejam otimizados e o serviço seja mais eficiente.

Disciplinados pela Lei nº 11.107/05 os consórcios públicos são a junção de dois ou mais entes da federação, por meio de uma associação pública ou privada. Visam permitir que uma prestação de serviços ou gestão de determinada atividade seja feita em conjunto. Por exemplo a Autoridade Pública Olímpica, que envolveu o consórcio entre a União o Estado do Rio de Janeiro e o Município do Rio de Janeiro.

O consórcio tem personalidade jurídica própria, logo é uma hipótese de descentralização e sua personalidade jurídica não se confunde com a personalidade jurídica de cada ente que o compõe.

A doutrina debate se os ajustes firmados entre os entes da Administração Pública teriam natureza jurídica de contratos administrativos ou de convênios. Para Hely Lopes Meirelles estes possuem natureza de contrato administrativo⁴⁸, já para Maria Sylvia Zanella Di Pietro⁴⁹ são caracterizados como convênios.

Odete Medauar⁵⁰ destaca que os convênios se caracterizam pela busca de interesses recíprocos e convergentes, e para a realização de objetivos de caráter comum. Assim, segundo a autora, poderiam ser firmados inclusive pelos estes federativos entre si, ou entre estes e particulares. Por exemplo um consórcio entre universidades públicas privadas para que partilhassem o acervo de suas bibliotecas entre os discentes.

Nesta linha o convênio gera obrigações recíprocas, e é caracterizado pelo tipo de resultado que se pretende atingir, sendo similar ao contrato de sociedade no direito privado. Há comunhão de interesses, um fim comum a ser buscado. Podem existir prestações específicas e individualizadas, mas não há interesses individuais, como no contrato.

Para Di Pietro não se deve cogitar de remuneração para os partícipes, assim são incompatíveis com os convênios quaisquer modalidades de cláusulas penais, garantias ou arras. Isso não impede, porém, a presença de cláusulas sobre os valores pecuniários necessários à concretização do ajuste. Questões como repartição de gastos podem ser dispostos no instrumento que institui o convênio. Os convênios seria identificados exatamente pela análise global das cláusulas contidas em seu instrumento de formalização: havendo relação jurídica de coordenação (e não de subordinação) e cooperação (interesse na produção dos mesmos resultados concretos) estaríamos perante um convênio.

Ainda segundo a autora os convênios pressupõem pessoalidade no cumprimento das obrigações: a busca de objetivos comuns exige soma de esforços, tornando a pessoalidade uma característica natural dos convênios administrativos. Sua natureza cooperativa teria o poder de repelir cláusulas de permanência obrigatória.

A própria legislação indicaria a diferença: os contratos administrativos estariam previstos no art. 2º p. único, e art. 6º, XIV e XV, da Lei nº 8.666/93. Já os convênios seriam disciplinados pelo art. 2º e 116 da Lei nº 8.666/93 e pelo Decreto 6.017/17.

O consórcio público sempre terá personalidade jurídica própria, de acordo com o art. 6º da Lei nº 11.107/2005.

⁴⁸ MEIRELLES, Hely Lopes Meirelles. **Direito Administrativo Brasileiro** 43a. edição. São Paulo: Malheiros, 2018.

⁴⁹ DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo** 33ª ed. São Paulo: Gen Forense, 2020. Livro eletrônico não paginado.

⁵⁰ MEDAUAR, Odete. **Direito Administrativo Moderno** 21ª ed. São Paulo: Fórum, 2018.



O Decreto 6.017/07 estabelece que **a União só pode participar de um consórcio público em que também estejam presentes todos os Estados em cujo territórios estejam situados municípios consorciados (art. 1º § 2º).** Por exemplo: um consórcio formado pelos municípios de Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro e Vitória. Para a União integrar esse consórcio, é preciso que os Estados de GO, SP, RJ e ES estejam presentes. O mesmo Decreto determina que **a União celebrará convênios somente com consórcios públicos constituídos sob a forma de associação pública.**

1.6.1. REQUISITOS PARA CONSÓRCIO PÚBLICO

São requisitos para o consórcio público:

- **Celebração necessária de um protocolo de intenções.** O protocolo de intenções deverá ser ratificado por lei ou ter uma autorização legal para ser celebrado. O representante legal do consórcio público deve ser um chefe do poder executivo de qualquer dos entes de federação que estejam consorciados.
- **Constituir pessoa jurídica, seja de direito público ou direito privado.** Sendo de direito público, será denominado de associação pública ou autarquia multifederativa.

1.6.2. PRERROGATIVAS DE UM CONSÓRCIO PÚBLICO

As prerrogativas do consórcio público são:

- Competência para celebrar contratos com entidades públicas ou privadas, receber incentivos públicos, promover desapropriação, emitir documento de cobrança, exercer atividade de arrecadação de tarifa, etc.
- Haverá dispensa de licitação pela própria pessoa da administração direta ou indireta participante do consórcio público. A pessoa jurídica criada pelo consórcio pode celebrar um contrato com dispensa de licitação com uma das demais entidades administrativas que compõem o consórcio.
- Os consórcios públicos, como regra, se submetem ao procedimento de licitação, inclusive para a questão de dispensa de licitação. No entanto, serão **duplicados** os valores de dispensa da modalidade convite, quando houver até três entes consorciados. Caso haja mais de três entes consorciados, este valor de dispensa será **triplicado**.
- A área de atuação do consórcio será relativa à área de atuação dos entes consorciados. Poderá abranger municípios e o DF, por conta da competência municipal.

1.6.3. CONTRATO DE PROGRAMA

O Decreto 6.017/07 conceitua o chamado contrato de programa, estabelecendo que **é o instrumento pelo qual serão constituídas e reguladas as obrigações que o ente da federação e a administração indireta tenham com outro ente da federação; ou obrigações que tenha com o consórcio público, por meio da cooperação federativa.**

O contrato de programa vai regular as obrigações de um ente federado com outro ente federado no âmbito das prestações de serviço público, por meio da cooperação federativa. **Através do contrato de programa poderá ocorrer a transferência parcial ou total de encargos, serviços, pessoal, inclusive de bens necessários à continuidade de serviços transferidos pelo contrato de programa.**

1.6.4. CONTRATO DE RATEIO

O contrato de rateio é a **divisão de despesas**. No contrato de rateio há o instrumento pelo qual entes consorciados irão se comprometer a custear as despesas do objeto do contrato.



O ente consorciado que não consignar na sua lei orçamentária ou crédito adicional dotações suficientes para suportar com as despesas assumidas pelo contrato de rateio pode ser suspenso ou mesmo excluído do consórcio.

E mais, é ato de improbidade administrativa celebrar contrato de rateio de consórcio público sem a suficiente e prévia dotação orçamentária, ou então sem observar formalidades especificadas em lei.

1.7. TESES DO STJ

1.7.1. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

- 1) Aplica-se a prescrição quinquenal do Decreto n. 20.910/32 às empresas públicas e às sociedades de economia mista responsáveis pela prestação de serviços públicos próprios do Estado e que não exploram atividade econômica.
- 2) Inexiste direito à incorporação de vantagens decorrentes do exercício de cargo em comissão ou função de confiança na administração pública indireta.
- 3) As autarquias possuem autonomia administrativa, financeira e personalidade jurídica própria, distinta da entidade política à qual estão vinculadas, razão pela qual seus dirigentes têm legitimidade passiva para figurar como autoridades coatoras em Mandados de Segurança.
- 4) As empresas públicas e as sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos possuem legitimidade ativa *ad causam* para a propositura de pedido de suspensão, quando na defesa de interesse público primário.
- 5) A universidade federal, organizada sob o regime autárquico, não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que visa à repetição de indébito de valores relativos à contribuição previdenciária por ela recolhidos e repassados à União.
- 6) Os Conselhos de Fiscalização Profissionais possuem natureza jurídica de autarquia, sujeitando-se, portanto, ao regime jurídico de direito público.
- 7) O benefício da isenção do preparo, conferido aos entes públicos previstos no art. 4º, caput, da Lei n. 9.289/1996, é inaplicável aos Conselhos de Fiscalização Profissional.
- 8) O arquivamento provisório previsto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, dirigido aos débitos inscritos como dívida ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, não se aplica às execuções fiscais movidas pelos conselhos de fiscalização profissional ou pelas autarquias federais. (Súmula n. 583/STJ)
- 9) Os créditos das autarquias federais preferem aos créditos da Fazenda estadual desde que coexistam penhoras sobre o mesmo bem. (Súmula n. 497/STJ)
- 10) As agências reguladoras podem editar normas e regulamentos no seu âmbito de atuação quando autorizadas por lei.
- 11) Não é possível a aplicação de sanções pecuniárias por sociedade de economia mista, facultado o exercício do poder de polícia fiscalizatório.
- 12) Compete à justiça federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. (Súmula n. 150/STJ)
- 13) Compete à justiça comum estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. (Súmula n. 42/STJ)
- 14) Compete à Justiça ordinária estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista. (Súmula n. 501/STF)



1.7.2. CONSELHOS

- 1) Os conselhos de fiscalização profissionais possuem natureza jurídica de autarquia, sujeitando-se, portanto, ao regime jurídico de direito público.
- 2) Com a suspensão da redação dada pela Emenda Constitucional n. 19/1998 ao *caput* do art. 39 da Constituição Federal de 1988, no julgamento da Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.135/DF, o regime jurídico dos conselhos profissionais deve ser, obrigatoriamente, o estatutário.
- 3) Os servidores dos conselhos de fiscalização profissional submetem-se ao regime jurídico único, de modo que a aposentadoria ocorrida após a publicação das decisões proferidas nas ADI n. 1.717/DF e ADI n. 2.135/DF, esta última em sede de liminar, segue o regime estatutário.
- 4) Os conselhos de fiscalização profissionais não podem registrar seus veículos como oficiais porque compõem a administração pública indireta e o §1º do art. 120 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB autoriza apenas o registro de veículos oficiais da administração direta.
- 5) Os conselhos profissionais têm poder de polícia para fiscalizar as profissões regulamentadas, inclusive no que concerne à cobrança de anuidades e à aplicação de sanções.
- 6) A partir da vigência da Lei n. 12.514/2011, o fato gerador para a cobrança de anuidades de órgão de fiscalização profissional é o registro no conselho e não mais o efetivo exercício da profissão.
- 7) As anuidades devidas aos conselhos profissionais constituem contribuição de interesse das categorias profissionais, de natureza tributária, sujeita a lançamento de ofício.
- 8) O prazo prescricional para cobrança de anuidades pagas aos conselhos profissionais tem início somente quando o total da dívida inscrita atingir o valor mínimo correspondente a 4 (quatro) anuidades, conforme disposto no art. 8º da Lei n. 12.514/2011.
- 9) A Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, embora possua natureza jurídica especialíssima, submete-se ao disposto no art. 8º da Lei n. 12.514/2011, que determina que os conselhos de classe somente executarão dívida de anuidade quando o total do valor inscrito atingir o montante mínimo correspondente a 4 (quatro) anuidades.
- 10) Compete a Justiça Federal processar e julgar execução fiscal promovida por Conselho de Fiscalização Profissional. (Súmula n. 66/STJ)
- 11) Não se aplica o art. 20 da Lei n. 10.552/2002, que determina o arquivamento provisório das execuções de pequeno valor, às execuções fiscais propostas pelos conselhos regionais de fiscalização profissional.
- 12) Em execução fiscal ajuizada por conselho de fiscalização profissional, seu representante judicial possui a prerrogativa de ser pessoalmente intimado. (Tese julgada sob o rito do art. 1.039 do CPC/2015 - TEMA 580)
- 13) O registro no conselho de fiscalização profissional está vinculado à atividade básica ou à natureza dos serviços prestados pela empresa, por força do que dispõe o art. 1º da Lei n. 6.839/1980.
- 14) A atividade fiscalizatória exercida pelos conselhos profissionais, decorrente da delegação do poder de polícia, está inserida no âmbito do direito administrativo, não podendo ser considerada relação de trabalho e, de consequência, não está incluída na esfera de competência da Justiça Trabalhista.
- 15) O benefício da isenção do preparo, conferido aos entes públicos previstos no art. 4º, *caput*, da Lei n. 9.289/1996, é inaplicável aos conselhos de fiscalização profissional.
- 16) A atividade de músico é manifestação artística protegida pela garantia da liberdade de expressão, de modo que a exigência de inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil - OMB, bem como de pagamento de anuidade para o exercício de tal profissão, torna-se incompatível com a Constituição Federal de 1988.
- 17) As empresas de *factoring* convencional não precisam ser registradas nos conselhos regionais de administração, visto que suas atividades são de natureza eminentemente mercantil, ou seja, não envolvem gestões estratégicas, técnicas e programas de execução voltados a um objetivo e ao desenvolvimento de empresa.
- 18) O exame de suficiência instituído pela Lei n. 12.249/2010, que alterou o art. 12, § 2º, do Decreto-Lei n. 9.295/1946, será exigido de contadores e de técnicos em contabilidade que completarem o curso após a vigência daquela lei.



19) O ato do Conselho de Contabilidade, que requisita dos contadores e dos técnicos livros e fichas contábeis de seus clientes, não viola os princípios da privacidade e do sigilo profissional, já que visa à fiscalização da atividade contábil dos profissionais nele inscritos.

20) Os Conselhos Regionais de Farmácia possuem atribuição para fiscalizar e autuar as farmácias e as drogarias quanto ao cumprimento da exigência de manter profissional legalmente habilitado (farmacêutico) durante todo o período de funcionamento dos respectivos estabelecimentos. (Súmula n. 561/STJ) (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - TEMA 715)

21) É facultado aos técnicos de farmácia, regularmente inscritos no Conselho Regional de Farmácia, a assunção de responsabilidade técnica por drogaria, independentemente do preenchimento dos requisitos previstos no art. 15, § 3º, da Lei n. 5.991/1973, c/c o art. 28 do Decreto n. 74.170/1974, entendimento que deve ser aplicado até a entrada em vigor da Lei n. 13.021/2014. (Tese julgada sob o rito do art. 1036 do CPC/2015 - TEMA 727)

22) Não estão sujeitas a registro perante o respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária, nem à contratação de profissionais nele inscritos como responsáveis técnicos, as pessoas jurídicas que explorem as atividades de comercialização de animais vivos e de venda de medicamentos veterinários, pois não são atividades reservadas à atuação privativa de médico veterinário.

23) Não há comando normativo que obrigue a inscrição de professores e de mestres de artes marciais, ou mesmo de danças, de capoeira e de ioga, nos Conselhos de Educação Física, porquanto, à luz do que dispõe o art. 3º da Lei n. 9.696/1998, essas atividades não são próprias dos profissionais de educação física.

24) O registro de restaurantes e de bares no Conselho Regional de Nutrição e a presença de profissional técnico (nutricionista) não são obrigatórios, pois a atividade básica desses estabelecimentos não é a fabricação de alimentos destinados ao consumo humano (art. 18 do Decreto n. 84.444/1980), nem se aproxima do conceito de saúde trazido pela legislação específica.

1.8. JURISPRUDÊNCIA

1.8.1. SÚMULAS DO STF

Súmula Vinculante 52: Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas.

Súmula Vinculante 27: Compete à Justiça Estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a ANATEL não seja litisconsorte passiva necessária, assistente, nem opoente.

Súmula 08: Diretor de sociedade de economia mista pode ser destituído no curso do mandato.

1.8.2. SÚMULAS DO STJ

Súmula 525: A Câmara de vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais.

1.8.3. INFORMATIVOS DO STF⁵¹

Info 966. Plenário. ADI 4579/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 13/2/2020.

⁵¹CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:<<https://www.Buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia>>.



É possível que o chefe do Poder Executivo estadual convide, em consenso com a OAB, um representante da Ordem para integrar órgão da Administração. Isso é válido. No entanto, a lei não pode impor a presença de representante da OAB (“autarquia federal”) em órgão da Administração Pública local.

Info. 946. Plenário. RE 716378/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 1º e 7/8/2019 (repercussão geral).

A qualificação de uma fundação instituída pelo Estado como sujeita ao regime público ou privado depende: i) do estatuto de sua criação ou autorização e ii) das atividades por ela prestadas. As atividades de conteúdo econômico e as passíveis de delegação, quando definidas como objetos de dada fundação, ainda que essa seja instituída ou mantida pelo poder público, podem se submeter ao regime jurídico de direito privado.

Info 943. Plenário. ADI 5624 MC-Ref/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 5 e 6/6/2019.

A alienação do controle acionário de empresas públicas e sociedades de economia mista exige autorização legislativa e licitação. Por outro lado, não se exige autorização legislativa para a alienação do controle de suas subsidiárias e controladas. Nesse caso, a operação pode ser realizada sem a necessidade de licitação, desde que siga procedimentos que observem os princípios da administração pública inscritos no art. 37 da CF/88, respeitada, sempre, a exigência de necessária competitividade.

Info 920. Plenário. ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 17/10/2018.

É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. STF. Plenário. ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/3/2017 (Info 858). É inconstitucional determinação judicial que decreta a constrição de bens de sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos em regime não concorrencial, para fins de pagamento de débitos trabalhistas. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público não concorrencial está sujeita ao regime de precatórios (art. 100 da CF/88) e, por isso, impossibilitada de sofrer constrição judicial de seus bens, rendas e serviços, em respeito ao princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF/88) e da separação funcional dos poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III).

Info. 919. Plenário. RE 589998 ED/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 10/10/2018 (repercussão geral).

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados.

Info 910. 1ª Turma. RE 892727/DF, rel. orig. Min. Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Rosa Weber, julgado em 7/8/2018.

Não se submetem ao regime de precatório as empresas públicas dotadas de personalidade jurídica de direito privado com patrimônio próprio e autonomia administrativa que exerçam atividade econômica sem monopólio e com finalidade de lucro.

Info 889. Plenário. ADI 4874/DF, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 1º/2/2018.

É constitucional o art. 7º, III e XV, da Lei nº 9.782/99, que preveem que compete à ANVISA: III - estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária; XV - proibir a fabricação, a importação, o



armazenamento, a distribuição e a comercialização de produtos e insumos, em caso de violação da legislação pertinente ou de risco iminente à saúde; Entendeu-se que tais normas consagram o poder normativo desta agência reguladora, sendo importante instrumento para a implementação das diretrizes, finalidades, objetivos e princípios expressos na Constituição e na legislação setorial. Além disso, o STF, após empate na votação, manteve a validade da Resolução RDC 14/2012-ANVISA, que proíbe a comercialização no Brasil de cigarros com sabor e aroma. Esta parte do dispositivo não possui eficácia *erga omnes* e efeito vinculante. Significa dizer que, provavelmente, as empresas continuarão ingressando com ações judiciais, em 1ª instância, alegando que a Resolução é inconstitucional e pedindo a liberação da comercialização dos cigarros com aroma. Os juízes e Tribunais estarão livres para, se assim entenderem, declararem inconstitucional a Resolução e autorizar a venda. Existem, inclusive, algumas decisões nesse sentido e que continuam valendo.

Info 861. Plenário. RE 938837/SP, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, julgado em 19/4/2017 (repercussão geral).

Os pagamentos devidos, em razão de pronunciamento judicial, pelos Conselhos de Fiscalização (exs: CREA, CRM, COREN, CRO) não se submetem ao regime de precatórios.

1.8.4. INFORMATIVOS DO STJ⁵²

Info. 615. 1ª Seção. MS 21750-DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 25/10/2017.

A divulgação do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS pela CGU tem mero caráter informativo, não sendo determinante para que os entes federativos impeçam a participação, em licitações, das empresas ali constantes.

Info. 659. REsp 1.318.740-PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Rel. Acd. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, por maioria, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2019

Não é ilegal a terceirização de serviços jurídicos pela Caixa Econômica Federal.

STJ. 2ª Turma. AgRg no AREsp 825776/SC, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 05/04/2016. Não há violação do princípio da legalidade na aplicação de multa previstas em resoluções criadas por agências reguladoras, haja vista que elas foram criadas no intuito de regular, em sentido amplo, os serviços públicos, havendo previsão na legislação ordinária delegando à agência reguladora competência para a edição de normas e regulamentos no seu âmbito de atuação.

QUESTÕES

1. (MP-GO) MP-GO, 2019. Acerca da Administração Indireta do Estado, assinale a alternativa incorreta:

A) As entidades integrantes da Administração Indireta sujeitam-se ao controle finalístico da pessoa política, por meio do órgão da Administração Direta a que estejam vinculadas, em razão do poder hierárquico da pessoa política que as criou.

B) As despesas e receitas das entidades integrantes da Administração Indireta do Estado integram o orçamento fiscal da pessoa política a que estão vinculadas.

⁵²CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:<<https://www.Buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia>>.



- C) Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, as empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos essenciais e próprios do Estado, em condições não concorrenciais, sujeitam-se ao regime de precatórios.
- D) As empresas públicas e as sociedades de economia mista que explorem atividade econômica em sentido estrito não respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros.

2. (TJPA) CESPE/CEBASPE, 2019. Com relação à distinção entre empresa pública e sociedade de economia mista, assinale a opção correta.

- A) Empresa pública é uma entidade privada criada por lei com a finalidade de realizar um serviço público, enquanto a sociedade de economia mista é criada de forma similar às empresas privadas, com a finalidade de exercer atividade econômica.
- B) Empresa pública possui personalidade jurídica de direito público, enquanto a sociedade de economia mista possui personalidade jurídica de direito privado.
- C) Na empresa pública, o capital é exclusivo das pessoas jurídicas de direito público; na sociedade de economia mista, o Poder Público detém a maioria das ações com direito a voto, mas pode haver participação privada no capital.
- D) Na empresa pública, as ações com direito a voto são exclusivas do ente público que a controla; na sociedade de economia mista, o ente público controla a maior parte do capital, mas pode não possuir a maioria das ações com direito a voto.
- E) Na empresa pública, o capital social é inteiramente público; na empresa de economia mista, o Poder Público detém a maioria do capital social da empresa.

3. (TJRO) VUNESP, 2019. O ente personalizado, integrante da Administração Pública indireta, cuja criação é autorizada por lei, mas adquire existência jurídica após o registro dos seus estatutos, é

- A) agência executiva.
- B) fundação de direito privado.
- C) autarquia.
- D) serviço social autônomo.
- E) agência reguladora.

4. (TJAL) FCC, 2019. Considerando as medidas de organização da Administração Pública necessárias para o desempenho de suas atividades, operadas a partir dos mecanismos de desconcentração e de descentralização, nos limites estabelecidos pela Constituição Federal, tem-se que a

- A) desconcentração e a descentralização pressupõem a criação de novos entes, com personalidade jurídica própria, no primeiro caso para execução direta e, no segundo, para execução indireta de atividades públicas.
- B) descentralização por colaboração é utilizada precipuamente para transferência da titularidade de serviços públicos para a iniciativa privada ou organizações do terceiro setor, mediante delegação operada pelos institutos da concessão ou permissão.
- C) criação de órgãos públicos é uma expressão da desconcentração, porém extravasa a competência do Chefe do Executivo para dispor, mediante decreto, sobre organização da Administração, sendo matéria de reserva de lei formal.
- D) desconcentração pressupõe a criação de outros entes públicos ou privados, integrantes da estrutura administrativa, enquanto a descentralização refere-se à mera realocação de competências dentro da estrutura existente.
- E) descentralização ocorre sempre que se cria um novo órgão com plexo de atribuições próprias, o que se insere na competência normativa e regulamentar do Chefe do Executivo para dispor sobre organização administrativa.



5. (TJAL) FCC, 2019. Os consórcios públicos são um instituto relativamente recente, representando uma outra vertente em relação aos mais antigos consórcios administrativos. Referido instituto, tal como atualmente regulado pela legislação federal (Lei nº 11.107/2005),

A) possui uma governança extremamente complexa em decorrência da obrigação de participação da União, como ente consorciado, sempre que estiverem consorciados ao menos dois Estados, ou um Estado e Municípios situados fora do território correspondente.

B) constitui uma alternativa de prestação de serviços públicos utilizada em substituição a contratos de concessão, tendo como diferencial a possibilidade de outorga da titularidade dos serviços de um ente federativo para uma entidade privada consorciada.

C) é obrigatoriamente constituído como pessoa jurídica de direito público, mediante prévia autorização legislativa, não admitindo estabelecimento de vínculo jurídico com entidades privadas para compartilhamento de recursos financeiros.

D) demanda prévia celebração de contrato de rateio entre os entes públicos e os concessionários privados consorciados, com a definição clara das responsabilidades pelos investimentos demandados para a execução de seu objeto.

E) permite a gestão associada de serviços públicos pelos diferentes entes federativos, com a possibilidade de conjugação de recursos fiscais, podendo o consórcio público ser contratado, com dispensa de licitação, por entidades da Administração indireta dos entes consorciados.

COMENTÁRIOS

1. Gabarito – A

O comando da questão solicita assinalar a alternativa incorreta. Sendo assim:

A) Incorreta. O controle ministerial é o poder exercido pelos Ministérios Federais e pelas Secretarias Estaduais e Municipais, sobre órgãos e entidades pertencentes à Administração Pública Indireta. Na descentralização não há subordinação, uma vez que as entidades são dotadas de autonomia.

B) Correta. Cf. art. 165, §5º, I, da CRFB/88.

C) Correta. O STF, nas ADPFs 524 e 530, decidiu que “estão submetidas ao regime constitucional de precatórios as empresas estatais que atuam na ordem econômica prestando serviços públicos e, portanto, próprios do Estado, sem intuito de lucratividade nem caráter concorrencial”.

D) Correta. Cf. art. 37, §6º, da CRFB/88.

2. Gabarito – C

A) Incorreta. Tanto na criação da empresa pública quanto da sociedade de economia mista a lei é meramente autorizativa, dependendo do registro dos atos constitutivos no órgão competente.

B) Incorreta. Segundo a Lei nº 13.303/2016 ambas estatais possuem natureza jurídica de direito privado, e não de direito público.

C) Correta.

D) Incorreta. Nas sociedades de economia mista a maioria das ações com direito a voto devem pertencer ao ente público.

E) Incorreta. Nas sociedades de economia mista o Poder Público não precisa deter a maior parte do capital social, e sim a maioria das ações com direito a voto devem pertencer ao ente público.

3. Gabarito – B

A) Incorreta. A Agência Executiva é uma qualificação dada a uma autarquia ou fundação pública de direito público.

B) Correta. A lei poderá criar diretamente ou autorizar a criação de uma fundação pública. Na segunda hipótese os atos constitutivos deverão ser inscritos no registro civil das pessoas jurídicas, sendo assim uma fundação pública de direito privado.

C) Incorreta. A autarquia é instituída diretamente pela lei e sua personalidade jurídica tem início com a vigência da lei criadora.



D) Incorreta. O serviço social autônomo faz parte do terceiro setor, que não compõe a Administração Pública.

E) Incorreta. A Agência Reguladora é uma autarquia especial, logo é instituída diretamente pela lei e sua personalidade jurídica tem início com a vigência da lei criadora.

4. Gabarito – C

A) Incorreta. Na desconcentração há a criação de órgãos públicos que integram a estrutura interna da Administração Pública direta. Já na descentralização cria-se a outras entidades dotadas de personalidade jurídica própria, integrando a Administração Pública indireta.

B) Incorreta. Na descentralização por colaboração transfere-se apenas da execução da atividade, permanecendo a titularidade com o Poder Público (caso das concessionárias e permissionárias de serviço público). Já na descentralização por outorga há a transferência da titularidade e da execução do serviço público, por exemplo para as entidades da Administração indireta.

C) Correta. Cf. art. 84, VI, "a" CRFB/88.

D) Incorreta. A alternativa trocou os conceitos de desconcentração e descentralização.

E) Incorreta. A afirmação se refere ao conceito de desconcentração administrativa.

5. Gabarito – E

A) Incorreta. Cf. art. 1º, § 2º, da Lei 11.107/05.

B) Incorreta. Cf. art. 241 CRFB/88.

C) Incorreta. Cf. art. 1º, § 1º, da Lei 11.107/05.

D) Incorreta. Os entes públicos, no consórcio público, firmam o protocolo de intenções, que deverá ser remetido ao Poder Legislativo de cada um dos entes consorciados. que após ratificado, será formalizado o consórcio. O contrato de rateio não é indispensável na criação do consórcio, e só será exigido quando o objetivo for transferência de recursos do ente consorciado ao consórcio público.

E) Correta. Cf. o art. 2º, § 1º, III, da Lei 11.107/05.



CAPÍTULO 4 — TERCEIRO SETOR E ENTES DE COOPERAÇÃO

Para entender o terceiro setor, é interessante esclarecer quais são os demais. O primeiro setor é o Estado, e segundo a iniciativa privada / mercado. No terceiro estão organismos, instituições ou organizações sem fins lucrativos que realizam projetos de interesse do Estado. Atuam em áreas que não são de atuação exclusiva do Poder Público, com o objetivo de atuar junto à sociedade, visando o seu melhoramento.

Os entes de cooperação não integram a administração indireta e compreendem:

- Serviços Sociais Autônomos (Sistema S)
- Entidades de Apoio
- Organizações Sociais (OS)
- Organizações da Sociedade Civil de Serviço Público (OSCIP)

Ronny Charles⁵³ prefere inserir essas últimas duas entidades (OS e OSCIP) dentro do **terceiro setor**, que para ele inclui:

- **Organizações Sociais (OS)**
- **Organizações da Sociedade Civil de Serviço Público (OSCIP)**
- **Entidades de Utilidade Pública Federal (UPF)**
- **Entidades com certificado de entidades beneficentes de assistência social (CEBAS)**
- **Instituições Comunitárias de Ensino Superior (ICES)**

É bom ressaltar que existem autores que se utilizam a expressão **terceiro setor como sinônimo de entes de cooperação**. De toda sorte, a Lei nº 13.019/14, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a Administração Pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco.

Importante ter em mente que essas pessoas jurídicas não pertencem ao Estado, e em regra se submetem ao regime jurídico de direito privado. O terceiro setor está em uma área intermediária, em princípio privada, mas que se volta para a consecução de atividades privadas e auxilia o estado na consecução do interesse público e na realização de atividades que beneficiam a coletividade.

Embora não integrem a administração pública, alguns entes do terceiro setor **recebem fomento estatal** e inclusive **podem ser mantidos por recursos orçamentários ou contribuições parafiscais**, que servem para custeio de atividades realizadas por entidade privada que não integram funções próprias do Estado, mas que tenham finalidade pública. São **entidades paraestatais**, pois atuam ao lado do Estado.

Existiu uma longa discussão quanto à submissão dessas entidades ao regime jurídico administrativo, que hoje estão pacificadas. Di Pietro⁵⁴ já sustentava que os integrantes do terceiro setor são “predominantemente de direito privado, mas parcialmente derogado por normas de direito público”. O STF, na ADI 1923/DF, determinou que trata-se de um regime híbrido: por receberem recursos públicos, bens públicos e servidores públicos, o regime jurídico das organizações sociais tem de ser minimamente informado pela incidência dos princípios da Administração Pública (CF, art. 37, caput). Resumidamente:

- Não há obrigatoriedade de licitação;
- Apesar de afastado o dever de licitar, os princípios administrativos devem ser observados;
- As compras e contratações com emprego de recursos públicos devem ocorrer mediante regulamento próprio, com a devida publicidade e pautados pelos princípios administrativos;
- Os contratos de trabalho destas instituições são regidos pela CLT.

⁵³TORRES, Ronny Charles Lopes de. Terceiro Setor: entre a liberdade e o controle. Salvador: Juspodivm, 2013.

⁵⁴DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo** 33ª ed. São Paulo: Gen Forense, 2020. Livro eletrônico não paginado.



O Estado e o terceiro setor firmam parcerias, ações públicas para aprimorar projetos e prestação de serviços de interesse da sociedade. São os acordos administrativos colaborativos que segundo Justino de Oliveira “tem por fim instituir vínculos de colaboração entre o Estado e a sociedade civil. A finalidade desses vínculos colaborativos é promover a efetivação do direito ao desenvolvimento, principalmente por meio da realização de serviços sociais”⁵⁵.

É na concepção de parceria da administração pública com a sociedade civil é que vai nascer este terceiro setor. O grande diferencial entre o terceiro setor e os demais entes de cooperação é de que **o terceiro setor realiza as atividades independentemente da vontade estatal**. São justamente as suas atividades que vão justificar a iniciativa do estado de fomentar essas atividades, por meio de parcerias. **As entidades do terceiro setor não são criadas por lei.**

Fazem parte do terceiro setor as entidades que cumulativamente apresentem as seguintes características:

- Pertencer à iniciativa privada, nem direta ou indiretamente.
- Não ter finalidade lucrativa.
- Dotadas de personalidade jurídica.
- Exercer atividades voluntária.

São **elementos essenciais** para caracterização do terceiro setor:

- Origem privada, fora do estado.
- Inexistência de finalidade lucrativa.
- Objetivos e ações devem envolver atividades de interesse público.

Existem outras entidades paraestatais que contribuem para a persecução de finalidades públicas, como as entidades fechadas. Existe uma **diferença entre terceiro setor e entidade fechada**. Na **entidade fechada**, a atuação está restrita a determinado grupo social, voltada aos seus interesses (associações de classe, sindicatos, clubes, etc.). Alguns autores entendem que as entidades fechadas poderiam ser inseridas dentro do terceiro setor, mas, na verdade, não poderiam. Isso porque **as entidades fechadas têm diferentes finalidades**.

No **terceiro setor**, há interesses altruísticos que estão sendo defendidos, mas nas entidades fechadas realizam a atividade não em prol da coletividade, e sim da categoria. O terceiro setor quer finalidades públicas e não a determinados grupos da coletividade.

Começaremos a análise pelas entidades paraestatais, para finalizar com

1. ENTIDADES DE APOIO

As entidades de apoio também são pessoas jurídicas de direito privado e não tem finalidade lucrativa, exercendo **atividades não exclusivos de Estado**, mas **relacionados à ciência, pesquisa, saúde e educação**.

Di Pietro esclarece que as entidades de apoio são muitas vezes criadas por servidores públicos via meio de fundação ou associação, ou ainda cooperativas. A Lei nº 8.958/94 regula as relações entre as instituições federais de ensino superior e as fundações de apoio.

As **instituições federais de ensino superior (IFES)** e as demais **instituições científicas tecnológicas (ICT)** podem celebrar convênios e contratos com prazo determinado com as fundações instituídas para apoiar projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico, tecnológico, de estímulo à inovação, inclusive para a gestão administrativa e financeira que se mostre necessária para execução dos projetos. São, por exemplo, as entidades de apoio contratadas para realizar concurso público ou vestibular.

⁵⁵ OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público: termo de parceria e licitação. In Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado. Salvador: Instituto de Direito Público da Bahia, n.º 2, junho/julho/agosto de 2005.



A entidade de apoio será constituída sob a forma de uma **fundação de direito privado**, motivo pelo qual terão patrimônio próprio e administração própria. **Não precisam realizar licitação**, e há ainda hipóteses de **dispensa de licitação para contratação pela administração pública** de entidades de apoio brasileira, e que se destine a pesquisa, ensino ou desenvolvimento institucional, **desde que tenha inquestionável reputação ética e profissional**.

O regime de pessoal das entidades de apoio é **celetista**. Logo não há necessidade de contratação por meio de concurso público.

É vedada a subcontratação total do objeto de ajuste realizado entre uma instituição de ensino superior com a entidades de apoio, bem como é vedada a contratação parcial que delegue o núcleo do objeto contratual. A fundação deve ser apta à realização desse serviço.

2. CERTIFICADO DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL (UPF)

Estão inseridas dentro do terceiro setor, e trata-se de uma entidade que recebe um certificado de utilidade pública federal.

Este certificado estava inicialmente previsto na Lei 91/1935. Esta determinava regras para que as sociedades civis pudessem ser declaradas de utilidade pública (existência de personalidade jurídica, diretoria e conselhos não sejam remunerados e efetivo funcionamento e exercício desinteressado da sociedade). A Lei de 1935 foi revogada pela Lei nº 13.204/2015. Mesmo antes disso entendia-se que como os requisitos exigidos para o certificado de utilidade pública eram simples, o que impediria que estas fossem consideradas parte do terceiro setor.

3. ENTIDADES COM CERTIFICADO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS)

A conferência desse título permite imunidade tributária em relação a impostos (Art. 150, VI, “c” CRFB) e contribuições para a seguridade social (Art. 195, §7º CRFB). A Lei 12.101/09 impõe os requisitos para a concessão da certificação de entidade beneficentes de assistência social:

- Pessoas jurídicas de direito privado
- Que não tenham fins lucrativos
- Que sejam reconhecidas como entidades beneficente de assistência social
- Devem ter atividades prestadas na área de assistência social, saúde e educação
- Atender aos requisitos legais

O CEBAS será conferido à entidades que atuam nas áreas de saúde, educação e assistência social (art. 21, I a III, da Lei 12.101/09), através dos Ministérios das respectivas pastas. Por exemplo uma entidade que atua na área da saúde terão CEBAS conferido pelo Ministério da Saúde. A certificação tem um **prazo de 01 a 05 anos**, podendo ser renovado.

Em dezembro de 2019 o STF decidiu que é constitucional a exigência do CEBAS – Certificação de Entidades Benéficas de Assistência Social como requisito para fruição da imunidade tributária às contribuições para a seguridade social, ainda que esteja previsto em lei ordinária (RE 566.622). De acordo com o acórdão, os aspectos procedimentais da imunidade, relacionados à certificação, à fiscalização e ao controle das entidades beneficentes de assistência social podem ser regulamentados por lei ordinária; a lei complementar é exigida apenas para pode estabelecer as contrapartidas para que as entidades usufruam da imunidade tributária prevista na CRFB, de acordo com o art. 195, § 7º.

O STF entende que **o certificado de entidades de fins filantrópicos é um mero reconhecimento pelo Poder Público do preenchimento das condições**, situação na qual **receberá o benefício constitucional da imunidade**.



Questionou-se se seria constitucional exigir a renovação da certificação ao término do prazo, e o STF entendeu que é constitucional a exigência da renovação periódica (ADI 4.891 e MS30.576).

O STJ trouxe a Súmula 352, a qual diz que a obtenção ou a renovação do certificado de entidade beneficente de assistência social não exige a necessidade de cumprimento dos requisitos legais supervenientes.

Para obter o CEBAS, é necessidade que a entidade atendas aos seguintes requisitos:

- **Diretor, conselheiro ou sócio não devem receber remuneração, vantagem ou benefício.** A exceção se refere aos dirigentes que exerçam a gestão executiva da empresa. Já há inclusive lei afirmando que devem ser remunerados, mas deverá ter o limite máximo os valores praticados no mercado.
- **Aplicação de recursos, resultados positivos ou lucros integralmente no território nacional e na manutenção de seus objetivos institucionais.**
- **É preciso que a entidade conserve em bom estado, pelo prazo de 10 anos, contados da data da emissão, que comprovem a origem dos recursos aplicados.**
- **Entidade precisa cumprir as obrigações tributárias acessórias.**

4. INSTITUIÇÕES COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR (ICES)

São as instituições de Ensino Superior, reguladas pela Lei nº 12.881/2013, que cumprem as características abaixo, cumulativamente:

- Devem ser constituídas sob a forma de **associação ou fundação**;
- **Sem fins lucrativos**;
- **Adotam instrumentos de transparência** administrativa
- **Seu patrimônio, em caso de extinção, será destinado para outra instituição**, seja pública ou privada, desde que voltada para a educação superior.

A ICES deve ofertar serviços gratuitos à população, voltado ao desenvolvimento dos alunos ou da sociedade. A qualificação como ICES **permite que ela receba recursos orçamentários**. Por isso o dever de transparência.

A intitulação de ICES à uma entidade é o **Ministério da Educação**. **O Ministério tem 30 dias para decidir sobre o deferimento ou indeferimento**. Deferindo, haverá o prazo de 15 dias para emitir o certificado.

A qualificação da ICES é um **ato vinculado** ao cumprimento dos requisitos legais, não havendo discricionariedade.

5. SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMO (SISTEMA “S”)

Os serviços sociais autônomos são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, criados por lei, que **prestam atividade de interesse público em favor de certas categorias**, sejam sociais ou profissionais. Por exemplo o Serviço Social da Indústria (SESI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). São regulados pela nº 9.637/98.

As entidades dos Terceiro Setor são custeadas por tributos (contribuições especiais). Portanto submetem-se ao controle do Tribunal de Contas.

Ainda que não tenham a obrigação de licitar e de realizar concursos públicos devem contratar com observação dos princípios da administração: a contratação será por meio de processo seletivo minimamente impessoal e que respeite os ditames da moralidade, legalidade, publicidade e eficiência.

As organizações sociais firmam Contrato de Gestão para a colaboração com o Estado, regulados pela Lei nº 9.637/98.



Nos serviços sociais autônomos há uma **incidência parcial do regime jurídico público**, mas há algumas características específicas:

- Via de regra, **não estão sujeitos à necessidade de observar a Lei de Licitações**, podendo utilizar os seus próprios regimentos, mas deverão observar os princípios gerais da administração pública, por conta da destinação de recursos públicos.
- Em relação ao regime de pessoal, o **regime será trabalhista**.
- **O STF não exige a observância de concurso público**, já que são entidades do setor privado.
- São **criados através de lei**, possibilitando às respectivas confederações nacionais a constituir formalmente os serviços sociais autônomos, sob uma das formas jurídicas admitidas: fundação, associação etc.

ORGANIZAÇÃO SOCIAL (OS)

Segundo a Lei nº 9.637/98, o Poder Executivo pode qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado quando:

- Não tiverem fins lucrativos
- Tenham por finalidade desenvolver o ensino, pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico, preservação do meio ambiental, cultura e saúde.

A aprovação da qualificação como organização social se insere na **competência discricionária** do Ministério responsável ao objeto social da pessoa jurídica, bem como ao Ministério do Planejamento.

A Lei 9.637/98 exige a permanência no controle da organização de representantes do Estado. Portanto, a **OS deverá ter no mínimo 20% de participação do Poder Público, podendo chegar em até 40%**.

Deverá ser firmado um contrato de gestão, igualmente previsto pela Lei nº 9.637/98. O **contrato de gestão** é um contrato firmado entre o Poder Público e a entidade classificada como OS. A ideia do contrato de gestão é **fomentar a execução de atividades** relativas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, preservação do meio ambiental, cultura, saúde, etc. O contrato de gestão **discrimina as atribuições, responsabilidade e obrigações do Poder Público e da organização social**. No entanto, o contrato de gestão estabelece metas, bem como objetivos, os quais deverão fixar critérios para avaliação do cumprimento dessas metas pela organização social.

Feito o contrato, ele é submetido à aprovação do conselho de administração da organização social. **Aprovado o contrato de gestão, será submetido ao Ministro de Estado respectivo, ou a uma autoridade supervisora da correspondente área de atividade para aprová-lo.**

As organizações sociais podem receber **recursos orçamentários e bens públicos** para o cumprimento do contrato de gestão (art. 12 e 14 Lei 9.637/98).

O Poder Público também poderá desqualificar essa entidade, retirando o grau de OS, quando ficar constatado que a entidade descumpriu o contrato de gestão firmado.

Atente-se que **a organização social não precisa seguir a Lei de Licitações**. O art. 17 da Lei 9.637/98 diz que a organização social fará publicar, **no prazo máximo de 90 dias contado da assinatura do contrato de gestão**, regulamento dos procedimentos que adotará para a contratação de obras e serviços, bem como para compras com emprego de recursos públicos. Ainda, **existem hipóteses de dispensa licitatória para celebração de contrato de prestação de serviços com as organizações sociais para atividades contempladas no contrato de gestão**.

7. ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO (OSCIP)

As OSCIP's são reguladas pela Lei nº 9.790/99. **A OSCIP não é uma pessoa jurídica, mas uma qualificação que uma pessoa jurídica recebe, desde que não tenham fins lucrativos**. Sua finalidade é realizar determinadas atividades sociais. Mas essas atividades sociais estão elencadas na Lei.

A qualificação como OSCIP **só é conferida a pessoas jurídicas que tenham objetivos sociais com pelo menos uma das finalidades previstas em lei:**

- Promoção da assistência social;
- Promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico;
- Promoção gratuita da educação, observando-se a forma complementar de participação das organizações de que trata esta Lei;
- Promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de participação das organizações de que trata esta Lei;
- Promoção da segurança alimentar e nutricional;
- Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável;
- Promoção do voluntariado;
- Promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza;
- Experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-produtivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito;
- Promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar;
- Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais;
- Estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às atividades mencionadas neste artigo.
- Estudos e pesquisas para o desenvolvimento, a disponibilização e a implementação de tecnologias voltadas à mobilidade de pessoas, por qualquer meio de transporte.

Por outro lado, **não poderão ser consideradas como OSCIP:**

- as sociedades comerciais;
- os sindicatos, as associações de classe ou de representação de categoria profissional;
- as instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de credos, cultos, práticas e visões devocionais e confessionais;
- as organizações partidárias e assemelhadas, inclusive suas fundações;
- as entidades de benefício mútuo destinadas a proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito de associados ou sócios;
- as entidades e empresas que comercializam planos de saúde e assemelhados;
- as instituições hospitalares privadas não gratuitas e suas mantenedoras;
- as escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito e suas mantenedoras;
- as **organizações sociais**;
- as cooperativas;
- as fundações públicas;
- as fundações, sociedades civis ou associações de direito privado criadas por órgão público ou por fundações públicas;
- as organizações creditícias que tenham quaisquer tipos de vinculação com o sistema financeiro nacional a que se refere o art. 192 da Constituição Federal.

A qualificação na OSCIP, diferentemente da OS, trata-se de um **ato vinculado**. O requerimento da qualificação é **formulado ao Ministro da Justiça**. A lei traz um prazo de **30 dias para deferimento ou indeferimento** do Ministro da Justiça. Em caso de deferimento, o prazo para emissão do certificado é de **15 dias**.

A **perda da qualificação** da OSCIP se dá:



- a pedido da entidade (perda voluntária);
- por processo administrativo;
- por processo judicial.

Também nas OSCIP's é permitido participação de servidores públicos na composição do conselho.

O instrumento entre a OSCIP e o Poder Público é denominado **termo de parceria**, igualmente previsto pela Lei nº 9.790. Com isso, a OSCIP passa a exercer atividades que não sejam exclusivas do Estado. O termo de parceria **permite a destinação de recursos públicos** à OSCIP.

Caso a OSCIP adquira bem imóvel com recursos públicos do termo de parceria, o bem adquirido será **gravado com cláusula de inalienabilidade**, não podendo ser vendido.

A OSCIP também não precisa seguir o rito estrito da lei de licitações. O art. 14 da Lei 9.790 vai dizer que a organização parceira fará publicar, no prazo máximo de **30 dias**, contado da assinatura do Termo de Parceria, o regulamento que vai explicar os procedimentos para a contratação de obras e serviços, bem como para compras com emprego de recursos provenientes do Poder Público.

8. A LEI 13.019/14 E AS PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

A Lei 13.019/14 estabelece o conceito de organização da sociedade civil, compreendendo:

- Entidades privadas sem fins lucrativos
- Sociedades cooperativas que sejam integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade, ou voltadas para o fomento, educação, capacitação de trabalhadores rurais, ou sociedade cooperativas capacitadas para o exercício de atividade de interesse público
- Organizações religiosas que se dediquem a atividades e projetos de interesse público, de cunho social, diferente das destinadas exclusivamente para fins religiosos (ex.: creche, abrigo, alimentação dos pobres, etc.).

A Lei 13.019/14 trouxe uma ampliação do rol de entidades da sociedade civil que podem firmar parcerias com o Estado. A Lei prevê os seguintes **instrumentos de parceria** que podem ser firmados com o Poder Público:

- **Termo de colaboração:** é um instrumento em que são formalizadas **parcerias propostas pela administração pública**, que envolvem a **transferência de recursos públicos**. Quem propõe a parceria é o Poder Público.
- **Termo de fomento:** é um instrumento em que são formalizadas parcerias **propostas pela organização da sociedade civil**, que envolvem a **transferência de recursos públicos**. Quem propõe a parceria é a organização civil.
- **Acordo de cooperação:** é um termo de parceria firmado, não importando se quem opôs foi o Poder Público ou a organização da sociedade civil. O que caracteriza o acordo de cooperação é que **não envolve a transferência de recursos públicos**.

A Lei nº 13.800/2019 dispõe que fundações de apoio credenciadas na forma da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, equiparam-se às organizações gestoras definidas no inciso II do caput deste artigo, podendo realizar a gestão dos fundos patrimoniais instituídos por esta Lei, desde que as doações sejam geridas e destinadas em conformidade com esta Lei.

9. CHAMAMENTO PÚBLICO

O **chamamento público** é o procedimento destinado a selecionar a organização da sociedade civil que irá firmar uma parceria com o Poder Público. Haverá o chamamento de entidades interessadas, que



apresentam as suas propostas. Estas são julgadas por uma **comissão de seleção**, com **pelo menos 01 servidor de cargo efetivo ou emprego público permanente**.

A administração pública **pode dispensar o chamamento público** em algumas situações:

- **Quando a peculiaridade do caso exigir** (ex.: urgência porque houve a paralisação de atividades de relevante interesse público ou iminência de paralisação), ficando formalizado o termo de parceria com a sociedade civil pelo **prazo de 180 dias**.
- **Estiver em situação de guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem pública**, pois excepcionalidade da situação dispensa o chamamento público.

Por outro lado, o **chamamento público pode ser inexigível**:

- **Quando a competição entre as organizações da sociedade civil é inviável**, em razão da natureza singular do objeto da parceria.
- **Quando as metas somente puderem ser atingidas por certa entidade específica**. Isso será claro nos casos de tecnologia.

10. DIFERENÇAS ENTRE OSCIP'S E OS'S

De forma breve cabe diferenciar as duas entidades.

As Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público são disciplinadas pela Lei nº 9.790/99.

- O Ministério da Justiça confere título de OSCIP, que vale para todo o território nacional.
- A qualificação como OSCIP é um ato vinculado, uma vez preenchidos os requisitos, a entidade pode exigir o certificado.
- Firmam Termos de Parceria com a Administração Pública.
- A posterior desqualificação prejudica qualquer Termo de Parceria vigente em território nacional e a impede de firmar novos.
- Há necessidade de concurso de projetos (art. 23 do Decreto 3.100/1999).

Já as Organizações Sociais são reguladas pela Lei nº 9.637/98, e atuam nas áreas ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde.

- Cada ente federativo deve ter legislação própria para poder qualificar entidades como OS.
- A qualificação como OS é um ato discricionário do chefe do Poder Executivo.
- A desqualificação posterior prejudica a entidade apenas perante aquele determinado ente federado, não afetando a continuidade de suas atividades junto aos demais.
- Firmam Contratos de Gestão com a Administração Pública.
- Há possibilidade de dispensa de licitação pública (art. 24, XXIV, Lei 8.666/1993)
- Devem adotar procedimento público, pessoal e objetivo.

11. QUARTO SETOR

Alguns doutrinadores, como Ricardo Alexandre e João de Deus⁵⁶ entendem que existe um quarto setor, à margem dos demais setores. **Esse seria caracterizado pela informalidade** e incluiria atividades como comércio informal e “bicos”, mas também incluiria o exercício de atividades ilícitas como o tráfico de drogas, a corrupção, a lavagem de dinheiro etc.

⁵⁶ ALEXANDRE, Ricardo; DE DEUS, João de Deus. Direito Administrativo Esquematizado 3ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017.



Fernanda Marinela⁵⁷ observa que o quarto setor está infiltrado dentro dos demais. No primeiro setor (Estado) está infiltrado como quarto setor a corrupção. No segundo setor (Privado), há mercadorias falsificadas, combustíveis adulterados, etc. No terceiro setor (Entes de Cooperação) há inúmeras instituições que são apenas de fachadas.

Percebe-se que o quarto setor é um setor informal, mas que destrói, em parte, os demais setores.

Ronny Charles entende que estas informalidades não poderiam ser tidas como um quarto setor, pois seriam disfunções dentro de cada setor.

12. JURISPRUDÊNCIA

12.1. INFORMATIVOS DO STJ⁵⁸

STJ, Info 646. 1ª Seção. EREsp 1.619.954-SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 10/04/2019.

As entidades dos serviços sociais autônomos não possuem legitimidade passiva nas ações judiciais em que se discute a relação jurídico-tributária entre o contribuinte e a União e a repetição de indébito das contribuições sociais recolhidas. Os serviços sociais são meros destinatários de subvenção econômica e, como pessoas jurídicas de direito privado, não participam diretamente da relação jurídico-tributária entre contribuinte e ente federado. O direito que tais entidades possuem à receita decorrente da subvenção não gera interesse jurídico a ponto de justificar a ocorrência de litisconsórcio com a União. O interesse dos serviços sociais autônomos nesta lide é reflexo e meramente econômico.

QUESTÕES

1. (TJSC) CESPE/CEBRASPE, 2109. A respeito de organizações sociais, assinale a opção correta considerando o entendimento do STF em sede de controle concentrado.

- A) É inconstitucional a previsão legal de cessão de servidor público a organização social: essa hipótese configura desvio de função.
- B) O contrato de gestão não configura hipótese de convênio, uma vez que prevê negócio jurídico de natureza comutativa e se submete ao mesmo regime jurídico dos contratos administrativos.
- C) As organizações sociais, por integrarem o terceiro setor, integram a administração pública, razão pela qual devem submeter-se, em suas contratações com terceiros, ao dever de licitar.
- D) O indeferimento do requerimento de qualificação da organização social deve ser pautado pela publicidade, transparência e motivação, mas não precisa observar critérios objetivos, devendo ser respeitada a ampla margem de discricionariedade do Poder Público.
- E) A qualificação da entidade como organização social configura hipótese de simples credenciamento, o qual não exige licitação em razão da ausência de competição.

2. (PGE-SC) FEPESE, 2018. Atendidos os requisitos previstos na atual Lei 9.637/1998, o Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas:

- 1. ao ensino.
- 2. à segurança pública.
- 3. à pesquisa científica.
- 4. ao desenvolvimento tecnológico.

⁵⁷MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 297.

⁵⁸CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.Buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia>>.



Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- A) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- B) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- C) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- D) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- E) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

3. (DPE-PE) CESPE, 2018. Considerando-se as novas formas de desestatização da prestação de serviços públicos de caráter social, as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que, atendidos os requisitos previstos em lei, firmam parceria com o Poder Público, por instrumento de contrato de gestão, para a execução de atividades de interesse público — especialmente ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde — recebem a qualificação de

- A) agência executiva.
- B) fundação pública.
- C) organização social.
- D) organização da sociedade civil de interesse público.
- E) serviço social autônomo.

4. (DPE-AL) CESPE, 2017. Os serviços sociais autônomos

- A) são beneficiados pelos privilégios processuais de dilação de prazo recursal.
- B) devem ser criados mediante autorização por lei.
- C) são alcançados pelos sistemas de precatórios.
- D) possuem personalidade jurídica de direito público.
- E) estão obrigados a realizar procedimentos licitatórios

5. (DPE-AC) CESPE/CEBRASPE, 2017. Acerca dos serviços sociais autônomos, julgue os itens a seguir.

I. As entidades de cooperação governamental, às quais são destinados recursos oriundos de contribuições para-fiscais, têm por finalidade desenvolver atividade social que represente a prestação de serviço de utilidade pública em benefício de certos grupamentos sociais ou profissionais.

II. As entidades de cooperação governamental não integram a estrutura da administração pública indireta, e, dada a natureza jurídica de direito privado que ostentam, não se submetem ao controle do tribunal de contas.

III. Conforme entendimento do STF, as entidades de serviços sociais autônomos integrantes do sistema “S” não se submetem à exigência do concurso público para a contratação de pessoal.

IV. As entidades de serviços sociais autônomos submetem-se a licitações para a realização de contratações, em cumprimento aos estritos termos da Lei n.º 8.666/1993.

Estão certos apenas os itens

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e IV.
- D) I, III e IV.
- E) II, III e IV.

COMENTÁRIOS

1. Gabarito – E

A) Incorreta. Cf. art. 14 da Lei nº 9.637 de 1998.



@cpiuris



www.cpiuris.com.br



contato@cpiuris.com.br



B) Incorreta. O contrato de gestão é instrumento que formaliza o vínculo entre os pactuantes, estabelece os objetivos do ajuste e define os direitos e as obrigações dos signatários, não se assemelhando a um contrato administrativo, uma vez que não há a previsão da adoção de cláusulas exorbitantes.

C) Incorreta. As organizações sociais não se submetem ao dever de licitar nos moldes da Lei nº 8.666/93. Segundo o STF “as organizações sociais, por integrarem o Terceiro Setor, não fazem parte do conceito constitucional de Administração Pública, razão pela qual não se submetem, em suas contratações com terceiros, ao dever de licitar, o que consistiria em quebra lógica de flexibilidade do setor privado, finalidade por detrás de todo marco regulatório instituído por Lei” (ADI 1.923).

D) Incorreta. De acordo com o STF “a previsão de competência discricionária no art. 2º, II, da Lei nº 9.637/98 no que pertine à qualificação tem de ser interpretada sob o influxo da principiologia constitucional, em especial dos princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (CF, art. 37, caput). É de se ter por vedada, assim, qualquer forma de arbitrariedade, de modo que o indeferimento do requerimento de qualificação, além de pautado pela publicidade, transparência e motivação, deve observar critérios objetivos fixados em ato regulamentar expedido em obediência ao art. 20 da Lei nº 9.637/98, concretizando de forma homogênea as diretrizes contidas nos incisos I a III do dispositivo”. (ADI 1.923).

E) Correta. Segundo o STF “A atribuição de título jurídico de legitimação da entidade através da qualificação configura hipótese de credenciamento, no qual não incide a licitação pela própria natureza jurídica do ato, que não é contrato, e pela inexistência de qualquer competição, já que todos os interessados podem alcançar o mesmo objetivo, de modo includente, e não excludente”. (ADI 1.923).

2. Gabarito – C

Segundo o STF “A atividade policial é carreira de Estado imprescindível à manutenção da normalidade democrática, sendo impossível sua complementação ou substituição pela atividade privada.” (ARE 654432/GO). As instituições que prestam serviços de segurança pública estão dispostas em rol taxativo no art. 144 CRFB/88, onde não consta as organizações sociais. Na mesma linha o art. 1º da Lei 9.637/98 estabelece que o Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde. Sendo assim estão incorretas as alternativas A, B, D e E, que listam a segurança pública.

3. Gabarito – C

A) Incorreta. A agência executiva é a qualificação que o Poder Público confere a determinadas entidades, e não um novo tipo de pessoa jurídica.

B) Incorreta. A fundação pública é instituída por lei, tendo regime jurídico de direito público, similar ao adotado pelas autarquias.

C) Correta. Cf. o art. 1º da Lei nº 9.637/98.

D) Incorreta. As OSCIP's são organizações sem fins lucrativos voltadas à resolução de problemas coletivos de interesse social, podendo prestar serviços públicos através de celebração de termo de parceria, na forma da Lei nº 9.790/98.

E) Incorreta. O Serviço Social Autônomo é um ente de cooperação com o Poder Público.

4. Gabarito – B

A) Incorreta. Os serviços sociais autônomos não pertencem à Administração Pública direta ou indireta, logo não possuem os privilégios da Fazenda Pública em juízo.

B) Correta.

C) Incorreta. Os serviços sociais autônomos não pertencem à Administração Pública direta ou indireta, logo não estão sujeitos ao regime de precatórios.

D) Incorreta. O terceiro setor não integra a Administração Pública, logo possuem personalidade jurídica de direito privado.

E) Incorreta. Cf. STF, ADI 1.923/DF e TCU Acórdão 3239/2013.

5. Gabarito – B

I - Correta

II – Incorreta. As entidades de cooperação governamental recebem recursos públicos estão sujeitos a fiscalização dos Tribunais de Contas.

III – Correta.

IV – Incorreta. As entidades de serviços sociais autônomos não estão obrigadas a licitar conforme o procedimento estabelecido pela Lei nº 8.666/93, porém, deverão contratar segundo os critérios de impessoalidade e moralidade.



@cpiuris



www.cpiuris.com.br



contato@cpiuris.com.br



61 3033-3739



61 98442-2591

CAPÍTULO 5 — ATOS ADMINISTRATIVOS

1. INTRODUÇÃO

Di Pietro⁵⁹ explica que o **ato administrativo é uma declaração do Estado, que produz efeitos jurídicos imediatos**, sob regime jurídico de direito público e sujeito a controle do Poder Judiciário.

Ainda que a Administração venha a manifestar sua vontade, não necessariamente seus atos poderão ser denominados de atos administrativos. Eles só poderão receber essa classificação se forem submetidos ao regime jurídico de direito público.

2. ATOS DA ADMINISTRAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS

É importante que se faça a **diferenciação entre atos da administração e atos administrativos**. Os atos da administração são todos os atos jurídicos praticados pelo Poder Público, estando ou não sujeitos ao regime jurídico público. Toda vez que a Administração atua, ela pode optar se irá se valer de suas prerrogativas (garantidas pelo regime jurídico administrativo) ou se, eventualmente, irá praticar atos que se assemelham àqueles que são praticados pelo particular.

Os atos da administração são a categoria geral, e esses incluem os chamados atos administrativos, que são submetidos ao regime jurídico específico e diferenciado (o regime jurídico administrativo visto no capítulo 02), que geram as chamadas prerrogativas da Administração Pública.

Tome-se por exemplo a locação: um ato praticado sob as regras de direito privado. Quando a Administração aluga um imóvel ela está dispensada de fazer licitação (poderá fazer, se quiser) e, ao celebrar esse contrato, a Administração se coloca num nível horizontal igual, ao do particular. Será um contrato regido pela igualdade entre as partes são iguais, sem que a Administração disponha de garantias e prerrogativas típicas de quem exerce o poder em nome da coletividade.

Como dito os atos da administração são gênero, do qual se deriva algumas espécies. As principais espécies são os atos privados da administração e os atos administrativos.

Quando houver esse conjunto de prerrogativas e a Administração agir de forma a, efetivamente, exercer um poder coletivo em nome da coletividade, estaremos diante de um ato administrativo e não de um ato da administração. Nos atos administrativos, o que se tem é a próprio Estado praticando um ato unilateral, tomando decisões que, com certa frequência, geram obrigações para os particulares. Por exemplo a emissão de uma licença ou uma autorização para funcionamento de um táxi. Nos atos administrativos (ou atos de administração) o Poder Público possui o poder de fazer surgir, unilateralmente, uma obrigação para os cidadãos e administrados.

Cabe ainda esclarecer o que é **o fato administrativo**. Pontes de Miranda⁶⁰ esclarece “que atos administrativos são aqueles que possuem um conteúdo humano e o fato administrativo em sentido estrito é aquele que não tem esse conteúdo propriamente humano, não tem propriamente vontade”. Celso Antônio Bandeira de Mello ilustra o entendimento doutrinário majoritário: o fato da administração não envolve propriamente uma vontade, sendo uma mera exteriorização ou concretização de uma decisão anterior. Os exemplos dados pela doutrina são: criação de uma estrada, pavimentação, construção ou demolição de um colégio, ou até mesmo um fato da natureza que repercuta sobre a administração, como a destruição de um prédio por uma enchente, por exemplo. O fato administrativo não é um ato jurídico, ele apenas acontece eventualmente; são fatos da natureza (que repercutem sobre a administração pública); ou são meras execuções/concretizações/materializações de um ato administrativo anterior.

⁵⁹DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo** 33ª ed. São Paulo: Gen Forense, 2020. Livro eletrônico não paginado.

⁶⁰MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. **Tratado de direito privado tomo III**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 14.



Há também a **classificação de atos como políticos ou de governo**. A natureza específica se dá por serem justamente atos permeáveis pela atuação política do Estado. Um exemplo seria o caso de uma sanção de lei, não caracterizando, para Celso Antônio Bandeira de Mello⁶¹, um ato administrativo, mas sim um ato político, um exercício de vontade, de representação do Presidente da República.

3. FASES DE CONSTITUIÇÃO DE UM ATO ADMINISTRATIVO

São três: perfeição, validade e eficácia. Estas se parecem muito com a Escada Pontean, famosa teoria de Pontes de Miranda⁶². Esta postula que todos os fatos jurídicos podem ser divididos em três planos de análise: existência, validade e eficácia.

3.1. PERFEIÇÃO

Em direito administrativo a perfeição significa a existência do ato, seu aperfeiçoamento e materialização, independentemente de ser ele válido ou não.

Quando se diz que um ato é perfeito no âmbito do direito administrativo significa apenas que ele está completo, não faltando nenhum outro requisito para que ele esteja absolutamente pronto e acabado.

Eventualmente pode ser considerado inválido: pode ser um ato perfeito, mas inválido, ou ineficaz. A validade e a eficácia são outras fases, autônomas. O ato jurídico perfeito é o que está terminado, que pode ser inválido ou ineficaz, pois se tratam de classificações independentes.

3.2. VALIDADE

A validade deve ser aferida de acordo com a lei. O ato, embora esteja completo (perfeito), pode desrespeitar uma norma imperativa, contrariar a lei, violar uma norma jurídica, não ter base legal, violar a finalidade pública, ter um motivo falso, pode ser objeto de desvio ou excesso de poder etc. Em todas essas hipóteses o ato será inválido.

3.3. EFICÁCIA.

Diz respeito à materialização do ato na ordem jurídica, na realidade fática. O ato será eficaz quando, de fato, produzir efeitos.

4. FORMAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

Quanto à formação dos atos administrativos, estes podem ser simples, compostos ou complexos.

4.1. SIMPLES

É aquele que se aperfeiçoa com apenas uma manifestação de vontade.

Por exemplo, é próprio o órgão que decide se concede ou não uma licença. Se o ato de atribuição de licença depende apenas do entendimento desse único órgão, o ato é simples. Ainda que haja, eventualmente, um procedimento administrativo, é um órgão só que decide se concede ou não aquela licença.

⁶¹MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Curso de Direito Administrativo** 33ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019, p.210.

⁶²MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. **Tratado de direito privado tomo III**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 15.



4.2. COMPOSTOS

São os atos que são praticados por um órgão, mas depois devem passar por algum tipo de homologação. A primeira manifestação é importante e decisiva, mas a segunda, embora necessária, é uma espécie de juízo de homologação: não constitui uma decisão de mérito tão importante quanto a primeira, e sim uma forma de se verificar se estão presentes ou não os requisitos formais.

Um exemplo comum é o concurso público, em que a banca examinadora estabelece quais os candidatos que foram aprovados no concurso, e após há um órgão, distinto do primeiro, que homologa ou não o certame. A homologação não é um ato que verificará novamente se os candidatos mereciam ou não ser aprovados, não fazendo qualquer juízo de valor no que diz respeito ao mérito. É um juízo de valor reduzido, relacionados a requisitos formais e eventuais irregularidades formais, uma mera homologação. Caso não haja qualquer irregularidade formal, a homologação é medida que se impõe, sendo uma obrigação, sem que o segundo órgão possa rever a decisão do primeiro órgão. Todo tipo de homologação, quando exigida, compõe um ato administrativo composto.

4.3. COMPLEXOS

São os atos administrativos em que existem dois juízos independentes, ambos de mérito, e de igual importância e com a mesma profundidade cognitiva. São atos em que os dois órgãos se manifestam de forma independente, sem que a segunda análise seja uma mera chancela ou aferição de regularidade ou não. Um exemplo é a concessão de aposentadoria, que por ser ato administrativo complexo só se aperfeiçoa após a análise do TCU, como visto no capítulo 02.

Existem duas manifestações de vontade e quando a primeira é praticada, o ato ainda não tem os seus efeitos principais. Só estará aperfeiçoado quando houver a segunda manifestação de vontade. As duas são essenciais para que o ato possa ser considerado perfeito e completo.

O efeito da primeira manifestação de vontade é preliminar, antecipatório: fazer com que o segundo órgão se manifeste. Essa é a ideia de **efeitos prodrômicos**, que são justamente os efeitos preliminares de um ato administrativo. Quando o primeiro órgão emite o seu juízo em um ato administrativo complexo, não haverá ainda os efeitos próprios do ato; mas já existem efeitos antecipatórios que são a possibilidade, agora, do segundo órgão se manifestar. Os efeitos produzidos pelo primeiro ato são efeitos prodrômicos.

Há uma certa divergência em relação à classificação de certos atos, como, por exemplo a nomeação do Procurador Geral da República, em que a divergência consiste em saber se é complexo ou composto. Ou seja, o Presidente nomeia, mas a sabatina e a aprovação do Senado constitui uma mera homologação, uma chancela do ato administrativo; ou o Senado atua como órgão que deve realmente aferir e fazer um juízo de conteúdo profundo sobre a nomeação? Maria Sylvia Zanella di Pietro⁶³ entende que a nomeação seria um ato composto, em que o Senado apenas homologa a decisão do Presidente da República. José Santos Carvalho Filho⁶⁴, por exemplo, entende que o ato é complexo. Embora haja divergência doutrinária, há uma leve tendência da doutrina em entender que se trata de um ato administrativo complexo e não composto, já que o Senado teria toda uma possibilidade de aferir o ato em profundidade, investigando todo o passado daquele nomeado, fazendo um juízo político, jurídico e econômico sobre aquela nomeação.

Outros exemplos de ato composto são: intervenção federal (para alguns), pois ela deve ser homologada e posteriormente ser aprovada pelo Congresso Nacional e, da mesma forma, o estado de sítio, que passa por prévia aprovação.

⁶³ DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo** 33ª ed. São Paulo: GenForense, 2020. Livro eletrônico não paginado

⁶⁴ CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de direito administrativo** 32ª ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 119.



5. CLASSIFICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO

Os atos praticados pela administração poderão ser classificados como:

- **Atos da administração de direito público:** seriam os atos administrativos.
- **Atos da administração de direito privado:** seriam os atos da administração.
- **Atos administrativos típicos:** são aqueles regidos pelo direito público.
- **Atos administrativos atípicos:** são aqueles regidos pelo direito privado.

A Administração poderá praticar **atos administrativos** e **atos de natureza privada**, também chamados de atos da administração.

A Administração pode praticar **atos políticos, não se sujeitando ao controle do Poder Judiciário**, pois há uma discricionariedade mais ampla. Por exemplo a declaração de guerra, veto, anistia etc.

A Administração também pratica **atos materiais**, os quais executam de atividade, sem manifestação de vontade da administração.

6. OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

Os atos administrativos possuem outras classificações:

O ato pode ser geral, quando é voltado a indivíduos incertos e indeterminados, havendo pluralidade indefinida.

O ato pode ser individual, quando o ato administrativo interfere na órbita jurídica de alguém especificamente, como é o caso de uma licença.

Por outro lado, um regulamento é um ato normal, que é efetivamente aprovado, diferente do decreto, que é a forma do regulamento. Exemplo: o Regulamento da Previdência é um decreto, ou seja, é um regulamento, uma forma de se esmiuçar o que está na lei, sendo materializado por meio de um decreto.

O ato pode ser constitutivo quando cria, modifica ou extingue relações dali em diante, ou declaratório, quando reconhece uma relação jurídica, situação jurídica pré-existente, não havendo nada de diferente aqui, no que se refere à teoria geral do direito.

O ato pode ser enunciativo, que é o caso de certidões, a administração não emite propriamente um juízo, uma manifestação de vontade, mas apenas atesta ou certifica uma situação de fato.

7. ATOS ADMINISTRATIVOS X FATOS ADMINISTRATIVOS

Os atos administrativos não se confundem com fato administrativo. Os **fatos administrativos** são fatos concretos que produzem efeitos no direito administrativo, por exemplo a morte do servidor. Já os **atos administrativos** decorrem de uma manifestação de vontade da administração, e por ela podem ser anulados ou revogados pela administração. Todavia, os fatos administrativos não podem ser revogados ou convalidados.

8. SILÊNCIO ADMINISTRATIVO

O silêncio da Administração não pode ser considerado um ato administrativo, salvo quando houver um silêncio qualificado: para tanto, **é necessário que haja norma legal prevendo que o silêncio da administração signifique algo**. Apenas com este pressuposto é possível inferir que o silêncio da Administração indica um posicionamento.



9. REQUISITOS DE VALIDADE OU ELEMENTOS DO ATO ADMINISTRATIVO

Hely Lopes Meirelles sustentava que poderia se falar genericamente em requisitos. Diferentemente, Celso Antônio Bandeira de Melo⁶⁵ entende que se deve se diferenciar os elementos (parte do ato) dos pressupostos do ato. Para o autor “sem os elementos não há ato jurídico algum (administrativo ou não). Sem os pressupostos não há ato administrativo formado de maneira válida”.

9.1. ELEMENTOS DO ATO POR CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELO

Os elementos dos atos são as realidades intrínsecas a ele. Se dividem em:

- **Conteúdo:** o que o ato dispõe.
- **Forma:** revestimento exterior do ato.

Quanto ao conteúdo do ato administrativo, o ato pode ser uma autorização (ato discricionário, unilateral e precário, que não gera um direito propriamente adquirido); permissão (ato discricionário e precário) ou a licença (ato vinculado e definitivo). São espécies quanto ao conteúdo de atos.

A licença é um ato definitivo e vinculada, ou seja, se o particular preencher os requisitos definidos em lei, faz jus à licença. A autorização, por outro lado, é um ato precário, e que depende de um juízo de oportunidade e conveniência, podendo ser revogado a qualquer tempo.

Existe, entretanto, uma exceção, que está contida na súmula 23 do STF, que trata sobre a licença para construir.

Súmula 23 - Verificados os pressupostos legais para o licenciamento da obra, não o impede a declaração de utilidade pública para desapropriação do imóvel, mas o valor da obra não se incluirá na indenização, quando a desapropriação for efetivada.

Entende-se que a licença para construir é uma exceção porque comporta revogação, apesar de que se o ato é vinculado não comportar revogação por não possuir mérito administrativo. No entanto, pelo teor da súmula, extrai-se que não há um direito absoluto para construir, de forma que a eventual desapropriação pode gerar revogação da licença para construir.

Ainda segundo Bandeira de Mello o ato administrativo deve preencher os **pressupostos de existência**, o objeto e pertinência do ato ao exercício da função administrativa. Ou seja:

- **Objeto:** é aquilo sobre o que o ato dispõe. Ex.: a intimação tem por objeto cientificar alguém de alguma coisa.
- **Conteúdo:** é o que o ato dispõe.
- **Pertinência temática:** é preciso que o ato possa ser atribuído ao Estado na sua função administrativa.

Por fim Bandeira de Mello se refere aos **pressupostos de validade**:

- **Pressuposto subjetivo:** o ato deve ter emanado de uma autoridade competente.
- **Pressuposto objetivo:** o ato deve ser dotado de motivos, requisitos procedimentais.
- **Pressuposto teleológico:** a finalidade do ato deve ser pública, prevista em lei.
- **Pressuposto lógico:** é a causa que gera o ato.

⁶⁵MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Curso de Direito Administrativo** 33ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019, p. 177.



- **Pressuposto formalístico:** forma adotada pelo ato deve ser adequada para o ato.

9.2. ELEMENTOS TRADICIONAIS DO ATO ADMINISTRATIVO

São elementos do ato administrativo estabelecidos, segundo o art. 2º da Lei de Ação Popular (Lei nº 4.717/65):

- **Competência**
- **Finalidade**
- **Forma**
- **Motivo**
- **Objeto**

9.1.1. COMPETÊNCIA (OU SUJEITO COMPETENTE)

A competência verifica se a autoridade administrativa poderá, pela lei, produzir o ato. É sempre um **elemento vinculado** do ato administrativo. A Lei define em todas as situações quem é a autoridade administrativa competente.

A competência é **irrenunciável, imprescritível e improrrogável**. A competência é um dever, pois a lei determina que se pratique o ato nos casos em que haja a adequação à lei.

A competência pode ser objeto de delegação ou avocação, desde que a **lei não tenha conferido exclusividade à competência**. A Lei 9.784/99 veda algumas hipóteses de delegação da competência:

- **Atos normativos**
- **Decisões de recurso hierárquico**
- **Competência exclusiva**

Atente-se que o art. 84, parágrafo único, da CRFB diz que **as hipóteses de decretos autônomos podem ser delegados ao Ministro de Estado, AGU ou PRG. Apesar de se tratar de ato normativo, é possível a delegação**.

A Lei 9.784/99 vai admitir a **delegação** de competência de um órgão administrativo ao outro, **mesmo que não seja hierarquicamente inferior à autoridade delegante**. Não há necessariamente a relação de verticalidade na delegação. Vale lembrar que **a delegação deve ser específica**, não se admitindo que haja a delegação genérica para outra autoridade.

A **cláusula de reserva** significa que a autoridade delegante se reserva da prática do ato delegado, mas não impede que também pratique aquele ato. Há uma concorrência de competências neste caso. Trata-se de uma **cláusula implícita** dos atos de delegação. Do mesmo modo, José dos Santos Carvalho Filho⁶⁶ defende que a delegação não retira da autoridade delegante a competência para desempenhar a atribuição que foi delegada. Há hipótese de **competência conjunta**. É isso que prevalece.

No entanto, no caso da **avocação é necessária a verticalidade**. A Lei 9.784/99 **restringe a possibilidade de avocação para os casos temporário e que se justifiquem por motivos relevantes**. É possível avocar, mas para tanto deverá ser temporária e os motivos sejam relevantes.

9.1.2. FINALIDADE

Significa saber qual é o **resultado que a Administração pretende alcançar com o ato administrativo**. É o **reflexo da legalidade**, pois é o Poder Legislativo que vai definir o objetivo que pode ser alcançado com aquele ato.

Não há uma margem de discricionariedade da Administração. Ou seja, o elemento é vinculado.

⁶⁶ CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de direito administrativo** 32ª ed. São Paulo: Atlas, 2018.

A violação da finalidade trazida pela lei gera o chamado **desvio de poder**. Esse desvio pode se mostrar de duas espécies:

- **Ato praticado com finalidade alheia ao interesse público:** remoção de ofício de servidor público em razão de ser inimigo da autoridade superior.
- **Ato praticado com desvio da finalidade pública específica:** é o caso de punição do servidor com remoção *ex officio*, mas sem que esta seja prevista para o ato.

Nos dois casos há desvio de poder. O abuso de poder é um gênero, do qual são espécies o excesso de poder e o desvio de poder, que é o **desvio de finalidade**. Tanto no excesso como no desvio há nulidade do ato administrativo. Todavia, **no excesso de poder, o agente extrapola a sua competência. No desvio de poder, o agente age de acordo com sua competência, mas não age de acordo com o interesse público** trazido pela lei.

9.1.3. FORMA

O ato administrativo **deve ter uma forma**, normalmente é determinada em lei. **Via de regra, o ato administrativo será escrito**, mas são possíveis atos administrativos orais, em casos de urgência e de pouca relevância. Inclusive, são possíveis atos administrativos gestuais ou por meio de sinais sonoros. Por exemplo as ordens verbais e até o apito do agente de trânsito.

Cabe mencionar o **princípio da instrumentalidade das formas**, em que estabelece não ser a forma a essência do ato, motivo pelo qual a forma somente seria um instrumento para se alcançar o interesse público. por essa razão, se o ato conseguir alcançar a sua finalidade, ainda que haja vício de forma, tal vício será considerado sanável.

A doutrina entende que, **em regra, a forma é ato vinculado**. No entanto, se a lei não previr em determinada situação a forma do ato, a forma será considerada discricionária.

9.1.4. MOTIVO

Motivo é saber o que levou a pessoa a fazer aquilo. É o **pressuposto de fato e de direito** que justifica a prática do ato administrativo. É importante saber que o **motivo** é a causa que dá origem a determinado ato administrativo. A **motivação** é a manifestação deste motivo. Alguém pode praticar um ato sem motivá-lo, é o caso da dispensa do funcionário em cargo comissionado, por exemplo, que em regra é um agente público exonerável *ad nutum*.

Há uma exceção: pela Lei do Processo Administrativo, todo ato que restrinja direitos deve ser motivado. Embora a regra seja de que atos discricionários não necessitam de motivação, se restringirem direitos de um indivíduo deverão ser motivados. Por exemplo a negativa de determinada autorização. Cabe ressaltar que essa regra é a rigor aplicável para a esfera federal. Já nos demais Entes há a possibilidade de se aplicar a regra federal por analogia caso não haja previsão por lei estadual, municipal ou distrital; mas não há determinação expressa do STF nesse sentido.

O motivo pode ser **vinculado** ou **discricionário**.

Há referência à motivação nos seguintes enunciados da Constituição Federal: art. 93, X; art. 121, § 2º; e art. 169, § 4º.

Já no âmbito da Administração Pública Federal, a motivação do ato administrativo encontra tratamento mais denso no art. 2º, *caput*, parágrafo único, no art. 38, § 2º, e no art. 50, ambos da Lei Federal 9.784/99. Entretanto, também há referência expressa ou implícita ao dever de fazê-lo em outros dispositivos legais.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro e José dos Santos Carvalho Filho fazem uma **distinção entre motivo e motivação**. Para eles, o **motivo é a circunstância de fato que impele a vontade do administrador**. A **motivação é a explicitação do motivo, ou dessa circunstância que impele o administrador**.



O professor Carvalho Filho entende que apenas os atos vinculados necessitam de motivação. Portanto, os atos discricionários não precisariam.

Todavia, Di Pietro, Eros Roberto Grau e Hely Lopes Meirelles entendem que **é necessária a motivação tanto em atos discricionários como em atos vinculados**. Este entendimento é prevalente, motivo pelo qual **a motivação é obrigatória**.

A motivação **não será obrigatória quando bastar a declaração de vontade do agente público** no exercício da sua competência para que o ato seja completo, por exemplo a exoneração *ad nutum*.

Por outro lado, em se tratando de motivação não obrigatória, caso justifique por conta própria a motivação do ato que gerou a declaração de vontade do agente público, e fique constatado que a motivação seria falsa, neste caso estará vinculado à sua motivação. É a aplicação da **teoria dos motivos determinantes**.

A teoria dos motivos determinantes será aplicada sempre que existir motivação, seja em atos vinculados ou discricionários: toda a vez que o agente enuncia os motivos de ter decidido ou agido de determinada maneira, ainda que a lei não o tenha exigido expressamente, o ato só será válido se estes realmente ocorreram e tiveram o condão de justificar o ato. Caso os motivos do ato sejam falsos, inexistentes ou incorretamente qualificados isto viciará o ato administrativo. A validade de um ato está vinculada, pela teoria dos motivos determinantes, à veracidade dos fatos descritos como motivadores da prática do ato. **O ato discricionário, se for motivado, passa a se vincular aos motivos indicados pela administração. Se esses motivos se mostrarem insuficientes ou inválidos, o ato administrativo discricionário praticado também será considerado inválido.** Por isso, teoria dos motivos determinantes, os quais vão determinar a validade ou invalidade do ato.

Alguns atos, como a exoneração *ad nutum* dispensam a motivação. Nesse caso o administrador não precisará expor os motivos, mas caso o faça estará vinculado a eles.

O momento em que essa motivação deve vir deve ser **contemporânea à prática do ato ou mesmo anterior à prática do ato**. Admite-se, em relação aos atos vinculados, a **motivação tardia**, ou seja, após a prática do ato, desde que fique evidente que o motivo existia anteriormente. Nos atos discricionários, **a ausência de motivação contemporânea ou anterior à prática do ato será gerar a nulidade do ato**. Este é o entendimento da **doutrina**. No entanto, **o STJ já entendeu que nas situações em que a lei não exige motivação, é possível que excepcionalmente se admita uma motivação tardia**, desde que se observe três requisitos (STJ, MS 40.427/DF):

- O **motivo** extemporaneamente alegado seja **preexistente**.
- O **motivo** seja **idôneo** para justificar o ato.
- O **motivo** seja a **razão determinante** da prática do ato.

Bandeira de Mello⁶⁷ diz que a **causa é um novo requisito para o ato administrativo**, além do motivo do ato administrativo. A causa seria a relação de **adequação entre o pressuposto do ato e o seu objeto**. a **correlação lógica entre o pressuposto (motivo) e o conteúdo do ato, em função da finalidade do ato**. O pressuposto de fato é o motivo, e entre o pressuposto do ato e o objeto do ato deve existir a causa, que é a correlação lógica entre aquilo que aconteceu e aquilo que foi praticado pelo com o objetivo de atingir a finalidade prevista no ato. Perceba que, quando se fala em causa se fará uma análise da razoabilidade e da proporcionalidade da causa.

Fernando Baltar complementa que a causa é um pressuposto de validade do ato administrativo. Se há uma correlação lógica entre o motivo do ato e a sua finalidade, há uma causa, significa que o ato foi válido. No entanto, se o motivo foi X e deveria ter feito Y, mas foi feito Z pelo agente público, o ato existe, porém, o ato não será válido. Dessa forma, não há como considerar causa como elemento da manifestação de vontade da administração, a qual poderá ser inválida, mas ocorreu.

⁶⁷MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Curso de Direito Administrativo** 33ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019, p. 407.



Motivação per relationem ou aliunde é uma técnica de fundamentação pela qual a pessoa que decidirá ao invés de fornecer argumentos próprios, adota algum parecer como razões de decidir. É possível que uma autoridade decida sobre um recurso e ao invés de declinar novas razões, no sentido de desprover o recurso, simplesmente adote as razões de decidir da autoridade anterior. Entende que essas são suficientes e, portanto, que haveria motivação para tal por relação, com base nos motivos apresentados por outra pessoa. Esse tipo de fundamentação é admitido no Brasil.

9.1.5. OBJETO OU CONTEÚDO

O objeto é o **efeito jurídico imediato** que o ato produz.

O conteúdo (ou objeto) **pode ou não vir fixado em lei**, podendo o objeto ser discricionário ou vinculado.

Perceba que **objeto e motivo são discricionários**, como regra, e compõe o mérito administrativo que passará a ser explorado abaixo.

10. MÉRITO ADMINISTRATIVO

O mérito administrativo está relacionado com a **possibilidade de a administração valorar critérios de conveniência e conteúdo do ato administrativo**.

Só é possível falar em mérito administrativo nos casos de **ato discricionário**. Se o ato é vinculado, o legislador já exerceu o seu juízo de discricionariedade, o qual determina o que a administração vai ou não fazer.

Deve-se atentar à diferença entre ato vinculado e ato discricionário. **Quando o ato é vinculado o administrado tem direito à prática deste, desde que preencha os requisitos previstos em lei**, ou seja, a Administração não tem a faculdade de praticar ou não o ato. Preenchidos os requisitos pelo cidadão é uma obrigação da administração pública praticar aquele ato. Daí, se o ato é vinculado, todos os seus elementos são vinculados. E, se o particular preencher os requisitos, ele faz jus à prática do ato não podendo a Administração recusar.

No ato discricionário, por outro lado, os elementos finalidade, forma e competência são vinculados, mas o motivo e o objeto são discricionários. Mesmo que o ato seja discricionário, ele está sujeito a um controle de legalidade. No que se refere à finalidade, forma e competência, serão SEMPRE elementos vinculados, mesmo na hipótese de um ato administrativo discricionário. Os elementos que caracterizam a discricionariedade do ato administrativo são o motivo e o objeto. Esses dois compõem o chamado mérito administrativo, ou seja, eles serão definidos a partir de um juízo de conveniência e oportunidade do administrador que detém legitimidade democrática e competência institucional (ou seja, conhecimento específico para praticar aquele ato). O mérito administrativo só existe no ato discricionário não abrange todos os elementos, somente dois.

No que se refere aos elementos vinculados é pacífico que estes podem sofrer controle de legalidade. **O que se discute é se no mérito administrativo é possível que haja controle de legalidade**, em outras palavras **se o Poder Judiciário pode se imiscuir no mérito administrativo**. Esse tema pode ser respondido de duas formas. Em uma na prova objetiva geralmente a resposta mais segura é que é negativa: o mérito administrativo é insindicável, não podendo o Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo. Entretanto, numa prova discursiva, em que há espaço para argumentação, deve-se apontar que há autores que já defendem a possibilidade de controle em algumas hipóteses de teratologia, absurdos jurídicos, mesmo no mérito administrativo, tais como Juarez Freitas⁶⁸ e José de Alfredo de Oliveira Baracho⁶⁹: assim não haveria propriamente um mérito administrativo totalmente blindado no controle de legalidade.

⁶⁸ FREITAS, Juarez. O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 388-389.

⁶⁹ BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Atos administrativos: elementos poder discricionário e o princípio da legalidade, limites da convalidação, forma de exercício. Boletim de Direito Administrativo, São Paulo, v. 13, n. 7, jul. 1997, p.398.

O STJ também já enfrentou a matéria se posicionando pela possibilidade do Poder Judiciário examinar o controle do mérito do ato administrativo, já que a Administração deve respeitar a juridicidade, inclusive quanto à conveniência e oportunidade (STJ, REsp 429570/GO). Por fim o próprio STF admite o controle, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo quando eivado de ilegalidade ou abusividade (Ag. Reg. no RE 663.078 e Ag. Reg. No RE 761.714). Porém, a Suprema Corte só o fará nos casos de ilegalidade, defeito de forma, abuso de autoridade, violação da razoabilidade ou proporcionalidade, ou teratologia.

O mérito administrativo é controlável pelo Poder Judiciário, mas este não poderá analisar o conteúdo propriamente dito. Ou seja, o juiz poderá apreciar o ato praticado pelo administrador que tenha violado a razoabilidade, já que esse é um princípio constitucional implícito. Mas o Poder Judiciário só poderá anular o ato administrativo discricionário, mas não poderá, por exemplo, aplicar ele mesmo outra penalidade ao servidor que tenha sido punido indevidamente.

Outra hipótese é o controle pelo Poder Judiciário de políticas públicas, quando estas se referem ao mínimo existencial. A rigor a escolha da atividade estatal prioritária é uma escolha discricionária do Poder Executivo. Porém, mesmo na escassez ou até na inexistência de recursos, o Estado não poderá se escusar do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal com o objetivo de garantir o mínimo de dignidade para a vida humana. Assim o particular que se vir prejudicado, por não ter garantido pelo Poder Executivo o atendimento ao seu mínimo existencial, poderá entrar com as medidas judiciais pertinentes para garantir que seu direito fundamental seja garantido, mesmo diante da alegação do princípio da reserva do possível pela Administração Pública. Segundo o STF como a CRFB garante o direito fundamental à educação, é dever dos municípios de oferecer acesso à creche. Trata-se de obrigação constitucional vinculante, uma vez que deriva da lei maior. Não há assim o que se falar de discricionariedade da Administração Pública, pois se trata de atendimento à legislação, logo o Poder Judiciário poderá forçar o Executivo a garantir as vagas em creches (RE 436.966).

11. ATRIBUTOS DO ATO ADMINISTRATIVO

São as características próprias dos atos administrativos quando há supremacia do interesse público. Os atributos são: presunção de legitimidade, presunção de veracidade, coercibilidade ou exigibilidade, a autoexecutoriedade, e, para alguns, a tipicidade. O ato administrativo pode ou não ter esses atributos, não sendo todos os atos que possuem esses atributos.

11.1. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE

A presunção de legitimidade implica em uma suposição: entende-se que o ato administrativo está conforme o direito, a Constituição e as leis.

Toda vez que a Administração pratica um ato presume-se que ele está em com o ordenamento jurídico, detendo legitimidade e cabendo eventualmente ao administrado (se desejar) afastar essa presunção, provando que o ato da administração é ilegítimo. Por exemplo quando for lavrada uma multa será ônus do particular provar que a sanção não foi aplicada no dia que ele circulou de carro, que o policial não possuía visibilidade da placa do automóvel, ou que não possuía aparelhos adequados etc.

A Administração, quando atua em nome da coletividade, pratica um ato regido pelo regime jurídico administrativo estudado no capítulo 02. Consequentemente esse ato gozará da presunção de estar conforme à lei, cabendo eventualmente a quem quiser afastá-lo, provar a sua ilegitimidade: essa presunção é *juris tantum*, ou seja, admite prova em contrário.

A presunção de legitimidade é **relativa**, sendo uma presunção de que os atos administrativos são praticados de acordo com a lei e com os princípios que regem a administração pública. Tanto é que no caso de mandado de segurança, **havendo empate entre os julgadores, prevalecerá a denegação da segurança**, visto que há presunção de legitimidade do ato administrativo.



Também é importante distinguir a **presunção de legitimidade com a presunção de veracidade**. A presunção de legitimidade significa que o ato, a princípio, está de acordo com a lei. No entanto, a presunção de veracidade é dizer que se presume que os fatos narrados são verdadeiros. Por essa razão, **os atos administrativos também têm presunção de veracidade**.

11.2. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE

Os agentes públicos possuem fé pública. Portanto toda vez que um ato administrativo é praticado presume-se que ele é verdadeiro e que a Administração não faltou com a verdade ou trouxe informações incompletas. Novamente será ônus do particular provar que essa presunção é falsa no caso concreto.

Essa presunção também é *juris tantum*, ou seja, admite prova em contrário.

11.3. IMPERATIVIDADE

Imperatividade significa que **o ato administrativo tem uma qualidade de império**.

Os atos administrativos **vão se impor a terceiros pessoas**, independentemente da concordância ou não de terceiros pessoas. A imperatividade **não se encontra em todos os atos administrativos**, mas se caracteriza uma ordem ao particular. É o atributo administrativo que permite que a Administração, com base no seu ato, crie de maneira unilateral obrigações para o administrado. Os atos administrativos possuem o condão de impor obrigações unilateralmente aos administrados, independentemente da concordância destes. Ou seja, quando uma pessoa é notificada para pagar uma multa, por exemplo, surge uma obrigação no mundo jurídico que foi constituída por só uma das partes.

No direito privado, tradicionalmente, a obrigação ou decorre de lei ou decorre da vontade das partes, e ambas precisam contribuir, anuir e aceitar, para que a obrigação contratual surja. Já no caso no direito administrativo, o Estado tem o poder de, unilateralmente e independentemente da concordância do particular, criar-lhe uma obrigação. O cidadão é obrigado a respeitar e cumprir essa obrigação mesmo que dela discorde, independentemente da sua vontade.

Se discordar poderá impugnar via processo administrativo ou, em virtude do princípio da inafastabilidade da jurisdição, pela via judicial. Mas enquanto não houver o afastamento da presunção de legitimidade, de veracidade e da imperatividade, aquela obrigação vale e, portanto, está efetivamente obrigado, vinculando o particular ainda que este discorde.

11.4. EXIGIBILIDADE

A exigibilidade é um **atributo do ato administrativo que exige obediência a uma obrigação imposta pela Administração**, e imposta por meios indiretos de coação (por exemplo multa para obrigar a fazer algo ou deixar de fazer algo).

É uma obrigação imposta pela administração por meio de coação.

O Estado, no exercício da função administrativa, pode exigir de terceiros o cumprimento e a observância das obrigações que impôs. A imperatividade apenas constitui uma dada situação ou impõe uma obrigação. Na exigibilidade Administração tenta induzir o particular a cumprir o ato que entende correto, por exemplo pela aplicação de multas. Nesse caso não é exigida a situação de urgência ou previsão expressa em lei, podendo ser tomado como algo implícito à luz do ordenamento jurídico e da própria capacidade que a administração tem de exercer poder de polícia e assim por diante. Aplicar multas é tipicamente uma atribuição da Administração Pública bem como zelar pela garantia e o respeito à certas práticas e normas jurídicas



11.5. AUTOEXECUTORIEDADE

Na autoexecutoriedade, a **Administração põe em execução o seu ato, através dos seus meios, sem que haja intervenção do Poder Judiciário**. A autoexecutoriedade só é admitida quando:

- **Lei expressamente trazer essa previsão legal**
- **Houver medidas urgentes por parte da administração**

A autoexecutoriedade **não se confunde com a exigibilidade**, pois nesta o Estado se vale de um meio indireto, enquanto na autoexecutoriedade a Administração faz o uso direto de suas decisões. Por exemplo o agente do DETRAN aplica uma multa quando o particular para no lugar errado. Trata-se de um ato administrativo dotado de exigibilidade, ou seja, um meio indireto de coação. No caso de o agente do DETRAN apreender o veículo, chamando o guincho e levando para o depósito do DETRAN, o ato passa a ser dotado de autoexecutoriedade, pois o Estado empregou força física direta.

Para Celso Antonio Bandeira de Mello⁷⁰ é o poder que os atos administrativos têm de serem executados pela própria Administração independentemente de qualquer solicitação ao Poder Judiciário. Quando a Administração por meios próprios pratica a ação, estaremos diante do atributo da autoexecutoriedade. Um exemplo é o caso da demolição de imóveis construídos irregularmente em áreas de preservação ambiental. A derrubada pode ser feita sem que a Administração tenha que recorrer ao Poder Judiciário: a Administração verifica a necessidade da demolição e, por força própria a pratica.

Por outro lado, se a Administração pratica o ato, tentando por meios indiretos, sobretudo multa, forçar o administrado a cumprir a obrigação por ela imposta, estamos diante da exigibilidade.

A autoexecutoriedade é uma exceção, já que nem todos os atos possuem tal atributo. Para que um ato seja autoexecutável é necessária a previsão legal ou que se trate de um caso de urgência. Se não se tratar de urgência e se não houver previsão em lei, o ato não detém o atributo autoexecutoriedade.

11.6. COERCITIBILIDADE OU COERCIBILIDADE

A coercibilidade significa que, por meios indiretos, a Administração pode tentar forçar que o administrado cumpra aquele ato. Os atos administrativos possuem o poder de serem exigidos quanto ao seu cumprimento, sob ameaça de sanção. Vai além da imperatividade, pois traz uma coerção para que se cumpra o ato administrativo. Por exemplo quando a Administração notifica o particular a retirar materiais de construção da porta da sua residência. Os agentes públicos poderão, à força, retirar os materiais. Ou poderão notificar o indivíduo e aplicar uma multa, que é um meio indireto que visa a coibir prática, obrigando o particular a cumprir o que a Administração determinou.

11.7. TIPICIDADE

Segundo esse atributo, o ato administrativo deve sempre corresponder a uma forma previamente prevista em lei. A tipicidade decorre como um corolário do princípio da legalidade, ou seja, se a administração só pode fazer o que está previsto em lei, os atos administrativos devem ter uma forma já prevista em lei.

⁷⁰MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Curso de Direito Administrativo** 33ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019, p. 431.



12. EXTINÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

Na hipótese de um agente público incompetente praticar um ato administrativo de forma equivocada, sem observar a forma prevista na lei, a forma e competência foram violadas. É possível, de alguma forma, aproveitar esse ato administrativo? Sim. Existem vícios que podem ser **convalidados**, ou seja, é aproveitado o ato administrativo que era anulável.

No caso da competência e da forma, se o vício for de forma, ou se a autoridade que praticou não foi a competente, o ato é anulável. No entanto, é possível convalidar o ato administrativo. A **anulação** do ato produz efeitos *ex tunc*. A Administração possui o dever de anular os seus atos quando forem contrários à constituição ou à lei. Este poder compõe a autotutela administrativa.

Quando a administração anula um ato todos os demais decorrentes deste devem ser desfeitos, uma vez que atos nulos não produzem direitos.

Tratando-se, entretanto, de um vício de forma ou de competência, o ato pode ser convalidado. A **convalidação** gera efeitos *ex tunc*. Ela salva todos os atos já praticados, a ideia é preservar o que já foi praticado. No caso de incompetência basta consultar o agente, que seria, pela lei, responsável pela prática do ato. O realmente competente poderá cancelar, convalidar, tudo o que foi feito. No caso da forma, troca-se para a forma correta.

A convalidação precisa produzir efeitos retroativos porque, do contrário, seria mais fácil praticar um ato novo. A vantagem da convalidação é justamente permitir que um ato já praticado e que era anulável, seja aproveitado, seja salvo.

Os atos administrativos podem ser revogados quando forem atos discricionários. A **revogação** será gerada pela mudança de entendimento da Administração sobre o mérito administrativo, uma reavaliação do juízo de conveniência e oportunidade. Se a Administração pratica um determinado ato discricionário com base nesse juízo de conveniência, ela pode, a qualquer momento, decidir que revogará o ato, também com base no seu juízo de oportunidade e conveniência. Nessa hipótese, revogado o ato, os efeitos serão *ex nunc*, ou seja, a revogação só terá efeitos dali em diante.

No entanto, se no lugar de revogação ocorrer anulação, os efeitos serão retroativos, uma vez que dos atos nulos não surgem direitos.

Como visto, Lei do Processo Administrativo Federal estabelece um prazo de 05 anos que pode estender por analogia integrativa a toda a esfera estadual e municipal que não tenha prazo específico.

Como visto no item sobre mérito administrativo o Poder Judiciário a princípio não pode revogar um ato do Poder Público, do Poder Executivo. Tanto a própria Administração, no exercício da autotutela, quanto o Judiciário, podem anular um ato, por violar a lei ou a constituição. Só o próprio detentor do juízo de conveniência e oportunidade, aquele que exerce e decide com base no mérito administrativo é que pode revogar o ato administrativo.

Quando o Poder Judiciário exerce a sua função atípica, por exemplo, organizando um concurso público, está praticando atos típicos de administração. Sendo um ato discricionário, poderá exercer o juízo de oportunidade e conveniência e, revogar seus próprios atos nesse caso.

13. CLASSIFICAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

Quanto aos destinatários, os atos podem ser classificados em:

- **Atos gerais:** é aquele que não tem destinatário certo ou específico, tendo caráter de norma. Ex.: edital de concurso público.
- **Atos individuais:** é aquele que tem um destinatário ou específicos. O ato geral prevalece sobre o ato individual. O ato individual pode ter como destinatário um sujeito ou sujeitos específicos. Esse ato individual pode ser singular ou plural.
 - **Ato individual singular:** nomeação de um sujeito para um cargo comissionado.
 - **Ato individual plural:** nomeação de diversos sujeitos para um cargo efetivo.

Quanto às prerrogativas, também poderá ser classificados os atos administrativos como:



- **Atos de império:** são os atos administrativos propriamente dito, revestidos de imperatividade. A administração atua com supremacia e prerrogativas.
- **Atos de gestão:** são os atos praticados com a finalidade de gerir os bens e serviços da administração. Não há necessidade de prerrogativas de direito público. A administração age em situação de igualdade com o particular.
- **Atos de expediente:** são os atos destinados a dar andamento à administração.

Quanto ao grau de liberdade, os atos ainda podem ser classificados em:

- **Atos vinculados:** ocorre quando o ato não detém nenhum juízo de valor. Isso porque todos os elementos do ato estão previstos na lei.
- **Atos discricionários:** ocorre quando a lei confere ao administrador o juízo de conveniência e oportunidade.

Existe uma discussão se existe ou não discricionariedade com relação aos conceitos jurídicos indeterminados. Neste caso, não há necessariamente uma discricionariedade administrativa. Primeiro, há uma interpretação de um conceito jurídico. **Caso após essa interpretação do conceito jurídico, e após ultrapassar a zona cinzenta, chegue-se a uma interpretação de que se extraia um juízo de certeza, seja positiva ou negativa, não haverá discricionariedade se vai ou não vai fazer.**

Por outro lado, se for realizada essa interpretação, e feita ela, continua-se em uma zona cinzenta, não alcançando certeza positiva ou negativa, **deve-se haver discricionariedade para adequar o conceito ao interesse público.**

Quanto à formação, os atos também se classificam em:

- **Ato simples:** são atos que dependem da manifestação de vontade de um único órgão. Ex.: alvará de construção dado por uma prefeitura.
- **Ato complexo:** também depende de duas ou mais manifestações de vontade, que ocorrem em patamar de igualdade, em órgãos diferentes. Ex.: nomeação de dirigente de agência reguladora (Senado aprova + Presidente nomeia), concessão inicial de aposentadoria.
- **Ato composto:** depende de duas ou mais manifestações de vontade, que ocorrem em patamar de desigualdade. A primeira é principal e a segunda é secundária, sendo que ambas ocorrem dentro de um **mesmo órgão**. Ex: atos que dependem do visto, da confirmação do chefe. Isso é muito comum em procuradorias.

Segundo Carvalho Filho⁷¹, no que toca aos efeitos, os atos que traduzem a vontade final da Administração só podem ser considerados perfeitos e acabados quando se consuma a última das vontades constitutivas de seu ciclo. O autor acrescenta que a vontade dos órgãos colegiados se configura como ato simples coletivo. É que as vontades formadoras são *interna corporis* e se dissolvem no processo de formação, de modo que apenas uma é a vontade que se projeta no mundo jurídico

Quanto à formação e eficácia dos atos administrativos, classificam-se em:

- **Ato perfeito:** para a doutrina majoritária, perfeição significa cumprir o **ciclo de formação** (percorreu a sua trajetória).
- **Ato válido:** o ato administrativo é válido quando **cumprir os requisitos previstos em lei, sem vícios**. Validade é a situação jurídica que resulta da conformidade do ato com a lei ou como outro ato de grau mais elevado.
- **Ato eficaz:** se o ato cumprir seus requisitos e está **pronto (idôneo) para produzir efeitos**, é eficaz, ainda que penda de condição suspensiva.

⁷¹CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de direito administrativo** 32ª ed. São Paulo: Atlas, 2018.



Celso Antonio Bandeira de Mello vai dizer que a eficácia é uma situação de disponibilidade para produção de efeitos próprios daquele ato. Portanto, os atos podem ter efeitos típicos e atípicos:

- **Efeitos típicos:** são os efeitos próprios do ato, sendo uma consequência lógica do ato.
- **Efeitos atípicos:** podem ser divididos em:
 - **Preliminares (prodrômicos):** é aquele produzido enquanto o ato ainda está pendente. O ato é eficaz, mas não exequível, pois depende da ocorrência de uma condição futura. Ou seja, o efeito prodrômico acarreta para o órgão controlador a obrigação de emitir o ato de controle, qual seja, homologar ou não o ato. Há um efeito que é produzido enquanto a situação de pendência do ato se faz presente. O ato é eficaz, mas ainda não é exequível, pois depende de implementação de uma condição futura, como a homologação de outro órgão. Enquanto essa homologação não vem não poderá produzir todos os seus efeitos. Há aqui um efeito prodrômico, pois o ato já faz nascer o outro ato de controle, que é o ato da homologação ou da não homologação
 - **Reflexos:** é o efeito que atinge indiretamente uma terceira pessoa. O Poder Público pode promover uma ação de desapropriação de um imóvel. Neste caso, o sujeito passivo será o proprietário, mas se estiver locado o imóvel, também atingirá o locatário, sendo atingido indiretamente pelo ato.
- **Ato exequível:** é aquele que já pode produzir efeitos imediatamente. Ex.: um ato publicado em janeiro diz que irá começar a produzir efeitos no dia 15 de fevereiro. Este ato será eficaz desde o dia da sua publicação, pois já se encontra apto para produzir efeitos, mas não se está apto para produzir efeitos imediatamente. Portanto, só no dia 15 de fevereiro será exequível.

Quanto aos efeitos, os atos podem ser classificados em:

- **Atos constitutivos:** são aqueles que constituem direitos, ou cuja manifestação de vontade da administração faz constituir um direito ao administrado. Ex.: concessão de construir ao administrador. Antes não havia essa licença, agora existe.
- **Atos declaratórios:** são os atos que apenas declaram situação preexistente. Ex.: ato que declara que certa construção provoca riscos à integridade física dos transeuntes.
- **Atos ablatórios:** é um ato que restringe o direito do administrado. Ex.: rescisão de um contrato administrativo, o qual, quando em vigor, o administrado tinha o direito, mas perde-se pela rescisão.
- **Atos enunciativos:** num sentido estrito, são atos que indicam juízos de valor, dependendo, portanto, de outros atos de caráter decisório. Ex.: pareceres. Num sentido amplo, são atos declarativos, sem coercibilidade, como certidões e atestados.

Os atos podem ser:

- **Ato nulo:** é o ato que é contaminado por um vício insanável ou nulidade absoluta. A decisão terá efeito *ex tunc*, retroagindo ao momento de produção do ato.
- **Ato anulável:** é o ato contaminado pelo vício que é sanável, admitindo a convalidação. Se houver a convalidação, haverá efeitos ex tunc, retroagindo ao momento da produção. Diante de um ato anulável, a **administração deve convalidá-lo quando isso ser possível**, não sendo decisão discricionária. A única exceção é o caso em que o vício se deu em razão de a autoridade que emitiu o ato ser incompetente. Não se pode obrigar uma autoridade que é competente para a prática do ato da mesma forma que a autoridade incompetente que praticou o ato, motivo pelo qual não necessariamente deverá a administração convalidá-lo.



Os vícios relacionados à **competência** admitem a convalidação, sendo denominado **ratificação**, **desde que não se trate de matéria de competência exclusiva**.

Em relação aos vícios quanto à **forma**, também será possível a ratificação, desde que a forma não seja essencial à validade do ato. Mas é indispensável que tenha havido uma forma, seja ela qual for, pois do contrário o ato seria inexistente.

Em relação ao motivo e a finalidade, se o ato estiver contaminado, o ato não poderá ser convalidado jamais.

Em se tratando do **objeto**, quando ele for ilegal, não poderá ser convalidado. Todavia, é possível falar em conversão, a qual ocorre quando há a transformação de um ato inválido em outro ato, de outra categoria, e com efeitos retroativos. Ex.: quando o Poder Público promove uma concessão do solo sem licitação, a lei, exigindo licitação, há um ato inválido. Nesse caso, não é possível convalidar a concessão de uso, mas é possível convertê-la em uma autorização ou permissão de uso, os quais são atos precários que não dependem de licitação.

- **Ato inexistente:** o ato guardaria apenas uma aparência de um ato, o qual não é um ato. Ex.: ato praticado por quem se diz ser funcionário público.

Vale ressaltar que o ato nulo poderá ser convalidado pela prescrição em homenagem à segurança jurídica. Todavia, **o ato inexistente não pode ser convalidado jamais**.

14. ESPÉCIES DE ATOS ADMINISTRATIVOS

São espécies de atos administrativos:

- **Atos normativos**
- **Atos ordinatórios**
- **Atos negociais**
- **Atos enunciativos**
- **Atos punitivos**

14.1 ATOS NORMATIVOS

Os atos normativos são manifestações de vontade do Poder Público, mas de **caráter abstrato**, para destinatários indeterminados, ainda que sejam determináveis.

Os atos normativos **devem ser expedidos sempre que a lei precisar de alguma regulamentação**. A lei poderá dizer isso expressamente ou mesmo silenciar, mas se o administrador reputar cabível a regulamentação da lei esta poderá ser regulamentada.

Com a EC 32/01, **passou-se a admitir decretos autônomos do chefe do Poder Executivo em situações específicas**, não visando a explicitação da lei. As hipóteses de decretos autônomos estão previstas nas alíneas a e b do inc. VI do art. 84 da CF e não podem ser ampliadas:

- Decreto do presidente da república sobre a organização e funcionamento da administração pública federal, desde que esse funcionamento não implique aumento de despesa, ou criação ou extinção de órgão.
- Decreto do presidente da república extinguir cargo ou função, quando estiver vago.

Veja que **não podem extinguir órgãos**.

Como tipos de atos normativos existem:

- **Decretos:** os decretos são atos regulamentares de competência privativa do Chefe do Poder Executivo.
- **Regulamentos:** visam explicar a correta execução da lei, detalhando-a. Há quem coloque regulamentos dentro do decreto.



- **Instruções normativas:** são atos normativos de caráter geral ou individual, emanados por autoridade. As autoridades são ministros de estado, secretários de estado ou municipais. A ideia das resoluções é uniformizar o procedimento administrativo ou explicar as leis ou decretos, dentro das respectivas pastas.
- **Avisos ministeriais:** atos normativos que decorrem dos ministérios, das secretarias estaduais ou municipais, dos órgãos imediatamente inferiores ao chefe do executivo. Alguns doutrinadores defendem que se trata de um ato ordinário.
- **Deliberações e resoluções:** são atos normativos dos atos colegiados. O conselheiro de uma agência reguladora é diretor de um conselho diretivo. Dessa forma, a agência reguladora expede deliberações e resoluções.

Entende o STF que é admissível o controle concentrado de constitucionalidade de decreto que, dando execução a lei inconstitucional, crie cargos públicos remunerados e estabeleça as respectivas denominações, competências, atribuições e remunerações. São inconstitucionais a lei que autorize o chefe do Poder Executivo a dispor, mediante decreto, sobre criação de cargos públicos remunerados, bem como os decretos que lhe deem execução (ADI 3232).

No final do ano de 2019 o STF decidiu, ainda, que considerado o princípio da separação dos poderes, **conflita com a Constituição Federal a extinção, por ato unilateralmente editado pelo Chefe do Executivo, de órgãos colegiados** que, contando com menção em lei em sentido formal, viabilizem a participação popular na condução das políticas públicas – mesmo quando ausente expressa ‘indicação de suas competências ou dos membros que o compõem’ (ADI 6.121 MC).

14.2. ATOS ORDINATÓRIOS

No ato ordinatório, há comando expedido pela autoridade administrativa superior para seus subordinados.

São exemplos de atos ordinatórios:

- **Portaria:** as portarias são atos administrativos formais praticados por autoridades administrativas de nível inferior ao Chefe do Executivo, quaisquer que sejam os escalões, que se destinam a uma variedade de situações, como expedir orientações funcionais em caráter concreto, impor a servidores determinada conduta funcional, instaurar procedimentos investigatórios e disciplinares. A portaria é um ato administrativo individual interno, pois atinge indivíduos especificados no próprio ato. Ex.: no âmbito do inquérito policial, o delegado determina a instauração do IP por meio de portaria; portaria de posse; portaria de vacância, etc.
- **Ordens de serviços.** Ato formal que se presta à maneira de conduzir determinada atividade, confundindo-se com a circular. Ex.: o procurador chefe pode determinar a forma de distribuição de processos na procuradoria. Ele edita uma norma de **caráter geral** que vai disciplinar a forma como será conduzida a atividade.
- **Circulares.** É ato administrativo formal através do qual autoridades superiores expõem ordens uniformes a servidores subordinados. São orientações em **caráter concreto**, distinguindo-se das instruções. Não se trata de um ato individual, e sim um ato geral interno, pois não individualiza as pessoas a serem atingidas pelo ato. É imposição em razão da hierarquia e da subordinação, só podendo ser expedida pelo chefe do órgão.
- **Memorandos e ofícios:** são atos de comunicação. O **memorando** é de comunicação interna, entre agentes do mesmo órgão. O **ofício** é um ato de comunicação entre uma autoridade e um particular ou entre autoridades.



14.3. ATOS NEGOCIAIS

Os atos negociais são **manifestações de vontade da Administração** que vão **coincidir com a pretensão de um particular**. É um ato de consentimento.

Não se deve confundir ato negocial com contrato administrativo, pois no contrato há manifestação bilateral de vontades, enquanto nos atos negociais há uma manifestação unilateral de vontade da Administração, que por acaso coincide com a pretensão do administrado. Quando há uma licença para construir, a faculdade da Administração coincide com a vontade do particular.

São exemplos de atos negociais:

- **Autorização:**

Há um ato **unilateral, discricionário e precário**, por meio do qual a administração:

- **faculta o uso de bem público pelo particular para atender interesse do particular:** ex.: interdição da rua para festa junina;
- **faculta a prestação do serviço público pelo particular, em caráter extremamente precário:** ex.: serviço de táxi;
- **autoriza o exercício de certa atividade material:** ex.: porte de armas. É denominada de autorização de polícia.

Como a autorização tem caráter precário, **por razões de conveniência ou oportunidade**, poderá a administração **revogar** a autorização em qualquer tempo, **sem que o administrado tenha direito à indenização**. Todos os bens públicos podem ter uso cedido ao particular por meio de autorização, concessão ou permissão de uso, a depender do caso particular. Ela pode ser simples, qualificada (com prazo), gratuita ou onerosa. Como visa a satisfazer interesse do administrado, **não gera qualquer direito**.

- **Permissão de uso de bem público:**

Há um ato **unilateral, discricionário e precário** (em menor grau), através do qual a administração faculta ao particular interessado a utilização de bem público. Distingue-se da autorização porque **a permissão atende ao interesse do particular e da coletividade, e não apenas do particular, como na autorização**.

É bom destacar que **não se pode confundir** permissão de serviços públicos com a permissão de utilização de bem público. No caso da permissão de serviço público, há um contrato administrativo, estando prevista no art. 40 da Lei 8.987/95.

Se a permissão de uso de bem público contiver um termo, isto é, **se houver prazo, ela deixa de ser precária**. Além disso, a permissão de uso, apesar de ter natureza jurídica de ato administrativo, **é necessário que haja procedimento licitatório**.

- **Licença:**

É um ato negocial **vinculado**, sempre sendo um ato de polícia. A administração pública, após verificar o preenchimento de todos os requisitos estabelecidos pela lei, vai liberar o desempenho de determinada atividade. Ex.: licença para construir. Por se tratar de ato vinculado, não admitirá revogação, via de regra, pois é admissível revogação no caso de licenças ambientais.

- **Admissão:**

É o ato por meio do qual se permite que o particular ingresse num determinado serviço público, ou seja, permitindo que usufrua de um determinado serviço prestado pelo Estado.

Tanto a licença, como a autorização e a permissão de uso de bem público, serão concedidas por meio de **alvará**, pois este é a forma do ato negocial.



14.4. ATOS ENUNCIATIVOS

Atos enunciativos são atos em que a Administração se restringe a expor alguma coisa. O Poder Público irá se certificar ou atestar um fato, que consta de seu registro, processo, arquivo público, ou ainda irá emitir uma opinião sobre determinado assunto.

São exemplos de atos enunciativos:

- **Parecer administrativo (opinativos)**
- **Certidões:** é aquilo que está registrado na repartição e é espelhado para o requerente. Ex.: certidão negativa de débitos.
- **Atestados:** a Administração verifica a situação de fato para depois atestar. Ex.: atestado de médico.
- **Apostila (averbação):** é o ato por meio do qual o Estado acrescentará informação ao registro público.

Em relação aos **pareceres**, é bom que se destaque que a lei poderá conceder aos pareceres ou notas técnicas o caráter vinculante. Nesse caso, apesar de ser uma opinião, a opinião vinculará o administrador. Em regra, porém, o parecer não será vinculante.

Vale lembrar que os pareceres podem ser:

- **Pareceres facultativos:** está presente nas situações em que a lei não exige o parecer para a prática de determinado ato.
- **Pareceres obrigatórios:** é aquele definido em lei como necessário para a validade do ato administrativo. Ex.: parecer da licitação, na fase interna.

Os pareceres obrigatórios poderão ser:

- **Pareceres obrigatórios vinculantes:** aqui, o parecer terá efeitos vinculantes, obrigando a autoridade que receber este parecer.
- **Pareceres obrigatórios não vinculantes:** aqui poderá a autoridade atuar conforme o parecer ou não. Como regra, os pareceres são não vinculantes em relação à autoridade que recebe o parecer, podendo fundamentadamente discordar do parecer.

Alguns doutrinadores entendem que os atos enunciativos não seriam atos administrativos, pois não manifestam a vontade do Estado.

14.5. ATOS PUNITIVOS

Nos atos punitivos, há instrumentos por meio dos quais a administração **aplica sanção aos servidores e administrados**. Ex.: multa de trânsito.

A interdição de atividade também é um ato punitivo. A destruição de coisa, demolição administrativa, também é ato punitivo.

15. EXTINÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

A extinção dos atos administrativos poderá se dar por:

- Revogação
- Anulação
- Cassação
- Caducidade



15.1. REVOGAÇÃO

A revogação não é propriamente uma invalidação, pois **apenas se retira do mundo jurídico**. Nela há a invalidação de um ato administrativo **por razões de conveniência e oportunidade**.

A revogação poderá ser **expressa** ou **tácita**. Ocorrendo a tácita quando a administração pratica um ato incompatível com o ato anteriormente praticado.

Se estamos tratando de mérito, apenas os atos discricionários poderão ser revogados. Na revogação, a **Administração apenas revê o seu julgamento acerca do mérito administrativo**, e, portanto, só a Administração, segundo prevalece na doutrina, poderá rever o mérito administrativo. Porém, como visto, acima o STF entende que o Poder Judiciário também poderá rever o mérito administrativo nos casos de ilegalidade, defeito de forma, abuso de autoridade ou teratologia, como foi explicitado no item 5.10.

O professor José dos Santos Carvalho Filho elenca cinco hipóteses de atos administrativos que não admitem revogação:

- **Ato já exauriu os seus efeitos** (ex.: ato que conferiu férias, e estas já foram gozadas, não dá mais para revogar)
- **Atos vinculados**
- **Atos que geram direitos adquiridos**
- **Atos integrativos**, pois integram o processo administrativo, impedidos pela preclusão administrativa
- **Meros atos administrativos**, como pareceres, certidão ou atestados

No tocante aos **atos individuais**, existe uma corrente, segundo a qual não haveria o direito de supressão da administração em revogar o ato que ela considera contrário ao interesse público. **A Administração poderia revogar esse ato, desde que indenizasse o particular pelos prejuízos sofridos.**

A **revogação terá efeitos *ex nunc***, não retroagindo, sendo válido todos os efeitos anteriores.

15.2. ANULAÇÃO

A anulação é a **declaração de que um ato administrativo foi produzido em desobediência à norma legal**. Tanto a Administração quanto o Poder Judiciário poderão anular atos ilegais.

Prevalece o entendimento ainda que o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, salvo quando houver violação à proporcionalidade, mas aí teria violado a própria legitimidade do ato administrativo.

A Administração poderá de ofício, pelo poder de autotutela, anular os atos eivados de nulidade.

A **anulação produzirá efeitos *ex tunc***, retroagindo à data de produção do ato.

Em que pese ser esta a regra geral, **existem situações que podem recomendar que o ato, apesar de nulo, tenha produzido efeitos até o momento de sua anulação, tendo efeitos *ex nunc***, não retroagindo.

Carvalho Filho⁷² afirma que **se o ato administrativo eivado de um vício for ampliativo de um direito, a declaração de sua nulidade deverá produzir efeitos *ex nunc***, ou seja, não poderia retroagir, pois o sujeito já se valeu daquele ato.

Quando se afirmar que **atos nulos podem ser invalidados a qualquer momento**, não significa que não possam ser sanados, significando dizer que **poderão ser sanados, desde que ocorra a decadência de declarar a sua nulidade**. **Diante da decadência, há a convalidação do ato eivado de uma nulidade absoluta.**

⁷²CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de direito administrativo** 32ª ed. São Paulo: Atlas, 2018.



A Lei 9.784 vai dizer, no art. 54, que o direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários decai em 05 anos, **salvo se o ato tiver sido praticado com má-fé.**

É importante destacar a **teoria do fato consumado**. Segundo esta teoria, uma ilegalidade poderá ser convalidada pela consolidação da situação de fato. Haveria mais prejuízos em anular do que manter.

O STJ e STF (Ag. Reg no RE 740.029) rejeitam a aplicação da teoria do fato consumado quando os efeitos produzidos foram provenientes de decisões de caráter provisório. No entanto, essa teoria do fato consumado será abarcada na seara jurisdicional em algumas hipóteses excepcionais. Por exemplo se há uma liminar que autoriza o sujeito se transferir da universidade particular para a universidade pública, mas quando do julgamento do mérito do mandado de segurança esse sujeito já tiver concluído a faculdade. Nesse caso, o julgamento deverá ser aplicado a teoria do fato consumado.

A declaração de ilegalidade dos atos individuais deve respeitar o princípio da ampla defesa e do contraditório. Se o ato for geral, não será preciso isso.

15.3. CASSAÇÃO

Na cassação, haverá a **invalidação de um ato que nasceu regular**, mas que se tornou irregular no momento da sua execução. Por exemplo: foi concedido um alvará de construção, mas houve a alteração do plano diretor. Dessa forma, o ato foi cassado em face da irregularidade superveniente.

Como a cassação é o reconhecimento de um vício, **haverá o efeito retroativo ao momento da produção do ato viciado**. Isso vai ocorrer em virtude de que o ato não poderá mais existir, apesar de ter nascido válido.

15.4. CADUCIDADE

É a extinção do ato pelo surgimento de uma lei posterior incompatível com o ato.

16. JURISPRUDÊNCIA

16.1. SÚMULAS DO STJ

Súmula 633 A Lei n. 9.784/1999, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria.

QUESTÕES

1. (TJMS) FCC, 2020. No tocante ao exercício do poder de autotutela pela Administração Pública, é correto afirmar:

- A) O exercício, pela Administração Pública, do poder de anular seus próprios atos não está sujeito a limites temporais, por força do princípio da supremacia do interesse público.
- B) Somente é admissível a cassação de ato administrativo em razão de conduta do beneficiário que tenha sido antecedente à outorga do ato.
- C) É vedada a aplicação retroativa de nova orientação geral, para invalidação de situações plenamente constituídas com base em orientação geral vigente à época do aperfeiçoamento do ato administrativo que as gerou.
- D) É possível utilizar-se a revogação, ao invés da anulação, de modo a atribuir efeito ex nunc à revisão de ato administrativo, quando se afigurar conveniente tal solução, à luz do princípio da confiança legítima.
- E) Não é possível convalidar ato administrativo cujos efeitos já tenham se exaurido



2. (TJPA) CESPE/CEBRASPE, 2019. De acordo com a doutrina administrativista clássica e majoritária, são atributos dos atos administrativos

- A) o sujeito, o objeto e a tipicidade.
- B) a presunção de legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade.
- C) a autoexecutoriedade, a tipicidade e a finalidade.
- D) a imperatividade, a finalidade e a presunção de legitimidade.
- E) a finalidade, o sujeito e o objeto.

3. (TJSC) CESPE/CEBRASPE, 2019. No âmbito do direito administrativo, segundo a doutrina majoritária, a autoexecutoriedade dos atos administrativos é caracterizada pela possibilidade de a administração pública

- A) anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, sem necessidade de controle judicial.
- B) assegurar a veracidade dos fatos indicados em suas certidões, seus atestados e suas declarações, o que afasta o controle judicial.
- C) impor os atos administrativos a terceiros, independentemente de sua concordância, por meio de ato judicial.
- D) executar suas decisões por meios coercitivos próprios, sem a necessidade da interferência do Poder Judiciário.
- E) executar ato administrativo por meios coercitivos próprios, o que afasta o controle judicial posterior.

4. (TJ-PR) CESPE/CEBRASPE, 2019. A administração pública pode produzir unilateralmente atos que vinculam os particulares. No entanto, tal vinculação não é absoluta, devendo o particular, para eximir-se de seus efeitos e anular o ato, comprovar, em juízo ou perante a própria administração, o defeito do ato administrativo contra o qual se insurge, por caber-lhe o ônus da prova. Essa descrição refere-se ao atributo do ato administrativo denominado

- A) autoexecutoriedade.
- B) imperatividade.
- C) presunção de legalidade.
- D) exigibilidade.

5. (MPE-PI) CESPE, 2019. O chefe do Poder Executivo estadual baixou resolução pela qual declarou ser de utilidade pública para fins de desapropriação determinado imóvel particular, situado no território do respectivo ente federado.

Nessa situação hipotética, o referido ato administrativo foi eivado de vício quanto

- A) à forma.
- B) à finalidade.
- C) ao objeto.
- D) ao motivo.
- E) à competência.

COMENTÁRIOS

1. Gabarito – C

- A) Incorreta. Cf. art. 54 da Lei 9.487/99.
- B) Incorreta. Na cassação o ato administrativo é extinto por ilegalidade superveniente em face do descumprimento pelo beneficiário dos requisitos impostos para sua expedição.
- C) Correta. Cf. art. 2º, parágrafo único, XIII, da Lei 9.784/99.



D) Incorreta. O particular de boa-fé deve ser protegido, em razão do princípio da segurança jurídica. Logo em algumas situações devem ser mantidos todos os efeitos produzidos pelo ato, ainda que seja ato que sofre de nulidade insanável

E) Incorreta. A convalidação possui efeito *ex tunc* e consiste na correção do vício do ato administrativo e consequente manutenção do ato no ordenamento jurídico. Cf. art. 55 da Lei 9.784/99.

2. Gabarito – B

A) Incorreta. A alternativa traz os elementos do ato administrativo e não atributos (exceto a tipicidade).

B) Correta.

C) Incorreta. A finalidade é elemento do ato administrativo e não atributo.

D) Incorreta. A finalidade é elemento do ato administrativo e não atributo.

E) Incorreta. A alternativa traz apenas elementos do ato administrativo.

3. Gabarito – D.

A) Incorreta. Conf. Súmula nº 473, do STF: "A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vício que os tornem ilegais, porque deles não originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial".

B) Incorreta. A presunção de veracidade não afasta a apreciação judicial.

C) Incorreta. A alternativa descreve a imperatividade.

D) Correta.

E) Incorreta. A autoexecutoriedade não afasta o controle judicial.

4. Gabarito – C.

Toda vez que a Administração pratica um ato presume-se que ele está em com o ordenamento jurídico, detendo legitimidade e cabendo eventualmente ao administrado (se desejar) afastar essa presunção, provando que o ato da administração é ilegítimo. Consequentemente esse ato gozará da presunção de estar conforme à lei, cabendo eventualmente a quem quiser afastá-lo, provar a sua ilegitimidade: essa presunção é *juris tantum*, ou seja, admite prova em contrário.

5. Gabarito – A.

A) Correta. A declaração de utilidade pública deveria ter sido feita por Decreto ou por lei com efeito concreto, e não por Resolução.

B) Incorreta. A forma está errada.

C) Incorreta. A forma está errada.

D) Incorreta. A forma está errada.

E) Incorreta. A forma está errada.



CAPÍTULO 6 — PODERES ADMINISTRATIVOS

1. INTRODUÇÃO

É o conjunto de medidas e instrumentos, e eventuais prerrogativas, de que se vale a Administração Pública para a consecução de sua finalidade. O Estado, para exercer suas atribuições, necessita de alguns poderes, que são considerados instrumentais.

Celso Antonio Bandeira de Mello⁷³ esclarece que o ordenamento atribui aos entes públicos obrigações de atendimento as necessidades da coletividade, e só por isso a dota de poderes. Por isso a doutrina fala em poderes-deveres da administração, ou deveres-poderes.

Por consequência os poderes administrativos são irrenunciáveis, pois visam o interesse público.

2. ABUSO DE PODER

Esse tema diz respeito ao princípio administrativo da finalidade. A ideia é de que todo ato público deve servir à finalidade para a qual foi criado. Existe uma finalidade geral, que é comum a todos os atos, e a finalidade específica de cada ato, que deverá ser aferida com base no ato. Por exemplo a remoção do servidor, não tendo caráter punitivo (essa não é sua finalidade), visa permitir que ele mude de lugar (essa é sua finalidade) de acordo com certos critérios.

O abuso de poder é um gênero, que significa usar de forma inadequada o Poder Público, do qual se desdobram duas espécies, o desvio de poder e o desvio de finalidade.

O **desvio de poder** ocorre quando determinado indivíduo tem competência para praticar um ato, mas exacerba daquela competência, ou seja, vai para além do que é competente.

Já o **desvio de finalidade** ocorre quando um determinado ato serve para uma finalidade e é desvirtuado para servir outra finalidade para a qual não foi criado. Por exemplo a remoção utilizada com a finalidade punitiva, no caso de um servidor que praticou algum ato ímprobo, que poderia ser punida por meio de um procedimento administrativo disciplinar ou sindicância, mas o chefe, ao invés, decide remover a pessoa no interesse público, determinando que vá para outra localidade. Essa remoção é nula, a própria administração deve proceder à anulação e se não o fizer esse ato comporta impugnação judicial.

Todas as vezes que a administração pública extrapola o caráter do poder, há o chamado **abuso de poder**:

- **Excesso de poder:** ocorre quando o agente extrapola a competência conferida por lei. É um vício de competência. Esse vício, a princípio, é sanável. O agente exerce o poder respeitando o interesse público, mas extrapola os limites.
- **Desvio de poder:** ocorre quando o agente atua em violação ao interesse público, ou seja, com finalidade diversa da conferida pela lei. Trata-se de um vício de finalidade. Atente-se há desvio de poder quando o agente atua visando finalidade diversa daquela trazida pela regra de competência.

3. PODER DISCRICIONÁRIO E PODER VINCULADO

Vale lembrar que o poder discricionário e o poder vinculado são na verdade formas do exercício dos demais poderes administrativos. Ou seja os atos administrativos são praticados com competências vinculadas ou discricionárias.

⁷³MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Curso de Direito Administrativo** 33ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019.



Toda atuação administrativa é minimamente vinculada à lei. Nos atos vinculados, não há margem de escolha ao administrador, enquanto nos atos discricionários, cabe ao administrador uma margem de liberdade para decidir e atuar.

No caso de **conceitos jurídicos indeterminados**, há discricionariedade do administrador, ou seja, há margem de escolha, sendo sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade, sendo denominado de **mérito administrativo**.

O poder discricionário não é um poder jurisdicional, e sim administrativo, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a Administração na oportunidade e conveniência. Claro que é possível, como já visto no item 5.10, controlar o poder discricionário, desde que seja com base na violação ao princípio da legalidade e /ou moralidade, proporcionalidade ou razoabilidade (legitimidade do ato).

Os limites do mérito da discricionariedade são controláveis pelo Poder Judiciário, mas não cabe fazer com relação ao conteúdo propriamente dito. Em outras palavras, o juiz pode analisar o ato praticado pelo administrador que tenha violado à razoabilidade, eis que se trata de um princípio constitucional implícito. Assim no caso de atuação do Poder Judiciário com relação ao poder discricionário, só caberá a anulação do ato administrativo, não podendo aplicar a penalidade ao servidor que tenha sido punido indevidamente.

Deve-se ter em mente que a discricionariedade é diferente de arbitrariedade: o ato arbitrário é ilegal, ilegítimo e inválido. O que existe é uma margem de liberdade, e não de arbitrariedade. Por exemplo uma pena de suspensão em que a lei prevê prazo de 30 a 60 dias e o agente suspende por 90 dias, trata-se de um ato arbitrário e não discricionário.

Assim há limites ao exercício do poder discricionário: a liberdade de atuação corresponde aos limites definidos em lei, e caberá ao Judiciário por meio do princípio da razoabilidade e proporcionalidade controlar o exercício desse poder discricionário, declarando a ilegalidade de atuação que viole estes princípios

4. CLASSIFICAÇÃO DOS PODERES ADMINISTRATIVOS

Os poderes administrativos são classificados em:

- Poder regulamentar
- Poder hierárquico
- Poder disciplinar
- Poder de polícia

4.1. PODER REGULAMENTAR (PODER NORMATIVO)

É o poder de expedir normas gerais e abstratas, dentro dos limites das leis. Os atos administrativos regulamentares a rigor **só podem ser expedidos segundo a lei**, não podendo ser contrário à lei e nem inovar na ordem jurídica. O regulamento é o ato normativo por excelência. Esse regulamento é formalizado por decreto. **Os regulamentos ou decretos são privativos do Chefe do Poder Executivo**. Outras autoridades administrativas poderão expedir outros atos, como resoluções e instruções normativas (dentre outros), mas não decretos. Por essa razão, parte da doutrina começa a dizer que o poder regulamentar seria do chefe do Poder Executivo, **motivo pelo qual este poder seria espécie do gênero poder normativo**.

O **regulamento** poderá ser **autorizado (delegado)**, ocorrendo quando a lei determina expressamente que ela seja regulamentada. O STF tem entendimento pacífico de que a lei pode determinar que ela seja regulamentada, mas não pode haver a delegação da função legislativa. Ou seja, **o STF não admite a delegação em branco**, pois viola o princípio da Separação de Poderes.

Alguns atos administrativos possuem caráter normativos, mas não foram emanados de um poder regulamentar, ou mesmo não estão nem mesmo regulamentando qualquer lei. Esses atos administrativos têm origem no poder hierárquico, o qual atribui competência às autoridades superiores para expedir



ordens aos seus subordinados. Quando o Tribunal monta o regimento interno, significa que quem está nas dependências do Tribunal deverá obedecer a ele. Isso decorre do poder hierárquico, e não pode poder regulamentar. Por essa razão, **nem todo ato normativo decorre do poder regulamentar**. Mas do poder regulamentar há exercício de atos normativos.

José dos Santos Carvalho Filho⁷⁴ entende que existem atos de regulamentação de primeiro grau e atos de regulamentação de segundo grau:

- **Atos de regulamentação de primeiro grau:** há decretos e regulamentos, os quais vão explicar a lei.
- **Atos de regulamentação de segundo grau:** são atos que regulamentam os decretos. São as instruções, orientações e resoluções.

No direito comparado, os regulamentos se dividem em dois grupos:

- **Regulamentos executivos (ou Decretos):** é expedido para fiel execução da lei. Trata-se de um ato de 2º grau. É a regra no direito brasileiro.
- **Regulamentos autônomos (ou Decretos):** como já visto no item 7.14 a, são atos normativos de primeiro grau. O art. 84, VI, da CRFB diz que o Presidente da República pode extinguir cargo público, desde que vago, por decreto autônomo, assim como disciplinar matéria de organização administrativa, desde que não gere despesas e não crie ou extinga órgão público, ainda que esteja vago.

Cabe ressaltar que os regulamentos autônomos, por serem atos de primeiro grau, estão sujeitos ao controle de constitucionalidade, e não de legalidade.

4.2. PODER HIERÁRQUICO

O poder hierárquico é um instrumento concedido à Administração para que essa possa **distribuir e escalonar, ordenar, fiscalizar e rever a atuação dos seus agentes**.

Há uma relação de subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal, já que há o escalonamento: uma relação de quem emana as ordens e quem as recebe.

O poder hierárquico **não depende de uma prévia existência legal**, presumindo-se da própria estrutura verticalizada da Administração. O poder hierárquico é **exercido dentro do âmbito interno de órgãos integrantes de uma mesma entidade**. Sendo assim não há que se falar de exercício do poder hierárquico da Administração em face do cidadão.

Por essa razão, **não se fala em hierarquia quando se está diante de duas entidades distintas**. Há hierarquia entre o presidente da república e o ministro da defesa, mas não há entre o ministro da defesa e o presidente do INSS, pois é outra entidade, dotada de personalidade jurídica.

O controle da autarquia é finalístico, por meio de supervisão, também denominado de tutela. No entanto, não há hierarquia.

No poder hierárquico decorre:

- poder de dar ordem
- poder de fiscalizar
- poder de delegar e avocar atribuições
- poder de rever os atos inferiores

Quando se fala em delegar, estar-se-á transferindo uma parcela de competência, normalmente do superior ao inferior hierárquico. Quando se fala em **avocação**, haverá o movimento inverso, chamando parcela de competência do subordinado ao superior hierárquico.

⁷⁴CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de direito administrativo** 32ª ed. São Paulo: Atlas, 2018.

Vale lembrar que a **delegação** poderá ocorrer entre órgãos que não guardam relação de subordinação entre um e outro, mas no caso ocorrido dentro do poder hierárquico será necessariamente decorrente da hierarquia. A delegação somente poderá ser excepcional e temporária, visto que já existe uma ordem estabelecida.

O poder de rever atos inferiores autoriza a **anulação** do ato proferido pelo agente inferior, e até mesmo **revogação** de atos.

4.3. PODER DISCIPLINAR

Poder disciplinar é o instrumento que visa **apurar infrações cometidas e aplicar penalidades cabíveis aos servidores**(vínculo hierárquico)**ou demais pessoas submetidas ou vinculadas à administração**(vínculo contratual). Esse poder **não é exclusivamente interno**, pois também pode ser aplicado em relação às pessoas jurídicas externas, como as concessionárias de serviço público.

Percebe-se que servidores e pessoas submetidas à administração que irão se submeter ao poder disciplinar da administração.

O que marca o fim do poder hierárquico e o início do poder disciplinar é a abertura do processo administrativo para apurar a responsabilidade pela prática de uma irregularidade administrativa. O poder hierárquico permite dar ordem e fiscalizar a ordem dada. Se for percebido que a ordem dada não foi cumprida, há necessidade de ser instaurado um processo administrativo para verificar essa irregularidade. Neste momento, encerra-se o poder hierárquico e inicia o poder disciplinar.

Atente-se que a **doutrina tradicional** costuma destacar a **natureza discricionária** do poder disciplinar, pois existe a possibilidade de a autoridade competente aferir aspectos como gravidade da infração, danos que provieram dessa infração, existência de agravantes e atenuantes etc.

Todavia, o STJ vem entendendo que não há discricionariedade do poder disciplinar, e sim uma efetivação de comandos constitucionais e infraconstitucionais (REsp 429.570/GO). A opção mais segura é apontar a característica discricionária.

Não são apenas os servidores públicos que se submetem ao poder disciplinar. Isso porque **o poder disciplinar também será exercido em face de pessoas físicas e jurídicas que celebram contratos com a administração**. Ou seja, pessoas vinculadas à administração estão sujeitas ao poder disciplinar da administração.

4.4. PODER DE POLÍCIA

O poder de polícia é uma faculdade conferida ao Estado para que possa restringir um direito individual em face de um potencial benefício, decorrente dessa restrição, para a sociedade.

O poder de polícia pode ser entendido em sentido amplo ou em sentido estrito. Em sentido amplo é qualquer atividade desempenhada pelo Estado, que, de alguma forma, restringe direitos individuais, podendo ser exercido inclusive pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Em um conceito mais estrito é a ideia de exercício mais direto pelo Poder Executivo, por meio de atos administrativos, e por meio da tentativa de conciliar interesses antagônicos. Ou seja, é preciso saber até onde vai o direito de um e começa o direito do outro. São intervenções gerais e abstratas (regulamentos) ou concretas e específicas (autorizações e licenças) do Poder Executivo, para prevenir ou obstar atividades particulares.

O Estado intermedia essas relações e estabelece regras e limites, como por exemplo limites sonoros, limites quanto à higiene que deve ser observado em determinado restaurante/estabelecimento comercial etc. Temos aqui a possibilidade de o estado reger esses direitos individuais, exigindo que o particular suporte, abstenha-se de determinada conduta, ou que tome certas precauções, como instalar extintores de incêndio.



O objeto do poder de polícia é regar o direito, sem que se possa abolir o direito, ou seja, o que se tem é a prerrogativa de que dispõe o estado de delimitar direitos, mas não de suprimir direitos fundamentais, observando sempre a máxima da proporcionalidade.

O poder de polícia é, em regra, **discricionário**. Embora haja grande divergência doutrinária, para fins de prova de primeira fase é possível marcar como correto que o poder de polícia se caracteriza pela discricionariedade.

Importante ressaltar que a Administração não tem a possibilidade de ficar inerte, de não tomar providências, tendo ela o poder-dever, havendo a possibilidade de a administração efetuar um direito de conveniência quanto à melhor forma de concretizar um determinado objetivo.

O poder de polícia é **imperativo**, ou seja, envolve a possibilidade de a administração criar obrigações unilateralmente.

O poder de polícia é **coercitivo**, permitindo que a administração se valha de meios indiretos de cumprimento, fixando multas, por exemplo.

Só será **autoexecutável quando houver previsão em lei ou em se tratando de casos de urgência**.

E como todos os atos administrativos, aqueles que decorram do poder de polícia gozam da presunção de veracidade e legitimidade, havendo uma inversão do ônus da prova se o particular quiser afastar essa presunção.

Um debate enfrentado na doutrina e no STF refere-se à **possibilidade de delegação do poder de polícia**: Entende-se que sim, mas não a particulares. Na ADI 1717/DF, discutiu-se o regime jurídico dos conselhos profissionais, o STF entendeu que o particular não pode exercer o poder de polícia propriamente.

O STJ entende que o particular pode, de forma eventual, receber a delegação dos atos materiais acessórios (prévios ou posteriores) ao exercício do poder de polícia, mas não poderá receber a delegação do próprio poder de polícia, em si. Assim é possível a delegação de atos de fiscalização e do consentimento, mas jamais a sanção ou decisão (STJ, REsp 817.534/MG e EDcl no REsp 817534 / MG). Não há desequilíbrio entre os administrados porque não envolve se houve violação, apenas mera constatação: são atividades meramente operacionais, por vezes inclusive realizadas por máquinas e equipamentos, e não incluem o poder de decisão. É o caso da fiscalização de trânsito por pardais e radares eletrônicos. Para tal a contratação do particular deve ser impessoal, assegurando a igualdade de tratamento.

Assim a empresa privada pode ser responsável por manutenção de radares de velocidade em rodovia, mas não pode efetivamente lavrar a multa e notificar o infrator.

Outra hipótese é a delegação de atos materiais sucessivos ao ato jurídico de polícia, apenas referente à propriedade, jamais à liberdade. Por exemplo a demolição de obras irregulares e já desocupadas.

Os atos materiais podem ser delegados, mas o poder de polícia, em si, não.

Delegações mais amplas são possíveis, mas apenas para entidades públicas, como as autarquias. Não se pode delegar o exercício do poder de polícia a um ente particular ou a uma entidade de natureza privada. Por isso o STF decidiu que os conselhos profissionais devem ser entendidos como autarquias, havendo, inclusive, uma certa inconsistência, pois o STF entende que não se beneficiam do pagamento por precatórios (por não estarem incluídos no orçamento), mas possuem outras prerrogativas típicas da administração pública e são autarquias, devendo os seus servidores estarem sujeitos ao regramento estatutário, embora haja várias indefinições quanto a isso.

As sanções devem estar previstas em lei. O poder de polícia não envolve apenas a polícia em si, sendo uma entidade que concentra licenças, é uma entidade que exerce poder de polícia.

Por exemplo, o INMETRO exerce poder de polícia. No Distrito Federal, ainda, a AGEFIS, que pode até demolir certas construções irregulares, exerce poder de polícia.

O que justifica o poder de polícia é a **supremacia do interesse público sobre o privado**.

Será restringida a liberdade individual para garantir um bem social.

O poder de polícia se manifesta por **atos gerais** (limitação administrativa) ou **individuais** (concessão de Carteira Nacional de Habilitação), podendo ser **preventivos** (concessão de alvará) ou **repressivos** (dissolução de passeata).



Vale lembrar que, em regra, **o poder de polícia é negativo**. No entanto, poderá ser positivo, impondo obrigações de fazer, como é o caso da propriedade urbana que descumpra a função social urbana, situação na qual o Poder Público impõe ao proprietário o dever de parcelar ou edificar o terreno.

Enquanto alguns serviços públicos admitem delegação, o poder de polícia não pode ser delegado de sua responsabilidade. E, portanto, via de regra, não admite delegação.

O poder de polícia **não pode ser delegado a concessionárias ou a permissionárias, tampouco às entidades da administração indireta que possuam personalidade jurídica de direito privado**.

Sobre a possibilidade de delegação de **atividades acessórias** do poder de polícia, o STJ entendeu que toda a notificação de trânsito tem que ser lavrada pela autoridade administrativa, em virtude da indelegabilidade do poder de polícia. Todavia, é possível a delegação de atos materiais que precedem essa notificação feita pela autoridade administrativa.

Quando o STJ começa a desdobrar a atuação administrativa dentro do âmbito do poder de polícia, haverá o denominado **ciclos do poder de polícia** (Diogo de Figueiredo Moreira Neto⁷⁵):

- **Ordem de polícia:**

É um comando estatal, podendo ser um:

- **Comando negativo absoluto** (ordem de não fazer);
- **Comando negativo com reserva de consentimento** (ordem de não fazer enquanto a administração não autorizar a fazer);
- **Comando positivo** (ordem de fazer).

Em todos os casos há uma ordem de polícia. Ex.: o comando de não dirigir alcoolizado é um comando negativo absoluto. Por outro lado, a condução de veículo sem carteira de habilitação é um comando negativo que com consentimento ou sem consentimento poderá ser feito (com reserva).

Segundo o STJ, **não depende de prévio procedimento administrativo a recusa à expedição da CNH definitiva motivada pelo cometimento de infração de trânsito de natureza grave durante o prazo anual de permissão provisória para dirigir** (art. 148, § 3º, do CTB). O direito à obtenção da habilitação definitiva somente se perfaz se o candidato, após 01 ano da expedição da permissão para dirigir, não tiver cometido infração de natureza grave ou gravíssima e não for reincidente em infração média, segundo disposto no § 3º do art. 148 do CTB. Assim, a expedição da CNH é mera expectativa de direito, que se concretizará com o implemento das condições estabelecidas na lei. Havendo o cometimento de infração grave, revela-se desnecessária a instauração de prévio processo administrativo, considerando que a aferição do preenchimento dos requisitos estabelecidos pela lei para a concessão da CNH definitiva se dá de forma objetiva (Inf. 550, STJ).

- **Consentimento de polícia:**

Há um ato administrativo por meio do qual a administração verifica se a atividade ou o uso da propriedade estão adequados à ordem de polícia.

O consentimento vai se exteriorizar por um alvará, licença ou autorização.

- **Fiscalização:**

A Administração vai verificar se o particular está observando a ordem e o consentimento de polícia. Ex.: se o indivíduo não tinha carteira, não poderia dirigir sem a carteira. Após, o sujeito passou na prova e agora tem a CNH (consentimento). A lei diz que o sujeito pode andar, mas dentro da velocidade compatível. Neste caso, a administração está fazendo a fiscalização.

- **Sanção de polícia:**

⁷⁵MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. **Curso de direito administrativo: parte introdutória, parte geral e parte especial**. 15. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. P. 444-447.



Aqui há um ato administrativo que pune o administrado pelo desrespeito à ordem de polícia ou ao consentimento de polícia.

Para o STJ os atos de ciclos de polícia, denominados **consentimento de polícia** e **fiscalização de polícia**, **podem ser delegados a particulares**.

A imposição de restrição a direito individual não pode decorrer diretamente de um ato administrativo, ainda que de cunho normativo, pois esta restrição é um direito individual, **sendo necessário decorrer da lei**.

Dessa maneira, o poder de polícia poderá ser compreendido em dois sentidos:

- **Poder de polícia em sentido amplo:** seria o poder do Estado, entrando o Poder Legislativo que editar normas de caráter geral e inovador, as quais diminuirão ou condicionarão o exercício de um direito individual.
- **Poder de polícia em sentido estrito:** não se pode ter uma restrição a um direito individual por meio de um ato normativo. O poder de polícia em sentido estrito seria uma faculdade dada à administração, por meio do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, de fiscalizar e aplicar sanções nos casos de descumprimentos das proibições trazidas pela lei. Haverá restrições e sanções com base na lei.

4.4.1. ATRIBUTOS DO PODER DE POLÍCIA

São atributos do poder de polícia:

- **Discricionariedade:**
Cabe à administração avaliar qual é o momento mais oportuno para aplicar o poder de polícia e depois avaliar qual a sanção mais conveniente para aplicar ao caso. Por isso, o poder de polícia é discricionário. Ex.: autorização para portar arma, em que preenchidos os requisitos, a administração poderá autorizar.
Existem situações em que a administração estará compelida a agir de uma única forma. Nesses casos excepcionais, o poder de polícia é vinculado. Ex.: licença para dirigir veículo. Se a pessoa preencher os requisitos, deverá receber a CNH. Outro caso é a licença para construir.
- **Autoexecutoriedade:**
Autoexecutoriedade é a possibilidade de a administração decidir e **executar diretamente** o que ela decidiu, **sem a necessidade do Poder Judiciário**.
Este atributo não estará presente em todas as medidas de polícia da administração. A multa tem exigibilidade (coerção indireta), mas não tem executoriedade (coerção direta). Para receber a multa deverá ingressar no poder judiciário. Tanto é que não se pode reter o carro para compelir ao pagamento do valor da multa (STJ).
Deve a lei prever que o ato administrativo terá autoexecutoriedade, **ou no mínimo a urgência da situação poderá justificar que o ato tenha autoexecutoriedade**. Neste caso, há uma presunção de que a lei traz de forma implícita a autorização de que o ato seja executável.
- **Imperatividade:**
É o poder que a administração pública tem de impor uma obrigação ao particular, ainda que ele não concorde.
- **Coercibilidade:**
A administração pode utilizar de força para remover os obstáculos à efetivação de suas decisões.
A coercibilidade é inerente à autoexecutoriedade. A diferença é que a autoexecutoriedade permite que a administração execute diretamente os seus atos. Na coercibilidade é a força suficiente para que a administração execute o ato. Se não houver coercibilidade a autoexecutoriedade estaria esvaziada.

4.4.2. CONDIÇÕES DE VALIDADE OU LIMITES DO PODER DE POLÍCIA

Aqui há limitadores ao poder de polícia. São **limitadores ao poder de polícia** os aspectos relativos ao seu exercício. **Limitam o poder de polícia a competência, validade, forma do ato**, pois está ligado à validade do poder de polícia.

Um outro limite é a **necessidade de o ato respeitar o princípio da razoabilidade de da proporcionalidade**. O Estado quando exerce o poder de polícia, relativizando o direito de liberdade do indivíduo, deverá restringir o direito individual na exata proporção para beneficiar a coletividade.

Também poderá ser considerado limitador ao poder de polícia a própria **prescrição**. Isso porque após o descumprimento da ordem legal, o indivíduo estaria sujeito à punição, mas caso haja a prescrição, haverá essa limitação ao poder de polícia.

O art. 1º da Lei 9.873/99 diz que **prescreve em 05 anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta**, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Depois de instaurado o processo administrativo, **se este processo ficar paralisado por 03 anos, ocorrerá a prescrição intercorrente**.

Se o ilícito gerador da aplicação do poder de polícia também configurar um ilícito penal, o prazo de **prescrição da ação punitiva da administração também irá coincidir com o prazo de natureza penal**.

4.4.3. TAXAS DE POLÍCIA

A Administração, quando exercita o poder de polícia, **pode cobrar taxas de polícia**, espécie tributária. A taxa é um tributo vinculado a uma contraprestação estatal. No caso da taxa de polícia, este tributo **vincula-se ao custo da diligência**.

O poder de polícia está conceituado no art. 78 do CTN, o qual estabelece que: Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando **direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato**, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

O parágrafo único afirma ainda que: Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo **órgão competente** nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, **sem abuso ou desvio de poder**.

Em 2019 o STF entendeu que **a taxa de renovação de licença de funcionamento é constitucional, desde que haja o efetivo exercício do poder de polícia**, o qual é **demonstrado pela mera existência de órgão administrativo que possua estrutura e competência para a realização da atividade de fiscalização** (presunção de fiscalização efetiva). A base de cálculo da taxa de fiscalização seria a **área de fiscalização** (RCL30.326).

4.4.4. COMPETÊNCIA

A competência para exercer o poder de polícia é, em princípio, da pessoa federativa à qual a Constituição Federal conferiu o poder de regular a matéria, sendo **possível o poder concorrente** (exercício conjunto do poder de polícia, tal como ocorre no direito ambiental).

Assim, será **inválido** o ato de polícia praticado por agente de pessoa federativa que não tenha competência constitucional para regular a matéria e, portanto, para impor a restrição.

O STF tem inclusive a súmula 646, que diz: **ofende o princípio da livre concorrência** lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área.

A Súmula 645 do STF estabelece que é competente o **Município** para fixar o horário de funcionamento de **estabelecimento comercial**.



O STJ também editou a súmula 19, afirmando que a **fixação de horário bancário**, para atendimento ao público, é da competência da **União**.

Com relação às máquinas caça-níqueis, vídeo bingos, videopôquer e semelhantes, atividades incluídas no sistema de sorteios, cabe à União, e não aos Estados, autorizar e fiscalizar o seu funcionamento.

5. TESES DO STJ

- 1) A administração pública possui interesse de agir para tutelar em juízo atos em que ela poderia atuar com base em seu poder de polícia, em razão da inafastabilidade do controle jurisdicional.
- 2) O prazo prescricional para as ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, quando não existir legislação local específica, é quinquenal, conforme previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/32, sendo inaplicáveis as disposições contidas na Lei n. 9.873/99, cuja incidência limita-se à Administração Pública Federal Direta e Indireta.
- 3) Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (Súmula n. 467/STJ)
- 4) A prerrogativa de fiscalizar as atividades nocivas ao meio ambiente concede ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA interesse jurídico suficiente para exercer seu poder de polícia administrativa, ainda que o bem esteja situado dentro de área cuja competência para o licenciamento seja do município ou do estado.
- 5) Ante a omissão do órgão estadual na fiscalização, mesmo que outorgante da licença ambiental, o IBAMA pode exercer o seu poder de polícia administrativa, já que não se confunde a competência para licenciar com a competência para fiscalizar.
- 6) O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON detém poder de polícia para impor sanções administrativas relacionadas à transgressão dos preceitos ditados pelo Código de Defesa do Consumidor - art. 57 da Lei n. 8.078/90.
- 7) O PROCON tem competência para aplicar multa à Caixa Econômica Federal - CEF por infração às normas do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da atuação do Banco Central do Brasil.
- 8) A atividade fiscalizatória exercida pelos conselhos profissionais, decorrente da delegação do poder de polícia, está inserida no âmbito do direito administrativo, não podendo ser considerada relação de trabalho e, por consequência, não está incluída na esfera de competência da Justiça Trabalhista.
- 9) Não é possível a aplicação de sanções pecuniárias por sociedade de economia mista, facultado o exercício do poder de polícia fiscalizatório.
- 10) É legítima a cobrança da taxa de localização, fiscalização e funcionamento quando notório o exercício do poder de polícia pelo aparato administrativo do ente municipal, sendo dispensável a comprovação do exercício efetivo de fiscalização.
- 11) Quando as balanças de aferição de peso estiverem relacionadas intrinsecamente ao serviço prestado pelas empresas ao consumidor, incidirá a Taxa de Serviços Metrológicos, decorrente do poder de polícia do Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial - Inmetro em fiscalizar a regularidade desses equipamentos.
- 12) É legítima a cobrança da Taxa de Fiscalização dos Mercados de Títulos e Valores Mobiliários decorrente do poder de polícia atribuído à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, visto que os efeitos da Lei n. 7.940/89 são de aplicação imediata e se prolongam enquanto perdurar o enquadramento da empresa na categoria de beneficiária de incentivos fiscais.
- 13) Os valores cobrados a título de contribuição para o Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização - FUNDAF têm natureza jurídica de taxa, tendo em vista que o seu pagamento é compulsório e decorre do exercício regular de poder de polícia.



6. JURISPRUDÊNCIA

6.1. SÚMULAS STF

Súmula vinculante 49: Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área.

Súmula vinculante 38: É competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.

6.2. SÚMULAS STJ

Súmula 312 STJ: No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

6.3. INFORMATIVOS DO STF⁷⁶

As guardas municipais, desde que autorizadas por lei municipal, têm competência para fiscalizar o trânsito, lavrar auto de infração de trânsito e impor multas. O STF definiu a tese de que é constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício do poder de polícia de trânsito, inclusive para a imposição de sanções administrativas legalmente previstas (ex: multas de trânsito). STF. Plenário. RE 658570/MG, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 6/8/2015 (repercussão geral) (Info 793).

6.4. INFORMATIVOS DO STJ⁷⁷

Um dos atributos do poder de polícia é a autoexecutoriedade. Isso significa que a Administração Pública pode, com os seus próprios meios, executar seus atos e decisões, sem precisar de prévia autorização judicial. A Administração, contudo, pode, em vez de executar o próprio ato, ingressar com ação judicial pedindo que o Poder Judiciário determine essa providência ao particular. Ex: diante de uma irregularidade grave, a Administração Pública poderia, em tese, interditar o estabelecimento. Se ela, em vez de executar esta ordem diretamente, ajuíza ação pedindo que o Poder Judiciário determine essa providência, tal ação não pode ser julgada extinta por falta de interesse de agir. A autoexecutoriedade não retira da Administração Pública a possibilidade de valer-se de decisão judicial que lhe assegure a providência fática que almeja, pois nem sempre as medidas tomadas pelo Poder Público no exercício do poder de polícia são suficientes. STJ. 2ª Turma. REsp 1651622/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/03/2017.

A legislação de cada ente deverá prever o prazo prescricional da sanção de polícia. No âmbito federal o prazo é de 5 anos, com fundamento na Lei n.º 9.873/99. Caso não haja lei estadual ou municipal sobre o assunto, deverá ser aplicado o prazo prescricional de 5 anos por força, não da Lei n. 9.873/99, mas sim do art. 1º do Decreto 20.910/32; As

⁷⁶CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:<<https://www.Buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia>>.

⁷⁷CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:<<https://www.Buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia>>.



disposições contidas na Lei n.º 9.873/99 não são aplicáveis às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o seu art. 1º é expresso ao limitar sua incidência ao plano federal. Assim, inexistindo legislação local específica, incide, no caso, o prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32. STJ. 2ª Turma. AgInt no REsp 1409267/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 16/03/2017.

O PROCON detém poder de polícia para impor multas (art. 57 do CDC) decorrentes de transgressão às regras ditadas pela Lei n.º 8.078/90. Assim, a sanção administrativa aplicada pelo PROCON reveste-se de legitimidade, em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão do CDC. STJ. 1ª Turma. AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 04/08/2016.

QUESTÕES

1. (MPE-MG) FUNDEP, 2019. Sobre o poder de polícia e o exercício da segurança pública municipal, é correto afirmar, à luz do posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, que:

- A) a segurança pública, numa de suas dimensões, toca o exercício do poder de polícia, o que confere à polícia militar a titularidade da imposição de multas de trânsito, excluindo-se a possibilidade de a guarda municipal executar essa atividade.
- B) a fiscalização do trânsito, com aplicação das sanções administrativas legalmente previstas, embora possa dar-se ostensivamente, constitui atividade típica de segurança pública.
- C) o poder de polícia não se confunde com segurança pública; o exercício do primeiro não é prerrogativa exclusiva das entidades policiais, a quem a Constituição outorgou, com exclusividade, no art. 144, apenas as funções de promoção da segurança pública.
- D) a ordem jurídica brasileira estabeleceu que a atividade administrativa de fiscalização do trânsito é permitida à guarda municipal nas hipóteses de convênios celebrados com os órgãos policiais constitucionalmente legitimados para tanto.

2. (TJ-AL) FCC, 2019. A atuação da Administração Pública se dá sob diferentes formas, sendo o exercício do poder de polícia uma de suas expressões,

- A) presente na aplicação de sanções a particulares que contratam com a Administração ou com ela estabelecem qualquer vínculo jurídico, alçando a Administração a uma posição de supremacia em prol da consecução do interesse público.
- B) presente nas limitações administrativas às atividades do particular, tendo como principal atributo a imperatividade, que assegura a aplicação de medidas repressivas, independentemente de previsão legal expressa, a critério do agente público.
- C) dotada de exigibilidade, que confere meios indiretos para sua execução, como a aplicação de multas, e admitindo, quando previsto em lei ou para evitar danos irreparáveis ao interesse público, a autoexecutoriedade, com o uso de meios diretos de coação.
- D) verificada apenas quando há atuação repressiva do Poder Público, tanto na esfera administrativa, com aplicação de multas e sanções, como na esfera judiciária, com apreensão de bens e restrições a liberdades individuais.
- E) dotada de imperatividade, porém não de coercibilidade, pressupondo, assim, a prévia autorização judicial para a adoção de medidas que importem restrição à propriedade ou liberdade individual.

3. (MPE-PI) CESPE, 2019. De acordo com o STF, a competência das agências reguladoras para editar atos normativos que visem à organização e à fiscalização das atividades por elas reguladas representa o exercício de seu poder administrativo

- A) discricionário, que depende da conveniência e da oportunidade.



- B) de polícia, na sua função normativa, estando subordinado ao disposto na lei.
- C) normativo, que é dotado de autonomia com relação às competências definidas em lei.
- D) regulamentar, visando à normatização de situações concretas voltadas à atividade regulada.
- E) disciplinar, objetivando a punição do administrado pela prática de atividade contrária ao disposto no ato normativo.

4. (MPE-MG) FUNDEP, 2017. Dentre as alternativas abaixo sobre desvio de poder, indique a INCORRETA:

- A) O desvio de poder é vício de intenção, que deriva dos propósitos subalternos que animam o agente ou das circunstâncias de não realização da finalidade preordenada pela lei.
- B) O desvio de poder é vício objetivo que se refere ao descompasso entre a finalidade a que o ato serviu e a finalidade legal que por meio dele poderia ser servida.
- C) O desvio de poder é vício por omissão nas hipóteses em que a abstenção do ato é contrária ao que deveria ser feito, afinal “não agir é também agir”.
- D) O desvio de poder desnatura a finalidade da competência no exercício de atos impróprios à providência adotada.

5. (MPE-MG) FUNDEP, 2017. A respeito da legalidade administrativa, é CORRETO dizer:

- A) normatividade do Estado, no âmbito da atividade econômica, pressupõe planejamento como fator indicativo e estatístico ao setor público.
- B) Na regulamentação observa-se o poder de editar atos normativos (gerais e abstratos), bem como exercer a atividade administrativa controlando, fiscalizando e planejando o setor sob interesse.
- C) O decreto é espécie de ato administrativo de exclusiva competência do Presidente da República, cujo exercício, nos limites estabelecidos pelas leis e Constituição, ordena e organiza a ação administrativa, quer abstratamente, quer concretamente.
- D) O decreto regulamentar não cria, altera ou constitui direitos, apenas viabiliza na perspectiva operacional a adequada interpretação e aplicação da lei, ao passo que o decreto autônomo é espécie normativa primária, preexistente à lei.

COMENTÁRIOS

1. Gabarito – C.

- a) Incorreta. A fiscalização do trânsito pode ser exercida pelas Guardas Municipais.
- b) incorreta. A fiscalização do trânsito constitui atividade típica de segurança pública.
- c) Correta. Cf. STF, RE 658.570.
- d) Incorreta. Não é necessário convênio para que as Guardas Municipais possam exercer o poder de polícia.

2. Gabarito – C.

- a) Incorreta. A assertiva versa sobre o poder disciplinar, ou seja, a aplicação de sanções a particulares com vínculo específico com a Administração.
- b) Incorreta. As medidas aplicadas com base na imperatividade devem seguir o disposto na lei.
- c) Correta. A exigibilidade permite que o Poder Público imponha sanções administrativas por meios indiretos, sem necessidade de ação judicial. Já a autoexecutoriedade permite que se execute materialmente os atos administrativos, como forma de coagir o administrado, por meios diretos.
- d) Incorreta. O poder de polícia também atua de forma preventiva.
- e) Incorreta. Tanto a imperatividade como a coercibilidade são atributos do poder de polícia.

3. Gabarito – B

- A) Incorreta. Cf. Informativo nº 889 STF: o poder de polícia está relacionado com a competência para editar atos normativos, visando à organização e a fiscalização.
- B) Correta. Cf. Informativo nº 889 STF.
- C) Incorreta, de acordo com o Informativo nº 889 do STF o poder de polícia está relacionado com a competência para editar atos normativos visando à organização e a fiscalização.



D) Incorreta, uma vez que o poder normativo das agências reguladoras não abrange o poder de regulamentar leis, e sim atos de conteúdo técnico.

E) Incorreta. Cf. Informativo nº 889 STF.

4. Gabarito – A

a) Incorreta. Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello "No desvio de poder, ao contrário do que habitualmente se afirma e do que nós mesmos vínhamos sustentando, nem sempre há um 'móvel', isto é, uma intenção inadequada. Com efeito, o agente pode, equivocadamente, supor que uma dada competência era prestante, de direito, para a busca de um dado resultado e por isto haver praticado o ato almejando alcançá-lo pela via utilizada. Neste caso não haverá intenção viciada. (...)o ato será sempre viciado por não manter relação adequada com a finalidade em vista da qual poderia ser praticado. O que vicia, portanto, não é o defeito de intenção, quando existente - ainda que através disto se possa, muitas vezes, perceber o vício -, mas o desacordo *objetivo* entre a finalidade do ato e a finalidade da competência."

5. Gabarito - D.

a) Incorreta. Cf. Art. 174 da CRFB/88.

b) Incorreta. Os atos normativos administrativos possuem a função de complementar a lei, visando possibilitar sua fiel execução.

c) Incorreta. Pelo princípio da simetria, os decretos podem ser editados por Chefes do Poder Executivo dos demais Entes federativos.

d) Correta. Cf. art. 84, VI da CRFB/88.



CAPÍTULO 7 — AGENTES PÚBLICOS

1. INTRODUÇÃO

Qualquer pessoa que seja responsável, de forma definitiva ou transitória, pelo desempenho de uma função pública será considerada agente público. A nomenclatura “agentes públicos” é a mais abrangente possível, assemelhando-se, inclusive, à prevista no art. 327, *caput*, CP. Embora o Código Penal use a expressão “funcionário público”, encontra-se em desuso no direito administrativo, mas os conceitos de agente público e funcionário público são semelhantes no sentido de que ambos são bastante abrangentes e, nesse ponto, são também semelhantes ao conceito de agente público previsto no art. 1º da lei de improbidade administrativa.

Portanto, ainda que de forma temporária ou não remunerada, será caracterizado o sujeito como agente público. Ou seja, agente público é uma expressão que designa qualquer pessoa, particular ou não, que de forma transitória, ainda que sem remuneração, atue em nome do Estado. Não é necessário que essa pessoa tenha um vínculo específico com a Administração. Poderá ser um particular, mas desde que atue em nome do Estado. Por exemplo o jurado ou mesário.

Imagine, então, que dentro da divisão agentes públicos, nós tenhamos três grandes grupos: agentes políticos, particulares em colaboração e agentes estatais/agentes administrativos.

A doutrina, no entanto, diverge bastante no que diz respeito a essa classificação. Hely Lopes Meirelles⁷⁸, que traz uma classificação bastante tradicional, entende que seriam agentes políticos os agentes delegados, os agentes credenciados e os agentes administrativos.

Adotaremos aqui que os agentes credenciados, os agentes honoríficos e os agentes delegados estarão dentro da classificação de particulares em colaboração. Destaque-se que parte da doutrina entende que os agentes públicos são apenas os agentes políticos, agentes credenciados, agentes honoríficos, agentes delegados e agentes administrativos.

Será considerado agente público o sujeito **pela atividade que exerce**, e não pela pessoa que é.

2. CLASSIFICAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS

Celso Antonio Bandeira de Mello⁷⁹ classifica os agentes públicos em:

- Agentes políticos
- Servidores públicos
- Militares
- Particulares em colaboração com o Poder Públicos

2.1. AGENTE POLÍTICO

Agentes políticos são os responsáveis pela vontade política do Estado, aqueles que exercem função política. Há um dissenso doutrinário sobre quais agentes exercem função política, existindo um conceito mais restritivo e um conceito mais amplo. Há um consenso, porém, no que se refere aos exercentes de mandato eletivo.

Com certeza são agentes políticos, por exemplo, o Presidente da República, os parlamentares, os prefeitos, os governadores. Também são considerados agentes políticos os secretários e ministros de estado. Estes seriam o núcleo duro do conceito de agentes políticos.

⁷⁸MEIRELLES, Hely Lopes. **Direito Administrativo Brasileiro** 43a. edição. São Paulo: Malheiros, 2018.

⁷⁹MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Curso de Direito Administrativo** 33ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019



Porém, há autores, como Diógenes Gasparini⁸⁰, que entendem que membros do Ministério Público e da Magistratura também são agentes políticos. São indivíduos bastante diferenciados do servidor público comum, uma vez que compõe estruturas autônomas e exercem ao fim ao cargo funções políticas.

Nesse sentido, há quem coloque dentro da classificação de agentes políticos não só os exercentes de mandato eletivo (eventualmente secretários e ministros) como também MP e magistratura. Caso seja cobrado em provas objetivas pode-se considerar esta alternativa como correta, pois esse entendimento já goza de certa aceitação da boa parte da doutrina.

Há um conceito ainda mais amplo em que os integrantes das carreiras dos Tribunais de Contas e defensores públicos também seriam agentes políticos.

São agentes políticos:

- Presidente da República, governador de Estado e prefeitos.
- Ministro de estado, secretário estadual e secretário municipal.
- Deputados federais e senadores, deputados estaduais, distritais e vereadores.
- Membros do MP e membros do Poder Judiciário (STF, Info. 438, RE 228.977 e RE 553.637 ED).

Em relação aos **membros de Tribunais de Contas**, há precedente do STF que estes **não se enquadram no conceito de agente político** (Info. 537). Contudo, o STF entende que a Súmula Vinculante nº 13, que veda o nepotismo, aplica-se aos membros dos Tribunais de Contas (Rcl 6.702 MC-AgR). O STF, a doutrina, de um modo geral, repele o enquadramento dos Conselheiros dos Tribunais de Contas na categoria de agentes políticos, os quais, como regra, estão fora do alcance da Súmula Vinculante 13, salvo nas exceções apontadas pela Corte: as hipóteses de nepotismo cruzado ou de fraude à lei.

2.2. SERVIDORES PÚBLICOS

Servidor público é o agente público que tem vínculo com a Administração direta ou indireta. É um agente público que recebe a remuneração do Estado.

Os servidores públicos podem ser classificados em:

- Servidores estatutários
- Empregados públicos
- Servidores temporários

2.2.1. SERVIDORES ESTATUTÁRIOS

Servidor estatutário, como indica o nome, é aquele que está sujeito a um estatuto. O regime estatutário é o **estabelecido pela lei**, impondo direito e obrigações do servidor público para com o Estado. Estes servidores ocupam **cargos públicos**.

Havendo uma desavença pelo servidor contra o Estado, é solucionado pela Justiça Comum.

2.2.2. EMPREGADOS PÚBLICOS

O empregado público tem uma relação empregatícia, sendo submetido à legislação trabalhista. É uma relação de trabalho **regida pela CLT**.

Havendo uma desavença com seu empregador, será julgado pela **Justiça de Trabalho**.

⁸⁰GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014.



2.2.3. SERVIDORES TEMPORÁRIOS

O concurso público é a forma determinada pela CRFB para a seleção e contratação de pessoal na Administração Pública. Mas há a previsão de duas hipóteses de contratação sem concurso prévio: as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração (art. 37, inciso II); e a contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, inciso IX).

A Lei nº 8.745/93 regula a contratação de servidores temporários, determinando o que deve ser a necessidade temporária do excepcional interesse público. Por exemplo: situações de calamidade pública (como a COVID19), assistência a emergência em saúde pública, realização de recenseamentos e outras pesquisas de natureza estatística efetuadas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, admissão de professor substituto e professor visitante, entre outros.

O servidor temporário encontra suas previsões na CRFB, podendo ser contratados sem concurso por um tempo determinado. O que justifica a contratação de servidores temporários é a situação de **necessidade temporária de excepcional interesse público**.

O servidor temporário vai exercer uma função, mas não está vinculado a um cargo e nem a um emprego público. Para o STJ **é possível a contratação temporária de servidor temporário, ainda que seja para o exercício de atividade permanente**, desde que haja uma **situação temporária de excepcional interesse público** (MS 20335-DF).

STF entende que o art. 37, IX, da CF/88 **autoriza que a Administração Pública contrate pessoas, sem concurso público**, tanto para o desempenho de atividades de caráter eventual, temporário ou excepcional, como também para o desempenho das funções de caráter regular e permanente, **desde que indispensáveis ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público**. (ADI 3068).

Servidor temporário deverá ser julgado na Justiça Comum, pois a relação jurídica estabelecida com o Estado é uma relação jurídica de direito público.

2.3. MILITARES

Os militares são agentes públicos, com previsão na CRFB, mas com regime disciplinado em lei própria.

O regime jurídico pelos militares é erigido sob dois pilares **hierarquia e disciplina**.

São direitos dos militares:

- Direito ao 13º salário.
- Direito ao salário família.
- Gozo de férias remuneradas com um terço a mais.
- Direito a licença gestante e paternidade

Aos militares é vedada a sindicalização, a greve e a filiação partidária.

Quanto à vedação de greve por militares, **o STF estende esta vedação aos policiais civis**, a despeito de a norma ser restritiva de direitos e da inexistência de óbice explícito ao policial civil (ARE 654.432).

2.4. PARTICULARES EM COLABORAÇÃO COM O PODER PÚBLICO

Aqui há um particular que colabora com o Poder Público. São pessoas físicas que prestam serviços ao Estado sem vínculo empregatício, com ou sem remuneração.

Os particulares em colaboração com o Poder Público podem ser classificados em:

- **Particulares que receberam uma delegação do poder público:** é o caso dos **serviços notariais** (concurso de cartórios). O oficial de cartório recebe uma delegação do Poder Público, exercendo uma função pública em seu próprio nome. Aqui há o oficial do cartório, registrador, notarial, etc., os quais são **remunerados pelo particular**.



- **Particulares em colaboração por requisição, nomeação ou designação:** esses são os jurados, conscritos, mesários da justiça eleitoral, etc.
- **Gestores de negócios:** é uma pessoa que assume espontaneamente o desempenho de uma função pública, pois está diante de uma situação de emergência. Não há nomeação e nem designação do Estado. Ex.: terremoto, epidemia ou inundação, o particular colabora com o Poder Público.

O que une essas três classificações é o fato de que todas são particulares e remanescem particulares, mas atuam em uma função estatal.

Os exemplos clássicos de agentes honoríficos são os de jurado e mesário. Ou seja, se, eventualmente, um mesário, numa determinada eleição agride uma pessoa que vai votar, ou falta com o seu dever e prejudica alguém, haverá uma hipótese de responsabilidade civil do estado. Se trata de um particular em colaboração com o Estado, mais especificamente é um agente honorífico, que é um particular que está ali em razão do estado.

Os agentes credenciados são particulares que atuam no SUS, por exemplo. São os casos de médicos particulares que são credenciados ao SUS. Esse médico pode ser uma pessoa jurídica que presta serviços ao SUS ou empregado do hospital. É sempre um hospital particular que, por acaso, é conveniado ao SUS. Esse médico pode ser considerado agente público por se tratar de ser um agente credenciado.

Ou seja, ainda que ele seja um particular que nunca fez concurso público e que, portanto, não está vinculado de forma mais estreita ao estado, age naquele momento enquanto médico da rede conveniada do SUS e qualquer erro médico por ele praticado gera responsabilidade civil do estado.

Os mais conhecidos dentre os agentes delegados são os titulares de serventias registras e notariais (mais popularmente conhecidos como “donos de cartórios”): são agentes que não exercem cargo público, que continuam sendo particulares, mas que atuam como delegação do estado. É titular de uma serventia que presta serviços públicos.

Nesse sentido, ele atua por conta própria, sendo responsável por ônus e bônus de sua atividade. Paga tributos como pessoa natural mas atua exercendo uma função que é pública, portanto, é possível cogitar a responsabilização do Estado. Caso haja condenação ao titular do cartório e este não tiver como pagar, haverá direito de regresso contra o Estado, afinal de contas se trata de uma atividade delegada.

Importante ressaltar que os titulares só respondem por dolo ou culpa. Há uma disposição sobre isso ser ou não constitucional, uma vez que o delegatário do serviço público e responderia objetivamente por atuar em nome do estado. Ainda não há qualquer declaração de inconstitucionalidade sobre o referido dispositivo legal, sendo, portanto, vigente.

Os agentes delegados não são propriamente servidores públicos, não exercem cargo público, sendo o concurso apenas uma exigência para fins de impessoalidade, para que essa delegação seja dada para quem mais merece, o que significa que essas pessoas não estão sujeitas à aposentadoria compulsória, tendo o STF pacificado a questão (ADI 2602).

3. CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES PÚBLICAS

3.1. CARGO PÚBLICO

Cargo é um **local criado por lei**, dentro do serviço público, que possui uma **atribuição, nomenclatura e uma remuneração própria**. Ex.: concurso para o cargo de delegado de polícia civil.

O cargo se subdivide em:

- **Cargo efetivo:** é o cargo cujo provimento deriva de um concurso público, ou seja, de prévia aprovação em concurso público.
- **Cargo em comissão:** é um cargo de livre nomeação e livre exoneração, devendo ser criados por lei, mas apenas para atribuições de direção, assessoramento ou de chefia. A CF diz que a lei vai



determinar um **percentual mínimo para esses cargos em comissão que devem ser ocupados por servidores de carreira.**

3.2. EMPREGO PÚBLICO

Emprego público é um **local no serviço público**, também criado por lei, que também possui uma **atribuição, nomenclatura e uma remuneração própria**. O emprego público **se submete ao regime trabalhista (CLT)**.

É o vínculo que liga a pessoa à administração que diferencia o emprego público do cargo público.

3.3. FUNÇÃO PÚBLICA

Função é atribuição, é a atividade que o servidor faz.

Existe função sem cargo e sem emprego, como é o caso do particular em colaboração com a administração. Todo cargo possui função, mas nem toda função tem um cargo.

A função pode ser conferida ao cargo, mas que pode ser conferida a alguém que desempenha uma função pública em caráter excepcional.

Os cargos, empregos e as funções públicas **só podem ser criados por lei**. No entanto, **a extinção de cargos e funções públicas podem se dar por meio de decretos ou por meio de lei**. São os chamados decretos autônomos, expedidos pelo chefe do poder executivo.

3.3.1. DIFERENÇA ENTRE CARGO EM COMISSÃO E FUNÇÃO DE CONFIANÇA

Funções de confiança são atribuições baseadas na confiança, as quais só podem ser criadas por lei, para o desempenho de chefia, assessoramento ou direção.

A diferença é que a função de confiança só pode ser desempenhada por servidor de carreira (efetivo).

O cargo em comissão pode ser exercido por uma pessoa sem vínculo com a administração ou por servidores de cargos efetivo.

4. REGIME JURÍDICO DO SERVIDOR

Em primeiro lugar, o STF entende que servidor não tem direito adquirido a regime jurídico, podendo o Estado modificá-lo unilateralmente, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos (RE 563.965).

O estado poderá inclusive transformar o regime jurídico estatutário num regime jurídico celetista. Mas se o vínculo do servidor com o Estado é celetista (contratual), o **Estado não pode obrigar o servidor a adotar o novo regime, pois o vínculo é contratual**. Neste caso, o servidor terá a opção de mudar para o novo regime.

O servidor estatutário não tem essa opção, não tendo direito adquirido ao regime jurídico.

Cabe analisar aqui o chamado **regime jurídico único**, que decorre do art. 39 CRFB/88. Este prevê que os entes da federação deverão adotar um único regime para reger os servidores das respectivas Administrações Públicas (direta, autárquica e fundacional), devendo optar por exclusivamente o regime estatutário ou apenas o regime celetista. A CRFB não indica, contudo, em quais situações deverá ser utilizado um ou outro regime, apenas que deverá ser único.

Porém, a questão está sob análise do STF. Explica-se: a EC nº 19/1998 deu nova redação ao art. 39 CRFB, tornando possível a adoção do regime jurídico pluralizado (adoção dos dois regimes na administração pública, o estatutário para cargos públicos e o celetista para empregos públicos) ao suprimir a exigência de



obrigatoriedade de adoção de regime único. Em seguida a Lei nº 9.962/2000 admitiu a adoção do regime celetista, além do estatutário, para a Administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Assim a União poderia, por exemplo, realizar concurso para admitir empregados celetistas para Autarquias.

A EC nº 19/1998 teve sua constitucionalidade formal contestada através da ADI nº 2.135-4, sob a alegação que não teria sido observado o *quórum* mínimo de 3/5 previsto no art. 60 § 2º CRFB. O STF, em decisão cautelar de 02/08/2007, suspendeu a eficácia da nova redação do art. 39 CRFB. A decisão precária e provisória impede a adoção do regime jurídico pluralizado a partir da data de deferimento da cautelar, e até que seja julgada em definitivo a ADI. Assim, a partir da publicação do acórdão do deferimento da medida cautelar em 07/03/2008 tornou-se inviável a contratação de pessoal pela CLT, por considerar que esta disciplina relação de caráter tipicamente privado. Porém, em nome da segurança jurídica, foram ressaltados os contratos já existentes. A medida cautelar também atingiu os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37 IX CRFB). Até 25/04/2020 a ação principal da ADI 2.135 ainda não havia sido julgada, estando pendente a apreciação de petição de *amicus curiae*.

5. CONDIÇÕES DE INGRESSO

O art. 37 da CF, em seu inciso II, diz que a investidura em cargo ou emprego público dependem de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. O que **não pode é haver concurso apenas por meio de títulos**. Ressalva-se em relação aos cargos em comissão, que são cargos de livre nomeação e livre exoneração.

Os cargos e os empregos públicos são acessíveis aos brasileiros, sejam eles brasileiros natos ou naturalizados. Também são acessíveis aos estrangeiros na forma da lei. A CF consagra uma **norma de eficácia limitada**. Portanto, a admissão de estrangeiro em cargo público e em emprego público depende de regulamentação legal.

A Lei nº 11.892 autoriza o ingresso de estrangeiros a cargo ou empregos públicos **de professor de universidades federais ou professor de instituto federal de pesquisa científica (pesquisador)**. Porém, o STF irá decidir se estrangeiro aprovado em concurso público para provimento de cargo de professor, técnico ou cientista em universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais tem direito à nomeação e à posse. O tema é objeto do Recurso Extraordinário 1.177.699, que, por unanimidade, teve a repercussão geral reconhecida no Plenário Virtual do Tribunal, mas ainda está pendente de julgamento.

É vedada, via de regra, entre brasileiro nato e brasileiros naturalizados, salvo aquelas previstas na CF e pelo poder constituinte originário. Portanto, **serão somente admissíveis aos brasileiros natos** os seguintes cargos:

- Presidente e Vice-Presidente da República;
- Presidente da Câmara dos Deputados;
- Presidente do Senado Federal;
- Ministro do Supremo Tribunal Federal;
- Carreira diplomática;
- Oficial das Forças Armadas.
- Ministro de Estado da Defesa

6. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO

O inciso III do art. 37 da CF diz que o prazo de validade do concurso público será de **até 02 anos, prorrogável uma vez, por igual período**. Pode ter prazo de validade de até 1 ano, podendo ser renovado por igual período. O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previsto no edital, tem direito líquido e certo à nomeação. O candidato aprovado fora do número de vagas não tem esse direito subjetivo à nomeação, mesmo que surjam novas vagas no prazo de validade do certame.



No RE 598.099, decidido em repercussão geral pelo STF, chegou-se ao entendimento de que há sim direito subjetivo à nomeação daquele que foi aprovado dentro do número de vagas previstas no edital.

O STJ entende que o candidato aprovado fora das vagas, mas classificado dentro do limite de vagas surgidas dentro do prazo e validade do concurso vai ter direito líquido e certo **se o edital dispuser que, além das vagas previstas no edital, serão providas as vagas que vierem a existir durante a validade do concurso** (RMS 37.700 e AgRg no RMS 28368/RS).

O STJ entende que o candidato aprovado fora das vagas passa a ter o direito subjetivo à nomeação, quando o candidato imediatamente anterior a ele for convocado para a vaga posteriormente e manifestar a desistência (AgRg no RMS 41.031/PR e STJ, AgRg no RMS 48.266/TO).

O STF, em repercussão geral, entendeu que o direito subjetivo à nomeação não tem caráter absoluto, pois **excepcionalmente a administração poderá deixar de nomear os candidatos que foram aprovados dentro do número de vagas**, mas deverá cumprir os seguintes requisitos (RE 598.099):

- **Superveniência do fato ensejador:** o fato ensejador da impossibilidade de nomeação deve ter sido posterior à publicação do edital
- **Imprevisibilidade:** a situação deve ser imprevisível à época da publicação do edital.
- **Gravidade:** os acontecimentos devem ser extremamente gravosos.
- **Necessidade:** a administração só pode deixar de nomear os candidatos quando não existirem meios menos gravosos de lidar com a situação excepcional.

O STF ainda entende que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

- Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;
- Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;
- Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (RE 837.311)

7. CONTROLE DOS CONCURSOS PÚBLICOS

No que concerne ao **controle dos concursos públicos**, a própria administração faz o controle (autotutela), mas o Poder Judiciário também poderá fazê-lo, mas isto será por meio de um **juízo de legalidade**. Não cabe ao Poder Judiciário o papel de revisor das bancas de concurso público, devendo se pautar na verificação de compatibilidade daquilo que foi cobrado e aquilo que está previsto no edital. O Judiciário não pode corrigir a questão.

Admite-se que o legislador fixe critérios limitativos quanto ao sexo e idade dos candidatos, mas para tanto é necessário que haja uma relação lógica e sejam necessárias em razão das atribuições que sejam exercidas. Ou seja, são possíveis essas limitações, desde que **respeitem a proporcionalidade**.

A aferição do cumprimento desses requisitos do edital deve ser aferida no momento da posse (regra geral).

Nos concursos para ingresso na **magistratura e no Ministério Público**, o STF firmou o entendimento de que é constitucional a exigência do edital de comprovação do preenchimento dos **requisitos na inscrição definitiva** do concurso (RE 655.265).



A exigência de exame psicotécnico é legal, **desde que esteja prevista na lei e no edital**. Não basta apenas que o edital exija a previsão de psicotécnico, sendo necessário que a lei faça essa previsão.

O STF, na súmula 686 e posteriormente na Súmula Vinculante 44, diz que só por lei pode sujeitar a exame psicotécnico candidato para determinado cargo público. Portanto, o exame psicotécnico depende de previsão legal.

Os exames físicos são legítimos, desde que **exista previsão legal e em edital e guardem relação de pertinência com as atividades que serão desenvolvidas**. (STJ RMS 56.200-AgInt-EDcl/PE).

Em relação à exigência de exame físico, o STF já definiu que **é vedada a realização de segunda chamada, ainda que haja uma incapacidade temporária excepcional**, salvo se o edital trazer a previsão no sentido da possibilidade de admitir a segunda chamada (630.733/DF).

Porém, no final de 2018 o mesmo **STF reconheceu o direito de candidatas gestantes à remarcação de testes de aptidão física em concursos públicos, independentemente de haver previsão no edital** (RE 1.058.333). O STF entendeu o nascimento com êxito exorbita os limites individuais da genitora, alcançando a própria coletividade. Enquanto a saúde pessoal do candidato em concurso é motivo exclusivamente individual e particular, a maternidade e a família constituem direitos de solidariedade. Por ter o Poder Constituinte estabelecido expressamente a proteção à maternidade, à família e ao planejamento familiar, a condição de gestante goza de proteção constitucional reforçada. Em razão desse amparo constitucional específico, a gravidez não pode causar prejuízo às candidatas, sob pena de ofender os princípios da isonomia e da razoabilidade.

8. RESERVA DE VAGAS

Com relação à reserva de vagas para pessoas com deficiência, a CF, no art. 37, VIII, estabelece que a lei vai reservar um percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas com deficiência.

A Lei 7.852 garantiu o percentual mínimo de 5% das vagas a ser destinadas às pessoas com deficiência. A Lei 8.112 trouxe o percentual máximo, o qual será de 20%.

Diante de o mínimo ser 5% e o máximo for de 20%, se houver duas vagas, não é necessário observar esse percentual. Se houver 05 vagas, uma deverá ser para pessoa com deficiência.

Por fim a **Lei 12.990/2014 reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal**, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União. A Lei tem validade de dez anos, período contado a partir da data da sanção presidencial. A **lei foi declarada constitucional pelo STF na ADC 41/DF**. Entendeu o STF que uma sociedade justa e solidária repousa no tratamento igualitário, sendo o sistema de cotas instrumento cabível para corrigir a notória falta de oportunidade para os negros, concluindo que é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.

9. PROVIMENTO E VACÂNCIA

9.1. PROVIMENTO

Prover é preencher. Provimento é o preenchimento de um cargo ou função. São tipos de provimento:

- **Provimento originário:** não há prévia vinculação com a administração pública.
- **Provimento derivado:** depende de vínculo anterior do servidor com a administração pública.



Quando o servidor é nomeado e não toma posse, não se exonera o servidor. Neste caso, a **nomeação é tornada sem efeito**. Por outro lado, caso o servidor **tome posse, mas não entre em exercício, será o servidor exonerado**. Lembre-se que **posse poderá se dar por procuração**, mas exercício não.

São formas de provimento:

- **Nomeação:** é a forma mais comum, ocorrendo para o provimento originário, em relação aos cargos efetivos e para os cargos em comissão. Após a nomeação, o servidor tem 30 dias para tomar posse e 15 dias para entrar em exercício, na órbita federal.
- **Provimento vertical:** o servidor vai ingressar no cargo em uma categoria mais elevada. Ex.: sujeito era juiz de direito e passa a ser desembargador.
- **Readaptação:** readaptar ocorre quando o servidor passa a ocupar um cargo diverso ao que ocupava em razão da necessidade de adequar o desempenho da função com a limitação física ou psíquica que o servidor experimentou.
- **Recondução:** é o retorno do servidor estável ao cargo que anteriormente ocupava, em razão da anterior **inabilitação de estágio probatório relativo a outro cargo** ou **houve a reintegração de outro servidor ao cargo que ele estava**. Reconduzir é fazer voltar para o cargo que ocupava. Ou seja, é necessário que não se tenha adquirido a estabilidade no novo cargo e que tenha estabilidade no cargo anterior.

Segundo o STJ, não é possível a aplicação, por analogia, do instituto da recondução previsto na Lei 8.112/1990 a servidor público estadual na hipótese em que o ordenamento jurídico do estado for omissivo acerca desse direito. A analogia das legislações estaduais e municipais com a Lei 8.112/1990 somente é possível se houver omissão no tocante a direito de cunho constitucional autoaplicável que seria necessário para suprir a omissão da legislação estadual, bem como que a situação não dê azo ao aumento de gastos.

- **Reintegração:** é o retorno do servidor demitido ilegalmente, por força de anulação da demissão.
- **Aproveitamento:** é o reingresso de servidor que estava em disponibilidade, sendo agora aproveitado. Agora, surgiu vaga em um cargo com a natureza e vencimento compatível com o cargo do servidor que anteriormente havia sido colocado em disponibilidade.
- **Reversão:** a reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado, dando-se em interesse da administração ou por conta da cessação da invalidez temporária. Quando o pedido de reversão ocorre no interesse da administração, só será atendido se houver 3 condições:
 - existência de um cargo vago
 - aposentadoria ter sido voluntária e ter ocorrida há menos de 5 anos da solicitação da reversão
 - servidor ser anteriormente estável na atividade

Disponibilidade é uma **garantia de inatividade remunerada**. Essa garantia é assegurada ao servidor **estável**, no caso do cargo em que ocupava ser extinto ou ser declarada a desnecessidade do cargo. Nesse caso, passa à inatividade remunerada, sendo esta **remuneração proporcional ao tempo de serviço**.

Apesar de não estarem no rol da Lei 8.112/90, existem outras formas de provimentos:

- **Transformação e reclassificação:** o servidor público civil será investido em um novo cargo ou função, com diferente denominação ou enquadramento, por força da extinção do cargo ou da função que detinha. Isto é comum com as procuradorias de autarquias federais as quais se tornaram procuradorias federais.

9.2. VACÂNCIA

Vacância é o fato administrativo pelo qual o servidor é destituído do cargo, surgindo uma vaga.

Além das hipóteses de provimento, há a vacância, que é justamente o oposto. A vacância ocorre justamente quando uma pessoa deixa de ocupar um cargo público, enquanto o provimento é quando ela



passa a ocupar o cargo público, seja alterando de cargos dentro da administração (provimento derivado), seja tendo a possibilidade de ingressar em um cargo sem que antes ocupasse algum outro cargo na administração (provimento originário, como nomeação).

A vacância ocorre por exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria ou posse em outro cargo incompatível. Isso está previsto no art. 33 da lei 8112/91.

Quando a pessoa se aposenta, o cargo fica vago, pois deixa de ocupar o cargo.

De igual maneira, quando é promovida, se era, por exemplo, procuradora federal de primeira categoria e passa para a segunda categoria, haverá a troca de cargo, permanece na mesma carreira, mas ascendeu de nível, vagando o cargo anterior.

Por outro lado, a demissão é uma hipótese de vacância. Importante lembrar que, enquanto no direito trabalhista a demissão é um ato por meio do qual o empregado pede para sair, sendo despedimento o ato pelo qual ele é mandado embora. No direito administrativo é diferente, ou seja, a demissão é quando algum tipo de irregularidade por ter cometido, por exemplo, algum ato de corrupção ou de improbidade, há um procedimento administrativo disciplinar, ele é demitido do serviço público.

Já quando o próprio servidor pede para sair, é uma hipótese de exoneração. Importante lembrar, também, que o indivíduo que está em estágio probatório pode ser “mandado embora” sem que configure uma demissão, mas sim uma exoneração, por não ser esse indivíduo estável. Portanto, caso não seja aprovado na avaliação de desempenho pode ser exonerado do serviço público.

A exoneração pode ser tanto um ato de vontade do titular do cargo que deseja sair e pede a sua exoneração como, eventualmente, forma de vacância do cargo quando o indivíduo não goza de estabilidade ou vitaliciedade.

A demissão tem um caráter punitivo e a exoneração, não necessariamente. A exoneração de pessoa que não foi aprovada no estágio probatório não se trata de uma punição, mas sim de se constatar de que ela pessoa não preenche os requisitos para se tornar estável no serviço público a fim de que ingresse de forma definitiva.

Por fim, a posse em outro cargo incompatível é quando uma determinada pessoa toma posse em um cargo que, sem pedir exoneração do cargo anterior, sendo os dois cargos incompatíveis, o primeiro cargo tornar-se-á vago, como se pedisse, automaticamente, para sair.

Se o indivíduo toma posse sem pedir exoneração do anterior e sendo os cargos incompatíveis, automaticamente haverá vacância do primeiro, conforme estabelece a lei 8.112/91.

Mas a própria lei 8.112/91 tem um próprio regramento específico no que diz respeito a como lidar com esse tipo de problema.

De acordo com a inteligência do art. 133, o indivíduo tem uma espécie de boa-fé presumida, ou seja, se no prazo para apresentação de resposta, ele fizer opção pelo cargo que desejar, não terá, inclusive, que devolver o que recebeu de forma equivocada, de forma até inconstitucional, porque se presume a sua boa-fé, conforme dispõe no seu §5º.

Sobre a possibilidade de acumulação de cargos confira o item 9.11.

10. CRIAÇÃO DE CARGOS

Pelo disposto no art. 169, CF, eventual aumento da remuneração dos servidores ou autorização para provimento de cargos, devem estar previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Não basta a previsão no orçamento, na Lei Orçamentária Anual. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que disciplina a edição da LOA, deve conter autorização para eventual aumento remuneratório. A LDO sempre precisa conter autorização para aumento remuneratório ou para provimento de cargos.

O STF entende que é inconstitucional uma lei que conceda aumento a servidor público do executivo federal sem iniciativa do Presidente da República (ADI 1.124). Só o Presidente da República tem iniciativa para propor projeto de lei com aumento remuneratório ao executivo federal. Essa regra é aplicada por simetria aos servidores dos estados, ou seja, é o Governador que possui iniciativa privativa para aumentar a remuneração dos professores da rede pública estadual, por exemplo (ADI 2872).



Por outro lado, quando se tratar de criação de cargos no legislativo, cada Mesa é que tem iniciativa. Por exemplo, no Senado, é a Mesa do Senado que possui iniciativa para propor a criação de cargos e da mesma forma acontece com a Câmara, devendo a aprovação vir por meio de uma resolução interna de cada casa.

Quando se tratar de criação de cargos ou aumento no Judiciário, os próprios Tribunais que gozam da iniciativa. Tratando da esfera federal, o STF é quem goza da iniciativa, mandando uma proposta de LDO, e depois de LOA, para o executivo. Mas essas propostas têm que ser aprovadas por meio de lei pelo Congresso Nacional.

O Procurador Geral da República, na esfera federal, é quem pode criar cargos e propor aumento remuneratório no Ministério Público, nas esferas do MPU como um todo (MPT, MPM, MPDFT, MPF), e na esfera estadual seria o Procurador Geral de Justiça. Possui a iniciativa, mas a aprovação é por meio de lei, aprovada pelo Congresso Nacional.

Haverá vacância quando ocorrer:

- **Exoneração:** seja a pedido ou de ofício pela administração, nos casos de cargo em comissão ou de inabilitação em estágio probatório.
- **Demissão:** é uma sanção administrativa, após um procedimento administrativo com ampla defesa e contraditório.
- **Promoção, readaptação e aposentadoria:** ocorre quando alguém é promovido, abrindo o cargo anterior. Ex.: proveu juiz a desembargador, abrindo vaga para juiz. Da mesma forma ocorre com a readaptação, em que a pessoa sai do cargo para ir para outro compatível com suas necessidades. A aposentadoria é uma forma de vacância.
- **Posse de outro cargo inacumulável**
- **Falecimento do servidor**

11. REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES

Existem duas formas de remuneração:

- **Vencimentos:** há o pagamento de uma parcela fixa e uma parcela variável (gratificação, adicional, indenização, etc.). As parcelas fixas são chamadas de **vencimento**, e as variáveis são adicional, gratificação, etc. Quando se referir a vencimentos, estar-se-á compreendendo a parcela fixa e a parcela variável.
- **Subsídios:** é o pagamento feito por uma parcela única.

A Constituição diz que alguns cargos **necessariamente** devem ser remunerados por subsídio:

- Membros do Poder Judiciário
- Membros do MP
- Membros do Legislativo
- Membros do Tribunal de Contas
- Membros da AGU
- Membros da defensoria pública
- Policiais

Os outros cargos podem receber subsídios, mas também podem ser remunerados por vencimentos, depender da lei.

É importante saber que a fixação ou alteração da remuneração só pode ser feita por **lei específica**, com exceção dos membros do Poder Legislativo que terão suas remunerações fixadas por ato do Congresso Nacional, conforme a CF.



A EC 19/98 **proibiu qualquer vinculação ou equiparação de remuneração**. Isto significa que estão vedados os denominados reajustes automáticos de vencimentos ou subsídios. A EC vedou por exemplo que o delegado de polícia tenha subsídio de 80% do subsídio do juiz.

A CF ainda assegura aos servidores públicos a chamada **revisão geral anual**.

A constituição fixa como teto máximo de remuneração o **subsídio mensal do ministro do STF (art. 37 XI)**. A indenização não entra no limite do teto constitucional. Atente-se que o **subsídio de ministro do STF também é o teto para empresas públicas, sociedades de economia mista e as suas subsidiárias que recebam recursos públicos para custearem as suas despesas**. Se não receber esta ajuda do governo para custear despesas, não é necessário observar a exigência do teto constitucional. Ex.: presidente de um banco público não recebe o teto constitucional.

12. PERDA DO CARGO DO SERVIDOR ESTÁVEL

Um servidor estável pode perder o cargo público quando estiverem presentes qualquer das hipóteses do art. 41 e 169, §3º, ambos da CF. O art. 169, §3º, CF trata justamente sobre o enxugamento de despesas da máquina pública.

Segundo o art. 41, servidor poderá perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, por ter sido condenado por um crime com pena igual ou superior a um ano, com abuso do poder do cargo, como o crime de facilitação de descaminho, corrupção ou concussão, por exemplo. Também pode ser demitido mediante um processo administrativo, em que lhe seja assegurada a ampla defesa, ou seja, nesse caso não necessita de um processo judicial. E pode ser exonerado mediante avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa, que foi uma disposição incluída pela EC 19/98, numa tentativa de desburocratizar a máquina pública, permitindo que servidores sejam exonerados quando não preenchessem certos requisitos de produtividade, não atuando como bons servidores. Essa lei complementar, no entanto, nunca foi aprovada, não possuindo o dispositivo uma aplicação prática.

No art. 169 CRFB há a possibilidade de exoneração do servidor para conter gastos com pessoal. Existem limites de gastos com pessoal, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) e, ultrapassado esse teto (de por exemplo, 50% da receita corrente líquida para a União e 60% para estados, DF e municípios), deve nos próximos quadrimestres, reduzir esse gasto.

A exoneração de pessoal seguirá uma ordem: inicialmente irá exonerar pelo menos 20% dos cargos em comissão. Após exonera aqueles que não são estáveis no serviço público. Caso ainda haja um excesso de gasto com pessoal, é possível exonerar os servidores estáveis, utilizando critérios impessoais (para evitar perseguição).

Há lei específica que dispõe sobre a exoneração para enxugamento de gastos quando se tratar de uma carreira de estados. A Lei 9.801/99 dispõe sobre os requisitos mais específicos para que o servidor seja exonerado. Seu art. 2º, caput, dispõe que a exoneração será por ato normativo dos Chefes de cada um dos poderes da União, estados e municípios, devendo adotar um critério geral e impessoal.

O artigo 3º estabelece que a exoneração dos servidores estáveis que desenvolva atividade exclusiva de Estado (assim definida em lei), observará as seguintes condições: somente será admitida quando a exoneração de servidores dos demais cargos do órgão ou da unidade administrativa objeto da redução de pessoal tenha alcançado, pelo menos, trinta por cento do total desses cargos, e cada ato reduzirá em no máximo trinta por cento o número de servidores que desenvolvam atividades exclusivas de Estado. São servidores como advogados públicos etc. Os servidores que exercem atividade exclusiva do estado, para serem exonerados com o fundamento de enxugamento de gastos, necessitam de um procedimento mais dificultoso.

Importante lembrar que certas licenças não podem ser obtidas por servidores que estejam no estágio probatório. A lei 8.112/91 possui uma série de possibilidade de licenças e afastamento e algumas delas não podem ser obtidas durante o estágio probatório, como, por exemplo, licença para mandato classista, licença para tratar de assuntos particulares sem remuneração, licença para capacitação.



O estágio será suspenso nos seguintes casos: afastamento para participar de curso de formação, licença por motivo de doença de pessoa da família, licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, licença para atividade política e afastamento para servir em organismo internacional.

Nesses casos o estágio é suspenso por não ser possível a avaliação de desempenho.

O art. 41 CRFB expõe que são estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. O prazo trienal para aquisição de estabilidade no cargo, fixado pela EC 19/1998, é aplicável indistintamente a todos os servidores públicos (STF, ADI 230). Embora a jurisprudência oscile um pouco, o que prevalece é que o mero decurso do prazo de 03 anos não garante automaticamente a aprovação em estágio probatório e a estabilidade.

13. RESPONSABILIDADE DOS SERVIDORES

A responsabilidade dos servidores pode ser civil, administrativa e penal.

13.1. RESPONSABILIDADE CIVIL

O art. 37 § 6º CRFB estabelece a responsabilidade objetiva da Administração Pública, na modalidade risco administrativo, pelo danos causados por seus agentes aos particulares, quando aqueles estiverem desempenhando função pública. Esta questão será aprofundada em capítulo específico mais a frente, mas é importante ter em mente que a responsabilidade civil do Estado independe da presença de um elemento subjetivo, já a responsabilização civil do agente estatal provocador do dano pressupõe a prova do dolo ou culpa.

Caso tenha o servidor causado um dano ao particular, o administrado terá direito a responsabilidade objetiva contra o Estado. Caso condenado pelo ato praticado por seu agente o Poder Público terá, então direito de regresso contra o servidor. Mas agora a se aplicará a responsabilidade subjetiva.

Os danos causados pelo servidor à administração serão apurados por meio de processo administrativo, assegurando-se ampla defesa e contraditório. Existe **controvérsia da forma como o servidor irá reparar o dano**. Entende-se que os valores devem ser descontados mensalmente da remuneração dos servidores. A discussão reside no fato de que se haveria a necessidade ou não do prévio consentimento do servidor para a ocorrência do desconto em folha.

A primeira corrente sustenta é desnecessário o consentimento, bastando que o servidor seja notificado. Já a corrente dominante, aqui representada por Ronny Charles, defende que é necessário o consentimento do servidor para que se proceda a este desconto. Diante disso, se o servidor não concordar, deverá a administração buscar o poder judiciário para efetuar a cobrança.

A parte final do parágrafo 6º do artigo 37 CRFB estipula que o agente causador do dano pode ser responsabilizado, e terá que ressarcir a Administração que tenha sido condenada a indenizar o particular prejudicado. Cabe ressaltar que o agente somente será responsabilizado se restar comprovado que este agiu com dolo ou culpa (responsabilidade subjetiva na modalidade culpa comum). O ônus da prova será do Estado: só será assegurado o direito de regresso ao Poder Público se este comprovar a culpa do seu agente.

No segundo semestre de 2019 o STF consagrou a tese da dupla garantia, entendendo que em razão do disposto no art. 37, § 6º, da CRFB, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (STF. RE 1027633/SP). Dupla garantia pois há a proteção do particular prejudicado pela responsabilidade objetiva do Estado, e também a proteção do servidor, que somente pode ser responsabilizado em regresso pelo Estado, mediante demonstração de culpa ou dolo. Assim o STF afastou o entendimento defendido pelo STJ e por Celso Antônio Bandeira de Mello que admitiam a possibilidade de ajuizamento de ação diretamente contra o agente público.



13.2. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA

Na responsabilidade administrativa, há um ilícito administrativo praticado pelo servidor, exercendo a administração o seu poder disciplinar e aplica a sanção devida ao servidor.

O exercício do poder disciplinar fica sujeito ao controle exercido pelo Poder Judiciário, mas apenas quanto ao controle de legalidade, e não de mérito. Isto é, o Poder Judiciário poderá anular a decisão administrativa ou o processo administrativo, não podendo substituí-lo.

A responsabilidade administrativa independe da existência da responsabilidade civil ou da responsabilidade penal. Mas há certas circunstâncias de que aquilo que foi decidido na esfera penal irá surtir efeitos na esfera administrativa, inclusive para a esfera civil.

Segundo o STF (Informativo 816), são três as situações em que há a comunicabilidade a partir da sentença absolutória penal:

- Quando a sentença decide pela **inexistência do fato**
- Quando a sentença decide pela **inexistência de autoria**
- Quando a sentença foi absolutória por **provada a presença de uma excludente de ilicitude**.

Nesses casos, a sentença penal irá se comunicar à administrativa.

13.3. RESPONSABILIDADE PENAL

A responsabilidade penal decorre da prática de um ilícito penal pelo servidor no exercício de sua função ou em razão dela. São os chamados crimes próprios. São estudados em direito penal.

14. ACUMULAÇÃO DE CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES PÚBLICAS

A CRFB veda a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas, seja na administração direta ou indireta, bem como subsidiárias, empresas controladas direta ou indiretamente pelo Poder Público.

O artigo 37, XVI, CF, permite que o indivíduo cumule dois cargos de professor, sendo muito comum que haja professores na rede estadual e municipal, por exemplo.

Permite também que o indivíduo cumule cargo de professor com outro técnico ou científico. O científico é aquele que se exige conclusão em nível superior, que seria a hipótese de um juiz, promotor, procurador federal etc., e o técnico pode ser considerado, segundo o STJ, que exige algum tipo de formação técnica, como por exemplo técnico em edificação, técnico em contabilidade. Os cursos técnicos são considerados cargos técnicos, ou seja, se a pessoa ocupa um cargo público de técnico em edificação, pode também ser professor de engenharia civil de uma universidade pública ou em um instituto federal de tecnologia, por exemplo.

Nesse caso os cargos são cumuláveis. O cargo de nível médio, segundo um precedente bastante citado no STJ não permitiria a cumulação. Embora até haja casos de pessoas que sejam técnicas de um tribunal e que sejam professores em universidades públicas, segundo o entendimento do STJ, se trata de prática irregular e os tribunais de contas realmente “criam caso” com esse tipo de cumulação.

Nada impede, no entanto, é que esse técnico de tribunal seja professor em uma universidade privada, o que se impede é a cumulação de cargos públicos para limitar o gasto da máquina pública e, de certa forma, uma oligarquia funcional, em que um número pequeno de pessoas ocupe vários cargos.

Há também a possibilidade de cumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Isso é bastante comum, por exemplo médico da rede estadual ou municipal ou em dois hospitais públicos.

Assim em alguns casos é possível a acumulação remunerada, desde que:

- **Compatibilidade de horários** e;
- **Obedeça ao teto remuneratório** (subsídio do ministro do STF), embora a jurisprudência esteja revendo este posicionamento.



A acumulação será possível nas seguintes situações:

- Dois cargos de professor
- Um cargo de professor e outro de técnico científico
- Dois cargos ou dois empregos privativos de profissionais de saúde, que tenham profissões regulamentadas.

O **teto remuneratório** está previsto no art. 37 XI. O entendimento clássico é o teto deve ser aplicado mesmo quando se cumulam cargos. Nesse aspecto, há decisão do TCU (acórdão 1994/2015) e do STF (MS 24.448) no sentido que é a soma dos rendimentos que deve ser confrontada com o teto remuneratório, por força do art. 40 § 11 CRFB. Essa seria a norma caso servidor que receba seu salário já no valor do teto, tal como um Ministro do STF, seja contratado também como professor de uma universidade federal. Se entendeu, durante muito tempo, que o teto já seria a remuneração dele como ministro, ou seja, já ganha o máximo que um servidor público pode ganhar no Brasil. Em outras palavras, ser professor de uma universidade pública seria uma hipótese em que teria que trabalhar de graça.

Porém, o STF em 2017 adotou posição oposta, entendendo que, se a constituição permite a cumulação desses dois cargos, o teto deve ser aferido individualmente em relação a cada um deles (REs 602.043 e 612.975). Supondo que o teto seja de 36 mil, e que já receba isso como ministro do STF, não pode ganhar mais de 36 mil em nenhum dos dois cargos, cada um, mas a soma dos dois pode ser mais de 36 mil. O teto deve ser aferido em relação a cada cargo individual, porque a cumulação nesse caso é permitida pela constituição.

A vedação à cumulação é a remunerada. Se não houver remuneração, segundo precedentes do STF, a cumulação não remunerada é permitida. Exemplo do caso de um delegado que exercia determinado cargo sem remuneração e esse cargo era uma das hipóteses de vedação. Ele pediu licença do primeiro cargo para assumir o segundo cargo, de delegado, e o STF entendeu que essa cumulação seria permitida, pois o que se veda é que o indivíduo seja remunerado por vários cargos. Se a cumulação não é remunerada é permitida (RE646.260).

Outra limitação imposta pela CRFB, no art. 37, XVI, veda a acumulação de cargos públicos exceto quando houver **compatibilidade** de horário. Em 2018 o STF entendeu que **a acumulação lícita de cargos acumuláveis não se encontra limitada ao patamar de 60 horas semanais** pois inexistente tal requisito na Constituição Federal (RE 1.094.802 AgR), entendimento que passou a ser adotado pelo STJ, derrubando o adotado anteriormente por esta corte, no ano seguinte REsp 1.767.955/RJ).

Vale lembrar que a Constituição admite que o servidor eleito para o cargo de **vereador** venha a acumular o cargo de vereador com outro cargo que ele ocupa, desde que haja a **compatibilidade de horários, acumulando também as remunerações**. Ex.: vereador acumulando cargo de enfermeiro do Estado.

A Lei 8.112 vai admitir, no art. 119, que o servidor possa exercer mais de um cargo de confiança ou de natureza especial interinamente, sem prejuízo das atribuições do cargo que ocupa atualmente. Nessa situação, o sujeito poderá ocupar, **mas deverá exercer uma opção**, ou seja, **optar por uma das remunerações no período da interinidade**.

O art. 37, §10, da CF **veda que haja a percepção simultânea de proventos de aposentadoria** com a remuneração do cargo ou função pública, salvo **se os dois cargos eram acumuláveis na atividade**, e também **salvo nos cargos eletivos e de comissão**, declarados em lei de livre nomeação ou exoneração.

15. ESTABILIDADE, VITALICIEDADE E ESTÁGIO PROBATÓRIO

15.1. ESTABILIDADE

Estabilidade é um **direito outorgado ao servidor estatutário**, que tenha sido nomeado em razão de concurso público, sendo um direito de permanecer no serviço público **após o prazo de três anos de efetivo**



exercício. Isso vai depender da avaliação especial de desempenho, por meio da comissão de estágio probatório.

O art. 41 CRFB expõe que são estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. O prazo trienal para aquisição de estabilidade no cargo, fixado pela EC 19/1998, é aplicável indistintamente a todos os servidores públicos (STF, ADI 230). Embora a jurisprudência oscile um pouco, o que prevalece é que o mero decurso do prazo de 03 anos não garante automaticamente a aprovação em estágio probatório e a estabilidade.

Não fazem jus à estabilidade os empregados públicos. Apesar de este entendimento ser prevalente na doutrina, o TST tem entendimento em sentido contrário, de forma que o empregado público também teria estabilidade.

O art. 19 do ADCT traz um outro caso de estabilidade, estabelecendo que também são considerados estáveis todos os servidores públicos civis que sejam federais, estaduais, municipais, da administração direta ou indireta, que estivessem em exercício **há pelo menos 05 anos da data da promulgação da constituição, ainda que tenham ingressado no serviço público sem concurso.** José dos Santos Carvalho Filho chama isso de **estabilização**.

O STF entende que empregados de empresas públicas e sociedades de economia que prestem serviço público **não tem estabilidade** (AI 468.580 AgR.), mas esses servidores **devem ser demitidos motivadamente.** A falta de motivação é vício insanável, sendo nulo o ato de demissão.

Adquirida estabilidade, o servidor **só poderá ser demitido** nas seguintes hipóteses:

- Se houver decisão judicial transitada em julgado
- Se houver um processo administrativo disciplinar
- Se demonstrar insuficiência de desempenho, através de avaliação periódica
- Necessidade de adequação de gastos de pessoal nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal

A demissão de servidor estável, segundo a LRF, para adequar o orçamento, só será possível após já ter ser reduzido em pelo menos 20% o gasto com quem ocupa cargo em comissão ou função de confiança, e após a exoneração de todos os servidores não estáveis. Após a demissão desses, aí sim poderão demitir os servidores estáveis.

No caso de demissão, os servidores estáveis terão como indenização a proporção de 1 mês de remuneração para cada ano no serviço público.

15.2. VITALICIEDADE

A vitaliciedade é uma garantia conferida aos **membros da magistratura, MP e Tribunal de Contas.** Aqueles que possuem vitaliciedade **só perderão o cargo por meio de sentença judicial transitada em julgado.**

A para os que ingressaram por concurso público a vitaliciedade é adquirida **após 02 anos de exercício, quando adquirida em primeiro grau.** Membros de segundo grau, nomeados pelo quinto constitucional, ministros de Tribunal Superior, ministros do STF vão adquirir essa **vitaliciedade no momento em que tomam posse** (investidura). Os membros dos tribunais de contas também adquirem a vitaliciedade com a investidura no cargo.

15.3. ESTÁGIO PROBATÓRIO

O estágio probatório é o período que existe, dentro do qual o servidor será avaliado, quanto aos requisitos necessários para o desempenho do cargo. A EC 19/98 alterou o art. 41 CRFB e aumentou para 03 anos o prazo para que o servidor estatutário adquira a estabilidade.

O entendimento que prevalece é de que é indissociável o prazo da estabilidade do estágio probatório, razão pela qual ele também terá esse prazo.



16. DIREITO DE GREVE

Os servidores públicos possuem direito à greve. Segundo a CF, **o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica** (art. 37, VII).

Esta lei, até o presente momento, não foi editada. O art. 37, inc. VII CRFB não possui eficácia plena, exigindo a edição de ato normativo que integre sua eficácia. Como a mesma não foi editada o STF consolidou, nos Mandados de Injunção 670, 708 e 712, o entendimento mesmo sem haver lei, os servidores públicos podem fazer greve, **devendo ser aplicadas as leis que regulamentam a greve para os trabalhadores da iniciativa privada** (Lei nº 7.701/88 e Lei nº 7.783/89). Este é o entendimento do STF.

Nem sempre a greve será permitida. Categorias militares, inclusive o corpo de bombeiros e as polícias militares, são consideradas essenciais e este direito é portanto mitigado (art. 142, da CRFB). Para os demais servidores o direito de greve é possível.

Ainda assim é possível que, diante do caso concreto e mediante solicitação de entidade ou órgão legítimo, seja facultado ao juízo competente a fixação de regime de greve mais severo, em razão de tratarem de "serviços ou atividades essenciais".

São **requisitos** para a deflagração de uma greve no serviço público:

- Tentativa de negociação prévia, direta e pacífica;
- Frustração ou impossibilidade de negociação ou de se estabelecer uma agenda comum;
- Deflagração após decisão assemblear;
- Comunicação formal aos interessados, no caso, ao ente da Administração Pública a que a categoria se encontre vinculada e à população, com antecedência mínima de 72 horas (uma vez que todo serviço público é atividade essencial);
- Adesão ao movimento por meios pacíficos;
- Necessidade da paralisação deverá ser parcial, assegurando o funcionamento dos serviços essenciais em cota mínima.
- A paralisação dos serviços (quaisquer que sejam) pode ser apenas parcial. A regularidade na prestação deve ser mantida, especialmente visando suprir as necessidades urgentes da população, sob pena de configurar abuso de direito.

Caso os servidores públicos realizem greve, a Administração Pública, **em regra**, deverá descontar da remuneração os dias em que eles ficaram sem trabalhar, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo.

O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público(STA 867 MC).

Vale lembrar que os dias em que o trabalhador fica afastado do serviço com o objetivo de participar da greve **são considerados pela legislação como período de suspensão do contrato de trabalho**.

O contrato de trabalho pode sofrer a paralisação temporária de seus efeitos, embora mantenha a sua vigência. Essa paralisação pode ser classificada como suspensão ou interrupção:

- **Suspensão (total):** não há trabalho, não há pagamento de salários, não há contagem do tempo de serviço e não há recolhimento fundiário ou mesmo previdenciário.
- **Interrupção (parcial):** não há trabalho, há pagamento de salários, há contagem do tempo de serviço e há recolhimento fundiário ou mesmo previdenciário.

Quando a Lei classifica a greve como hipótese de **suspensão do contrato de trabalho**, ela está dizendo que não haverá trabalho, mas que também não haverá pagamento de salários.

O administrador público **não poderá deixar de descontar** da remuneração do servidor os dias em que ele ficou sem trabalhar fazendo greve. Caso não haja o desconto dos dias paralisados, isso representará:

- Enriquecimento sem causa dos servidores que não trabalharam;



- Violação ao princípio da indisponibilidade do interesse público;
- Violação ao princípio da legalidade.

Não poderá ser feito o desconto **se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público**. Considera-se assim aquelas circunstâncias em que o ente da administração tenha contribuído, mediante conduta recriminável, para que a greve ocorresse. Ex: não haverá desconto se a greve tiver sido provocada por atraso no pagamento aos servidores públicos ou se houver outras circunstâncias excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão da relação funcional ou de trabalho.

Em vez de realizar o desconto, é possível que os servidores públicos façam a compensação dos dias parados (ex: trabalhando duas horas a mais por dia). Ressalte-se, contudo, que não há uma obrigatoriedade de a Administração Pública aceitar a compensação.

Todavia, o STF decidiu que **não se mostra razoável a possibilidade de desconto em parcela única sobre a remuneração do servidor público dos dias parados e não compensados provenientes do exercício do direito de greve** (Inf. 592).

Por tudo isso, o STF entendeu que a administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre. É permitida a compensação em caso de acordo. **O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público**.

Por fim, foi decidido que **não há necessidade de processo administrativo prévio para realizar descontos na remuneração do servidor, em razão de dias parados decorrentes de greve**.

17. TESES DO STJ: CONCURSO PÚBLICO, SERVIDORES

Por fim, seguem as teses do STJ sobre os temas abordados no capítulo.

17.1. CONCURSO PÚBLICO

- 1) O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora do certame e tampouco se imiscuir nos critérios de atribuição de notas e de correção de provas, visto que sua atuação se restringe ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público e da observância do princípio da vinculação ao edital.
- 2) A divulgação, ainda que *a posteriori*, dos critérios de correção das provas dissertativas ou orais não viola, por si só, o princípio da igualdade, desde que os mesmos parâmetros sejam aplicados uniforme e indistintamente a todos os candidatos.
- 3) O provimento originário em concurso público não permite a invocação do instituto da remoção para acompanhamento de cônjuge ou companheiro, em razão do prévio conhecimento das normas expressas no edital do certame.
- 4) A administração pública pode anular, a qualquer tempo, o ato de provimento efetivo flagrantemente inconstitucional, pois o decurso do tempo não possui o condão de convalidar os atos administrativos que afrontem a regra do concurso público.
- 5) A investidura em cargo público efetivo submete-se a exigência de prévio concurso público, sendo vedado o provimento mediante transposição, ascensão funcional, acesso ou progressão. *(VIDE SÚMULA VINCULANTE N. 43/STF)
- 6) Na hipótese de abertura de novo concurso público dentro do prazo de validade do certame anterior, o termo inicial do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança por candidatos remanescentes é a data da publicação do novo edital.



- 7) A nomeação ou a posse tardia de candidato aprovado em concurso público, por força de decisão judicial, não configura preterição ou ato ilegítimo da Administração Pública a justificar uma contrapartida indenizatória, salvo situação de arbitrariedade flagrante.
- 8) A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de decisão judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções e às progressões funcionais que alcançariam caso a nomeação houvesse ocorrido a tempo e a modo.
- 9) A vedação de execução provisória de sentença contra a Fazenda Pública inserida no art. 2º-B da Lei n. 9.494/1997 não incide na hipótese de nomeação e de posse em razão de aprovação em concurso público.
- 10) A contratação de servidores sem concurso público, quando realizada com base em lei municipal autorizadora, descaracteriza o ato de improbidade administrativa, em razão da ausência de dolo genérico do gestor público.
- 11) O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público. (Súmula n. 466/STJ)
- 12) O candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital tem direito subjetivo a ser nomeado no prazo de validade do concurso.
- 13) A desistência de candidatos convocados, dentro do prazo de validade do concurso, gera direito subjetivo à nomeação para os seguintes, observada a ordem de classificação e a quantidade de vagas disponibilizadas.
- 14) A abertura de novo concurso, enquanto vigente a validade do certame anterior, confere direito líquido e certo a eventuais candidatos cuja classificação seja alcançada pela divulgação das novas vagas.
- 15) O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, que se convola em direito subjetivo caso haja preterição na convocação, observada a ordem classificatória.
- 16) A simples requisição ou a cessão de servidores públicos não é suficiente para transformar a expectativa de direito do candidato aprovado fora do número de vagas em direito subjetivo à nomeação, porquanto imprescindível a comprovação da existência de cargos vagos.
- 17) O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, que se convola em direito subjetivo caso haja preterição em virtude de contratações precárias e comprovação da existência de cargos vagos.
- 18) Não ocorre preterição na ordem classificatória quando a convocação para próxima fase ou a nomeação de candidatos com posição inferior se dá por força de cumprimento de ordem judicial.
- 19) A surdez unilateral não autoriza o candidato a concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência.
- 20) Deverão ser reservadas, no mínimo, 5% das vagas ofertadas em concurso público às pessoas com deficiência e, caso a aplicação do referido percentual resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que respeitado o limite máximo de 20% das vagas ofertadas, conforme art. 37, §§ 1º e 2º, do Decreto n. 3.298/99, e art. 5º, §2º, da Lei n. 8.112/90.
- 21) O candidato *sub judice* não possui direito subjetivo à nomeação e à posse, mas à reserva da respectiva vaga até que ocorra o trânsito em julgado da decisão que o beneficiou.
- 22) A nomeação ou a convocação para determinada fase de concurso público após considerável lapso temporal entre uma fase e outra, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a publicação no Diário Oficial.
- 23) Não se aplica a teoria do fato consumado na hipótese em que o candidato toma posse em virtude de decisão liminar, salvo situações fáticas excepcionais.
- 24) É legítimo estabelecer no edital de concurso público critério de regionalização.
- 25) É legítimo estabelecer no edital de concurso público limite de candidatos que serão convocados para as próximas etapas do certame (Cláusula de Barreira).
- 26) O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público. (Súmula n. 266/STJ)
- 27) Nos concursos públicos para ingresso na Magistratura ou no Ministério Público a comprovação dos requisitos exigidos deve ser feita na inscrição definitiva e não na posse.

- 28) A prorrogação do prazo de validade de concurso público é ato discricionário da Administração, sendo vedado ao Poder Judiciário o reexame dos critérios de conveniência e oportunidade adotados.
- 29) A Administração atua com discricionariedade na escolha das regras do edital de concurso público, desde que observados os preceitos legais e constitucionais.
- 30) A exoneração de servidor público em razão da anulação do concurso pressupõe a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
- 31) O candidato que possui qualificação superior à exigida no edital está habilitado a exercer o cargo a que prestou concurso público, nos casos em que a área de formação guardar identidade.
- 32) O Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública com o objetivo de anular concurso realizado sem a observância dos princípios estabelecidos na Constituição Federal.
- 33) A nomeação tardia do candidato por força de decisão judicial não gera direito à indenização.
- 34) O servidor não tem direito à indenização por danos morais em face da anulação de concurso público eivado de vícios.
- 35) O militar aprovado em concurso público e convocado para a realização de curso de formação tem direito ao afastamento temporário do serviço ativo na qualidade de agregado.
- 36) O provimento originário de cargos públicos deve se dar na classe e padrão iniciais da carreira, conforme a legislação vigente na data da nomeação do servidor.
- 37) A Administração Pública pode promover a remoção de servidores concursados, sem que isso caracterize, por si só, preterição aos candidatos aprovados em novo concurso público.
- 38) Há preterição de candidatos aprovados se as vagas regionalizadas estabelecidas no edital de concurso público forem preenchidas por remoção lançada posteriormente ao início do certame.
- 39) O candidato aprovado dentro do número de vagas que requer transferência para o final da lista de classificados passa a ter mera expectativa de direito à nomeação.
- 40) A banca examinadora pode exigir conhecimento sobre legislação superveniente à publicação do edital, desde que vinculada às matérias nele previstas.
- 41) O Poder Judiciário não analisa critérios de formulação e correção de provas em concursos públicos, salvo nos casos de ilegalidade ou inobservância das regras do edital.
- 42) A limitação de idade, sexo e altura para o ingresso na carreira militar é válida desde que haja previsão em lei específica e no edital do concurso público.
- 43) Somente a lei pode estabelecer limites de idade nos concursos das Forças Armadas, sendo vedado, diante do princípio constitucional da reserva legal, que a lei faculte tal regulamentação a atos administrativos expedidos pela Marinha, Exército ou Aeronáutica.
- 44) A aferição do cumprimento do requisito de idade deve se dar no momento da posse no cargo público e não no momento da inscrição.
- 45) O edital é a lei do concurso e suas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos.
- 46) O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes. (Súmula n. 377 do STJ)
- 47) A exigência de exame psicotécnico é legítima quando prevista em lei e no edital, a avaliação estiver pautada em critérios objetivos e o resultado for público e passível de recurso.
- 48) Constatada a ilegalidade do exame psicotécnico, o candidato deve ser submetido a nova avaliação, pautada por critérios objetivos e assegurada a ampla defesa.
- 49) A exigência de teste de aptidão física é legítima quando prevista em lei, guardar relação de pertinência com as atividades a serem desenvolvidas, estiver pautada em critérios objetivos e for passível de recurso.
- 50) É vedada a realização de novo teste de aptidão física em concurso público no caso de incapacidade temporária, salvo previsão expressa no edital.
- 51) É possível a realização de novo teste de aptidão física em concurso público no caso de gravidez, sem que isso caracterize violação do edital ou do princípio da isonomia.
- 52) O candidato não pode ser eliminado de concurso público, na fase de investigação social, em virtude da existência de termo circunstanciado, inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado ou extinta pela prescrição da pretensão punitiva.

53) O entendimento de que o candidato não pode ser eliminado de concurso público, na fase de investigação social, em virtude da existência de termo circunstanciado, inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado ou extinta pela prescrição da pretensão punitiva não se aplica aos cargos cujos ocupantes agem *stricto sensu* em nome do Estado, como o de delegado de polícia.

54) O candidato pode ser eliminado de concurso público quando omitir informações relevantes na fase de investigação social.

55) O termo inicial do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança, na hipótese de exclusão do candidato do concurso público, é o ato administrativo de efeitos concretos e não a publicação do edital, ainda que a causa de pedir envolva questionamento de critério do edital.

56) O termo inicial do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança, na hipótese em que o candidato aprovado em concurso público não é nomeado, é o término do prazo de validade do concurso.

57) O encerramento do concurso público não conduz à perda do objeto do mandado de segurança que busca aferir suposta ilegalidade praticada em alguma das etapas do processo seletivo.

17.2. SERVIDORES

1) A Justiça do Trabalho não tem competência para decidir os feitos em que se discutem critérios utilizados pela administração para a seleção e a admissão de pessoal em seus quadros, uma vez que envolve fase anterior à investidura no emprego público.

2) Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obtenção de prestações trabalhistas, nas hipóteses em que o trabalhador foi admitido na administração pública pelo regime celetista, antes da Constituição Federal de 1988 e sem concurso público.

3) As contratações temporárias celebradas pela administração pública, na vigência da Constituição Federal de 1988, ostentam caráter precário e submetem-se à regra do art. 37, inciso IX, não sendo passíveis de transmutação de sua natureza eventual pelo decurso do tempo.

4) Não ocorre a decadência administrativa prevista no art. 54 da Lei n. 9.784/1999 em situações de evidente inconstitucionalidade, como é o caso de admissão de servidores sem concurso público.

5) Não é possível estender a estabilidade excepcional do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988.

6) A contratação de servidores temporários ou o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, por si sós, não caracterizam preterição na convocação e na nomeação de candidatos advindos de concurso público, tampouco autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital.

7) Ocorrida a vacância na titularidade da serventia extrajudicial na vigência da atual Constituição Federal, o provimento de novo titular deve ser realizado por meio de concurso público, nos termos do art. 236, § 3º, da CF/1988.

8) O direito à liberdade de crença, assegurado pela Constituição, não pode criar situações que importem tratamento diferenciado - seja de favoritismo, seja de perseguição - em relação a outros candidatos de concurso público que não professam a mesma crença religiosa.

9) É ilegítima a previsão de edital de concurso público que exige o prévio registro na Delegacia Regional do Trabalho como condição para que os graduados em Letras ou em Secretariado Bilíngue exerçam a atividade de Secretário-Executivo.

10) A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, presta-se a avaliar idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da administração pública.

11) Em concursos públicos, a inaptidão na avaliação psicológica ou no exame médico exige a devida fundamentação.

12) É indevida a acumulação de proventos de duas aposentadorias, de cargos públicos não acumuláveis na atividade, ainda que uma delas seja proveniente do reingresso no serviço público mediante aprovação em concurso, antes da Emenda Constitucional n. 20/98.

17.3. REMUNERAÇÃO

1) A lei que garanta aos servidores públicos o direito à revisão geral anual dos seus vencimentos (art. 37, X, da Constituição Federal), tem natureza constitucional, razão pela qual não pode ser apreciada em sede de recurso especial.

2) Não compete ao Poder Judiciário equiparar ou reajustar os valores do auxílio-alimentação dos servidores públicos.

3) É indevida a devolução ao erário de valores recebidos de boa-fé, por servidor público ou pensionista, em decorrência de erro administrativo operacional ou nas hipóteses de equívoco ou má interpretação da lei pela administração pública. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 531)

4) É de 200 horas mensais o divisor adotado como parâmetro para o pagamento de horas extras aos servidores públicos federais, cujo cálculo é obtido dividindo-se as 40 horas semanais (art. 19 da Lei n. 8.112/90) por 6 dias úteis e multiplicando-se o resultado por 30 (total de dias do mês).

5) O pagamento do adicional de penosidade (art. 71 da Lei n. 8.112/90) depende de regulamentação do Executivo Federal.

6) A incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas aos vencimentos de servidores públicos federais somente é possível até 28.2.1995, enquanto que, no interregno de 1.3.1995 a 11.11.1997 a incorporação devida seria de décimos, sendo indevida qualquer concessão a partir de 11.11.1997, data em que a norma autorizadora da incorporação foi expressamente revogada pela Medida Provisória n. 1.595-14, convertida na Lei n. 9.527/1997 (art. 15).

7) Os efeitos do Decreto n. 493/92, que regulamentou o pagamento da Gratificação Especial de Localidade - GEL, devem retroagir à data em que se encerrou o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 17 da Lei n. 8.270/91.

8) É legítimo o tratamento diferenciado entre professores ativos e inativos, no que tange à percepção da Gratificação de Estímulo à Docência - GED, instituída pela Lei n. 9.678/1998, tendo em vista a natureza da gratificação, cujo percentual depende da produtividade do servidor em atividade.

9) A lei que cria nova gratificação ao servidor sem promover reestruturação ou reorganização da carreira não tem aptidão para absorver índice de reajuste geral.

10) A fixação ou alteração do sistema remuneratório e a supressão de vantagem pecuniária são atos comissivos únicos e de efeitos permanentes, que modificam a situação jurídica do servidor e não se renovam mensalmente.

11) A contagem do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança contra ato que fixa ou altera sistema remuneratório ou suprime vantagem pecuniária de servidor público inicia-se com a ciência do ato impugnado.

12) Não cabe o pagamento da ajuda de custo prevista no art. 53 da Lei n. 8.112/90 ao servidor público que participou de concurso de remoção.

13) É devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração.

14) O prazo prescricional de cinco anos para converter em pecúnia licença-prêmio não gozada ou utilizada como lapso temporal para jubileamento tem início no dia posterior ao ato de registro da aposentadoria pelo Tribunal de Contas.

15) Os efeitos da sentença trabalhista, quanto ao reajuste de 84,32%, referente ao IPC - Índice de Preços ao Consumidor de março de 1990, têm por limite temporal a Lei n. 8.112/90, que promoveu a transposição do regime celetista para o estatutário.

16) O termo inicial da prescrição do direito de pleitear a indenização por férias não gozadas é o ato de aposentadoria do servidor.

- 17) É possível a supressão do índice de 26,05% relativo à URP - Unidade de Referência de Preços de 1989 incorporado em decorrência de sentença trabalhista transitada em julgado, pois a eficácia desta está adstrita à data da transformação dos empregos em cargos públicos e ao consequente enquadramento no Regime Jurídico Único.
- 18) A Vantagem Pecuniária Individual - VPI possui natureza jurídica de Revisão Geral Anual, devendo ser estendida aos Servidores Públicos Federais o índice de aproximadamente 13,23%, decorrente do percentual mais benéfico proveniente do aumento impróprio instituído pelas Leis n. 10.697/2003 e 10.698/2003.
- 19) Os candidatos aprovados em concurso público para os cargos da Polícia Civil do DF e da Polícia Federal fazem jus, durante o programa de formação, à percepção de 80% dos vencimentos da classe inicial da categoria.
- 20) É legítimo o ato da Administração que promove o desconto dos dias não trabalhados pelos servidores públicos participantes de movimento grevista.
- 21) É vedado o cômputo do tempo do curso de formação para efeito de promoção do servidor público, sendo, contudo, considerado tal período para fins de progressão na carreira.
- 22) O tempo de serviço prestado às empresas públicas e sociedades de economia mista somente pode ser computado para efeitos de aposentadoria e disponibilidade.
- 23) O direito de transferência *ex officio* entre instituições de ensino congêneres conferido a servidor público federal da administração direta se estende aos empregados públicos integrantes da administração indireta.
- 24) Os efeitos da sentença trabalhista têm por limite temporal a Lei n. 8.112/90, que promoveu a transposição do regime celetista para o estatutário, inexistindo violação à coisa julgada, ao direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.
- 25) A pensão por morte do servidor público federal é devida até a idade limite de 21 (vinte e um) anos do dependente, salvo se inválido, não cabendo postergar o benefício para os universitários com idade até 24 (vinte e quatro) anos, ante a ausência de previsão normativa.
- 26) Não é possível o registro de penas nos assentamentos funcionais dos servidores públicos quando verificada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, por força do entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o art. 170 da Lei n. 8.112/90 viola a Constituição Federal.
- 27) A abertura de concurso de remoção pela administração revela que a existência de vaga a ser preenchida pelo servidor aprovado é de interesse público.
- 28) A investidura originária não se enquadra no conceito de deslocamento para fins da concessão da licença para acompanhar cônjuge com exercício provisório.
- 29) É lícita a cassação de aposentadoria de servidor público, não obstante o caráter contributivo do benefício previdenciário.
- 11) O termo inicial para o pagamento dos proventos integrais devidos na conversão da aposentadoria proporcional por tempo de serviço em aposentadoria integral por invalidez é a data do requerimento administrativo.
- 12) A concessão de aposentadoria especial aos servidores públicos será regulada pela Lei n. 8.213/91, enquanto não editada a lei complementar prevista no art. 40, § 4º, da CF/88.
- 13) A limitação da carga horária semanal para servidores públicos profissionais de saúde que acumulam cargos deve ser de 60 horas semanais.
- 14) O Auxiliar Local que prestou serviços ininterruptos para o Brasil no exterior, admitido antes de 11 de dezembro de 1990, submete-se ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (art. 243 da Lei n. 8.112/1990).
- 15) A Lei n. 8.112/90, quando aplicada aos servidores do Distrito Federal por força da Lei Distrital n. 197/91, assume status de lei local, insuscetível de apreciação em sede de recurso especial, atraindo o óbice da Súmula n. 280/STF.

18. JURISPRUDÊNCIA

18.1. SÚMULAS STF

Súmula vinculante 55: O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos

Súmula vinculante 51: O reajuste de 28,86%, concedido aos servidores militares pelas Leis 8.622/1993 e 8.627/1993, estende-se aos servidores civis do Poder Executivo, observadas as eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais.

Súmula vinculante 42: É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.

Súmula vinculante 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

Súmula vinculante 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica.

Súmula vinculante 16: Os arts. 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor.

Súmula vinculante 15: O cálculo de gratificações e outras vantagens não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo do servidor público.

Súmula vinculante 4: Salvo os casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

Súmula vinculante 3: Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.

Súmula 682: Não ofende a Constituição a correção monetária no pagamento com atraso dos vencimentos de servidores públicos.

Súmula 359: Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.

Súmula 47: Reitor de universidade não é livremente demissível pelo presidente da república durante o prazo de sua investidura.

Súmula 39: À falta de lei, funcionário em disponibilidade não pode exigir, judicialmente, o seu aproveitamento, que fica subordinado ao critério de conveniência da administração.

Súmula 36: Servidor vitalício está sujeito à aposentadoria compulsória, em razão da idade



Súmula 20: É necessário processo administrativo, com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso.

18.2. SÚMULAS DO STJ

Súmula 635: Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido - sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar - e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção.

Súmula 378: Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes

18.3. INFORMATIVOS STF

Presunção de inocência e eliminação de concurso público

Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal. Com essa tese de repercussão geral (Tema 22), o Plenário, em conclusão de julgamento e por maioria, negou provimento a recurso extraordinário em que se discutia a possibilidade de se restringir a participação em concurso público de candidato que respondia a processo criminal (Informativo 825). Na espécie, foi inadmitida a participação de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDf) — acusado pela suposta prática do delito de falso testemunho — em seleção para o Curso de Formação de Cabos no Quadro de Praças Policiais e Militares Combatentes (QPPMC). O ato de exclusão do candidato foi fundamentado no edital de convocação do referido processo seletivo, que vedava a participação de concorrente “denunciado por crime de natureza dolosa”. Em sede de mandado de segurança, o magistrado de piso assegurou a matrícula e a frequência do soldado no Curso de Formação. Posteriormente, a decisão foi mantida pelo tribunal *a quo* no acórdão ora recorrido. Prevaleceu o voto do ministro Roberto Barroso (relator), que assentou a necessidade de ponderação entre bens jurídicos constitucionais para a solução da controvérsia posta. Assim, a questão não poderia ser solucionada a partir de um tradicional raciocínio silogístico, ou dos critérios usuais para resolução de antinomias — hierárquico, de especialidade e cronológico —, haja vista a existência de normas de mesma hierarquia indicando soluções diferentes. Nessas situações, o raciocínio deve percorrer três etapas: a) identificar as normas que postulam incidência na hipótese; b) identificar os fatos relevantes ou os contornos fáticos gerais do problema; e c) harmonizar as normas contrapostas, calibrando o peso de cada qual e restringindo-as no grau mínimo indispensável, de modo a fazer prevalecer a solução mais adequada à luz de todo o sistema jurídico. Na espécie, de um lado, destaca-se o princípio da presunção de inocência [Constituição Federal (CF), art. 5º, LVII], reforçado pelos princípios da liberdade profissional (CF, art. 5º, XIII) e da ampla acessibilidade aos cargos públicos (CF, art. 37, I). De outro lado, ressalta-se o princípio da moralidade administrativa (CF, art. 37, caput).

O ministro Roberto Barroso apresentou duas regras para a ponderação dos valores em jogo e a determinação objetiva de idoneidade moral, quando aplicável ao ingresso no serviço público mediante concurso. A primeira, apta a estabelecer parâmetro pelo qual se pode recusar a alguém a inscrição em concurso público, é a necessidade de



condenação por órgão colegiado ou de condenação definitiva. Há analogia com a Lei da “Ficha Limpa” (LC 135/2010), critério que já foi aplicado mesmo fora da seara penal.

A segunda regra é a necessidade de relação de incompatibilidade entre a natureza do crime e as atribuições do cargo. Nem toda condenação penal deve ter por consequência direta e imediata impedir alguém de se candidatar a concurso público. Entretanto, para concorrer a determinados cargos públicos, pela natureza deles, é possível, por meio de lei, a exigência de qualificações mais restritas e rígidas ao candidato. Por exemplo, as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça — Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública — e da segurança pública. O relator concluiu que a solução mediante o emprego dessas regras satisfaz o princípio da razoabilidade ou proporcionalidade, visto que é: a) adequada, pois a restrição imposta se mostra idônea para proteger a moralidade administrativa; b) não excessiva, uma vez que, após a condenação em segundo grau, a probabilidade de manutenção da condenação é muito grande e a exigência de relação entre a infração e as atribuições do cargo mitiga a restrição; e c) proporcional em sentido estrito, na medida em que a atenuação do princípio da presunção de inocência é compensada pela contrapartida em boa administração e idoneidade dos servidores públicos. Para ele, a negativa de provimento ao recurso é reforçada pelo fato de ter havido a suspensão condicional do processo. Não fosse o longo período entre o oferecimento da denúncia e a audiência de suspensão condicional, provavelmente o processo criminal não estaria em curso no momento em que o recorrido foi excluído do aludido curso.

Informativo 965, Plenário. RE 560900/DF, rel. Min. Roberto Barroso, julgamento em 5 e 6.2.2020.

O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/88, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão. STF. Plenário. RE 565089/SP, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 25/9/2019 (repercussão geral – Tema 19) (Info 953).

O § 4º do art. 39 da CF/88 prevê que os servidores remunerados pelo regime de subsídio recebem “parcela única” mensal, sendo “vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória”. Vale ressaltar, no entanto, que o art. 39, § 4º, da CF/88 não estabelece uma vedação absoluta ao pagamento de outras verbas além do subsídio. O modelo de remuneração por subsídio tem por objetivo evitar que atividades “normais” exercidas pelo servidor público, ou seja, atividades que são inerentes ao cargo que ele ocupa (e que já são remuneradas pelo subsídio) sejam também remuneradas com o acréscimo de outras parcelas adicionais. Dito de outra forma: o subsídio remunera o servidor pelas atividades que ele realiza e que são inerentes ao seu cargo, ou seja, as atividades “normais” de seu cargo. O art. 39, § 4º proíbe que este servidor receba outras verbas (além do subsídio) para exercer essas atividades “normais”. Contudo, o art. 39, § 4º, não proíbe que o servidor receba: a) valores que não ostentam caráter remuneratório, como os de natureza indenizatória; e b) valores pagos como retribuição por eventual execução de encargos especiais não incluídos no plexo das atribuições normais e típicas do cargo considerado. O que o art. 39, § 4º, da CF/88 impede é a acumulação do subsídio com outras verbas destinadas a retribuir o exercício de atividades próprias e ordinárias do cargo. Justamente por isso, é constitucional lei estadual que preveja o pagamento de gratificação para servidores que já recebem pelo regime de subsídio quando eles realizarem atividades que extrapolam as funções próprias e normais do cargo. Essas



atividades, a serem retribuídas por esta parcela própria, detêm conteúdo ocupacional estranho às atribuições ordinárias do cargo e, portanto, podem ser remuneradas por gratificação além da parcela única do subsídio, sem que isso afronte o art. 39, § 4º, da CF/88. Essa gratificação somente seria inconstitucional se ficasse demonstrado que estaria havendo um duplo pagamento pelo exercício das mesmas funções normais do cargo. STF. Plenário. ADI 4941/AL, rel. orig. Min. Teori Zavascki, red. p/ o ac. Min. Luiz Fux, julgado 14/8/2019 (Info 947).

A estabilidade especial do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) não se estende aos empregados das fundações públicas de direito privado, aplicando-se tão somente aos servidores das pessoas jurídicas de direito público. O termo “fundações públicas”, utilizado pelo art. 19 do ADCT, deve ser compreendido como fundações autárquicas, sujeitas ao regime jurídico de direito público. Ex: empregados da Fundação Padre Anchieta não gozam dessa estabilidade do art. 19 do ADCT em razão de se tratar de uma fundação pública de direito privado. STF. Plenário. RE 716378/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 1º e 7/8/2019 (repercussão geral) (Info 946).

18.4. INFORMATIVOS STJ

Inexiste direito adquirido para os médicos cooperados estrangeiros de permanecer nos quadros de agentes públicos da saúde pública, ainda que já tenham sido vinculados ao Projeto Mais Médicos para o Brasil. STJ. 2ª Turma. RO 213-DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 05/12/2019 (Info 663)

Informativo n. 651. MS 20.857-DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Acd. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, por maioria, julgado em 22/05/2019, DJe 12/06/2019

O prazo prescricional previsto na lei penal se aplica às infrações disciplinares também capituladas como crime independentemente da apuração criminal da conduta do servidor.

Informativo n. 646. REsp 1.767.955-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, por unanimidade, julgado em 27/03/2019, DJe 03/04/2019.

A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/1988, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais.

Informativo n. 648. REsp 1.549.433-DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, por maioria, julgado em 09/04/2019, DJe 15/05/2019.

Profissionais de empresas privadas que exerçam atividade de prevenção e combate ao incêndio podem adotar a nomenclatura "bombeiro civil".

Informativo n. 645.

RMS 52.622-MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, por unanimidade, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019.

É constitucional a remarcação de curso de formação para o cargo de agente penitenciário feminino de candidata que esteja lactante à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público.

Informativo n. 658.

REsp 1.666.294-DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 05/09/2019, DJe 11/10/2019.



A existência de condenação criminal transitada em julgado impede o exercício da atividade profissional de vigilante por ausência de idoneidade moral

Informativo n. 644

REsp 1.569.560-RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Rel. Ac. Min. Og Fernandes, por maioria, julgado em 21/06/2018, DJe 11/03/2019

O cômputo dos dez ou quinze minutos que faltam para que a "hora-aula" complete efetivamente uma "hora de relógio" não pode ser considerado como tempo de atividade extraclasse dos profissionais do magistério.

QUESTÕES

1. (TJ-MS), FCC, 2020. Juan Mesquita é brasileiro naturalizado, tem 55 anos de idade e acaba de se aposentar. Antes da aposentadoria, ocupava emprego público de fisioterapeuta em Hospital Municipal. Candidatou-se em concurso público para o cargo efetivo de fiscal de rendas do Estado e foi aprovado. Sabe-se que dispõe da escolaridade exigida para o cargo, goza de boa saúde física e mental, está em dia com suas obrigações militares e eleitorais e em pleno gozo de seus direitos políticos. Considerando a situação descrita, é correto concluir que Juan

A poderá tomar posse no cargo público, desde que requeira a desaposentação em relação ao vínculo anterior.

B não poderá tomar posse no cargo público, pois se trata de cargo privativo de brasileiro nato.

C não poderá tomar posse no cargo público, pois a percepção da aposentadoria com os vencimentos do cargo implica acúmulo vedado pela Constituição Federal.

D poderá tomar posse no cargo público, pois não há nenhum impedimento para tanto.

E não poderá tomar posse no cargo público, pois ultrapassou a idade máxima exigida para vincular-se ao regime próprio de previdência dos servidores públicos.

2. (TJ-PA) CESPE/CEBRASPE, 2019. Determinado servidor público estadual possui vencimento-base inferior ao salário mínimo. Sua remuneração é complementada por meio de um abono, destinado a garantir a percepção do mínimo legal.

Considerando-se os enunciados de súmula vinculante do STF, nesse caso, se for criada uma nova gratificação de desempenho aplicável a esse servidor, ela

A deverá incidir sobre o salário mínimo.

B deverá incidir sobre a soma do vencimento-base com o abono, excluídas as demais parcelas indenizatórias.

C deverá incidir sobre a remuneração bruta do servidor, excluídas apenas as parcelas de caráter transitório.

D não poderá incidir sobre o abono.

E não poderá incidir sobre o vencimento-base.

3. (TJBA) CESPE/CEBRASPE, 2019. Se os servidores estatutários de uma autarquia ambiental deflagrarem greve e pararem de trabalhar,

A a greve será, de pronto, ilegal, visto que ainda não foi editada lei que regulamente a greve no serviço público.

B a greve poderá ser considerada legal se o Estado der causa à deflagração, assim como ocorreria no caso de servidores policiais civis.

C a administração pública poderá agir discricionariamente para escolher se desconta da remuneração dos servidores os dias parados.

D a greve poderá ser declarada legal, porém a administração pública deverá, em regra, descontar da remuneração dos servidores os dias parados.

E a administração pública será obrigada, caso haja requerimento de sindicato ou associação, a promover uma compensação pelas horas não trabalhadas, evitando o desconto na remuneração dos servidores.

4. (MPE-GO) MPE-GO, 2019. Quanto ao direito de greve, a luz da jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal, podemos afirmar que:

AO exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança.

BO direito de greve é assegurado aos integrantes da polícia civil, por serem servidores públicos e não militares, assegurados à aplicação da Lei n. 7.783/83, até que a matéria seja regulamentada por lei ordinária.

CA administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, não permitida a compensação em caso de acordo.

DA Justiça Comum é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada.

5. (MPE-MT) FCC, 2019. Em matéria de servidor público:

A Não há cargo sem função, tampouco função sem cargo.

B Há distinção entre cargo e emprego público, pois o vínculo que une o servidor à Administração pública é diferente.

C Inexiste diferença entre cargo e emprego público, pois em ambos os casos o vínculo que une o servidor à Administração pública é o mesmo.

D Todo servidor público só pode ser contratado mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, sem qualquer exceção.

E Não há previsão legal para que o servidor público seja contratado mediante concurso público de provas ou de provas e títulos

COMENTÁRIOS

1. Gabarito – D

A) Incorreta. Juan Mesquita não possui mais vínculo funcional, pois já está aposentado e, segundo o STF, a desaposentação não é possível (RE 381.367, RE 827.833 e RE 661.256).

B) Incorreta. Cf. art. 12, § 3º CRFB.

C) Incorreta. Cf. art. 37, XVI, da CRFB c/c art. 40, § 6º CRFB. Como Juan era empregado público (celetista) sua aposentadoria será pelo Regime Geral de Previdência Social. Logo poderá tomar posse no público.

D) Correta.

E) Incorreta. Cf. art. 40, II, da CF c/c art. 1º LC 152/2015. Veja ainda a Súmula 683 do STF.

2. Gabarito – D.

A) Incorreta. Cf. Súmula vinculante n.º 4 STF.

B) Incorreta. Cf. Súmula vinculante n.º 15 STF.

C) Incorreta. Cf. Súmula vinculante n.º 15 STF.

D) Correta.

E) Incorreta. A legislação local fixará a base de cálculo a ser adotada, podendo ser o vencimento-base. Cf. art. 39 CRFB cada Ente federativo terá competência para instituir o regime jurídico bem com os valores pecuniários a serem recebidos pelos seus servidores.

3. Gabarito – D

A) Incorreta. O STF reconhece o direito de greve dos servidores, aplicando por analogia a Lei 7.783/89, no que couber.



- B) Incorreta. Segundo o STF o direito de greve não se estende aos policiais civis, cf. art. 142, §3º, IV, da CRFB/88. Ver também STF Recl. 11246 AgR/BA.
- C) Incorreta. Não há discricionariedade no desconto dos dias parados, segundo o STF no RE 693.456/RJ.
- D) Correta.
- E) Incorreta. Não há obrigação do Estado de possibilitar a compensação dos dias parados, é assunto passível de acordo.

4. Gabarito – A

- A) Correta.
- B) Incorreta. Segundo o STF o direito de greve não se estende aos policiais civis, cf. art. 142, §3º, IV, da CRFB/88. Ver também STF Recl. 11246 AgR/BA.
- C) Incorreta. Não há obrigação do Estado de possibilitar a compensação dos dias parados, é assunto passível de acordo.
- D) Incorreta. A justiça comum, federal ou estadual, é competente para julgar a abusividade de greve de servidores públicos celetistas da Administração pública direta, autarquias e fundações públicas. STF RE 846854/SP.

5. Gabarito – B

- A) Incorreta. Todo cargo público deverá ter uma função pública estipulada por lei, mas é permitida a criação de funções de confiança para o exercício de atividades de chefia, direção e assessoramento.
- B) Correta.
- C) Incorreta. O cargo público gera vínculo estatutário, enquanto o emprego público gera vínculo celetista.
- D) Incorreta. Cf. Art. 37 II CRFB.
- E) Incorreta. Cf. Art. 37 II CRFB.



CAPÍTULO 8 — LICITAÇÕES PÚBLICAS

1. CONCEITO

Segundo Ronny Charles⁸¹, a licitação é um procedimento prévio de seleção, por meio do qual a Administração, através de critérios previamente estabelecidos e isonômicos, seleciona a melhor alternativa para a celebração de um contrato para a administração. A principal lei que rege a matéria é a Lei 8.666/93, sendo este um verdadeiro estatuto das licitações e contratos administrativos.

São os procedimentos administrativos para que se escolha com quem a Administração Pública irá contratar. Essa escolha não pode ser feita de forma aleatória, como se particular fosse. A ideia é de se escolher a proposta mais vantajosa para o Poder Público ao mesmo tempo em que se assegura a isonomia, que a Administração Pública deve guardar perante todos os cidadãos de toda a sociedade.

A licitação serve para três finalidades: escolher a proposta mais profícua, garantia da isonomia no procedimento e, posteriormente alteração legislativa que sofreu o art. 3º da lei 8.666/93, a garantia de promoção do desenvolvimento sustentável nacional eventualmente possibilitando, como critério de desempate, a escolha de empresa brasileira em detrimento de estrangeiras, para que aquele gasto público seja revertido para o próprio país com a permanência do capital no território brasileiro.

Quem pode licitar? Quem são as pessoas que, em virtude da indisponibilidade do interesse público, não podem contratar com qualquer pessoa? São todas aquelas pessoas jurídicas que compõe a administração direta e indireta. Por exemplo, os entes federados e seus órgãos, como também autarquias, fundações. Lembrando que as empresas estatais (empresas públicas e sociedades de economia mista), sejam exploradoras de atividade econômica ou prestadora de serviço público, possuem regime próprio licitatório previsto na Lei 13.303/16.

Também já foi visto capítulo 06 que as entidades do terceiro setor, por exemplo, não tem o dever de licitar. Mas apesar de não estarem sujeitas à lei 8.666/93 devem respeitar o mínimo que se espera de uma entidade que deva exercer uma atividade com múnus público, devendo adotar procedimentos que permitam o atendimento ao regime jurídico administrativo, especialmente quanto a impessoalidade e a moralidade.

2. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS

O art. 22, XXVII CRFB outorga à União a competência privativa para legislar sobre normas gerais de licitação e contratos. Assim os demais entes federativos poderão legislar sobre normas específicas sobre o tema.

Caso a União não tivesse criado a Lei nº 8.666/93 ainda assim o estado membro não poderia legislar sobre normas gerais, pois a competência não é concorrente e sim privativa. Atente-se que, naquilo que é geral, a lei que tratar de licitação terá caráter nacional, mas no que for específico terá natureza federal, regulando apenas o da União, não existindo impedimento para que exista uma regulação diversa no campo estadual ou municipal.

O art. 22, XXVII CRFB remete ao inciso XXI do art. 37 CRFB: as obras, serviços, compra e alienações serão contratados por meio de licitação pública que vão assegurar igualdade de condições a todos os concorrentes. Dessa forma, garante-se **isonomia**, de forma que só é possível que se institua **exigências** de qualificação técnica e econômica que se mostrem **indispensáveis** ao cumprimento da licitação.

O art. 22, XXVII, faz uma alusão ao inciso III, §1º, do art. 173 da CF. Este dispositivo diz que a lei vai estabelecer o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e suas subsidiárias que explorem atividade econômica. Para estas aplica-se a Lei nº 13.303/16.

⁸¹TORRES, Ronny Charles Lopes de, BARCELOS, Dawison. Licitações e Contratos nas Empresas Estatais. Salvador: Juspodivm, 2018.



3. OBJETO

O objeto da licitação são obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões e permissões, locação pela administração, quando for contratar com terceiros.

4. FINALIDADES DA LICITAÇÃO

A licitação tem como finalidade uma **contratação mais vantajosa** para a Administração, e, ao mesmo tempo, **respeitar o tratamento igualitário** daqueles que queiram participar do processo licitatório. A Lei 12.349/10 incluiu dentro dessas finalidades a **promoção do desenvolvimento nacional sustentável**.

Portanto são finalidades:

- Obter a contratação mais vantajosa para a administração
- Assegurar princípio da isonomia
- Promover o desenvolvimento nacional sustentável

Nos processos licitatórios poderá ser estabelecida uma **margem de preferência**. Será dada preferência a:

- **Produtos manufaturados nacionais**
- **Bens e serviços produzidos ou prestados por empresas com reservas de cargos para pessoas com deficiência ou para reabilitados da previdência social**

É possível que haja **margem de preferência adicional** para os produtos manufaturados e para os serviços nacionais resultantes de desenvolvimento de inovação tecnológica realizados no Brasil.

Essa margem de preferência tem como **limite 25%** acima do preço do produto ou do produto estrangeiro. Pode ser que o edital fixe percentual menor.

5. DESTINATÁRIOS DAS REGRAS LICITATÓRIAS

Segundo o art. 1º, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, serão destina-se aos:

- Órgãos da administração direta
- Fundos especiais
- Autarquias
- Fundações públicas
- Empresas públicas
- Sociedades de economia mista
- Demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Não estão sujeitos ao dever de licitar:

- Serviços sociais autônomos
- Organizações sociais (OS)
- Organizações da sociedade civil de interesse civil (OSCIP)

Como visto o capítulo 06 essas são entidades do terceiro setor, logo permite-se que se estabeleça um regulamento próprio para contratação de obras, serviços e produtos. Essas entidades, apesar de não licitarem, devem observar princípios que regem a Administração Pública no tocante aos regramentos que adotam para fins de contratação.

Com relação às empresas estatais (Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e subsidiárias) que explorem atividade econômica podem dispensar a obediência total das regras da lei de



licitações, quando esta obediência significar um óbice à atividade de mercado. Parte significativa da doutrina vai dizer que essa exceção estará presente quando estivermos diante da atividade-fim. Portanto, **para a atividade-fim, as empresas públicas e sociedades de economia mista estariam dispensados de observar a lei de licitações**. Para a atividade-meio, será necessário licitar. Celso Antônio Bandeira de Mello⁸² aponta que:

Sem dúvida, a adoção do mesmo procedimento licitatório do Poder Público seria inconveniente com a normalidade de suas atuações na esfera econômica, isto é, não seria exequível em relação aos seus rotineiros procedimentos para operar o cumprimento das atividades negociais em vista das quais foram criadas. As delongas que lhe são próprias inibiriam seu desempenho expedito e muitas vezes obstarium à obtenção do negócio mais vantajoso. Dela não haveria cogitar em tais casos.

O STF entende que **as empresas estatais exploradoras de atividades econômicas pode ficar submetidas a um regime diferenciado de licitação**. A Lei nº 13.303/2016 trouxe novos requisitos para o afastamento da licitação e procedimentos licitatórios específicos para as empresas estatais.

6. PRINCÍPIOS GERAIS DA LICITAÇÃO

A lei de licitações, em seu art. 3º, traz os princípios básicos da licitação. Alguns já foram abordados no capítulo 02 e se recomenda a revisão, embora um breve resumo seja apresentado abaixo. Os princípios aplicáveis às licitações são os da:

- Legalidade
- Impessoalidade
- Moralidade
- Publicidade
- Igualdade
- Vinculação ao instrumento licitatório
- Julgamento objetivo
- Probidade

O art. 3º indica a existência de outros princípios correlatos, tais como princípio da competitividade, formalismo, obrigatoriedade da licitação, economicidade, sigilo das propostas, etc.

6.1. LEGALIDADE

O princípio da legalidade pode ser enxergado por duas vertentes:

- **vertente negativa:** o administrador não poderá ir além da lei.
- **vertente positiva:** o administrador deve agir segundo a lei, com autorização legal.

O conceito de legalidade administrativa vem evoluindo para a ideia de legitimidade, não bastando a legalidade nua e crua, sendo necessário observar a moralidade e a finalidade pública no ato administrativo. Veja o item 2.2.1.

⁸²MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Curso de Direito Administrativo** 33ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019.

6.2. IMPESSOALIDADE

A impessoalidade abomina os favoritismos.

Quando o Poder Público contratar, deverá fazê-lo com base na melhor proposta, e não com o licitante A ou B. Quando é feito o contrato, o responsável pela licitação não está contratando em nome próprio, e sim em nome do Estado.

Veja o item 2.2.2.

6.3. MORALIDADE

Exige que a atuação do administrador seja ética. Veja o item 2.2.3.

6.4. IGUALDADE

Impede que haja uma discriminação entre os participantes do certame.

6.5. PUBLICIDADE

É a publicidade dos atos administrativos do processo licitatório. É nulo o ato praticado em inobservância à publicidade.

O art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa diz que constitui improbidade administrativa, que atenta contra os princípios administrativos, negar publicidade aos atos oficiais.

Veja o item 2.2.4.

6.6. PROBIDADE

É a moralidade qualificada, pela qual o administrador exerce as suas funções.

6.7. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

Essa vinculação é a imposição de respeito a normas previamente estabelecidas como regras do certame. Deve-se obedecer ao previsto no edital.

6.8. JULGAMENTO OBJETIVO

É um julgamento de acordo com os critérios estabelecidos no instrumento convocatório.

6.9. SIGILO DAS PROPOSTAS

O princípio do sigilo das propostas impede que a proposta seja publicizada antes da abertura dos envelopes.

Há um edital que convoca os interessados que irão apresentar uma proposta de fornecimento de um bem, por exemplo. É importante que essas manifestações sejam mantidas em sigilo até a efetiva abertura conjunta e pública, para que as empresas não possam combinar entre si e nem mudar a proposta, ajustando-a por saber o preço da outra.

Há inclusive crime da lei de licitações para o caso de haver violação a este sigilo.



6.10. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

A licitação tem como primeira manifestação externa justamente a publicação de um edital. Abre-se um processo administrativo para se averiguar o quantitativo, a necessidade da contratação, o objeto, verificar se há condições de efetuar aquela contratação e publica-se o edital, dando início à uma fase externa, que irá chamar eventuais interessados. O edital é um instrumento convocatório que chama os interessados para participar daquele procedimento e é absolutamente essencial que tenha obrigatoriedade e vinculatividade.

6.11. JULGAMENTO OBJETIVO

Em virtude da necessidade de se preservar a isonomia, bem como se assegurar a vantagem para Administração Pública, é que o julgamento deve ser objetivo, ou seja, o critério que permita aferir a proposta mais vantajosa deve poder ser extraído de uma forma que não dependa de valores, subjetividades pessoais das pessoas envolvidas. A ideia é justamente permitir que numa comparação entre a proposta que é dada pelo particular e o edital, se possa chegar de forma objetiva ao resultado de qual é a melhor opção. Sem que ao final a escolha da melhor proposta seja algo que dependa das emoções ou preferências dos envolvidos naquele procedimento licitatório

7. CONTRATAÇÃO DIRETA

Contratação direta é a contratação sem a necessidade de licitar. A lei de licitações prevê hipóteses de contratação direta:

- dispensa de licitação
- inexigibilidade de licitação

7.1. DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nos casos de dispensa de licitação as hipóteses arroladas em lei são **taxativas**. São as situações onde a competição é possível, mas o legislador preferiu não tornar essa competição obrigatória, autorizando a contratação direta. A doutrina divide as hipóteses de dispensa em:

- Licitação dispensada
- Licitação dispensável

7.1.1. LICITAÇÃO DISPENSADA

A licitação dispensada se dá com a hipóteses de **alienação de bens da administração**.

Como regra, quando os bens forem **imóveis**, a alienação dependerá de:

- **Autorização legislativa**
- **Avaliação prévia**
- **Licitação na modalidade de concorrência**

Essa licitação de modalidade **concorrência** estará **dispensada** quando estiver diante de **ação em pagamento, doação, permuta, entre outros casos**.



Apesar da alienação do imóvel, via de regra, exigir licitação na modalidade concorrência, será ela dispensada nos casos especificados em lei.

Em relação aos bens **móveis**, a alienação dependerá de:

- **Avaliação prévia**
- **Licitação na modalidade de concorrência ou leilão**

Note que **não será necessária autorização legislativa**.

Essa licitação será dispensada quando houver doação, permuta e venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da administração pública e outros casos previstos em lei.

7.1.2. LICITAÇÃO DISPENSÁVEL

Nesses casos, apesar de também ser um rol taxativo, o gestor poderá entender que no caso concreto a licitação atende ao interesse público, podendo realizá-la, caso assim entenda.

A licitação é dispensável:

- **Em razão do seu valor**
- **Por razões excepcionais**
- **Por conta do seu objeto**
- **Em razão da pessoa**

Na aquisição de serviços e obras de engenharia com valor de **até 10% do convite**, a licitação será dispensável.

Esse percentual será de **20% do convite**, se houver contratação por consórcios públicos, sociedades de economia mista, empresas públicas e autarquias e fundações qualificadas como agência executiva.

Se o **consórcio público for formado por mais de 03 (três) entes públicos**, será **triplicado os 10%**, alcançando os **30% do valor da modalidade convite**.

Em razão de causas excepcionais, objeto e pessoa, a licitação **poderá** ser dispensada se estiver diante de:

- **Licitação deserta:** é a licitação que ninguém apareceu, ocorrendo quando não acudirem interessados à licitação, não podendo se repetir sem prejuízo para a administração.
- **Houver interesse de intervenção ao domínio econômico:** nesses casos, em que a União age para regularizar determinado abastecimento ou regularizar os preços, a licitação será dispensável.
- **Houver propostas incompatíveis:** a proposta será tida como incompatível quando as propostas consignam preços manifestamente superiores aos praticados no mercado. Neste caso, haverá uma renovação das propostas. Caso persista esta situação, será admitido a adjudicação direta pelo valor que não seja superior ao constante no registro de preços.
- **Contratação de órgãos da administração pública:** bens produzidos ou serviços prestados pela administração pública, e que tenha sido criado para este fim específico, autoriza a dispensa.
- **Segurança nacional:** também poderá justificar a dispensa de licitação.
- **Locação de imóvel:** mas para dispensar deverá obedecer alguns critérios: i) deve atingir as finalidades precípuas da administração; ii) motivos para que seja no imóvel a escolha; iii) preço compatível com o valor de mercado.
- **Contratação remanescente:** neste caso, há uma contratação remanescente de obras, serviços ou fornecimento, pois houve uma rescisão contratual, sendo necessário vislumbrar o segundo colocado da lista da licitação, submetendo-se este às mesmas condições do vencedor da licitação.
- **Compras de gêneros perecíveis:** os hortifrutigranjeiros, pães, etc.



- **Contratação de institutos de pesquisa:** é necessário que a instituição não tenha fins lucrativos. Com base nisso, entende-se que é lícito a contratação de serviços de concurso público por meio direto.
- **Acordo internacional para aquisição de bens e serviços:** é necessário apenas que este acordo internacional seja específico nesse sentido.
- **Compra de obras de arte e objetos históricos**
- **Impressões e serviços de informática**
- **Aquisição vinculada à garantia:** no caso de faltar alguma peça, e para não perder a garantia, seja necessária adquirir diretamente o produto com o fornecedor, a fim de promover a manutenção do objeto.
- **Abastecimento de embarcação, aeronaves ou tropas:** para padronização do material militar, salvo o de uso especial ou administrativo.
- **Contratação de associação de portadores de deficiência:** desde que não tenha fins lucrativos.
- **Pesquisa e desenvolvimento:** limitada no caso de obras e engenharia em **300 mil reais**.
- **Contratação de energia elétrica e gás natural:** se estiver diante de um único fornecedor de gás ou energia elétrica, a hipótese será de inexigibilidade de licitação.
- **Contratação de subsidiárias e empresas controladas**
- **Contratação de organizações sociais para prestação de serviços públicos:** desde que estejam contempladas as atividades no contrato de gestão. A doutrina estende essa regra às OSCIP's, desde que para cumprimento do termo de parceria.
- **Contratação de instituição científica e tecnológica:** busca-se a transferência de tecnologia, sendo o licenciamento do direito de uso ou exploração de uma criação que está protegida por lei. Ressalta-se que instituição científica e tecnológica é órgão ou entidade da administração pública, tendo como missão executar atividades de pesquisa. Agência de fomento é órgão ou instituição que pode ter natureza pública ou privada, tendo como objetivo financiar o desenvolvimento da ciência, tecnologia ou inovação.
- **Contratação de consórcio público ou convênio de cooperação:** celebrado o contrato de programa com determinado ente da federação, a contratação poderá ser feita diretamente, sem a necessidade de licitação. Lembrando que o consórcio poderá ter personalidade jurídica de direito público ou privado.
- **Contratação nos casos de resíduos sólidos:** para contratação de coleta, processamento e da comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis, será dispensável a licitação para a contratação de cooperativas, formadas por pessoas físicas de baixa renda, assim reconhecidas pelo Poder Público.
- **Complexidade tecnológica e defesa nacional:** portanto, bens e serviços que exijam cumulativamente uma complexidade tecnológica e necessidade de se garantir a defesa nacional, podem ser contratados diretamente, sem licitação.
- **Contingentes militares:** para aquisição de bens e serviços para atender contingentes militares para realização de missão de paz no exterior, poderá se dar de forma direta.
- **Assistência técnica e extensão rural por meio do PRONATERRA:** há uma contratação de uma instituição com fins lucrativos ou não, mas que preste serviços de assistência técnica e extensão rural no âmbito do PRONATERRA.
- **Estímulo à inovação científica**
- **Transferência de produtos estratégicos para o SUS**
- **Contratação de entidades sem fins lucrativos para combate à seca:** objetivo é implementar cisternas e outras tecnologias para obtenção de água.
- **Contratação direta de insumos que se mostrem estratégicos para a saúde.**
- **Guerra**
- **Grave perturbação da ordem**



- **Emergência ou calamidade pública**, caso em que será preciso licitar apenas os bens necessários àquela situação, e para as parcelas de **obras e serviços que possam ser concluídos no prazo máximo de 180 dias**, contados do fato que ensejou a contratação.

É importante destacar hipótese de licitação dispensável em situações de guerra, grave perturbação da ordem, emergência ou calamidade pública, casos de comprometimento da segurança nacional.

As duas primeiras se relacionam com os arts. 136 a 139 CRFB, que regulam o sistema constitucional de crises, ou direito de auto preservação do estado. Exige-se a decretação de estado de defesa ou de sítio.

Já as duas últimas se vinculam com os arts. 62 e 167 § 3º CRFB. A decretação do estado de calamidade e de emergência geram uma exceção prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, que permite ao ente federativo realizar gastos públicos sem esclarecer de onde virá a receita para tal. O estado de emergência é preventivo, e deve ser decretado antes da confirmação da situação calamitosa; já o estado de calamidade será decretado simultaneamente a situação. Ambos são decretados pelo chefe do Poder Executivo com a autorização do Legislativo. Durante a pandemia de COVID19 inúmeros entes federativos decretaram estado de emergência e/ou calamidade visando exatamente esta flexibilização do orçamento.

Na mesma linha a Lei nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019 determina, em seu art. 4º, hipóteses licitação dispensável:

Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei⁸³.

§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o **caput** deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.

§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.

§ 3º Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com o Poder Público suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido⁸⁴.

§ 4º Na hipótese de dispensa de licitação de que trata o **caput**, quando se tratar de compra ou contratação por mais de um órgão ou entidade, o sistema de registro de preços, de que trata o inciso II do **caput** do art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, poderá ser utilizado⁸⁵.

§ 5º Na hipótese de inexistência de regulamento específico, o ente federativo poderá aplicar o regulamento federal sobre registro de preços.⁸⁶

§ 6º O órgão ou entidade gerenciador da compra estabelecerá prazo, contado da data de divulgação da intenção de registro de preço, entre dois e quatro dias úteis, para que

⁸³Redação dada pela Medida Provisória nº 926, de 2020.

⁸⁴Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020.

⁸⁵Incluído pela Medida Provisória nº 951, de 2020.

⁸⁶Incluído pela Medida Provisória nº 951, de 2020.



outros órgãos e entidades manifestem interesse em participar do sistema de registro de preços nos termos do disposto no § 4º e no § 5º⁸⁷.

7.2. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Na inexigibilidade, a **competição é inviável**. Portanto, as hipóteses que a lei traz são **exemplificativas**. Marçal Justen Filho⁸⁸ esclarece que

É inexigível a licitação quando a disputa for inviável. Havendo viabilidade de disputa é obrigatória a licitação, excetuados os casos de dispensa imposta por lei. Sob esse ângulo, a inexigibilidade deriva da natureza das coisas, enquanto que a dispensa é produto da vontade legislativa. Esse é o motivo pelo qual as hipóteses de inexigibilidade indicadas em lei são meramente exemplificativas, enquanto as de dispensa são exaustivas.

São hipóteses de inexigibilidade:

- **Aquisição junto a um fornecedor exclusivo:** é vedada a preferência por marca, mas a exclusividade é do fornecedor. Essa exclusividade pode ser absoluta (só há um no país) ou relativa (só há um no local da licitação).
- **Contratação de serviços técnicos especializados:** é inexigível a licitação, pois se está diante de uma situação em que há uma notória especialização do contratado e se está diante de um serviço a ser prestado dotado de singularidade. São dois requisitos:
 - i) **notória especialização;**
 - ii) **singularidade do serviço.** Isso justifica a contratação de determinados escritórios de advocacia pelo governo para defender determinados assuntos.
- **Contratação de profissional do setor artístico:** poderá ser feita diretamente ou pelo empresário exclusivo desse artista, desde que seja consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.

Para haver licitação é necessário que se cumpra os **3 requisitos**, pois, não havendo um deles, não será possível a licitação:

- **Pressuposto lógico:** pluralidade de bens e fornecedores de bens admitem a licitação. Se o fabricante for exclusivo, mas houver mais de um fornecedor, segundo o STJ, não há inexigibilidade.
- **Pressuposto fático:** generalidade da contratação admite a licitação. Deve haver uma contratação específica para haver a inexigibilidade. Ex.: contratação de um advogado famoso para uma causa singular.
- **Pressuposto jurídico:** interesse público. Sempre que a licitação prejudicar o interesse público, a licitação será inexigível. O TCU entende que as EP/SEM não precisam licitar para as suas atividades-fim, quando se tratar de exploração econômica.

Nas situações de inexigibilidade e nas situações de dispensa, se ficar comprovado que houve superfaturamento, **respondem solidariamente o fornecedor, o prestador de serviços e também o agente público**, sem prejuízo de outras sanções.

⁸⁷Incluído pela Medida Provisória nº 951, de 2020.

⁸⁸JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 18ª Edição. São Paulo: RT, 2019, pág. 233.



8. PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO

A modalidade concorrência é a mais completa, incluindo todas as fases do processo licitatório, e será utilizada aqui para explicar o rito da licitação. Em regra, uma licitação inclui **uma fase interna e outra externa**. O procedimento da concorrência seguirá a seguinte ordem:

- Fase interna
- Audiência pública ou publicação do edital
- Habilitação das propostas
- Classificação
- Homologação
- Adjudicação

8.1. FASE INTERNA

Na fase interna, ou seja, antes da publicação do edital, há vários procedimentos formais importantíssimos, tais como:

- Solicitação da contratação
- Confecção e aprovação do projeto básico
- Estimativa dos gastos necessários para a contratação
- Indicação dos recursos orçamentários para contratação (é dispensável, segundo o STJ)
- Designação da comissão ou do pregoeiro
- Elaboração da minuta do edital
- Exame da minuta pelo órgão de assessoramento jurídico (parecer obrigatório, não vinculante)
- Autorização a abertura da licitação pela autoridade competente

Na **fase interna da licitação** a Administração Pública define o objeto, estabelece os parâmetros da obra ou do serviço que se deseja contratar ou do bem que se deseja adquirir. Para isso ela elabora um projeto arquitetônico, o chamado projeto básico (art. 6º IX Lei 8666) com um projeto orçamentário que estipula qual o valor máximo que Administração poderá gastar. Esse valor, em regra, é público, mas o valor orçamentário máximo que a administração está disposta a gastar com aquela obra é mantida em sigilo.

Após do projeto básico, é editado o projeto executivo e depois é executada a obra propriamente dita. O projeto executivo contém um cronograma, sendo o roteiro a ser seguido por quem irá executar a obra. O ideal é que o responsável por elaborar o projeto básico não possa, sob nenhuma hipótese, ganhar a licitação para construir, visando evitar fraudes. A regra é que poderá ser contratado somente para fiscalizar a obra. O ideal seria sempre realizar uma licitação somente para o projeto básico e outra para elaborar o projeto executivo.

A Lei nº 8.666/93, entretanto, prevê a possibilidade de que a pessoa que se sagrar vencedora na licitação já fazer também o projeto executivo. Quem ganha a licitação vê o projeto básico, já sabe o que vai fazer e, além disso, o edital pode conter uma cláusula que estabelece que essa empresa também fará o projeto executivo. O que não pode é o contratado para executar a obra elaborar também o projeto básico.

8.1.1. COMISSÃO DE LICITAÇÃO

A comissão de licitação terá no mínimo três membros, sendo dois servidores efetivos do órgão público licitando. Todos os membros respondem solidariamente pelos atos praticados na licitação. Um membro poderá se exonerar da responsabilidade se ele for voto vencido numa decisão, mas deverá consigná-la em ata.

Essa comissão poderá ser:

- **Especial:** é designada especialmente para a licitação. Dissolve-se após a conclusão da licitação.



- **Permanente:** é designada para o órgão, fazendo todos os processos licitatórios no período de 01 ano.

É vedada a recondução de todos os membros de um ano para o outro, mas basta que altere apenas um deles para que respeite as disposições legais.

8.2. FASE EXTERNA

A fase externa **é inaugurada com a realização de audiência pública ou com a publicação do edital**, Sempre que o valor estimado para uma licitação, ou para licitações simultâneas ou sucessivas, for superior a 100 vezes ao valor máximo estabelecido para a tomada de preços, o procedimento licitatório será iniciado obrigatoriamente com uma audiência pública, que deverá ocorrer com uma antecedência mínima de **15 dias úteis da data da publicação do edital**. Este valor poderá ser para uma única licitação ou para licitações simultâneas ou sucessivas.

- **Licitações simultâneas:** são as que têm objetos similares, mas tem uma realização prevista com **intervalos não superiores a 30 dias**, entre uma e outra.
- **Licitações sucessivas:** são licitações que também têm objetos similares, mas o edital subsequente tem uma data anterior a 120 dias, após o término do contrato resultante da licitação antecedente. Há uma licitação sucessiva quando entre o término da contratação da licitação vigente (antecedente) e a publicação do novo edital tem um intervalo de até 120 dias.

Por isso é necessário verificar se os valores das licitações ultrapassam 100 vezes o valor máximo da tomada de preço para promover audiência pública.

O edital poderá ser publicado completo ou em uma versão resumida, estando a completa disponível para consulta em versão eletrônica ou na repartição pública. A publicação será no Diário Oficial e em jornal de grande circulação.

Caso a licitação seja na modalidade convite, publica-se a **carta convite**.

8.2.1. PUBLICAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

Os resumos dos editais devem ser publicados ao menos uma vez no **Diário Oficial da União**, se for entidade federal, ou no **Diário Oficial do Estado ou do DF**, se a licitação tiver caráter estadual, municipal ou distrital.

Ainda, publica-se ao menos uma única vez em **jornal diário de grande circulação**, normalmente o do Estado onde ocorre o certame. Se o município tiver um jornal de grande circulação, também será feito nesse jornal local.

Na modalidade de licitação convite, não é necessária essa publicação, bastando que a unidade administrativa afixe na repartição, em local apropriado, a **cópia da carta-convite**.

Será fixado o prazo para os interessados apresentarem suas propostas. O **prazo mínimo** para receber as propostas ou realizar o evento em que as propostas serão apresentadas dependerá da modalidade licitatória:

- **Concurso:** prazo de **45 dias**.
- **Concorrência:** via de regra, o prazo é de **30 dias**. Mas se for **regime de empreitada integral** ou do **tipo melhor técnica ou técnica e preço**, o intervalo será de **45 dias**.
- **Tomada de preços:** via de regra, o prazo é de **15 dias**. Se a licitação for do **tipo melhor técnica ou técnica e preço**, o prazo é de **30 dias**.
- **Leilão:** o prazo é de **15 dias**.
- **Pregão:** o prazo é de **08 dias úteis**.
- **Convite:** o prazo é de **5 dias úteis**.

Esses prazos **podem ser superiores**, pois se trata de intervalo mínimo!



Um fase possível é a de **impugnação do edital**. Administrativamente, qualquer cidadão interessado poderá impugnar o edital, desde que o faça até o 5º dia útil anterior à data marcada para abertura dos envelopes que contém as propostas. Sendo **licitante**, a impugnação poderá ser feita **até o 2º dia anterior** à data da abertura dos envelopes.

Se houver alguma **alteração no edital**, deverá sempre haver nova publicação. É denominado de **errata**. Todavia, será preciso observar novamente o intervalo mínimo, **salvo se a alteração não modificar o conteúdo das propostas**.

8.2.2. HABILITAÇÃO

Habilitação é o momento em que será verificado se o interessado pode ou não participar da licitação. O órgão licitante vai procurar identificar a capacidade do licitante de efetivamente executar os serviços ou entregar os bens que a Administração deseja contratar.

Até essa fase qualquer licitante poderá desistir da licitação. Após será necessário ter uma justificativa do Poder Público.

Vale lembrar que **na tomada de preços não ocorrerá a fase de habilitação**, pois os licitantes são previamente cadastrados. No entanto, a Administração poderá exigir documentos específicos. Da mesma forma, **no convite não há fase de habilitação**.

Exige-se nessa fase as seguintes documentações:

- Habilitação jurídica
- Habilitação técnica
- Qualificação econômico-financeira
- Regularidade fiscal e trabalhista
- Necessidade de se comprovar a observância do preceito que veda o trabalho noturno, perigoso e insalubre para menores de 18 anos e para qualquer tipo de trabalho para os menores de 16 anos, salvo se for aprendiz a partir dos 14 anos.

O edital de licitação poderá dispensar um ou mais documentos de habilitação para o procedimento licitatório, quando estiver contratando com **institutos de ciência e tecnologia**, segundo a Lei 8.666/ 1993.

Com a **habilitação jurídica** busca-se verificar se o licitante tem capacidade jurídica de ser titular de direito e deveres em relação ao contrato, sendo necessária a **juntada do contrato social**.

Na **qualificação técnica** será verificado se o licitante tem aptidão e habilidade para execução da pretensão contratual. Se a empresa tem experiência no ramo, o maquinário e o número de funcionários necessários para o correto atendimento do objeto do contrato. O STJ admite editais que contenham regra de experiência prévia, com a exigência de execução de obras similares anteriormente. Só não é possível extrapolar o que é necessário para que o contrato seja firmado e executado (REsp 1.257.886/PE).

A **qualificação econômico-financeira** é a verificação sobre as condições que têm o licitante para cumprir com seu compromisso. É a verificação da capacidade econômica do particular, ou seja, se ele tem fôlego financeiro suficiente para executar o contrato. O art. 31 da Lei 8.666/93 traz exigências originárias e rotineiras para tanto. Segundo esse dispositivo, a documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a apresentação de:

- **Balanco patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;**
- **Certidão negativa de falência ou concordata, ou certidão negativa de execução patrimonial;**
- **Garantia limitada a 1% do valor estimado do objeto da contratação.**

Com relação à exigência de certidão negativa de concordata, **o STJ entende que a empresa em recuperação judicial tem o direito de participar da licitação**, ainda que junte a certidão de que comprove



sua situação em recuperação judicial. A preservação da empresa, de sua função social e do estímulo à atividade econômica atendem também, em última análise, ao interesse da coletividade, uma vez que se busca a manutenção da fonte produtora, dos postos de trabalho e dos interesses dos credores. O estímulo a atividade econômica, cumpre a verdadeira a função da recuperação judicial (AREsp 309.867).

A **regularidade fiscal e trabalhista** visa demonstrar se o interessado se mantém regular com suas obrigações fiscais e trabalhistas.

No tocante às trabalhistas, se for verificada a existência de débitos, mas estes estiverem garantidos por penhora ou com a exigibilidade suspensa, será expedida uma certidão positiva com efeitos de negativa.

A microempresa e a empresa de pequeno porte **ficam dispensadas da regularidade fiscal**, ou seja, deverá juntar a certidão positiva de débito com a fazenda pública, mesmo assim poderá participar da licitação. Caso ela se sagre vencedora, a administração dará o **prazo de 05 dias úteis para se regularizar com o fisco**. A isto se dá o nome de saneamento.

Quanto a **necessidade de se comprovar a observância do preceito que veda o trabalho noturno, perigoso e insalubre para menores de 18 anos e para qualquer tipo de trabalho para os menores de 16 anos, salvo se for na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos**. É o cumprimento do art. 7º, XXIII, da CRFB.

A lei de licitações, em seu art. 32, §1º, diz que **a exigência de documentos de habilitação poderá ser dispensada** se for realizado na modalidade:

- Concurso
- Convite
- Fornecimento de bem para pronta entrega
- Leilão

8.2.3. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

Terminada a habilitação, haverá a classificação das propostas. As propostas serão avaliadas em seu conteúdo, a fim de verificar se é adequada ou inadequada, utilizando para tal critérios como preço máximo, planilha de preços, exequibilidade de preços. Verificada que a proposta está inadequada, a proposta será desclassificada.

Se todos os licitantes forem inabilitados, ou se todos os participantes tiverem suas propostas desqualificadas, haverá uma **licitação fracassada**.

Se todos tiverem sido inabilitados, a Administração poderá fixar aos licitantes o **prazo de 08 dias úteis** para que possam apresentar **novas documentações** a fim de se habilitar na licitação.

Supondo, por exemplo, que de dez interessados, cinco foram considerados habilitados, ficando os demais inabilitados. Neste caso, haverá a classificação das propostas. No entanto, foi verificado que as cinco propostas foram consideradas inidôneas, havendo a desclassificação dos cinco interessados. Nesta situação, a Administração poderá conceder um **prazo de 08 dias úteis** para que estes apresentem novas propostas.

No caso de **convite**, estes prazos caem para **03 dias úteis**.

8.2.4. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Em igualdade de condições, será necessário desempatar. Será assegurada a preferência a bens e serviços na seguinte ordem:

- bens e serviços produzidos no país
- bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras (não importa a origem do capital)
- bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que invistam pesquisa e desenvolvimento de tecnologia no Brasil



- bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem o cumprimento para reserva de cargos para pessoas com deficiência ou reabilitados da previdência social
- atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação

Se nenhum dos critérios resolver o empate, será promovido o **sorteio**.

Se alguma das empresas for de pequeno porte ou microempresa, terá essa preferência no desempate, diminuindo a sua proposta. Se ela não diminuir, então irá em pé de igualdade passar pelos critérios acima mencionados. O empate é considerado até 10% a mais da proposta vencedora. Já no pregão, esse empate ficto é limitado a 5% para as empresas de pequeno porte ou microempresa.

8.2.5. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Homologação é o ato administrativo através do qual a autoridade superior vai manifestar sua concordância com a **legalidade**: não apenas com a legalidade do procedimento licitatório, mas também se a contratação é conveniente para a Administração Pública (**conveniência** do procedimento licitatório).

A **adjudicação** é o ato administrativo pelo qual vai se declarar como satisfatória a proposta vencedora. Através da adjudicação, afirma-se a intenção de celebrar o contrato com o ofertante, com a proposta vencedora.

O primeiro classificado não tem o direito subjetivo à adjudicação, ou seja, pode haver a homologação, mas não haver a adjudicação. O adjudicatário também não tem direito subjetivo ao contrato.

A administração fica vinculada à licitação, mas não fica obrigada a contratar. O particular também fica vinculado, mas deverá celebrar o contrato **dentro do prazo de 60 dias**, a contar da abertura da proposta. Se não assinar no prazo, sofrerá sanções. Se a administração não o convocar no prazo, poderá ele se recusar a assinar após o prazo. Neste caso, chamará o segundo colocado para celebrar o contrato na proposta do primeiro.

No pregão, essa adjudicação é feita pelo **próprio pregoeiro**. Nas demais modalidades, a **adjudicação é feita pela autoridade que autorizou o certame**.

Segundo o STJ, **o licitante que for convocado dentro do prazo de validade de sua proposta e não celebrar o contrato**, deixar de entregar a documentação, apresentar documentação falsa, retardar a execução do que contratado, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, **ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 anos**(REsp 520.553/RJ).

O termo inicial para efeito de contagem e detração (abatimento) da penalidade prevista no art. 7º da Lei 10.520/2002, aplicada por órgão federal, coincide com a data em que foi publicada a decisão administrativa no Diário Oficial da União – e não com a do registro no SICAF (Inf. 561, STJ).

9. MODALIDADES DE LICITAÇÃO

As modalidades de licitação são:

- Concorrência
- Tomada de preço
- Convite
- Concurso
- Leilão
- Pregão

A escolha da modalidade vai depender de dois critérios: pelo valor ou pelo objeto.

A modalidade de licitação é determinada **de acordo com o valor** da licitação, se será concorrência, tomada de preço ou convite. No **tocante ao valor**, a escolha ocorre da seguinte forma:



- **Obras e serviços de engenharia (art. 23, I da Lei nº 8.666/93):**
 - até **\$150 mil reais** é modalidade **convite**.
 - De **\$150 mil reais e \$1,5 milhões de Reais** é modalidade **tomada de preços**.
 - **acima de \$ 1,5 milhões de reais** é modalidade **concorrência**.
- **Demais obras e serviços (art. 23, II da Lei nº 8.666/93):**
 - até **R\$ 80 mil** é modalidade **convite**.
 - de **\$80 mil reais e R\$ 650 mil** é modalidade **tomada de preços**.
 - **acima de \$650 mil** é modalidade **concorrência**.

Também poderá ser **com base no objeto** que será determinada a licitação, podendo ser concurso, leilão ou pregão.

9.1. CONCORRÊNCIA

A concorrência é, em regra, utilizada para contratações de maior vulto econômico. É a modalidade mais complexa, justamente para evitar fraudes, prevista no art. 22 § 1º da Lei 8.666/93.

De acordo com o Decreto 9.412, de 18 de junho de 2018 a **concorrência é obrigatória a partir de R\$ 3.300.000,00**, mas é possível que se licite por modalidade concorrência, um objeto que tenha por valor R\$ 1.000.000,00. Ou seja, em tese, poderia se adotar a tomada de preços, mas o administrador que quiser poderá adotar a modalidade licitatória mais complexa. O que se veda é que se adote o convite.

Em alguma, as hipóteses raras independentemente do valor, a modalidade será concorrência: contrato de concessão de serviço público (independente se o valor é superior ou não a R\$ 3.300.000,00), concessão de direito real de uso, contratos de obras celebrados por meio de empreitada integral e licitações internacionais, salvo na hipótese em que o consulado ou a embaixada brasileira no exterior já tenha um rol de fornecedores, admitindo-se a tomada de preços. Também se admite se o bem ou serviço a ser contratado não tiver fornecedor no Brasil, que o órgão faça licitação internacional na modalidade convite ou tomada de preços, desde que respeitados os limites de valor.

No RDC (Regime Diferenciado de Contratações Públicas, instituído pela Lei nº 12.462/2011) admite-se, nessa modalidade específica, que haja uma contratação integrada de forma que a mesma empresa faça o projeto básico, o projeto executivo e a obra. A Administração fará apenas um anteprojeto muito simples e quem irá apresentar o projeto arquitetônico, os materiais etc. será a própria empresa que quer construir. Isso é contratação integrada, a empresa vencedora faz tudo, do projeto básico até a obra.

Na Lei nº 13.303/16 não se admite exatamente o que é RDC permite. Não é possível que a empresa faça o projeto básico, executivo e obra, mas admite-se em seu art. 42 a contratação semi-integrada, que é próxima ao RDC. Em outras palavras, no estatuto das estatais, o projeto básico deve ser feito por uma outra empresa. Entretanto, poderá a empresa contratada, além de fazer o projeto executivo, fazer alterações no projeto básico.

Existem hipóteses em que a concorrência terá aplicação **independentemente do valor envolvido**:

- **Concessão de serviço público** comum ou especial
- **Concessão de direito real de uso de bem público** salvo quando se tratar de inexigibilidade
- **Empreitada integral** não se confunde com empreitada global
- **Compra e alienação de bens imóveis** salvo os casos de dispensa e nos casos de dação ou decisão judicial, que poderá ser leilão
- **Licitação internacional** é aquela que admite a participação de empresa estrangeira que não tenha sede no país; se tiver cadastro internacional de licitantes, poderá ser feito por tomada de preço, desde que não ultrapasse os limites máximos da tomada de preço; poderá ser feita na



modalidade convite também, quando não houver fornecedor no país, observando o limite máximo estabelecido para os valores.

9.2. TOMADA DE PREÇOS

Na tomada de preços há uma disputa entre os interessados cadastrados na administração, podendo ser acrescidos à disputa os não cadastrados que atenderem às condições previstas no edital de cadastramento **até o 3º dia anterior** à data do recebimento das propostas.

Na esfera federal, esse cadastramento é feito no SICAF (Sistema de Cadastro Federal). Esse cadastro tem duração de 01 ano.

9.3. CONVITE

O órgão contratante convida ao menos três empresas ou profissionais no ramo de atuação. Essas pessoas podem estar previamente cadastradas ou não, apresentando as ofertas. Não estando cadastrado, deverá manifestar interesse no prazo de **24 horas antes** do início da licitação.

Se existirem na praça mais de três possíveis interessados e for realizado um novo convite com objeto idêntico ou assemelhado, é obrigatório convidar mais ao menos mais um interessado.

O convite dispensa a publicação de edital em diário oficial ou em jornal, exigindo que a unidade administrativa afixe em lugar adequado uma cópia do instrumento convocatório (**carta-convite**). A publicidade é feita pelo envio aos convidados e afixando no átrio da repartição.

Pode ser que a comissão seja composta por **um servidor**, desde que seja **efetivo** do órgão.

O início do prazo mínimo de **05 dias úteis** conta-se a partir do último recebimento do AR da carta-convite ou da afixação da carta-convite no átrio da repartição.

No convite, o **recurso deverá ser apresentado em 02 dias úteis**.

Sendo todos licitantes desclassificados por inabilitação, o prazo para apresentarem novas documentações **poderá** ser de **03 dias úteis**. É facultativo esse prazo, que poderá variar entre 08 e 03 dias úteis.

9.4. CONCURSO

Concurso é modalidade para escolha de trabalho científico, técnico ou artístico, mediante ao pagamento de um prêmio ou uma remuneração, obedecendo aos critérios estabelecidos no edital.

No concurso, o julgamento das apresentações feitas é realizado por uma comissão especial, integrada por pessoas de reputação ilibada, mas que tenham conhecimento da matéria que está sendo analisada, **podendo ser servidores públicos ou não**.

O intervalo mínimo é de 45 dias, como dito antes.

9.5. LEILÃO

Leilão é utilizado para:

- **alienação de bens móveis inservíveis, apreendidos ou penhorados (empenhado) pela administração**
- **alienação de bens imóveis cuja aquisição tenha derivado de procedimentos judiciais ou dação em pagamento**

O maior lance ou maior oferta **deverá ser ao menos o valor da avaliação**.

Acima de R\$ 650 mil reais não se poderá fazer leilão. Sempre o tipo será **maior lance**, devendo ser superior ao da avaliação.



9.6. PREGÃO

É utilizado para aquisição de **bens e serviços comuns, independentemente do valor da contratação.**

Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. Tem-se entendido que é possível realização de pregão para serviços de engenharia, desde que sejam caracterizados como serviços comuns (Decreto nº 10.024/2019 e Súmula TCU nº 257–“O uso do pregão nas contratações de serviços comuns de engenharia encontra amparo na Lei nº 10.520/2002”). Já Para obras públicas não poderá ser utilizada a modalidade pregão.

A tendência atual é a ampliação da utilização do pregão, reforçada pelo Decreto nº 10.024/2019.

O pregão poderá se dar de forma eletrônica ou presencial. A Lei 10.520/2002 diz que a adoção da modalidade de pregão é facultativa. Porém, o Decreto nº 10.024/2019 impõe a adoção da modalidade eletrônica nos pregões organizados pela União, pois aumenta o número de pessoas que pode se interessar em participar.

São **características** específicas da modalidade pregão:

- **Pregoeiro** ao invés da comissão de licitação, será designado entre os servidores do órgão ou da entidade que promove a licitação, o pregoeiro. É o pregoeiro que recebe as propostas, assim como os lances, fazendo análise das propostas, fazendo também a classificação delas, bem como a habilitação dos licitantes e a adjudicação do objeto do certame ao vencedor.
- **Comissão de apoio** não se trata de comissão licitante, somente dará apoio ao pregoeiro.
- **Inversão de fases** no pregão, antes de verificar quem está habilitado, é realizada a disputa de preços. Ou seja, a fase de disputa de preços é anterior à habilitação. Depois que alguém venceu no preço é que será verificado se ele está habilitado.
- **Apresentação de lances** além das propostas que são inicialmente apresentadas, os licitantes podem apresentar lances verbais e consecutivos. No caso do pregão presencial, estes lances poderão ser feitos pelos licitantes que tiverem até 10% de sua proposta superior à dos vencedores. Encerrada a etapa dos lances, o pregoeiro pode realizar uma negociação com o licitante que apresentou a proposta mais vantajosa. O que não pode ocorrer é negociar condições diferentes das previstas no edital, pois está vinculado ao instrumento convocatório.
- **Fase única recursal** o pregão só tem a possibilidade de apresentar o recurso uma vez.
- **Prazo de publicação do edital** o prazo é de **08 dias úteis**.
- **Tipo menor preço** sempre será esse tipo de licitação.

No pregão, são **vedadas** algumas exigências, tais como:

- É vedada a garantia de propostas
- É vedada a aquisição de edital como condição para participar do certame
- É vedado o pagamento de taxas e emolumentos, salvo as que se referem ao custo do fornecimento do edital quando for o caso.

No pregão ordem do rito licitatório é alterada. No pregão, a aferição a fase da habilitação é feita após a classificação das propostas. Ou seja, primeiro se classifica e depois de habilita. O conceito é agilizar o procedimento, além de potencialmente atrair um maior número de interessados:

- Publicação do edital
- **Classificação das propostas**
- Habilitação das propostas
- **Adjudicação do objeto**
- Homologação



Todos os licitantes que **apresentem até 10%** da proposta vencedora passam para a próxima fase do pregão. Na classificação, passarão **no mínimo três propostas** para os lances verbais.

Não havendo o mínimo de três propostas com valores de até 10%, serão chamados os licitantes que ultrapassaram os 10% para promoverem lances verbais.

Caso o primeiro colocado não seja habilitado, será chamado o segundo colocado, mas não na proposta do primeiro, pois este já teve a oportunidade de baixar sua proposta nos lances verbais. Neste caso, **será chamado o segundo para uma negociação do preço**.

Habilitado o licitante, o pregoeiro irá adjudicar. Neste momento, haverá o prazo de recurso, devendo este ser imediato. Se recorrer imediatamente, haverá o prazo de **03 dias** para elaborar as razões.

9.7. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)

O sistema de registro de preços não é uma modalidade licitatória, mas um instrumento que facilita a atuação da Administração em futuras contratações. Há aqui um registro formal de preços para que se valha desse registro em contratações futuras. O sistema de registro de preços será adotado quando:

- **Contratação frequente** pelas características do bem ou do serviço, existia essa necessidade de contratação frequente.
- **Contratação por mais de um órgão ou entidade** também se valerá do SRP quando for necessária a contratação por mais de um órgão ou mais de uma entidade.
- **Entregas parcelas ou serviços por unidade de medida** é possível também o sistema de registro de preços quando for mais propícia a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas, ou serviços remunerados com unidades de medida.
- **Imprevisibilidade de uso efetivo pela administração** também se admite a preferência do sistema de registro de preços quando não for possível pela natureza do objeto prever quanto será utilizado efetivamente pela Administração.

O sistema de registro de preços **dispensa a prévia dotação orçamentária**, pois o objetivo imediato não é contratar, e sim registrar o preço.

A seleção de licitantes será feita na modalidade de **concorrência** ou de **pregão**, havendo então o sistema de registro de preços. Veja, não é modalidade de licitação. A partir de então, serão convocados os selecionados para assinar a **ata de registro de preços**, produto do pregão ou concorrência, **terá vigência de 12 meses**, surgindo um dever de compromisso ao licitante pelo valor estabelecido na ata de registro de preços.

É necessário fazer uma distinção entre:

- **Órgão gerenciador:** esse órgão é responsável pela condução do certame e pelo gerenciamento da ata de registro de preços.
- **Órgão participante:** é um órgão que integra a ata de registro de preços, tendo uma pretensão contratual, mas não é ele que conduz. Ou seja, terá interesse de contratar o bem, constando o órgão na ata de registro de preços.
- **Órgão não participante:** o sistema de registro de preços permite que o órgão que não tenha sido incluído na origem, ou seja, que não tenha integrado a ata de registro de preços, possa vir a aderir a ata do registro de preços. É a denominada **licitação carona**, ou órgão carona. Parte da doutrina faz uma crítica, mas vem sendo admitido.

Atente-se que a **União não poderá aderir à ata de entidades estaduais e municipais**, podendo aderir à ata de outras entidades federais. O Decreto 7.892/2013 também estabelece que o quantitativo **não poderá ser superior a cinco vezes** o que está definido no edital. Ex.: edital da licitação era de 30 carros, poderá haver a compra de no máximo 150 carros.

Na sistemática do sistema de registro de preços, a licitação vai englobar o somatório das pretensões contratuais do órgão gerenciador e do órgão participante. Então, por exemplo, se um órgão



quiser 100 unidades, o outro órgão quer mais 200, outro ainda quer 100 unidades. Então, o sistema de registro de preços será considerado uma possível aquisição de 400 unidades, considerando de todos os órgãos.

10. TIPOS DE LICITAÇÃO

10.1. MENOR PREÇO

O tipo de licitação de menor preço é o tipo preferência para a aquisição de bens e serviços comuns. No pregão só é admitido o tipo menor preço.

10.2. MELHOR TÉCNICA

O gestor vai realizar uma análise das propostas em duas fases:

- **1ª fase:** serão abertas as propostas técnicas criando-se uma classificação de acordo com os critérios pertinentes.
- **2ª fase:** abertura dos envelopes em que estão verificados os preços.

Após, o gestor chama o candidato melhor classificado na apresentação das propostas técnicas para a negociação do preço, tendo como parâmetro a proposta de menor valor apresentada entre os licitantes que tiveram uma pontuação mínima na primeira fase.

Como o objetivo do certame é escolher a melhor técnica, chama-se o primeiro colocado para negociar com ele o preço.

Só se admite esse tipo de licitação para serviços de informática e serviços de natureza intelectual (art. 13 da Lei nº 8.666/93).

10.3. MELHOR TÉCNICA E MENOR PREÇO

Aqui há uma avaliação única dos dois tipos diferentes de propostas, realizando uma média ponderada para determinar o vencedor.

10.4. TIPO MAIOR LANCE OU OFERTA

O licitante oferece uma oferta, com maior valor possível. O parâmetro mínimo é o valor da avaliação do bem.

11. RECURSOS

A lei de licitações, no art. 109, traz três espécies de recursos:

- **Recurso hierárquico** tem o prazo de **05 dias úteis**, com efeito suspensivo automático, sendo cabível quando:
 - sujeito for habilitado ou inabilitado
 - houver julgamento das propostas
 - anulação ou revogação da licitação
 - indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral
 - rescisão unilateral do contrato
 - houver aplicação de penas de advertência, suspensão temporária ou multas.
- **Pedido de reconsideração** é cabível contra decisão do Ministro de Estado (ou Secretário de Estado ou Municipal) que aplicar àquela empresa a pena de declaração de inidoneidade. O prazo de interposição do pedido de reconsideração é de **10 dias úteis**.



- **Representação** o prazo de interposição é de **5 dias úteis**. A representação tem objeto residual. Isto quer dizer que situações em que não foram contempladas no recurso hierárquico ou pedido de reconsideração serão abarcadas pela representação.

O prazo para recursos não é o mesmo estabelecido para juntada de documentos obrigatórios, estes devem ser entregues dentro do prazo mínimo estabelecido pela modalidade licitatória.

No **pregão**, quando é declarado o vencedor, qualquer licitante pode manifestar imediatamente e motivadamente a intenção de recorrer. Caso não o faça no prazo incidirá a preclusão. Manifestando o interesse de recorrer será dado a ele o **prazo de 03 dias para apresentar as razões do seu recurso**, ficando desde já intimados os demais licitantes para apresentarem contrarrazões, também no prazo de 03 dias a partir do esgotamento do prazo do recorrente.

12. ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO

Quando se fala em anulação ou revogação, é preciso lembrar do **princípio da autotutela**. Esse princípio autoriza a Administração a anular ou a revogar os seus atos, seja por vício de legalidade ou por motivo de conveniência ou oportunidade.

A anulação é decorrente de um vício de legalidade, enquanto a revogação se dá por falta de conveniência e oportunidade.

A invalidação, como regra, não gera a obrigação de indenizar do Estado em favor do particular, salvo quando o contratado tiver executado obras, serviços, ou fornecido bens até a data da nulidade da licitação, devendo ainda comprovar eventuais prejuízos sofridos. Caso o licitante, agora contratado, não tenha sido o causador da nulidade terá direito à indenização.

No caso da revogação, como já visto, há um juízo de conveniência e oportunidade. A licitação poderá ser revogada **por razões de interesse público**. Tais razões **devem se dar por fato superveniente**. É necessário que este fato superveniente esteja comprovado, que se mostre pertinente e suficiente para justificar essa conduta. A ideia é **impedir a arbitrariedade** do Administrador / gestor público.

Assim pode-se revogar a licitação, mas somente por fato **superveniente**. Este fato deverá ser **pertinente**, ou seja, ter relação com o objeto licitatório, além de ser **suficiente** para justificar a medida tão gravosa como o é a revogação da licitação.

O particular **terá 05 dias úteis para recorrer** da decisão que revogou ou anulou a licitação. O recurso **não terá efeito suspensivo**.

13. LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE

O serviço de publicidade está submetido à lei de licitações. A Lei 12.232/10 traz as normas gerais para licitação e para contratação de serviços de publicidade, prestados por meio das agências de propaganda.

Nas contratações de serviços de publicidade, poderão ser incluídas não apenas o serviço de publicidade propriamente dito, mas também as atividades complementares, que também serão reguladas pela lei nº 12.232/10. Serão considerados como **atividade complementar aos serviços de publicidade**:

- Planejamento e execução de pesquisa, relacionada à atividade publicitária
- Produção e execução técnica de peça publicitária ou de projetos publicitários desenvolvidos
- Criação e o desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária

Todas essas atividades também se sujeitam à licitação.

É terminantemente **proibido incluir nas licitações de serviços de publicidade atividades não previstas pela Lei 12.232/10**, em especial:

- Assessoria de imprensa
- Comunicações e relações públicas



- Atividades que tenham por finalidade a realização de eventos festivos

O instrumento convocatório das licitações de publicidade irá possuir algumas exigências específicas.

- Esses procedimentos licitatórios adotarão obrigatoriamente o tipo melhor técnica ou melhor técnica e preço, já que se trata de serviço de publicidade.
- Os documentos de habilitação serão apresentados apenas pelos licitantes classificados no julgamento final da proposta.
- É possível a adjudicação do objeto de licitação a mais de uma agência de propaganda. Neste caso, haverá um procedimento de licitação interno entre as contratadas.

13. SISTEMA DE COTAÇÃO ELETRÔNICA

O sistema de cotação eletrônica tem por objetivo de ampliar a competitividade, racionalizando o procedimento para a aquisição de bens, especialmente os de pequeno valor, previstos no inciso II do art. 24 da Lei no 8.666/93, que podem ser adquiridos com dispensa de licitação.

O art. 4, § 2º do Decreto 5.450/05 prevê de que as contratações diretas promovidas pela Administração Federal sejam realizadas preferencialmente por meio de Cotação Eletrônica (na esfera federal, via o sistema Comprasnet). Cria-se uma infraestrutura informatizada, que permite uma melhor apuração do menor preço para as contratações de pequeno valor. O sistema visa permitir a transparência e a maior publicidade, reduzindo os riscos de fraude e ampliando a competição entre os interessados.

14. LICITAÇÕES PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

A Lei 11.488/07 estendeu para as **sociedades cooperativas**, que tenham auferido no calendário anterior receita bruta idêntica às empresas de pequeno porte, o **mesmo tratamento diferenciado das licitações dado pela LC 123/06 às microempresas e empresas de pequeno porte**.

Ressalte-se que se consideram:

- **Microempresas** aquela que teve o faturamento bruto anual de até R\$ 360 mil reais.
- **Empresas de pequeno porte** aquelas que tiveram receita bruta superior a R\$ 360 mil reais até R\$ 4.8 milhões de reais.

É possível classificar as disposições da LC 123/06 em relação ao tratamento diferenciado no ambiente das licitações públicas em 3 espécies:

- **Benefício nas licitações**

Existe a possibilidade de **regularidade fiscal postergada**. Ou seja, a regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte só serão exigidas **para a assinatura do contrato administrativo**.

Outro benefício é o chamado **desempate ficto**. Nas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte **sejam iguais ou até 10% superiores a melhor empresa** que não seja microempresa e empresa de pequeno porte, haverá o desempate ficto ao seu favor. Ressalte-se que sendo **modalidade pregão**, o percentual acima referido **cairá para 5%**. O art. 45 da LC 123 afirma que a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, dentre as empatadas em empate ficto, **poderá apresentar uma proposta pelo preço inferior à proposta que até o momento se mostrava vencedora**. A lei não permite uma nova proposta por aquela que outrora era a vencedora.

- **Benefício creditício**

A microempresa e a empresa de pequeno porte são titulares de direitos creditórios, decorrentes de empenhos que foram liquidados por órgão ou entidade da União, dos Estados,



DF e municípios que não foram pagos em até 30 dias, contados da liquidação desses empenhos, poderão exigir que estas entidades emitam uma **cédula de crédito microempresarial**, que é um título de crédito.

- **Licitações diferenciadas**

As licitações diferenciadas são as mais importantes. A Administração Pública poderá realizar um processo licitatório diferenciado quando se tratar de microempresa e empresa de pequeno porte.

Poderá haver **licitações exclusivas**, ou seja, certames realizados exclusivamente com a participação de microempresa e empresa de pequeno porte, **desde que o valor do certame seja de até R\$ 80 mil reais**. Irão participar apenas microempresa e empresa de pequeno porte.

Outra licitação diferenciada é a **subcontratação obrigatória**, podendo ser exigido dos licitantes a subcontratação de microempresa ou de empresa de pequeno porte nas licitações de serviços ou de obras.

Também é possível a chamada **cota reservada**, ou seja, é possível que se estabeleça uma cota de **até 25% do objeto para contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte** em certame que exija a aquisição de bens e serviços de natureza divisível.

Não havendo vencedor microempresa ou de empresa de pequeno porte, essa margem de 25% poderá ser adjudicada para o vencedor da licitação, ou ainda, em caso de recusa, para os licitantes remanescentes.

O art. 49 da LC 123 diz que **não se aplicam às licitações diferenciadas** quando:

- não existir ao menos 3 fornecedores competitivos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte sediados no local ou regionalmente, e se mostrem capazes de cumprir as exigências do edital;
- não for vantajosa para a administração pública;
- estiver diante de um caso em que a licitação é dispensável ou inexigível.

15. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES (RDC)

O Regime Diferenciado de Contratações(RDC), inaugurado pela Lei 12.462/11, vai apresentar diversas inovações para licitações e contratos. Ele é aplicável **exclusivamente** às licitações e contratos necessários à realização:

- **Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016**
- **Copa das Confederações** da Federação Internacional de Futebol Associação e **Copa do Mundo FIFA 2014**;
- **Obras de infraestrutura e de contratação de serviços para os aeroportos das capitais dos Estados da Federação distantes até 350 km das cidades sedes dos mundiais.**
- **Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)**;
- **Obras e serviços de engenharia do Sistema Único de Saúde – SUS**;
- **Obras e serviços de engenharia para construção, ampliação e reforma e administração de estabelecimentos penais e de unidades de atendimento socioeducativo**;
- **Segurança pública**;
- **Obras e serviços de engenharia, relacionadas a melhorias na mobilidade urbana ou ampliação de infraestrutura logística**
- **Locação de bens móveis e imóveis pela administração pública**, nos quais o locador realiza prévia aquisição, construção ou reforma substancial, com ou sem aparelhamento de bens, por si mesmo ou por terceiros, do bem especificado pela administração;
- **Ações em órgãos e entidades dedicados à ciência, à tecnologia e à inovação**;



O RDC **não é obrigatório**, mesmo para os projetos previstos na lei. A opção pelo RDC deverá constar no instrumento convocatório, implicando o afastamento das regras da Lei 8.666/93, que passarão a ser aplicadas somente subsidiariamente.

As modalidades licitatórias previstas na Lei 8.666/93, como não são citadas no RDC, não serão aplicadas. Isso porque **o próprio RDC é uma nova modalidade de licitação**, contendo regras e procedimentos próprios.

Em relação aos **contratos administrativos** formulados com base no RDC, **serão regidos pela Lei de Licitações**, mas irão observar regras específicas na Lei 12.462/11.

15.1. REGRAS APLICÁVEIS ÀS LICITAÇÕES DO RDC

15.1.1. CARÁTER SIGILOSO DO ORÇAMENTO

O orçamento só será tornado público ao final da licitação, pois possibilita à empresa a apresentar um valor menor. Este orçamento é informado aos órgãos de controle interno e externo. Somente o pessoal que participar da licitação é que não saberá.

Não é cabível o orçamento sigiloso quando estiver utilizando critério de:

- maior desconto
- melhor técnica ou
- conteúdo artístico

15.1.2. INOVAÇÕES PARA AQUISIÇÃO

No caso das licitações para aquisição de bens, o RDC expressamente prevê algumas inovações para aquisição, tais como:

- **Indicação de marca ou modelo**, quando:
 - houver a necessidade de padronização do objeto
 - a marca ou modelo for o único capaz de atender às necessidades da administração
 - marca ou modelo servirem como referência, caso em que indicará a marca X, ou outra semelhante ou de melhor qualidade
- **Exigência de amostra do bem** no procedimento de pré-qualificação, na fase de julgamento das propostas ou de lances;
- **Exigência de certificação da qualidade do produto ou do processo de fabricação**, inclusive sob o aspecto ambiental, por qualquer instituição oficial competente ou por entidade credenciada; e
- **Exigir carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor.**

15.1.3. REGIME DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA

O RDC permite um regime de contratação integrada. O RDC permite a utilização de alguns regimes, tais como:

- empreitada por preço unitário;
- empreitada por preço global;



- contratação por tarefa;
- empreitada integral; ou
- contratação integrada.

A contratação integrada compreende a elaboração e desenvolvimento de projeto básico e projeto executivo.

Elaborado o projeto, executa a obra e de serviços de engenharia, a montagem que se mostrar necessária, a realização de testes para verificar se está tudo certo, a pré-operação e as operações necessárias até a entrega final do objeto.

Na contratação integrada existe a proibição de aditivos contratuais para evitar a descaracterização da proposta inicial. Só poderá haver aditivos contratuais para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro e também se for necessária a alteração do projeto ou de suas especificações para uma melhor adequação técnica aos objetivos da contratação.

15.1.4. REMUNERAÇÃO VARIÁVEL

É possível a chamada remuneração variável, em sede de RDC.

Nas contratações de obras e serviços, é possível estabelecer uma remuneração variável, a qual vai depender do desempenho da empresa contratada.

Serão estabelecidas metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazo de entrega. A remuneração dependerá do cumprimento dessas regras.

Essa remuneração variável vai respeitar o limite orçamentário fixado pela administração para aquela obra ou serviço, mas a remuneração vai variar.

15.1.5. CONTRATAÇÕES SIMULTÂNEAS

É permitida a contratação de mais de uma empresa ou instituição para execução do mesmo serviço, quando esta ser possível ou se mostrar conveniente.

Esta contratação **só é permitida para serviços**, e não para obras ou serviços de engenharia.

15.2. FASES DO RDC

As fases do RDC são semelhantes às do pregão.

Poderá haver inversão de fase no RDC, mas terá o rito similar àquelas prevista no procedimento licitatório padrão, pois terá a habilitação antes do julgamento das propostas.

Os documentos de regularidade fiscal da empresa podem ser exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas. Ou seja, a habilitação se dá em momento posterior. Pode acontecer, no caso do RDC, essa exigência apenas em relação ao licitante mais bem classificado.

15.3. PUBLICIDADE NO RDC

A publicidade no RDC será realizada da seguinte forma.

Primeiro, é feita a **publicação do edital no Diário Oficial da União, do Estado, DF ou município**. Após, será divulgado no site oficial, divulgando o edital.

O regime diferenciado de contratação irá prever **prazos mínimos** entre a publicação do edital e a sessão em que serão julgadas as propostas:

- **Aquisição de bens:**



- **Prazo mínimo de 5 dias úteis:** o critério de menor preço ou maior desconto.
- **Prazo mínimo de 10 dias úteis:** não for o critério de menor preço ou de maior desconto.
- **Contratação de serviços e obras:**
 - **Prazo mínimo de 15 dias úteis:** critério for o menor preço ou maior desconto.
 - **Prazo mínimo de 30 dias úteis:** não for o critério de menor preço ou de maior desconto.
- **Prazo mínimo de 10 dias úteis:** critério maior oferta.
- **Prazo mínimo de 30 dias úteis:** critério em combinação de técnica e preço, melhor técnica, ou se for de conteúdo artístico.

15.4. MODOS DE DISPUTA

O RDC vai admitir alguns modos de disputa:

- **Modo de disputa aberto** os licitantes irão apresentar as suas ofertas mediante lances públicos e sucessivos, até alguém ser o vencedor.
- **Modo de disputa fechado** as propostas são entregues pelo licitante de forma sigilosa até a data e horário designado, situação na qual será divulgada.
- **Modo de disputa combinado** o instrumento convocatório estabelece que o procedimento será realizado em duas etapas, uma aberta em seguida de uma fechada, ou uma fechada seguida de uma aberta, sendo a primeira eliminatória.

15.5. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

O RDC estabelece alguns critérios de julgamento, sendo eles:

- **Menor preço e maior desconto:** nesse critério será considerado o menor dispêndio para a administração pública. No caso de maior desconto, quando a licitação envolver obras ou serviços de engenharia, o desconto pelo licitante deve incidir sobre toda a planilha de custos apresentada no orçamento estimativo pela administração. Quem dar o maior desconto leva a licitação.
- **Técnica e preço:** haverá ponderação no tocante às técnicas e no tocante ao preço. A lei permite que se atribua fatores de ponderação distintos para valorar a técnica e preço (ex.: 70% técnica e 30% preço).
- **Melhor técnica ou conteúdo artístico:** nesse caso, o critério utilizado para contratação de projetos, projetos arquitetônicos, natureza técnica, científica ou artística. O edital vai informar o pagamento que a administração vai fazer, podendo ser de um prêmio ou remuneração relacionada àquela contratação que a administração fará.
- **Maior oferta de preço:** nesse caso é quem paga mais. Isto será utilizado quando o contrato gerar uma receita para a administração, querendo ela receber o máximo possível.
- **Maior retorno econômico:** nesse critério, procura-se selecionar a proposta que proporcione a maior economia para a Administração Pública. Nesse critério, é celebrado um contrato de eficiência com o contratado. O contrato de eficiência envolve a prestação de um serviço, podendo incluir obras ou serviços de bens, mas essencialmente é um contrato de serviços. O objetivo é proporcionar uma redução das despesas correntes, que são aquelas em que a Administração tem todo mês. A remuneração do contratado se dará através de um percentual da economia gerada. Neste caso a licitação é de maior retorno econômico para o Poder Público.



15.6. CRITÉRIOS DE DESEMPATE

Havendo empate entre duas ou mais empresas no RDC, o **desempate será definido a partir da apresentação de uma nova proposta fechada** ato contínuo à classificação.

Outro desempate poderá ser a **avaliação de desempenho contratual prévio**. Para tanto, é necessário haver um sistema objetivo de avaliação já instituído.

O terceiro critério de desempate é o estabelecido nos arts. 3º da Lei 8.248/91 e da Lei 8.666/93.

15.7. RECURSOS

Via de regra, o RDC vai adotar uma **fase recursal única**, como o pregão adota, que se dará após a habilitação do vencedor.

Se houver a inversão das fases, o procedimento de habilitação irá anteceder à apresentação das propostas e julgamento delas, adotando uma fase recursal múltipla, de forma que os procedimentos serão muito similares aos da lei de licitação.

Quer sejam vários recursos admitidos, em razão da inversão da fase no RDC, ou quer seja por único recurso admitido, em virtude da obediência da regra do RDC, o prazo recursal é de 05 dias úteis.

15.8. REGRAS APLICÁVEIS AOS CONTRATOS DO RDC

A Lei 13.190/15 incluiu um dispositivo que admite expressamente o emprego de mecanismos privados de resolução de disputas, tais como arbitragem e mediação, para resolver conflitos do próprio RDC.

São regras dos contratos do RDC:

- **Convocação de licitante remanescente**

Quando o convocado (vencedor) não assinar o termo do contrato, não aceitar ou não retirar o instrumento no prazo definido pelo edital e naquelas condições, será necessário convocar o licitante remanescente na ordem de classificação. Será convocado para assinar o contrato nas condições do licitante vencedor. Se nenhum desses licitantes remanescentes aceitar a convocação nas condições do vencedor, a administração poderá convocá-los nas condições que os licitantes apresentaram, respeitando o limite orçamentário para a contratação.

Ex.: o vencedor disse que entregaria os bens por \$10 mil Reais, porém ocorreu uma mudança significativa no mercado e atualmente os mesmos produtos estão valendo \$140 mil Reais. O segundo licitante disse que entregaria mercadorias idênticas por \$160 mil. Pelo orçamento da Administração até \$200 mil seria possível contratar. Se nenhum outro licitante aceitar vender por \$100 mil, chamará o segundo lugar e será oferecido nas suas condições (\$160 mil).

- **Contratação de remanescente por dispensa**

Nesse caso, há dispensa para contratação de um remanescente de obras, serviços ou fornecimentos, chamando os licitantes remanescentes para que cumpram nas condições que eles ofertaram, desde que respeite o orçamento como limite de despesas.

- **Regra dos prazos contratuais**

O RDC indica duas regras para o prazo de seus contratos:

- **Obras:** os contratos para execução de obras, previstos no plano plurianual, estes contratos poderão ter o **prazo máximo de 04 anos**.
- **Serviços contínuos:** se a contratação do RDC se der para serviços contínuos, o contrato celebrado pelos entes públicos, responsáveis pelo objeto do RDC, **poderão ter sua vigência estabelecida por até 60 meses**.



15.9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento de normas do RDC e a inexecução do contrato podem levar a sanções administrativas.

As sanções administrativas são:

- Impedimento de licitar
- Impedimento de contratar com a administração pública por até 5 anos
- Multa
- Descredenciamento do sistema de cadastramento dos entes federativos

A aplicação dessas sanções poderá advir das seguintes **infrações**, o licitante que:

- **não celebrar o contrato dentro do prazo de validade da sua proposta;**
- **deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documento falso;**
- **retardar da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;**
- **não manter a proposta**, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente justificado;
- **fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato;**
- **comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;** ou
- **der causa à inexecução total ou parcial do contrato.**

16. LICITAÇÕES NA LEI Nº 13.303/16

A nova Lei das Estatais passou regular as licitações e contratos no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista nos seus arts. 28 a 84.

De acordo art. 28 da Lei nº 13.303/16, as contratações com terceiros, como regra, serão precedidas de licitação.

É importante ter em mente que o estatuto das estatais será aplicado independente da atividade desempenhada, ou seja, se prestadora de serviço ou exploradora de atividade econômica. Assim a Lei nº 8.666/93 não será mais aplicável às estatais, salvo nas hipóteses de lacuna e situações expressamente previstas na própria Lei 13.303/16, como defende Carvalho Filho⁸⁹.

Já o pregão poderá continuar sendo utilizado pelas estatais para a aquisição de bens e serviços comuns.

A Lei 13.303 visa dar flexibilidade para as estatais, permitindo que elas se aproximem mais das práticas adotadas pela iniciativa privada, mas sem abandonar a submissão necessária ao regime jurídico administrativo. São estabelecidas regras especiais no que se refere às licitações, facilitando a realização destas. Como visto as empresas governamentais não podem receber privilégios não extensíveis às empresas privadas, em razão do princípio da livre concorrência. Porém, a adoção de procedimentos licitatórios, embora indispensável, engessava as estatais e faziam com que essas perdessem a competitividade. O estatuto jurídico das empresas estatais se inspirou e reproduziu em parte o Regime Diferenciado de Contratações, que permite, por exemplo, contratações mais ágeis e simplificadas, processos menos morosos etc.

Por exemplo, a dispensa de licitação, que na lei 8.666/90 corresponde a 10% ou 20% do valor da carta convite, quando se tratar de uma empresa estatal, o valor é de R\$ 100.000,00 quando se tratar de obras e serviços e R\$ 50.000,00 quando se tratar de compras e serviços.

⁸⁹CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de direito administrativo** 32ª ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 551.



Ou seja, nessas hipóteses, em se tratando de uma obra de até R\$ 100.000,00 ou de bens e serviços de até R\$ 50.000,00, será dispensável a licitação, não sendo necessário à sua realização, podendo haver contratação direta (art. 29). O mesmo artigo apresenta outras hipóteses de licitação dispensada:

- quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes;
- para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento de suas finalidades precípuas, quando as necessidades de instalação e localização condicionarem a escolha do imóvel, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;
- na contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento, em consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições do contrato encerrado por rescisão ou distrato, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido;
- na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos;
- para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia;
- na contratação de associação de pessoas com deficiência física, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para a prestação de serviços ou fornecimento de mão de obra, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;
- na contratação de concessionário, permissionário ou autorizado para fornecimento ou suprimento de energia elétrica ou gás natural e de outras prestadoras de serviço público, segundo as normas da legislação específica, desde que o objeto do contrato tenha pertinência com o serviço público.
- nas contratações entre empresas públicas ou sociedades de economia mista e suas respectivas subsidiárias, para aquisição ou alienação de bens e prestação ou obtenção de serviços, desde que os preços sejam compatíveis com os praticados no mercado e que o objeto do contrato tenha relação com a atividade da contratada prevista em seu estatuto social;
- na contratação de coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda que tenham como ocupação econômica a coleta de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública;
- para o fornecimento de bens e serviços, produzidos ou prestados no País, que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional, mediante parecer de comissão especialmente designada pelo dirigente máximo da empresa pública ou da sociedade de economia mista;
- nas contratações visando ao cumprimento do disposto nos arts. 3º, 4º, 5º e 20 da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios gerais de contratação dela constantes;
- em situações de emergência, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contado da ocorrência da emergência, vedada a prorrogação dos respectivos contratos, observado o disposto no § 2º ;



- na transferência de bens a órgãos e entidades da administração pública, inclusive quando efetivada mediante permuta;
- na doação de bens móveis para fins e usos de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica relativamente à escolha de outra forma de alienação;
- na compra e venda de ações, de títulos de crédito e de dívida e de bens que produzam ou comercializem

17. TESES DO STJ

- 1) A Lei n. 8.666/1993, que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, não guarda pertinência com as questões envolvendo concursos para preenchimento de cargos públicos efetivos.
- 2) Ainda que o servidor esteja de licença à época do certame, não é possível a participação de empresa que possua no seu quadro de pessoal servidor público, efetivo ou ocupante de cargo em comissão/função gratificada, ou dirigente do órgão contratante ou responsável pela licitação.
- 3) A previsão indenizatória do art. 42, §2º, da Lei n. 8.987/1995 não se aplica às hipóteses de permissão, mas apenas aos casos de concessão de serviço público.
- 4) Não é devida indenização a permissionário de serviço público de transporte coletivo por prejuízos suportados em face de déficit nas tarifas quando ausente procedimento licitatório prévio.
- 5) Nos termos do §2º do art. 42 da Lei n. 8.987/1995, a administração deve promover certame licitatório para novas concessões de serviços públicos, não sendo razoável a prorrogação indefinida de contratos de caráter precário.
- 6) Extinto o contrato de concessão por decurso do prazo de vigência, cabe ao Poder Público a retomada imediata da prestação do serviço até a realização de nova licitação, independentemente de prévia indenização, assegurando a observância do princípio da continuidade do serviço público.
- 7) A contratação de advogados pela administração pública, mediante procedimento de inexigibilidade de licitação, deve ser devidamente justificada com a demonstração de que os serviços possuem natureza singular e com a indicação dos motivos pelos quais se entende que o profissional detém notória especialização.
- 8) A contratação direta, quando não caracterizada situação de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, gera lesão ao erário (dano *in rei psa*), na medida em que o Poder Público perde a oportunidade de contratar melhor proposta.
- 9) A alegação de nulidade contratual fundamentada na ausência de licitação não exime o dever de a administração pública pagar pelos serviços efetivamente prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração, quando comprovados, ressalvadas as hipóteses de má-fé ou de haver o contratado concorrido para a nulidade.
- 10) A superveniente homologação/adjudicação do objeto licitado não implica a perda do interesse processual na ação em que se alegam nulidades no procedimento licitatório.

18. JURISPRUDÊNCIA

18.1. INFORMATIVOS DO STF⁹⁰

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), empresa pública federal, pode ser contratada sem licitação, com fundamento no art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93, para a

⁹⁰CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:<<https://www.Buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia>>.

prestação de serviços de logística: Art. 24 (...) VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado; A ECT preenche todos os requisitos legais necessários à possibilidade de sua contratação direta, haja vista integrar a Administração e ter sido criada em data anterior à da Lei nº 8.666/93 para prestação de serviços postais, dentre os quais se incluem os serviços de logística integrada. STF. 2ª Turma. MS 34939/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/3/2019 (Info 934).

É inconstitucional lei estadual que exija Certidão negativa de Violação aos Direitos do Consumidor dos interessados em participar de licitações e em celebrar contratos com órgãos e entidades estaduais. Esta lei é inconstitucional porque compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratos (art. 22, XXVII, da CF/88). STF. Plenário. ADI 3.735/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 8/9/2016 (Info 838).

O Governo do Rio Grande do Sul editou uma lei estadual determinando que a administração pública do Estado, assim como os órgãos autônomos e empresas sob o controle do Estado utilizarão preferencialmente em seus sistemas e equipamentos de informática programas abertos, livres de restrições proprietárias quanto à sua cessão, alteração e distribuição (“softwares” livres). Determinado partido político ajuizou uma ADI contra essa lei afirmando que ela teria inconstitucionalidades materiais e formais. O STF julgou improcedente a ADI e afirmou que a lei é constitucional. A preferência pelo “software” livre, longe de afrontar os princípios constitucionais da impessoalidade, da eficiência e da economicidade, promove e prestigia esses postulados, além de viabilizar a autonomia tecnológica do País. Não houve violação à competência da União para legislar sobre licitações e contratos porque a competência da União para legislar sobre licitações e contratos fica restrita às normas gerais, podendo os Estados complementar as normas gerais federais. A referida lei também não viola o art. 61, II, “b”, da CF/88 porque a competência para legislar sobre “licitação” não é de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo, podendo ser apresentada por um parlamentar, como foi o caso dessa lei. STF. Plenário. ADI 3059/RS, rel. orig. Min. Ayres Britto, red. p/ o acórdão Min. Luiz Fux, julgado em 9/4/2015 (Info 780).

A União detém competência para legislar sobre as normas gerais de licitação, podendo os Estados e Municípios legislar sobre o tema para complementar as normas gerais e adaptá-las às suas realidades. Assim, lei municipal pode proibir que os agentes políticos do município (e seus parentes) mantenham contrato com o Poder Público municipal. STF. 2ª Turma. RE 423560/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 29/5/2012 (Info 668).

18.2. INFORMATIVOS DO STJ⁹¹

O credenciamento é uma hipótese de inexigibilidade de licitação na qual “a Administração aceita como colaborador todos aqueles que, atendendo as motivadas exigências públicas, manifestem interesse em firmar contrato ou acordo administrativo.” (TORRES, Ronny Charles Lopes de. Leis de Licitações Públicas comentadas. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 348). Desse modo, o credenciamento é um

⁹¹CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.Buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia>>.



procedimento por meio do qual a Administração Pública anuncia que precisa de pessoas para fornecer determinados bens ou para prestarem algum serviço e que irá contratar os que se enquadrem nas qualificações que ela exigir. Após esse chamamento público, os interessados podem se habilitar para serem contratados. Fala-se que é uma hipótese de inexigibilidade de licitação porque não haverá competição (disputa) entre os interessados. Todos os interessados que preencham os requisitos anunciados serão considerados “credenciados” e estarão aptos a serem contratos. O Banco do Brasil publicou edital para credenciamento de advogados para prestar serviços advocatícios. Ocorre que o edital de credenciamento publicado previu um critério de pontuação, de forma que os advogados e escritórios que se inscrevessem iriam ser avaliados e organizados segundo uma ordem de classificação baseada no currículo, experiência etc. O TCU e o STJ entendem que isso não é válido. O estabelecimento de critérios de classificação para a escolha de licitantes em credenciamento é ilegal. O credenciamento é considerado como uma espécie de inexigibilidade de licitação justamente pelo fato de não ser possível, em tese, a competição entre os interessados. Logo, a previsão de critérios de pontuação entre os interessados contraria a natureza do processo de credenciamento. Assim, no credenciamento só se admite a existência de requisitos mínimos. Se o interessado preencher, ele está credenciado; se não atender, encontra-se eliminado. Os critérios permitidos são, portanto, meramente eliminatórios (e não classificatórios). STJ. 1ª Turma. REsp 1747636-PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 03/12/2019 (Info 662).

Sociedade empresária em recuperação judicial pode participar de licitação, desde que demonstre, na fase de habilitação, a sua viabilidade econômica. STJ. 1ª Turma. AREsp 309867-ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 26/06/2018 (Info 631).

Se um servidor público for sócio ou funcionário de uma empresa, ela não poderá participar de licitações realizadas pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado este servidor público (art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93). O fato de o servidor estar licenciado do cargo não afasta a referida proibição, considerando que, mesmo de licença, ele não deixa possuir vínculo com a Administração Pública. Assim, o fato de o servidor estar licenciado não afasta o entendimento segundo o qual não pode participar de procedimento licitatório a empresa que possuir em seu quadro de pessoal servidor ou dirigente do órgão contratante ou responsável pela licitação. STJ. 2ª Turma. REsp 1.607.715-AL, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 7/3/2017 (Info 602).

O pregão é uma modalidade de licitação disciplinada pela Lei 10.520/2002. O art. 7º da Lei prevê que o licitante que for convocado dentro do prazo de validade de sua proposta e não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação, apresentar documentação falsa, retardar a execução do que contratado, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 5 anos. Esse prazo de 5 anos (ou menos) de punição começa a ser contado quando? Inicia-se com a publicação da decisão no Diário Oficial ou somente no dia em que é feito o registro negativo sobre a empresa no SICAF? Isso é importante porque a inserção dessa informação no SICAF pode demorar um tempo para acontecer. Qual é, portanto, o termo inicial da sanção? A data da publicação no Diário Oficial. O termo inicial para efeito de contagem e detração (abatimento) da penalidade prevista no art. 7º da Lei 10.520/2002, aplicada por órgão federal, coincide com a data em que foi publicada a decisão administrativa no Diário Oficial da União — e não com a



do registro no SICAF. STJ. 1ª Seção. MS 20784-DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. para acórdão Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 9/4/2014 (Info 561).

O edital da licitação poderá exigir que a empresa a ser contratada tenha, em seu acervo técnico, um profissional que já tenha conduzido serviço de engenharia similar àquele previsto para a licitação. Além disso, o edital também poderá exigir que a própria empresa já tenha atuado em serviço similar. STJ. 2ª Turma. RMS 39883-MT, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 17/12/2013 (Info 533).

Não deve ser reconhecida a nulidade em processo licitatório na hipótese em que, a despeito de recurso administrativo ter sido julgado por autoridade incompetente, tenha havido a posterior homologação de todo o certame pela autoridade competente. STJ. 2ª Turma. REsp 1348472-RS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 21/5/2013 (Info 524).

O art. 24, II da Lei nº 8.666/93 c/c o art. 1º, II, "a", do Decreto 9.412/2018 prevê que o administrador público não precisa fazer licitação se for para contratar compras ou serviços (que não sejam de engenharia) que não ultrapassem R\$ 17.600,00. Se a Administração Pública contrata uma empresa privada para organizar um concurso e esse contrato prevê que a empresa receberá R\$ 15.000,00 e mais o dinheiro arrecadado com as inscrições dos candidatos, esta situação não se enquadra no art. 24, II da Lei. Ainda que os valores recolhidos como taxa de inscrição não sejam públicos, a adequada destinação deles é de interesse público primário. Mesmo que a contratação direta de banca realizadora de concurso sem licitação não afete o interesse público secundário (direitos patrimoniais da Administração Pública), é contrária ao interesse público primário, pois a destinação de elevado montante de recursos à empresa privada ocorrerá sem o processo competitivo, violando, dessa maneira, o princípio da isonomia. STJ. 2ª Turma. REsp 1356260-SC, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 7/2/2013 (Info 516).

A Lei nº 8.666/93 prevê o seguinte: "Art. 7º (...) § 2º As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: III — houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;" Para que seja atendido o inciso III do § 2º do art. 7º da Lei de Licitações, não se exige a disponibilidade financeira, mas tão somente que haja previsão destes recursos na Lei Orçamentária. STJ. 2ª Turma. REsp 1141021-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 21/8/2012

QUESTÕES

1. (TJ-MS) FCC, 2020. A Lei das Estatais – Lei Federal nº 13.303/2016 – estabelece diversas hipóteses de dispensa de licitação aplicáveis às empresas públicas e sociedades de economia mista. Segundo o artigo 29 da lei, é dispensável a licitação:

A para obras e serviços de engenharia de valor até R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda a obras e serviços de mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente.

B para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo.

C na contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento, em consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e mantidas as condições da proposta do licitante a ser contratado, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido.



D na doação de bens móveis para fins e usos de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica relativamente à escolha de outra forma de alienação.

E na contratação de serviços técnicos especializados relativos a assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias, com profissionais ou empresas de notória especialização.

2. (TJ-MS) FCC, 2020. No tocante aos chamados “tipos de licitação”, dispõe a Lei Federal nº 8.666/1993 que

A quando a concorrência for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço", o prazo mínimo para recebimento das propostas será de 45 dias.

B é vedada a adoção dos tipos "melhor técnica" ou "técnica e preço" para licitações na modalidade convite.

C quando a tomada de preço for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço", o prazo mínimo para recebimento das propostas será de 20 dias.

D a adoção dos tipos "melhor técnica" ou "técnica e preço" para licitações na modalidade pregão é possível, porém limitada à fase de julgamento e classificação das propostas, não se aplicando à fase de lances.

E para contratação de bens e serviços de informática, a Administração Pública adotará obrigatoriamente o tipo de licitação "melhor técnica", permitido o emprego de outro tipo de licitação nos casos indicados em decreto do Poder Executivo.

3. (MPE-GO) MPE-GO, 2020. Conforme Lei n. 8.666/93, assinale a alternativa incorreta:

A A Administração Pública poderá nos editais de licitação para contratação de serviços, exigir da contratada que um percentual mínimo de sua mão de obra seja oriundo ou egresso do sistema prisional, com a finalidade de ressocialização do reeducando, na forma estabelecida em regulamento.

B Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência aos bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras de capital nacional e que invistam no desenvolvimento social do País.

C É dispensável a licitação para a construção, a ampliação, a reforma e o aprimoramento de estabelecimentos penais, desde que configurada situação de grave e iminente risco à segurança pública.

D É vedada a inexigibilidade de licitação para serviços de publicidade e divulgação.

4. (TJRJ) VUNESP, 2019. Os contratos com terceiros destinados à prestação de serviços às autarquias, agências executivas, empresas públicas e sociedades de economia mista, inclusive de engenharia e de publicidade, à aquisição e à locação de bens serão, em regra, precedidos de licitação. Excepcionalmente, a contratação poderá se dar de forma direta

A para serviços e compras em geral, de valor até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e para alienações, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizado de uma só vez.

B nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada a suas características peculiares, vinculada a oportunidades de negócio definidas e específicas, justificada a inviabilidade de procedimento competitivo.

C para serviços técnicos especializados, com profissionais ou empresas de notória especialização, inclusive para serviços de publicidade e divulgação ou aqueles prestados por intermédio de agência de propaganda.

D para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento de suas finalidades precípuas, quando as necessidades de instalação e localização condicionarem a escolha do imóvel, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia.

E nos casos de obras e serviços de engenharia de valor até R\$ 100.000,00 (cem mil reais), desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda a obras e serviços de mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente.

5. (TJPA) CESPE, 2019. Determinado órgão público deseja contratar uma associação de pessoas com deficiência física para o fornecimento de mão de obra. O valor da contratação é de R\$ 10 milhões, preço compatível com o praticado no mercado. A associação é de comprovada idoneidade e não tem fins lucrativos.

Nesse caso, de acordo com a Lei n.º 8.666/1993, a licitação é

A dispensável.

B inexigível.

C dispensada.

D deserta.

E obrigatória.

COMENTÁRIOS

1. Gabarito – D.

A) Incorreta. Cf. art. 29, I, Lei nº 13.383/16.

B) Incorreta. Cf. art. 30, I, Lei nº 13.303/16.

C) Incorreta. Cf. art. 29, VI, Lei nº 13.303/16.

D) Correta. Cf. art. 29, XVII, Lei nº 13.303/16.

E) Incorreta. Cf. art. 30 II, Lei nº 13.303/16.

2. Gabarito – A

A) Correta. Cf. art. 21, §2º, I, “b”, Lei nº 8.666/93.

B) Incorreta. Cf. art. 45, §1º, Lei 8.666/93.

C) Incorreta. Cf. art. 21, §2º, II, “b”, da Lei nº 8.666/93.

D) Incorreta. Cf. art. 4º, X, da Lei 10.520/02.

E) Incorreta. Cf. art. 45, §4º, da Lei 8.666/93.

3. Gabarito – B

A) Incorreta. Cf. art. 40, §5º, da Lei nº 8.666/93.

B) Correta. Cf. art. 3º, §2º, da Lei nº 8.666/93.

C) Incorreta. Cf. art. 24, XXXV, da Lei nº 8.666/93.

D) Incorreta. Cf. art. 25, II, da Lei nº 8.666/93.

4. Gabarito – D

A) Incorreta. Cf. art., 24, II, da Lei 8.666/93

B) Incorreta. Cf. art. 28, § 3º, II, da Lei 13.303/16.

C) Incorreta. Cf. art. 25, II, Lei 8.666/93 c/c art. 30, II, Lei 13.303/16.

D) Correta. Cf. art. 24, X, da Lei 8.666/93 c/c art. 29, V, da Lei 13.303/16.

E) Incorreta. Cf. art., 24, I, da Lei 8.666/1993

5. Gabarito – A

A) Correta. Cf. art. 24 XX Lei n.º 8.666/1993.

B) Incorreta. Cf. art. 25 Lei 8.666/1993

C) Incorreta. Cf. art. 17 Lei 8.666/1993

D) Incorreta. A licitação deserta não é uma modalidade de licitação, e sim a situação que ocorre quando, em um processo licitatório, não surgem interessados no dia da sessão de julgamento da proposta

E) Incorreta. Não se trata de obrigatoriedade de licitar, trata-se de uma das exceções da Lei nº 8.666/93.



CAPÍTULO 9 — CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

1. CONCEITO

Os contratos administrativos são aqueles que realizados pela Administração Pública. Esses se submetem a regras específicas, baseadas no regime jurídico administrativo, as quais geram prerrogativas e restrições para o Poder Público.

O ensinamento básico é a diferenciação com os contratos da administração, que são todos aqueles em que o Estado figura como parte, e os contratos administrativos, que são aqueles em que o Estado figura como parte, e portanto é uma espécie do gênero contratos da administração, mas que além disso, tem regime jurídico próprio – público.

2. ESPÉCIES

Maria João Estorninho⁹² é a autora portuguesa referencia no tema contratos públicos, e esclarece que os Contratos da Administração regem-se por três princípios característicos:

- Consensualismo
- Prossecução do interesse público
- Equilíbrio econômico financeiro

A Lei nº 8.666/1993 estabelece em seu artigo 6º, XIV e XV quais serão as partes contratantes e contratada. Nem todo o contrato firmado pelo Poder Público possui necessariamente prerrogativas. Os contratos em que o Estado figura como parte constituem um gênero, chamados pela doutrina de Contratos da Administração e englobam dois tipos:

- Contratos privados da Administração: há aqui uma relação de igualdade e equilíbrio entre as partes (Administração e particular), sema estipulação automática de cláusulas exorbitantes. Adotam o regime predominantemente privado, especialmente o direito civil e empresarial. Por exemplo quando na locação, compra de imóvel, abertura de conta bancária. NÃO há a incidência automática de cláusulas exorbitantes.
- Contratos administrativos: são os contratos administrativos *stricto sensu*, em que a Administração – esses são regidos pelo Direito Público, e a própria lei garante vantagens especiais para a Administração, as chamadas cláusulas exorbitantes. Por exemplo no caso dos contratos de concessão de serviços públicos e o uso dos bens públicos.

É importante ter em mente que todos os contratos celebrados pelo Poder Público se mostram submissos ao regime jurídico administrativo, em maior ou menor intensidade. Alguns pontos via de regra estarão presentes, tais como existência de condições e formalidades para estipulação e aprovação, necessidade de autorização para contratar, prévia licitação e possibilidade de controle pelos Tribunais de Contas.

O que diferencia os contratos privados da administração dos Contratos Administrativos, então, é a existência ou não de uma relação desigual entre as partes, com vantagens dadas pela lei ao Estado. Se a relação é equilibrada estaremos diante dos contratos privados da Administração, também chamados por Rafael Carvalho Rezende Oliveira⁹³ de contratos semi-públicos ou quase públicos. Estão exemplificados no Art. 62 § 3º I Lei 8.666/93. Aplica-se o regime jurídico administrativo de forma não preponderante, sendo

⁹² ESTORNINHO, Maria João. **Curso de Direito dos Contratos Públicos**: por uma contratação pública sustentável. Coimbra: Almedina, 2013.

⁹³ OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. **Curso de Direito Administrativo**. São Paulo: Gen Método, 2020.



regidos pelo direito privado. As cláusulas exorbitantes só serão permitidas se estiverem expressas no contrato, caso contrário não serão aplicadas.

Já os contratos administrativos *stricto sensu*, que a partir de agora serão denominados simplesmente de contratos administrativos nesse texto, são caracterizados por uma relação verticalizada, onde o Poder Público ocupa a posição privilegiada. Não há paralelo destes no direito privado, logo são regidos predominantemente pelo Direito Administrativo. São os contratos públicos por excelência, regidos pelo art. 54 da Lei nº 8.666/93.

Os contratos administrativos, em geral, apresentam algumas **características**. Resumiremos agora, e detalharemos os desdobramentos de alguns em seguida:

- Consensuais: se tornam perfeitos e acabados com a manifestação de vontade;
- Bilaterais: as obrigações são pré-definidas, não são contratos aleatórios e ambas as partes assumem obrigações;
- Comutativos: há equivalência de prestações, previamente conhecidas;
- Onerosos: as prestações são avaliáveis economicamente;
- Formais: assumem, via de regra, a forma escrita, e não basta o consenso de vontade, há requisitos que devem ser obedecidos (presentes no art. 60 Lei 8.666/93);
- Personalíssimos: as partes envolvidas na contratação são essenciais para o próprio contrato, cabendo sua execução ao próprio contratado. As partes não podem ser alteradas sem consentimento do Poder Público, existindo também limites à subcontratação;
- De adesão: o particular contratado não possui espaço para debater as cláusulas contratuais. A Administração Pública tem o monopólio da situação.

3. PRINCÍPIOS E CARACTERÍSTICAS

São características dos contratos administrativos:

3.1. FORMALISMO

Os contratos administrativos devem ser formalizados. Não basta o consenso de vontade, há requisitos que devem ser observados: por exemplo licitação prévia, forma escrita salvo pequenas compras de pronto pagamento (Art. 60 p. único, Lei 8.666/93), existência de cláusulas necessárias (art. 55) e prazo determinado (art. 57 § 3º Lei 8.666/93).

Também se exige o arquivamento dos contratos administrativos em ordem cronológica e o registro de seus extratos (art. 60 Lei 8.666/93), que os contratos devem mencionar “os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais” (art. 61 Lei 8.666/930 e a publicação na imprensa oficial dos contratos e seus aditamentos (art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93) etc.

O instrumento contratual, portanto, é obrigatório como regra. Mesmo nos casos de dispensa e de inexigibilidade de licitação, este instrumento contratual é obrigatório, quando esses preços estiverem compreendidos nessas modalidades de licitação de dispensa ou de inexigibilidade. Ou seja, nos casos de concorrência e tomada de preços, o instrumento contratual sempre será escrito.

Se estivermos diante de dispensa ou inexigibilidade, em cujo valor do contrato se insira no valor em que geralmente se exige concorrência ou tomada de preços, o instrumento contratual será obrigatório.

A exceção em que se admite o contrato verbal ocorre quando há **compras de pronto pagamento com valor não superior a 5% da modalidade convite** (regime de adiantamento).

Nos casos de compra de entrega imediata e integral dos bens adquiridos, esses instrumentos contratuais poderão ser substituídos por outros instrumentos, como a carta-contrato, nota de empenho de



despesas, autorização de compras, ordem de autorização de serviços, que são instrumentos mais simples. Nesses casos, há documentos mais simples, pois a entrega é imediata e integral dos bens adquiridos.

É importante destacar que em nome dos princípios da boa fé, da vedação enriquecimento sem causa e da confiança legítima o STJ vem entendendo que mesmo que o contrato verbal em compras de pronto pagamento ultrapasse um pouco o limite legal, o pagamento será feito, desde que os valores das mercadorias e serviços sejam compatíveis com o praticado no mercado (STJ, REsp 1111083 / GO). Exatamente por os aspectos formais poderem, atualmente, sofrer flexibilização parte da doutrina se refere a essa características como **formalismo moderado**⁹⁴.

3.2. BILATERALIDADE

Ninguém pode ser obrigado a contratar como Estado. Logo a manifestação de vontade de todas as partes contratantes é necessária. Assim são fixadas obrigações recíprocas. Há liberdade para manifestação de vontade do particular, ainda que reduzida (preço, reajuste.). Em alguns contratos administrativos específicos, como os de petróleo e gás, permitem uma maior negociação, como de prazos para a execução do objeto.

3.3. COMUTATIVIDADE

As obrigações devem ser equivalentes e previamente estabelecidas. Isto se traduz, especialmente, no fato que os termos da proposta vencedora na licitação devem ser mantidos até o final do contrato. A comutatividade se reflete especialmente na fixação das obrigações das partes e na necessidade de preservação do equilíbrio econômico financeiro, que será visto abaixo.

3.4. PUBLICIDADE

A publicação resumida do instrumento contratual é uma condição de eficácia do contrato. É indispensável para que o contrato tenha eficácia que ele seja publicado. A publicação na imprensa oficial não só dos contratos, mas também de seus aditamentos (art. 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93).

3.5. PERSONALÍSSIMO (*INTUITU PERSONAE*)

O contrato deve ser executado pelo escolhido na licitação, sob pena de violação aos princípios da impessoalidade e moralidade. Como a escolha na licitação deve ser respeitada, cabe a execução ao próprio contratado, não cabendo a sua substituição.

O caráter personalíssimo não é absoluto. A lei autoriza subcontratação parcial (se prevista no edital e no contrato administrativo), a cessão de posição e a mudança no controle acionário (art. 72 e 78, VI Lei nº 8.666/93).

3.6. MUTABILIDADE/INSTABILIDADE

Trata-se da possibilidade de alteração do contrato administrativo. O contrato administrativo também pode ser modificado, inclusive de forma unilateral pela Administração Pública.

Como o interesse público é mutável a Administração possui a prerrogativa de rescindir o contrato ou de alterar unilateralmente as cláusulas regulamentares (Art. 58 I e II Lei 8.666/93).

⁹⁴ OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. **Curso de Direito Administrativo**. São Paulo: Gen Método, 2020.



Dirley da Cunha Jr.⁹⁵ diz que a alteração do contrato poderá se dar por uma **álea administrativa**, ou seja, ato decorrente da Administração Pública (fato do príncipe ou fato da administração), ou por uma **álea econômica** (teoria da imprevisão). Ronny Charles e Fernando Baltar⁹⁶ vão dizer que deve ser acrescentado que é possível haver alteração de contrato em decorrência do **consenso entre as partes**, bem como outras áleas econômicas, como ocorre com o reajuste e com a repactuação.

3.7. DESEQUILÍBRIO

O regime jurídico dos contratos administrativos confere prerrogativas ao Poder Público. Há uma desigualdade entre as partes, onde a posição superior é da Administração Pública, em razão do princípio da supremacia do interesse público. O desequilíbrio e a instabilidade resguardam o interesse público que motivou a contratação e garantem que o serviço a ser prestado seja regular e contínuo, e por isso extrapolam o padrão comum dos contratos em geral.

O art. 58 da lei de licitações traz exemplos de cláusulas exorbitantes, também conhecidas como cláusulas de privilégio:

- Modificação unilateral do contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado;
- Rescisão unilateral do contrato
- Fiscalização da execução;
- Aplicação de sanções pela inexecução total ou parcial do ajuste;
- Ocupação provisória dos bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo, nos casos de serviços essenciais.

Com a edição da Lei 13.303/16 pacificou-se que os **contratos das empresas públicas e sociedades de economia mista** seguirão preceitos de direito privado (art. 68). Porém, estas também estão submetidas parcialmente pelo regime de direito público. Então alguns pontos deverão ser observados: necessidade de caução; proibição de contrato por tempo indeterminado e alterações contratuais somente por acordo entre as partes (art. 72 e art. 81).

4. VIGÊNCIA DOS CONTRATOS

O art. 57 da lei de licitações diz que, em regra, os contratos vão durar enquanto vigente o exercício financeiro (crédito orçamentário). Como o crédito orçamentário tem vigência de um ano o prazo de duração do contrato será de 01 ano.

São **exceções**:

- **Aquisição de projetos de produtos que estejam contemplados no plano plurianual (04 anos)**
- **Serviços contínuos (até 60 meses)**
- **Aluguel de equipamento para informática (até 48 meses)**
- **Algumas hipóteses de dispensa de licitação (até 120 meses)**

No caso de serviços contínuos, excepcionalmente e justificadamente, além desses 60 meses, é possível estender o prazo por mais 12 meses, no máximo.

A lei de licitação diz que é vedado o prazo de contratação indeterminado. Contudo, **tem-se entendido que a Administração pode ter vigência por prazo indeterminado, nos casos em que a**

⁹⁵ CUNHA Jr, Dirley. **Curso de Direito Administrativo 13ª ed.** Salvador: Juspodivum, 2019.

⁹⁶ TORRES, Ronny Charles Lopes e BALTAR NETO, Fernando Ferreira. **Sinopse para Concursos vol. 09 – Direito Administrativo 10ª.** Salvador: Juspodivum, 2020.

Administração seja usuária do serviço e o serviço seja prestado por um único fornecedor(Advocacia Geral da União, registrado em sua Orientação Normativa nº 36; Parecer SEORI/AUDIN-MPU Nº 332/2017). Ex.: casos de águas e esgotos.

Atente-se que tais contratos não se confundem com os denominados **contratos de escopo**. Contratos de escopo são contratos que possuem uma finalidade de realização do objeto. **Este contrato vai se extinguir com a realização do objeto**, com a entrega da obra, e não com a vigência do prazo. Ex.: o contrato para um serviço de obra irá se concluir com o término da obra, ainda que haja vigência o contrato.

5. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

A prorrogação contratual consiste na prolongação do prazo contratual com o mesmo contratado e nas mesmas condições (Art. 57 Lei nº 8.666/93). Só é possível prorrogar contratos ainda em andamento. Um contrato já extinto jamais poderá ser prorrogado.

Essa prorrogação é feita através de um **termo aditivo**, termo esse firmado entre as partes.

Para fins didáticos, Ronny Chales e Fernando Baltar⁹⁷ sugerem que essas prorrogações sejam divididas em duas espécies:

- **Renovação:** há prolongamento de um contrato de serviços contínuos. Ex.: serviço contínuo de vigilância de 12 meses. Este contrato pode ser renovado por mais 12 meses, continuando o pagamento. Trata-se de uma renovação contratual.
- **Prorrogação em sentido estrito:** a lei autoriza que os prazos e início da etapa de execução, de conclusão ou de entrega sejam alterados, ou seja, há prorrogação dos prazos, não necessariamente haverá uma repercussão econômica. Ex.: por conta de um fato excepcional, prorroga-se o prazo por mais 90 dias. neste caso, há uma prorrogação, não sendo necessariamente obrigatório a pagar algo a mais.

6. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Os contratos administrativos podem ser alterados bilateralmente ou, como cláusula exorbitante, unilateralmente.

6.1. ALTERAÇÕES BILATERAIS

Ocorrem quando a Administração e o particular concordam em alterar o contrato. NÃO configura cláusula exorbitante. Por exemplo:

- Substituição da garantia do contrato
- Necessidade de modificação do regime de execução da obra e serviço, ou modo de fornecimento, em razão de verificação técnica da inaplicabilidade do termo original
- Necessidade de modificação da forma de pagamento
- Alteração do equilíbrio econômico-financeiro do contrato

⁹⁷ TORRES, Ronny Charles Lopes e BALTAR NETO, Fernando Ferreira. **Sinopse para Concursos vol. 09 – Direito Administrativo** 10ª. Salvador: Juspodivum, 2020.



6.2. ALTERAÇÕES UNILATERAIS

Dentre as prerrogativas da Administração, denominadas cláusulas exorbitantes, encontra-se a possibilidade de modificação unilateral dos contratos, as quais serão admitidas em algumas situações. O Estado pode impor sua vontade ao particular e unilateralmente alterar algumas disposições contratuais para atender ao interesse público, dentro de limites legais. A alteração só pode ser do objeto e cláusulas regulamentares (modo de execução do contrato). Não se pode alterar as cláusulas econômico financeiras (relação entre remuneração e encargos do contratado) sob pena de enriquecimento ilícito da Administração (art. 58 § 1º e 2º Lei nº 8.666/93).

Será admitida a alteração contratual unilateral para:

- **Alterações qualitativas:** modificação do projeto ou das especificações, são as alterações para aprimorar a técnica que será utilizada;
- **Alterações quantitativas:** relacionadas à diminuição ou aumento do seu objeto, desde que respeitados os limites legais. São as modificações do valor contratual em decorrência de acréscimo ou de uma diminuição do seu objeto.

O art. 65 Lei nº 8.666/93 coloca os requisitos limites para a alteração dos contratos, **ainda que essa alteração se dê por acordo entre as partes.**

Requisitos:

- Necessidade de alteração por interesse público;
- Não pode prejudicar os direitos do contratado;
- Não pode modificar o objeto do contrato;
- Devida motivação, pautada sempre no melhor atingimento do interesse público;
- Respeito aos limites legais impostos à uma alteração contratual e;
- Necessidade de manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato.

Limites:

- Em regra, poderá **suprimir ou acrescentar até 25% do objeto** inicialmente contratado.
- Se for serviços de obra ou reforma de edifício ou de equipamento, **esse acréscimo poderá ser de até 50%** do quantitativo originariamente fixado.

O contratado **fica obrigado a aceitar**, nas mesmas condições anteriormente fixado, os acréscimos ou supressões do serviço. Art. 58§ 1º da Lei nº 8.666/93 determina que as cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado.

7. ADITIVO E APOSTILA

As alterações contratuais, em regra, exigirão a formalização de um aditivo.

A lei 8.666 permite a utilização da **apostila** em algumas situações, nas situações em que seria desnecessária o termo aditivo.

A apostila é a anotação ou registro administrativo que é realizado no contrato, podendo ser realizado na última página do contrato ou da juntada de um termo ao contrato.

Poderá se valer da apostila quando:

- Variação do valor contratual for decorrente de um reajuste já previsto no contrato
- Compensações ou penalizações financeiras, compensando um débito com uma multa imposta
- Empenho de dotações orçamentárias suplementares até o valor corrigido.



8. EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO CONTRATO

A ideia é proteger a equação econômica do contrato, visando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro; a manutenção pode ser proposta pelo particular quanto pela Administração. Seu fundamento legal está no art. 37, XXI CRFB (“mantidas as condições efetivas da proposta”). A equação será sempre calculada a partir da data da proposta, e não da assinatura do contrato.

É o equilíbrio entre encargos e vantagens assumidas pelas partes do contrato. Uma vez que estes foram estabelecidos na contratação, devem ser preservadas ao longo da execução. Engloba todos os aspectos econômicos relevantes para a execução: não só o montante de dinheiro devido ao particular, mas também prazo para pagamento, periodicidade, abrangência do contrato e qualquer outra vantagem.

Celso Antônio Bandeira de Mello⁹⁸ explica que:

Equilíbrio econômico-financeiro (ou equação econômico-financeira) é a **relação de igualdade** formada, de um lado, pelas **obrigações assumidas pelo contratante** no momento do ajuste e, de outro, pela **compensação econômica** que lhe corresponderá. A equação econômico-financeira é **intangível**.

São dois os institutos que asseguram a revisão econômica do contrato:

- **Reajuste:** decorre de um risco ordinário (álea ordinária)
- **Reequilíbrio econômico-financeiro:** decorre de algo extraordinário (álea extraordinária)

O art. 55, III da Lei nº 8.666/93 expõe os pagamentos devidos ao particular contratado: o preço expressamente previsto e as formas de atualização (correção monetária, reajustamento de preços e recomposição de preços).

8.1. CORREÇÃO MONETÁRIA

É a atualização da margem de lucro inicialmente acordada, a manutenção do valor real do contrato. Não há acréscimo ou ganho, só atualização em decorrência da desvalorização da moeda / inflação (Art. 40 XIV “c” da Lei nº 8.666/93).

8.2. REAJUSTE

O reajuste é um instrumento para recomposição econômica ordinária, estando relacionada com um evento futuro desfavorável, mas previsível e suportável, sendo usual para determinado negócio, as chamadas áleas ordinárias.

Trata-se do aumento ordinário e regular do custo dos insumos necessários para o cumprimento do contrato, logo são variações previsíveis e esperadas. Como há alteração no custo, logo aumenta-se automaticamente o valor do pagamento (Art. 40, XI Lei nº 8.666/93).

Não é igual à correção monetária. Na correção monetária não há alteração de valor, no reajuste há alteração do custo da prestação do serviço pactuado. Logo aumenta o pagamento para que a margem de lucro do particular fique igual.

O edital da licitação já prevê o critério de reajuste, tal como o IPCA/FGV, ou índices de preços específicos para insumos hospitalares, material de construção etc.

⁹⁸ BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo, 22ª ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 619-620



O reajuste deve ser previsto em contratos **com prazo igual ou superior a um ano**. Pode ter prazo superior ao ano, mas a periodicidade deverá ser anual, a fim de garantir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

8.3. RECOMPOSIÇÃO / REVISÃO DE PREÇOS

Em razão de alguma situação ou de algum fato, houve o desequilíbrio econômico-financeiro. Aqui está se tratando de eventos imprevisíveis ou fatos extraordinários, ou ainda eventos previsíveis, mas de consequências imprevisíveis, que vão retardar ou impedir a execução daquilo que foi originalmente ajustado. Ou seja, aqui a previsão de reajuste foi insuficiente.

Podem ser alterações no contrato em relação ao valor ou ao regime de execução da obra / serviço ou situações inesperadas que levam ao desequilíbrio contratual

Há o desequilíbrio contratual e a necessidade da revisão do mesmo (Art. 65 II “d” Lei nº 8.666/93). A recomposição ocorre quando se fizer necessária, sempre que ocorrerem situações inesperadas tais como caso fortuito, força maior, fato da administração ou fato do príncipe. Não segue, assim, o critério anual.

No momento da elaboração do contrato faz-se a matriz de risco matriz de riscos associados ao empreendimento, que estabelece quais os riscos serão suportados pela Administração e quais serão encargos do particular contratado, esclarecendo quais levarão à recomposição.

A questão se relaciona com a teoria da imprevisão, que será abordada abaixo.

9. TEORIA DA IMPREVISÃO

A Teoria da Imprevisão se baseia na chamada cláusula *rebus sic stantibus* (“enquanto as coisas estão assim”), implícita em todos os contratos de prestação sucessiva. Segundo ela o contrato deve ser cumprido desde que presentes as condições de quando foi pactuado. Caso elas se alterem substancialmente rompe-se o equilíbrio contratual: se é possível reestabelecer a equação financeira inicial se recompõe / revisa; caso não seja possível o contrato será rescindido (Art. 78 XVII c/c art. 65, II “d” Lei nº 8.666/93).

A teoria da imprevisão não se aplica na ocorrência de simples elevação suportável de preço. Isso é risco do contrato / risco empresarial. Por exemplo, não enseja a aplicação da teoria da imprevisão: o aumento do piso salarial da categoria, em dissídio coletivo (STJ, AgRg no REsp nº 417.989/PR), a majoração da folha de pagamento por acordo / convenção coletiva, já que esta é previsível), a concessão de benefício de participação nos lucros ou resultados (uma vez que essa é uma negociação entre particular e seus empregados e não envolve a Administração Pública. A Teoria da Imprevisão pode se manifestar em razão de:

- Fato do príncipe
- Fato da Administração
- Caso fortuito e força maior
- Interferências imprevistas

9.1. FATO DO PRÍNCIPE

São atos gerais do Estado que afetam indiretamente o contrato. A atuação do Poder Público é geral e abstrata, e atinge indiretamente a relação contratual. Por exemplo, a recente proibição do amianto em contratos de construção civil, que exige a troca de insumos; o aumento exorbitante de carga tributária, tal como ICMS-Combustível e contrato de transporte público (art. 65§5º Lei nº 8.666/93).

O Poder Público aqui não age como parte contratual (estado administrador) e sim como Estado Império (com uso da supremacia). Para a doutrina majoritária, representada por Di Pietro para configurar fato do príncipe é necessário que o agente que praticou a conduta seja da mesma esfera do ente federativo que celebrou o contrato atingido. Se for ente federativo diverso será caso fortuito.

9.2. FATO DA ADMINISTRAÇÃO

São atos ou omissões da Administração que incidem diretamente sobre o contrato e impedem sua execução (Art. 78 XIII a da Lei nº 8.666/93) Podem levar a revisão ou a rescisão do contrato. Por exemplo, a não concessão da licença ambiental ou a demora na desapropriação do terreno necessário para a obra.

9.3. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR

São os eventos imprevisíveis ou inevitáveis que impedem ou oneram a execução do contrato. Além da rescisão ou revisão do contrato, podem gerar indenização ao particular contratado pelos prejuízos decorrentes (art. 79 § 2º Lei nº 8.666/93). Por exemplo um fato imprevisível da natureza que atrasa ou torna mais custosa a prestação contratual, como um tsunami, um deslizamento ou uma pandemia.

9.4. INTERFERÊNCIAS IMPREVISÍVEIS

São fatos imprevisíveis, preexistentes, que oneram mas não impedem a execução do contrato. Já existiam no momento que o contrato foi assinado, mas só foram reveladas durante a sua execução. Por exemplo, o solo ser diferente do previsto, o que aumenta o curso de perfuração, terraplanagem.

Também se admite caso haja um amento, terremoto, etc., o qual tornará mais onerosa a prestação.

10. EXECUÇÃO DO CONTRATO

10.1. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Trata-se de um poder-dever. A Administração deve designar representantes especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato. Esse representante é o fiscal do contrato, que fará o registro necessário das falhas e defeitos (Art. 58 II c/c art. 67 da Lei nº 8.666/93).

É possível que o Poder Público contrate a empresa que realizou o projeto básico ou executivo da obra para que exerça o trabalho de fiscalização, de supervisão, de gerenciamento daquele empreendimento, pois detém maior domínio de um servidor público.

A fiscalização não exclui nem atenua a responsabilidade do contratado por danos causados à administração ou a terceiros (art. 70 Lei 8.666/93).

A Lei de Licitações, no art. 71, diz que o contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato.

Uma questão importante sobre **terceirização** foi decidida pelo STF em 2019, no RE 760.931/DF: o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do particular contratado pelo Estado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). No caso de terceirização de mão de obra o STF, na ADC 16, declarou constitucional o art. 71 § 1º da lei 8666/93, excluindo a responsabilidade subsidiária do Estado pelos débitos trabalhistas das empresas quando há terceirização. Para o STF o Estado só pode ser condenado subsidiariamente em caso de demonstração de ausência de fiscalização. E será ônus do empregado do particular contratado provar a falha de fiscalização. Não se pode atribuir o encargo à administração pública por mera presunção de culpa da administração. É necessário demonstrar cabalmente o nexo causal entre a conduta do agente público e o prejuízo experimentado pelo trabalhador. Se não comprovar, não haverá responsabilidade da administração.



A administração irá responder solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários resultantes do contrato, por força do art. 72 § 2º da Lei nº 8.666/93.

Quanto a **subcontratação** contratado, sem prejuízo de suas responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar parte da obra ou parte do serviço, mas até o limite admitido pela Administração. A possibilidade de subcontratação e os seus limites **devem estar previstas no edital**. Se o edital for silente, não é possível subcontratar.

O contrato pode prever **recebimento provisório e recebimento definitivo**. O recebimento provisório é feito pelo fiscal do contrato. O recebimento definitivo é feito pelo servidor ou comissão designada pela autoridade competente. Há aqui uma análise e detalhamento da prestação contratual, passando a receber o objeto do contrato. Recebido o objeto do contrato, não se esvai a responsabilidade civil pela execução do contrato.

É possível em algumas situações dispensar o recebimento provisório, e, nesses casos, haverá somente o recebimento definitivo:

- Tiver diante de gêneros perecíveis
- Serviços de obras ou produtos cujo valor vai até o valor limite para a modalidade convite, desde que não se componham de aparelho, equipamentos e instalações sujeitos a testes de funcionamento e produtividade.

11. MEDIAÇÃO E AUTOCOMPOSIÇÃO DE CONFLITOS, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Essa é uma tendência trazida pelo atual CPC, que trouxe conceitos de conciliador e mediador:

- **Conciliador:** é quem conduz, atuando preferencialmente nos casos em que não há vínculo anterior entre as partes, sugerindo soluções.
- **Mediador:** atua preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, de modo que os interessados possam, por si próprios, obter uma solução consensual.

Na arbitragem não há autocomposição, mas as partes interessadas vão submeter a questão ao juízo arbitral, e isto se dá por meio da convenção de arbitragem.

Dentro da convenção poderá haver:

- **Cláusula compromissória:** há uma previsão no contrato de que se houver um conflito, será este submetido a um árbitro ou tribunal arbitral. A cláusula é anterior ao problema existir.
- **Compromisso arbitral:** o litígio já existe, devendo ser ele submetido ao árbitro. O compromisso é posterior ao problema existir.

A arbitragem poderá ser de **direito** ou de **equidade**, pois as partes poderão existir. Todavia, **quando estiver em um dos polos a administração pública, necessariamente a arbitragem será de direito**, por conta do princípio da legalidade.

Os entes federativos podem criar Câmara de Prevenção e Resolução de Conflitos na seara administrativa, no âmbito dos respectivos órgãos da advocacia pública.

A **competência dessa Câmara de Prevenção e Resolução de Conflitos** na seara administrativa será para:

- Dirimir conflitos nos órgãos da própria administração pública
- Avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos por meio da composição, nos casos controvérsia entre particular e pessoa jurídica de direito público
- Promover a celebração de um termo de ajustamento de conduta (TAC)



A **instauração do procedimento administrativo para resolução do conflito**, de forma consensual, cujo objetivo é encontrar a solução consensual do conflito atualmente existente, **gera a suspensão da prescrição**.

Se houver consenso entre as partes, o acordo será reduzido a termo, constituindo **título executivo extrajudicial**.

A Lei da Arbitragem (Lei 9.307/96) foi alterada pela Lei 13.129/15, e passou a dispor que:

Art. 1º As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis.

§ 1º A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis.

§ 2º A autoridade ou o órgão competente da administração pública direta para a celebração de convenção de arbitragem é a mesma para a realização de acordos ou transações.

§ 3º A arbitragem que envolva a administração pública será sempre de direito e respeitará o princípio da publicidade.

12. INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DOS CONTRATOS

A inexecução do contrato pode ser total ou parcial, podendo ensejar a sua rescisão. A rescisão contratual poderá ser amigável, unilateral ou ainda judicial. O art. 78 da Lei de Licitações elenca situações em que constituem **motivos para rescisão** do contrato:

- não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- lentidão na execução do contrato, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
- atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
- paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
- subcontratação total ou parcial do seu objeto não admitidas no edital e no contrato;
- desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
- cometimento reiterado de faltas na sua execução;
- decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
- alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;
- razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento;
- supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além dos limites fixados em lei;
- suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
- atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado



o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

- não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;
- ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

12.1. RESCISÃO UNILATERAL

A **rescisão unilateral** só poderá ser proposta pelo Estado, por interesse público superveniente à contratação ou por descumprimento de cláusula contratual por parte do particular (art. 77 Lei nº 8.666). Nesse caso a extinção será antes do prazo estipulado. São algumas hipóteses que podem levar à rescisão unilateral:

- descumprimento de cláusulas contratuais;
- atraso ou paralisação da obra;
- a subcontratação ou cessão do objeto contratual não admitidas no edital e no contrato;
- alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;
- razões de interesse público (motivação e publicidade).

A **rescisão unilateral** poderá trazer algumas **consequências**:

- **assunção imediata do objeto do contrato**, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração;
- **ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade**;
- **execução da garantia contratual**, para ressarcimento da Administração, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos;
- **retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos** causados à Administração.

A assunção do objeto é fundada no princípio da continuidade. Portanto, a rescisão implicará assunção de objeto pela administração, podendo ocupar o bem.

No caso de rescisão do contrato administrativo por ato unilateral da Administração Pública, sob justificativa de interesse público, impõe ao Estado a obrigação de indenizar o particular pelos prejuízos daí decorrentes, como tais considerados não apenas os danos emergentes, mas **também os lucros cessantes** (STJ – REsp 1240057/AC). A Administração deve indenizar o particular se houver dano, bem como indenizar os investimentos não amortizados do contratado. O particular tem direito de devolução da garantia prestada, os pagamentos devidos pela execução do contrato e o pagamento pelo custo da desmobilização (art. 79 § 2 Lei nº 8.666/93).

12.2. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS EM FACE DA ADMINISTRAÇÃO

A *exceptio non adimpleti contractus*, também chamada de exceção de contrato não cumprido, está estabelecida no art. 78, XV da Lei nº 8.666/93.

Segundo este dispositivo, o atraso **superior a 90 dias** dos pagamentos devidos pela administração, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, permite ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que receba o que ele tem de direito.



A doutrina clássica defendia que a exceção do contrato não cumprido jamais poderia ser invocada pelo particular nos contatos administrativos, seria uma cláusula exorbitante baseada no princípio da continuidade dos serviços públicos. Já a doutrina moderna justifica que a sua **aplicação mitigada**: no caso de atraso superior a noventa dias o particular pode optar entre (a) pedir rescisão contratual ou (b) suspender a execução do contrato prestação dos serviços até que seja normalizado o pagamento (necessidade de notificação prévia).

O STJ consagra o entendimento no sentido de que a regra de não-aplicação da *exceptio non adimpleti contractus*, em sede de contrato administrativo, não é absoluta (AgRg no REsp 326.871/PR e RMS 15.154/PE). O mesmo STJ entende que não precisam necessariamente pleitear judicialmente a suspensão do contrato, por inadimplemento da Administração Pública. Isso porque "condicionar a suspensão da execução do contrato ao provimento judicial, é fazer da lei letra morta" (REsp 879.046/DF e REsp 910.802/RJ)

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Sanções administrativas são punições impostas pela Administração, em razão da inexecução total ou parcial do contrato, a administração pode aplicar ao contratado algumas sanções, tais como (Art. 87 Lei nº 8.666/93):

- **advertência**
- **multa**
- **suspensão temporária e impedimento de contratar com a Administração por até 02 anos**
- **declaração de inidoneidade**

A decisão discricionária e fundamentada e deverá obedecer ao Princípio da Proporcionalidade e garantir o contraditório e a ampla defesa.

Advertência será aplicada por escrito, para infrações leves.

A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as outras sanções. Seu valor deve estar previsto no contrato. Pode ser descontada da garantia ou, se for maior, a Administração cobrará a diferença dos próximos pagamentos devidos ao particular ou ainda judicialmente.

A suspensão temporária vai atingir o direito de participar de licitação ou de contratar com a administração pública pelo prazo de até 02 anos.

O entendimento do STJ é de que **há incidência geral dessa suspensão**, ficando suspenso de contratar com os demais órgãos da administração pública, e não restrito ao órgão aplicador da pena (Resp 151.167/2003).

Na declaração de inidoneidade, o ente federado não poderá licitar ou contratar com a Administração Pública **enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição** ou **até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade**.

Essa reabilitação poderá ser concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada.

A declaração de inidoneidade é aplicada pelo ministro de Estado, secretário de estado ou secretário distrital ou municipal.

O STJ já aplicou a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, a fim de estender os efeitos da declaração de inidoneidade a uma sociedade empresarial diversa, que foi constituída com o objetivo de burlar a aplicação dessa sanção administrativa.

Tanto a suspensão temporária quanto a declaração de inidoneidade duas penalidades só fazem efeitos para o futuro, sem alcançar contratos já firmados e em andamento (STJ, MS 13.101 / MS 14.002)

14. SANÇÕES PREVISTAS NA LEI DO PREGÃO



A Lei do Pregão criou uma nova espécie de sanção que é o **impedimento de licitar e de contratar com a União, Estados, DF e municípios**.

Além desse impedimento de licitar ou contratar, a lei prevê o **descredenciamento dessa empresa dos sistemas de cadastramento de fornecedor pelo prazo de até 5 anos**, sem prejuízos de multas e demais cominações legais.

15. GARANTIAS

A possibilidade de exigência de garantias está prevista no art. 55 VI c/c art. 56da Lei nº 8.666/93. Trata-se de um poder-dever: visando a execução do contrato e o pagamento das possíveis multas o Estado pode exigir uma garantia correspondente a 5% a 10% do valor do contrato. O percentual será calculado em razão da complexidade técnica, do vulto e dos riscos financeiros para a Administração. Exigir ou a garantia é ato discricionário da Administração. Mas é o particular que escolhe qual desses tipos irá fornecer:

- Caução em dinheiro
- Caução em títulos da dívida pública
- Fiança bancária
- Seguro-garantia

Após o término do contrato a garantia será devolvida corrigida monetariamente.

Atenção: a Garantia Contratual é diferente da Garantia da Proposta. A segunda é prestada pelo licitante como garantia de participar da licitação, no valor de no máximo 1% do valor da proposta (art. 31 III Lei nº 8.666/93).

16. OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA OU RETOMADA DO OBJETO CONTRATUAL

Via de regra ocorre enquanto a Administração decide se irá ou não rescindir o contrato, para permitir a continuidade do serviço público. Pode se usada como medida cautelar (enquanto se apuram as faltas), ou após a rescisão do contrato (para possibilitar a continuidade do serviço, enquanto realiza uma nova licitação).

Seu objetivo sempre será assegurar a continuidade do serviço público, embora sua aplicação não esteja limitada aos contratos que tratam desse tema. O Estado pode ocupar temporariamente móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato.

17. CONVÊNIOS

O convênio, em sentido amplo, é um acordo ajustado entre pessoas administrativas entre si, ou entre pessoas e particulares entre si, em que não haja o interesse de lucro, ou econômico, mas tem por objetivo a realização de um fim com interesse público.

Há nos convênios a ideia de **cooperação**, quer seja entre entidades da administração pública ou entre particulares e entidades da administração pública.

Em regra, não é necessária licitação para realizar convênio, visto que não tem interesse lucrativo.

17.1. CONVÊNIO EM SENTIDO ESTRITO

É um acordo que disciplina a transferência de recursos financeiros e tenha como partícipe o órgão ou entidade da administração federal e do outro órgão ou entidade da administração estadual, distrital ou municipal, ou entidades privadas sem fins lucrativos, cujo objetivo é a execução de programas de governo em regime de mútua cooperação. Aqui **há repasse de verbas**.



17.2. TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA

É um instrumento através do qual fica ajustada a transferência de crédito de órgão da administração pública direta ou indireta federal para outro órgão ou entidade federal da mesma natureza. Por isso é de execução descentralizada, passando a execução para outro órgão ou entidade.

17.3. CONTRATO DE REPASSE

É um contrato por meio do qual há transferência de recursos financeiros que irá se processar por intermédio de uma instituição ou um agente financeiro público federal.

18. CONSÓRCIOS PÚBLICOS

Consórcio público é pessoa jurídica formada por entes da federação, podendo ser constituída por associação pública, com personalidade jurídica de direito público e com natureza de autarquia, mas também pode ser constituída como pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos.

O consórcio público integra a administração pública indireta dos entes consorciados.

19. JURISPRUDÊNCIA

19.1. INFORMATIVOS DO STF⁹⁹

O art. 175, I, da CF prevê que a lei disporá sobre as condições para a prorrogação dos contratos de concessão. (...) o inciso XII do art. 23 da Lei 8.987/1995 estabelece que as condições para a prorrogação devem ser disciplinadas no contrato de concessão, configurando-se como cláusula essencial, marcada pela discricionariedade da Administração Pública e na supremacia do interesse público. (...) A norma dispõe sobre a contratação de termo predefinido, firmado a partir de licitação, cabendo à Administração avaliar, excepcionalmente, com base nos parâmetros legais de atendimento ao interesse público, a conveniência e a oportunidade da prorrogação. (...) A prorrogação indefinida do contrato, porém, configura burla às determinações legais e constitucionais quanto à licitação obrigatória para adoção do regime de concessão e permissão para exploração de serviços públicos. (...) além de outras condicionantes, deve-se comprovar a prestação de serviço adequado, consistente no cumprimento, pelo período antecedente de cinco anos contado da data da proposta de antecipação da prorrogação, das metas de produção e de segurança definidas no contrato, por três anos, ou das metas de segurança definidas no contrato, por quatro anos. (...) A definição legal de serviço adequado (Lei 8.987/1995, art. 6º, § 1º) expõe ser ele “o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”. O serviço adequado é aquele que atende, quanto ao objeto contratado, os índices de atendimento. (...) A prorrogação contratual ao termo final do contrato ou a prorrogação antecipada devem ser submetidas a consulta pública. (...) Para tanto, após o encerramento da consulta

⁹⁹CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:<<https://www.Buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia>>.



pública, encaminham-se ao Tribunal de Contas da União (TCU) o estudo prévio, os documentos que comprovem o cumprimento das exigências de serviço adequado e o termo aditivo de prorrogação contratual para avaliação final quanto à legitimidade e economicidade da solução aventada.

[ADI 5.991 MC, rel. min. Cármen Lúcia, 20-2-2020, P, *Informativo* 967.]

O contrato administrativo se encerra no prazo nele definido, salvo a realização de ajuste, ao final do termo, pela prorrogação contratual, se atendidas as exigências legais para tanto e se presente o interesse público na permanência do contrato. Nesse passo, é incongruente com a natureza da prorrogação contratual a ideia de sua formalização em momento antecedente ao término do contrato, como também é incongruente com sua natureza a garantia indissolúvel de sua realização já no instrumento contratual. A discricionariedade da prorrogação é uma das marcas mais acentuadas do contrato administrativo e, assim, está, inclusive, prevista nas sucessivas legislações relativas às concessões de energia elétrica (Leis 9.074/1995 e 12.783/2013) e também no termo cujas cláusulas se questiona nos autos.

[**RMS 34.203**, rel. min. Dias Toffoli, j. 21-11-2017, 2ª T, *DJE* de 20-3-2018.]

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. Obs: a tese acima foi a fixada pelo STF. No entanto, penso que é importante um esclarecimento revelado durante os debates: é possível sim, excepcionalmente, que a Administração Pública responda pelas dívidas trabalhistas contraídas pela empresa contratada e que não foram pagas, desde que o ex-empregado reclamante comprove, com elementos concretos de prova, que houve efetiva falha do Poder Público na fiscalização do contrato. STF. Plenário. RE 760931/DF, rel. orig. Min. Rosa Weber, red. p/ o ac. Min. Luiz Fux, julgado em 26/4/2017 (repercussão geral) (Info 862).

É INCONSTITUCIONAL norma da Constituição Estadual que preveja que o Estado (poder concedente) terá até 25 anos para pagar a indenização decorrente da encampação do serviço público que era prestado pela empresa concessionária. STF. Plenário. ADI 1746/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 18/9/2014 (Info 759).

19.2. INFORMATIVOS DO STJ¹⁰⁰

Informativo n. 649

REsp 1.745.415-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019

O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao contrato de fiança bancária acessório a contrato administrativo.

Se um consórcio público celebrou convênio com a União por meio do qual estão previstos repasses federais, o fato de um dos entes integrantes do consórcio possuir pendência inscrita no CAUC não pode impedir que o consórcio receba os valores prometidos. Isso porque o consórcio público é uma pessoa jurídica distinta dos entes federativos que o integram e, segundo o princípio da intranscendência das sanções, as

¹⁰⁰CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:<<https://www.Buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia>>.



punições impostas não podem superar a dimensão estritamente pessoal do infrator, ou seja, não podem prejudicar outras pessoas jurídicas que não sejam aquelas que praticaram o ato. Assim, o fato de ente integrante de consórcio público possuir pendência no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (CAUC) não impede que o consórcio faça jus, após a celebração de convênio, à transferência voluntária a que se refere o art. 25 da LC 101/2000. STJ. 2ª Turma. REsp 1463921-PR, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 10/11/2015 (Info 577).

Concessionária de rodovia pode cobrar de concessionária de energia elétrica pelo uso de faixa de domínio de rodovia para a instalação de postes e passagem de cabos aéreos efetivada com o intuito de ampliar a rede de energia, na hipótese em que o contrato de concessão da rodovia preveja a possibilidade de obtenção de receita alternativa decorrente de atividades vinculadas à exploração de faixas marginais. STJ. 1ª Seção. EREsp 985695-RJ, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 26/11/2014 (Info 554).

Se for reconhecida a nulidade do contrato administrativo por ausência de prévia licitação, a Administração Pública, em regra, tem o dever de indenizar os serviços prestados pelo contratado. No entanto, a Administração Pública não terá o dever de indenizar os serviços prestados pelo contratado na hipótese em que este tenha agido de má-fé ou concorrido para a nulidade do contrato. STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1394161-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 8/10/2013 (Info 529).

Para que a pessoa possa participar de licitações e contratar com a Administração Pública é necessário que comprove sua regularidade fiscal, ou seja, a inexistência de débitos com o Poder Público. Essa regularidade fiscal não é exigida apenas no momento da licitação e da contratação, persistindo durante toda a execução do contrato. No entanto, segundo o STJ, é ilegal reter o pagamento devido a fornecedor em situação de irregularidade perante o Fisco. Essa prática não é permitida, considerando que não existe autorização na Lei para que seja feita (viola o princípio da legalidade). No caso de falta de regularidade fiscal durante a execução do pacto, a Lei de Licitações autoriza que o Poder Público imponha penalidades ao contratado (art. 87) ou rescinda o contrato. STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1313659-RR, Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23/10/2012 (Info 507).

QUESTÕES

1. (TJRO) VUNESP, 2019. A empresa Serviços de Sucesso Ltda. sagrou-se vencedora em processo de licitação e celebrou, com o Poder Público, contrato cujo objeto é a prestação de serviços de portaria e limpeza em prédio público onde funciona a sede do contratante. Após o início da execução, por razões técnicas desconhecidas à época da licitação, o contratante constatou a necessidade de mudar o local de sua sede, dentro do mesmo Município. Nesse cenário, o contrato celebrado com a empresa Serviços de Sucesso Ltda.

A somente poderá ser aditado de forma unilateral no caso hipotético se a modificação implicar alteração do valor inicial atualizado do contrato, para mais ou para menos, em até 50%.

B deve ser anulado, pois os serviços contratados não são delegáveis ao particular, configurando violação ao dever de realização de concurso público.

C somente poderá ser aditado por acordo entre as partes, pois a mudança do local de prestação dos serviços contratados constitui alteração de regime de execução, que não admite alteração unilateral do contrato.

D deve ser revogado, pois a alteração do local de prestação dos serviços contratados constitui modificação



substancial do objeto, violando o dever de licitar.

E poderá ser aditado, pois a mudança do local de prestação dos serviços contratados, no caso hipotético, constitui modificação qualitativa, permitindo alteração unilateral do contrato.

2. (TJSC) CESPE, 2019. Um empregado de empresa contratada pelo poder público para prestar serviços ligados à atividade-fim do órgão contratante comprovou, em demanda trabalhista, o inadimplemento da empresa em relação ao pagamento de suas verbas rescisórias. Nessa ação, foi reconhecida a existência da dívida trabalhista.

Com referência a essa situação, assinale a opção correta a partir do entendimento majoritário e atual do STF.

A O Estado possui culpa presumida e responde solidariamente pelos encargos trabalhistas inadimplidos, visto que a terceirização da atividade-fim constitui ato ilícito.

B O Estado possui responsabilidade solidária e de aplicação automática com relação às dívidas trabalhistas da empresa contratada.

C O Estado possui responsabilidade subsidiária, a qual independe de culpa, sendo suficiente a comprovação de que não foi possível realizar a cobrança em desfavor da empresa inadimplente.

D A responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas não é transferida automaticamente da empresa contratada para o poder público, seja em caráter solidário ou subsidiário.

E A responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas é transferida automaticamente da empresa contratada para o poder público, sendo suficiente, para tanto, a comprovação da inadimplência do empregador.

3. (TJSC) CESPE, 2019. A alteração unilateral de contrato administrativo pela administração pública poderá

A ser qualitativa, se houver necessidade de modificar o projeto ou as especificações, ou quantitativa, se for necessária a modificação do valor em razão de acréscimo ou diminuição do seu objeto.

B ocorrer normalmente, desde que sejam atendidos os limites legais, mas não deverá servir para garantir o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

C ocorrer comumente, porque é aceita pela doutrina e pela jurisprudência pátria, embora não esteja prevista expressamente na legislação aplicável.

D ser unicamente quantitativa, não sendo possível que o poder público diminua o montante contratual a valor inferior ao que foi acordado na licitação.

E implicar na modificação do regime de execução da obra ou do serviço ou na substituição da garantia de execução

4. (TJAC), VUNESP, 2019. Com base no que dispõe a Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 8.666/93), a declaração de nulidade de um contrato administrativo

A é dotada de efeitos retroativos, impedirá os efeitos jurídicos que ele deveria produzir, mas não desconstituirá os já produzidos, e exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado pelo período do contrato e por outros comprovados prejuízos que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

B é dotada de efeitos retroativos, impedirá os efeitos jurídicos que ele deveria produzir e desconstituirá os já produzidos, mas não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data da declaração e por outros comprovados prejuízos que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

C é dotada de efeitos retroativos, impedirá os efeitos jurídicos que ele deveria produzir e desconstituirá os já produzidos, e exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado pelo período do contrato e por outros eventuais prejuízos, independentemente de sua culpa, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

D não é dotada de efeitos retroativos, não cancela os efeitos jurídicos já constituídos ou produzidos e obriga a Administração a indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data da declaração e pelos prejuízos que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

5. (TJBA) CESPE, 2019. Uma empresa contratada pela administração pública não entregou bens em conformidade com o projeto básico, razão pela qual, após o regular processo administrativo, a contratante rescindiu unilateralmente o contrato e aplicou uma multa à citada empresa.

Nessa situação hipotética

A a multa deverá ser descontada, preferencialmente, dos pagamentos eventualmente ainda devidos pela administração pública.

B a multa deverá ser descontada, primordialmente, da garantia do respectivo contrato.

C a administração agiu equivocadamente, pois multa e rescisão unilateral são inacumuláveis quando motivadas pelo mesmo fato.

D a administração pública, em regra, não estará autorizada a reter unilateralmente pagamentos devidos à empresa para compensar os prejuízos sofridos.

E excepcionalmente, caso a multa aplicada seja superior ao saldo a pagar à contratada, a administração pública poderá reter o pagamento até a quitação da multa.

COMENTÁRIOS

1. Gabarito - E

A) Incorreta. Cf. art. 65, I, a, da Lei 8.666/93

B) Incorreta. Trata-se de hipótese de anulação do contrato.

C) Incorreta. O erro está no “somente”.

D) Incorreta. Trata-se de hipótese de revogação.

E) Correta. Cf. art. 65, I, a, da Lei 8.666/93.

2. Gabarito – D

Todas as alternativas com base na Reclamação 26.894/SP, STF.

3. Gabarito – A

A) Correta. Cf. art. 65, incisos I e II da Lei nº 8.666/93.

B) Incorreta. Cf. art. 65, §6º, da Lei nº 8.666/93.

C) Incorreta. Cf. Art.58, I e art. 65, I, “a” e “b” Lei nº 8.666/93.

D) Incorreta. Cf. Art. 65, §1º, da Lei nº 8.666/93.

E) Incorreta. Cf. art. 65, II, da Lei nº 8.666/93.

4. Gabarito – B

A) Incorreta. A declaração de nulidade opera efeitos retroativos, mas gera a necessidade de indenizar.

B) Correta. Cf. art. 59 Lei nº. 8.666/1993.

C) Incorreta. A alternativa dispõe sobre os efeitos de nulidade no Direito Civil.

D) Incorreta. A alternativa troca os efeitos da nulidade e da anulabilidade, contrariando o art. 59 Lei nº. 8.666/1993.

5. Gabarito – B

A) Incorreta. Cf. art. 87 §1º da Lei 8.666/93.

B) Correta. Cf. art. 87 §1º da Lei 8.666/93.

C) Incorreta. Cf. art. 80 da Lei 8.666/93.

D) Incorreta. Cf. art. 80 §1º da Lei 8.666/93.

E) Incorreta. A lei prevê a compensação entre os valores ainda devidos ao contratado, pelos serviços prestados, e o montante a que este foi condenado, a título de multa.





@cpiuris



www.cpiuris.com.br



contato@cpiuris.com.br



61 3033-3739



61 98442-2591

CAPÍTULO 10 — SERVIÇOS PÚBLICOS

1. CONCEITOS E ELEMENTOS

O conceito de serviço público é composto por três elementos. Pelo **elemento material**: busca identificar o conteúdo da atividade prestada. O serviço público seria uma atividade administrativa de prestação de uma utilidade ou comodidade à população, fruível de forma individual ou coletiva, mas sempre pelos administrados.

Já o **elemento subjetivo**: busca definir serviço público a partir de quem o presta. O serviço público é aquele prestado pelo Poder Público, cuja titularidade pertence ao Estado. Poderá inclusive prestar o serviço por meio do particular, mas é o Poder Público sempre será o titular do serviço. Não confundir titularidade do serviço com titularidade da prestação do serviço. O serviço público é de titularidade do Estado, mas a prestação poderá ser feita por delegação para o particular.

Elemento formal: a atividade será qualificada como serviço público quando ela se submete ao regime jurídico de direito público.

É possível fundir os três elementos para se chegar ao conceito concreto e aplicado no Brasil .

Portanto, serviço público é a atividade de prestação de comodidade ou utilidade aos administrados, seja do ponto de vista individual ou coletivo, prestado pela Administração Pública ou pelo Poder Público, diretamente ou por delegação, submetido a regime jurídico de direito público.

2. PRINCÍPIOS

São princípios específicos do serviço público:

2.1. PRINCÍPIO DA GENERALIDADE

A prestação do serviço deve ser de forma indiscriminada, com igualdade entre os usuários, além alcançar a maior amplitude possível. Decorre do princípio da isonomia, e visa assegurar o oferecimento do serviço público a todos, sem qualquer discriminação entre os usuário.

O mesmo respeito ao princípio da igualdade justifica tratar os usuários de forma diferenciada. Consequentemente a súmula 407 do STJ dispõe que é legítima a cobrança de tarifa de água de acordo com a categoria do usuário e com a faixa de consumo. Fernanda Marinela¹⁰¹ esclarece que

Esse princípio decorre de um raciocínio simples: o Brasil é um país relativamente pobre, tendo o serviço público que atingir e satisfazer os diversos grupos sociais na persecução do bem comum. Sendo assim, quando esse serviço depender de uma cobrança, ela deve ser condizente com as possibilidades econômicas do povo brasileiro, ou seja, a mais baixa possível.

2.2. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE

A prestação de serviços públicos não pode ser interrompida, sob pena de grave prejuízo à coletividade. Não se trata de prestar o serviço em horário integral ou em todos os meses ou dias da semana ininterruptamente, e sim de garantir a prestação de acordo com a necessidade da população, bem como o funcionamento pontual e regular do serviço. A Lei 8.987/1995 lei traz situações em que **não se considera que houve uma descontinuidade** do serviço público a interrupção dos serviços:

- em casos de **emergência**

¹⁰¹MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.



- após um **aviso prévio**, motivado por **ordem técnica ou de segurança** das instalações (Art. 6º, § 3º I);
- após um **aviso prévio**, quando houver o **inadimplemento do usuário** (Art. 6º, § 3º II).

O STJ entende que é legítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, desde que precedido de notificação (AgRg no REsp 1090405/RO). Na mesma linha é legítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o usuário estiver inadimplente, desde que precedido de notificação. Apesar da divergência entre o art. 6º, § 3º, II Lei nº 8.987/95 e o art. 22 CDC, pacificou-se o entendimento de que havendo inadimplemento é possível o corte do fornecimento (AgRg no AREsp 412822/RJ,).

Porém, não se admite o corte de fornecimento quando puder afetar o direito à saúde e à integridade física do usuário; ou de serviços essenciais, tais como escolas, hospitais ou presídios. Nesse caso há uma essencialidade do serviço público, que sobretudo é prestado à coletividade. Por exemplo serviços públicos essenciais de saúde, mesmo quando inadimplentes, não sofrerão cortes no fornecimento unidade de saúde, uma vez que prevalecem os interesses de proteção à vida e à saúde. (STJ, REsp 285.262-MG e AgRg no Ag 1329795/CE).

O corte será legítimo no fornecimento de serviços públicos essenciais quando inadimplente pessoa jurídica de direito público, desde que precedido de notificação e a interrupção não atinja as unidades prestadoras de serviços indispensáveis à população. Julgados: AgRg no AgRg no AREsp 152296/AP,

Deve-se ressaltar que em razão da pandemia de COVID19 alguns Tribunais de Justiça concederam decisões cautelares suspendendo a possibilidade de interrupção de fornecimento de serviços essenciais, inclusive de telefonia e internet, enquanto perdurasse o período de isolamento. Cabe acompanhar se o entendimento irá vigorar na Corte Superior.

O STJ estabelece que a suspensão por inadimplemento só se mostra possível quando os débitos forem atuais, relativos ao mês de consumo. Os débitos anteriores devem ser cobrados judicialmente. O entendimento se mantém mesmo na hipótese de recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor (normalmente por fraude do medidor). A jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. Porém, a suspensão é possível se a fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurada de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa. (REsp 1.412.433-RS)

O STJ também entende que é ilegítimo o corte por débitos anteriores de um usuário anterior. Ou seja, a dívida de energia elétrica tem natureza pessoal e não *propter rem* (AgRg no AREsp 196374/SP).

Na mesma linha é ilegítimo o corte no fornecimento de energia elétrica em razão de débito irrisório, por configurar abuso de direito e ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível a indenização ao consumidor por danos morais (AREsp 452420/SP).

Por fim o corte no fornecimento de energia elétrica somente pode recair sobre o imóvel que originou o débito, e não sobre outra unidade de consumo do usuário inadimplente (REsp 662214/RS).

Fernanda Marinela¹⁰² diz que o princípio da continuidade tem repercussão sobre o direito de greve do servidor público, visto que este não pode ser executado ao ponto de quebrar a continuidade do serviço público realizado por aquela categoria. Isto é, a greve não pode gerar a interrupção do serviço público, deverá manter ao menos o necessário para a garantia da continuidade do serviço público.

2.3. PRINCÍPIO DA MODICIDADE DAS TARIFAS

A prestação do serviço público deve respeitar a condição econômica do usuário. A ideia é de que o Estado não tem o intuito de ter lucro, cobrando o menor valor possível, de forma que seja acessível à população a prestação do serviço. Sendo assim o concessionário poderá negociar como o Poder

¹⁰² MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.



Concedente formas diversificar a prestação de seus serviços, visando permitir a fixação de um menor valor tarifário. Por exemplo explorando a locação de lojas e de espaços publicitários nas estações e nos trens do metrô.

2.4. PRINCÍPIO DA ATUALIDADE

O serviço deve ser atual, fazendo uso de equipamentos e técnicas modernas. Exige-se que o serviço seja prestado de acordo com o “estado da técnica”, isto é, utilizando-se das técnicas mais modernas possíveis.

Este conceito caminha juntamente com os **princípios da eficiência e da segurança**, sendo que este último é essencial uma vez que garante a salvaguarda da incolumidade das pessoas e dos bens afetos aos serviços.

2.5. PRINCÍPIO DA MUTABILIDADE DO REGIME

O regime de execução poderá ser alterado, adequando-se às novas necessidades do administrado, conforme o interesse público.

3. CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO

O serviço público pode ser classificado em:

- **Serviço público próprio:** o Estado assume a titularidade do serviço, podendo executar diretamente ou indiretamente, por meio de delegação.
- **Serviço público impróprio:** a titularidade não pertence exclusivamente ao Estado, ainda que seja regulamentado ou fiscalizado pelo Estado. Poderá o particular exercê-lo, sem que haja delegação estatal.
- **Serviço público delegável:** é o que admite delegação. Ex.: serviço de transporte público.
- **Serviço público indelegável:** o Estado deverá prestar diretamente, como é o caso do correio postal e o correio aéreo nacional, os quais não admitem delegação.
- **Serviço público *uti singuli* (individual):** é o serviço público que atende individualmente o administrado. É possível mensurar a utilização de cada um.
- **Serviço público *uti universi* (universal):** não possui usuário determinado, sendo utilizado o serviço pela coletividade. Ex.: serviço de iluminação pública.
- **Serviço público administrativo:** é executado pela administração, mas para atender as necessidades internas da administração.
- **Serviço público comercial (ou industrial):** envolve o oferecimento de utilidades materiais ao indivíduo. Ex.: água tratada, energia elétrica, esgoto, etc. Terá caráter de serviço industrial ou comercial.
- **Serviço público social:** satisfazem uma necessidade de cunho social, como é o caso de educação, assistência social, seguridade social, etc.
- **Serviço público exclusivo:** atribuído exclusivamente ao Estado, que tem a sua titularidade.
- **Serviço público não exclusivo:** o ordenamento permite a titularidade pelo Poder Público, mas também permite que seja do setor privado. O particular poderá prestar esse serviço independentemente de delegação. Ex.: hospital poderá ser particular. Será, no entanto, necessário observar normas gerais do Poder Público.

4. REMUNERAÇÃO

Os serviços públicos podem ser gratuitos ou remunerados.



Quando **não possuem usuários determinados**, como limpeza urbana ou iluminação pública, como não é possível mensurar o quanto cada um o utiliza, o serviço não será remunerado diretamente pelo beneficiário. Diante disso, a doutrina fala em **serviço gratuito**, apesar da remuneração vir por meio de tributo.

Quando o serviço público atender diretamente e individualmente àquele administrado, como é o serviço de telefonia ou de energia elétrica, é possível exigir uma contraprestação direta pelo usuário. Nesse caso, o **serviço será remunerado**, cabendo a seguinte subdivisão:

- **Serviço individual e compulsório de pagamento obrigatório:** neste caso, há a incidência de taxa, que é um tributo vinculado a uma contraprestação estatal, ainda que não se tenha utilizado do serviço posto à disposição pelo Estado.

A Súmula Vinculante 19 diz que a taxa cobrada exclusivamente por serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo, ou de resíduos proveniente de imóveis, não viola a constituição federal. Frise-se que, quando há cobrança de taxa pelo recolhimento de lixo tendo por fato gerador a extensão do imóvel, o STF entende que isto é constitucional.

- **Serviço individual e facultativo:** nos casos de transporte público e telefonia, não haverá taxa, mas apenas tarifa ou preço público. O usuário vai aceitar o serviço público, e, sendo utilizado, irá pagar pelo seu efetivo uso.

O STJ e STF firmaram o entendimento de que a contraprestação cobrada pelos serviços de águas e esgotos tem natureza jurídica de tarifa, e não de taxa, pois é possível mensurar o quanto cada pessoa consume.

Como não se consegue se dividir o quanto cada pessoa utiliza a iluminação pública, ou seja, por não ser divisível, esse serviço não pode ser remunerado por taxa. Este entendimento é sumulado pela súmula 670. Diante desse entendimento, o Congresso aprovou a EC 39/02, que inseriu o art. 149-A da CF, permitindo aos municípios e ao DF instituir uma contribuição para o serviço de iluminação pública, sendo esta constitucional.

No que toca ao serviço de telefonia, há discussão sobre a cobrança de valores fixos das contas telefônicas, que tratam das chamadas assinaturas mensais. O STJ entendeu que a cobrança da assinatura mensal não é taxa, não havendo ilegalidade, sendo admissível a tarifa básica. Este entendimento está previsto na súmula 356 do STJ.

5. PRESTAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Os serviços públicos podem ser prestados de forma concentrada, desconcentrada ou descentralizada.

Na forma **concentrada** e a forma **desconcentrada** são uma execução direta, pois o próprio Estado presta o serviço público.

No caso da forma **descentralizada**, a execução do serviço público é realizada indiretamente. Isto é, uma pessoa jurídica distinta do ente federativo é quem presta o serviço. Quando se fala que o serviço público foi delegado, significa que o Estado transferiu a terceiro a execução do serviço.

Se a delegação ocorrer internamente, no âmbito da própria Administração ocorre a descentralização por serviços, também chamada de outorga. Caso seja transferida a um particular a hipótese será de descentralização por colaboração.

5.1. DELEGAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO

Essa transferência poderá se dar por:



- **Outorga:** transferência decorrente de lei.
- **Delegação convencional (negocial):** delegação propriamente dita. Nesses casos há a transferência da execução do serviço, da titularidade da prestação do serviço, e não a titularidade do serviço propriamente dito, pois continuará sendo do Estado.

Quando uma pessoa jurídica é criada, está-se diante de uma descentralização, que pode ocorrer por outorga ou por delegação. Em regra quando o Ente político descentraliza, repassa a titularidade de algo. Existe diferença entre transferir a mera execução de uma atividade e transferir a titularidade da atividade.

A titularidade do ente federativo é importante, pois **é com base em quem é titular do serviço público é que se define o juízo competente para processar e julgar determinados litígios**. Instituições particulares e federais de ensino superior agem por delegação da União. Nesse caso, o foro **competente para eventual mandado de segurança contra ato do diretor da instituição de ensino superior particular será julgado pela justiça federal**.

No caso das instituições de ensino superior particular, **se não for mandado de segurança**, mas somente uma ação de conhecimento ou cautelar, ou ainda qualquer outra ação que não seja MS, a **competência será da justiça estadual**, visto que não haveria ato de uma autoridade coatora que atua por delegação da União.

Quando o Estado **outorga**, estará ele transferindo a **titularidade da prestação do serviço** a uma entidade de sua administração indireta. Ou seja, o Estado outorga para uma pessoa jurídica (pertencentes à Administração indireta, mas podem ser pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado), a execução de um serviço público. A Administração indireta exercerá a atividade em nome próprio. A outorga será feita por lei e não pode ser concedida a um particular.

Por exemplo ao criar uma autarquia o ente federativo pode deixar de prestar diretamente aquele serviço, permitindo que a administração indireta, através da autarquia, passe a ser a titular responsável por prestar o serviço. A autarquia atuando em nome próprio e não em nome do ente político, mas quando o Estado delega ao particular, necessariamente detém a titularidade do serviço público, delegando apenas a execução.

Quando se fala em **descentralização** também se fala em administração indireta.

Com a delegação, o Estado vai transferir a **titularidade da prestação do serviço** a alguém por meio de um contrato ou de um ato administrativo, podendo se dar por concessão, permissão ou autorização. O Estado transfere unicamente a execução do serviço, para que o ente delegado preste ao público em seu próprio nome e por sua conta e risco, contudo sob fiscalização do Estado.

5.2. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO

Concessão é a delegação da prestação de um serviço público. A concessão tem natureza jurídica de contrato administrativo, de modo que a competência privativa para legislar sobre normas gerais é da União.

A Lei 11.079 instituiu as Parcerias Público Privadas, passando o ordenamento ter a dois tipos de concessões: **comuns** e as **especiais**.

Seja qual for a concessão, comum ou especial, **algumas características são comuns a todas as espécies de concessões**:

- delegação da concessão não poderá ser feita a uma pessoa física
- a concessão é formalizada por meio de um contrato administrativo
- a delegação, em regra, é precedida de licitação, na modalidade concorrência

As concessões comuns são:

- Concessão de serviço público



- Concessão de serviço público precedida de obra pública

Dentro das concessões comuns, há a concessão de serviço público. Logicamente, é uma forma de delegação da prestação de um serviço público. Uma **pessoa jurídica**, ou mesmo um **consórcio de empresas** que demonstre a capacidade para o desempenho do serviço público por sua conta e risco e com prazo determinado, irá celebrar o contrato com a Administração Pública.

A diferença entre a concessão de serviço público e a concessão de serviço público precedida de obra pública é justamente a obra pública anterior. Essa obra é realizada pela própria concessionária do serviço público, fazendo o investimento necessário e posteriormente será amortizado através da exploração do serviço público por um prazo determinado.

Ou seja, antes de prestar o serviço será necessária a implementação de uma obra, a qual terá o concessionário o seu investimento ressarcido a partir da prestação do serviço.

Nas concessões especiais, de acordo com a Lei 11.079/2004. A ideia é a da parceria público-privada, que prevê:

- **Concessão patrocinada:** é uma concessão que envolve adicionalmente a tarifa cobrada do usuário uma contraprestação pecuniária paga pelo parceiro público. Além da prestação do usuário, há uma contraprestação do agente público ao parceiro privado.
- **Concessão administrativa:** é um contrato de prestação de serviços de que a administração pública (direta ou indireta) seja a usuária, ainda que envolva execução de obra, fornecimento ou instalação de bens. O que há aqui é a prestação de serviços públicos em que a Administração Pública é a usuária.

5.3. PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO

Apesar de controvérsia, a permissão de serviço público tem natureza jurídica de **contrato administrativo**. Também é submetida à licitação, mas a delegação é realizada a **título precário**. Isto quer dizer que em algum momento a administração poderá revogar essa permissão sem a necessidade de observar um prazo.

A **permissão poderá ser celebrada por pessoa física ou jurídica**. Esse contrato a ser firmado com a administração terá natureza de contrato de adesão e por conta de sua precariedade poderá haver a revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente quando desejar, não retirando a característica contratual da concessão.

5.4. AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO

A autorização de serviço público, diferentemente de permissão e de concessão, não é negócio ou contrato administrativo, mas sim **ato administrativo unilateral, precário e discricionário**.

Aqui, o Poder Público vai consentir que o particular realize uma determinada atividade, mas **o interesse que prepondera é o interesse do particular**. Ex.: táxi, seguros, bancos, etc.

6. SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO SONORA E DE SONS E IMAGENS

Pelo art. 223 CRFB compete ao Poder Executivo da União a delegação dos serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens (rádio e televisão), observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.



Permissões e autorizações para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens são feitas através de um **ato do Poder Executivo que outorga essa concessão, permissão ou autorização, e para renová-las também é necessário o ato do Chefe do Poder Executivo.**

Esse ato somente irá produzir efeitos **após uma deliberação do Congresso Nacional.** Não se pode cancelar essa concessão, permissão ou autorização antes do termo final do prazo concedido. **Esse cancelamento depende de decisão judicial.**

O prazo dessa delegação será da seguinte forma:

- **Rádio: 10 anos**
- **Televisão: 15 anos**

7. CONTRATOS DE CONCESSÃO COMUNS

Nos contratos de concessão o Poder Público delega um serviço público a terceiros que o prestará em nome próprio, por sua conta e risco, nas condições previamente fixadas. A base legal das concessões está no art. 175 CRFB, além da Lei nº8.987/95 e a Lei nº 9.075/95. O contrato de concessão sempre será por **prazo determinado.** Excepcionalmente, o prazo para concessão poderá ser prorrogado (art. 23, XII Lei 8987/95). A prorrogação não pode ocorrer de forma arbitrária, devendo ser motivada. A lei não fixa prazo máximo para os contratos, serão arbitrados seguindo critérios de razoabilidade: serviços públicos mais complexos e com investimentos financeiros expressivos via de regra exigem um período maior.

O Poder Concedente escolherá o particular concessionário através da licitação, via de regra na *modalidade concorrência* (o art. 2º, II, da Lei nº 8.987/95). É possível que nos programas da desestatização se dê na modalidade **leilão.**

Apenas quando expressamente autorizado por outras leis específicas, é possível adotar outra modalidade de licitação, diversa da concorrência. A Lei nº 9.491/97, por exemplo, permite que as concessões abrangidas pelo Programa Nacional de Desestatização sejam precedidas de leilão. A concessão é precedida de licitação, mas admite-se o leilão para as atividades previstas no Programa Nacional de Desestatização.

O edital poderá prever a **inversão das fases de habilitação e julgamento**, aproximando-se da ideia de pregão. Quando permitida a **participação de empresas em consórcios**, haverá a indicação da empresa responsável pelo consórcio. Lembre-se que a concessão só é possível se o concessionário for uma pessoa jurídica, bem como poderá ser uma empresa ou conjunto de empresas, formando um consórcio de empresas. **A empresa líder do consórcio será responsável perante o poder concedente.** As outras empresas também poderão responder, inclusive solidariamente, mas existe uma empresa líder que sempre tratará o contrato de concessão.

No tocante à **remuneração, o usuário do serviço público é quem paga o serviço**, sendo esta a forma de remuneração do concessionário. A remuneração do Concessionário a rigor é feita exclusivamente pelas tarifas cobradas aos usuários, sendo garantindo o equilíbrio econômico financeiro contrato. O contrato estabelece o preço inicial a ser cobrado pelo concessionário e sua fórmula de atualização. Como já dito visando a modicidade da tarifa o Poder Concedente poderá autorizar que o Concessionário explore adicionais, como espaços publicitários ou lojas.

Se houver a alteração de impostos, da situação e não há culpa do concessionário, poderá haver a revisão da tarifa. Atente-se que **não irá gerar a revisão do contrato quando houver a alteração do imposto de renda.** A alteração da situação, seja para mais ou para menos, irá gerar a alteração da tarifa.

A infraestrutura necessária para a execução do serviço, caso já existente, será repassada pelo Concedente durante o prazo contratual ao concessionário. Caso inexistente será construída ou adquirida junto a terceiros pelo Concessionário para cumprir o disposto no contrato de concessão. O Concessionário é responsável ao menos por parte da gestão da infraestrutura e serviços relacionados, não atuando apenas como mero agente, e fica obrigado a entregar a infraestrutura ao concedente no final do contrato.



A exploração de qualquer atividade econômica gera um risco, sendo inerente a isso. O exercício da atividade econômica se dá **por conta e risco do Concessionário**. Na prática é elaborada uma matriz de riscos associados ao empreendimento, que estabelece quais os riscos serão suportados pela Administração e quais serão encargos do Concessionário. Por exemplo riscos ambientais, decorrentes do processo de engenharia, aumento de demanda etc.

Porém, a **responsabilidade do Concessionário**, por eventuais danos experimentados por usuário ou por terceiros, é **objetiva**. Ainda que a fiscalização do Poder Concedente tenha sido falha, isto **não atenua** a responsabilidade do concessionário.

É preciso que se ressalte as situações de danos causados por **condutas omissivas**. Isso porque o entendimento que prevalece é de que no caso de omissão **é preciso demonstrar a responsabilidade subjetiva**: culpa na prestação de serviço (falta do serviço).

A **responsabilidade do Poder Concedente é subsidiária**, só respondendo por aquilo que não se conseguir o ressarcimento em face do concessionário. Em determinados casos, mesmo a concessão integral dos serviços não é suficiente para afastar a responsabilidade solidária do Estado para responder pelos possíveis danos, como é o caso dos danos ambientais (STJ REsp 28.222).

O contrato de concessão, comum ou especial, **poderá prever o emprego de mecanismos privados para resolução de disputas** entre o concessionário e concedente que eventualmente venham a surgir na execução do contrato. **Poderão inclusive instituir a arbitragem**.

A tarifa vai ser fixada de acordo com a proposta que se mostrar vencedora na licitação, podendo um dos tipos de licitação ser a de menor preço, fixando a tarifa de acordo com aquilo que foi estabelecido na proposta vencedora. **Esse valor poderá ser revisado**, pois o equilíbrio econômico-financeiro é garantido constitucionalmente.

É possível que o concessionário realize uma **subconcessão**, sendo ele em parte concedente, e promover uma subconcessão. Se houver uma **expressa autorização do poder concedente** e houver **previsão no contrato de concessão**, será admitida a subconcessão. A subconcessão não se confunde com a subcontratação, bastando que essa (subcontratação) esteja prevista no edital, de forma que poderá subcontratar alguém para ajudar a executar o serviço. Mas neste caso, quem irá executar o serviço será o contratado. Na subconcessão, exige-se que a outorga seja sempre precedida de concorrência, visto que irá gerar a sub-rogação do subconcessionário, ingressando na relação contratual com todos os direitos e obrigações do subconcedente dentro dos limites daquela subconcessão. O subconcessionário passa a substituir o subconcedente. Por isso é a **necessidade de concorrência, autorização expressa do poder concedente e autorização expressa de autorização no contrato de concessão**.

É possível ainda que o Poder Concedente venha a **intervir na concessão para assegurar o princípio da continuidade do serviço público e da adequação do serviço público**. A intervenção possui caráter temporário e não constitui uma punição.

Se for necessário, a intervenção deverá ser expedido decreto pelo Poder Concedente, em que será designado um interventor com os objetivos e limites dessa intervenção.

Quando é declarada a intervenção o Poder Concedente tem o prazo de 30 dias para instaurar o processo administrativo para justificar as causas determinantes dessa medida, bem como a sua necessidade e forma que será usada para apuração das responsabilidades pela prestação inadequada do serviço.

A verificação deve ser concluída em no máximo 180 dias. Caso ele não seja cumprido tal prazo a intervenção será considerada, retornando a administração dos serviços ao concessionário. A intervenção poderá levar a três conclusões:

- a inadequação do serviço, situação na qual deverá se decretar a caducidade da concessão,
- aplicação de penalidade
- caso nenhuma responsabilidade restar comprovada, deve o concessionário retornar a administração total dos serviços. Nesse último caso, pelo Art. 34, deverá ocorrer a prestação de contas por parte do interventor.



O contrato de concessão se extinguirá nos seguintes casos:

- **Advento do termo contratual:** é término do prazo do contrato.
- **Encampação:** é a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão em razão de interesse público, por meio de uma lei específica que autorize essa encampação. Como a retomada é de interesse público, e não por violação do contrato pelo concessionário, haverá a indenização.
- **Caducidade:** é o fim do contrato de concessão em razão da inexecução do contrato, seja total ou parcial. O concessionário não executou o contrato, totalmente ou parcialmente. Essa caducidade se dará independentemente de uma indenização prévia, sendo necessária garantir a adequada prestação do serviço.
- **Anulação**
- **Falência ou extinção do concessionário**
- **Rescisão amigável**
- **Rescisão judicial:** se justifica para proteger o concessionário, pois é ele que deverá rescindir dessa forma. Ou seja, quando o concessionário não tem mais interesse em seguir na concessão, por conta do descumprimento de normas pela administração, não poderá simplesmente abandonar o contrato. Nesse caso, será necessário buscar o judiciário para poder rescindir o contrato.

A **Reversão** é a mudança da titularidade dos bens afetados à prestação do serviço público, transferindo-os do Concessionário para o Poder Concedente. Os bens utilizados na prestação do serviço passarão a ser da titularidade dos entes públicos, visando a continuidade do serviço público.

Rem outras palavras reversão é a incorporação dos bens utilizados para prestação de serviços públicos que foi concedido, quando finalizado aquele contrato. É possível que o sujeito tenha vários investimentos no último ano para que seja atual, **caso em que poderá ser indenizado**. O valores investidos em equipamentos e ainda não amortizados deverão ser indenizados exatamente para evitar o sucateamento e interrupção de investimentos nos últimos anos da concessão. A reversão não é causa da extinção do contrato, e sim sua consequência.

É possível ainda a **transferência da concessão ou do controle da sociedade concessionária**, caso em que deverá ser precedida da anuência do Poder Concedente. Se houver essa transferência da titularidade ou do controle acionário da sociedade concessionária **sem a anuência** do poder concedente, **haverá a caducidade do contrato de concessão**, por conta da violação de uma norma contratual.

O Poder Concedente poderá autorizar a **assunção do controle ou a administração temporária da Concessionária**. Fiadores e garantidores da Concessionária poderão assumir a sua administração temporária ou assumir o controle efetivamente da sociedade, a fim de reestruturar financeiramente e assegurar continuidade daqueles serviços públicos que vêm sendo prestados.

A **administração temporária pelos financiadores do serviço** ocorre quando não há a transferência de propriedade de ações ou de quotas ao financiador ou garantidor, pois ele somente irá administrar temporariamente o serviço. Isso ocorre quando se concede ao financiador ou garantidor o poder de indicar os membros do conselho de administração que serão eleitos pelos acionistas, situação em que escolherão os membros do conselho fiscal, os quais serão eleitos pelos acionistas ou quotistas, além do poder de veto das decisões.

8. CONTRATOS DE CONCESSÕES ESPECIAIS (PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA)

Reguladas pela Lei nº 11.079/2004, as Parceria Público-Privada (PPP) são contratos de prestação de serviços de médio e longo prazo (de 5 a 35 anos), com valor não inferior a vinte milhões de reais.



A Lei 11.079/2004 não indica qualquer área ou setor prioritário para a contratação de parcerias público-privadas, havendo apenas a vedação à delegação das funções regulatórias, jurisdicionais, do exercício do poder de polícia e de outras atividades exclusivas do Estado (Lei 11.079/2004, art. 4.º, III). São vedadas as celebrações de contratos que tenham por objeto único o fornecimento de mão-de-obra, equipamentos ou execução de obra pública.

As PPP são utilizadas principalmente para a implantação da infraestrutura necessária a prestação do serviço contratado pela Administração, tais como água e saneamento, transportes e mobilidade urbana, portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, defesa, parques nacionais iluminação pública etc. São projetos com custo elevado, por isso dependem de iniciativas de financiamento do setor privado. As PPP visam orientar o investimento privado para projetos interessantes para o Estado, liberando recursos públicos para outros interesses da sociedade.

Nesse modelo a remuneração do particular será fixada com base em padrões de performance, sendo devida somente quando o serviço estiver à disposição do Estado ou dos usuários. Além destas não existem outras limitações.

Não se trata de uma privatização, já que não há transferência integral ou definitiva para o setor privado.

A PPP não se confunde com a obra pública. A PPP envolve a contratação da obra e dos serviços a ela associados, desde que seja possível estabelecer indicadores de desempenho objetivos e mensuráveis durante todo o ciclo de vida do contrato. Assim na PPP a relação entre o Poder Público e o parceiro privado está circunscrita a um só contrato. Já na obra pública, em regra, são necessários diversos contratos.

Na obra pública o prazo máximo do contrato é de 05 anos, já na PPP o limite é de 35 anos.

Por fim na PPP o risco da construção é do parceiro privado e dada a natureza da contratação integrada (obra + serviço), o agente privado tem incentivos para executar a obra com maior qualidade: defeitos dela decorrentes afetarão a qualidade do serviço prestado e ocasionarão a redução da contraprestação pública. Podem inclusive ensejar a rescisão contratual sem ônus para o Poder Público.

Na mesma linha a concessão especial /PPP não se confunde com a concessão comum. A diferença central é a forma de remuneração do parceiro privado. Nas concessões comuns a remuneração do concessionário advém exclusivamente das tarifas cobradas aos usuários, nas parcerias público-privadas há pagamento de contraprestação pela Administração Pública, com ou sem cobrança de tarifa dos usuários.

Existem mais algumas nuances tanto as concessões comuns quanto as especiais possuem prazo determinado. No entanto, as **concessões especiais devem ter o prazo compatível com a amortização do investimento feito pelo parceiro privado**. As concessões especiais **não podem ter um prazo inferior a 05 anos, mas também não poderão ter prazo superior a 35 anos**.

Na concessão especial, a **remuneração** é paga pelo usuário pela contraprestação; mas há a hipótese de uma outra contraprestação paga ao parceiro privado pelo parceiro público, quando se tratar da concessão patrocinada.

As **contraprestações públicas** são os pagamentos feitos pela Administração Pública ao parceiro privado em contrapartida ao serviço prestado. Preferencialmente, o valor da contraprestação deverá ser variável e vinculado ao desempenho do parceiro privado (Art. 6º parágrafo único da Lei 11.079/2004). Essas contraprestações públicas não podem ser pagas antes da disponibilização do serviço pelo concessionário. Porém, é permitida estipulação de um parcelamento do serviço e pagamento de contraprestação relativa à parcela disponibilizada. A parcela do serviço deverá estar disponível para utilização, sendo ilegal a divisão do serviço em parcelas não fruíveis (art. 7º da Lei 11.079, de 2004). Não há limite para a contraprestação do setor público em projetos de PPP, uma vez que a Administração Pública, direta ou indiretamente, é a única usuária. Entretanto, nas concessões patrocinadas, as contraprestações públicas não poderão exceder 70% (setenta por cento) da remuneração do parceiro privado, salvo autorização legislativa específica. (art. 10 §3º Lei nº 11.079/04).

As obrigações pecuniárias contraídas pela Administração Pública em contrato de PPP poderão ser garantidas mediante (art. 8º Lei 11.079/04):

- vinculação de receitas, instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei;
- contratação de seguro-garantia com as companhias seguradoras que não sejam controladas pelo Poder Público;
- garantia prestada por organismos internacionais ou instituições financeiras que não sejam controladas pelo Poder Público;
- garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada para essa finalidade;
- outros mecanismos admitidos em lei observado o disposto no inciso V do art. 167 da Constituição Federal;

As concessões especiais preveem o compartilhamento: uma repartição objetiva dos riscos entre as partes, inclusive fato do príncipe, caso fortuito, força maior, álea extraordinária, etc. Para tal também é formulada a matriz de risco nas PPP.

Existem algumas vedações:

- Não se pode celebrar contrato de parceria público-privada com período inferior a 5 anos.
- Não poderá celebrar PPP cujo objeto seja apenas fornecimento de mão de obra, ou fornecimento e instalação de equipamentos, ou simplesmente a execução de obras públicas. É necessário haver uma mistura de ao menos duas dessas atividades.
- Além disso, o contrato de execução de parceria público-privada não poderá ter valor inferior a **10 milhões** de reais.

As **obrigações pecuniárias contraídas pela Administração Pública** nos casos de PPP's poderão ser garantidas, mediante vinculação de receita, utilização ou instituição de fundos especiais, contratos de seguro-garantia, organismos internacionais que irão prestar garantia em favor da administração pública, fundo garantidor ou fundo estatal para garantir essa medida, ou ainda outros mecanismos previstos em lei.

Poderão ser previstas a fixação de garantias pelo parceiro privado, e não apenas pelo parceiro público, as quais poderão ser feitas inclusive em favor do financiador do projeto, a fim de estimular esse financiamento com os juros mais baixos.

Por fim, nas parcerias público-privadas, os contratos devem prever cláusula de aplicação de penalidades, mas não apenas para o parceiro privado, como também para a administração pública.

9. SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE'S).

Para implantar e gerir o objeto da parceria entre o Poder Público e o poder privado, deverá ser constituído uma sociedade de propósito específico, mas isto antes do contrato de parceria público-privada.

Regidas pela Lei 11.079/2004, são sociedades empresárias incumbidas de implantar e gerir o objeto da parceria público-privada. Devem obedecer a padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas.

A constituição da SPE é um pré-requisito para celebração do contrato (art.9º). **A finalidade das SPE é evitar a confusão patrimonial** entre a SPE e as empresas que integram o seu quadro societário, o que poderia ocorrer caso os ativos e as receitas relacionadas com os serviços objeto da PPP fossem utilizados em outros negócios das empresas sócias da SPE.

A Lei 11.079/2009, art. 9.º, apresenta normas peculiares às sociedades de propósito específico no âmbito das parcerias público-privadas, mas não cria novo tipo societário. As SPEs são apenas sociedades empresárias comuns, de qualquer tipo (sociedade limitada, sociedade anônima ou outro tipo previsto em lei), com objeto social delimitado (implantar e gerir o objeto da parceria – Lei 11.079/2004, art. 9.º). Podem assumir a forma de companhia aberta.

A SPE também exerce outras funções úteis no contexto das PPPs. A separação entre a executora do projeto (a SPE) e seus proprietários (os concessionários) oferece maior grau de transferência contábil à

operação da PPP, permitindo diagnósticos sobre a real rentabilidade do projeto, solidez financeira, eficiência operacional e outras informações úteis na gestão do contrato.

A existência da SPE também facilita a assunção da concessão pelos financiadores do projeto em caso de inadimplemento, hipótese autorizada pela Lei 11.079/2004, art. 5.º, §2.º, I).

A administração não pode ser titular do capital votante dessa SPE, exceto quando eventualmente essa maioria do capital votante seja produto da aquisição por uma instituição financeira controlada do Poder Público daquelas quotas sociais em caso de inadimplemento do contrato de financiamento.

Se a SPE se torna inadimplente e o financiador do projeto for um banco público, poderá assumir o controle para evitar a inidoneidade financeira da sociedade e para evitar a descontinuidade do serviço público. Se houver interesse da sociedade de propósito específico, essa transferência só será possível se houver previamente uma autorização expressa da administração pública.

10. CONCESSÕES PATROCINADAS

Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas no moldes da Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 que, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, envolve o pagamento de uma contraprestação pecuniária por parte do governo ao agente privado (§ 1º do art. 2º da Lei n.º 11.079, de 2004).

É possível que essas concessões tenham mais de 70% da remuneração do parceiro privado paga pela administração pública. Neste caso, para firmar esse contrato de concessão patrocinada, é necessária prévia autorização legislativa específica, já que vai onerar consideravelmente a administração.

11. PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSES (PMI)

No PMI (Procedimento de Manifestação de Interesse) a autoridade pública manifesta seu interesse em receber estudos de viabilidade, levantamentos, investigações, dados, informações técnicas, projetos ou pareceres de interessados em projetos de parcerias público-privadas, nas modalidades patrocinada e administrativa, de concessão comum e de permissão. Já é uma realidade no Brasil, sendo utilizado principalmente por prefeituras que não possuem corpo funcionários com especialização necessária para a elaboração de quesitos técnicos de editais de licitação de áreas complexas, como saneamento básico e iluminação pública.

No PMI os particulares apresentam, integral ou parcialmente, os estudos necessários (por exemplo de demanda, engenharia e arquitetura, viabilidade econômico-financeira, impacto sócio-ambiental), bem como o próprio edital de licitação e a minuta de contrato administrativo que serão utilizados pela Administração Pública nas futuras PPP.

Em outras palavras, o particular participa de um processo seletivo para apresentar os estudos que basearão o contrato administrativo da PPP, e o rascunho do próprio edital de licitação da PPP. Caso seu projeto seja selecionado não receberá absolutamente nada no primeiro momento, e a Administração Pública o transformará o estudo no próprio edital definitivo de licitação da PPP. O particular só será remunerado após o término desta concorrência.

Quando for escolhido o parceiro privado após o término da concorrência da PPP o autor do projeto será ressarcido. O pagamento será de responsabilidade do parceiro privado da PPP.

No Brasil a previsão do PMI está nas Leis 8.987/1995, art. 21 e 11.079/2004, art. 3.º, caput e §1.º, sendo regulamentada pelo Decreto 5.977/2006. O Decreto 5.977/2006 regula o procedimento destinado à apresentação de projetos, estudos, levantamentos ou investigações, elaborados por pessoa física ou jurídica da iniciativa privada, a serem utilizadas em modelagens de parcerias público-privadas já definidas como prioritárias no âmbito da administração pública federal.



12. TESES DO STJ

- 1) É legítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando inadimplente o usuário, desde que precedido de notificação.
- 2) É legítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, desde que precedido de notificação.
- 3) É ilegítimo o corte no fornecimento de energia elétrica quando puder afetar o direito à saúde e à integridade física do usuário.
- 4) É legítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando inadimplente pessoa jurídica de direito público, desde que precedido de notificação e a interrupção não atinja as unidades prestadoras de serviços indispensáveis à população.
- 5) É ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando inadimplente unidade de saúde, uma vez que prevalecem os interesses de proteção à vida e à saúde.
- 6) É ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando a inadimplência do usuário decorrer de débitos pretéritos, uma vez que a interrupção pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo.
- 7) É ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais por débitos de usuário anterior, em razão da natureza pessoal da dívida.
- 8) É ilegítimo o corte no fornecimento de energia elétrica em razão de débito irrisório, por configurar abuso de direito e ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível a indenização ao consumidor por danos morais.
- 9) É ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito decorrer de irregularidade no hidrômetro ou no medidor de energia elétrica, apurada unilateralmente pela concessionária.
- 10) O corte no fornecimento de energia elétrica somente pode recair sobre o imóvel que originou o débito, e não sobre outra unidade de consumo do usuário inadimplente.

13. JURISPRUDÊNCIA

13.1. INFORMATIVOS DO STF¹⁰³

Prorrogação de contrato de concessão de ferrovia e serviço adequado O Plenário, por maioria, indeferiu medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra os seguintes dispositivos: § 2º, do inciso II do art. 6º (1); §§ 1º, 3º, 4º e 5º do art. 25 (2); e o § 2º do art. 30 (3), todos da Lei 13.448/2017.

O Plenário afirmou que o art. 175, I, da CF (6) prevê que a lei disporá sobre as condições para a prorrogação dos contratos de concessão. Enfatizou que o inciso XII do art. 23 da Lei 8.987/1995 (7) estabelece que as condições para a prorrogação devem ser disciplinadas no contrato de concessão, configurando-se como cláusula essencial, marcada pela discricionariedade da Administração Pública e na supremacia do interesse público. A norma dispõe sobre a contratação de termo predefinido, firmado a partir de licitação, cabendo à Administração avaliar, excepcionalmente, com base nos parâmetros legais de atendimento ao interesse público, a conveniência e a oportunidade da prorrogação. Assinalou que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece a prorrogação do prazo contratual no espaço de discricionariedade da Administração Pública à qual cabe analisar e concluir sobre a oportunidade e a conveniência da prorrogação. A prorrogação indefinida do contrato, porém, configura

¹⁰³CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:<<https://www.Buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia>>.



burla às determinações legais e constitucionais quanto à licitação obrigatória para adoção do regime de concessão e permissão para exploração de serviços públicos. A Lei 13.448/2017 estabelece diretrizes gerais para a prorrogação e relicitação dos contratos de parceria qualificados no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), nos termos da Lei 13.303/2016, para os setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário da Administração Pública federal. Não procede a alegação da autora de que a exigência posta no § 2º do inciso II do art. 6º da Lei 13.448/2017 importa em ofensa à eficiência e favorecimento de interesses particulares em detrimento do interesse público. Conforme se prescreve na norma impugnada, além de outras condicionantes, deve-se comprovar a prestação de serviço adequado, consistente no cumprimento, pelo período antecedente de cinco anos contado da data da proposta de antecipação da prorrogação, das metas de produção e de segurança definidas no contrato, por três anos, ou das metas de segurança definidas no contrato, por quatro anos. A definição legal de serviço adequado (Lei 8.987/1995, art. 6º, § 1º) expõe ser ele “o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”. O serviço adequado é aquele que atende, quanto ao objeto contratado, os índices de atendimento. A prorrogação contratual ao termo final do contrato ou a prorrogação antecipada devem ser submetidas a consulta pública. Para tanto, após o encerramento da consulta pública, encaminham-se ao Tribunal de Contas da União (TCU) o estudo prévio, os documentos que comprovem o cumprimento das exigências de serviço adequado e o termo aditivo de prorrogação contratual para avaliação final quanto à legitimidade e economicidade da solução aventada. STF, Informativo 967, Plenário. ADI 5991 MC/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 20.2.2020.

A concessionária não tem direito adquirido à renovação do contrato de concessão de usina hidrelétrica. A União possui a faculdade de prorrogar ou não o contrato de concessão, tendo em vista o interesse público, não se podendo invocar direito líquido e certo a tal prorrogação. Dessa forma, a prorrogação do contrato administrativo insere-se no campo da discricionariedade. A Lei nº 12.783/2013 subordinou a prorrogação dos contratos de concessão de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica à aceitação expressa de determinadas condições. Se estas são recusadas pela concessionária, a Administração Pública não é obrigada a renovar a concessão. A Lei nº 12.783/2013 pode ser aplicada para a renovação de contratos ocorrida após a sua vigência mesmo que a assinatura do pacto original tenha ocorrido antes da sua edição. STF. 2ª Turma. RMS 34203/DF e AC 3980/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgados em 21/11/2017 (Info 885).

13.2. INFORMATIVOS DO STJ¹⁰⁴

Informativo n. 660. REsp 1.816.095-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019. São penhoráveis as verbas recebidas por escola de samba a título de parceria público-privada com a administração pública.

Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do

¹⁰⁴CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:<<https://www.Buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia>>.

fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. STJ. 1ª Seção. REsp 1412433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018 (recurso repetitivo) (Info 634).

A interferência judicial para invalidar a estipulação das tarifas de transporte público urbano viola a ordem pública, mormente nos casos em que houver, por parte da Fazenda estadual, esclarecimento de que a metodologia adotada para fixação dos preços era técnica. Segundo a “doutrina Chenery”, o Poder Judiciário não pode anular um ato político adotado pela Administração Pública sob o argumento de que ele não se valeu de metodologia técnica. Isso porque, em temas envolvendo questões técnicas e complexas, os Tribunais não gozam de expertise para concluir se os critérios adotados pela Administração são corretos ou não. Assim, as escolhas políticas dos órgãos governamentais, desde que não sejam revestidas de reconhecida ilegalidade, não podem ser invalidadas pelo Poder Judiciário. STJ. Corte Especial. AgInt no AgInt na SLS 2240-SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 7/6/2017 (Info 605).

QUESTÕES

1. (MPECE) CESPE, 2020. Julgue os próximos itens, com relação a parceria público-privada.

I Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão que pode ser celebrado na modalidade patrocinada ou administrativa.

II É vedada a celebração de contrato de parceria público-privada caso o valor do contrato seja inferior a dez milhões de reais e o período de prestação do serviço seja inferior a cinco anos.

III Na contratação de parceria público-privada, os riscos do negócio ficam integralmente por conta da contratada.

IV A contratação de parceria público-privada deve ser precedida de licitação na modalidade pregão eletrônico.

Estão certos apenas os itens

AI e II.

BII e III.

CIII e IV.

DI, II e IV.

EI, III e IV.

2. (TJRJ) VUNESP, 2019. A respeito da concessão ou permissão de serviços públicos, assinale a alternativa correta.

A Admite-se a rescisão amigável de contratos de concessão comum ou patrocinada, por razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas pela máxima autoridade do ente contratante, mediante homologação judicial.

B Incumbe ao Poder Concedente declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço ou obra pública e promover diretamente as desapropriações, cabendo à concessionária responsabilizar-se pelas indenizações decorrentes.

CA sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos constituem diretriz de contratação de parcerias público-privadas.

DA transferência de concessão ou do controle societário da concessionária sem prévia anuência do Poder Concedente implicará a encampação da concessão.

E Antes da celebração do contrato, deverá ser constituída sociedade de propósito específico, vedada a aquisição da maioria do seu capital votante pelo ente contratante ou por instituição financeira controlada pelo Poder Público, em qualquer caso.

3. (MPE-MG) FUNDEP, 2019. Assinale a assertiva verdadeira com relação às parcerias público-privadas:

A A contraprestação da Administração Pública, nos contratos de parceria público-privada, não poderá ser feita por cessão de créditos não tributários.

B A concessão patrocinada é o contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens, ao passo que a concessão administrativa é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado.

C A repartição de riscos entre as partes, típica das concessões ordinárias, não se aplica, por expressa disposição legal, às parcerias público-privadas; por outro lado, é diretriz normatizada na Lei das PPPs o respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos entes privados incumbidos da sua execução.

D As obrigações pecuniárias contraídas pela Administração Pública em contrato de parceria público-privada poderão ser garantidas mediante a vinculação de receitas, observada a Constituição da República, e a instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei.

4. (TJRO) VUNESP, 2019. Na hipótese de sociedade de propósito específico contratada encontrar-se em dificuldade financeira e sem plenas condições de gerir o objeto do contrato de concessão patrocinada, o Poder Concedente poderá

A autorizar que os financiadores com quem a sociedade de propósito específico mantenha vínculo societário direto assumam sua administração temporária, com a faculdade de indicar os membros do Conselho de Administração, a serem eleitos em Assembleia Geral pelos acionistas.

B autorizar a transferência do controle da sociedade de propósito específico, desde que prevista a possibilidade no edital e contrato, devendo o adquirente atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessária à assunção do serviço, comprometendo-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor.

C adquirir a maioria do capital votante da sociedade de propósito específico e prosseguir na execução do contrato, indicando os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e exercendo poder de veto em deliberações dos acionistas.

D instaurar processo administrativo para apuração de infração contratual e, após o exercício do contraditório e ampla defesa pela sociedade de propósito específico, se constatada a inadimplência, declarar a encampação da concessão e aplicar multa por inexecução parcial do contrato.

E rescindir o contrato de concessão e retomar imediatamente a execução do objeto contratado, diferindo o pagamento de indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis ainda não amortizados ou depreciados e que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido.

5. (TJAL) FCC, 2019. Considere que em um contrato de concessão rodoviária, regido pela Lei federal nº 8.987/1995, tenha sido atribuída à concessionária a obrigação de realização de determinadas obras de recuperação e ampliação da rodovia, ficando a cargo do poder concedente a realização de algumas obras de pequena monta na mesma malha rodoviária, que já estavam sendo executadas por empresas contratadas pela Lei nº 8.666/1993. Ocorre que, em virtude da falência da empresa contratada, uma dessas obras de responsabilidade do poder concedente foi paralisada e o contrato correspondente, rescindido. Considerando tratar-se de obra indispensável para assegurar a fluidez do tráfego na rodovia concedida, o poder concedente alterou unilateralmente o contrato de concessão, para incluir a conclusão da referida obra como obrigação da concessionária, procedendo ao reequilíbrio econômico financeiro

mediante aditamento contratual prevendo a prorrogação do prazo de concessão. De acordo com as disposições legais aplicáveis, conduta do poder concedente

A será legítima se não ultrapassado o prazo máximo de trinta e cinco anos para a exploração dos serviços concedidos e observado o limite de vinte e cinco por cento do valor do contrato de concessão, calculado tomando por base os investimentos originalmente alocados como responsabilidade da concessionária.

B somente será legítima se comprovada a necessidade do aditamento como condição para manutenção da regularidade e atualidade do serviço e observado o limite de vinte e cinco por cento do valor original do contrato de obras, devidamente atualizado.

C não encontra embasamento legal, eis que a manutenção da fluidez do tráfego é uma obrigação essencial à regularidade dos serviços concedidos, ficando os custos extraordinários para sua manutenção por conta e risco da concessionária.

D é legítima do ponto de vista da inclusão da obra como obrigação da concessionária, dado o princípio da mutabilidade dos contratos administrativos, porém não quanto à ampliação do prazo de concessão, eis que o reequilíbrio somente poderia ser feito mediante aumento da tarifa.

E será legítima se não importar alteração do objeto definido no instrumento convocatório, não estando o poder concedente obrigado a observar o limite de vinte e cinco por cento do valor do contrato regido pela Lei nº 8.666/1993 para fins da alteração unilateral imposta no contrato de concessão.

COMENTÁRIOS**1. Gabarito - A**

I – Certo. Cf. art. 2º, *caput*, da Lei 11.079/04.

II – Certo. Cf. art. 2º, § 4º, I, da Lei 11.079/04.

III – Errado. Cf. art. 5º, III, da Lei 11.079/04.

IV – Errado. Cf. art. 10 da Lei 11.079/04.

2. Gabarito - C

A) Incorreta. É possível a rescisão amigável (distrato).

B) Incorreta. As desapropriações necessárias à adequada prestação de serviço público no regime de concessão poderão ser de responsabilidade da concessionária, caso previsto no edital de licitação.

C) Correta. Cf. art. 4º, VII, da Lei 11.079/04.

D) Incorreta. Cf. art. 27 da Lei 8.987/95.

E) Incorreta. Cf. art. 9º da Lei 11.079/04.

3. Gabarito - D

A) Incorreta. Cf. 6º, II, da lei 11.079/2004.

B) Incorreta. Cf. art. 2º §1º da lei 11.079/04

C) Incorreta. Cf. 4º, VI da lei 11.079/04.

D) Correta. Cf. art. 8º, I da lei 11.079/04.

4. Gabarito - B

Todas as alternativas se baseiam nos art. 9º, § 1º, Lei 11.079/04 c/c art. 27, § 1º, da Lei 8.987/95.

5. Gabarito - E

A) Incorreta. Cf. Art. 5º, I, Lei 11.079/2004 c/c art. 22 da Lei 13.448/2017.

B) Incorreta. Cf. Art. 5º, I, Lei 11.079/2004 c/c art. 22 da Lei 13.448/2017.

C) Incorreta. Cf. art. 58, I, Lei 8.666/1993.

D) Incorreta. Cf. art. 6º, da Lei 13.448/2017.

E) Correta. Cf. art. 65, I e II, Lei 8.666/1993.

CAPÍTULO 11 — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

1. TEORIAS

Embora a atuação da Administração Pública vise a satisfação do o Estado eventualmente pode causar dano aos particulares. Nessa hipótese deverá indenizá-los, como forma de reparação do prejuízo causado. Celso Antônio Bandeira de Mello¹⁰⁵ explica que:

A responsabilidade civil do Estado está ligada a obrigação que lhe incumbe de reparar economicamente os danos lesivos a esfera juridicamente garantida de outrem e que lhes sejam imputáveis em decorrência de comportamentos unilaterais lícitos ou ilícitos, comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos.

A responsabilidade civil do Estado evoluiu ao longo dos anos. Como é sabido, no direito comparado a responsabilidade civil do estado passou por três grandes fases:

1.1. 1ª TEORIA – TEORIA DA IRRESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

Trata-se da fase da total irresponsabilidade traduzida pela expressão *the king can do no wrong*. Por essa linha o governante jamais poderia ser responsabilizado por seus atos, não gerando qualquer direito à reparação. Típica da era absolutista, nessa fase o Estado não assumia qualquer responsabilidade pelos danos causados a terceiros, seja por ele ou por seus agentes. Atualmente a doutrina da "irresponsabilidade estatal" está totalmente superada.

1.2. 2ª TEORIA – TEORIA DA RESPONSABILIDADE COM CULPA

Com o a derrocada do absolutismo e ascensão do liberalismo surge a fase da responsabilidade com culpa comum do Estado. Esta pretendia equiparar o Estado ao indivíduo - sendo assim, o Estado era obrigado a indenizar os danos causados a terceiros da mesma forma que na relação obrigacional entre particulares. Porém, como o Estado age por meio de seus agentes, somente seria possível pleitear a indenização se estes tivessem agido com culpa ou dolo, cabendo ao particular o ônus da prova. A falta do serviço poderia ocorrer pela inexistência do mesmo, mau funcionamento ou retardamento. Ocorrendo qualquer destas modalidades surge a obrigação de indenizar, mas sempre cabendo o ônus da prova ao particular.

Para a mesma teoria, é preciso fazer uma diferenciação:

- **Ato de império:** o Estado atua com soberania, sendo irresponsável.
- **Ato de gestão:** o Estado atua como particular, podendo ser responsabilizado subjetivamente, caso cause algum dano, por dolo ou culpa.

1.3. 3ª TEORIA: TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA (CULPA DO SERVIÇO OU CULPA ANÔNIMA)

A Teoria da Culpa Administrativa representou o primeiro estágio da transição entre a doutrina subjetiva da culpa civil e a responsabilidade objetiva. Por ela o dever do Estado indenizar o dano causado

¹⁰⁵ MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Curso de Direito Administrativo** 33ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019, p. 977.



ao particular somente existe caso seja comprovada a existência de falta do serviço, sendo adotada **assim quando se trata da responsabilidade civil do Estado por omissão**.

Não se trata de falar a culpa subjetiva do agente, mas da ocorrência de falta na prestação do serviço.

Essa teoria não exige que lesado identifique o agente público causador do dano, tampouco exige que o ato seja de gestão ou de império. Deve-se apenas demonstrar é que houve uma falta do serviço público, por isso também era denominada de culpa anônima.

O Estado tinha o dever de agir e falhou. Falhou porque **não prestou o serviço ou não prestou adequadamente**, ou ainda **porque prestou o serviço a destempo**.

No Brasil a teoria da Culpa Administrativa foi adotada a partir da Constituição de 1824.

1.4. 4ª TEORIA: TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO

Pela Teoria do Risco Administrativo a atuação estatal que cause dano a um particular gera o dever da Administração Pública indenizar, **independentemente se o dano foi causado pela falta do serviço ou pela culpa de determinado agente público**. Basta que o dano decorra da atuação Estado.

Nessa teoria não cabe ao particular comprovação de qualquer espécie de culpa do Estado. Porém, o Poder Público poderá apresentar em sua defesa excludentes de responsabilidade. A **Teoria do Risco Administrativo foi consagrada a partir da Constituição de 1946**.

Na teoria do risco administrativo, a doutrina chega a um consenso. Ainda que o Estado atue de forma legítima, às vezes essa atuação gera prejuízo a alguém. Esse prejuízo deverá ser suportado pelo Estado, pois é inerente à atividade pública.

A CRFB/88, em tese, adotou a Teoria do Risco Administrativo para a atuação estatal e a culpa administrativa para a omissão. É importante lembrar que quando se trata de um ato ilícito o Estado responde objetivamente, em nome do Princípio da Legalidade. Já na hipótese de responsabilidade por ato lícito, o fundamento da responsabilização do Estado é a isonomia. Em outras palavras, pode ser que o Estado tenha realizado atividade de forma lícita, mas gerou danos anormais para uma parte específica da população, em nome da coletividade. Estas pessoas que sofreram o dano têm direito à indenização.

Se o Estado realiza determinada obra de recapeamento está promovendo o bem, mas ao mesmo tempo a interdição da via causará um enorme prejuízo aos lojistas que dependem do movimento de pedestres. Ou seja, se está havendo a socialização do ganho pela sociedade, também deverá haver a socialização da perda. A atuação do Estado é legítima, mas a responsabilidade é pelo dano causado. É suficiente a demonstração do dano decorrente da atuação estatal.

Aqui o Estado responderá objetivamente. Basta que se prove o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido pelo particular. Atuação administrativa traz embutida em si um risco inerente, logo deve o estado responder objetivamente por eventuais danos decorrentes de seus atos.

Assim, **a responsabilidade é objetiva, quando se tratar de ação, e subjetiva, quando se tratar de omissão**, devendo, neste caso, ser comprovada a culpa anônima. A poda de árvores é um caso comum: quando cai uma árvore causando danos a um carro, por exemplo, entende-se que houve uma omissão específica por parte do Estado em não podar a árvore gerando o dever de indenizar.

O STF admite em casos específicos que a responsabilidade por omissão também seja objetiva: no caso do suicídio do preso ou assassinato, o Estado responde objetivamente por violação do seu dever específico de zelar pela integridade física e moral do preso sob sua custódia (STF: ARE 700.927). Na mesma linha a superlotação de cela gera dever de indenizar o preso em razão da situação degradante (STF, RE nº 580.282, julgado em 16/2/2017).

A grande característica da Teoria do Risco Administrativo, é que, além de hipótese de responsabilidade objetiva, **admite excludente de responsabilidade**. Se ficar provado que houve culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior ou culpa exclusiva de terceiro, afasta-se a responsabilidade, pois interrompe-se/exclui-se o nexo causal em razão de uma dessas excludentes.



As pessoas jurídicas de direito público, integrantes da Administração direta ou indireta, respondem objetivamente por seus atos. Igualmente as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público também respondem objetivamente. Por exemplo uma concessionária de ônibus de transporte, essa empresa atua em nome do Estado, é uma delegatária de serviço público, eventuais danos por ela causados serão de responsabilidade objetiva. Discutiu-se a empresa privada prestadora de serviço público também responderia objetivamente perante não usuários do sistema. O STF pacificou que a responsabilidade é objetiva não importando se um indivíduo lesado é usuário do serviço.

Outro ponto importante é que a responsabilidade do agente público causador do dano é subjetiva. Para responsabilizá-lo é necessário que se prove culpa. Por exemplo, servidor público dirigindo carro da Administração Pública, vem uma pessoa na contramão e bate no carro. Neste caso, não houve nexos causal, inexistente conduta do Estado que tenha gerado dano. Foi a conduta do particular que gerou o dano.

O Estado responde objetivamente, desde que haja nexos causal, e, eventualmente responde pela culpa de seus servidores. No exemplo o servidor não teve culpa, e o dano causado não pode ser imputado ao Estado. De outro giro, se fosse o servidor na contramão e batesse no carro do particular, o Estado, independentemente de sua culpa (fiscalização do servidor), responderá. Mas para que o agente responda, será necessário provar sua culpa.

O Estado tem direito de regresso contra o agente causador do dano. Outro exemplo é de médico que causa dano ao paciente durante cirurgia em hospital público. O paciente pode ajuizar uma ação contra o Estado e este, por sua vez, pode ajuizar uma ação de regresso contra o médico, devendo provar que o médico agiu com culpa.

Discute-se a possibilidade de a vítima ajuizar uma ação contra o Estado e o agente. O STJ e o STF divergem. O STF tem um precedente antigo negando esta possibilidade, ante a garantia que tem o servidor de não ser processado, devendo a demanda tramitar apenas contra o Estado, que só depois, se o caso, ingressará com ação em face do servidor. O STJ possui julgado admitindo esta possibilidade.

Outra discussão diz respeito a denúncia da lide: o Estado poderia denunciar o servidor público à lide? Em geral a denúncia da lide não tem sido admitida, uma vez que se entende que haveria tumulto processual por causa da mistura de discussões no processo, uma responsabilidade é objetiva, outra subjetiva, e o Estado pode depois ajuizar ação regressiva depois, não havendo prejuízo.

1.5. 5ª TEORIA: TEORIA DO RISCO INTEGRAL

A Teoria do Risco Integral consiste em um aumento da responsabilidade civil, uma vez que não há a adoção de excludentes de responsabilidade como culpa exclusiva de terceiro, força maior, caso fortuito, etc.

Nela o Estado será sempre responsável quando houver um evento lesivo. A existência de excludentes de responsabilidade não possuem o condão de afastar o dever de indenizar. O nexos causal é aglutinante/diferenciado, é a realização do risco antevisto no resultado..

No Brasil esta teoria só é aplicada mediante indicação expressa por exemplo caso de danos por atividades nucleares (artigo 21, XXIII, “c” e “d” CRFB).

O STJ entende que no caso de danos ambientais será adotada a teoria do risco integral, ainda que o poluidor seja o estado, por força do princípio do poluidor-pagador, específico da matéria, c/c art. 14 § 1º da Lei nº 6.938/81. A teoria do risco integral será adotada ainda que o Estado seja indiretamente responsável pela poluição, hipótese por exemplo de não remoção de invasores de unidades de conservação da natureza. Nesse caso a responsabilidade por omissão do estado é objetiva, solidária e integral, mas de execução diferida subsidiária (STJ, REsp 1374284/MG).



2. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NO DIREITO BRASILEIRO

A responsabilidade civil do Poder Público está fundada na busca da isonomia: todos se beneficiam com a ação estatal, logo devem suportar igualmente o ônus que decorrentes das atividades da Administração Pública.

Por outro lado a responsabilidade objetiva Estatal reconhece a desigualdade jurídica que existe entre um particular e o Estado. Seria injusto que um administrado, ao sofrer danos patrimoniais ou morais decorrentes das atividades da Administração, ainda precisasse comprovar a existência de culpa desta, para que lhe fosse assegurado o seu direito à reparação. O artigo 37 da Constituição Federal, em seu parágrafo 6º, preceitua:

Art. 37§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem à terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O artigo consagra no Brasil a adoção da responsabilidade objetiva da Administração Pública na modalidade risco administrativo pelos danos causados pelos seus agentes. Esta alcança todas as pessoas jurídicas de direito público (administração direta, autarquias e fundações de direito público), independentemente das atividades que exerçam e, também, todas as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público (empresas públicas e sociedade de economia mista prestadoras de serviços públicos, as fundações públicas com personalidade jurídica de direito privado que prestem serviços públicos e ainda as pessoas privadas não integrantes da administração pública). Porém, não estão abrangidas pelo artigo mencionados as empresas públicas e as sociedades de economia mistas exploradoras de atividade econômica, estas respondem pelos danos que seus agentes causarem à terceiros, da mesma forma que as demais pessoas privadas.

As concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços públicos também respondem objetivamente, sendo pacífico que há responsabilidade civil objetiva das empresas que prestam serviço público mesmo em relação aos danos que sua atuação cause à terceiros não usuários do serviço público. Logo é absolutamente irrelevante saber se a vítima do dano causado por prestador de serviço público é ou não usuário do serviço: basta apenas que o dano seja produzido por um sujeito na qualidade de prestador de serviço público (STF, RE 591.874).

A parte final do parágrafo 6º do artigo 37 CRFB estipula que o agente causador do dano pode ser responsabilizado, e terá que ressarcir a Administração que tenha sido condenada a indenizar o particular prejudicado. Cabe ressaltar que o agente somente será responsabilizado se restar comprovado que este agiu com dolo ou culpa (responsabilidade subjetiva na modalidade culpa comum). O ônus da prova será do Estado: só será assegurado o direito de regresso ao Poder Público se este comprovar a culpa do seu agente.

No segundo semestre de 2019 o STF consagrou a tese da dupla garantia, entendendo que em razão do disposto no art. 37, § 6º, da CRFB, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (STF. RE 1027633/SP). Dupla garantia pois há a proteção do particular prejudicado pela responsabilidade objetiva do Estado, e também a proteção do servidor, que somente pode ser responsabilizado em regresso pelo Estado, mediante demonstração de culpa ou dolo. Assim o STF afastou o entendimento defendido pelo STJ e por Celso Antônio Bandeira de Mello que admitiam a possibilidade de ajuizamento de ação diretamente contra o agente público.

Deve-se ressaltar que quando o Estado está na condição de garante, tendo o dever legal de assegurar a integridade de pessoas ou coisas que estejam à ele vinculadas por alguma condição específica, a responsabilidade é objetiva. Ainda que os danos causados não tenham sido realizados diretamente por



atuação de seus agentes, o Estado responderá por uma omissão específica, ressalvada a hipótese de alguma excludente (culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior).

3. RESPONSABILIDADE DOS NOTÁRIOS

Os notários são particulares que prestam serviços públicos em nome próprio e são considerados funcionários públicos para fins penais, além de serem considerados autoridade pública para mandado de segurança. O entendimento que prevalece é de que **a responsabilidade dos notários é objetiva. Este entendimento foi confirmado pelo STF em 2019.** O STF entendeu que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. O Estado possui responsabilidade civil direta, primária e objetiva pelos danos que notários e oficiais de registro, no exercício de serviço público por delegação, causem a terceiros. (RE 842846/RJ, Info 932).

4. REQUISITOS PARA A DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE ESTATAL

São requisitos para a demonstração da responsabilidade estatal:

- ação ou omissão do Estado
- dano material ou moral
- nexo causal entre a conduta do Estado e o prejuízo experimentado

5. CAUSAS EXCLUDENTES E ATENUANTES DA RESPONSABILIDADE

São excludentes da responsabilidade civil do Estado:

- força maior
- caso fortuito
- ato de terceiros
- culpa exclusiva da vítima

Essas excludentes são para a teoria do risco administrativo.

A responsabilidade extracontratual objetiva consagrada pelo art. 37 § 6º CRFB admite excludentes de responsabilidade. Caso fique demonstrada a culpa concorrente da administração e do particular, na hipótese de culpa exclusiva da vítima, a indenização será proporcionalmente reduzida, sendo o ônus da prova da administração pública.

Nas hipóteses de caso fortuito e força maior, não existindo nenhuma ação comissiva do Estado, este somente poderá ser responsabilizado se tiver concorrido diretamente com sua omissão para a ocorrência dano: por exemplo por ter deixado de prestar adequadamente um serviço de sua obrigação, como retirada de população de áreas de risco ou contenção de encostas. Nesse caso, a responsabilidade, se houver, será subjetiva. Esse raciocínio vale também no caso de danos ocasionados por atos de terceiros, caso se comprove que o serviço não prestado pelo Estado teria impedido efetivamente o ato danoso de terceiro.

6. RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR DANOS DECORRENTES DE SUA OMISSÃO

No caso de responsabilidade do Estado por omissão, é adotada a **teoria da culpa administrativa**, devendo demonstrar que o Estado tinha o dever de agir, mas foi negligente, imprudente ou imperito, e, portanto, deve ser responsabilizado.

Deverá ser responsabilizado em razão de:

- não ter prestado o serviço que deveria ter prestado



- não prestou de forma adequada
- não prestou de forma tempestiva

Tanto o STF quanto o STJ entendem que há responsabilidade objetiva do Estado nos casos de ação e não há responsabilidade objetiva nos casos de omissão, visto que a responsabilidade é subjetiva.

O STJ e STF entendem que no caso de morte por suicídio no estabelecimento prisional, a responsabilidade do Estado é **objetiva**, visto que estaria em custódia do Estado, sabendo dos riscos inerentes àquele meio (RE 841.526). Na verdade, em regra, o Estado é objetivamente responsável pela morte de detento. Isso porque houve inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88.

A regra é **excepcionada** nos casos em que o Estado conseguir provar que a morte do detento não podia ser evitada. Neste caso, rompe-se o nexo de causalidade entre o resultado morte e a omissão estatal.

Houve um precedente onde foi encontrado um cadáver humano em decomposição em um dos reservatórios de água que abastece uma cidade. **O STJ entendeu que a empresa pública concessionária do serviço de água deveria ser condenada a reparar os danos morais sofridos pelo cliente.** Ficou configurada a responsabilidade subjetiva por omissão da concessionária decorrente de falha do dever de efetiva vigilância do reservatório de água (RESP 1.562.862). Além disso, **restou caracterizada a falha na prestação do serviço, indenizável por dano moral, quando a Companhia não garantiu a qualidade da água distribuída à população.** O dano moral, no caso, é *in re ipsa*, ou seja, o **resultado danoso é presumido.** (Inf. 553, STJ).

7. RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR ATOS LEGISLATIVOS

A regra que prevalece em relação aos atos legislativos é a da **irresponsabilidade do Estado.**

Por outro lado, se a lei for declarada inconstitucional, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, é possível que tenha responsabilidade civil do Estado por conta de o dano ser causado por um ato permitido pelo Estado fora do exercício de suas competências constitucionais.

Em relação às **leis de efeito concreto**, que atingem pessoas determinadas, aqui incide sim a responsabilidade civil do Estado, visto que tais leis fogem das características de generalidade e abstração, comuns como as leis gerais. Isso porque acarreta um ônus que não é suportado por todos os membros da coletividade, e sim apenas por aquelas pessoas atingidas.

Existem divergência doutrinária de possibilidade ou não de responsabilização do Estado por atos legislativos constitucionais. O entendimento prevalente é de que não é possível responsabilizar o Estado se o ato legislativo foi constitucional.

Há uma doutrina francesa que tem adeptos no Brasil, apesar de não ser a majoritária, no sentido de que é possível a responsabilização do estado por atos legislativos constitucionais, quando esses atos tiverem uma abstração mitigada.

Fernando Baltar afirma que é exemplo disso a medida provisória que proibiu comercialização de bebidas alcoólicas nas margens das rodovias federais. É uma norma constitucional, mas a abstração é reduzida, pois impõe sacrifício a uma parcela reduzida da coletividade, que é a parcela que vendia bebidas nas estradas. É constitucional, pois protege a sociedade, mas aquelas pessoas que exerciam atividades lícitas foram prejudicadas por uma lei constitucional com abstração reduzida. Então, defende-se que caberia indenização.

Porém, lembre-se que se entende pela impossibilidade de se responsabilizar o estado por normas abstratas constitucionais, mesmo que de abstração reduzida.

8. RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR DANOS DECORRENTES DE SUA OMISSÃO LEGISLATIVA

Neste caso, o Estado não legislou quando deveria, como geralmente ocorre nas hipóteses de inconstitucionalidade por omissão, geradas por normas constitucionais de aplicabilidade limitada.

O Brasil vem se posicionando no sentido de impossibilidade de responsabilização estatal nesse caso.

9. RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR ATOS JUDICIAIS

O art. 133 do NCPC diz que o juiz responde por perdas e danos, quando no exercício de suas funções procede dolosamente, inclusive com fraude, bem como quando recusa, omite ou retarda, sem motivo justo, uma providência que deveria ter ordenado de ofício ou a requerimento de uma parte.

Neste caso, estar-se-á tratando de uma responsabilidade do juiz.

Se o dano deriva de ato culposos, **há responsabilização do Estado quando o erro se dá na seara processual penal**, e não na seara processual civil.

Veja, para se falar em responsabilidade civil por ato culposos do juiz, que gere prejuízo, é apenas na seara penal, mais precisamente aqueles que forem condenados por erro judicial ou ficar preso em tempo superior ao fixado na sentença.

Se for culposa a atuação do juiz, não haverá responsabilização na seara civil.

10. A RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS DECORRENTES DE OBRAS PÚBLICAS

A responsabilidade civil por danos decorrentes de obras públicas exige a análise de dois aspectos:

- se ocorreu o “fato da obra”, ou se foi causado por má execução;
- se a obra está sendo executada diretamente pela Administração Pública ou se está a cargo de um particular que tenha celebrado com o Poder Público um contrato administrativo com esse objeto (execução da obra).

Entende-se que o dano foi causado pelo só fato da obra quando ele decorre da própria natureza da obra, ou se foi causado por um fato imprevisível ou inevitável ocorrido na execução da obra sem que tenha havido irregularidade na sua execução. Nesse caso a responsabilidade da administração será objetiva, independente se a administração estiver executando a obra ou um particular contratado por ela.

Já os casos de má execução são os danos causados por culpa do executor, as irregularidades imputadas a quem está realizando a obra. Logo, é necessário apurar quem está executando a obra. Se for a própria Administração, diretamente, será caso de responsabilidade objetiva, cabendo ação de regresso contra o agente. Se a obra estiver sendo executada por um particular contratado pela Administração pública, ele responderá civilmente pelo dano, sendo a responsabilidade subjetiva, ou seja, se o executor tiver dolo ou culpa. (Art. 70 Lei nº 8.666/93).

11. PRESCRIÇÃO

Segundo o STJ, o prazo para impetrar uma ação de reparação de danos contra o Estado é de 05 anos, contados da lesão ao patrimônio, pois continua em vigor o Decreto 20.910/32, que disciplina o direito à reparação econômica.

Segundo o STF, **é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil** (RE 069.669). Dito de outro modo, se o Poder Público sofreu um dano ao erário decorrente de um ilícito civil e deseja ser ressarcido, ele deverá ajuizar a ação no prazo prescricional previsto em lei.

Vale ressaltar, entretanto, que **essa tese não alcança prejuízos que decorram de ato de improbidade administrativa que, até o momento, continuam sendo considerados imprescritíveis** (art. 37, § 5º).

Segundo o STJ, o termo inicial da prescrição de pretensão indenizatória decorrente de suposta tortura e morte de preso custodiado pelo Estado, nos casos em que não chegou a ser ajuizada ação penal para apurar os fatos, é a data do arquivamento do inquérito policial. Se tivesse sido ajuizada ação penal contra os autores do crime, o termo inicial da prescrição da ação de indenização seria o trânsito em julgado da sentença penal (Inf. 556, STJ).



12. SUJEITO PASSIVO DA LIDE

No polo passivo da lide irá integrar o Estado. Parcela da doutrina sustenta que o Estado pode denunciar à lide o agente público causador do dano, a fim de que a responsabilidade do Estado e do agente sejam decididas no mesmo processo.

Mas o entendimento prevalente é no sentido de impossibilidade dessa denunciação da lide. O lesado tem direito a um processo que venha discutir apenas a responsabilidade objetiva.

Uma questão importante também se faz necessária nos casos em que o particular ajuíza ação diretamente contra o agente público. **Entende-se, nesse caso, que não é possível.**

Em verdade, a ação deve ser promovida em face do Estado e após ele promove uma ação em face do servidor público. Há uma garantia ao servidor neste sentido. O particular tem a garantia da responsabilidade objetiva e o servidor tem a garantia de não ser acionado diretamente pelo particular, mas somente pelo Estado.

13. RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR DANOS CAUSADOS POR ATOS TERRORISTAS

Em regra, adota-se a teoria da culpa administrativa, de modo que só irá ressarcir quando ficar demonstrado que houve um nexo causal entre o atentado terrorista, o dano causado pelo atentado terroristas e a falha do Estado no dever de prestar o serviço de segurança pública.

O Estado atuou culposamente, razão pela qual houve o dano. É a aplicação da **teoria da falta do serviço**.

A ressalva importante advém da Lei 10.744, fruto dos atentados terroristas de 2001, pois os seguros das aeronaves passaram a ter um valor desproporcional, eis que as seguradoras não queriam mais fazer.

Essa lei diz que a União poderá assumir despesas de responsabilidade civil perante terceiros na hipótese de danos de bens e a pessoas, sejam passageiros ou não, quando decorrentes de atentados terroristas, ou por outros atos de guerra ou eventos parecidos, desde que tenham ocorridos no Brasil ou no exterior, contra aeronaves de matrícula brasileira e operados por empresas brasileira de transporte aéreo público, e no montante de até 1 bilhão de dólares.

Ficariam excluídas as empresas de táxi-aéreo desse rol. Tirando essa exceção, por atentados terroristas, a União vai responder quando demonstrar a falha do sistema de segurança pública.

14. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELA PERDA DE UMA CHANCE

É a teoria da perda de uma chance tem como base a probabilidade de uma chance ser concretizada e a certeza do prejuízo decorrente dessa oportunidade que foi perdida.

O STJ vai dizer que o objeto da reparação é a perda da chance, como bem jurídico autônomo, ou seja, de um ganho provável. A reparação do dano não ocorre pelos danos sofridos, mas pela chance perdida, chance essa que deve ser **concreta, real, séria, com alto grau de probabilidade**.

Para que seja responsabilizado o Estado, é necessário que haja uma atuação estatal tenha nexo causal com a perda dessa oportunidade.

15. ERROS MÉDICOS E SUS

Segundo o STJ, a **União não tem legitimidade passiva em ação de indenização por danos decorrentes de erro médico ocorrido em hospital da rede privada durante atendimento custeado pelo Sistema Único de Saúde (SUS)**. De acordo com a Lei 8.080/90, a responsabilidade pela fiscalização dos hospitais credenciados ao SUS é do Município, a quem compete responder em tais casos (Inf. 563, STJ).



16. TESES DO STJ SOBRE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

- 1) Os danos morais decorrentes da responsabilidade civil do Estado somente podem ser revistos em sede de recurso especial quando o valor arbitrado é exorbitante ou irrisório, afrontando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
- 2) O termo inicial da prescrição para o ajuizamento de ações de responsabilidade civil em face do Estado por ilícitos praticados por seus agentes é a data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
- 3) As ações indenizatórias decorrentes de violação a direitos fundamentais ocorridas durante o regime militar são imprescritíveis, não se aplicando o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
- 4) O prazo prescricional das ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública é quinquenal (Decreto n. 20.910/1932), tendo como termo *a quo* a data do ato ou fato do qual originou a lesão ao patrimônio material ou imaterial.
- 5) A responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, devendo ser comprovados a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo de causalidade.
- 6) Há responsabilidade civil do Estado nas hipóteses em que a omissão de seu dever de fiscalizar for determinante para a concretização ou o agravamento de danos ambientais.
- 7) A Administração Pública pode responder civilmente pelos danos causados por seus agentes, ainda que estes estejam amparados por causa excludente de ilicitude penal.
- 8) É objetiva a responsabilidade civil do Estado pelas lesões sofridas por vítima baleada em razão de tiroteio ocorrido entre policiais e assaltantes.
- 9) O Estado possui responsabilidade objetiva nos casos de morte de custodiado em unidade prisional.
- 10) O Estado responde objetivamente pelo suicídio de preso ocorrido no interior de estabelecimento prisional.
- 11) O Estado não responde civilmente por atos ilícitos praticados por foragidos do sistema penitenciário, salvo quando os danos decorrem direta ou imediatamente do ato de fuga.
- 12) A despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima.
- 13) No caso de atropelamento de pedestre em via férrea, configura-se a concorrência de causas, impondo a redução da indenização por dano moral pela metade, quando: (i) a concessionária do transporte ferroviário descumpra o dever de cercar e fiscalizar os limites da linha férrea, mormente em locais urbanos e populosos, adotando conduta negligente no tocante às necessárias práticas de cuidado e vigilância tendentes a evitar a ocorrência de sinistros; e (ii) a vítima adota conduta imprudente, atravessando a via férrea em local inadequado.
- 14) Não há nexo de causalidade entre o prejuízo sofrido por investidores em decorrência de quebra de instituição financeira e a suposta ausência ou falha na fiscalização realizada pelo Banco Central no mercado de capitais.
- 15) A existência de lei específica que rege a atividade militar (Lei n. 6.880/1980) não isenta a responsabilidade do Estado pelos danos morais causados em decorrência de acidente sofrido durante as atividades militares.
- 16) Em se tratando de responsabilidade civil do Estado por rompimento de barragem, é possível a comprovação de prejuízos de ordem material por prova exclusivamente testemunhal, diante da impossibilidade de produção ou utilização de outro meio probatório.
- 17) É possível a cumulação de benefício previdenciário com indenização decorrente de responsabilização civil do Estado por danos oriundos do mesmo ato ilícito.
- 18) Nas ações de responsabilidade civil do Estado, é desnecessária a denúncia da lide ao suposto agente público causador do ato lesivo.

17. JURISPRUDÊNCIA

17.1. SÚMULAS DO STJ

Súmula 624: É possível cumular a indenização do dano moral com a reparação econômica da Lei nº 10.559/2002 (Lei da Anistia Política)

17.2. INFORMATIVOS DO STF¹⁰⁶

STF, Informativo 969, Plenário. RE 136861/SP, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 11.3.2020.

Responsabilidade civil do Estado e dever de fiscalizar – 3 Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais ou quando for de conhecimento do Poder Público eventuais irregularidades praticadas pelo particular. Com essa tese de repercussão geral (Tema 366), o Plenário, em conclusão de julgamento e por maioria, negou provimento a recurso extraordinário interposto de acórdão em que o tribunal de origem deu provimento a recurso de apelação por considerar ausente o nexo causal entre as falhas noticiadas na prestação de serviços públicos e a explosão havida em loja de fogos de artifício (Informativos 917 e 918). Prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes, no qual expôs que a Constituição Federal, no art. 37, § 6º (1), adotou a responsabilidade objetiva do Estado pela teoria do risco administrativo, não pela teoria do risco integral. Várias são as decisões do Supremo Tribunal Federal nesse sentido e a apontar a impossibilidade de qualquer legislação, inclusive, ampliar isso e aceitar a teoria do risco integral. A observância de requisitos mínimos, positivos e negativos, é necessária para a aplicação da responsabilidade objetiva. Na situação dos autos, dois requisitos positivos exigíveis estão ausentes. Inexiste conduta, comissiva ou omissiva, do Poder Público. Por conseguinte, o nexo causal não pode ser aferido. A abertura de comércio de fogos com pólvora não é possível sem a perícia da Polícia Civil, órgão do Estado-membro. É ela que pode realizar a vistoria, não o município. Ademais, a legislação da municipalidade estabelecia o procedimento e previa a inspeção. Exigia, no protocolo, a comprovação do seu pedido e o recolhimento da taxa na Polícia Civil para dar sequência ao procedimento. Entretanto, protocolada a pretensão, faltou a comprovação de ter sido feito requerimento na Polícia Civil. Logo, o procedimento administrativo ficou parado. A atuação do Poder Público municipal foi a esperada: aguardar a complementação dos documentos pelos requerentes. Nada seria exigível da municipalidade. A atividade praticada pelos comerciantes era clandestina. Eles precisavam da licença para funcionar, o que só poderia ser concedido com prévia vistoria. Dessa maneira, os proprietários começaram a comercializar sem autorização. Inclusive, a má-fé dos proprietários do imóvel foi reconhecida em outro processo relacionado a esta causa. Naqueles autos, o magistrado acentuou que, no local, funcionava verdadeiro depósito clandestino de pólvora, armazenada em quantidade tal que se fazia supor uma fábrica clandestina. Assim, existiu desvio na utilização do imóvel. Percebe-se que, além da ausência de requisitos positivos, incide a culpa exclusiva dos proprietários, porque não aguardaram a necessária licença e estocaram pólvora.

¹⁰⁶CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:<<https://www.Buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia>>.



Info 947. RE 1027633/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 14/8/2019 (repercussão geral) A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Info 932. Plenário. RE 842846/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 27/2/2019
O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. O Estado possui responsabilidade civil direta, primária e objetiva pelos danos que notários e oficiais de registro, no exercício de serviço público por delegação, causem a terceiros.

STF Info 963, ARE 1175599 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 10/12/2019
Também STJ. Info 634 1ª Turma. REsp 1492832-DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 04/09/2018

O Ministério da Fazenda editou a Portaria nº 492/1994, reduzindo de 30% para 20% a alíquota do imposto de importação dos brinquedos em geral. Com a redução da alíquota, houve a entrada de um enorme volume de brinquedos importados no Brasil, oriundos especialmente da China, sendo estes bem mais baratos que os nacionais. Como resultado, várias indústrias de brinquedos no Brasil foram à falência e, mesmo as que permaneceram, sofreram grandes prejuízos. Uma famosa indústria de brinquedos ingressou com ação contra a União afirmando que a Portaria, apesar de ser um ato lícito, gerou prejuízos e que, portanto, o Poder Público deveria ser condenado a indenizá-la. O STJ não concordou com o pedido. Não se verifica o dever do Estado de indenizar eventuais prejuízos financeiros do setor privado decorrentes da alteração de política econômico-tributária no caso de o ente público não ter se comprometido, formal e previamente, por meio de determinado planejamento específico. A referida Portaria tinha finalidade extrafiscal e a possibilidade de alteração das alíquotas do imposto de importação decorre do próprio ordenamento jurídico, não havendo que se falar em quebra do princípio da confiança. O impacto econômico-financeiro sobre a produção e a comercialização de mercadorias pelas sociedades empresárias causado pela alteração da alíquota de tributos decorre do risco da atividade próprio da álea econômica de cada ramo produtivo. Não havia direito subjetivo da indústria quanto à manutenção da alíquota do imposto de importação.

Info 901
1ª Turma. RE 598356/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/5/2018
A pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público possui responsabilidade civil em razão de dano decorrente de crime de furto praticado em suas dependências, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88. Caso concreto: o caminhão de uma empresa transportadora foi parado na balança de pesagem na Rodovia Anhanguera (SP), quando se constatou excesso de peso. Os agentes da concessionária determinaram que o condutor estacionasse o veículo no pátio da concessionária e, em seguida, conduziram-no até o escritório para ser autuado. Aproximadamente 10 minutos depois, ao retornar da autuação para o caminhão, o condutor observou que o veículo havia sido furtado. O STF condenou a Dersa – Desenvolvimento Rodoviário S/A, empresa concessionária responsável pela rodovia a indenizar a transportadora. O Supremo



reconheceu a responsabilidade civil da prestadora de serviço público, ao considerar que houve omissão no dever de vigilância e falha na prestação e organização do serviço. STF.

17.3. INFORMATIVOS DO STJ¹⁰⁷

Info 664

2ª Seção. CC 151130-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 27/11/2019 (). A União, na condição de acionista controladora da Petrobras, não pode ser submetida à cláusula compromissória arbitral prevista no Estatuto Social da Companhia, seja em razão da ausência de lei autorizativa, seja em razão do próprio conteúdo da norma estatutária. Caso concreto: um grupo de acionistas da Petrobrás formulou requerimento para instauração de procedimento arbitral perante a Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM-BOVESPA) contra a União e a Petrobrás, no qual pedem o ressarcimento pelos prejuízos decorrentes da desvalorização dos ativos da Petrobras, em razão dos desgastes oriundos da Operação Lava Jato. O procedimento foi instaurado com base no art. 58 do Estatuto Social da Petrobrás, onde consta uma cláusula compromissória dizendo que as disputas que envolvam a Companhia, seus acionistas, administradores e conselheiros fiscais deverão ser resolvidas por meio de arbitragem. A União afirmou que não estava obrigada a participar dessa arbitragem, argumento que foi acolhido pelo STJ.

Info 643

REsp 1.574.350-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, por unanimidade, julgado em 03/10/2017, DJe 06/03/2019

O tráfego de veículos com excesso de peso gera responsabilidade civil em razão dos danos materiais às vias públicas e do dano moral coletivo consistente no agravamento dos riscos à saúde e à segurança de todos, sendo viável, como medida coercitiva, a aplicação de multa civil (astreinte), ainda que já imputada multa administrativa.

Info 630

1ª Turma. REsp 1.565.166-PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 26/06/2018. São imprescritíveis as ações de reintegração em cargo público quando o afastamento se deu em razão de atos de exceção praticados durante o regime militar. Ex: João era servidor da ALE/PR. Em 1963, João foi demitido em razão de perseguição política perpetrada na época da ditadura militar. Em 2011, João ajuizou ação ordinária contra o Estado do Paraná pedindo a sua reintegração ao cargo. Esta pretensão é considerada imprescritível considerando que envolve a efetivação da dignidade da pessoa humana. Vale ressaltar, contudo, que a imprescritibilidade da ação que visa reparar danos provocados pelos atos de exceção não implica no afastamento da prescrição quinquenal sobre as parcelas eventualmente devidas ao autor. Não se deve confundir imprescritibilidade da ação de reintegração com imprescritibilidade dos efeitos patrimoniais e funcionais dela decorrentes, sob pena de prestigiar a inércia do Autor, o qual poderia ter buscado seu direito desde a publicação da Constituição da República. Em outras palavras, o recebimento dos “atrasados” ficará restrito aos últimos 05 anos contados do pedido.

¹⁰⁷CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:<<https://www.Buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia>>.



Info 640

3ª Turma. REsp 1749941-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 04/12/2018.

4 Concessionária de rodovia não responde por roubo e sequestro ocorridos nas dependências de estabelecimento por ela mantido para a utilização de usuários. A segurança que a concessionária deve fornecer aos usuários diz respeito ao bom estado de conservação e sinalização da rodovia. Não tem, contudo, como a concessionária garantir segurança privada ao longo da estrada, mesmo que seja em postos de pedágio ou de atendimento ao usuário. O roubo com emprego de arma de fogo é considerado um fato de terceiro equiparável a força maior, que exclui o dever de indenizar. Trata-se de fato inevitável e irresistível e, assim, gera uma impossibilidade absoluta de não ocorrência do dano. Cuidado. O STF já reconheceu a responsabilidade civil da concessionária que administra a rodovia por FURTO ocorrido em seu pátio: STF. 1ª Turma. RE 598356/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/5/2018 (Info 901).

QUESTÕES

1. (TJMS) FCC, 2020. Em conhecido acórdão proferido em regime de repercussão geral, versando sobre a morte de detento em presídio – Recurso Extraordinário nº 841.526 (Tema 592) – o Supremo Tribunal Federal confirmou decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, calcada em doutrina que, no tocante ao regime de responsabilização estatal em condutas omissivas, distingue-a conforme a natureza da omissão. Segundo tal doutrina, em caso de omissão específica, deve ser aplicado o regime de responsabilização

A integral; em caso de omissão genérica, aplica-se o regime de responsabilização objetiva.

B objetiva; em caso de omissão genérica, aplica-se o regime de responsabilização subjetiva.

C subjetiva; em caso de omissão genérica, aplica-se o regime de responsabilização objetiva.

D objetiva; em caso de omissão genérica, não há possibilidade de responsabilização.

E subjetiva apenas em relação ao agente, exonerado o ente estatal de qualquer responsabilidade; em caso de omissão genérica, aplica-se o regime de responsabilização objetiva do ente estatal.

2. (TJPA) CESPE, 2019. Segundo o entendimento majoritário do STJ, no caso de ação indenizatória ajuizada contra a fazenda pública em razão da responsabilidade civil do Estado, o prazo prescricional é

A decenal, como previsto no Código de Processo Civil, em detrimento do prazo trienal previsto pelas normas de direito público.

B quinquenal, como previsto pelas normas de direito público, em detrimento do prazo decenal contido no Código de Processo Civil.

C trienal, como previsto pelo Código de Processo Civil, em detrimento do prazo quinquenal contido no Código Civil.

D quinquenal, como previsto pelas normas de direito público, em detrimento do prazo trienal contido no Código Civil.

E trienal, como previsto no Código Civil, em detrimento do prazo quinquenal contido no Código de Processo Civil.

3. (TJSC) CESPE, 2019. De acordo com o entendimento majoritário e atual do STJ, a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é

A objetiva, bastando que sejam comprovadas a existência do dano, efetivo ou presumido, e a existência de nexo causal entre conduta e dano.

B objetiva, bastando a comprovação da culpa *in vigilando* e do dano efetivo.

C subjetiva, sendo necessário comprovar negligência na atuação estatal, o dano causado e o nexo causal entre ambos.



D subjetiva, sendo necessário comprovar a existência de dolo e dano, mas sendo dispensada a verificação da existência de nexo causal entre ambos.

E objetiva, bastando que seja comprovada a negligência estatal no dever de vigilância, admitindo-se, assim, a responsabilização por dano efetivo ou presumido.

4. (TJBA) CESPE, 2019. A respeito da responsabilidade civil do Estado, julgue os itens a seguir.

I O Estado é responsável pela morte de detento causada por disparo de arma de fogo portada por visitante do presídio, salvo se comprovada a realização regular de revista no público externo.

II O Estado necessariamente será responsabilizado em caso de suicídio de pessoa presa, em razão do seu dever de plena vigilância.

III A responsabilidade do Estado, em regra, será afastada quando se tratar da obrigação de pagamento de encargos trabalhistas de empregados terceirizados que tenham deixado de receber salário da empresa de terceirização.

Assinale a opção correta.

A Apenas o item I está certo.

B Apenas o item III está certo.

C Apenas os itens I e II estão certos.

D Apenas os itens II e III estão certos.

E Todos os itens estão certos.

5. (MPE-BA) CEFETBA, 2018. Com relação à responsabilidade civil do Estado pela guarda e segurança das pessoas submetidas a encarceramento, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.

() É de responsabilidade do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a obrigação de ressarcir os danos comprovadamente causados aos detentos custodiados em presídios, em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento.

() O Estado responde pelos danos causados a detentos em decorrência da insuficiência das condições legais de encarceramento, salvo os danos morais individuais decorrentes da superlotação carcerária, por ser um problema de estrutura do sistema prisional, dependente de providências de atribuição legislativa e administrativa, podendo o Judiciário apreciar o dano moral apenas em sua dimensão coletiva.

() Quanto à responsabilidade pelos danos causados aos detentos, em decorrência da superlotação carcerária, a Corte Constitucional distingue o tratamento jurídico dado aos presos definitivos daquele conferido aos provisórios, haja vista que esses últimos sujeitam-se ao chamado risco social.

() Trata-se de tema abrangido pelo art. 37, § 6º, da Constituição Federal, preceito normativo autoaplicável, que não se sujeita à intermediação legislativa ou à providência legislativa.

() O Estado não pode invocar a reserva do possível para se eximir do dever de indenizar os danos pessoais causados a detentos em estabelecimentos carcerários, salvo se comprovar a insuficiência de recursos financeiros para eliminar o grave problema prisional globalmente considerado, dependente que é da definição e implantação de políticas públicas específicas.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

A V F F V F

B V F F V V

C V V F V V

D F V V F F

E F V V F V

COMENTÁRIOS

1. Gabarito - B

Todas as alternativas estão baseadas no Recurso Extraordinário 841.526 (Tema 592).



@cpiuris



www.cpiuris.com.br



contato@cpiuris.com.br



2. Gabarito - D

Todas as alternativas estão baseadas no REsp 1.251.933/PR.

3. Gabarito - C

Todas as alternativas estão baseadas no AgInt no AREsp 1249851/SP.

4. Gabarito - B

I- Errado. Cf. RE 841.526/RS.

II- Errado. Cf. RE 841.526/RS.

III- Certo. Cf. art. 67 da Lei 8.666/93. Ver também STF, Rcl 29240 AgR/SP.

5. Gabarito – A

I. Correta. Cf. art. 37, § 6º CRFB.

II. Incorreta. Cf. STF, RE 580252.

III. Incorreta. Cf. STF, RE 580252.

IV. Correta. Cf. art. 37, § 6º CRFB.

V. Incorreta. Cf. STF, RE 592581.



@cpiuris



www.cpiuris.com.br



contato@cpiuris.com.br

253



61 3033-3739



61 98442-2591

CAPÍTULO 12 — BENS PÚBLICOS

1 INTRODUÇÃO

Bens públicos são, segundo o art. 98 do CC, todos aqueles que pertencem a pessoas jurídicas de direito público.

Celso Antonio Bandeira de Melo¹⁰⁸ entende que, além dos bens que pertencem às pessoas jurídicas de direito público, são bens públicos aqueles que sejam afetados a prestação de um serviço público. Por exemplo, o bem de uma concessionária de direito público que esteja destinado à prestação de serviço público seria um bem público.

2. BENS DAS EMPRESAS PÚBLICAS E DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

É necessário diferenciar as empresas públicas e as sociedades de economia mista que prestam serviços públicos das empresas públicas e das sociedades de economia mista que exploram atividade econômica.

Em relação às empresas públicas e das sociedades de economia mista que prestam serviços públicos, seus bens terão natureza pública, sendo impenhoráveis, inalienáveis e imprescritíveis, além de impossibilidade de oneração.

O STF alarga esta ideia, estabelecendo que estas características irão se aplicar às empresas públicas e das sociedades de economia mista que exercem atividade econômica sob o regime de monopólio legal (Cf. RE 220.906).

Sobre o tema, reveja o item 3.5, especialmente sobre o regime híbrido aplicável às empresas públicas e sociedades de economia mista.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS PÚBLICOS

O CC, no art. 99, promove a classificação dos bens públicos:

- **Bens de uso comum do povo:** destinados ao uso comum, da coletividade, não havendo distinção de usuários. Ex.: rua, praia, mar, etc. Poderá haver restrições, como a instalação de cancela e cobrança de pedágio, desde que haja justificativa e isto não descaracteriza a natureza do bem. Por exemplo, a limitação de acesso de turistas em espaços ambientalmente protegidos.
- **Bens de uso especial:** são aqueles afetados a uma utilização pela administração, podendo ser utilizados pela administração ou por um particular, por meio de um ato unilateral ou bilateral, da administração. Ex.: permissão do uso, concessão, etc. Ou ainda qualquer bem que tenha restrição ou pagamento para determinado bem também terá uma natureza de bem de uso especial. Ex.: sede da prefeitura.
- **Bens dominicais:** os bens dominicais são bens do patrimônio disponível, pois estão desafetados. Estes bens podem ser alienados a qualquer momento. Estes bens também estão sujeitos à impenhorabilidade, imprescritibilidade, não sendo passíveis de oneração, mas poderão ser alienados. Esta alienação pressupõe autorização legislativa, avaliação e licitação.

Afetação é a preposição de um bem a um dado destino, seja de uso comum ou de uso especial. A afetação poderá ocorrer independentemente da conduta do Estado. Isto é, existem bens naturalmente afetados, como rios, mares, praias, etc. Agora, outros bens podem ser afetados por lei ou por ato administrativo (ex.: casa que se torna uma delegacia).

¹⁰⁸ MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Curso de Direito Administrativo** 33ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019, P.921.



Já a desafetação é a retirada da finalidade do bem. Os bens que sejam afetados por lei, por ato administrativo ou por fato administrativo são bens relativamente inalienáveis. Relativamente, pois se quiser aliená-los, basta desafetá-los, situação na qual deixam de ser bem comum de uso especial, já que esta destinação foi dada por lei ou por ato administrativo, havendo a promoção da desafetação, situação na qual se tornarão bens dominicais.

A desafetação do bem público, em regra, vai depender de lei ou de ato administrativo. É possível que essa desafetação também se dê por um fato administrativo, como um terremoto ou incêndio que destrói a repartição. A desafetação ocorre por meio de um ato de hierarquia igual ou superior ao ato responsável pela sua afetação.

Os bens de uso especial podem ser desafetados, enquanto os bens de uso comum do povo não podem ser desafetados, sendo absolutamente inalienáveis.

Quando irregularmente ocupado o bem público, **não há que se falar em direito de retenção pelas benfeitorias realizadas, tampouco em direito a indenização pelas acessões**, ainda que as benfeitorias tenham sido realizadas de boa-fé (Inf. 551, STJ).

4. POSSIBILIDADE DO USO DE BEM PÚBLICO PELO PARTICULAR

Dentro desse assunto interessa falar dos instrumentos estatais de outorga de títulos para que o uso de bens públicos seja utilizado pelo particular.

4.1. INSTRUMENTO ESTATAIS DE OUTORGA DE TÍTULOS PARA QUE O USO DE BENS PÚBLICOS SEJA UTILIZADO PELO PARTICULAR

4.1.1. AUTORIZAÇÃO DE USO

A autorização de uso é um instrumento utilizado pela administração para **viabilizar a utilização de um bem público pelo particular**.

Essa autorização é um **ato unilateral**, que vai independe de uma autorização prévia e legal, bem como irá **independe de uma licitação anterior**. É um **ato discricionário** e **precário**. A autorização é conferida **no interesse privado**.

Ex.: autorizações para comércio por vendedores ambulantes.

4.1.2. PERMISSÃO DE USO

A permissão de uso é um ato **unilateral, discricionário** e **precário**, por meio do qual a Administração legitima a autorização exclusiva de um bem público por um particular.

Na verdade, **a permissão é conferida no interesse preponderante da coletividade**, diferentemente da autorização.

A permissão de uso não depende de autorização legislativa, nem de licitação prévia, salvo se houver lei específica nesse sentido, ou quando se tratar de uma permissão qualificada, com prazo certo.

4.1.3. CONCESSÃO DE USO

A concessão de uso é **contrato administrativo**. A Administração através da concessão de uso legitima o **uso exclusivo** de um bem ao particular, com **caráter de estabilidade**.

A concessão poderá ser remunerada, mas também poderá ser gratuita. Neste caso, deverá ser precedida de uma **autorização legislativa** e de uma **licitação**.

Ex.: possibilidade de utilização de um hotel numa área de propriedade do Poder Público.



Podem ocorrer as seguintes **modalidades de concessão de uso**:

- Concessão de uso de exploração
- Concessão de simples uso

Isso vai depender se será conferido ou não ao concessionário o poder de gestão dominial, ou seja, como dono. Por exemplo haverá exploração como gestão de dono quando há concessão de minas ou de águas.

Haverá concessão de uso quando há concessão das áreas de aeroportos, sepulturas, etc. Não é concessão de exploração, pois não se quer angariar qualquer lucro.

A concessão poderá ter **caráter temporário** (como a concessão de água), ou a concessão poderá ter **caráter perpétuo** (como a concessão de sepultura).

A concessão também poderá ter **caráter remunerado** ou **gratuito**.

4.1.4. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO

Essa concessão também é um contrato administrativo, em que a administração transfere um direito real de uso. Um direito real de uso de bem público. Por exemplo o direito real de uso de um terreno, do espaço aéreo, etc.

A concessão de direito real de uso pode ser gratuita ou remunerada.

A concessão de direito real de uso depende de **autorização legislativa** e **prévia licitação, na modalidade concorrência**.

4.2. INSTRUMENTO PRIVADOS DE OUTORGA DE TÍTULOS PARA USO EXCLUSIVO DE BENS PÚBLICOS POR PARTICULARES

A utilização de instrumentos privados de outorga de títulos para uso exclusivo de bens públicos por particulares **só vai ser admitida para bens dominiais**.

4.2.1. LOCAÇÃO

Neste caso, a União, Estados, DF e municípios serão os locatários do bem. Haverá uma relação de direito privado.

Mesmo que se esteja diante de uma locação, quando ser pessoa jurídica de direito público, haverá uma derrogação de certas normas de direito privado, já que é preciso observar a supremacia do interesse público.

4.2.2. ENFITEUSE DOS TERRENOS DE MARINHA

A enfiteuse é um instrumento que permite que a União atribua a outra pessoa o domínio útil do terreno de Marinha, pagando por a remuneração anual, também chamada de **foro**. Apenas os terrenos de Marinha admitem a enfiteuse.

Esse domínio útil confere a transferência da posse, direito de uso, de gozo, em caráter perpétuo em favor do enfiteuta. A propriedade do terreno de Marinha é da União.

Caso o enfiteuta decidir vender o bem, neste caso **deverá observar o direito de preferência** do senhorio direto, que é a União. Se não for observado e efetivamente vendê-lo, a União terá o direito de preferência.

Caso a União não faça a utilização do direito de preferência, e o enfiteuta fazer a venda do bem, caberá à União o direito de perceber um valor, o qual é chamado de **laudêmio**.



Portanto, são duas as modalidades de remuneração que a União faz jus:

- **Foro:** é a remuneração anual que aquele detentor do domínio útil faz à União.
- **Laudêmio:** é o valor pago pelo foreiro ao senhorio direto, quando este não exerce o direito de preferência na alienação, tendo direito a este valor.

A **pena de comisso** é uma penalidade fixada em face do foreiro, implicando a extinção da enfiteuse pelo não pagamento do foro pelo período de **03 anos consecutivos**. Neste caso, o senhorio direto poderá reaver o domínio útil desse bem. Todavia, o senhorio direto deverá arcar com as benfeitorias necessárias, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

5. BENS PÚBLICOS EM ESPÉCIE

5.1. TERRAS DEVOLUTAS

Terras devolutas são terras de ninguém, que não são privadas e não estão sendo aplicadas para nenhum uso público. Na verdade, as terras devolutas não são terras de ninguém, pois, em regra, são bens dominiais, pertencendo, via de regra, aos Estados. **Excepcionalmente, as terras devolutas pertencerão à União**, quando:

- forem indispensáveis à **defesa das fronteiras**
- forem indispensáveis às **fortificações e construções militares**
- forem indispensáveis às **vias federais de comunicação**
- forem indispensáveis à **preservação do meio ambiente**

Essa é a literalidade do art. 20, II, da CF. Caso não seja essas hipóteses, em regra, serão do Estado. O STF confirmou este entendimento em março de 2020, ao declarar que as terras devolutas pertencem, em regra, aos Estados-membros, com exceção daquelas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, que são de propriedade da União (ACO 158/SP).

5.2. TERRENOS DE MARINHA

Terrenos de Marinha são áreas banhadas pelas águas do mar, ou áreas banhadas por rios navegáveis, na sua foz, **estendendo-se até a distância de 33 metros para área terrestre**, contados da linha do preamar médio de 1831.

Os terrenos de Marinha pertencem à União.

5.3. TERRENOS RESERVADOS

Terrenos reservados são os terrenos banhados por rios navegáveis que se estendem até a distância de 15 metros para a terra.

Esses terrenos reservados serão de propriedade da União, caso o rio seja federal, ou do Estado, caso seja estadual o rio.

Se o proprietário ribeirinho provar que tem a propriedade do imóvel, neste caso ele se submeterá a uma **servidão administrativa de 10 metros**, não havendo falar em indenização e nem desapropriação.

5.4. TERRAS TRADICIONALMENTE OCUPADAS PELOS ÍNDIOS

O art. 20, XI, da CF diz que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios pertencem à União.

São considerados **bens públicos de uso especial**.

Os índios terão direito ao **usufruto exclusivo** desses bens e em **caráter perpétuo**.



Há uma ressalva constitucional, que é no sentido de que o **Congresso Nacional**, após ouvir as comunidades indígenas afetadas, **poderá permitir que seja promovido o aproveitamento de recursos hídricos, pesquisa e lavra de minérios naquela região.**

Neste caso, **será assegurada à comunidade indígena a participação do produto da lavra.** Para isso, é necessária autorização do Congresso Nacional.

5.5. PLATAFORMA CONTINENTAL

Plataforma continental é bem da União. É o prolongamento das terras continentais sobre o mar **até a profundidade de 200 metros.** Essa plataforma poderá ter 1 km, por exemplo, no caso em que se distanciar tudo isso para se chegar à parte em que o mar apresenta 200 metros de profundidade. Da mesma forma poderá ter 4 km, caso em seguida haja a profundidade de 200 metros.

Não confundir a plataforma continental com o **mar territorial.** O mar territorial é uma faixa de 12 milhas marítimas de largura, começando da terra.

Não confundir com **zona contígua.** Essa zona contígua começa quando termina o mar territorial, sendo uma faixa de 12 a 24 milhas, onde o Brasil adota medidas destinada à fiscalização para evitar violações ao ordenamento.

Não confundir plataforma continental com **zona econômica exclusiva.** A zona econômica exclusiva é a faixa de 12 a 200 milhas, onde o Brasil exercer a sua soberania para exploração de recursos naturais.

5.6. RIOS

Os rios são públicos quando **navegáveis e fluviáveis.**

Pertencerão à **União** os rios que:

- estiverem dentro de sua área de domínio
- percorrem mais de um Estado
- são limítrofes com outros países
- se estendem ao território estrangeiro ou dele provenham

Fora dessas hipóteses, os rios pertencerão aos Estados.

5.7. FAIXA DE FRONTEIRA

Faixa de fronteira é uma área de 150 km de largura, que vai correr paralelamente à linha divisória do território nacional. Essa faixa é contada da linha divisória entre os países e conta-se 150 km para dentro do Brasil.

Nessa faixa de fronteira haverá bens públicos e particulares.

5.8. ILHAS

Serão bens da União:

- ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países
- ilhas oceânicas e costeiras, salvo as ilhas que contenham sede de municípios, exceto se dentro desses municípios aquelas que estejam afetadas ao serviço público federal ou à unidade ambiental federal.

As áreas que estiverem sob o domínio do Estado, dentro da ilha, vão pertencer ao Estado membro.



6. TESES DO STJ

- 1) Os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedades de economia mista sujeitos a uma destinação pública equiparam-se a bens públicos, sendo, portanto, insuscetíveis de serem adquiridos por meio de usucapião.
- 2) Os imóveis administrados pela Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap são públicos e, portanto, insuscetíveis de aquisição por meio de usucapião.
- 3) O imóvel vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação - SFH, porque afetado à prestação de serviço público, deve ser tratado como bem público, não podendo, pois, ser objeto de usucapião.
- 4) É possível reconhecer a usucapião do domínio útil de bem público sobre o qual tinha sido, anteriormente, instituída enfiteuse, pois, nessa circunstância, existe apenas a substituição do enfiteuta pelo usucapiente, não havendo qualquer prejuízo ao Estado.
- 5) É incabível a modificação unilateral pela União do valor do domínio pleno de imóvel aforado, incidindo somente a correção monetária na atualização anual do pagamento do foro na enfiteuse de seus bens (art. 101 do Decreto-Lei n. 9760/1946).
- 6) As concessões de terras devolutas situadas na faixa de fronteira, feitas pelos Estados, autorizam, apenas, o uso, permanecendo o domínio com a União, ainda que se mantenha inerte ou tolerante, em relação aos possuidores. (Súmula n. 477/STF)
- 7) Terras em faixas de fronteira e aquelas sem registro imobiliário não são, por si só, terras devolutas, cabendo ao ente federativo comprovar a titularidade desses terrenos.
- 8) O descumprimento de encargo estabelecido em lei que determinara a doação de bem público enseja, por si só, a sua desconstituição.
- 9) A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. (Súmula n. 619/STJ)
- 10) Construção ou atividade irregular em bem de uso comum do povo revela dano presumido à coletividade, dispensada prova de prejuízo em concreto.
- 11) Os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha não são oponíveis à União. (Súmula n. 496/ STJ)

7. JURISPRUDÊNCIA

7.1. SÚMULAS DO STF

Súmula 650: Os incisos I e XI do art. 20 da Constituição Federal não alcançam terras de aldeamentos extintos, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto.

Súmula 479: As margens dos rios navegáveis são domínio público, insuscetíveis de expropriação e, por isso mesmo, excluídas de indenização.

Súmula 477: As concessões de terras devolutas situadas na faixa de fronteira, feitas pelos estados, autorizam, apenas, o uso, permanecendo o domínio com a união, ainda que se mantenha inerte ou tolerante, em relação aos possuidores.

7.2. SÚMULAS DO STJ

Súmula 103: Incluem-se entre os imóveis funcionais que podem ser vendidos os administrados pelas forças armadas e ocupados pelos servidores civis.



Súmula 496: Os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha não são oponíveis à União

7.3. INFORMATIVOS DO STF¹⁰⁹

Info 969

Plenário. ACO 158/SP, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 12/3/2020.

As terras devolutas pertencem, em regra, aos Estados-membros, com exceção daquelas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, que são de propriedade da União (art. 20, II, da CF/88). As terras devolutas pertencem aos Estados-membros desde a Constituição de 1891, que delas excetuava apenas a porção do território indispensável para a defesa das fronteiras, fortificações, construções militares e estradas de ferro federais. Esse mesmo tratamento jurídico foi mantido, com pequenas variações, nas Constituições de 1934, 1937, 1946, 1967, EC 1 de 1969 e, finalmente, na Constituição Federal de 1988. Caso concreto: no Estado de São Paulo havia uma grande área que era considerada como terra devoluta. Diante disso, em 1939, o Estado ajuizou ação discriminatória para regularizar essa área, tendo o pedido sido julgado procedente, com a expedição de títulos de domínio das terras em favor do autor. A União, posteriormente, propôs ação anulatória alegando que as referidas terras seriam de sua propriedade desde 1872, por anexação. O Estado de São Paulo, por sua vez, alegou que eram terras devolutas, e, por isso, passíveis de alienação a particulares. Apesar de inexistente, à época, qualquer registro imobiliário no sentido de se cuidar de terras devolutas, não se exigiria prova nesse sentido, pois a regra então vigente era no sentido da presunção da natureza devoluta dessas terras. Assim, havia presunção de que eram terras devolutas e cabia à União o ônus de provar que adquiriu as terras por meio de compra ou anexação; que as terras lhe eram úteis; e a exata individuação para fins de saber se elas coincidem com as áreas em relação às quais o estado de São Paulo expediu os títulos que se pretende anular. É possível concluir que a União adquiriu terras na região, mediante compra ou anexação. Entretanto, não há provas de que essas terras tenham sido efetivamente úteis para o suposto fim original a que se prestariam. Além disso, não há qualquer precisão na individuação dessas terras à época da aquisição. A União não se desincumbiu de seu ônus probatório.

7.4. INFORMATIVOS DO STJ¹¹⁰

Informativo n. 660

REsp 1.770.001-AM, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019

Não configura desapropriação indireta quando o Estado limita-se a realizar serviços públicos de infraestrutura em gleba cuja invasão por particulares apresenta situação consolidada e irreversível.

Informativo n. 658. REsp 1.765.707-RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 15/08/2019, DJe 11/10/2019.

¹⁰⁹CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:<<https://www.Buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia>>.

¹¹⁰CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:<<https://www.Buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia>>.

O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança da multa prevista no § 2º do art. 116 do Decreto-Lei n. 9.760/1946 é a data em que a União tem ciência efetiva da ausência de transferência das obrigações enfiteúticas.

Informativo n. 655.

REsp 1.650.730-MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 20/08/2019, DJe 27/08/2019.

É inadequada a discussão acerca da tradicionalidade da ocupação indígena em ação possessória ajuizada por proprietário de fazenda antes de completado o procedimento demarcatório.

Informativo n. 655.

REsp 1.650.730-MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 20/08/2019, DJe 27/08/2019.

Não cabe produção de laudo antropológico em ação possessória ajuizada por proprietário de fazenda ocupada por grupo indígena.

QUESTÕES

1. (TJMS) FCC, 2020. No tocante ao domínio público, considera-se

A investidura: a alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de área remanescente ou resultante de obra pública, sendo hipótese de dispensa de licitação, desde que obedecidos os requisitos e limites estatuídos na Lei nº 8.666/1993.

B direito de extensão: a prerrogativa que a Administração Pública possui de ampliar a desapropriação para áreas contíguas que sejam necessárias ao melhor aproveitamento da obra ou serviço que resultarão do ato expropriatório.

C terrenos de marinha: áreas que, banhadas pelas correntes navegáveis, fora do alcance das marés, vão até a distância de 15 metros para a parte de terra, contados desde o ponto médio das enchentes ordinárias.

D faixa de segurança: a faixa interna de 150 km (cento e cinquenta quilômetros) de largura, paralela à linha divisória terrestre do território nacional.

E zona contígua brasileira: faixa que se estende das doze às duzentas milhas marítimas, contadas a partir das linhas de base que servem para medir a largura do mar territorial.

2. (MPE-CE) CESPE, 2020. As terras devolutas indispensáveis à preservação do meio ambiente são consideradas bens

A de uso comum do povo de titularidade dos municípios.

B de uso especial de titularidade dos estados.

C dominicais de titularidade dos estados.

D de uso comum do povo de titularidade da União.

E dominicais de titularidade da União.

(TJRJ) VUNESP, 2019. Foi registrado um loteamento que, entretanto, nunca foi implantado. Judas e sua família construíram e começaram a morar numa área que seria destinada a ser um logradouro público. Após 10 anos de ocupação mansa e pacífica, mediante moradia com sua família, Judas ajuizou uma ação de usucapião.

É correto afirmar que a usucapião

A não poderá ser reconhecida, tendo em vista que não decorreu o prazo de 15 anos da usucapião extraordinária, quando então poderá ser reconhecida.

B poderá ser reconhecida, independentemente da dimensão da área ocupada, tendo em vista que se presume o justo título e boa-fé, em razão da longevidade da posse e da sua função social.



C poderá ser reconhecida, desde que o imóvel tenha dimensão inferior a 250 m² e Judas não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

D somente poderá ser reconhecida a usucapião se houver a citação de todos os confrontantes e ausência de oposição do loteador e da Municipalidade.

E não poderá ser reconhecida, pois os bens públicos são imprescritíveis.

4. (TJAL) FCC, 2019. Suponha que uma autarquia estadual pretenda alienar alguns imóveis de sua propriedade, objetivando a obtenção de receitas para a aquisição de um imóvel situado em região mais central da cidade e no qual pretende concentrar suas atividades. Considerando o regime jurídico aplicável aos bens públicos, bem como as disposições da Lei federal nº 8.666/1993,

A as alienações e as aquisições prescindem de autorização legislativa, devendo, contudo, haver despacho motivado do dirigente da autarquia, avaliação prévia dos imóveis e adoção de procedimento licitatório para cada um dos negócios jurídicos, na modalidade leilão ou concorrência.

B a aquisição do novo imóvel depende de prévia autorização legislativa para afetação às finalidades da autarquia, devendo ser efetuada por procedimento licitatório na modalidade concorrência, aplicando-se as mesmas exigências em relação às alienações.

C o caráter de inalienabilidade dos imóveis pertencentes à entidade de direito público impede a sua venda, salvo em se tratando de aquisição por meio de desapropriação.

D as alienações dependem de prévia autorização legislativa, admitindo-se a permuta de imóvel(is) que se pretende alienar por outro que atenda às necessidades atuais de instalação e localização da autarquia, com dispensa de licitação, observados os valores de mercado.

E a autarquia poderá vender ou permutar os imóveis em questão, mediante autorização legislativa específica para o negócio jurídico escolhido, afastando-se, em ambos os casos, a necessidade de prévio procedimento licitatório.

5. (MPE-MT) FCC, 2019. Mares e rios, terrenos e edifícios destinados aos serviços da Administração pública são exemplos de bens públicos, respectivamente,

A de uso especial.

B de uso comum do povo e dominicais.

C de uso comum do povo.

D dominicais.

E de uso comum do povo e de uso especial.

COMENTÁRIOS

1. Gabarito - A

A) Correta. Cf. art. 17, § 3º, I, da Lei 8.666/93.

B) Incorreta. A assertiva se refere à desapropriação por zona, prevista no art. 4º do Decreto-Lei 3.365/41.

C) Incorreta. Cf. art. 2º do Decreto-lei nº 9.760/46.

D) Incorreta. Cf. art. 20, §2º, da CRFB/88

E) Incorreta. A zona contígua brasileira compreende uma faixa que se estende das doze às vinte e quatro milhas marítimas, contadas a partir das linhas de base que servem para medir a largura do mar territorial.

2. Gabarito - E

A) Incorreta. Cf. art. 20, II, da CRFB.

B) Incorreta. Cf. art. 20, II, da CRFB.

C) Incorreta. Cf. art. 20, II, da CRFB.

D) Incorreta. As terras devolutas são classificadas pela doutrina como bens dominicais ou de uso especial.

E) Correta. Cf. art. 20, II, da CRFB.



3. Gabarito - E

- A) Incorreta. A usucapião não se aplica aos bens públicos.
- B) Incorreta. A usucapião não se aplica aos bens públicos.
- C) Incorreta. A usucapião não se aplica aos bens públicos.
- D) Incorreta. Cf. Súmula nº 340 do STF.
- E) Correta. Súmula nº 340 do STF.

4. Gabarito - D

- A) Incorreta. Deve haver autorização legislativa. Cf. art. 17, "caput" e inciso I c/c art. 24, X Lei nº 8.666/93.
- B) Incorreta. A licitação é dispensada. Cf. art. 17, "caput" e inciso I c/c art. 24, X Lei nº 8.666/93.
- C) Incorreta. É possível a alienação. Cf. art. 17, "caput" e inciso I c/c art. 24, X Lei nº 8.666/93.
- D) Correta
- E) Incorreta. Somente no caso de permuta é possível a dispensa. Cf. art. 17, "caput" e inciso I c/c art. 24, X Lei nº 8.666/93.

5. Gabarito - E

- A) Incorreta. Cf. art. 99 do Código Civil.
- B) Incorreta. Cf. art. 99 do Código Civil.
- C) Incorreta. Cf. art. 99 do Código Civil.
- D) Incorreta. Cf. art. 99 do Código Civil.
- E) Correta



CAPÍTULO 13 — INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

1. INTRODUÇÃO

No Brasil a ordem econômica se pauta **pelo princípio da subsidiariedade**. Em outras palavras, a iniciativa privada ocupará o papel principal, e o Poder Público só atuará diretamente em situações excepcionais, nos limites impostos pelo art. 173 CRFB: para atender aos imperativos de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Como explica Luís Roberto Barroso¹¹¹:

No sistema de sociedade aberta e de economia de mercado — que é nosso modelo constitucional — a atividade econômica pública é complementar da iniciativa privada, dominada pelo princípio da subsidiariedade e ocupando os espaços vazios dos quais se ausenta a iniciativa privada ou quando esta fracassa.

Assim o Estado deve, na medida do possível, abandonar a **intervenção direta** no domínio econômico. Intervenção direta é realizada quando o Estado presta serviços e produz bens através de seus próprios órgãos; ou ainda quando o faz através de suas empresas estatais, sendo o chamado Estado empresário, típico por exemplo do Brasil pós Segunda Guerra Mundial.

Na década de 1990 o Estado brasileiro era considerado demasiadamente grande e ineficiente. A influencia do neoliberalismo levaram a adoção do modelo de intervenção indireta, com o perfil de Estado Regulador: quando ele se limita a elaborar normas, reprimir abusos, interferir na iniciativa privada e regular preços e abastecimento. Atuando como regulador o Estado impõe normas e mecanismos com o intuito de punir e/ou prevenir condutas abusivas que possam vir a prejudicar a harmonia social, de acordo com o art. 174 CRFB.

A fiscalização se dá através do poder de polícia conferido às Agências Reguladoras e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

O incentivo normalmente se dá por meio da cessão de créditos e benefícios fiscais

O planejamento significa a previsão governamental aplicação de recursos públicos em determinados setores da economia, o que significa planificar os cursos dos mercados. Por exemplo decidindo promover a construção de casas populares como forma de incentivar o setor de construção civil. Também pode ocorrer através de planos econômicos e tabelamento de preços

O fomento incentiva a indústria e o comércio, seja através de legislação favorável à exploração da atividade ou, inclusive, por incentivos tributários, por exemplo.

A regulamentação se dá pela intervenção do Estado com o objetivo de implementar políticas que promovem os valores sociais e os direitos fundamentais.

2. PRINCÍPIOS DA ORDEM ECONÔMICA

São princípios que norteiam a ordem econômica, segundo o art. 170:

- soberania nacional
- propriedade privada
- função social da propriedade
- livre concorrência
- defesa do consumidor
- defesa do meio ambiente

¹¹¹BARROSO, Luís Roberto. Regime jurídico das empresas estatais. *Revista de direito administrativo*, v. 242, p. 87.



- redução das desigualdades regionais e sociais
- busca do pleno emprego

Percebe-se que o Brasil adota um sistema capitalista, pois prestigia a livre concorrência e a livre iniciativa, mas sem se descuidar das questões sociais. Nesta linha a livre iniciativa e a livre concorrência devem ser ponderadas com os valores de justiça social.

3. ATUAÇÃO REGULATÓRIA

O Estado pode atuar de forma regulatória, a qual **tem um objetivo de reprimir o abuso do poder econômico, para interferir na iniciativa privada, e, caso haja necessidade, para controlar preços e regular o abastecimento.**

3.1. REPRESSÃO DO ABUSO DO PODER ECONÔMICO

Abuso é exercício irregular de um direito. O abuso do poder econômico poderá se revelar de diversas maneiras, tais como ocorre com:

- **Dominação de mercados**
- **Eliminação da concorrência**
- **Aumento arbitrário dos lucros**
- **Truste:** algumas empresas que dominam o mercado pressionem os concorrentes, dominando o mercado, inclusive suprimindo ou eliminando a concorrência
- **Cartel:** é um acordo entre empresas para impor determinados preços e impedir novos concorrentes e assim os eliminando
- **Dumping:** empresa pratica preços abaixo do preço de custo, visando eliminar a concorrência. Após a eliminação do concorrente, ela aumenta arbitrariamente os lucros.

Uma das formas de repressão do abuso do poder econômico se dá através do **CADE**, que é o **Conselho Administrativo de Defesa Econômica**. Regulado pela Lei nº 12.529/2011. Trata-se de uma autarquia federal, **vinculada ao Ministério da Justiça**. Possui o CADE competência de um Tribunal Administrativo, tendo atribuição para julgar processos quando há formação de cartéis, monopólios privados, aumento arbitrários dos lucros, combater a prática do dumping, trustee, cartel etc.

O CADE pode, agir preventivamente, apreciando as fusões e incorporações de grandes grupos econômicos, cuja união poderá resultar em concentração de mercado e consequentemente potenciais violações da livre concorrência.

4. INTERVENÇÃO DIRETA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA

A intervenção do Estado também poderá se dar de forma direta, no exercício da atividade econômica deverá ser considerada como uma exceção.

Isso porque o art. 173 da CF diz que a exploração direta do Estado na atividade econômica só será permitida quando ela se mostrar necessária aos **imperativos da segurança nacional** ou **quando houver um relevante interesse coletivo**, conforme definido em lei.

Essa intervenção poderá se dar através do monopólio de produção, exercido principalmente pelas empresas públicas e sociedades de economia mista.

Monopólio é supressão da atividade do regime de livre iniciativa, só podendo o Estado exercer certa atividade, com o dever de fazê-lo para beneficiar a coletividade. O monopólio privado é inconstitucional. O art. 177 da CF prevê um monopólio da União para algumas atividades:

- Pesquisa e lavra de jazidas de petróleo e gás natural



- Refinação do petróleo
- Importação e exportação de produtos e derivados básicos de petróleo e gás natural
- Transporte marítimo de petróleo bruto ou de derivados básicos de petróleo
- Transporte por meio de qualquer conduto de petróleo bruto ou de derivados básicos de petróleo ou de gás natural
- Pesquisa, lavra, enriquecimento, reprocessamento, industrialização e comércio de minério e minerais nucleares, com exceção dos radioisótopos, podendo a sua produção e sua comercialização, inclusive o seu uso, poderão ser autorizados sob o regime de produção.

Outros monopólios estatais podem ser encontrados nos Art. 176F, Art. 177, I a V, Art. 21, XXIII c/c Art. 177, V todos da CRFB.

O monopólio se caracteriza pela detenção exclusiva de determinadas atividades pelo Estado. Caso o Poder Público decida por delegar o direito de execução de suas atividades a poucos selecionados, que atendam a requisitos impostos pelo estado ocorrerá a delegação. Hely Lopes Meirelles¹¹² esclarece que:

Monopolizado pela União um bem ou uma atividade do domínio econômico, nada impede que ela confira o *privilegio* de sua exploração a autarquias, a fundações públicas, a empresas estatais, a concessionários ou a permissionários que satisfaçam as exigências do interesse público. O monopólio não se confunde com o privilégio. *Monopólio* é a detenção exclusiva do bem ou da atividade por uma só pessoa; *privilegio* é a delegação do direito de exploração do bem ou da atividade monopolizada a um ou alguns interessados. Só pode dar *privilegio* quem tem o *monopólio*. O monopólio é sempre exclusivo e excludente dos demais interessados; o privilégio pode ser exclusivo ou não.

Atente-se que o fato de a União ter o monopólio **não impede que a União contrate empresas estatais ou privadas para realização das atividades ligadas a petróleo e gás natural**. Entende-se que a EC nº 09 de 1995 flexibilizou o monopólio estatal em petróleo e gás: antes o setor era explorado em regime de monopólio de produção, onde apenas a PETROBRAS estava autorizada a atuar no setor. A EC nº 09/95 atribuiu unicamente à União o direito a escolher como o setor de petróleo e gás passaria a se desenvolver: com a manutenção do monopólio da PETROBRAS, ou permitindo que empresas privadas nacionais ou estrangeiras passassem a explorar e produzir petróleo no país. Em outras palavras, no texto original da CRFB o monopólio era uma imposição do legislador constituinte. Após a EC nº 09/1995 a alteração da política econômica para o setor, por exemplo retornando algumas áreas para ação monopolizada, basta a edição de lei ordinária. Foi exatamente o que ocorreu, por exemplo, na criação da primeira versão do contrato de partilha de produção, onde a PETROBRAS atuaria como operadora única ou necessária.

Assim uma lei ordinária poderá estabelecer outros monopólios, mas apenas para fins de serviços públicos, não podendo fazer para fins de serviços privados. Por exemplo no serviço postal.

Para a melhor compreensão, recomenda-se a leitura dos itens sobre agências reguladoras (3.3.4), empresas estatais (3.5) e serviços públicos (10).

5. JURISPRUDÊNCIA

5.1. SÚMULAS DO STF

Súmula vinculante 49: Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área.

¹¹²MEIRELLES, Hely Lopes. **Direito Administrativo Brasileiro** 43a. edição. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 611.



Súmula Vinculante 38: É competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.

5.2. INFORMATIVOS DO STF

ADPF 46, rel. p/ o ac. min. Eros Grau, j. 5-8-2009, P, DJE de 26-2-2010
serviço postal – conjunto de atividades que torna possível o envio de correspondência, ou objeto postal, de um remetente para endereço final e determinado – não consubstancia atividade econômica em sentido estrito. Serviço postal é serviço público. A atividade econômica em sentido amplo é gênero que compreende duas espécies, o serviço público e a atividade econômica em sentido estrito. Monopólio é de atividade econômica em sentido estrito, empreendida por agentes econômicos privados. A exclusividade da prestação dos serviços públicos é expressão de uma situação de privilégio. Monopólio e privilégio são distintos entre si; não se os deve confundir no âmbito da linguagem jurídica, qual ocorre no vocabulário vulgar. A Constituição do Brasil confere à União, em caráter exclusivo, a exploração do serviço postal e o correio aéreo nacional (art. 21, X). O serviço postal é prestado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), empresa pública, entidade da administração indireta da União, criada pelo DL 509, de 10 de março de 1969. É imprescindível distinguirmos o regime de privilégio, que diz com a prestação dos serviços públicos, do regime de monopólio sob o qual, algumas vezes, a exploração de atividade econômica em sentido estrito é empreendida pelo Estado. A ECT deve atuar em regime de exclusividade na prestação dos serviços que lhe incumbem em situação de privilégio, o privilégio postal. Os regimes jurídicos sob os quais em regra são prestados os serviços públicos importam em que essa atividade seja desenvolvida sob privilégio, inclusive, em regra, o da exclusividade. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente por maioria. O Tribunal deu interpretação conforme à Constituição ao art. 42 da Lei 6.538 para restringir a sua aplicação às atividades postais descritas no art. 9º desse ato normativo.

5.3. INFORMATIVOS DO STJ

Informativo n. 641. REsp 1.543.465-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, por unanimidade, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019

A reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários mínimos, prevista no art. 40, I, do Estatuto do Idoso, não se limita ao valor das passagens, abrangendo eventuais custos relacionados diretamente com o transporte, em que se incluem as tarifas de pedágio e de utilização dos terminais.

QUESTÕES

1. (DPE-MT) UFMT, 2016. Na Europa ou na América Latina, a atividade reguladora estatal ganhou força a partir da segunda metade do século XX, num quadro relacionado a políticas inspiradas na redefinição do papel do Estado. Implementaram-se programas de desestatização que privilegiaram a atividade privada, em detrimento da atuação direta do Estado em setores diversos, abrangendo áreas relacionadas a serviços considerados de interesse social.

(CARVALHO, C. E. V. de. Regulação de serviços públicos: na perspectiva da constituição econômica brasileira. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2007.)



Assinale a afirmativa relacionada ao sentido social atribuído à atividade regulatória estatal por construção doutrinária.

A Os objetivos sociais da atividade reguladora estatal devem ser dissociados de seus objetivos econômicos, a fim de garantir a consecução de interesses que não podem ser atingidos por meio da livre concorrência.

B Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este indicativo para os setores público e privado.

CA disciplina reguladora exercida pelo Estado conduz à maior eficiência produtiva ou alocativa, se comparada às soluções próprias e espontâneas do mercado.

D As políticas regulatórias de caráter redistributivo, além dos objetivos econômicos de estímulo à concorrência e à eficiência, visam implementar metas sociais como a universalização do acesso a serviços essenciais.

E Quando o Estado não atua diretamente no mercado como produtor de bens e serviços, a regulação funciona como um mecanismo para corrigir falhas de mercado e estabelecer um regime concorrencial.

2. (MPDF), MPDF, 2015. Julgue os itens a seguir:

I. Afronta o princípio da livre concorrência, lei distrital que impeça a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área.

II. As disposições constitucionais que disciplinam a forma de exploração do monopólio da União sobre a pesquisa e lavra das jazidas de petróleo não permitem a edição de um marco legal que confira tratamento privilegiado a empresas estatais na execução dessas atividades.

III. O acordo de leniência declarado cumprido pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica não impede a propositura de ação penal contra os beneficiários desta medida caso o Ministério Público não tenha também subscrito o acordo.

IV. A caracterização de infração à ordem econômica independe da forma exteriorizada da conduta.

V. A verificação de paralelismo consciente de preços entre empresas concorrentes não é suficiente para caracterização de infração à ordem econômica no Brasil.

Estão CORRETOS os itens:

AI, II e IV.

BI, III e V.

CII e IV.

DI, IV e V.

EII e III.

3. (PGNF) ESAF, 2015. No concernente à intervenção do Estado no domínio econômico, indique a opção incorreta.

A Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, o serviço postal não consubstancia atividade econômica em sentido estrito, porquanto se trata de exclusividade na prestação de serviços, denotando, assim, situação de privilégio.

B Na intervenção por absorção ou participação o Estado atua como agente econômico.

CO Estado, por meio da intervenção por direção, utiliza-se de comandos imperativos que, se forem descumpridos, sujeitam o infrator a sanções negativas.

DA exploração de atividade econômica pelas empresas públicas e sociedades de economia mista constitui intervenção estatal indireta no domínio econômico.

EA atividade econômica em sentido amplo é gênero que compreende duas espécies, o serviço público e a atividade econômica em sentido estrito.

4.(PGE-PI) CESPE, 2014. No que concerne à intervenção do Estado no domínio econômico, assinale a opção correta.

AÉ vedada ao Estado a outorga de privilégios a particulares como forma de fomento da atividade econômica.

B As hipóteses de monopólio estatal estão previstas expressamente na CF, não se admitindo a ampliação dessas hipóteses por legislação infraconstitucional.

C Vedado pela CF e pela Lei de Defesa da Concorrência, o monopólio natural ocorre quando um setor da economia é dominado por um único agente econômico, em razão da exploração patenteada e exclusiva de determinado fator de produção.

DO monopólio convencional não pode ser objeto de intervenção do Estado, por não constituir prática abusiva.

E Ao passo que garante aos estados o monopólio dos serviços locais de gás canalizado, a CF veda a delegação da prestação desses serviços a terceiros por meio de concessão.

5. (PGE-PI) CESPE, 2014. Assinale a opção correta a respeito das disposições constitucionais que regulam a intervenção do Estado no domínio econômico.

A Nas hipóteses constitucionalmente previstas de exploração de atividade econômica diretamente pelo Estado, essa atividade deverá ser exercida por meio das empresas estatais, ou seja, empresas públicas e sociedades de economia mista.

B Somente por lei específica poderá ser criada empresa pública ou sociedade de economia mista.

C Às empresas estatais é permitido o exercício de atividade econômica em sentido estrito, sendo-lhes defeso prestar serviços públicos.

DA regulação de atividades econômicas pelo Estado é excepcional, admitida apenas quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou ao atendimento de relevante interesse coletivo.

EA definição das hipóteses que configuram imperativos da segurança nacional ou relevante interesse coletivo compete ao presidente da República, por meio de decreto presidencial, ouvido previamente o Conselho da República.

COMENTÁRIOS

1. Gabarito - D

A) Incorreta. Cf. Art. 3º c/c 170, VII e 173 CRFB.

B) Incorreta. Cf. art. 173 CRFB.

C) Incorreta. Cf. Art. 3º c/c 170, VII e 173 CRFB.

D) Correta. Cf. Art. 3º III e 170, VII da CRFB.

E) Incorreta. Cf. Art. 177, § 2º III CRFB.

2. Gabarito - D

I – Correta. Súmula Vinculante 49.

II – Incorreta. Cf. art. 177 c/c art. 150 III “b” CRFB.

III – Incorreta. Art. 87 Lei nº 12.529/11.

IV – Correta.

V – Correta. Cf. art. 36 § 3º, I, “a” da lei 12.529/11.

3. Gabarito - D

A) Correta. STJ, AgRg no REsp 1400238/RN.

B) Correta. Há três modalidades de intervenção: por absorção ou participação, por direção e por indução.

C) Correta. Trata-se das modalidades direção e indução.

D) Incorreta. Cf. art. 173 CRFB

E) Correta. Cf. art. 173 e art. 175 CRFB

4. Gabarito - B

A) Incorreta. Art. 170 CRFB.

B) Correta Art. 146 CRFB



C) Incorreta. O monopólio natural é permitido pela CRFB, já que não configura prática abusiva. Art. 36 § 1º Lei 12.529/11.

D) Incorreta. O monopólio convencional constitui prática abusiva: art. 173, §4º, da CRFB Lei 12.529/2011.

E) Incorreta. O monopólio convencional constitui prática abusiva: art. 173, §4º, da CRFB Lei 12.529/2011.

5. Gabarito - A

A) Correta

B) Incorreta. Cf. art. 37, inciso XIX, da CF.

C) Incorreta. Cf. Art. 175 CRFB.

D) Incorreta. Cf. arts. 173 e 174 CRFB

E) Incorreta. Cf. Art. 173 CRFB.



CAPÍTULO 14 — PROCESSO ADMINISTRATIVO

O processo administrativo federal é regulado pela Lei 9.784/99, que estabelece suas regras gerais. Trata-se de uma lei subsidiária, que será aplicada se não houver regulação específica em sentido contrário. Por outro lado, **se não houver uma lei tratando sobre processo administrativo para uma situação específica, ela deverá ser aplicada integralmente**. Por exemplo a Lei nº 9.605/98 e o Decreto 6.514/2008 versam sobre o processo administrativo para apuração das infrações ambientais, para essas situações a Lei nº 9.784/99 só será aplicada subsidiariamente.

Na mesma linha a competência para legislar sobre Direito Administrativo, via de regra é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal e estendida aos Municípios (cf. art. 24 e 30 CRFB/88). Sendo assim todos os Entes federativos são competentes para legislar sobre procedimentos administrativos. Por essa razão a Lei nº 9.784/99 é aplicável, a rigor, somente na esfera federal. Caso essa norma fosse aplicada aos demais Entes haveria uma clara violação à autonomia federativa.

Porém, o STJ já dispôs que, caso inexistam normas locais sobre processo administrativo, é possível a aplicação subsidiária da Lei nº 9.874/99, já que essa norteia toda a Administração Pública, podendo servir como parâmetro para os demais Entes Federativos (Súmula STJ 633). Mas, caso o estado ou município já tenham legislado sobre processo administrativo, não será possível a aplicação da Lei nº 9.784/99.

O processo administrativo é norteado pela busca da verdade real: a Administração deseja saber o que de fato ocorreu, pois há interesse público na descoberta da verdade. Os interesses em jogo não são transigíveis, são indisponíveis, logo deve-se apurar com cuidado os fatos. É interesse do Estado descobrir quem praticou o ilícito, pois é esta pessoa deverá ser afastada do trato com a coisa pública. A busca pela verdade real decorre da característica do processo administrativo, onde, diferentemente do processo judicial, a posição do agente público não é passiva. É sim ativa, voltada à justiça distributiva traduzida no atingimento do interesse público. Na mesma linha a Administração deve tomar decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade, não se satisfazendo somente com a verdade oferecida pelos sujeitos. Ela não pode ignorar fatos que conhece, sob a alegação de que tais elementos fáticos não constam dos autos.

Em síntese, há **um impulso oficial**: o processo administrativo não depende de provocação da parte, o próprio Poder Público deve impulsioná-lo. Na mesma linha processo administrativo é, em regra, formal, devendo cumprir todas as determinações previstas em lei, ainda que não tenha um rito processual tão rígido como o Processo Civil, permitindo certa discricionariedade. O processo administrativo deve, ainda, respeitar a celeridade, como uma garantia.

A denúncia anônima é suficiente para instauração de processo administrativo. A lei 8.112/90 fala claramente que não se admite a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, mas o STJ já sumulou o contrário: a Administração pode verificar se a denúncia tem um mínimo de plausibilidade para seguir adiante (súmula 611).

É vedada a cobrança de taxas para despesas no processo administrativo (Súmula Vinculante 21).

1. PRINCÍPIOS

Segundo o art. 2º da Lei 9.784, a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da:

- **Legalidade**
- **Finalidade**
- **Motivação**
- **Razoabilidade**
- **Proporcionalidade**
- **Moralidade**
- **Ampla defesa**
- **Contraditório**



- **Segurança jurídica**
- **Interesse público**
- **Eficiência**

Segundo Marçal Justen Filho a sanção administrativa apresenta semelhanças com a sanção penal. Consequentemente os princípios fundamentais do Direito Processual Penal podem ser aplicados no âmbito do Direito Administrativo, especialmente no sancionador. Principalmente os princípios necessários ao respeito da dignidade da pessoa humana, tais como o da igualdade, presunção de inocência, devido processo legal, legalidade, ampla defesa dentre outros.

1.1. MOTIVAÇÃO

O princípio da motivação obriga a Administração Pública a exteriorizar o fundamento de sua decisão. A Lei nº 9.784/99, no seu artigo 50, estabelece o dever de motivar, com indicação dos fatos e fundamentos, para oito espécies de processo:

- os que neguem ou afetem direitos ou interesses dos administrados;
- que imponham ou agravem deveres destes;
- que decidam processos de concurso ou seleção;
- que dispensem ou declarem inexigência de licitação;
- que decidam recurso administrativo;
- que decorram de reexame de ofício;
- que deixem de aplicar jurisprudência já firmada ou divirjam de pareceres e fundamentos anteriores;
- nos casos de revogação, suspensão e convalidação de ato administrativo.

O mesmo artigo 50, § 1º estabelece que a motivação deve ser clara, explícita e congruente, mas que admite-se que ela seja remissiva a fundamento anterior que faça parte dos autos. Pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões solução de vários assuntos da mesma natureza, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados. Por fim exige-se que a motivação tanto nas decisões de órgãos colegiados quanto para aquelas proferidas oralmente.

Trata-se de um princípio geral de direito administrativo. Sobre o tema, reveja os itens 2.2.6 g.

1.2. OFICIALIDADE

Trata-se do impulso de ofício. Este princípio gera divergência na doutrina, pois parcela diz que se faz presente apenas quando o Poder Público atua de ofício. Haveria a possibilidade de instauração do processo por iniciativa da Administração, independentemente de provocação de qualquer das partes, além de determinar a produção de provas de ofício, etc. Está previsto no art. 2º, parágrafo único, XII, art. 5º e art. 29 da Lei nº 9.784/99.

A oficialidade no processo administrativo é muito mais ampla do que o impulso oficial no processo judicial. Ela compreende o poder-dever de instaurar, fazer andar e rever de ofício a decisão. Sendo o processo meio de atingir o interesse público, haveria uma clara lesão caso se o processo não chegasse ao fim, além de configurar uma atuação ineficiente.

Outra parcela da doutrina nomeia esse princípio como oficiosidade. O princípio da oficialidade significaria que órgão que instaura o processo deve ser oficial, pertencente ao Estado.

No entanto, a ideia principal é a possibilidade de atuar de ofício.



1.3. PRINCÍPIO DA GRATUIDADE

Está previsto no art. 2º, XI, da Lei nº 9.784/99 Trata-se da proibição de cobrança de despesas processuais. Esta proibição não é absoluta, pois somente é possível a cobrança se houver previsão legal (por exemplo quando há leis específicas exigindo cobrança de determinados atos processuais ao longo do processo administrativo). Essa cobrança não poderá implicar empecilho injustificável para utilização do processo. Esta cobrança não poderá se mostrar desarrazoada e impeditiva de acesso ao processo administrativo. Veda-se a onerosidade excessiva do cidadão quando se tem a Administração Pública como parte do processo, e a ela não é obrigado o recolhimento de qualquer custa processual.

A Súmula Vinculante 21 estabelece é inconstitucional a exigência de depósito prévio ou de arrolamento de bens para admissão de recurso administrativo.

1.4. PLURALIDADE DE INSTÂNCIAS

O princípio da pluralidade de instâncias decorre do princípio da autotutela. Di Pietro¹¹³ diz que, no processo administrativo, é **possível alegar em instância superior o que inclusive o que não foi alegado na instância inferior**.

Ainda, no processo administrativo **é possível que a instância superior venha a reexaminar fatos**.

Além disso, **é possível que na instância superior novas provas venham a ser produzidas**.

1.5. SEGURANÇA JURÍDICA

O princípio da segurança jurídica vai se justificar para que a atuação da Administração Pública seja previsível, sendo necessária a previsibilidade dos atos administrativos e estabilização das relações jurídicas.

Com base no princípio da segurança jurídica, a atuação da administração pública deverá encontrar dois limites:

- Vedação à aplicação retroativa de uma nova interpretação dada pela administração
- Mesmo a autotutela deverá ser exercida após um prazo razoável

O art. 54 da Lei 9784/99 consolidou o princípio da segurança jurídica quando estabeleceu que **a administração tem o direito de anular os atos administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis aos destinatários dentro do prazo de 05 anos**. Após este prazo, haverá decadência dos atos administrativos, salvo se comprovar que o indivíduo agiu de má-fé, caso em que não se observará este prazo de 05 anos.

O STJ já firmou a tese que as situações flagrantemente inconstitucionais não se submetem ao prazo decadencial de 05 anos previsto no artigo 54 da Lei 9.784/1999, não havendo que se falar em convalidação pelo mero decurso do tempo. Ou seja, se os atos administrativos forem absolutamente inconstitucionais, não há de se falar em decadência e nem mesmo em prescrição para que se tomem as providências cabíveis. A violação da Constituição não se convalidaria com o decurso do tempo.

Isto é muito aplicado com relação aos concursos públicos. Portanto, o servidor que mantém um contrato com a administração fora das hipóteses legais, e que viola o princípio do concurso público, não poderia esse servidor continuar, ainda que tenha passado 10 anos.

¹¹³DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo** 33ª ed. São Paulo: GenForense, 2020. Livro eletrônico não paginado.



1.6. IMPARCIALIDADE

Segundo este princípio não pode existir a vinculação da atividade de instrução do processo administrativo à atividade decisória final, seja em favor do administrado, seja em favor da Administração. A decisão administrativa deve ser tomada de acordo com a instrução conduzida pelo órgão administrativo.

A Administração não é uma terceira estranha à controvérsia: ela instaura o processo, conduz a instrução e emite a decisão administrativa final. Ainda assim, no processo administrativo, a relação jurídica é bilateral: ele pode ser instaurado tanto mediante provocação do interessado quanto por iniciativa do próprio Poder Público. Para que haja imparcialidade é preciso que o convencimento da Administração seja isento, contemporâneo ao processo e embasado no que foi debatido e provado nos autos.

Assim haveria clara violação ao princípio da imparcialidade o eventual prejulgamento ou inclinação para determinado resultado, a decisão sobre pleito e processos administrativos próprios, a decisão em casos nos quais a comissão processante possui grau hierárquico inferior ao do processado ou em casos nos quais a Administração declara de antemão o futuro resultado final do processo administrativo.

Caso o contraditório e a ampla defesa não forem respeitados haverá claro prejuízo a imparcialidade, gerando a nulidade de processo administrativo e a possibilidade de sua revisão pelo Poder Judiciário. O contraditório deve ser substancial, protegido em seus dois aspectos, formal e material. No sentido formal, o contraditório significa a possibilidade do particular ser ouvido; já o material significa que a manifestação do administrado deve ser capaz de modificar o convencimento do Poder Público: ou seja, sua oitiva do administrado não pode ser um ato meramente *pro forma* em um processo em que a decisão final já esteja previamente formada.

O art. 18 da Lei 9.784/99 estabelece que estará impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que:

- tenha interesse direto ou indireto na matéria;
- tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau;
- esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro.

O STJ já se pronunciou sobre o caráter taxativo das hipóteses de impedimento em processo administrativo, decidindo que as normas de competência não podem ser fundadas em suposições, devendo sua previsão, mormente quando restritiva, constar em termos precisos e rigorosos, sob pena de gerar manipulações através de critérios que não sejam estritamente formais, gerando incertezas e inseguranças. A salvaguarda da imparcialidade constitui a razão de ser de uma série de institutos, a fim de que o processo seja conduzido e apreciado sem quaisquer pressões ou influências, sujeitando-se apenas ao ordenamento jurídico, entre os quais desponta a previsão de suspeição/impedimento dos membros (STJ. MS n. 200802600198).

1.7. FORMALISMO MODERADO

Não se exige nos processos administrativos o atendimento rigorismos formais ao considerar as manifestações do administrado. O pressuposto é que particular não contará necessariamente com o auxílio da defesa técnica.

Maria Sylvia Zanella di Pietro esclarece que o formalismo moderado não possui efeito irrestrito, aplicável a qualquer tipo de processo. Alguns processos administrativos exigem uma determinada forma. Assim, caso a lei imponha uma determinada formalidade ou estabeleça um procedimento mais rígido, estas determinações devem ser atendidas sob pena de nulidade do processo. Por exemplo os processos administrativos concorrenciais, como o concurso público a licitação, exigem o atendimento ao formalismo estrito, visando garantir o julgamento isento e a igualdade entre os participantes.



2. COMPETÊNCIA

A competência administrativa é o conjunto de poderes conferido às pessoas jurídicas de direito público, que limitam e justificam o exercício da atividade administrativa.

Em razão da indisponibilidade do interesse público, a competência é irrenunciável.

Poderá ser objeto de delegação e de avocação, mas é irrenunciável, motivo pelo qual ambas têm caráter temporário.

2.1. DELEGAÇÃO E AVOCAÇÃO

A **delegação** ocorre quando um órgão administrativo ou seu titular transfere parte de sua competência a outro órgão ou a outro titular. Poderá ocorrer na linha vertical ou a linha horizontal, não havendo a necessidade de se observar a hierarquia nesse ponto.

Por outro lado, a **avocação** é a atração realizada por órgão ou agente superior de competência atribuída a um órgão ou agente subordinado. A avocação exige a existência de subordinação hierárquica. Atente-se que somente será possível uma avocação sem subordinação hierárquica se uma lei expressamente estabelecer esta competência.

Alguns **atos não podem ser objeto de delegação**, tais como:

- Edição de atos normativos
- Decisão de recursos administrativos
- Competência exclusiva do órgão ou entidade

Quando a decisão é tomada por delegação, **é considerada que ela foi tomada pelo agente delegado**.

2.2. IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO

Impedimento e suspeição poderão justificar o não exercício da competência atribuída por lei. O **impedimento** tem uma relação com situações objetivamente estabelecidas e acabam sendo objetivamente aferidas.

No caso do impedimento, o agente **fica impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade** que:

- tenha interesse direto ou indireto na matéria;
- tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o 3º grau;
- esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro daquele interessado no processo.

A suspeição é **subjetiva**, podendo ser arguida quando a autoridade ou servidor tenha uma amizade íntima ou uma inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o 3º grau.

3. PECULIARIDADES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

3.1. ATOS PROCESSUAIS

Em razão do princípio da oficialidade ou oficiosidade, o processo administrativo poderá se iniciar de ofício ou a requerimento de qualquer interessado.

Se houver requerimento do interessado, salvo nos casos em que for admitida uma solicitação oral, **deverá ele ser feito por escrito**. A forma do requerimento não é predeterminedada. Ou seja, observa-se o princípio do informalismo.

Não havendo disposição específica, os atos processuais deverão ser praticados no prazo de 5 dias. Eventualmente, os prazos poderão ser dilatados **até o dobro de 05 dias**.

Os atos do processo deverão ser realizados preferencialmente na sede do órgão da administração, mas se for outro o local, deverá haver a cientificação do interessado.

3.2. PARECERES E LAUDOS TÉCNICOS

Parecer é a opinião fundamentada e detalhada. Em regra, os pareceres têm cunho opinativo.

Os pareceres podem ser:

- **parecer facultativo:** a manifestação não é obrigatória, não vinculando a autoridade.
- **parecer obrigatório:** a manifestação é obrigatória, porém o administrador não precisa seguir o parecer obrigatoriamente. Deverá apenas informar as razões pelas quais divergiu do parecerista.
- **parecer vinculante:** a manifestação do parecerista, além de obrigatória, vincula o administrador, devendo decidir nos moldes do parecerista.

Em regra, o parecer deverá ser emitido no **prazo máximo de 15 dias**, e caso seja extrapolado, o processo deverá ter prosseguimento e ser decidido inclusive com a dispensa do parecer, desde que ele não seja vinculante. Neste caso, o parecerista poderá responder disciplinarmente pelo não cumprimento tempestivo e adequado de sua função.

3.3. TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA

A Lei 12.008/09 assegura uma prioridade na tramitação de processos administrativos quando há como parte ou interessado pessoas com idade **igual ou superior a 60 anos**, **pessoas com deficiência** e, também, as **pessoas com doenças graves**.

3.4. RECURSO ADMINISTRATIVO, COISA JULGADA ADMINISTRATIVA E REVISÃO

3.4.1. RECURSO ADMINISTRATIVO

Recurso administrativo é uma forma de impugnar a decisão administrativa. A Lei 9.784/99 trata do **recurso hierárquico próprio**, derivando da própria hierarquia, não sendo necessária a previsão legal autorizando o recurso hierárquico próprio.

Por outro lado, para o chamado **recurso hierárquico impróprio**, não é identificada essa relação hierárquica, caso em que o órgão revisor não é um superior hierárquico do órgão recorrido. Para admitir este recurso é preciso que haja uma autorização legal nesse sentido. Ou seja, o recurso hierárquico impróprio só se admite por expressa previsão em lei. É muito comum nos casos de descentralização e supervisão ministerial.

O recurso administrativo é dirigido à autoridade que prolatou a decisão, situação na qual poderá reconsiderar a decisão no prazo de 05 dias. Caso não reconsidere, poderá encaminhar o recurso para a autoridade superior, a fim de que decida se reformará ou não a decisão.

O recurso se submeterá ao **prazo de 10 dias para interposição**, **não recebendo efeito suspensivo** e o processo administrativo poderá tramitar por **até 3 instâncias**.

Se houver um receio de um prejuízo injusto ou um receio de difícil ou incerta reparação, a autoridade recorrida poderá imediatamente ou então a autoridade superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso.



3.4.2. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA

Há coisa julgada administrativa quando não há mais qualquer recurso na seara administrativa para impugnar a decisão. Porém, a decisão administrativa ainda poderá ser impugnada perante o Poder Judiciário. Isso significa apenas que determinado assunto decidido na via administrativa, não poderá mais sofrer alteração naquela seara.

3.4.3. REVISÃO

A Lei 9.784/99 vai dizer que os processos administrativos dos quais resultem sanções poderão ser objeto de revisão, podendo ser feita a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que surjam fatos novos, ou circunstâncias relevantes e idôneas, a justificar a percepção de que aquela sanção aplicada teria sido inadequada.

Não se admite que a revisão do processo administrativo implique o agravamento da sanção.

3.5. PRECLUSÃO

Preclusão é fenômeno endoprocessual, sendo a perda da oportunidade dentro do processo. A preclusão poderá ser de três espécies:

- **Preclusão consumativa:** o sujeito praticou aquela faculdade e, portanto, já não mais pode exercitá-la novamente.
- **Preclusão lógica:** a parte exterioriza uma vontade incompatível com o desejo de praticar o ato.
- **Preclusão temporal:** é o esgotamento do prazo sem que tenha havido o exercício da faculdade pelo interessado.

3.6. PROCESSO ADMINISTRATIVO E SÚMULA VINCULANTE

As decisões proferidas em processo administrativo se submetem aos entendimentos das súmula vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

Se o ato administrativo negar vigência, aplicar de forma inadequada ou contrariar o enunciado da súmula vinculante, caberá reclamação ao STF.

Se a violação à súmula vinculante se dá de **forma omissiva**, ou seja, se for impugnada um não fazer da administração pública, ou mesmo de **forma comissiva**, por conta de um ato, o uso da reclamação só será admitido **após o esgotamento da via administrativa**.

3.7. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

O processo administrativo disciplinar (PAD) é um instrumento para apurar a prática de um ilícito administrativo disciplinar, que foi praticada por um servidor público.

Há alguns sistemas de processamento disciplinar do agente público:

- **Sistema hierárquico:** o poder disciplinar é exercido exclusivamente pelo servidor hierarquicamente superior àquele que está sendo julgado. O superior apura a falta e aplica a pena. Era tipicamente utilizado quando vivenciaremos uma época da “verdade sabida”. Este sistema era aplicado nas faltas leves.
- **Sistema da jurisdição completa:** a falta do servidor e a pena a ele aplicada são estritamente estabelecidas pela lei. A decisão sobre a incursão do sujeito naquela falta e, portanto, a aplicação da pena seria uma decisão que caberia apenas ao órgão de jurisdição.



- **Sistema misto (jurisdicionalização moderada):** é o sistema adotado no Brasil. A pena é aplicada pelo superior hierárquico, mas há intervenção dos órgãos por meio de pareceres, existindo um certo grau de discricionariedade da pena. Nada impede que se busque o judiciário para evitar certas ilegalidades.

O Brasil adota o sistema misto ou da jurisdicionalização moderada.

As infrações administrativas são ações ilícitas, mas que devem ter sido praticadas no exercício das atribuições do agente público, ou a pretexto de exercê-las no cargo que está investido.

3.7.1. ESPÉCIES DE PROCESSO DISCIPLINAR

São quatro as espécies de processo disciplinar:

- **Verdade sabida:** há o conhecimento pessoal e direto da infração administrativa pela autoridade superior. A autoridade superior toma conhecimento e já aplica a pena. Esse processo não é mais adotado no Brasil, pois não respeita contraditório e ampla defesa.
- **Sindicância acusatória:** é um processo disciplinar que serve para apurar a autoria ou existência de uma irregularidade de menor gravidade. É um instrumento mais célere. Este procedimento é composto por uma comissão de dois ou três servidores estáveis.
- **Sindicância investigativa:** é realizada para apurar indícios de irregularidade de forma genérica, sendo indicação prévia de autoria. Essa sindicância é um instrumento para apuração de irregularidade sem aplicação de sanções, mas detém natureza inquisitorial.
- **Processo administrativo disciplinar (PAD):** é um rito mais complexo, sendo destinado a apurar infrações mais graves, sendo composta por comissão de três servidores estáveis.

A Súmula Vinculante 05 estipula que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar **não ofende a Constituição Federal**.

A análise detalhada da Súmula Vinculante 05 é especialmente relevante, já que há clara divergência com a súmula 343, do STJ ("é obrigatória a presença de advogado em todas as fases de processo administrativo disciplinar"). O STJ jamais alterou expressamente o seu entendimento, mas atualmente prevalece que a súmula 343 está revogada.

Portanto, em um processo administrativo, não necessariamente disciplinar, o administrado pode ser acompanhado por advogado apenas se assim desejar. Caso o acusado não tenha assistência jurídica esta circunstância não gerará a nulidade do processo administrativo.

A sindicância acusatória e o processo administrativo disciplinar irão se diferenciar em relação ao **Prazo de conclusão:**

- **Sindicância:** deve ser concluída até o prazo de 30 dias da sua instauração. Esse prazo é prorrogável por igual período de 30 dias.
- **Processo administrativo disciplinar (PAD):** deve ser concluída até o prazo de 60 dias da sua instauração. Esse prazo é prorrogável por igual período de 60 dias

Há diferença ainda no **alcance das penas:**

- **Sindicância:** poderá resultar em arquivamento, mas também na punição com advertência ou suspensão de até 30 dias. Caso seja mais grave que isso, a sindicância deverá resultar em processo administrativo disciplinar. O STJ firmou entendimento que, diante de seu caráter meramente investigatório (inquisitorial) ou preparatório de um processo administrativo disciplinar, como a sindicância visa apenas apurar a ocorrência de infrações administrativas e não à aplicação de sanção ao servidor público, podem ser dispensadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo também prescindível a presença obrigatória do investigado (MS 20.647/DF)



- **Processo administrativo disciplinar (PAD):** será possível aplicação de penas de suspensão superior a 30 dias, demissão, cassação de aposentadoria, disponibilidade ou destituição de cargo de confiança.

3.7.2. PENALIDADES DISCIPLINARES

A Lei 8.112 apresenta as seguintes penalidades disciplinares:

- Advertência
- Suspensão
- Demissão
- Cassação de aposentadoria
- Disponibilidade de cargo ou função
- Destituição de cargo de confiança

A **competência** para aplicar essas sanções disciplinares dependerá da penalidade.

Serão aplicadas pelo Presidente da República, Presidente do Senado, Presidente da Câmara, Presidente da Assembleia Legislativa, etc.:

- Demissão
- Cassação de aposentadoria
- Disponibilidade de cargo ou função
- Destituição de cargo de confiança

Para aplicar **penalidade de suspensão superior a 30 dias**, ou seja, que exige PAD, será de atribuição das autoridades administrativas que estão hierarquicamente imediatamente inferiores ao chefe do poder.

Para as penalidades de **advertência** e **suspensão de até 30 dias**, será o chefe da repartição o responsável pela aplicação.

É importante destacar que o Decreto 3.035/99 delegou essa competência para demitir e para cassar aposentadoria, disponibilidade, etc. aos ministros de Estado.

3.7.3. FASES DO PROCESSO DISCIPLINAR

São fases do processo disciplinar:

- **Fase de instauração:**

A instauração se dá com a publicação do ato que constituirá a comissão de 3 servidores estáveis, sendo que o presidente da comissão deverá ocupar um cargo superior, ou ao mesmo nível, do sujeito que será julgado, ou ter uma escolaridade superior em relação ao servidor investigado.

- **Fase de inquérito administrativo:**

É a instrução, defesa e relatório. O inquérito administrativo possui defesa, observando-se contraditório e ampla defesa, não se confundindo com o inquérito policial. Após a apuração de provas e havendo a tipificação da infração, será formulada a indiciamento do servidor. O servidor terá o prazo de 10 dias para formular a sua defesa escrita. Feito isso, a comissão elabora um relatório minucioso, sendo ele conclusivo no sentido da inocência ou responsabilização do servidor. Este relatório será encaminhado à autoridade competente para ver se demite, suspende ou não.

- **Fase de julgamento:**

O julgamento irá acatar o relatório da comissão, ou caso esteja manifestamente contrária à prova dos autos, não irá acatar motivadamente. Não é obrigatória a intimação do interessado para apresentar alegações finais após o relatório do inquérito administrativo. Isso porque a manifestação do sujeito já foi feita na defesa.



Se o julgamento contrariar os autos, a autoridade poderá inclusive agravar a pena do servidor, desde que o faça motivadamente.

Quando houver conveniência do serviço público, e a critério da autoridade julgadora, poderá a penalidade ser convertida em multa, desde que se mostre mais conveniente para a administração pública.

Essa multa terá como base **50% por dia da remuneração do servidor**. Se ele for multado, durante o período de cumprimento dessa multa, será obrigado a permanecer no serviço.

4. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DISCIPLINAR

Segundo a lei, a ação disciplinar prescreve em **05 anos**, para infrações de **demissão, cassação de aposentadoria, disponibilidade ou destituição em cargo ou comissão**.

Se a infração tem como penalidade a **suspensão**, a penalidade prescreverá em **02 anos**.

Sendo a pena da infração uma **advertência**, a prescrição se dá com **180 dias**.

O prazo prescricional começa a correr a partir do momento em que o fato se tornou conhecido.

A abertura da sindicância ou a instauração do processo disciplinar, com a publicação da respectiva portaria, **interromperá a prescrição**. A partir do momento da publicação da portaria até o momento da decisão final proferida pela autoridade competente, **o prazo não irá correr**.

Contudo, se ocorrer o final do prazo legal para conclusão do PAD, e ainda não houver julgamento, aí o prazo prescricional voltará a correr.

Portanto, **o prazo prescricional para se concluir um PAD é de 140 dias**. Isso porque há 60 dias para o PAD e mais 60 dias para o caso de prorrogação. No entanto, a autoridade, após concluído o relatório, terá 20 dias para proferir a sua decisão.

Depois que este prazo foi extrapolado, o procedimento continua válido, mas volta a ter curso na integralidade do prazo prescricional, conforme entende o STF.

Em junho de 2019 o STF decidiu que o termo inicial do lustro prescricional para a apuração do cometimento de infração disciplinar é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o Processo Administrativo Disciplinar. A contagem da prescrição interrompe-se tanto com a abertura de sindicância quanto com a instauração de processo disciplinar. Após o decurso de 140 dias (prazo máximo conferido pela Lei n. 8.122/90 para conclusão e julgamento do PAD), o prazo prescricional recomeça a correr integralmente (RMS 35868).

5. TESES DO STJ

No segundo semestre de 2019 o STJ destacou doze entendimentos sobre processo administrativo federal:

- No âmbito de recurso ordinário, a decadência administrativa prevista no artigo 54 da Lei 9.784/1999 pode ser reconhecida a qualquer tempo e *ex officio*, por se tratar de matéria de ordem pública, sendo indispensável seu prequestionamento nas instâncias especiais.
- Diante da ausência de previsão legal, o prazo decadencial de cinco anos do artigo 54, caput, da Lei 9.784/1999 é insuscetível de suspensão ou de interrupção, devendo ser observada a regra do artigo 207 do Código Civil.
- A superveniência da Lei Distrital 2.834/2001 não interrompe a contagem do prazo decadencial iniciado com a publicação da Lei 9.784/1999, uma vez que sua única finalidade é aplicar, no âmbito do Distrito Federal, as regras previstas na referida lei federal.
- O prazo decadencial para que a administração promova a autotutela, previsto no artigo 54 da Lei 9.784/1999, aplica-se tanto aos atos nulos, quanto aos anuláveis.
- As situações flagrantemente inconstitucionais não se submetem ao prazo decadencial de 05 anos previsto no artigo 54 da Lei 9.784/1999, não havendo que se falar em convalidação pelo mero decurso do tempo.



- O prazo previsto no artigo 54 da Lei 9.784/1999 para a administração rever seus atos não pode ser aplicado de forma retroativa, devendo incidir somente após a vigência do referido diploma legal.
- A Lei 9.784/1999, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da administração pública federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria. (Súmula 633/STJ).
- Em se tratando de atos de que decorram efeitos patrimoniais contínuos, como aqueles decorrentes de pagamentos de vencimentos e de pensões, ocorridos após a entrada em vigor da Lei 9.784/1999, nos quais haja pagamento de vantagem considerada irregular pela administração, o prazo decadencial de cinco anos é contado a partir da percepção do primeiro pagamento indevido, consoante o § 1º do artigo 54 da Lei 9.784/1999.
- É possível interromper o prazo decadencial com base no artigo 54, § 2º, da Lei 9.784/1999 desde que haja ato concreto, produzido por autoridade competente, em prol da revisão do ato administrativo identificado como ilegal, cujo prazo será fixado a partir da identificação do interessado.
- Os atos administrativos abstratos, como as notas e os pareceres da Advocacia-Geral da União, não configuram atos de autoridade tendentes à revisão das anistias e são, portanto, ineficazes para, por si sós, interromper o fluxo decadencial, nos moldes do artigo 54, § 2º, da Lei 9.784/1999.
- Por se tratar de hipótese de ato administrativo complexo, a decadência prevista no artigo 54 da Lei 9.784/1999 não se consuma no período compreendido entre o ato administrativo concessivo de aposentadoria ou de pensão e o julgamento de sua legalidade pelo Tribunal de Contas, vez que tais atos se aperfeiçoam apenas com o registro na Corte de Contas.
- O prazo previsto no artigo 49 da Lei 9.784/1999 é impróprio, visto que ausente qualquer penalidade ante o seu descumprimento.

Seguem, ainda, as demais teses do STJ sobre Processo Administrativo disciplinar:

- 1) A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição (Súmula Vinculante n. 5 do STF).
- 2) As instâncias administrativa e penal são independentes entre si, salvo quando reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria na esfera criminal.
- 3) É possível a utilização de prova emprestada no processo administrativo disciplinar, devidamente autorizada na esfera criminal, desde que produzida com observância do contraditório e do devido processo legal.
- 4) É possível a instauração de processo administrativo com base em denúncia anônima.
- 5) Instaurado o competente processo administrativo disciplinar, fica superado o exame de eventuais irregularidades ocorridas durante a sindicância.
- 6) O excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar não conduz à sua nulidade automática, devendo, para tanto, ser demonstrado o prejuízo para a defesa.
- 7) A autoridade administrativa pode aplicar a pena de demissão quando em processo administrativo disciplinar é apurada a prática de ato de improbidade por servidor público, tendo em vista a independência das instâncias civil, penal e administrativa.
- 8) A decretação de nulidade no processo administrativo depende da demonstração do efetivo prejuízo para as partes, à luz do princípio *pas de nullité sans grief*.
- 9) O termo inicial do prazo prescricional em processo administrativo disciplinar começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido pela Administração, conforme prevê o art. 142, § 1º, da Lei 8.112/90.
- 10) O prazo da prescrição no âmbito administrativo disciplinar, havendo sentença penal condenatória, deve ser computado pela pena em concreto aplicada na esfera penal.



- 11) A Lei n. 8.112/1990 pode ser aplicada de modo supletivo aos procedimentos administrativos disciplinares estaduais, nas hipóteses em que existam lacunas nas leis locais que regem os servidores públicos.
- 12) É possível a substituição de membros da comissão processante, desde que respeitados, quanto aos membros designados, os requisitos insculpidos no art. 149 da Lei n. 8.112/1990.
- 13) As alegações de imparcialidade e de suspeição de membro da comissão processante devem estar fundadas em provas, não bastando meras conjecturas ou suposições desprovidas de qualquer comprovação.
- 14) A imparcialidade de membro de comissão não fica prejudicada tão somente por este compor mais de uma comissão processante instituída para apuração de fatos distintos que envolvam o mesmo servidor.
- 15) A simples oitiva de membro da comissão processante, de autoridade julgadora ou de autoridade instauradora como testemunha ou como informante no bojo de outro processo administrativo ou até mesmo penal que envolva o investigado não enseja, por si só, o reconhecimento da quebra da imparcialidade.
- 16) Na composição de comissão de processo administrativo disciplinar, é possível a designação de servidores lotados em órgão diverso daquele em que atua o servidor investigado, não existindo óbice nas legislações que disciplinam a apuração das infrações funcionais.
- 17) Em regra, a instauração de processo administrativo disciplinar contra servidor efetivo cedido dar-se-á no órgão em que tenha sido praticada a suposta irregularidade (cessionário), devendo o julgamento e a eventual aplicação de sanção ocorrer no órgão ao qual o servidor efetivo estiver vinculado (cedente).
- 18) A participação de membro do Ministério Público em conselho da Polícia Civil torna nulo o procedimento administrativo disciplinar instaurado para processar e para julgar servidor público estadual por prática de ato infracional.
- 19) A convalidação de atos, determinada pelo Supremo Tribunal Federal - STF na ADPF n. 388, não alcança aqueles produzidos no âmbito de processo administrativo disciplinar declarado nulo em razão da participação de membro do Ministério Público em conselho da Polícia Civil estadual.
- 20) Compete ao Ministro de Estado da Educação a instauração de procedimento administrativo disciplinar e a aplicação de penalidades previstas na Lei n. 8. 112/1990 contra servidor integrante do quadro de pessoal de Universidade Pública Federal, por força do disposto nos Decretos n. 3.035/1999 e n. 3. 669/2000.
- 21) O superintendente regional de Polícia Federal é competente para designar os membros de comissão permanente de disciplina, bem como para determinar a abertura de procedimento administrativo disciplinar no âmbito da respectiva superintendência.
- 22) A designação de comissão temporária para promover processo administrativo disciplinar é legítima, nos termos da Lei n. 8.112/1990, já que a existência de comissão permanente para a apuração de faltas funcionais só é exigida para os casos determinados em lei.
- 23) Os policiais rodoviários federais se sujeitam às disposições da Lei n. 8. 112/1990, que nada dispõe sobre a necessidade de ser permanente a comissão que conduz o processo administrativo disciplinar instaurado para apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições.
- 24) A designação de comissão temporária para promover processo administrativo disciplinar contra servidor policial federal viola os princípios do juiz natural e da legalidade, a teor da Lei n. 4.878/1965, que exige a condução do procedimento por comissão permanente de disciplina.
- 25) O controle judicial no processo administrativo disciplinar - PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo.
- 26) A Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992) não revogou, de forma tácita ou expressa, os dispositivos da Lei n. 8.112/1990, em relação aos processos administrativos disciplinares.
- 27) Declarações prestadas à mídia por autoridade pública, acerca de irregularidades cometidas por servidores públicos a ela subordinados, não ensejam, por si só, a nulidade do PAD.
- 28) A administração pública, quando se depara com situação em que a conduta do investigado se amolda às hipóteses de demissão ou de cassação de aposentadoria, não dispõe de discricionariedade para aplicar pena menos gravosa por se tratar de ato vinculado.

- 29) Não há falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade quando a única reprimenda prevista para a infração disciplinar apurada é a pena de demissão.
- 30) Em caso de inobservância de prazo razoável para a conclusão de processo administrativo disciplinar, não há falar em ilegalidade na concessão de aposentadoria ao servidor investigado.
- 31) O deferimento de provimento judicial que determine à autoridade administrativa que se abstenha de concluir procedimento administrativo disciplinar suspende o curso do prazo prescricional da pretensão punitiva administrativa.
- 32) É possível o imediato cumprimento da penalidade aplicada na conclusão de processo administrativo disciplinar, uma vez que os recursos administrativos e os pedidos de reconsideração, em regra, não possuem efeito suspensivo automático.
- 33) Reconhecida a nulidade de PAD pela existência de vício insanável, antes do seu julgamento, não há que se falar em *reformatio in pejus* quando a segunda comissão processante opina por penalidade mais gravosa.
- 34) Meras alegações de que existe fato novo não têm o condão de abrir a via da revisão do processo administrativo disciplinar, sendo indispensável a comprovação da existência de fatos novos, desconhecidos ao tempo do PAD.
- 35) O mandado de segurança não é a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático-probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar - PAD.
- 36) Na via do mandado de segurança, é possível valorar a congruência entre a conduta apurada e a capitulação da pena de demissão aplicada no processo administrativo disciplinar.
- 37) É cabível recurso administrativo hierárquico em face de decisão prolatada em Processo Administrativo Disciplinar - PAD.
- 38) A ausência de termo de compromisso de membro de comissão processante não implica nulidade do PAD, uma vez que tal designação decorre de lei e recai, necessariamente, sobre servidor público, cujos atos funcionais gozam de presunção de legitimidade e de veracidade.
- 39) É inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira. (Súmula 19/STF)
- 40) É possível utilizar a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.492/1992), em interpretação sistemática, para definir o tipo previsto no art. 132, IV, da Lei n. 8.112/1990 e justificar a aplicação de pena de demissão a servidor.
- 41) Na esfera administrativa, o proveito econômico auferido pelo servidor é irrelevante para a aplicação da penalidade no processo disciplinar, pois o ato de demissão é vinculado (art. 117, c/c art. 132 da Lei 8112/1990), razão pela qual é despidendo falar em razoabilidade ou proporcionalidade da pena.
- 42) A demonstração do ânimo específico de abandonar o cargo público que ocupa (*animus abandonandi*) é necessária para tipificar conduta de servidor como prática de infração administrativa de abandono de cargo.
- 43) O fato de o acusado estar em licença para tratamento de saúde não impede a instauração de processo administrativo disciplinar, nem mesmo a aplicação de pena de demissão.
- 44) Não caracteriza cerceamento de defesa no PAD a ausência de interrogatório para a qual contribuiu o próprio investigado, ante a impossibilidade de favorecimento a quem deu causa à alegada nulidade.
- 45) É dispensada a intimação pessoal do servidor representado por advogado, sendo suficiente a publicação da decisão proferida no PAD no Diário Oficial da União.
- 46) Diante do silêncio da Lei n. 8.112/1990 e demais diplomas legais sobre processo administrativo disciplinar, deve ser observada a regra dos art. 26, § 2º, e art. 41 da Lei n. 9.784/1999 que impõe o prazo de, no mínimo, três dias úteis entre a notificação do servidor e a realização de prova ou de diligência ordenada no PAD, sob pena de nulidade.
- 47) A não realização da oitiva de testemunha não constitui cerceamento de defesa no PAD quando há o esgotamento das diligências para sua intimação ou ainda, quando intimada, a testemunha tenha deixado de comparecer à audiência.
- 48) A falta de intimação de advogado constituído para a oitiva de testemunhas não gera nulidade se intimado o servidor investigado.

- 49) A simples ausência de servidor acusado ou de seu procurador não macula a colheita de depoimento de testemunha no PAD, desde que pelo menos um deles tenha sido intimado sobre a realização da audiência.
- 50) Em processo administrativo disciplinar, a falta de intimação do servidor público após a apresentação do relatório final pela comissão processante não configura ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa por ausência de previsão legal.
- 51) O indeferimento de produção de provas pela comissão processante, não causa nulidade do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, desde que motivado nos termos do art. 156, §§ 1º e 2º, da Lei n. 8.112/1990.
- 52) É possível o aproveitamento de prova produzida em processo administrativo disciplinar declarado nulo para a instrução de novo PAD, desde que seja assegurado o contraditório e a ampla defesa, e que o vício que ensejou referida nulidade não recaia sobre a prova que se pretende aproveitar.
- 53) A acareação entre os acusados, prevista no § 1º do art. 159 da Lei n. 8. 112/1990, não é obrigatória, competindo à comissão processante decidir sobre a necessidade de sua realização quando os depoimentos forem colidentes e a comissão não dispuser de outros meios para a apuração dos fatos.
- 54) É dispensável a transcrição integral de diálogos colhidos em interceptação telefônica no âmbito do PAD, pois tal obrigatoriedade não encontra amparo legal.
- 55) O exame de sanidade mental do servidor (art. 160 da Lei n. 8.112/1990) só é imperativo na hipótese em que haja dúvida razoável de que o investigado tivesse, ao tempo dos fatos, condições de assumir a responsabilidade funcional pelos atos a ele atribuídos.
- 56) A preexistência de doença mental ao tempo do cometimento dos fatos apurados no processo administrativo disciplinar impede a aplicação da pena disciplinar se constatada, por qualquer meio, a absoluta inimizabilidade do agente.
- 57) Em matéria de demissão por enriquecimento ilícito (art. 132, IV, da Lei 8. 112/1990 c/c art. 9º, VII, da Lei 8.429/1992), compete à administração pública comprovar o incremento patrimonial significativo e incompatível com as fontes de renda do servidor no PAD e ao servidor acusado o ônus de demonstrar a licitude da evolução patrimonial constatada pela administração, sob pena de configuração de improbidade administrativa.
- 58) O fato de o servidor ter prestado anos de serviços ao ente público, e de possuir bons antecedentes funcionais, não é suficiente para amenizar a pena a ele imposta se praticadas infrações graves a que a lei, expressamente, prevê a aplicação de demissão.
- 59) A regra do crime continuado (art. 71 do Código Penal) não incide por analogia sobre o PAD, porque a aplicação da legislação penal ao processo administrativo restringe-se aos ilícitos que, cometidos por servidores, possuam também tipificação criminal.
- 60) É possível haver discrepância entre a penalidade sugerida pela comissão disciplinar e a aplicada pela autoridade julgadora desde que a conclusão lançada no relatório final não guarde sintonia com as provas dos autos e a sanção imposta esteja devidamente motivada.
- 61) Quando o fato objeto da ação punitiva da administração também constituir crime e enquanto não houver sentença penal condenatória transitada em julgado, a prescrição do poder disciplinar reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal para pena cominada em abstrato.
- 62) A portaria de instauração do processo disciplinar prescinde de minuciosa descrição dos fatos imputados, sendo certo que a exposição pormenorizada dos acontecimentos se mostra necessária somente quando do indiciamento do servidor.
- 63) O prazo prescricional interrompido com a abertura do Processo Administrativo Disciplinar - PAD voltará a correr por inteiro após 140 dias, uma vez que esse é o prazo legal para o encerramento do procedimento.
- 64) No PAD, a alteração da capitulação legal imputada ao acusado não enseja nulidade, uma vez que o indiciado se defende dos fatos nele descritos e não dos enquadramentos legais.
- 65) Da revisão do PAD não poderá resultar agravamento da sanção aplicada, em virtude da proibição do *bis in idem* e da *reformatio in pejus*.



6. JURISPRUDÊNCIA

6.1. SÚMULAS DO STF

Súmula vinculante 21: É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo

Súmula vinculante 5: A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.

Súmula 443: A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta.

Súmula 383: A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.

Súmula 19-: É inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira.

6.2. SÚMULAS DO STJ

Súmula 641: A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados

Súmula 635: Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei nº 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido - sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar - e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção.

Súmula 611: Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto à Administração

Súmula 591: É permitida a “prova emprestada” no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa.

Súmula 592: O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa

Súmula 510: A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas.

Súmula 434: O pagamento da multa por infração de trânsito não inibe a discussão judicial do débito.

Súmula 373: É ilegítima a exigência de depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo.

Súmula 312: No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.



Súmula 85: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

6.3. INFORMATIVOS DO STF¹¹⁴

Servidor público e processo administrativo disciplinar – 2 Em conclusão de julgamento, a Segunda Turma negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança no qual se impugnava decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que manteve a demissão do impetrante do cargo de auditor-fiscal da Receita Federal, em razão da prática de ilícito administrativo (Informativo 766). Na espécie, o recorrente reiterava o argumento de que o ato debatido estaria contaminado por vício de forma que tornaria nulo o processo administrativo disciplinar. Aduzia que servidor em estágio probatório não poderia compor comissão de inquérito, sob pena de descumprir-se o caput do art. 149 da Lei 8.112/1990 (1). Sustentava, ainda, haver desproporcionalidade da pena administrativa aplicada, que não teria levado em conta a absolvição na esfera criminal. O colegiado destacou que, para o STJ, a exigência legal foi atendida, pois a estabilidade no serviço público federal do integrante em estágio probatório foi adquirida em 1993, em outro cargo. Complementou que a Administração, ao saber do questionamento, substituiu o referido servidor, sem aproveitar qualquer ato decisório no processo disciplinar. Ausente a demonstração de prejuízo concreto, a declaração de nulidade é desautorizada.

Quanto ao argumento de desproporcionalidade da pena em decorrência da absolvição na esfera criminal, observou que competia ao administrador aplicar a penalidade prescrita na lei. Despiciendo cogitar-se de razoabilidade ou proporcionalidade. Além disso, a jurisprudência desta Corte reconhece a independência entre as esferas penal e administrativa. A repercussão da primeira na segunda ocorre somente nos casos em que constatada a inexistência material dos fatos ou a negativa de autoria, até porque a valoração na esfera administrativa não é a mesma da penal. Na situação em apreço, a improcedência do pedido condenatório na esfera penal decorreu de falta de prova. No processo administrativo, a produção de prova foi suficiente para a formação do convencimento condenatório disciplinar.

STF, Informativo 970, Segunda Turma. RMS 32357/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 17.3.2020.

A sentença proferida no âmbito criminal somente repercute na esfera administrativa quando reconhecida: a) a inexistência material do fato; ou b) a negativa de sua autoria. Assim, se a absolvição ocorreu por ausência de provas, a administração pública não está vinculada à decisão proferida na esfera penal. STF. 2ª Turma. RMS 32357/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 17/3/2020 (Info 970).

6.4. INFORMATIVOS DO STJ¹¹⁵

O art. 141, I, da Lei nº 8.112/90 prevê que as penalidades disciplinares de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidores públicos ligados ao Poder

¹¹⁴CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:<<https://www.Buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia>>.

¹¹⁵CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:<<https://www.Buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia>>.

Executivo federal devem ser aplicadas pelo Presidente da República. Por meio do Decreto nº 3.035/99, o Presidente da República delegou aos Ministros de Estado e ao Advogado-Geral da União a atribuição para aplicar tais penalidades. Assim, o Advogado-Geral da União, com base no Decreto nº 3.035/99, possui competência para, em processo administrativo disciplinar, aplicar pena de demissão a Procurador da Fazenda Nacional, que é membro integrantes da carreira da AGU. Vale ressaltar, contudo, que cabe recurso hierárquico próprio ao Presidente da República contra a aplicação dessa penalidade. STJ. 1ª Seção. MS 17449-DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 14/08/2019 (Info 657).

O prazo prescricional previsto na lei penal se aplica às infrações disciplinares também capituladas como crime independentemente da apuração criminal da conduta do servidor. Para se aplicar a regra do § 2º do art. 142 da Lei nº 8.112/90 não se exige que o fato esteja sendo apurado na esfera penal (não se exige que tenha havido oferecimento de denúncia ou instauração de inquérito policial). Se a infração disciplinar praticada for, em tese, também crime, deve ser aplicado o prazo prescricional previsto na legislação penal independentemente de qualquer outra exigência. STJ. 1ª Seção. MS 20857-DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Acd. Min. Og Fernandes, julgado em 22/05/2019 (Info 651).

O indiciado se defende dos fatos que lhe são imputados e não de sua classificação legal. Assim, a posterior alteração da capitulação legal da conduta, não tem o condão de gerar nulidade o Processo Administrativo Disciplinar. A descrição dos fatos ocorridos, desde que feita de modo a viabilizar a defesa do acusado, afasta a alegação de ofensa ao princípio da ampla defesa. STJ. 1ª Seção. MS 19.726/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 13/12/2017.

As irregularidades verificadas no processo disciplinar, para justificarem a sua anulação, devem ser graves a ponto de afetar as garantias do devido processo legal, dependendo, portanto, da efetiva demonstração de prejuízos à defesa do servidor, segundo o princípio da instrumentalidade das formas (*pas de nullité sans grief*). STJ. 3ª Seção. RO nos EDcl nos EDcl no MS 11.493/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 25/10/2017.

A Portaria de instauração do Processo Administrativo Disciplinar dispensa a descrição minuciosa da imputação, exigida tão somente após a instrução do feito, na fase de indiciamento, o que é capaz de viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. STJ. 3ª Seção. RO nos EDcl nos EDcl no MS 11.493/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 25/10/2017.

A nulidade do processo administrativo disciplinar somente deve ser declarada quando houver efetiva demonstração de prejuízo sofrido pela defesa do servidor. STJ. 2ª Turma. AgInt no RMS 53.758/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 10/10/2017.

O termo inicial da prescrição é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente. Isso significa que, quando ela toma conhecimento, inicia-se a contagem do prazo. A contagem desse prazo prescricional é interrompida com a publicação do primeiro ato instauratório válido (seja a abertura da sindicância ou a instauração do PAD). No entanto, essa interrupção não é definitiva, considerando que se passarem 140 dias sem que o PAD seja julgado, o prazo prescricional recomeça a correr por inteiro. STJ. 1ª Seção. MS 21.669/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 23/08/2017.



QUESTÕES

1. (TJPA) CESPE, 2019. De acordo com a Lei n.º 9.784/1999, o recurso administrativo deve ser dirigido à autoridade

A que tiver proferido a decisão, a qual, se não a reconsiderar, deverá encaminhá-lo à autoridade superior.

B que tiver proferido a decisão, a qual deve encaminhá-lo à autoridade superior sem emitir novo juízo de valor sobre a decisão recorrida.

C que tiver proferido a decisão, a qual deve limitar-se a decidir sobre a tempestividade do recurso e a cumprir as formalidades legais.

D hierarquicamente superior à que tiver proferido a decisão, sendo a indicação errônea da autoridade motivo para o não conhecimento do recurso.

E hierarquicamente superior à que tiver proferido a decisão, devendo ser corrigida de ofício pelo agente público eventual indicação equivocada da autoridade julgadora.

2. (TJAL) FCC, 2019. No que concerne aos institutos da prescrição e decadência, quando aplicados às relações jurídicas que envolvem a Administração pública, tem-se que

A nas relações com os particulares que contratam com a Administração, o prazo decadencial para aplicação de sanções deve ser o dobro do prazo de prescrição fixado pelo Código Civil para as ações contra a Fazenda Pública.

B a decadência opera-se apenas em relação aos efeitos patrimoniais das relações administrativas, impedindo, por exemplo, a cobrança de débitos tributários, porém nunca extinguindo pretensões punitivas.

C o poder de autotutela conferido à Administração encontra limites temporais pela ação da decadência, inclusive em relação ao dever de anular atos eivados de ilegalidade.

D o exercício do poder disciplinar pela Administração perante seus servidores não é atingido pela decadência ou prescrição, eis que estas somente se operam em relação à responsabilidade civil e penal dos servidores.

E os prazos prescricionais estabelecidos na legislação trabalhista não se aplicam às ações ajuizadas, em face de entidades da Administração indireta, por servidores contratados pelo regime celetista, as quais são informadas por regras próprias estatutárias.

3. (MPE-SP) MPE-SP, 2019. Com relação ao processo administrativo, assinale a alternativa correta.

A Nos processos administrativos, a Administração Pública não poderá se ater a rigorismos formais ao considerar as manifestações do administrado. O princípio do informalismo em favor do administrado deve ser aplicado a todos os processos administrativos, inclusive nos da espécie ampliativo de direito de natureza concorrencial, como o concurso público e a licitação.

B A Lei no 9.784/1999, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos Estados e Municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria.

C Considerando que aos litigantes em processo administrativo são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar ofende a Constituição.

D A duração razoável dos processos, erigida como cláusula pétrea e direito fundamental (art. 5º, LXXVIII, CF), tem aplicação restrita aos processos judiciais em face do princípio da separação de poderes.

E Não raramente a Administração Pública altera a interpretação de determinadas normas legais. Todavia, a mudança de orientação, em caráter normativo, considerando os princípios da indisponibilidade e da supremacia do interesse público, podem afetar as situações já reconhecidas e consolidadas na vigência da orientação anterior.

4. (TJPR) CESPE, 2019. De acordo com a Lei n.º 9.784/1999, que regula processos administrativos no âmbito federal, um órgão administrativo ou o seu titular poderá delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, desde que

A estes sejam hierarquicamente subordinados àqueles.

B a finalidade seja editar atos de caráter normativo.

C a finalidade seja decidir recursos administrativos.

D não haja impedimento legal, e que a delegação seja feita com base na conveniência.

5. (DPE-MA) FCC, 2018. O recurso administrativo é meio hábil para propiciar o reexame da atividade da Administração por razões de legalidade ou de mérito. O recurso hierárquico impróprio é aquele dirigido

A à autoridade ou instância superior do mesmo órgão administrativo, pleiteando revisão do ato recorrido por terceiro interessado.

B pela parte, à autoridade ou órgão estranho à repartição que expediu o ato recorrido, mas com competência julgadora expressa.

C pela parte, à autoridade ou órgão estranho à repartição que expediu o ato recorrido, sem a necessidade de competência julgadora expressa, bastando estar, de alguma forma, em posição hierárquica superior em relação à autoridade recorrida.

D à mesma autoridade que expediu o ato, para que o invalide ou o modifique, e, por isso, apesar de consistir em reanálise é imprópria, pois não é dirigida à autoridade ou órgão hierarquicamente superior.

E em forma de denúncia formal, à autoridade superior, dando conta de irregularidades internas ou abuso de poder na prática de atos da Administração, feita pela parte atingida diretamente pela irregularidade ou abuso de poder.

COMENTÁRIOS

1. Gabarito – A

A) Correta. Cf. art. 56 § 1º Lei nº 9.784/99.

B) Incorreta. É possível a revisão de ofício, antes de remeter a questão para análise da autoridade superior.

C) Incorreta. Cf. art. 63º Lei nº 9.784/99.

D) Incorreta. Cf. art. 56 Lei nº 9.784/99.

E) Incorreta. Cf. art. 56 Lei nº 9.784/99.

2. Gabarito – C

A) Incorreta. Cf. STJ, REsp 769942/RJ.

B) Incorreta. A decadência alcança os efeitos patrimoniais das relações administrativas e às pretensões punitivas.

C) Correta. Cf. art. 54 da Lei 9.784/99.

D) Incorreta. Cf. art. 142 da Lei 8.112/90.

E) Incorreta. Cf. art. 7º, XXIX CRFB, aplicável ao empregado público.

3. Gabarito – B

A) Incorreta. O informalismo realmente se aplica, em geral, aos processos administrativos. Porém, o concurso público e a licitação são formais.

B) Correta. F. Súmula 633, do STJ.

C) Incorreta. Cf. Súmula Vinculante 05.

D) Incorreta. Cf. art. 5º LXXVIII CRFB.

E) Incorreta. Cf. art. 24 LINDB.

4. Gabarito – D

A) Incorreta. Cf. art. 12, *caput*, Lei 9.784/99.

B) Incorreta. Cf. art. 13, inciso I, Lei 9.784/99.

C) Incorreta. Cf. art. 13, inciso II, Lei 9.784/99.

D) Correta. Cf. art. 12, *caput*, Lei 9.784/99.



5. Gabarito – B

- A) Incorreta. O recurso será dirigido para um órgão não pertencente a entidade que prolatou a decisão.
- B) Correta.
- C) Incorreta. Em razão da expressão "sem a necessidade de competência julgadora expressa. É preciso lei expressa prevendo a possibilidade de interposição do recurso hierárquico impróprio.
- D) Incorreta. O recurso dirigido à mesma autoridade que proferiu a decisão alvejada é o pedido de reconsideração. O recurso hierárquico impróprio se caracteriza por ser dirigido para um órgão não pertencente a entidade que prolatou a decisão.
- E) Incorreta. O conceito se relaciona com a representação.



CAPÍTULO 15 — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

1. INTRODUÇÃO

A improbidade administrativa é uma hipótese de sanção cível, e não administrativa, e que sempre se dá meio de ação judicial. A ação judicial será proposta pela própria entidade que teve seu patrimônio lesado ou que foi de alguma forma prejudicada (a entidade em que se deu o ato ímprobo) ou pelo Ministério Público.

Segundo o STJ o Ministério Público tem legitimidade *ad causam* para a propositura de Ação Civil Pública objetivando o ressarcimento de danos ao erário, recorrentes de atos de improbidade. O Ministério Público estadual possui legitimidade recursal para atuar como parte no Superior Tribunal de Justiça nas ações de improbidade administrativa, reservando-se ao Ministério Público Federal a atuação como fiscal da lei (REsp 1.481536 / RJ).

Regulada pela Lei nº 8.429/1992 a ação de improbidade administrativa poderá ou não gerar uma condenação, com aplicações de sanções como a suspensão dos direitos políticos, multa, perda do cargo, dentre outras.

O direito brasileiro é regido pela independência das esferas, e como visto acima a improbidade administrativa é uma sanção cível. Mas o mesmo fato pode repercutir em outras esferas, como na penal e na esfera administrativa (um PAD, por exemplo).

Os atos de improbidade são de três tipos: enriquecimento ilícito, dano ao erário e atentado a princípios, de forma que também será subsidiária a classificação entre eles. Se configurado o ato mais grave e o menos grave, valerá apenas o mais grave. Por exemplo, uma pessoa subtrai dinheiro da Administração Pública e depois compra um carro. Houve tanto um dano ao erário quanto um enriquecimento ilícito. Mas esse ato é considerado só como ato de enriquecimento ilícito e não como ato de enriquecimento ilícito e dano ao erário, porque aquele é mais grave que este.

Se não houver nem enriquecimento ilícito e nem dano ao erário, haverá só uma violação a princípio administrativo, e serão aplicadas as respectivas sanções. Apenas nessa hipótese poderá ser classificado como ato ímprobo atentatório à Administração Pública.

Todo crime configura, ao menos em tese, um ato ímprobo. Por ser muito amplo, qualquer violação a princípio é ato ímprobo, desde que dolosa. Quase todos os crimes contra a Administração Pública são dolosos, salvo peculato culposo e um ou outro em legislação extravagante. Além de ser um crime, certamente será um ato ímprobo, pois, ainda que não gere enriquecimento ilícito e nem dano ao erário, certamente de alguma forma, irá atentar contra algum princípio. Ou seja, todo crime contra a administração é ato ímprobo, mas não necessariamente um ato ímprobo será um crime.

A regra é a independência das esferas e se um indivíduo pratica um mesmo ato que configure crime e improbidade administrativa. Suponha que um indivíduo subtraia um computador da repartição em que trabalha valendo-se dessa condição, por exemplo. Caso esse servidor seja absolvido na esfera criminal, não o exime, em regra, de responder na esfera cível, e paralelamente ainda poderá ocorrer um PAD. Nada impede, por exemplo, que sendo absolvido por falta de provas na esfera criminal, que seja punido por improbidade administrativa. Também não impede que seja exonerado do serviço público no PAD. As esferas são independentes, conforme previsão no art. 935, CC/02.

O que realmente é vedado é que se descumpra o **efeito panprocessual** do processo penal. Em algumas hipóteses o processo penal irradia efeitos para os demais campos do direito e, nesses casos, vincula o direito civil e administrativo, por exemplo. Por exemplo, se no processo penal se absolve por negativa de autoria ou inexistência de materialidade, será caracterizado o efeito panprocessual do processo penal, não podendo a autoria e a materialidade serem desconsideradas em relação às outras esferas jurídicas. Ou seja, o efeito panprocessual do processo penal é uma exceção, mas vincula as demais esferas.

Na prática é comum que as absolvições ocorram por atipicidade formal ou material. Se for por atipicidade formal, o magistrado dirá que o fato não constitui crime. Não significa dizer que o fato em si não ocorreu. Se for por atipicidade material, ainda que haja a subsunção do fato à norma e que haja em



tese o crime, a lesão ao bem jurídico não foi suficiente, aplicando-se o princípio da insignificância. Essas hipóteses são de absolvições que dizem respeito à atipicidade, não gerando o efeito panprocessual. A não ser que o juiz diga que o fato é atípico porque não existiu, não haverá efeito panprocessual.

É o juízo cível que é o juiz natural para averiguar se houve improbidade administrativa ou não, que deve saber a capitulação legal daquele fato.

A **competência legislativa** para legislar sobre improbidade é privativa da União, ou seja, os demais entes federativos não podem legislar sobre improbidade, a não ser na hipótese remota de haver uma lei complementar que delegue essa competência legislativa para pontos específicos. No entanto essa lei complementar não foi publicada, sendo, portanto, de competência privativa da União, sendo vedada aos demais entes.

A improbidade tem uma certa proximidade com uma outra competência legislativa: a para legislar sobre procedimentos no geral, inclusive administrativos. Legislar sobre processo a competência é competência privativa da União, e legislar sobre procedimento a competência é concorrente, cabendo à União editar as normas gerais e aos demais entes, complementar as normas gerais.

Algumas vezes pode ser que uma norma que pareça ser de improbidade na verdade trata de procedimento administrativo e, sendo esse o caso, o estado poderá legislar de forma concorrente com a União, cabendo a esta editar apenas as normas gerais. Não havendo a edição de normas gerais a competência será plena dos demais entes, e sobrevindo norma da União, com eficácia paralisante, suspenderá os efeitos daquela norma geral editada anteriormente pelo estado.

A Constituição faz menção ao termo “improbidade administrativa” no art. 15, quando estabelece que os direitos políticos serão suspensos por condenação por improbidade administrativa com trânsito em julgado.

No art. 85 CRFB se estabelece que a prática de ato de improbidade pelo Presidente configura crime de responsabilidade:

Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra:

(...)

V - a probidade na administração;

Ainda o art. 14, §2º, CRFB, que trata da improbidade em período eleitoral.

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

(...)

§ 2º Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.

E no art. 37, §4º, CF, que é a base constitucional da improbidade.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Para o STJ a presença de indícios de cometimento de atos ímprobos autoriza o recebimento fundamentado da petição inicial nos termos do artigo 17, parágrafos 7º, 8º e 9º, da Lei 8.429/92, devendo prevalecer, no juízo preliminar, o princípio do *in dubio pro societate* (AgRg no AREsp 604.949).

O STJ já pacificou que nas ações de improbidade administrativa, não há litisconsórcio passivo necessário entre o agente público e os terceiros beneficiados com o ato ímprobo (REsp 1.688.985). Na mesma linha entende o STJ que é inviável a propositura de ação civil de improbidade administrativa



exclusivamente contra o particular, sem a concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda (REsp 1.171.017-PA). O conceito de agente público é bastante amplo, podendo envolver inclusive alguém que sequer tenha remuneração ou que está de forma transitória na administração. O que importa é que essa pessoa, para que seja considerada agente público, tenha algum vínculo com a administração pública para ser agente público.

Por exemplo, o agente público de uma autarquia que libera dinheiro para um banco privado, para um projeto social, e o gerente, em conluio com esse agente público, desviam dinheiro. Observa-se, portanto, que as pessoas jurídicas também podem ser sujeito ativo de improbidade.

Quando a União não concorre para o capital montante daquela entidade com mais de 50%, qualquer eventual ação de improbidade limita-se ao patrimônio público ali em jogo, de acordo com o disposto no art. 1º, parágrafo único da Lei de Improbidade Administrativa. A Lei de Improbidade Administrativa estabelece que:

Art. 1º Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei.

Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos.

Ou seja, se a União tem mais de 50%, a improbidade administrativa sempre é possível. Mas se o recurso corresponder a menos de 50% do capital daquela empresa, eventual ação limitar-se-á ao que há de público nela.

Existem atos ímprobos em diversas leis especiais, como por exemplo a lei que permite a prefeitos que concedam isenções de ISS e, se forem concedidos fora dos parâmetros previstos na lei complementar do ISS, haverá um ato ímprobo. Outro exemplo são os atos previstos na Lei das Eleições. Alguns atos claramente ilícitos que são praticados por agentes públicos durante as eleições, além de todas as respectivas punições da própria lei, é possível também que essa pessoa também responda por improbidade. Não são dispositivos previstos na LIA, mas que dispões que serão equiparados, para todos os fins a atos de improbidade.

Segundo o STJ é **inadmissível a responsabilidade objetiva** na aplicação da Lei 8.429/1992, exigindo-se a presença de dolo nos casos dos artigos 9º e 11 (que coíbem o enriquecimento ilícito e o atentado aos princípios administrativos, respectivamente) e ao menos de culpa nos termos do artigo 10, que censura os atos de improbidade por dano ao Erário (AgRg no REsp 1.500.812).

A ausência da notificação do réu para a defesa prévia, prevista no artigo 17, parágrafo 7º, da Lei de Improbidade Administrativa, só acarreta nulidade processual se houver comprovado prejuízo (*pas de nullité sans grief*).

É possível o deferimento da **medida acautelatória de indisponibilidade de bens** em ação de improbidade administrativa nos autos da ação principal sem audiência da parte adversa e, portanto, antes da notificação a que se refere o artigo 17, parágrafo 7º, da Lei 8.429/92. Também é possível a indisponibilidade quando ausente (ou não demonstrada) a prática de atos (ou a sua tentativa) que induzam a conclusão de risco de alienação, oneração ou dilapidação patrimonial de bens do acionado, dificultando ou impossibilitando o eventual ressarcimento futuro. A indisponibilidade de bens pode recair sobre aqueles adquiridos anteriormente ao suposto ato, além de levar em consideração, o valor de possível multa civil como sanção autônoma



No caso de **enriquecimento ilícito, as sanções são**: perda da função, indisponibilidade e perda de bens e ressarcimento ao erário, além de penas que são gradativas, como multa, suspensão dos direitos políticos e impossibilidade de contratar com a administração. Quando se tratar de enriquecimento ilícito, perda da função pública ou ato atentatório à princípio administrativo, sempre é possível declarar a perda da função pública. O juiz, no entanto, não está obrigado a aplicar todas essas sanções, devendo, à luz da proporcionalidade, dosar e verificar quais são os suficientes para sancionar o ato já praticado. O STJ já se manifestou no sentido de que no caso de dano ao erário apenas o ressarcimento em si não é suficiente, devendo ser cumulado com outro tipo de sanção, tal como multa por exemplo (Ag. 1.313.876).

A sanção de indisponibilidade e perda dos bens, na hipótese de ato ímprobo de enriquecimento ilícito recairão sobre os bens ilicitamente enriquecidos. Na hipótese de dano ao erário, são os bens que sofreram o dano, ainda que não se tenha enriquecido com eles.

A sanção de ressarcimento do dano, na hipótese de ato ímprobo de enriquecimento ilícito, será sempre se houver o dano, havendo a possibilidade de não haver dano. Na hipótese de dano ao erário, haverá sempre o ressarcimento do dano. Também em relação à violação de princípio administrativo, se houver dano, deverá ressarcir-lo, não sendo aqui propriamente um dano ao erário.

A multa, que possui natureza civil, na hipótese de enriquecimento ilícito, será de até 3 vezes o valor do enriquecimento ilícito. Será de até 02 vezes o valor do dano na hipótese de dano ao erário e de até 100 vezes o valor da remuneração na hipótese de ato atentatório a princípio administrativo.

A suspensão de direitos políticos, na hipótese de enriquecimento ilícito, será de 8 a 10 anos. Será de até 05 a 08 anos na hipótese de dano ao erário e de 03 a 05 anos na hipótese de ato atentatório a princípio administrativo.

A impossibilidade de contratar será de 10 anos na hipótese de ato ímprobo de enriquecimento ilícito. Será de até 05 anos na hipótese de dano ao erário e de 3 anos na hipótese de ato atentatório a princípio administrativo.

Na hipótese prevista no art. 10-A da LIA (conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõem o caput e o § 1º do art. 8º-A da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003) a pena poderá ser de perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 05 (cinco) a 08 (oito) anos e multa civil de até 3 (três) vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido.

Para o STJ a revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ação de improbidade administrativa implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontrando óbice na súmula 7/STJ, salvo se da leitura do acórdão recorrido verificar-se a desproporcionalidade entre os atos praticados e as sanções impostas (REsp 1.444.454).

O STJ já decidiu que promotores de justiça podem perder o cargo em razão de condenação em ação de improbidade. Ainda que membros do MP tenham direito à vitaliciedade e a necessidade de uma ação judicial para aplicar a pena de demissão, no entanto, não induz a conclusão de que estes não podem perder o cargo em razão de sentença proferida na ação civil pública por ato de improbidade administrativa (REsp 1.191.613). Além de a Constituição Federal assegurar que todos os agentes públicos estão sujeitos à perda do cargo em razão de atos ímprobos, na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992) não há exceções às sanções previstas. Seria, então, uma segunda hipótese de perda do cargo para quem é vitalício.

O STF pacificou o entendimento de que o Presidente da República não responde com base na LIA, por ter um regime de punição político-administrativo diverso: o do impeachment em razão de crimes de responsabilidade específicos do cargo (PET 3.240).

Por outro lado, todos os demais agentes respondem por improbidade administrativa, sem que se deva falar em prerrogativa de foro por não ser matéria criminal e sim cível, não havendo prerrogativa de foro nessa hipótese.

Na ação de improbidade, assim como na ação popular, há o chamado litisconsórcio móvel, ou seja, o ente da administração opta por qual polo ingressar, se no ativo ou passivo. Por exemplo, o MP ingressa com ação civil pública e o ente da administração está figurando como polo passivo. A entidade pública pode ficar do lado do MP, caso entenda que seja melhor para o interesse público, ou pode ficar no polo ativo contra essa pessoa.

Um jurado pode ser agente público para fins de improbidade administrativa, por exemplo.

Enriquecimento ilícito é todo tipo de vantagem patrimonial que será auferida por determinada pessoa, ampliando o seu patrimônio. Estão previstas no art. 9º da LIA. Esses atos só podem ser punidos a título de dolo. Apesar de não estar expresso na LIA, trata-se de uma construção jurisprudencial que possui uma certa base textual. De acordo com o STJ, nos atos específicos dos atos de improbidade por dano ao erário, o art. 10, *caput*, traz expressamente que podem ser atos de ação ou omissão na sua forma dolosa ou culposa. Nos demais casos, hipóteses dos artigos 9 e 11, só por dolo.

Os atos que causam prejuízo ao erário estão previstos no art. 10 da LIA.

Também temos os do art. 10-A, que constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõem o *caput* e o § 1º do art. 8º-A da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.

As hipóteses de violação de princípios da administração pública estão previstas no art. 11 da LIA.

Todos os róis são de caráter exemplificativo, sendo possível que uma conduta configure ato de improbidade e não esteja presente em nenhuma das hipóteses previstas na LIA.

O art. 13 trata da declaração de bens, bastante usual na prática. Essa hipótese pode impedir a posse do indivíduo que não entrega sua declaração de bens (Declaração de Imposto de Renda) e do indivíduo que seja agente público que não entrega a sua declaração de bens, periodicamente, quando requerida, pode ser demitido do serviço público.

Para a ação de improbidade administrativa, pode haver ou não previamente um inquérito civil do MP. Diferente do que acontece no procedimento comum, há uma notificação prévia para que o agente público faça uma espécie de defesa preliminar. Ou seja, antes mesmo do juiz decidir se aceita ou não a petição inicial, tem que notificar preliminarmente o agente público para que este possa fazer uma espécie de defesa preliminar.

Feita a notificação, à luz da defesa preliminar e da petição inicial, analisa se dá ou não início ao processo, recebendo a petição inicial e determinando a citação da outra parte.

Esmiuçando:

A CF estabelece que os atos de improbidade implicarão:

- a suspensão dos direitos políticos
- perda da função pública
- indisponibilidade de bens
- ressarcimento ao erário

Essa disposição é regulamentada pela Lei 8.429/92.

2. ELEMENTOS DO ATO DE IMPROBIDADE

Para que o ato de improbidade implique a aplicação das medidas sancionatórias, é preciso que alguns elementos estejam presente:

- Sujeito passivo
- Sujeito ativo
- Ato de improbidade
- Elemento subjetivo

2.1. SUJEITO PASSIVO

O sujeito passivo é aquele que sofre o ato de improbidade.

Poderão ser atingidos pelo ato de improbidade:

- Administração direta, indireta e fundacional
- Empresa incorporada pelo patrimônio público
- Qualquer entidade a cuja criação o Estado tenha custeado 50% ou mais do seu patrimônio ou para sua receita anual



Estes são os **sujeitos passivos primários** do ato de improbidade.

O parágrafo único do art. traz os **sujeitos passivos secundários** do ato de improbidade, bastando que sejam lesados indiretamente o patrimônio público ou que haja lesão aos princípios da administração para que se tenha um ato de improbidade.

- Qualquer entidade que receba subvenção do Poder Público
- Entidade para qual o Poder Público tenha concorrido com menos de 50% para sua receita anual. Nesse caso, fica limitada a possibilidade de punição àquilo que o Estado concorreu.

Veja, pessoa física não pode ser sujeito passivo de ato de improbidade.

2.2. SUJEITO ATIVO

Sujeito ativo é quem pratica o ato de improbidade.

Poderá ser sujeito ativo:

- Agente público
- Terceiro que esteja combinado com o agente público, desde que induza, concorra ou se beneficie com o ato de improbidade.

Agente público é todo aquele que exercer, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por nomeação, designação ou contratação, ou qualquer forma de vínculo, cargo, emprego, mandato ou função nas entidades compreendidas como sujeito passivo, poderão ser sujeito ativo do ato de improbidade.

Segundo o STJ, não é possível o ajuizamento de ação de improbidade administrativa **exclusivamente em face de particular**, sem a concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda.

Estagiário, segundo o STJ, poderá ser sujeito ativo do ato de improbidade administrativo.

2.3. ATO DE IMPROBIDADE

O ato de improbidade é ilegal, imoral, praticado no exercício de uma função pública, constituindo-se um ilícito de natureza civil e de natureza política, não sendo ilícito de natureza penal, necessariamente.

Recentemente, a LC 157/2016 alterou a Lei nº 8.429/92, criando uma 4ª espécie de ato de improbidade administrativa.

Dessa forma, em relação aos atos de improbidade, a lei está dividida em 4 categorias:

- Atos que levam ao enriquecimento ilícito
- Atos que causam prejuízos ao erário
- Atos decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário
- Atos que violam os princípios da administração pública

2.3.1. ATOS QUE LEVAM AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO (ART. 9)

O art. 9º diz que constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades que são sujeitos passivos do ato.

São exemplos de atos de improbidade que importem enriquecimento ilícito:

- receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público;
- perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no art. 1º por preço superior ao valor de mercado;



- perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado;
- utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades;
- receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem;
- receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;
- adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público;
- aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade;
- perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza;
- receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado;
- incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;
- usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei.

O STJ já decidiu que, ainda que não haja danos ao erário, é possível a condenação por ato de improbidade administrativa que importe enriquecimento ilícito.

2.3.2. ATOS QUE CAUSAM PREJUÍZOS AO ERÁRIO (ART. 10)

O art. 10 diz que constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, **dolosa ou culposa**, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas como sujeito passivo do ato de improbidade.

São exemplos de atos de improbidade que causam prejuízos ao erário:

- facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;
- permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
- doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie;
- permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no art. 1º desta lei, ou ainda a prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado;



- permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado;
- realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea;
- conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
- frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente
- frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente;
- ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;
- agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público;
- liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;
- permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;
- permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades.
- celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei;
- celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas na lei.
- facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação, ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie
- permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidade privada mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie
- celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie
- agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas
- liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular.
- liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular.

2.3.3. ATOS DECORRENTES DE CONCESSÃO OU APLICAÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO FINANCEIRO OU TRIBUTÁRIO (ART. 10-A)

Segundo o art. 10-A, constitui ato de improbidade administrativa **qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõem o caput e o § 1º do art. 8º-A da Lei Complementar nº 116/03.**



Esse dispositivo foi inserido pela LC 157/2016, criando uma quarta espécie de ato de improbidade administrativa.

Apesar de a nova lei ser uma lei complementar, vale ressaltar que isto se deu em razão de que a LC 157 tratou sobre ISSQN, tema que exige lei complementar. Logo, o tema "improbidade administrativa" não é reservado para lei complementar.

Isso significa que, se no futuro o legislador quiser revogar o art. 10-A da Lei nº 8.429/92, acrescentado pela LC 157/2016, ele poderá fazer isso por meio de uma simples lei ordinária. Em suma, **o art. 4º da LC 157/2016 é materialmente uma lei ordinária porque trata de assunto (improbidade administrativa) para o qual a CF/88 não exige lei complementar**.

Com relação ao novo ato de improbidade administrativa, observe-se que o legislador resolveu ser extremamente rigoroso em relação à medida imposta e **determinou que constitui ato de improbidade administrativa conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário em contrariedade ao art. 8ºA, caput ou § 1º da LC 116/2003**.

Vale ressaltar que o art. 10-A afirma que **configura ato de improbidade administrativa a ação ou omissão**. Por exemplo se determinado Município está concedendo isenção fiscal de ISS em contrariedade ao art. 8ºA da LC 116/2003. São realizadas novas eleições municipais e assume um novo Prefeito. Caso este não tome providências para fazer cessar esta isenção, responderá por ato de improbidade administrativa por conta de sua omissão.

Para que o agente público responda pelo ato de improbidade administrativa do art. 10-A, exige-se dolo. Assim, se o dirigente municipal agiu apenas com culpa, não poderá ser condenado pelo art. 10-A.

Segundo a jurisprudência do STJ, o ato de improbidade administrativa só pode ser punido a título de mera culpa se isso estiver expressamente previsto na lei. É o caso do art. 10 da Lei nº 8.429/92. Se o tipo não fala em culpa, entende-se que ele só pune a conduta se praticada dolosamente.

O administrador que praticar o ato de improbidade do art. 10-A está sujeito às seguintes penalidades:

- Perda da função pública;
- Suspensão dos direitos políticos de **5 a 8 anos** e
- Multa civil de **até 3 vezes** o valor do benefício financeiro ou tributário concedido.

A ação de improbidade pedindo a condenação do agente público pelo art. 10-A poderá ser proposta:

- Pelo Ministério Público;
- Pela pessoa jurídica interessada.

Atente-se que a "pessoa jurídica interessada" não é apenas o Município no qual o ato de improbidade está sendo praticado. O Município que está sendo prejudicado pela concessão de isenção em desacordo com o art. 8º-A da LC 116/2003 também deve ser considerado como "pessoa jurídica interessada" e poderá propor a ação de improbidade ou intervir no processo como interessado.

A nova hipótese de ato de improbidade inserida no art. 10-A da Lei nº 8.429/92 já está em vigor, mas **somente produzirá efeitos a partir de 30/12/2017**.

É o que prevê o § 1º do art. 7º da LC 157/2016, o qual prevê que o disposto no caput e nos §§ 1º e 2º do art. 8º-A da Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003, e no art. 10-A, no inciso IV do art. 12 e no § 13 do art. 17, todos da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, somente produzirão efeitos após o decurso do prazo referido no art. 6º desta Lei Complementar.

2.3.4. ATOS QUE VIOLAM OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ART. 11)

O art. 11 diz que constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições.

São exemplos de atos de improbidade que violam



- praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;
- retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
- revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;
- negar publicidade aos atos oficiais;
- frustrar a licitude de concurso público;
- deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;
- revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.
- descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.
- deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação.

2.3.5. ELEMENTO SUBJETIVO

Elemento subjetivo é o dolo ou culpa.

A jurisprudência admite a forma culposa do ato administrativo, quando este ato causar dano ao erário.

Nos demais casos, como o enriquecimento ilícito e a violação dos princípios administrativo, será necessário que a conduta seja dolosa.

3. SANÇÕES POSSÍVEIS

As sanções têm natureza extrapenal, pois se trata de ilícito de caráter civil e político.

Os atos de improbidade poderão importar:

- Ressarcimento ao erário
- Indisponibilidade dos bens, podendo ser feita antecipadamente
- Suspensão dos direitos políticos
- Perda da função pública
- Perda de bens e valores acrescidos ilicitamente
- Multa civil
- Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios do Poder Público

Ressalte-se que o STJ entende que é possível, no âmbito da ação civil pública de improbidade, a perda da função pública do membro do Ministério Público, ainda que se trate de membro vitalício. A garantia da vitaliciedade diz que só se pode perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado. E nada impede que dentre as sanções aplicadas ao promotor de justiça haja a perda da função pública que exerce.

A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos, que são sanções ainda previstas na CF, **só irá ocorrer com o trânsito em julgado da sentença.**

Se for necessário no caso concreto, a **autoridade judicial ou administrativa** poderá determinar o afastamento do agente no exercício de seu cargo de forma antecipada, mas não haverá prejuízo da remuneração.

A aplicação das sanções da lei de improbidade independe da ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo se houver a pena de ressarcimento.

Além disso, independe da aprovação ou rejeição das contas pelo Tribunal de Contas.



4. GRADAÇÃO DAS SANÇÕES

As sanções têm alguma gradação. Isso irá depender da categoria do ato de improbidade.

São sanções por ato de improbidade que **cause enriquecimento ilícito**:

- Perda dos valores acrescidos ilicitamente;
- Ressarcimento do dano causado ao erário (**inclusive dano moral**), se houver.
- Perda da função do agente público;
- Suspensão de direitos políticos por **08 a 10 anos**.
- Multa civil no valor de **até 03 vezes o valor acrescido ilicitamente** ao patrimônio do agente ímprobo.
- Proibição de contratar e de receber benefícios fiscais e creditícios **por 10 anos** (perceba que aqui a lei não usa a palavra até).

Segundo o STJ, ainda que não haja danos ao erário, é possível a condenação por ato de improbidade administrativa que importe enriquecimento ilícito (art. 9º da Lei nº 8.429/92), excluindo-se, contudo, a possibilidade de aplicação da pena de ressarcimento ao erário. (REsp 1.412.214-PR, Inf. 580, STJ).

Sanções pelo ato de improbidade que **cause prejuízo ao erário**:

- Perda dos valores acrescidos ilicitamente, se ocorrer essa circunstância. Essa sanção, quando ocorrer, **sempre será em desfavor do terceiro**, quando este enriquecer ilicitamente com ato do agente público que causa dano ao erário.
- Ressarcimento dos danos causados. **Tanto o agente quanto o terceiro podem ser obrigados a ressarcir.**
- Perda de função
- Suspensão de direitos políticos por **05 a 08 anos**.
- Multa civil no valor de **até 02 vezes o dano causado** ao erário.
- Proibição de contratar e receber benefícios fiscais e creditícios pelo prazo de **05 anos**.

Segundo o STJ, é cabível a aplicação da pena de ressarcimento ao erário nos casos de ato de improbidade administrativa **consistente na dispensa ilegal de procedimento licitatório** (art. 10, VIII, da Lei 8.429/1992) **mediante fracionamento indevido do objeto licitado**. De fato, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, a existência de prejuízo ao erário é condição para determinar o ressarcimento ao erário, nos moldes do art. 21, I, da Lei 8.429/1992. Neste caso, **não há como concluir pela inexistência do dano, pois o prejuízo ao erário é inerente (in re ipsa) à conduta ímproba, na medida em que o Poder Público deixa de contratar a melhor proposta, por condutas de administradores** (REsp 1.376.524-RJ).

Sanções pela **violação a princípio da administração**:

- Ressarcimento integral do dano, se houver. **Somente sobre o terceiro** pode recair essa responsabilidade.
- Perda de função.
- Suspensão dos direitos políticos por **03 a 05 anos**.
- Multa de **até 100 vezes a remuneração** mensal do agente
- Proibição de contratar e receber benefícios fiscais e creditícios pelo prazo de **03 anos** (não pode ser abaixo disso, vide Info 581, STJ).

OSTJ decidiu que as **penalidades de suspensão dos direitos políticos e de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios não podem ser fixadas abaixo de 03 anos, considerando que este é o mínimo previsto no art. 12, III, da Lei nº 8.429/92**. Não existe autorização na lei para estipular sanções abaixo desse patamar (Inf. 581, STJ).



5. DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAL

Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa ou ao Ministério Público para que seja instaurada investigação para apurar a suposta ocorrência de ato de improbidade.

Essa representação não poderá ser apócrifa, devendo ser escrita.

Se houver fundado indício de responsabilidade, a decretação de da indisponibilidade dos bens poderá ser imediatamente requerida ao juízo competente. Inclusive poderá o juiz aplicar essa medida sobre bens adquiridos **anteriormente à conduta** ímproba.

A ação judicial seguirá um rito comum, proposta pelo MP ou pela pessoa jurídica interessada.

Estando devidamente instruída, será determinada a notificação do requerido, o qual apresentará uma manifestação escrita no prazo de **15 dias**. O juiz recebe essa manifestação e no prazo de 30 dias decide se recebe a inicial ou se vai rejeitá-la.

Estando convencido de que o ato não existiu ou de que o pleito é improcedente, ou de que a via eleita foi inadequada, o juiz rejeita a ação.

Caso contrário, o juiz receberá a petição inicial, ordenando a citação do réu para apresentar contestação.

A autoridade judicial e a autoridade administrativa podem determinar o afastamento do agente público no exercício do seu cargo, caso seja necessário, sem prejuízo da remuneração.

As ações de improbidade administrativa poderão ser propostas em:

- até 05 anos, após o término do mandato ou do cargo em comissão, ou;
- no prazo prescricional da sanção administrativa de demissão, nos casos de exercício de cargo efetivo ou de emprego público.

Em relação aos **particulares**, o STJ entende que **deve ser aplicado o prazo de 05 anos**.

O *periculum in mora* para decretar a indisponibilidade de bens decorrente do ato de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF) é **presumido**.

Ainda que proferida por juízo absolutamente incompetente, é válida a decisão que, em ação civil pública proposta para a apuração de ato de improbidade administrativa, tenha determinado – até que haja pronunciamento do juízo competente – a indisponibilidade dos bens do réu a fim de assegurar o ressarcimento de suposto dano ao patrimônio público.

Segundo o STJ, a indisponibilidade pode recair sobre bens de família.

6. RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA DE PESSOAS JURÍDICAS PELA PRÁTICA DE ATOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO (LEI 12.846/13)

Aqui há uma responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoa jurídica por prática de ato contra a administração.

Neste caso, não se analisa culpa *lato sensu*.

Serão submetidas a esta responsabilização:

- sociedades empresárias
- sociedades simples, personificadas ou não
- fundações
- associações
- sociedades estrangeiras etc.

Segundo a Lei 12.846, as pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, nos âmbitos administrativo e civil, **pelos atos lesivos previstos nesta Lei praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não**.



6.1. ATOS LESIVOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Segundo a Lei, constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, que atentem:

- **contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro**
- **contra princípios da administração pública**
- **contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil**

Destacam-se como atos lesivos à administração pública:

- **prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;**
- **comproadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei;**
- **comproadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;**
- **dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.**
- **frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;**
- **impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;**
- **afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;**
- **fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;**
- **criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;**
- **obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou**
- **manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;**

Essa responsabilização poderá se dar na via administrativa, mas também poderá ocorrer na via judicial.

6.2. RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Na esfera administrativa, as pessoas jurídicas poderão sofrer algumas sanções, tais como:

- multa
- publicação extraordinária da decisão condenatória

Essas sanções são penalidades que podem ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente.

A instauração e julgamento do processo administrativo para apuração da responsabilidade da pessoa jurídica, caberá à autoridade máxima de cada órgão ou à entidade de poder.

O processo será conduzido por uma comissão da administração, **devendo haver 2 ou mais servidores estáveis.**

O **prazo da defesa** da pessoa jurídica será de **30 dias**.

A comissão irá concluir o processo no prazo de 180 dias, prorrogável pela autoridade que instaurou o processo. Ao final desses 180 dias, a comissão irá apresentar um relatório, recomendando uma punição ou não.



Vale destacar que a personalidade jurídica da pessoa jurídica poderá ser desconsiderada sempre que houver abuso de direito, situação na qual irá estender os efeitos das sanções aos administradores e aos sócios que tinham o poder de gestão e administração.

6.3. RESPONSABILIZAÇÃO JUDICIAL

A responsabilização da pessoa jurídica na esfera administrativa não afasta a responsabilização da esfera judicial.

Essa responsabilização judicial poderá ser afastada quando houver o **acordo de leniência**.

A responsabilização na esfera judicial poderá dar ensejo a algumas sanções, podendo ser aplicadas cumulativamente ou isoladamente:

- **Perdimento de bens**
- **Suspensão ou interdição parcial das atividades da empresa.**
- Se for o caso, a **dissolução compulsória da empresa**, caso tenha sido constituída para cometer ilícito ou esteja sendo utilizada para atos ímprobos
- **Proibição de receber incentivos de órgãos, entidade pública ou instituição financeira controlada pelo Poder Público pelo prazo mínimo de 1 ano e máximo de 5 anos.**

6.4. ACORDO DE LENIÊNCIA

As unidades federativas podem, por meio de seus órgãos de controle interno, de forma isolada ou em conjunto com o Ministério Público e com as respectivas advocacias públicas, celebrar acordo de leniência com pessoas responsáveis por prática de atos de improbidade administrativa, e pelos atos e fatos da Lei 12.846/13.

No âmbito do poder executivo federal, será realizado pela Controladoria Geral da União.

Essa pessoa jurídica vai fazer uma colaboração com o Poder Público. Essa colaboração deverá resultar:

- na **identificação dos demais envolvidos na infração**, quando couber; e
- na **obtenção célere de informações e documentos que comprovem o ilícito sob apuração**.

Caso haja a homologação do acordo de leniência, a pessoa jurídica ficará **isenta da sanção administrativa de publicação extraordinária** da decisão condenatória.

Em segundo lugar, **ficará isenta das sanções restritivas do direito de licitar e de contratar**.

Ainda, **poderá ter reduzida em seu favor 2/3 da multa imputada**.

O acordo de leniência **somente poderá ser celebrado se preenchidos**, cumulativamente, os seguintes requisitos:

- a **pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar** sobre seu interesse em cooperar para a apuração do ato ilícito;
- a **pessoa jurídica cesse completamente seu envolvimento na infração investigada** a partir da data de propositura do acordo;
- a **pessoa jurídica admita sua participação no ilícito e coopere plena e permanentemente com as investigações e o processo administrativo**, comparecendo, sob suas expensas, sempre que solicitada, a todos os atos processuais, até seu encerramento.

O acordo de leniência não exime de reparar o dano causado.

A proposta de acordo de leniência somente se tornará pública **após a efetivação do respectivo acordo**, salvo no interesse das investigações e do processo administrativo.

Em caso de **descumprimento** do acordo de leniência, a pessoa jurídica **ficará impedida de celebrar novo acordo pelo prazo de 03 anos** contados do conhecimento pela administração pública do referido descumprimento.



Compliance consiste em mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica, o que nos termos do art. 7, VII, deve ser levado em consideração na aplicação de sanções

6.5. PRESCRIÇÃO

As infrações previstas na Lei 12.846 ficam sujeitas a prescrição. O prazo prescricional será de **05 anos**.

A **instauração do processo** vai interromper a prescrição. Caso haja a formulação da proposta de um acordo de leniência, ficará suspenso o prazo prescricional. A partir de o momento em que há a celebração do acordo de leniência, ficará interrompida a prescrição.

Para o STJ o termo inicial da prescrição em improbidade administrativa em relação a particulares que se beneficiam de ato ímprobo é idêntico ao do agente público que praticou a ilicitude. A eventual prescrição das sanções decorrentes dos atos de improbidade administrativa não obsta o prosseguimento da demanda quanto ao pleito de ressarcimento dos danos causados ao erário, que é imprescritível (artigo 37, parágrafo 5º da CF). No caso de agentes políticos reeleitos, o termo inicial do prazo prescricional nas ações de improbidade administrativa deve ser contado a partir do término do último mandato.

Resumidamente, se o requerido for detentor de cargo em comissão, função de confiança ou mandato eletivo, o prazo de prescrição para a propositura de ação de improbidade será de 05 anos a contar do término do exercício do cargo, função de confiança ou mandato. Na hipótese de reeleição o prazo prescricional começará a partir do término último mandato, conforme entendimento do STJ.

Caso o réu seja servidor público, o prazo prescricional será o mesmo previsto para infrações puníveis com demissão, contado a partir do conhecimento do ato infracional pela Administração Pública – para a União o prazo prescricional será de 05 anos.

Caso particulares participem do ato de improbidade, o entendimento majoritário é o prazo prescricional seguirá o utilizado para o agente público com que atuou em concurso. Já para as entidades privadas que recebem benefício fiscal ou aquelas em que o dinheiro público concorre com menos de 50% da formação do capital, a ação de improbidade prescreve em até 05 anos da data da apresentação à Administração Pública da prestação de contas final.

Porém, segundo a jurisprudência do STF, são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na lei de Improbidade Administrativa (RE 852475).

6.6. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO

O STF já considerou julgou que não possui competência para processar e julgar ação de improbidade administrativa contra agente político. O foro por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal em relação às infrações penais comuns, segundo os ministros, não é extensível às ações de improbidade administrativa, que têm natureza civil (PET 3.240). A corte reconheceu o duplo regime sancionatório, ou seja, o fato de um agente estar sujeito a crime por responsabilidade não excluiria a sua responsabilização também por improbidade administrativa. Os agentes políticos, com exceção do presidente da República, encontram-se sujeitos a um duplo regime sancionatório, e se submetem tanto à responsabilização civil pelos atos de improbidade administrativa quanto à responsabilização político-administrativa por crimes de responsabilidade.

A ação de improbidade administrativa não possui natureza penal, sendo assim a fixação de competência da Justiça de primeiro grau para julgar ação de improbidade respeita o princípio republicano e atenta às capacidades institucionais dos diferentes graus de jurisdição para a instrução processual.

7. TESES DO STJ

Por fim, cabe apresentar as teses do STJ sobre o tema:



- 1) É inadmissível a responsabilidade objetiva na aplicação da Lei n. 8.429/1992, exigindo-se a presença de dolo nos casos dos arts. 9º e 11 (que coíbem o enriquecimento ilícito e o atentado aos princípios administrativos, respectivamente) e ao menos de culpa nos termos do art. 10, que censura os atos de improbidade por dano ao Erário.
- 2) O Ministério Público tem legitimidade ad causam para a propositura de Ação Civil Pública objetivando o ressarcimento de danos ao erário, decorrentes de atos de improbidade.
- 3) O Ministério Público estadual possui legitimidade recursal para atuar como parte no Superior Tribunal de Justiça nas ações de improbidade administrativa, reservando-se ao Ministério Público Federal a atuação como fiscal da lei.
- 4) A ausência da notificação do réu para a defesa prévia, prevista no art. 17, § 7º, da Lei de Improbidade Administrativa, só acarreta nulidade processual se houver comprovado prejuízo (*pas de nullité sans grief*).
- 5) A presença de indícios de cometimento de atos ímprobos autoriza o recebimento fundamentado da petição inicial nos termos do art. 17, §§ 7º, 8º e 9º, da Lei n. 8.429/92, devendo prevalecer, no juízo preliminar, o princípio do *in dubio pro societate*.
- 6) O termo inicial da prescrição em improbidade administrativa em relação a particulares que se beneficiam de ato ímprobo é idêntico ao do agente público que praticou a ilicitude.
- 7) A eventual prescrição das sanções decorrentes dos atos de improbidade administrativa não obsta o prosseguimento da demanda quanto ao pleito de ressarcimento dos danos causados ao erário, que é imprescritível (art. 37, § 5º, da CF).
- 8) É inviável a propositura de ação civil de improbidade administrativa exclusivamente contra o particular, sem a concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda.
- 9) Nas ações de improbidade administrativa, não há litisconsórcio passivo necessário entre o agente público e os terceiros beneficiados com o ato ímprobo.
- 10) A revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ação de improbidade administrativa implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontrando óbice na súmula 7/STJ, salvo se da leitura do acórdão recorrido verificar-se a desproporcionalidade entre os atos praticados e as sanções impostas.
- 11) É possível o deferimento da medida acautelatória de indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa nos autos da ação principal sem audiência da parte adversa e, portanto, antes da notificação a que se refere o art. 17, § 7º, da Lei n. 8.429/92.
- 12) É possível a decretação de indisponibilidade de bens do promovido em ação civil Pública por ato de improbidade administrativa, quando ausente (ou não demonstrada) a prática de atos (ou a sua tentativa) que induzam a conclusão de risco de alienação, oneração ou dilapidação patrimonial de bens do acionado, dificultando ou impossibilitando o eventual ressarcimento futuro.
- 13) Na ação de improbidade, a decretação de indisponibilidade de bens pode recair sobre aqueles adquiridos anteriormente ao suposto ato, além de levar em consideração, o valor de possível multa civil como sanção autônoma.
- 14) No caso de agentes políticos reeleitos, o termo inicial do prazo prescricional nas ações de improbidade administrativa deve ser contado a partir do término do último mandato.
- 15) Os Agentes Políticos sujeitos a crime de responsabilidade, ressalvados os atos ímprobos cometidos pelo Presidente da República (art. 86 da CF) e pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não são imunes às sanções por ato de improbidade previstas no art. 37, § 4º, da CF.
- 16) Os agentes políticos municipais se submetem aos ditames da Lei de Improbidade Administrativa - LIA, sem prejuízo da responsabilização política e criminal estabelecida no Decreto-Lei n. 201/1967.
- 17) A ação de improbidade administrativa deve ser processada e julgada nas instâncias ordinárias, ainda que proposta contra agente político que tenha foro privilegiado.
- 18) A aplicação da pena de demissão por improbidade administrativa não é exclusividade do Judiciário, sendo passível a sua incidência no âmbito do processo administrativo disciplinar.
- 19) Havendo indícios de improbidade administrativa, as instâncias ordinárias poderão decretar a quebra do sigilo bancário.

- 20) O afastamento cautelar do agente público de seu cargo, previsto no parágrafo único do art. 20 da Lei n. 8.429/92, é medida excepcional que pode perdurar por até 180 dias.
- 21) O especialíssimo procedimento estabelecido na Lei n. 8.429/92, que prevê um juízo de delibação para recebimento da petição inicial (art. 17, §§ 8º e 9º), precedido de notificação do demandado (art. 17, § 7º), somente é aplicável para ações de improbidade administrativa típicas.
- 22) Aplica-se a medida cautelar de indisponibilidade dos bens do art. 7º aos atos de improbidade administrativa que impliquem violação dos princípios da administração pública do art. 11 da LIA.
- 23) O ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/92 não requer a demonstração de dano ao erário ou de enriquecimento ilícito, mas exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não necessita ser específico, sendo suficiente o dolo genérico.
- 24) Nas ações de improbidade administrativa é admissível a utilização da prova emprestada, colhida na persecução penal, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 25) O magistrado não está obrigado a aplicar cumulativamente todas as penas previstas no art. 12 da Lei n. 8.429/92, podendo, mediante adequada fundamentação, fixá-las e dosá-las segundo a natureza, a gravidade e as consequências da infração.

8. JURISPRUDÊNCIA

8.1. SÚMULAS DO STJ

Súmula. 634 Ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente público.

8.2. INFORMATIVOS STF

O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei nº 8.429/92, em virtude da autonomia das instâncias. STF. Plenário. RE 976566, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/09/2019 (repercussão geral – Tema 576)

A nomeação do cônjuge de prefeito para o cargo de Secretário Municipal, por se tratar de cargo público de natureza política, por si só, não caracteriza ato de improbidade administrativa. STF. 2ª Turma. Rcl 22339 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4/9/2018 (Info 914).

Poderá ficar caracterizado o nepotismo mesmo em se tratando de cargo político caso fique demonstrada a inequívoca falta de razoabilidade na nomeação por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral do nomeado. STF. 1ª Turma. Rcl 28024 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 29/05/2018

São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. STF. Plenário. RE 852475/SP, Rel. orig. Min. Alexandre de Moraes, Rel. para acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 08/08/2018 (repercussão geral) (Info 910).

Os agentes políticos, com exceção do Presidente da República, encontram-se sujeitos a duplo regime sancionatório, de modo que se submetem tanto à responsabilização civil pelos atos de improbidade administrativa quanto à responsabilização político-administrativa por crimes de responsabilidade. O foro especial por prerrogativa de



função previsto na Constituição Federal em relação às infrações penais comuns não é extensível às ações de improbidade administrativa. STF. Plenário. Pet 3240 AgR/DF, rel. Min. Teori Zavascki, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 10/5/2018 (Info 901).

Os agentes políticos, com exceção do Presidente da República, encontram-se sujeitos a um duplo regime sancionatório, de modo que se submetem tanto à responsabilização civil pelos atos de improbidade administrativa, quanto à responsabilização político-administrativa por crimes de responsabilidade. Não há qualquer impedimento à concorrência de esferas de responsabilização distintas, de modo que carece de fundamento constitucional a tentativa de imunizar os agentes políticos das sanções da ação de improbidade administrativa, a pretexto de que estas seriam absorvidas pelo crime de responsabilidade. A única exceção ao duplo regime sancionatório em matéria de improbidade se refere aos atos praticados pelo Presidente da República, conforme previsão do art. 85, V, da Constituição. O foro especial por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal em relação às infrações penais comuns não é extensível às ações de improbidade administrativa, de natureza civil. Em primeiro lugar, o foro privilegiado é destinado a abarcar apenas as infrações penais. A suposta gravidade das sanções previstas no art. 37, § 4º, da Constituição, não reveste a ação de improbidade administrativa de natureza penal. Em segundo lugar, o foro privilegiado submete-se a regime de direito estrito, já que representa exceção aos princípios estruturantes da igualdade e da república. Não comporta, portanto, ampliação a hipóteses não expressamente previstas no texto constitucional. E isso especialmente porque, na hipótese, não há lacuna constitucional, mas legítima opção do poder constituinte originário em não instituir foro privilegiado para o processo e julgamento de agentes políticos pela prática de atos de improbidade na esfera civil. Por fim, a fixação de competência para julgar a ação de improbidade no 1º grau de jurisdição, além de constituir fórmula mais republicana, é atenta às capacidades institucionais dos diferentes graus de jurisdição para a realização da instrução processual, de modo a promover maior eficiência no combate à corrupção e na proteção à moralidade administrativa.

[Pet 3.240 AgR, rel. p/ o ac. min. Roberto Barroso, j. 10-5-2018, P, DJE de 22-8-2018.]

Os agentes políticos, com exceção do Presidente da República, encontram-se sujeitos a duplo regime sancionatório, de modo que se submetem tanto à responsabilização civil pelos atos de improbidade administrativa quanto à responsabilização político-administrativa por crimes de responsabilidade. O foro especial por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal em relação às infrações penais comuns não é extensível às ações de improbidade administrativa. STF. Plenário. Pet 3240 AgR/DF, rel. Min. Teori Zavascki, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 10/5/2018 (Info 901).

8.3. INFORMATIVOS STJ

A ação de improbidade administrativa deve ser processada e julgada nas instâncias ordinárias, ainda que proposta contra agente político que tenha foro privilegiado no âmbito penal e nos crimes de responsabilidade. STJ. Corte Especial. AgRg na Rcl 12514-MT, Rel. Min. Ari Pargendler, julgado em 16/9/2013 (Info 527).



Em caso de ação de improbidade administrativa que envolva dois ou mais réus, o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 23 da Lei nº 8.429/92 deve ser contado de forma individual. O art. 23 é claro no sentido de que o início do prazo prescricional ocorre com o término do exercício do mandato ou cargo em comissão, sendo tal prazo computado individualmente, mesmo na hipótese de concurso de agentes, haja vista a própria natureza subjetiva da pretensão sancionatória e do instituto em tela. STJ. 2ª Turma. REsp 1230550/PR, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 20/02/2018.

QUESTÕES

1. (MP-CE) CESPE, 2020. Prefeito de município da Federação, juntamente com um servidor público federal e um advogado privado, cometeu ato de improbidade administrativa envolvendo recursos públicos federais conforme previsão da Lei n.º 8.429/1992, o que causou prejuízo ao erário.

Nessa situação hipotética, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de improbidade administrativa

A será imprescritível para todos os envolvidos, tenha sido sua conduta dolosa ou culposa, assim como para as ações de ressarcimento ao erário decorrentes da improbidade.

B iniciará, no caso do prefeito, após o término do primeiro mandato, ainda que ele seja reeleito para o mesmo cargo.

C iniciará, no caso do prefeito, após o término do segundo mandato, se ele tiver sido reeleito para o mesmo cargo.

D será, para o advogado e para o servidor público federal, o previsto no estatuto do servidor.

E iniciará, no caso do prefeito e do servidor público federal, a partir da data da prática do ato

2. (MP-CE) CESPE, 2020. Servidor público estadual que, no exercício da função pública, concorrer para que terceiro enriqueça ilicitamente estará sujeito a responder por ato de improbidade administrativa que

A atenta contra os princípios da administração pública, se sua conduta for dolosa.

B atenta contra os princípios da administração pública, ainda que sua conduta seja culposa.

C importa enriquecimento ilícito, se sua conduta for dolosa.

D importa enriquecimento ilícito, ainda que sua conduta seja culposa.

E causa prejuízo ao erário, ainda que sua conduta seja culposa.

3. (MP-CE) CESPE, 2020. Lúcio, conselheiro de tribunal de contas estadual, Pierre, prefeito de município, e Mário, desembargador de tribunal de justiça estadual, cometeram ato de improbidade administrativa, previsto na Lei n.º 8.429/1992.

Nessa situação hipotética, no âmbito do Poder Judiciário, deverá ocorrer o processamento e julgamento em 1.ª instância de

A Lúcio, Pierre e Mário.

B Lúcio e Pierre, somente.

C Lúcio e Mário, somente.

D Pierre e Mário, somente.

E Pierre, somente.

4. (TJPA) CESPE, 2019. À luz da Lei n.º 8.429/1992, assinale a opção correta, a respeito de improbidade administrativa.

A Se a lesão ao patrimônio público decorrer de ato comissivo, o ressarcimento será devido independentemente da existência de dolo; se decorrer de ato omissivo, o ressarcimento somente será devido se o ato tiver sido doloso.

BA representação para instauração de investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade pode ser apresentada por qualquer cidadão, desde que se comprove estar em gozo dos direitos políticos.

C Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, seja ele servidor público ou não, sujeitam-se à referida lei.

D Os empregados de entidade cuja receita anual seja total ou parcialmente custeada pelo erário sujeitam-se à referida lei, desde que exerçam função remunerada.

EO Ministério Público deve obrigatoriamente figurar no polo ativo dos processos de improbidade administrativa, sob pena de nulidade.

5. (TJAL) FCC, 2019. Suponha que tenha sido interposta ação de improbidade administrativa em face de diretor de uma empresa na qual o Estado do Alagoas detém participação acionária minoritária, apontando a ocorrência de prejuízos financeiros à companhia em face da realização de investimentos em projetos deficitários. A inicial da ação judicial aponta, ainda, a responsabilidade de Secretários de Estado na formatação de tais projetos e possível conluio com o diretor da companhia para as aprovações societárias correspondentes. Considerando as disposições da legislação aplicável, a referida demanda afigura-se

A cabível, tanto em face do diretor como dos Secretários de Estado, limitando-se a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos à companhia.

B cabível apenas em face dos Secretários de Estado, dada a necessária condição de agentes públicos, respondendo o diretor da companhia exclusivamente na esfera civil.

C descabida, eis que não se verifica prejuízo a entidade pública ou a empresa na qual o poder público detenha a maioria do capital social.

D cabível apenas em face do diretor da companhia, nos limites da conduta lesiva apurada, não alcançando os Secretários de Estado, os quais poderão responder por crime de responsabilidade.

E cabível apenas se apurada conduta dolosa dos imputados, eis que o elemento volitivo doloso é determinante para a caracterização de atos de improbidade, que não admitem modalidade culposa.

COMENTÁRIOS

1. Gabarito – C

A) Incorreta. O prazo de prescrição para a propositura de ação de improbidade será de 5 anos a contar do término do exercício do cargo, função de confiança ou mandato

B) Incorreta. No caso de agentes políticos reeleitos, o termo inicial do prazo prescricional nas ações de improbidade administrativa deve ser contado a partir do término do último mandato, e não do primeiro.

C) Correta

D) Incorreta. A assertiva é correta apenas para o servidor. Embora o entendimento majoritário seja que a prescrição para a aplicação de penalidade é a mesma prevista para o agente público que atuou em concurso com o particular, há doutrina no sentido de que se aplica o prazo de 10 anos, por ser o previsto no Código Civil como prazo genérico

E) Incorreta. Cf. art. 23, I Lei 8.429/92

2. Gabarito – E

Todas as alternativas conforme o art. 10, inciso XII, da Lei 8.429/92.

3. Gabarito – A

Todas as alternativas conforme REsp1.138.173/RN.

4. Gabarito – C

A) Incorreta. Cf. 5º da Lei 8.429/92.

B) Incorreta. Cf. art. 14, caput e §1º Lei 8.429/92

C) Correta. Cf. art. 1º, caput, da Lei 8.429/92.

D) Incorreta. Cf. art. 2º da Lei 8.429/92



E) Incorreta. Cf. art. 17, caput e §4º, da Lei 8.429/92.

5. Gabarito – A

A) Correta. Cf. art. 1º parágrafo único Lei 8.429/92.

B) Incorreta. Cf. art. 3º Lei 8.429/92.

C) Incorreta. Cf. art. 1º parágrafo único Lei 8.429/92.

D) Incorreta. Cf. Pet 3240.

E) Incorreta. Cf. art. 10, Lei 8.429/92



CAPÍTULO 16 — CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

1. INTRODUÇÃO

Por força do regime democrático e do sistema representativo os atos do Estado não podem se distanciar da satisfação do interesse público. Consequentemente deve existir uma fiscalização constante, capaz de verificar e punir potenciais desvios. Maria Zanella Di Pietro¹¹⁶ esclarece que o controle sobre a Administração Pública pode ser definido como o "poder de fiscalização e correção que sobre ela exercem os órgãos dos Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, com o objetivo de garantir a conformidade de sua atuação com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico".

2. CLASSIFICAÇÃO DO CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO

O controle da administração pública poderá ser classificado das seguintes formas:

2.1. CONFORME O MOMENTO A SER EXERCIDO O CONTROLE

Esse controle poderá ser:

- **Prévio:** o controle é exercido antes da prática do ato. É o Senado Federal que autoriza a União, Estado ou Município a contrair empréstimo externo.
- **Concomitante:** o controle acontece durante a prática do ato. É a fiscalização de um contrato em andamento, enquanto a obra está sendo executada.
- **Posterior (ou Corretivo):** o controle tem por objetivo convalidar ou declarar a nulidade de um ato administrativo. Por exemplo a homologação de uma licitação é um controle a posteriori.

2.2. CONFORME A AMPLITUDE

O controle poderá ser:

- **Hierárquico:** esse controle resulta do poder hierárquico, o escalonamento vertical dos órgãos da Administração Pública.
- **Finalístico:** também é chamado de tutela ou de supervisão ministerial. Não decorre da hierarquia, sendo exercido pela administração direta sobre a indireta, e depende de previsão legal.

2.3. CONFORME A ORIGEM

O controle poderá ser:

- **Interno:** quando é realizado pela própria Administração, ou no interior de um mesmo Poder. Os responsáveis pelo controle interno ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade devem cientificar a irregularidade ao Tribunal de Contas, sob pena de responder solidariamente pela irregularidade.

¹¹⁶DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo** 33ª ed. São Paulo: GenForense, 2020. Livro eletrônico não paginado.



- **Externo:** é o controle realizado por um órgão que pertence a um Poder distinto do que praticou o ato. Por ser um controle realizado por um Poder em face do outro, típico do sistema de freios e contrapesos. Por exemplo quando o Congresso Nacional susta ato do Poder Executivo que exorbita o poder regulamentar, ou quando um juiz anula um ato administrativo.

Não há hierarquia entre os sistemas de controle externo e interno. Há complementaridade. No controle interno pode fiscalizar a aplicação de verbas públicas federais, repassadas a Estado ou Município por força de convênio ou outro instrumento jurídico, pois trata-se de proteção do patrimônio público sob a guarda do ente controlador, consoante jurisprudência do STF, representada pelo RMS 25.943/DF.

Por fim, cumpre notar que o STF vem entendendo, a teor do MS 33.340/DF, que o Tribunal de Contas ao exercer o controle externo possui competência para aferir se o administrador atuou de forma prudente, moralmente aceitável e de acordo com o que a sociedade dele espera.

3. CONTROLE EXERCIDO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO (RECURSOS ADMINISTRATIVOS)

O controle interno exercido pela própria Administração se dá, via de regra, através dos recursos administrativos.

A Lei 9.784/99 trata do processo administrativo na esfera federal e limita a três o número de instâncias, salvo se houver disposição em sentido contrário.

O art. 58 da mesma lei diz que tem legitimidade para interpor recurso administrativo o titular que for parte no processo, mas também as pessoas cujos direitos ou interesses sejam afetados ao menos de forma indireta com a decisão.

Em se tratando de **direitos coletivos**, organizações e associações também têm legitimidade para recorrer. Sendo **difuso o interesse**, as associações e os próprios cidadãos também são legitimados a recorrer.

O prazo para recorrer, salvo disposição em sentido contrário, será **de 10 dias**.

Em relação aos efeitos do recurso administrativo, **todos terão efeitos devolutivos**, visto que isto é inerente ao recurso. Se houver disposição legal neste sentido também poderá ter efeito suspensivo.

No processo administrativo, o recurso é dirigido à própria autoridade que prolatou a decisão. Esta autoridade poderá exercer juízo de retratação. Caso não exerça, a autoridade competente poderá apreciar o pleito recursal.

Na análise dos recursos, a autoridade competente tem capacidade plena de rever aquela decisão atacada, inclusive ressalte-se que poderá anular ou reformar o ato impugnado, melhorando a situação do recorrente, mas também poderá reformar a decisão impugnada para piorar a situação do recorrente. Trata-se da chamada **reformatio in pejus**, possível no recurso administrativo.

3.1. ESPÉCIES DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

3.1.1. REPRESENTAÇÃO

A representação é uma denúncia perante a própria Administração, e o denunciante poderá ser qualquer pessoa.

3.1.2. RECLAMAÇÃO

A reclamação é um recurso interposto **por quem foi atingido pelo ato administrativo**.

O prazo para interposição da reclamação é de **01 ano**, a contar da data do ato que causou o prejuízo.



3.1.3. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO

O pedido de reconsideração é dirigido a mesma autoridade que praticou o ato. Na verdade, perdeu muito a razão de ser, visto que qualquer recurso será encaminhado à autoridade competente que prolatou a decisão, a qual poderá reconsiderar a decisão.

Se não houver prazo fixado em lei, **o direito ao pedido de reconsideração será de 01 ano, contados da data da decisão.**

O STF, na súmula 430, diz que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo para impetração do mandado de segurança.

3.1.4. RECURSO HIERÁRQUICO PRÓPRIO

Este recurso decorre da hierarquia, devendo ser dirigido à autoridade que prolatou a decisão. Se essa autoridade não reconsidera a sua decisão, encaminhará o recurso à autoridade superior.

Este recurso não depende de previsão legal.

Como regra, este recurso terá o **prazo de 10 dias.**

3.1.5. RECURSO HIERÁRQUICO IMPRÓPRIO

O recurso hierárquico impróprio **só é admissível quando houver previsão legal.**

A lei deverá indicar quem é a autoridade, em quais situações será admitido o recurso e o prazo para que seja admitido o recurso.

3.1.6. REVISÃO

A revisão é um recurso que o servidor pode apresentar sempre que tiver sido punido pela administração, querendo solicitar um novo exame daquela decisão, visto que surgiram novos fatos e novas provas que demonstram a sua inocência ou justificam o abrandamento da sanção.

Essa revisão só se justifica para beneficiá-lo. Poderá ser requerida a qualquer tempo, inclusive quando a administração tomar conhecimento de alguma situação que beneficie o servidor. Ou seja, poderá ser promovida de ofício.

4. CONTROLE LEGISLATIVO

O controle legislativo poderá ser:

- Controle político
- Controle financeiro e orçamentário
- Controle judicial

4.1. CONTROLE POLÍTICO

O controle político é previsto constitucionalmente. Por exemplo o art. 49, III CFRB confere ao Congresso Nacional o poder de autorizar o Presidente da República a se ausentar do país. Outro exemplo é a apreciação do Congresso sobre atos de concessão ou renovação de concessão de emissoras de rádio e de televisão.



Na mesma linha o Senado Federal aprova as indicações para presidente do Banco Central, Diretor de agência reguladora, além de sabatar os candidatos a ministros do STF indicados pelo Presidente da República.

4.2. CONTROLE FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

A fiscalização financeira e orçamentária é típica função do Poder Legislativo.

É o Congresso Nacional que julga as contas prestadas pelo Presidente da República. Neste caso, há um parecer emitido pelo Tribunal de Contas da União, mas executará o julgamento em si é o parlamento. O exercício da função fiscalizatória é executado com auxílio do TCU. Os Tribunais de Contas são órgãos independentes, mas são auxiliares das casas legislativas.

O Tribunal de Contas não é um Poder da República, mas também não é submetido a qualquer Poder, a teor do entendimento do STF, externado na ADI 4.190 MC-REF/RJ. Por isso, entende-se que é um órgão constitucionalmente independente, que tem a função de auxiliar o Poder Legislativo na fiscalização orçamentária e financeira.

As competências do TCU estão previstas no art. 71 da CRFB, lhe incumbindo o controle sobre toda e qualquer movimentação de recursos públicos federais. O mesmo artigo estabelece prerrogativas ao TCU:

- TCU emite parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelo presidente da república, mas quem julgará as contas será o Congresso Nacional.
- As contas dos demais administradores e responsáveis por dinheiro público serão julgadas pelo TCU.
- Aplicação de sanções previstas em lei
- Fixação de prazos para que órgãos ou entidades adotem as providências necessárias para o cumprimento da lei.
- O TCU ainda poderá **sustar ato administrativo** impugnado se não forem atendidas as providências que determinou. Neste caso, susta o ato administrativo e comunica o Poder Legislativo dessa sustação. Se estivermos diante de um contrato administrativo, **a sustação desse contrato administrativo será de competência do Congresso Nacional**, após a notificação do TCU. Todavia, caso o Congresso Nacional **não tome qualquer providência no prazo de 90 dias**, a **competência retorna ao TCU** para sustar o contrato administrativo.

Veda-se que o TCU realize controle sobre entidades administrativas vinculadas a ente federativo diverso, salvo se houver patrimônio público da União envolvido (STF, MS 24.423/DF). Além disso, também está previsto no art. 71, VI CRFB que o TCU poderá fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município.

A súmula 347 STF estabelece que **o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, poderá fazer o controle de constitucionalidade das leis do Poder Público** (controle incidental de constitucionalidade). Porém, em 2018, no julgamento do MS 35.410, o STF considerou que o Tribunal de Contas da União não pode deixar de aplicar leis que entenda inconstitucionais. Porém, isso não significa, segundo a Corte, declarar a inconstitucionalidade da norma. A diferença é sutil: deixar de aplicar uma norma por entendê-la inconstitucional é diferente de declará-la inconstitucional pois não haverá declaração de inconstitucionalidade com efeito erga omnes.

Na mesma linha o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas possui fisionomia institucional própria, que não se confunde com a do Ministério Público comum, sejam os dos Estados, seja o da União. Esse *Parquet* especial possui atuação funcional exclusiva perante as Cortes de Contas, **não detendo legitimidade ad causam para executar as decisões formadas no âmbito administrativo por meio de ação desenvolvida pelos meios ordinários ou pela via reclamatória**. (STF. Rcl 24162 AgR). Assim o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas possui atuação funcional exclusiva perante as Cortes de Contas, limitada



ao controle externo a que se refere o art. 71 da CF/88. Em outras palavras, a atuação do Procurador de Contas é restrita ao âmbito administrativo do Tribunal de Contas ao qual faz parte, não possuindo, em regra, legitimidade ativa para propor demandas judiciais (STF, Rcl 24159 AgR). Não terá legitimidade para impetrar mandado de segurança mesmo que para defender suas prerrogativas institucionais (STF, RE 1.178.617).

4.3. CONTROLE JUDICIAL

O Poder Judiciário pode avaliar a adequação de um ato administrativo. Neste caso, será verificado se o ato está de acordo com o princípio da moralidade, legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, além de outros princípios e normas constitucionais e legais.

O Poder Judiciário faz este controle de legalidade do ato administrativo, mas também o faz como controle de legitimidade.

O Poder Judiciário não poderá se imiscuir nas atribuições do Poder Legislativo e Executivo, sob pena de violação à separação de poderes. Todavia, verificar se o ato praticado está em conformidade com o ordenamento, o Poder Judiciário poderá fazer.

Di Pietro classifica os atos administrativos conforme se são atos políticos, legislativos ou interna corporis:

- **Atos políticos:** os atos praticados por agentes políticos para formação da vontade pública. Ex.: veto do chefe do poder executivo. Na maioria das vezes, serão insuscetíveis de controle por parte do Poder Judiciário, salvo se o ato for praticado com afronta a um princípio ou norma constitucional. **O STJ e o STF vêm exercendo essa interferência na discricionariedade administrativa quando constatarem que houve uma abusividade governamental.**
- **Atos legislativos:** esses atos vão se submeter à via judicial por meio do controle concentrado de constitucionalidade.
- **Atos interna corporis:** estes atos não poderão ser controlados pelo Poder Judiciário, sendo questões internas da Casa Legislativa. Ex.: eleição de mesa, comissão, etc. Se esses atos não desobedecem a comandos constitucionais ou normas legais, o Poder Judiciário não poderá se imiscuir nos atos *interna corporis*.

5. JURISPRUDÊNCIA

5.1. INFORMATIVOS STJ

Informativo n. 647. REsp 1.434.625-CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 09/04/2019, DJe 15/04/2019.

A agência de turismo devidamente credenciada para efetuar operações de câmbio é equiparada a instituição financeira e subordina-se à regular intervenção fiscalizatória do Bacen.

QUESTÕES

1. (MP-RS) MP-RS, 2016. Em relação ao controle e fiscalização da administração municipal, assinale a alternativa correta.

A É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais.



B A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Legislativo Municipal, na forma da lei.

C O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal.

D Na apreciação das contas de gestão do Prefeito Municipal é vedada a imposição de multa ou a determinação de ressarcimento ao erário, o que dependerá de sentença judicial transitada em julgado.

E Ao flagrar falhas relacionadas a ato de admissão de pessoal no âmbito do Município, o Tribunal de Contas exonará imediatamente o servidor indevidamente nomeado.

2. (TJRS) FAURGS, 2016. Acerca do controle externo e interno da Administração Pública, assinale a alternativa correta.

A O controle externo dos Municípios onde não houver Tribunal de Contas ou Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios será exercido pelo respectivo Tribunal de Contas do Estado de cujas decisões cabe recurso à Câmara Municipal.

B As agências reguladoras integram o sistema de controle externo da administração pública direta e indireta como auxiliares do Tribunal de Contas.

C A Constituição Estadual, em função da autonomia dos Estados-membros, fixará o número de Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado.

D O Tribunal de Contas, como auxiliar do controle externo, a cargo do Poder Legislativo e dele integrante, será organizado segundo o modelo constitucional das corporações legislativas respectivas.

E Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno, com a finalidade de, entre outras, apoiar o controle externo no exercício da sua missão institucional.

3. (DPE-RN) CESPE, 2015. Tendo em vista que, relativamente aos mecanismos de controle da administração pública, a própria CF dispõe que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, integradamente, sistemas de controle interno em suas respectivas esferas, assinale a opção que apresenta exemplo de meio de controle interno da administração pública.

A Fiscalização realizada por órgão de controladoria da União sobre a execução de determinado programa de governo no âmbito da administração pública federal.

B Controle do Poder Judiciário sobre os atos do Poder Executivo em ações judiciais.

C Sustação, pelo Congresso Nacional, de atos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar.

D Julgamento das contas dos administradores e dos demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da administração direta e indireta realizado pelos TCs.

E Ação popular proposta por cidadão visando à anulação de determinado ato praticado pelo Poder Executivo municipal, considerado lesivo ao patrimônio público.

COMENTÁRIOS

1. Gabarito – A.

A) Correta. Cf. art. 31, §4º CRFB.

B) Incorreta. Cf. art. 31 CRFB.

C) Incorreta. Cf. art. 31, §2º CRFB.

D) Incorreta. Cf. art. 71, §3º CRFB.

E) Incorreta. Cf. art. 71, III CRFB.

2. Gabarito – E

A) Incorreta. Cf. art. 31, *caput* e §1º, CRFB/88 c/c art. 75 CRFB.

B) Incorreta. Cf. art. 70 CRFB.

C) Incorreta. Cf. art. 75 CRFB.

D) Incorreta. Cf. art. 75 CRFB.

E) Correta. Cf. art. 74 IV CRFB.



3. Gabarito – A.

Todas as alternativas cf. art. 74 da CRFB.



@cpiuris



www.cpiuris.com.br



contato@cpiuris.com.br



61 3033-3739



61 98442-2591

CAPÍTULO 17 — INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE

1. INTRODUÇÃO

Mesmo com a Constituição reconhecendo o direito fundamental à propriedade privada (art. 5º, XXII e XXIII, CRFB/88), o Estado possui o domínio eminente sobre todos os bens existentes no seu território. Trata-se de uma parcela da soberania e do poder de império, logo todos particulares estão sujeitos a restrições sobre seus bens. O Estado possui o poder de regulamentar ou restringir o direito de propriedade privada, ou até mesmo de transferir a propriedade privada para seu patrimônio.

O ordenamento prevê várias formas de intervenções da propriedade, podendo haver intervenção restritiva (onde o particular conserva o domínio, mas se sujeita as imposições do Poder Público) ou intervenção supressiva (onde o Estado transfere para si a propriedade do particular). São modalidades de intervenção do estado na propriedade:

- Limitação administrativa
- Servidão administrativa
- Ocupação temporária
- Requisição administrativa
- Tombamento
- Desapropriação

2. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA

A limitação administrativa é uma modalidade de intervenção do estado na propriedade que gera restrições de caráter geral e abstrato, que **atingirão o caráter absoluto** do direito de propriedade.

São restrições gerais e abstratas, de aplicabilidade uniforme, que atingem um número indeterminado proprietários de uma mesma classe, indistintamente. Se fundamentam no exercício do Poder de Polícia, e podem recair sobre bens móveis, imóveis, serviços e atividades.

Trata-se de uma relação de direito pessoal, traduzida em obrigações positivas (de fazer), negativas (não fazer) ou permissivas (permitir que se faça), que visam condicionar o exercício do direito de propriedade ao cumprimento de sua função social. Podem estar relacionada à segurança, salubridade, estética, defesa nacional, preservação ambiental. Por exemplo medidas técnicas e gabaritos de imóveis, espaçamento entre prédios, medidas de segurança contra incêndio, regras sanitárias, restrições de atividades em razão de seu impacto sobre ecossistemas.

A Constituição da República não faz referência expressa às limitações administrativas. Entretanto, o princípio implícito da supremacia do interesse público, de um lado, e a enunciação da função social da propriedade (art. 5.º, XXIII e art. 170, III, ambos da CRFB/88), de outro, estão a indicar os fundamentos para qualquer tipo de intervenção do Estado na propriedade, inclusive das limitações genéricas.

Em regra, não gera direito à indenização. Caso a limitação administrativa causar um prejuízo específico ao sujeito, poderá gerar indenização, .

Se essa limitação administrativa prejudicar totalmente a utilização da propriedade, haverá, em verdade, uma desapropriação indireta, visto que houve a supressão, motivo pelo qual caberá indenização.

A pretensão reparatória do esvaziamento do conteúdo econômico da propriedade decorrente de limitações administrativas **prescreve em 05 anos**, nos termos do art. 10, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

Os danos eventualmente causados pela limitação administrativa devem ser objeto de ação de direito pessoal, e não de direito real, que seria o caso da desapropriação indireta. A limitação administrativa distingue-se da desapropriação: nesta, há transferência da propriedade individual para o



domínio do expropriante, com integral indenização; naquela, há apenas restrição ao uso da propriedade imposta genericamente a todos os proprietários, sem qualquer indenização.

Dessa forma, **as restrições ao direito de propriedade impostas por normas ambientais, ainda que esvaziem o conteúdo econômico, não constituem desapropriação indireta.**

Segundo o STJ, é indevida indenização em favor de proprietários de imóvel atingido por ato administrativo, **salvo se comprovada limitação mais extensa que as já existentes, na hipótese em que a aquisição do imóvel objeto da demanda tiver ocorrido após a edição dos atos normativos que lhe impuseram as limitações supostamente indenizáveis.**

Ademais, **as limitações administrativas preexistentes à aquisição do imóvel não geram indenização pelo esvaziamento do direito de propriedade**, principalmente quando o gravame narrativo é antecedente à alienação e à ciência do adquirente.

Em regra, por serem genéricas, não gera direito à indenização: são consideradas gratuitas. Caso o particular comprove dano específico, poderá ser indenizado: por exemplo uma limitação que comprovadamente onere, de forma desproporcional, determinado proprietário, ocasionando o esvaziamento do valor econômico do seu bem. O ônus da prova será encargo do administrado. Segundo o STJ os danos eventualmente causados devem ser objeto de ação de direito pessoal cujo prazo prescricional é de 05 anos, e não de direito real, nos termos do art. 10, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Segundo o STJ **as restrições ao direito de propriedade impostas por normas ambientais, ainda que esvaziem o conteúdo econômico, não constituem desapropriação indireta.**

Ainda pelo STJ é indevida indenização em favor de proprietários de imóvel atingido por ato administrativo, **salvo se comprovada limitação mais extensa que as já existentes, na hipótese em que a aquisição do imóvel objeto da demanda tiver ocorrido após a edição dos atos normativos que lhe impuseram as limitações supostamente indenizáveis.** Soma-se que **as limitações administrativas preexistentes à aquisição do imóvel não geram indenização pelo esvaziamento do direito de propriedade**, principalmente quando o gravame narrativo é antecedente à alienação e à ciência do adquirente.

3. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA

Servidão administrativa é um direito real público, o qual autoriza o Poder Público a usar a propriedade imóvel para permitir que haja a execução de obras ou de serviços que sejam de interesse público. Maria Sylvia Zanella di Pietro conceitua servidão administrativa como sendo "o direito real de gozo, de natureza pública, instituído sobre imóvel de propriedade alheia, com base em lei, por entidade pública ou por seus delegados, em face de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública".

Os dois bens devem ser vizinhos, mas não necessariamente contíguos. Há uma relação entre a coisa serviente (a propriedade privada que vai suportar o encargo da servidão) e a coisa dominante (o serviço público concreto ou o determinado bem afetado a uma utilidade pública). Assim o dono do prédio sujeito à servidão (prédio serviente) se obriga a tolerar seu uso, para certo fim, pelo dono do prédio favorecido (prédio dominante). Por exemplo utilizar a propriedade para colocar postes de energia ou postes de sinalização.

Não há uma lei específica sobre a servidão administrativa, entretanto o art. 40 do DL nº 3365/41, que regulamenta a desapropriação, confirma a sua existência. Em **regra, não gera direito à indenização**, havendo um caráter específico e incide sobre coisas determinadas, e **atinge o caráter exclusivo da propriedade**. Poderá gerar indenização quando demonstrada a ocorrência de dano.

A instituição da servidão não exige qualquer situação de urgência ou perigo. Visa somente para potencializar ou viabilizar o desempenho de um serviço público ou a melhor utilização de um bem dominante, afetado ao interesse público

A servidão segue três princípios:

- **Uso moderado:** o exercício da servidão deve se restringir ao estrito atendimento das necessidades para as quais ela foi instituída. A restrição para o particular deve se restringir ao estritamente necessário.
- **Perpetuidade:** a servidão permanece enquanto perdurar o prédio serviente, ou a necessidade pública.
- **Indivisibilidade:** a servidão não pode ser separada do prédio dominante. Permanece a possibilidade da servidão ser extinta pela reunião dos dois prédios no domínio da mesma pessoa, pela perda ou desaparecimento da coisa gravada, ou pela desafetação da coisa dominante

Em **regra a instituição da servidão não gera direito à indenização**. Não há perda da propriedade, trata-se de restrição leve. Porém, poderá gerar indenização quando demonstrada a ocorrência de dano ao particular. O dano deve ser efetivo, e ônus da prova será do requerente, já que a presunção goza de presunção de legitimidade.

A indenização jamais poderá ser superior a do valor da propriedade, uma vez que só há mera restrição da propriedade, e não supressão. Segundo o STJ caso o particular adquira o imóvel já com a servidão já instituída não caberá indenização, pois se pressupõe que essa situação foi levada em consideração na composição do preço.

O prazo prescricional será de 05 anos (art. 10, parágrafo único, DL 3.365/41).

4. OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA

A ocupação temporária é uma restrição branda, de caráter pessoal, que atinge caráter exclusivo (restrito) da propriedade particular, fundada na necessidade de apoio à realização de obras ou exercício de atividades públicas ou de interesse público, em situação de normalidade. Por exemplo a ocupação de um clube para posto de campanha de vacinação, de escolas nas eleições, a instalação de canteiros de obras em terrenos à margem de rodovias que serão asfaltadas.

O art. 36 do DL 3365/41 estabelece que é permitida a ocupação temporária, a qual será indenizada por ação própria. E essa ocupação poderá se dar com terreno não edificado que sejam vizinhos às obras e necessários à sua realização.

Via de regra, ocupação temporária será em bens imóveis. Porém, o art. 80 da Lei de Licitações estabelece que, como consequência da rescisão pelo descumprimento das obrigações perante a Administração Pública, poderá gerar a ocupação e utilização do local, das instalações e dos equipamentos do particular, para que prevaleça o princípio da continuidade do serviço público. Neste caso, segundo a lei de licitações, será possível inclusive a ocupação de bens móveis.

Geralmente a ocupação temporária não gera direito à indenização, salvo se o particular comprovar sua duração e/ou danos anormais. O prazo prescricional será de 05 anos (art. 10, parágrafo único, DL 3.365/41).

5. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA

Requisição administrativa é um ato administrativo unilateral, o qual é autoexecutório, consistindo na utilização de bens e serviços particulares pela administração, por conta de perigo público iminente ou guerra, sendo posteriormente cabível indenização, se houver dano. A requisição administrativa tem fundamento constitucional, sendo expressamente prevista no artigo 5º, XXV da Constituição. Possui **natureza jurídica de direito pessoal** da Administração Pública e poderá incidir sobre bens móveis, imóveis e serviços. Na mesma linha os arts. 136 §1º II e 139 VI, VII se referem ao uso da requisição durante o estado de defesa e de sítio. Há menção do instituto, ainda, no art. 1.228 §3º CC.

Apenas a União possui competência para legislar sobre requisições administrativas (art. 22, III CRFB). Porém, qualquer ente federativo poderá se valer do instituto.



Para a doutrina é possível a requisição de bens fungíveis (tais como alimentos, combustível, remédios) que na prática será semelhante à desapropriação. Porém, esta prevê três requisitos:

- Indenização posterior e condicionada à existência de dano;
 - A posse do bem é autoexecutória, logo não depende de decisão judicial
 - Fundamento na necessidade pública inadiável e urgente
- A possibilidade de indenização seguirá a mesma lógica da ocupação temporária.

Segundo o STF a requisição de bens públicos de outros entes federativos só poderá ser utilizada em caráter excepcional, e somente poderia ser efetivada após a observância do procedimento constitucional de declaração formal do Estado de Defesa ou do Estado de Sítio.

A COVID19 retomou os debates sobre a requisição administrativa. Ela já era prevista na Lei do SUS (art. 15, XIII Lei 8.080/1990), porém foi ressaltada pelo art. 3º VII da Lei nº 13.979/2020.

Duas ações que versam sobre requisições administrativas e COVID19 já chegaram ao STF. A ADPF 671 debate a adoção da fila única: solicitava-se a regulação pelo poder público da utilização dos leitos de unidades de tratamento intensivo (UTIs) na rede privada durante a pandemia do novo coronavírus. O argumentava-se que o Sistema Único de Saúde (SUS) deveria assumir integralmente a gestão de hospitais e profissionais de saúde públicos e privados, a fim de garantir o acesso igualitário aos serviços por meio de uma fila única de acesso

O relator afirmou que as autoridades competentes podem utilizar as requisições administrativas de bens e serviços particulares relacionados à saúde, especificamente no caso de iminente perigo público. Ressaltou que qualquer ente da federação tem competência para adotar a medida, tendo como finalidade o cuidado com a saúde e a assistência pública, conforme estabelece a Constituição Federal (artigo 23, inciso II), a Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/1990, artigo 15, inciso XIII) e o Código Civil (artigo 1.228, parágrafo 3º) e a Lei 13.979/2020, que incluiu mais uma previsão de requisição administrativa voltada diretamente para o enfrentamento da Covid-19. Essa última prevê que qualquer ente federado pode requisitar bens e serviços “de pessoas naturais e jurídicas”, com garantia do pagamento posterior de indenização justa. Para isso, a autoridade competente avaliará a existência de perigo público iminente, após considerar as diferentes situações de emergência de acordo com a realidade e o caso concreto. Nessa toada, segundo o Relator, caso o Poder Judiciário apreciasse a questão, iria desrespeitar as leis criadas e a separação de Poderes: como já existem diversas normas que viabilizam a requisição administrativa de bens e serviços, e a atuação do Judiciário nesse sentido desrespeita o princípio da separação dos Poderes. Negado o seguimento da ação, foi interposto agravo regimental ainda pendente de julgamento até a data de fechamento deste livro.

Já na ACO 3385 a decisão se deu na concessão de pedido de tutela de urgência. O Estado do Maranhão relata que, diante da existência de mais de mil casos suspeitos da Covid-19 e duas mortes, adquiriu os ventiladores a fim de equipar adequadamente o Hospital de Cuidados Intensivos, com 132 leitos de UTI exclusivos para casos de coronavírus. No entanto, foi informado que a União havia requisitado, em caráter compulsório, todos os ventiladores da Intermed adquiridos pelo estado e toda a produção da empresa nos próximos 180 dias.

Ao pedir a suspensão da medida, o Maranhão argumentou que a autonomia dos entes federativos impede que um deles (no caso, a União) assuma, mediante simples requisição administrativa, o patrimônio, o quadro de pessoal e os serviços de outro ente público. Segundo o ministro relator Celso de Mello, a requisição de bens e/ou serviços, nos termos previstos pela Constituição da República (artigo 5º, inciso XXV), somente pode incidir sobre a propriedade particular. Bens estaduais e municipais só podem ser utilizados pela União nos casos de decretação do estado de defesa e do estado de sítio, o que não ocorre no momento. Assim a suspensão da requisição é necessária para evitar, até o julgamento do mérito da ação, maiores danos aos destinatários dos aparelhos, “cuja utilização pode significar a diferença entre a vida e a morte”. Para o relator a Lei 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da pandemia da Covid-19, não legitima o uso pela União de seu poder requisitório de bens pertencentes aos entes federativos, pois essa medida já foi negada pelo STF, em caso semelhante, no julgamento do Mandado de Segurança (MS) 25295.

6. TOMBAMENTO

O Instituto do tombamento tem como fundamento legal o Decreto Lei 25/37 e o artigo 216 § 1º da Constituição Federal. Tombamento é um procedimento administrativo através do qual o Poder Público vai reconhecer o valor histórico, paisagístico, cultural, científico de uma coisa ou local, situação na qual passarão a ser preservados. Trata-se de restrição estatal na propriedade privada, que se destina especificamente à proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, assim considerado, o conjunto de bens móveis, imóveis, materiais e imateriais existentes no país cuja conservação se justifique de interesse público.

O tombamento é uma modalidade restritiva da propriedade, que objetiva proteger o patrimônio cultural brasileiro. Poderão ser objeto do tombamento bens de qualquer natureza, seja móvel ou imóvel, seja de natureza material ou de natureza imaterial, seja bem público ou bem privado. Se o Poder Público estiver diante dessa situação, deverá ele tombá-lo. Portanto, o ato de tombamento tem a natureza jurídica de ato vinculado.

As coisas tombadas, que pertençam à União, aos Estados ou aos Municípios, inalienáveis por natureza, só poderão ser transferidas de uma à outra das referidas entidades.

O art. 3º do DL 25/37 esclarece quais bens não poderão ser tombados. Assim excluem-se do tombamento, por não serem considerados patrimônio histórico e artístico nacional as obras de origem estrangeira:

- que pertençam às representações diplomáticas ou consulares acreditadas no país;
- que adornem quaisquer veículos pertencentes a empresas estrangeiras, que façam carreira no país;
- que se incluam entre os bens referidos no art. 10 da Introdução do Código Civil, e que continuem sujeitas à lei pessoal do proprietário;
- que pertençam a casas de comércio de objetos históricos ou artísticos;
- que sejam trazidas para exposições comemorativas, educativas ou comerciais
- que sejam importadas por empresas estrangeiras expressamente para adorno dos respectivos estabelecimentos.

Os bens de origem estrangeira podem, em tese, ser objeto de tombamento, à exceção das situações mencionadas pelo art. 3º, DL 25.

6.1. ESPÉCIES DE TOMBAMENTO

Quanto à sua constituição:

- **Tombamento de ofício:** se dá em bens públicos, como é o tombamento dos bens da União, Estados, DF e municípios. Neste caso, somente haverá a notificação da entidade proprietária do bem. Art. 25 DL nº 25/37.
- **Tombamento voluntário:** ocorrerá diante de um bem privado, em que o próprio proprietário do bem irá requerer o tombamento. Ou ainda há um procedimento da administração pelo tombamento sem oposição do particular. Art. 7º DL nº 25/37.
- **Tombamento compulsório:** ocorrerá quando o particular não concorda com o ato de tombamento do Poder Público. Poderá se dar mediante um processo, após a recusa do proprietário. Art. 8º DL nº 25/37.

Quanto à eficácia:

- **Tombamento provisório:** é o tombamento que começa após a notificação do proprietário. Art. 6º DL nº 25/37.
- **Tombamento definitivo:** ocorre o tombamento após a inscrição do bem no livro de tombamento. Art. 10 DL nº 25/37.

Quanto aos destinatários:



- **Tombamento geral:** o tombamento é geral quando incide sobre os bens de uma determinada localidade. Segundo o STJ o ato de tombamento geral não precisa individualizar os bens abarcados pelo tombamento, pois as restrições impostas pelo Decreto-Lei n. 25/1937 se estendem à totalidade dos imóveis pertencentes à área tombada.
- **Tombamento individual:** o tombamento incide especificamente sobre um bem, havendo a notificação do proprietário.

6.2. EFEITOS DO TOMBAMENTO

Os efeitos do tombamento é:

- Proibição de destruição, demolição ou mutilação do bem
- Exige-se uma autorização para restauração e pintura
- Imposição de servidão administrativa para os imóveis vizinhos
- Cabível a vigilância pública do bem de tempos em tempos
- Se o bem for vendido, há um direito de preferência
- Há possibilidade da tutela pública para conservação e para reparação do bem, caso se esteja diante de um proprietário hipossuficiente.
- Poderá gerar direito à indenização se causar algum dano ao seu proprietário

6.3. COMPETÊNCIA PARA O TOMBAMENTO

A competência legislativa relacionada ao tombamento é concorrente (art. 24 VII CRFB). Na mesma linha, a competência administrativa para a proteção da cultura é comum entre todos os entes federados (art. 23, III e IV CRFB). Logo, é possível que um mesmo bem possa ser tombado em mais de uma ordem jurídica, o chamado tombamento cumulativo (STJ, RMS 18.952/RJ).

6.4. TOMBAMENTO DE BENS PÚBLICOS

Sendo a competência para o tombamento comum a todos os entes federativos, surge a questão do tombamento de bens públicos. **É pacífico na doutrina e na jurisprudência que bens públicos podem ser tombados.**

A divergência doutrinária surge sobre a hipótese de um ente federativo tombar um bem que pertença a um outro ente, por exemplo o estado tombar um bem do município. José dos Santos Carvalho Filho, corrente minoritária, entende que não seria possível o tombamento de bens de entes “maiores” pelos “menores”. O autor segue a lógica da desapropriação (art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 3.365/41). Assim, para ele, a União poderá tombar bens dos estados e municípios; os estados poderiam realizar o tombamento de bens municipais, e por fim os municípios só poderiam tombar seus próprios bens.

Já a corrente majoritária, inclusive defendida pelo STJ e STF, sustenta a possibilidade do tombamento entre entes federados indistintamente, seja de “baixo para cima” ou de “cima para baixo”, já que o pacto federativo não prevê hierarquia entre os entes da federação, e sim autonomia (STF ACO 1208, STJ, RMS 18.952/RJ).

7. DESAPROPRIAÇÃO

A desapropriação é uma forma supressiva de restrição da propriedade.

Através da desapropriação, o Poder Público adquire a propriedade de forma originária, sem qualquer relação com a propriedade anterior.

Hely Lopes Meirelles diz que a desapropriação é a transferência compulsória da propriedade particular ou da propriedade pública, quando se estiver diante de uma entidade superior sobre a inferior.

Essa transferência compulsória poderá se dar por:



- Utilidade pública
- Necessidade pública
- Interesse social

Neste caso, haverá prévia e justa indenização em dinheiro, salvo algumas exceções constitucionais. Porém, há exceções para a regra da indenização: na **desapropriação sanção**, a indenização não será prévia e em dinheiro. São os casos de desapropriação sanção por descumprimento da função social da propriedade urbana ou então por interesse social para fins de reforma agrária.

Há ainda a **expropriação**, a **desapropriação confisco**, sem pagamento de qualquer indenização, nos casos em que há plantações ilícitas de psicotrópicos ou quando haja exploração de trabalho escravo.

7.1. BASE LEGAL

Há diversos dispositivos na Constituição Federal de 1988 que tratam do tema desapropriação:

- artigo 5º, inciso XXIV: define os três fundamentos ensejadores da desapropriação : necessidade pública, utilidade pública e interesse social. Somado a isso, determina que, como regra geral, a indenização deve ser prévia, justa e em dinheiro;
- artigo 22, inciso II: fixa a competência privativa da União para legislar sobre o assunto;
- artigo 182, parágrafo 4º, inciso III: permite ao Município que promova desapropriação sancionatória urbanística do imóvel não edificado, subutilizado ou não utilizado, com pagamento mediante títulos da dívida pública com prazo de resgate em até dez anos;
- artigo 184: defini a competência exclusiva da União para desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, resgatáveis no prazo de até vinte anos;
- artigo 184, parágrafo 5º: embora o dispositivo fale em “isenção”, na verdade a referida norma delimita a imunidade tributária de impostos federais, estaduais e municipais sobre operações de transferência de imóvel desapropriado para fins de reforma agrária;
- artigo 185: impede que a desapropriação para reforma agrária recaia sobre a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra e em caso de propriedade produtiva;
- artigo 243: prevê o confisco de glebas utilizadas para o plantio ilegal de plantas psicotópicas empregadas na produção de drogas, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções.

Já no plano infraconstitucional encontramos:

- Decreto-Lei nº 3.365/41: disciplina as desapropriações por necessidade e utilidade pública, sendo considerada a lei básica sobre o tema;
- Lei n. 4.132/62: disciplina desapropriações por interesse social;
- Decreto-Lei nº 1.075/70: dispõe sobre imissão na posse *initio litis* em imóveis desapropriados urbanos;
- Lei Complementar nº 76/93 combinada com a Lei nº 8.629/93: disciplina desapropriações de imóveis rurais para fins de reforma agrária;
- Lei Complementar nº 101/00: artigo 46 – torna nula de pleno direito o ato de desapropriação de imóvel urbano expedido sem atender o disposto no artigo 182, parágrafo 3º, da Constituição Federal ou sem prévio depósito judicial do valor da indenização;
- Lei nº 8.257/91: expropriação de terras usadas para cultivos ilegais, sem indenização;
- Lei nº 3.833/60: disciplina a desapropriação por utilidade pública para execução de obras no Polígono da Seca, adotando regime especial para fins do pagamento da indenização;



- Lei nº 10.257/01 (Estatuto da Cidade): regulamenta a desapropriação urbanística, de competência do Município, como importante instrumento de política urbana;
- Lei nº 10.406/02 (Código Civil): este diploma possui diversos dispositivos tratando do tema desapropriação, entre eles: i) artigo 519 (defini um caso de tresdestinação lícita, ao permitir que o bem expropriado receba destinação diversa daquela inicialmente prevista no decreto expropriatório); ii) artigo 1.228, parágrafo 3º (refere-se à desapropriação como forma de privação da propriedade); iii) artigo 1.257 (inclui a desapropriação entre os institutos de perda da propriedade).

7.2. COMPETÊNCIA

Duas são as modalidades de competência:

- **Competência para elaboração de leis:** é competência legislativa privativa da União (art. 22, I CRFB).
- **Competência material:** trata-se da competência para desapropriar. Em regra todos os entes federativos poderão se valer da desapropriação comum. Já as modalidades de desapropriação sanção só poderão ser executadas por entes específicos, como se verá abaixo.

Além dos **entes políticos**, poderão desapropriar também:

- os concessionários de serviços públicos
- os estabelecimentos de caráter público
- os que exercem funções delegadas ou outorgadas pelo Poder Público, desde que haja autorização expressa em lei ou ao menos uma autorização expressa em contrato.

A competência para desapropriar **não se confunde com a competência para declarar a desapropriação. A declaração para desapropriação deve ser feita pelo ente político**, através de um decreto do chefe do Poder Executivo, ou ao menos através de lei.

É possível que a lei atribua a competência para declarar a desapropriação a outra entidade. Ex.: no caso da ANEEL, é ela mesma quem poderá declarar a desapropriação.

Inclusive a Súmula 23 do STF diz que, verificados os pressupostos legais para o licenciamento da obra, não o impede a declaração de utilidade pública para desapropriação do imóvel, **mas o valor da obra não se incluirá na indenização**, quando a desapropriação for efetivada.

7.3. MODALIDADES DE DESAPROPRIAÇÃO

Existem algumas modalidades de desapropriação, podendo ser comuns e sanção:

- **Desapropriação comum:**
 - **Desapropriação por necessidade:** todos os entes federativos têm competência, sendo que a indenização é prévia e em dinheiro.
 - **Desapropriação por utilidade pública:** todos os entes federativos têm competência, sendo que a indenização é prévia e em dinheiro.
 - **Desapropriação por interesse social:** neste caso, todos os entes também têm competência, sendo a indenização prévia e em dinheiro.
- **Desapropriação sanção:**
 - **Desapropriação para fins de reforma agrária:** competência da União, caso em que será paga a indenização pelos títulos da dívida agrária.
 - **Desapropriação para fins de reforma urbana:** competência é do Município, sendo paga a indenização pelos títulos da dívida pública.
 - **Desapropriação confisco:** competência é da União, não havendo qualquer espécie de indenização.



Os bens desapropriados poderão ser posteriormente vendidos ou locados, desde que seja a alguém que estiver em condições de dar a eles a destinação social que justificou a desapropriação, ou poderão ser afetados para uso da Administração Pública.

Conforme o STJ, na ação de **desapropriação por utilidade pública, a citação do proprietário do imóvel desapropriado dispensa a do respectivo cônjuge**. Isso porque o art. 16 do Decreto-Lei 3.365/1941 (Lei das Desapropriações) dispõe que a *“citação far-se-á por mandado na pessoa do proprietário dos bens; a do marido dispensa a da mulher”* (REsp 1.404.085-CE).

Se em procedimento de **desapropriação por interesse social** constatar-se que a área medida do bem é maior do que a escriturada no Registro de Imóveis, **o expropriado receberá indenização correspondente à área registrada, ficando a diferença depositada em Juízo até que, posteriormente, se complemente o registro ou se defina a titularidade para o pagamento a quem de direito**. A indenização devida deverá considerar a área efetivamente desapropriada, ainda que o tamanho real seja maior do que o constante da escritura, a fim de não se configurar enriquecimento sem causa em favor do ente expropriante.

Ainda, de acordo com o STJ, não se encontrando averbada no registro imobiliário antes da vistoria, a reserva florestal não poderá ser excluída da área total do imóvel desapropriando para efeito de cálculo da produtividade do imóvel rural, em desapropriação para reforma agrária (AgRg no REsp 1301751/MT).

Segundo o art. 2º, §3º, Decreto-Lei 3.365/41, é vedada a desapropriação, pelos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios **de ações, cotas e direitos representativos do capital de instituições e empresas cujo funcionamento dependa de autorização do Governo Federal e se subordine à sua fiscalização**, salvo mediante prévia autorização, por decreto do Presidente da República.

7.3.1. DESAPROPRIAÇÃO SANÇÃO PARA REFORMA URBANA

A desapropriação sanção para reforma urbana é competência material unicamente do Poder Público municipal. A propriedade urbana, segundo o art. 182 CRFB, cumpre a sua função social obedece ao que está determinado no Plano Diretor.

Caso ela descumpra, deverá haver uma exigência em lei específica para que aquela área incluída no Plano Diretor venha a ser adequada ao aproveitamento do solo urbano. Se a despeito da lei específica não for atendida essa reivindicação legal, neste caso é possível que sucessivamente haja:

- **Parcelamento ou edificação compulsórios.**
- Haja a incidência do **IPTU progressivamente no tempo**, desde que não seja o aumento superior ao dobro do ano anterior, ficando limitado a 15% do valor do bem.
- **Desapropriação sanção**, em último caso.

Ou seja, haverá uma lei determinando que o proprietário promova o adequado uso da sua propriedade. Caso não o faça, haverá o parcelamento ou edificação compulsório. Não o fazendo, haverá IPTU progressivo. Por último, a desapropriação sanção.

A desapropriação sanção urbana vai implicar o pagamento por meio dos títulos da dívida pública, os quais deverão ter sua emissão previamente **autorizada pelo Senado Federal**, com prazo de resgate desses títulos é de **até 10 anos com parcelas anuais iguais e sucessivas**.

7.3.2. DESAPROPRIAÇÃO SANÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA

Esse caso também pressupõe o descumprimento da função social da propriedade rural (art. 186 CRFB), ou seja, é uma desapropriação sanção.

A indenização será em títulos da dívida agrária, no **prazo de 20 anos**, a partir do segundo ano de emissão dos mesmos. Vale ressaltar que **benfeitorias úteis e necessárias são pagas em dinheiro**.

A competência para essa desapropriação sanção para fins de reforma agrária é exclusiva da **União**.

São **insuscetíveis de desapropriação sanção para fins de reforma agrária**:



- A pequena e média propriedade rural, desde que seu proprietário não seja proprietário de outra propriedade
- A propriedades produtivas

Caso o particular seja beneficiado com a distribuição do imóvel rural por conta da reforma agrária receberá um título de domínio do imóvel ou uma concessão de uso do bem imóvel. Esse título é **inegociável pelo prazo de 10 anos**.

Segundo o STJ, nas desapropriações para fins de reforma agrária, **o valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação efetivada em juízo**, tendo como base o laudo adotado pelo juiz para a fixação do justo preço, pouco importando a data da imissão na posse ou mesmo a da avaliação administrativa (REsp 1.679.042).

7.3.3. DESAPROPRIAÇÃO CONFISCO

A desapropriação confisco, ou expropriação, está prevista no art. 243 CRFB.

As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem **localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas** ou **a exploração de trabalho escravo** serão **expropriadas e serão destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular**, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

Segundo o parágrafo único, todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo **será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica**, na forma da lei.

A competência da desapropriação sanção é da **União**.

Para o Supremo Tribunal Federal, a expropriação irá recair sobre a totalidade do imóvel, ainda que o cultivo ilegal ou a utilização de trabalho escravo tenham ocorrido em apenas parte dele (RE 543.974).

Recentemente, o STF entendeu que **o proprietário poderá evitar a expropriação se provar que não teve culpa pelo fato de estarem cultivando plantas psicotrópicas em seu imóvel**. A expropriação prevista no art. 243 da Constituição Federal pode ser afastada, **desde que o proprietário comprove que não incorreu em culpa, ainda que in vigilando ou in elegendo**.

Para a sanção, **não se exige a participação direta do proprietário no cultivo ilícito**, apesar de se exigir algum grau de culpa para sua caracterização, ou seja, mesmo que o proprietário não tenha participado diretamente, mas se agiu com culpa, deverá ser expropriado.

Mesmo assim, é possível que o proprietário afaste sua responsabilidade demonstrando que não incorreu em culpa. Ele pode provar, por exemplo, que foi esbulhado ou até enganado pelo possuidor ou pelo detentor. **A responsabilidade do proprietário é subjetiva, no entanto bastante próxima da objetiva**.

E se houver mais de um proprietário, o que fazer neste caso? **Se o imóvel pertencer a 2 ou mais proprietários (condomínio), haverá a expropriação mesmo que apenas um deles tenha participação ou culpa**. Restará apenas ao proprietário inocente buscar reparação daquele que participou ou teve culpa.

Importante destacar que **cabe ao proprietário (e não à União) o ônus da prova**. Em outras palavras, caberá ao proprietário provar que não agiu com culpa (RE 635.336/PE, Inf. 851).

7.4. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA E DESAPROPRIAÇÃO POR ZONA

7.4.1. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA

A desapropriação indireta é chamada também de **apossamento administrativo**.

É uma desapropriação que ocorre sem a obediência às exigências legais e o devido processo legal, ou seja, é um ato ilícito da Administração. Também se fará presente quando o Poder Público, a pretexto de realizar um tombamento, acaba suprimindo o exercício do direito de propriedade, praticando uma



intervenção supressiva. Para ser caracterizado exige-se a afetação do bem: destinação desse para finalidade pública e irreversibilidade da situação.

A desapropriação indireta é a nomenclatura utilizada para o erro do Poder Público. É possível lançar mão de um instrumento processual para forçar o Poder Público a indenizar o ato ilícito representado pelo apossamento da propriedade particular, sem o devido processo legal. Isso será feito através de uma **ação de reintegração de posse**.

O entendimento que prevalece é no sentido de que, **se já houver ocorrido uma incorporação do bem, destinando uma atividade de interesse público, a tutela judicial irá se restringir a indenizar o proprietário pela perda da propriedade**, em razão da supremacia do interesse público. Ou seja, a ação não será a ação de reintegração de posse e sim **ação de desapropriação indireta**. Neste caso, o sujeito vai receber o valor do bem. Serão cabíveis juros compensatórios desde a data da efetiva ocupação naquele imóvel.

A pretensão indenizatória decorrente de desapropriação indireta prescrevia em 20 anos na vigência do CC/1916 e **em 10 anos na vigência do CC/2002**(art. 1.238, parágrafo único, do CC/2002), respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/2002, conforme entendimento do STJ. Há uma exceção: o **prazo será de 15 anos se ficar comprovada a inexistência de obras ou serviços públicos no local**. Em regra, portanto, o prazo prescricional das ações indenizatórias por desapropriação indireta é de 10 anos porque existe uma presunção relativa de que o Poder Público realizou obras ou serviços públicos no local. Admite-se, excepcionalmente, o prazo prescricional de 15 anos, caso a parte interessada comprove, concreta e devidamente, que não foram feitas obras ou serviços no local, afastando a presunção legal (EREsp 1575846-SC, Info 658).

Na desapropriação indireta, quando há valorização geral e ordinária da área remanescente ao bem esbulhado em decorrência de obra ou serviço público, não é possível o abatimento no valor da indenização devida ao antigo proprietário. **Cabe ao Poder Público, em tese, a utilização da contribuição de melhoria como instrumento legal capaz de fazer face ao custo da obra**, devida proporcionalmente pelos proprietários de imóveis beneficiados com a valorização do bem.

Conforme o entendimento do STJ, **não há desapropriação indireta sem que haja o efetivo apossamento da propriedade pelo Poder Público**. Desse modo, as restrições ao direito de propriedade impostas por normas ambientais, ainda que esvaziem o conteúdo econômico, não constituem desapropriação indireta.

Isso porque a limitação administrativa distingue-se da desapropriação, uma vez que nesta há transferência da propriedade individual para o domínio do expropriante, com integral indenização, e naquela há, apenas, restrição ao uso da propriedade imposta genericamente a todos os proprietários, sem qualquer indenização. Ademais, a edição de leis ambientais que restringem o uso da propriedade caracteriza uma limitação administrativa, cujos prejuízos causados devem ser indenizados por meio de uma ação de direito pessoal, e não de direito real, como é o caso da ação contra a desapropriação indireta.

7.4.2. DESAPROPRIAÇÃO POR ZONA

A desapropriação por zona é a chamada desapropriação extensiva, a qual abrange a zona contígua, necessária ao desenvolvimento daquela obra, bem como se destina às zonas próximas à obra que tenham se valorizado de forma extraordinária em decorrência da realização do serviço.

7.5. PROCEDIMENTO DA DESAPROPRIAÇÃO

A desapropriação será realizada em duas fases:

- Fase declaratória
- Fase executória



7.5.1. FASE DECLARATÓRIA

Na fase declaratória há a indicação do bem a ser desapropriado e a justificativa da respectiva modalidade de desapropriação. A competência para declaração da desapropriação é do ente público.

A doutrina entende ser possível que a lei atribua a uma outra entidade da administração a competência para declarar a desapropriação. Ex.: ANEEL.

A declaração irá gerar alguns efeitos:

- Submete o bem à força desapropriatória
- Vai fixar o estado do bem, de forma que será pago com base nisso
- Permite que o Poder Público adentre ao imóvel para medir e ter noção exata do imóvel
- Fixa o termo inicial para o prazo de caducidade dessa declaração

A caducidade da declaração ocorrerá quando houver a perda da validade da declaração da desapropriação. Isto se dá quando o Poder Público, dentro de certo lapso temporal, não promoveu atos concretos destinados a efetivar a desapropriação.

São prazos para a caducidade:

- **Desapropriação comum de utilidade pública ou necessidade pública:** o prazo de caducidade é de **5 anos**.
- **Desapropriação comum de interesse social:** o prazo de caducidade é de **2 anos**.
- **Desapropriação sanção para fins de reforma agrária:** o prazo de caducidade é de **2 anos**.
- **Desapropriação sanção para fins de reforma urbana:** o prazo de caducidade é de **5 anos**.

7.5.2. FASE EXECUTÓRIA

Passada a fase declaratória, começa-se a fase executória.

A fase executória envolve a estimativa da indenização cabível, e que será paga, em regra, previamente à desapropriação.

A fase executiva implicará a **consolidação da transferência do bem** ao Poder Público.

A competência para execução da fase executória poderá ser delegada para entidades da administração indireta ou para concessionários ou permissionários do serviço público.

A fase executória poderá ser resolvida administrativamente, desde que exista acordo entre as partes.

Caso não acordem, essa questão será judicializada, por meio do processo.

No processo judicial, quando for contestar, o desapropriando somente poderá alegar na contestação **vício processual** ou **impugnação do preço da avaliação**. Qualquer outra alegação deverá fazer noutra ação.

O Ministério Público **só se mostra indispensável se a desapropriação for para fins de reforma agrária**. Caso contrário, não há essa necessidade de intervenção do Ministério Público.

- Imissão provisória na posse

Se houver urgência e tiver sido depositada a quantia da avaliação, o juiz irá ordenar a imissão provisória na posse do bem em favor do desapropriante.

Perceba que a imissão provisória se dá antes da transferência da propriedade, estando condicionada a dois fatores:

- **Declaração de urgência**
- **Depósito do valor da avaliação**

O sujeito nem precisa ser citado para essa imissão ainda, podendo ocorrer a imissão provisória, desde que seja declarada a urgência e depositado o valor da avaliação, situação na qual o juiz determina a imissão provisória na posse.



No caso de imissão provisória na posse, se houver divergência entre o preço que foi ofertado em juízo e o preço que foi fixado na sentença, **haverá a incidência de juros compensatórios de 12% ao ano, a contar da imissão na posse.**

Os **juros compensatórios** têm por objetivo compensar a perda da renda que foi comprovadamente sofrida pelo proprietário. Parcela da doutrina fala que não incidem juros compensatórios nas desapropriações que tiveram como fundo o descumprimento da função social da propriedade, apesar de já ter havido decisão do STJ em sentido contrário.

Os **juros moratórios** têm outra destinação, pois se destina a recompor a mora, ou seja, o atraso no pagamento da indenização. Esses juros moratórios serão devidos a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido realizado, sendo devido no montante de 6% ao ano, ou 0,5% ao mês.

Atente-se que poderão ser cumulados juros compensatórios com juros moratórios.

- Direitos do desapropriado

O desapropriado tem direito a uma justa indenização, mas além dele, poderá haver outros direitos, tais como:

- **Direito de retrocessão:**

É o direito do proprietário de exigir o bem de volta, se não for dado ao bem a destinação que justificou a desapropriação. Este direito está intimamente ligado à ideia de **tredestinação**, que é o desvio da finalidade do ato desapropriatório.

O direito de retrocessão só será cabível se a nova destinação não for pública, ou seja, se houver uma tredestinação ilícita.

Dentro desse direito estaria acobertada também a situação da **a destinação**, quando não se utiliza o bem desapropriado para qualquer finalidade.

Comprovada a inviabilidade ou a perda do interesse público, prevista no decreto expropriatório, o expropriante poderá adotar uma das seguintes modalidades, na seguinte ordem de preferência:

a) destinar a área para outra finalidade pública

b) alienar o bem a qualquer interessado, na forma da lei, assegurado a pessoa física ou jurídica desapropriada o direito de preferência

- **Direito de extensão:**

É o direito do expropriado de exigir que a desapropriação seja complementada, alcançando parte do bem que não foi incluído no ato declaratório da desapropriação. Mas a parte não incluída tornou inútil a área desapropriada remanescente.

É possível que o expropriante desista da ação de desapropriação?

Recentemente, **o STJ entendeu que é possível a desistência da desapropriação a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado.** No entanto, é indispensável que seja previsto os seguintes requisitos:

- **Ainda não tenha havido o pagamento integral do preço:** nesta hipótese já terá se consolidado a transferência da propriedade do expropriado para o expropriante; e
- **O imóvel possa ser devolvido sem que ele tenha sido alterado de forma substancial:** isto impede a utilização do imóvel como era feita anteriormente. Ex.: casa foi demolida pelo Poder Público.

Desse modo, em regra, é possível o direito de desistência da desapropriação. **A desistência poderá ser obstada (negada) se ficar provada uma das duas circunstâncias acima previstas.**

Cabe ressaltar que, **em havendo o pedido de desistência da ação pelo expropriante, esta deverá ser homologada.** A desistência somente **não será homologada, caso o expropriado consiga provar que existe circunstância que impeça a desistência.** Se o expropriado não demonstrar isso, o juiz deverá extinguir a ação pela desistência. Em outras palavras, **o STJ entende que é ônus do expropriado provar a existência de fato impeditivo do direito de desistência da desapropriação**(Inf. 596).



8. TESES DO STJ

8.1. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE

- 1) O ato de tombamento geral não precisa individualizar os bens abarcados pelo tombamento, pois as restrições impostas pelo Decreto-Lei n. 25/1937 se estendem à totalidade dos imóveis pertencentes à área tombada.
- 2) Inexistindo ofensa à harmonia estética de conjunto arquitetônico tombado, não há falar em demolição de construção acrescida.
- 3) O tombamento do Plano Piloto de Brasília abrange o seu singular conceito urbanístico e paisagístico, que expressa e forma a própria identidade da capital federal.
- 4) A indenização pela limitação administrativa ao direito de edificar, advinda da criação de área *non aedificandi*, somente é devida se imposta sobre imóvel urbano e desde que fique demonstrado o prejuízo causado ao proprietário da área.
- 5) É indevido o direito à indenização se o imóvel expropriado foi adquirido após a imposição de limitação administrativa, porque se supõe que as restrições de uso e gozo da propriedade já foram consideradas na fixação do preço do imóvel.
- 6) As restrições relativas à exploração da mata atlântica estabelecidas pelo Decreto n. 750/1993 constituem mera limitação administrativa, e não desapropriação indireta, sujeitando-se, portanto, à prescrição quinquenal.
- 7) A indenização referente à cobertura vegetal deve ser calculada em separado do valor da terra nua quando comprovada a exploração dos recursos vegetais de forma lícita e anterior ao processo interventivo na propriedade.
- 8) Nas hipóteses em que ficar demonstrado que a servidão de passagem abrange área superior àquela prevista na escritura pública, impõe-se o dever de indenizar, sob pena de violação do princípio do justo preço.
- 9) Os juros compensatórios incidem pela simples perda antecipada da posse, no caso de desapropriação, e pela limitação da propriedade, no caso de servidão administrativa nos termos da Súmula n. 56/STJ.
- 10) Não incide imposto de renda sobre os valores indenizatórios recebidos pelo particular em razão de servidão administrativa instituída pelo Poder Público.
- 11) Admite-se a possibilidade de construções que não afetem a prestação do serviço público na faixa de servidão (art. 3º do Decreto n. 35.851/1954).

8.2. DESAPROPRIAÇÃO

- 1) A indenização referente à cobertura vegetal deve ser calculada em separado do valor da terra nua quando comprovada a exploração dos recursos vegetais de forma lícita e anterior ao processo expropriatório.
- 2) As regras dispostas nos arts. 19 e 33 do CPC, quanto à responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, se aplicam às demandas indenizatórias por desapropriação indireta, eis que regidas pelo procedimento comum.
- 3) Nas ações de desapropriação incluem-se no cálculo da verba advocatícia as parcelas relativas aos juros compensatórios e moratórios, devidamente corrigidas (Súmula n. 131/STJ)
- 4) A intervenção do Ministério Público nas ações de desapropriação de imóvel rural para fins de reforma agrária é obrigatória, porquanto presente o interesse público.
- 5) A ação de desapropriação direta ou indireta, em regra, não pressupõe automática intervenção do Ministério Público, exceto quando envolver, frontal ou reflexamente, proteção ao meio ambiente, interesse urbanístico ou improbidade administrativa.



- 6) A imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação prévia ou de pagamento integral, exigindo apenas o depósito judicial nos termos do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941.
- 7) Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal.(Súmula n. 408/STJ)
- 8) Na desapropriação para instituir servidão administrativa são devidos os juros compensatórios pela limitação de uso da propriedade. (Súmula n. 56/STJ)
- 9) A eventual improdutividade do imóvel não afasta o direito aos juros compensatórios, pois eles restituem não só o que o expropriado deixou de ganhar com a perda antecipada, mas também a expectativa de renda, considerando a possibilidade de o imóvel ser aproveitado a qualquer momento de forma racional e adequada, ou até ser vendido com o recebimento do seu valor à vista.(Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 280)
- 10) Na desapropriação direta, os juros compensatórios são devidos desde a antecipada imissão na posse e, na desapropriação indireta, a partir da efetiva ocupação do imóvel, calculados, nos dois casos, sobre o valor da indenização corrigido monetariamente.
- 11) Na desapropriação, a base de cálculo dos juros compensatórios é a diferença entre os 80% do preço ofertado e o valor do bem definido judicialmente.
- 12) Nas hipóteses em que o valor da indenização fixada judicialmente for igual ou inferior ao valor ofertado inicialmente, a base de cálculo para os juros compensatórios e moratórios deve ser os 20% (vinte por cento) que ficaram indisponíveis para o expropriado.
- 13) O termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito.
- 14) Nas ações de desapropriação não há cumulação de juros moratórios e juros compensatórios, eis que se trata de encargos que incidem em períodos diferentes: os juros compensatórios têm incidência até a data da expedição do precatório original, enquanto que os moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional.(Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Temas 210 e 211)
- 15) O valor da indenização por desapropriação deve ser contemporâneo à data da avaliação do perito judicial.
- 16) Em se tratando de desapropriação, a prova pericial para a fixação do justo preço somente é dispensável quando há expressa concordância do expropriado com o valor da oferta inicial.
- 17) Em ação de desapropriação, é possível ao juiz determinar a realização de perícia avaliatória, ainda que os réus tenham concordado com o valor oferecido pelo Estado.
- 18) A revelia do desapropriado não implica aceitação tácita da oferta, não autorizando a dispensa da avaliação, conforme Súmula n. 118 do extinto Tribunal Federal de Recursos.
- 19) Se, em procedimento de desapropriação por interesse social, constatar-se que a área medida do bem é maior do que a escriturada no Registro de Imóveis, o expropriado receberá indenização correspondente à área registrada, ficando a diferença depositada em Juízo até que, posteriormente, se complemente o registro ou se defina a titularidade para o pagamento a quem de direito.
- 20) Na desapropriação é devida a indenização correspondente aos danos relativos ao fundo de comércio.
- 21) A imissão provisória na posse não deve ser condicionada ao depósito prévio do valor relativo ao fundo de comércio eventualmente devido.
- 22) A invasão do imóvel é causa de suspensão do processo expropriatório para fins de reforma agrária (Súmula n. 354/STJ).
- 23) Não incide imposto de renda sobre as verbas decorrentes de desapropriação (indenização, juros moratórios e juros compensatórios), seja por necessidade ou utilidade pública, seja por interesse social, por não constituir ganho ou acréscimo patrimonial.
- 24) O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente.

25) O pedido de desistência na ação expropriatória afasta a limitação dos honorários estabelecida no art. 27, § 1º, do Decreto nº 3.365/41.

26) São aplicáveis às desapropriações indiretas os limites percentuais de honorários advocatícios constantes do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

27) O prazo para resgate dos TDAs complementares expedidos para o pagamento de diferença apurada entre o preço do imóvel fixado na sentença e o valor ofertado na inicial pelo expropriante tem como termo a quo a data da imissão provisória na posse, de acordo com o prazo máximo de vinte anos para pagamento da indenização estabelecido pelo art. 184 da CF/88.

28) O promitente comprador tem legitimidade ativa para propor ação cujo objetivo é o recebimento de verba indenizatória decorrente de ação desapropriatória, ainda que a transferência de sua titularidade não tenha sido efetuada perante o registro geral de imóveis.

29) O possuidor titular do imóvel desapropriado tem direito ao levantamento da indenização pela perda do seu direito possessório.

30) Nas desapropriações realizadas por concessionária de serviço público, não sujeita a regime de precatório, a regra contida no art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/41 é inaplicável, devendo os juros moratórios incidir a partir do trânsito em julgado da sentença.

31) A ação de desapropriação indireta prescreve em 20 anos, nos termos da Súmula 119 do STJ e na vigência do Código Civil de 1916, e em 10 anos sob a égide do Código Civil de 2002, observando-se a regra de transição disposta no art. 2.028 do CC/2002.

9. JURISPRUDÊNCIA

9.1. SÚMULAS DO STF

Súmula 652: Não contraria a Constituição o art. 15, § 1º, do DL 3.365/41

Súmula 164: No processo de desapropriação, são devidos juros compensatórios desde a antecipada imissão de posse, ordenada pelo juiz, por motivo de urgência.

Súmula 378: Na indenização por desapropriação incluem-se honorários do advogado do expropriado

Súmula 617: A base de cálculo dos honorários de advogado em desapropriação é a diferença entre a oferta e a indenização, corrigidas ambas monetariamente.

Súmula 561: Em desapropriação, é devida a correção monetária até a data do efetivo pagamento da indenização, devendo proceder-se à atualização do cálculo, ainda que por mais de uma vez.

Súmula 476: Desapropriadas as ações de uma sociedade, o poder desapropriante, imitido na posse, pode exercer, desde logo, todos os direitos inerentes aos respectivos títulos.

Súmula 416: Pela demora no pagamento do preço da desapropriação não cabe indenização complementar além dos juros.

Súmula 23: Verificados os pressupostos legais para o licenciamento da obra, não o impede a declaração de utilidade pública para desapropriação do imóvel, mas o valor da obra não se incluirá na indenização, quando a desapropriação for efetivada.



9.2. SÚMULAS DO STJ

Súmula 354: A invasão do imóvel é causa de suspensão do processo expropriatório para fins de reforma agrária.

Súmula 141: Os honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a indenização e a oferta, corrigidas monetariamente.

Súmula 131: Nas ações de desapropriação incluem-se no cálculo da verba advocatícia as parcelas relativas aos juros compensatórios e moratórios, devidamente corrigidas. • Válida.

Súmula 113: Os juros compensatórios, na desapropriação direta, incidem a partir da imissão na posse, calculados sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente

Súmula 114: Os juros compensatórios, na desapropriação indireta, incidem a partir da ocupação, calculados sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente

Súmula 102: A incidência dos juros moratórios sobre os compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei.

Súmula 69: Na desapropriação direta, os juros compensatórios são devidos desde a antecipada imissão na posse e, na desapropriação indireta, a partir da efetiva ocupação do imóvel.

Súmula 67: Na desapropriação, cabe a atualização monetária, ainda que por mais de uma vez, independente do decurso de prazo superior a um ano entre o cálculo e o efetivo pagamento da indenização.

Súmula 56: Na desapropriação para instituir servidão administrativa são devidos os juros compensatórios pela limitação de uso da propriedade.

9.3. INFORMATIVOS DO STF¹¹⁷

O DL 3.365/41 dispõe sobre desapropriações por utilidade pública. Veja o que diz o art. 15-A, que foi incluído pela MP 2.183-56/2001: “Art. 15-A No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos. § 1º Os juros compensatórios destinam-se, apenas, a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário. § 2º Não serão devidos juros compensatórios quando o imóvel possuir graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero. § 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se também às ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem assim às ações que visem a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público, em especial aqueles destinados à proteção ambiental, incidindo os

¹¹⁷CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:<<https://www.Buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia>>.



juros sobre o valor fixado na sentença. § 4º Nas ações referidas no § 3º, não será o Poder Público onerado por juros compensatórios relativos a período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação.” O STF analisou a constitucionalidade do art. 15-A do DL 3.365/41 e chegou às seguintes conclusões: 1) em relação ao “caput” do art. 15-A do DL 3.365/41: 1. A) reconheceu a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios no patamar fixo de 6% ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem; 1. B) declarou a inconstitucionalidade do vocábulo “até”; 1. C) deu interpretação conforme a Constituição ao “caput” do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado na sentença; 2) declarou a constitucionalidade do § 1º do art. 15-A, que condiciona o pagamento dos juros compensatórios à comprovação da “perda da renda comprovadamente sofrida pelo proprietário”; 3) declarou a constitucionalidade do § 2º do art. 15-A, afastando o pagamento de juros compensatórios quando o imóvel possuir graus de utilização da terra e de eficiência iguais a zero; 4) declarou a constitucionalidade do § 3º do art. 15-A, estendendo as regras e restrições de pagamento dos juros compensatórios à desapropriação indireta. 5) declarou a inconstitucionalidade do § 4º do art. 15-A; 6) declarou a constitucionalidade da estipulação de parâmetros mínimo (0,5%) e máximo (5%) para a concessão de honorários advocatícios e a inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R\$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” prevista no § 1º do art. 27. STF. Plenário. ADI 2332/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 17/5/2018 (Info 902).

O princípio da hierarquia verticalizada, previsto no Decreto-Lei 3.365/1941, não se aplica ao tombamento, disciplinado no Decreto-Lei 25/1937. A lei de tombamento apenas indica ser aplicável a bens pertencentes a pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito privado e de direito público interno. Ademais, o tombamento feito por ato legislativo possui caráter provisório, ficando o tombamento permanente, este sim, restrito a ato do Executivo. Por fim, o tombamento provisório por ato legislativo não precisa ser precedido de notificação prévia da União, exigência restrita ao procedimento definitivo promovido pelo Executivo estadual. STF. Plenário. ACO 1208 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 24/11/2017

9.4. INFORMATIVOS DO STJ¹¹⁸

O prazo prescricional para a ação indenizatória por desapropriação indireta é de 10 anos, em regra, salvo comprovação da inexistência de obras ou serviços públicos no local, caso em que o prazo passa a ser de 15 anos. Informativo n. 658. EREsp 1.575.846-SC, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, por maioria, julgado em 26/06/2019, DJe 30/09/2019.

Existe o poder-dever do Município de regularizar loteamentos clandestinos ou irregulares restrito às obras essenciais a serem implantadas em conformidade com a legislação urbanística local, sem prejuízo do também poder-dever da Administração de cobrar dos responsáveis os custos em que incorrer a sua atuação saneadora. Informativo

¹¹⁸CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:<<https://www.Buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia>>.



n. 651. REsp 1.164.893-SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 23/11/2016, DJe 01/07/2019

As restrições ao direito de propriedade, impostas por normas ambientais, ainda que esvaziem o conteúdo econômico, não configuram desapropriação indireta. A desapropriação indireta só ocorre quando existe o efetivo apossamento da propriedade pelo Poder Público. Logo, as restrições ao direito de propriedade impostas por normas ambientais configuram limitações administrativas. STJ. 1ª Turma. AgInt no AREsp 1443672/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 11/02/2020. O prazo prescricional para exercer a pretensão de ser indenizado por limitações administrativas é de 5 anos, nos termos do art. 10 do Decreto-Lei 3.365/1941, disposição de regência específica da matéria. STJ. 2ª Turma. EDcl no REsp 1784226/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 06/06/2019.

Imóvel do particular foi incluído em unidade de conservação. Houve, no caso, uma limitação administrativa. Ele ajuizou ação de desapropriação indireta pedindo indenização. Mesmo não tendo havido desapropriação indireta, mas sim mera limitação administrativa, o juiz deverá conhecer da ação e julgar seu mérito. Devem ser observados os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da solução integral do mérito. STJ. 1ª Turma. REsp 1653169-RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 19/11/2019 (Info 662).

Não se imputa ao Poder Público a responsabilidade integral por alegada desapropriação indireta quando, em gleba cuja ocupação por terceiros apresenta situação consolidada e irreversível, limita-se a realizar serviços públicos de infraestrutura, sem que tenha concorrido para o esbulho ocasionado exclusivamente por particulares. Assim, na medida em que o Poder Público não pratica o ato ilícito denominado “apossamento administrativo” nem, portanto, toma a propriedade do bem para si, não deve responder pela perda da propriedade em desfavor do particular, ainda que realize obras e serviços públicos essenciais para a comunidade instalada no local. STJ. 2ª Turma. REsp 1770001-AM, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 05/11/2019 (Info 660).

A qualificação de imóvel como estação ecológica limita o direito de propriedade, o que afasta a incidência do IPTU. A inclusão do imóvel do particular em Estação Ecológica representa uma evidente limitação administrativa imposta pelo Estado, ocasionando o esvaziamento completo dos atributos inerentes à propriedade, retirando-lhe o domínio útil do imóvel. Além disso, o art. 49 da Lei nº 9.985/2000 estabelece que a área de uma unidade de conservação de proteção integral é considerada zona rural para efeitos legais, motivo pelo qual não incide IPTU, mas sim ITR, sendo este último tributo de competência tributária exclusiva da União. STJ. 2ª Turma. REsp 1695340-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 17/09/2019 (Info 657).

Qual é o prazo da ação de desapropriação indireta? Regra: 10 anos (art. 1.238, parágrafo único, do CC/2002). Exceção: o prazo será de 15 anos se ficar comprovada a inexistência de obras ou serviços públicos no local. Em regra, portanto, o prazo prescricional das ações indenizatórias por desapropriação indireta é de 10 anos porque existe uma presunção relativa de que o Poder Público realizou obras ou serviços públicos no local. Admite-se, excepcionalmente, o prazo prescricional de 15 anos, caso a parte interessada comprove, concreta e devidamente, que não foram feitas obras ou serviços no local, afastando a presunção legal. STJ. 1ª Seção. EREsp 1575846-SC, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 26/06/2019 (Info 658).



Nas ações de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária descabe a restituição, pelo expropriado sucumbente, de honorários periciais aos assistentes técnicos do INCRA e do MPF. STJ. 1ª Turma. REsp 1306051-MA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 08/05/2018 (Info 626).

QUESTÕES

1. (TJMS) FCC, 2020. A propósito do procedimento da desapropriação, a redação vigente do Decreto-lei nº 3.365/1941 estatui que

A a desapropriação deverá se efetivar mediante acordo ou judicialmente, dentro de 5 (cinco) anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e, decorrido tal prazo, este caducará.

B notificado administrativamente o expropriado, ele terá o prazo de 15 (quinze) dias para aceitar ou rejeitar a oferta de indenização, sendo que o silêncio será considerado aceitação.

C a alegação de urgência deve constar obrigatoriamente do decreto de utilidade pública e obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias a contar de sua publicação.

D uma vez notificado pelo expropriante, o particular que não concordar com a indenização oferecida poderá optar por resolver a questão por mediação ou arbitragem.

E a ação, quando a União for autora, será proposta no Distrito Federal ou no foro da Capital do Estado onde for domiciliado o réu, perante o juízo privativo, se houver; se for o Estado o autor, será proposta no foro da Capital respectiva; sendo outro o autor, no foro da situação dos bens.

2. (TJPA) CESPE, 2019. Assinale a opção que indica a denominação dada ao direito do expropriado de exigir de volta o imóvel objeto de desapropriação na hipótese de o poder público não dar o destino adequado ao bem desapropriado.

A desapropriação indireta

B enfiteuse

C redestinação

D retrocessão

E servidão administrativa

3. (MPE-MG) FUNDEP, 2019. Assinale a alternativa incorreta:

A É possível afirmar que os bens culturais inventariados estão submetidos a especial regime protetivo, a fim de evitar o seu perecimento ou degradação, promover sua preservação e segurança e divulgar a respectiva existência.

B Em razão da natureza fundamental, difusa, indisponível e intergeracional do patrimônio cultural, a determinação pelo Poder Judiciário de medidas tendentes a fazer com que o Legislativo e o Executivo cumpram a missão constitucional de promover a adequada tutela dos bens de valor cultural não implica violação à separação de Poderes.

C O tombamento é um ato administrativo de caráter constitutivo, através do qual um bem de valor cultural ou natural passa a ser digno de preservação após sua inscrição no Livro Tombo.

D É dispensável o prévio tombamento de um bem para viabilizar o acesso à jurisdição em sua defesa.

4. (MPE-SP) MPE-SP, 2019. Assinale a alternativa INCORRETA.

A Por se tratar de direito público de natureza real sobre um imóvel particular, para que este sirva ao uso geral como uma extensão ou dependência do domínio público, afetando, assim, o caráter de exclusividade da propriedade, o tombamento sempre será indenizável.



B Ao instituto do tombamento, porque possui disciplina própria, não se aplica o princípio da hierarquia verticalizada prevista no Decreto-Lei no 3.365/41, que excepciona os bens da União do rol dos que podem ser desapropriados.

C O ato de tombamento, seja ele provisório ou definitivo, tem por finalidade preservar o bem identificado como de valor cultural, contrapondo-se aos interesses da propriedade privada, não só limitando o exercício dos direitos inerentes ao bem, mas também obrigando o proprietário às medidas necessárias à sua conservação.

D Na hipótese de restrições administrativas, será devida a indenização a fim de garantir aplicação à teoria da distribuição equânime dos encargos públicos, caso a limitação impeça de se dar ao bem a destinação que se considerava natural, reconhecendo-se o dano especial e anormal, no direito de propriedade.

E É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos, assim como impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural.

5. (MPE-PI) CESPE, 2019. Na hipótese de rescisão unilateral de contrato administrativo, a administração pública poderá promover a apropriação provisória dos bens e do serviço vinculado ao objeto do contrato para evitar a interrupção de sua execução. Essa medida representa uma cláusula exorbitante que se materializa em intervenção do Estado na propriedade privada na modalidade denominada

A limitação administrativa.

B requisição administrativa.

C ocupação temporária.

D servidão administrativa.

E retrocessão.

COMENTÁRIOS

1. Gabarito - D

A) Incorreta. Art. 10 do Decreto-lei nº 3.365/1941

B) Incorreta. Art. 10-A, §1º, IV, do Decreto-lei nº 3.365/1941

C) Incorreta. Art. 15, § 2º, do Decreto-lei 3.365/1941

D) Correta. Art. 10-B do Decreto-lei nº 3.365/1941

E) Incorreta. Art. 11 do Decreto-lei nº 3.365/1941

2. Gabarito – D

A) Incorreta. Desapropriação indireta é o fato administrativo pelo qual o Estado se apropria de bem particular, sem observância dos requisitos da declaração e da indenização previa.

B) Incorreta. A enfiteuse foi abolida pelo atual Código Civil. Era o desmembramento da propriedade, em que o proprietário (denominado senhorio direto) conferia a alguém (o enfiteuta ou foreiro) o direito real consistente no domínio útil do imóvel, mediante o pagamento de uma importância anual denominada de foro, cânon ou pensão

C) Incorreta. Na tredestinação ocorre quando o ente público dá ao bem desapropriado uma destinação diferente daquela que motivou o ato de desapropriar.

D) Correta. Cf. art. 519 CC.

E) Incorreta. A servidão administrativa é o direito real de gozo, de natureza pública, instituído sobre imóvel de propriedade alheia, com base em lei, por entidade pública ou por seus delegados, em face de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública.

3. Gabarito – C



@cpiuris



www.cpiuris.com.br



contato@cpiuris.com.br



- A) Incorreta. Art. 39, §2º Lei 11.904/09.
- B) Incorreta. CRFB
- C) Correta.
- D) Incorreta. art. 216, §1º CRFB.
- E) Incorreta. art. 216, §1º CRFB.

4. Gabarito – A

- A) Incorreta.
- B) Correta. Art. 5º, do Decreto-Lei 25/1937.
- C) Correta. REsp 753.534/2011.
- D) Correta.
- E) Correta. Art. 23III e IV CRFB.

5. Gabarito – C

- A) Incorreta. As limitações administrativas derivam do poder de polícia da Administração e são exteriorizadas em imposições unilaterais e imperativas.
- B) Incorreta. Art.5º, XXV, da CF/88
- C) Correta.
- D) Incorreta. Servidão administrativa: é o direito real público que autoriza o Poder Público a usar da propriedade imóvel para permitir a execução de obras e serviços de interesse coletivo
- E) Incorreta. Retrocessão é a reversão do procedimento expropriatório devolvendo-se o bem ao antigo dono, pelo preço atual, se não lhe for atribuída uma destinação pública.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALEXANDRE, Ricardo; DE DEUS, João de Deus. **Direito Administrativo Esquematizado** 3ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017.
- ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. **Direito Administrativo descomplicado**. 25ª ed., São Paulo: Método, 2017.
- ALEX, Robert. *Teoria de los Derechos Fundamentales*. Madri: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001.
- ARAGÃO, Alexandre Santos de. **Agências Reguladoras e a Evolução do Direito Administrativo Econômico**. São Paulo: Gen Forense, 2013.
- ÁVILA, Humberto. Repensando o “Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Particular.” In: **Revista Trimestral de Direito Público**, nº 24. São Paulo: Malheiros, 1998.
- BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Atos administrativos: elementos poder discricionário e o princípio da legalidade, limites da convalidação, forma de exercício. *Boletim de Direito Administrativo*, São Paulo, v. 13, n. 7, jul. 1997.
- BARROSO, Luís Roberto. Regime jurídico das empresas estatais. **Revista de direito administrativo**, v. 242, p. 87.
- BINENBOJM, Gustavo. *Poder de Polícia, Ordenação, Regulação: transformações político-jurídicas, econômicas e institucionais do Direito Administrativo Ordenador* 2ª ed. Rio de Janeiro: Fórum, 2017.
- _____. Uma Teoria do Direito Administrativo: Direitos fundamentais, democracia e constitucionalismo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.
- BORBA, José Edwaldo Tavares. *Sociedade de economia mista e privatização*. Rio de Janeiro, Lúmen Júris, 1997.
- CANOTILHO, JJ Gomes. *Direito Constitucional e Teoria da Constituição* 7ª ed. Coimbra: Almedina, 2003.
- CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de direito administrativo** 32ª ed. São Paulo: Atlas, 2008.
- CARVALHO, Raquel Melo Urbano de. **Curso de direito administrativo**. Salvador: Juspodivm, 2008.
- CUNHA Jr, Dirley. **Curso de Direito Administrativo** 13ª ed. Salvador: Juspodivm, 2019.
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo** 33ª ed. São Paulo: Gen Forense, 2020.
- FREITAS, Juarez. O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010.
- JUSTEN FILHO, Marçal. *Comentários à lei de licitações e contratos administrativos*. 18ª Edição. São Paulo: RT, 2019.
- MARINELA, Fernanda. *Direito Administrativo*. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.
- MAZZA, Alexandre. **Manual de Direito Administrativo** 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012.
- MEDAUAR, Odete. *Direito Administrativo Moderno* 21ª ed. São Paulo: Fórum, 2018.
- MEIRELLES, Hely Lopes Meirelles. **Direito Administrativo Brasileiro** 43a. edição. São Paulo: Malheiros, 2018.
- MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Curso de Direito Administrativo** 33ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019.
- MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. *Tratado de direito privado tomo III*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.
- MONTESQUIEU. **O Espírito das Leis** 9ª ed. São Paulo: Martin Claret, 2010.
- MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. R. de Dir. Administrativo & Constitucional, ano 11, n. 45, jul./set. 2011. Belo Horizonte: Forum, 2011.
- _____, Diogo de Figueiredo. **Curso de direito administrativo: parte introdutória, parte geral e parte especial**. 15. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009.
- MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. **Curso de direito administrativo: parte introdutória, parte geral e parte especial**. 15. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009.
- OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público: termo de parceria e licitação. In **Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado**. Salvador: Instituto de Direito Público da Bahia, n.º 2, junho/julho/agosto de 2005.



OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende de Oliveira. **Precedentes no Direito Administrativo**. Forense. Rio de Janeiro, 2018.

_____. **Curso de Direito Administrativo** 8ª ed.. São Paulo: Gen Método, 2020.

OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. **Curso de direito administrativo** São Paulo: Gen Método, 2019.

OTERO, Paulo. **Legalidade e Administração Pública**: o sentido da vinculação administrativa à juridicidade. Coimbra: Almedina, 2011.

SARMENTO, Daniel (org.) **Interesses Públicos versus Interesses Privados**: Desconstruindo o Princípio da Supremacia do Interesse Público. 3ª tiragem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

SILVA, Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável in **Revista dos Tribunais nº 798**. São Paulo: RT, 2002, p. 23-50

TORRES, Ronny Charles Lopes de, BARCELOS, Dawison. **Licitações e Contratos nas Empresas Estatais**. Salvador: Juspodivm, 2018.

TORRES, Ronny Charles Lopes de. **Terceiro Setor**: entre a liberdade e o controle. Salvador: Juspodivm, 2013.

TORRES, Ronny Charles Lopes e BALTAR NETO, Fernando Ferreira. **Sinopse para Concursos vol. 09 – Direito Administrativo** 10ª. Salvador: Juspodivm, 2020.